

법의 개념

제3판

H. L. A. HART

2025 SUMMER 강의용 한국어판

강좌 외의 사용을 불허함

THE CONCEPT OF LAW

Third Edition

H. L. A. Hart

1961년 제1판의 하트의 머리말(PREFACE)

이 책의 목적은 법(law), 강제(coercion), 도덕(morality)을 서로 다른 동시에 관련 있는 사회적 현상으로서 이해하는 데 기여하는 것이다. 이 책은 주로 법철학(jurisprudence)을 공부하는 학생을 위한 것이지만, 법보다는 도덕철학(moral philosophy)이나 정치철학(political philosophy), 또는 사회학(sociology)에 주된 관심을 둔 이들에게도 유익하기를 바란다. 법률가들은 이 책을 분석법학(analytical jurisprudence)에 대한 하나의 에세이로 여길 것이다. 왜냐하면 이 책은 법에 대한 비판이나 법정책(legal policy)에 대한 비판보다는, 법적 사고의 일반적 틀을 명확히 하는 데 관심을 두고 있기 때문이다. 더구나 나는 여러 지점에서 단어의 의미에 관한 질문을 제기해 왔다. 예를 들어 ‘~할 수밖에 없는 상태(being obliged)’와 ‘의무(obligation)를 지닌 상태’는 어떻게 다른가, 어떤 규칙이 유효한 법규칙(valid rule of law)이라는 진술은 공직자의 행동을 예측하는 진술과 어떻게 다른가, 한 사회집단이 규칙을 준수한다는 주장에서는 무엇이 의미되는가, 그리고 그 주장은 구성원들이 습관적으로 어떤 행위를 한다는 주장과 어떻게 유사하며 또 어떻게 다른가 등을 고찰하였다. 사실 이 책의 중심 주제 가운데 하나는, 법뿐 아니라 모든 형태의 사회구조도 ‘내적 진술(internal statement)’과 ‘외적 진술(external statement)’이라는 두 가지 서로 다른 종류의 진술 사이의 중요한 구별을 이해하지 않고는 올바르게 이해될 수 없다는 것이다. 이 두 가지 진술은 사회적 규칙이 준수될 때 언제나 모두 가능하다.

이 책은 분석에 주된 관심을 두고 있음에도 동시에 기술적 사회학(descriptive sociology)에 대한 하나의 에세이로 간주될 수도 있다. 왜냐하면 단어의 의미에 대한 탐구는 단어에 대해서만 조명을 비춘다는 생각은 거짓이기 때문이다. 사회적 상황이나 관계의 유형들 사이에 존재하는, 즉각적으로는 자명하지 않은 많은 중요한 구별은, 관련 표현들의 표준적인 사용방식과 그러한 사용이 의존하는 사회적 맥락(대개 명시되지 않은 채로 남겨진다)을 검토함으로써 가장 잘 드러날 수 있다. 이러한 연구 영역에서는, J. L. 오스틴 교수의 말처럼, “단어에 대한 예민한 감각을 사회현상에 대한 예리한 인식의 수단으로 삼는” 것이 특히 유효하다.

나는 다른 많은 저자들에게, 그리고 그들의 저작에 명백하고도 깊은 빚을 지고 있다. 실제로 이 책의 많은 부분은 오스틴(Austin)의 명법(imperative) 이론을 토대로 구성된 단순한 법체계 모델의 한계점을 다루고 있다. 하지만 본문에서는 다른 저자들에 대한 직접적인 인용이나 주석이 거의 없다. 그 대신 책의 끝부분에 각 장을 읽은 뒤 참고할 수 있도록 광범위한 주석들을 마련해 두었다. 여기서 본문에서 제시된 견해들은 나의 선구자 및 동시대 이론들과 비교되며, 이 책의 논의를 그들의 저작에서 어떻게 더 확장해나갈 수 있을지도 제안하고 있다. 이러한 방식을 택한 것은 부분적으로 이 책의 논의가 하나의 연속적인 흐름을 지니고 있기 때문이며, 타 이론들과의 비교는 그 흐름을 방해할 수 있기 때문이다. 그러나 나는 또한 교육적인 목적을 함께 염두에 두었다: 나는 이러한 배열이, 법이론에 관한 책이란 기본적으로 다른 책들에 무엇이 들어 있는지를 배우기 위한 책이라는 믿음을 약화시키기를 바란다. 이 믿음을 저술하는 사람이 갖고 있다면, 그 학문은 거의 진전을 이루지 못할 것이며, 독자가 그 믿음을 갖고 있다면, 그 학문의 교육적 가치는 극히 제한된 수준에 머물 것이다.

나는 너무나 오랜 시간 동안, 너무나 많은 친구들에게 빚을 졌기 때문에 이제 와서는 나의 의무(obligations)들을 모두 밝히는 것이 어렵다. 하지만 나는 A. M. Honoré 씨에게는 특별한 빚을 고백해야 한다. 그의 상세한 비판은 내 사고의 혼란과 문체의 부적절함을 드러내 주었고, 나는 그것들을 제거하기 위해 노력하였다. 그럼에도 여전히 그가 못마땅해할 부분이 남아 있을까 두렵다. 이 책의 정치철학 부분과 자연법(natural law)에 대한 재해석 가운데 가치 있는 것이 있다면, 그것은 G. A. Paul 씨와의 대화 덕분이다. 또한 그는 교정쇄도 읽어 주었다. 나는 루퍼트 크로스 박사(Dr Rupert Cross)와 P. F. 스트로슨(Mr P. F. Strawson) 씨가 본문을 읽고 보내준 유익한 조언과 비판에도 깊이 감사하고 있다.

H. L. A. 하트 (H. L. A. HART)

1994년 제2판의 Bulloch와 Raz의 편집자 주 (Editors' Note)

(제2판을 위해 쓰여짐)

*The Concept of Law*는 출간된 지 불과 몇 년 만에 영미권을 넘어 전 세계적으로 법철학(jurisprudence)의 이해 방식과 연구 방식을 근본적으로 바꾸어 놓았다. 이 책은 엄청난 영향을 미쳤으며, 법이론의 맥락에서뿐 아니라 정치철학(political philosophy)과 도덕철학(moral philosophy)의 맥락에서도 이 책과 그 이론들에 대해 논의하는 수많은 저작들이 출판되었다.

하트(Hart)는 오랜 시간 동안 *The Concept of Law*에 한 장(chapter)을 추가할 계획을 염두에 두고 있었다. 그는 엄청난 영향력을 지닌 본문의 내용을 손보는 것을 원치 않았으며, 그의 뜻에 따라 본문은 소소한 정정(minor corrections) 외에는 변경 없이 그대로 출판되었다. 그러나 그는 그동안 이 책에 대한 다양한 논의들에 응답하고자 하였다. 그의 견해를 오해한 이들에 대해 자신의 입장을 옹호하고, 근거 없는 비판을 반박하며, 그 못지않게 중요하다고 그가 여겼던 바와 같이 정당한 비판에 대해서는 그 타당성을 인정하고, 그 지점을 보완하기 위해 책의 이론들을 조정하는 방식을 제안하고자 했던 것이다. 새로운 장(처음에는 머리말preface으로 구상되었다가 최종적으로 후서postscript로 계획된)은 하트의 생애가 끝났을 때 아직 미완성이었는데, 이는 그의 철저한 완벽주의(perfectionism) 때문만은 아니었다. 이 작업의 적절성에 대한 지속적인 의구심과, 원래 구상했던 책의 핵심 테제들(theses)의 생명력과 통찰력에 걸맞은 작업을 자신이 과연 해낼 수 있을지에 대한 끊이지 않는 불안감 또한 그 이유였다. 그럼에도 불구하고 그는 많은 중단 속에서도 이 후서 작업을 계속하였고, 사망 당시 두 부분으로 구성될 계획 중 첫 번째 부분은 거의 완성된 상태였다.

제니퍼 하트(Jennifer Hart)가 우리에게 초고들을 검토해 볼 것을 요청하며, 그 가운데 출판할 만한 것이 있는지를 판단해 달라고 했을 때, 우리에게 가장 중요한 생각은 하트 자신이 만족하지 않을 만한 것이 출판되어서는 안 된다는 것이었다. 따라서 우리는 후서의 첫 번째 부분이 대부분 완성된 상태였음을

발견하고 매우 기뻐했다. 두 번째 부분에 해당하는 것은 손으로 쓴 메모들뿐이었고, 그것은 지나치게 단편적이고 미완성된 것이어서 출판할 수 없었다. 반면 첫 번째 부분은 여러 버전이 존재했으며, 그것들은 타이핑되고, 수정되고, 다시 타이핑된 뒤 다시 수정되었다. 가장 최근의 버전조차도 하트 자신이 그것을 최종본으로 여기지는 않았던 것이 분명하다. 연필과 바이로펜(Biro)으로 이루어진 수많은 수정 흔적들이 있었기 때문이다. 더구나 하트는 이전 버전들을 폐기하지 않았고, 어떤 버전이든 손에 닿는 대로 계속 작업을 이어갔다. 이러한 점은 편집 작업을 어렵게 만들었지만, 지난 2년간 이루어진 수정들은 대부분 문체상의 뉘앙스에 대한 것이었으며, 이는 그가 본문 내용 자체에는 대체로 만족하고 있었다는 것을 보여준다.

우리의 과제는 여러 버전들을 비교하고, 한 버전에만 존재하는 텍스트의 일부가 나머지 버전에서 누락된 이유가 그가 의도적으로 삭제했기 때문인지, 아니면 모든 수정을 포함한 완전한 버전을 그가 아직 만들지 못했기 때문인지를 판별하는 것이었다. 이번에 출판된 텍스트는 하트가 폐기하지 않았으며, 이후에도 계속 수정해 나간 버전에 나타나는 모든 수정을 포함하고 있다. 때때로 텍스트 자체가 비논리적이거나 일관되지 않은 경우도 있었는데, 이는 필시 타자 작업을 맡은 사람이 그의 원고를 잘못 읽었기 때문이며, 하트가 그러한 오류를 항상 인지하지 못했기 때문일 것이다. 또 어떤 경우에는 문장을 쓰는 과정에서 자연스럽게 발생한 혼란일 수도 있으며, 이는 마지막 원고 정리 단계에서 다듬어졌을 문장이었으나, 하트가 그 단계까지 다다르지 못했기 때문이기도 하다. 이런 경우 우리는 원래의 텍스트를 복원하거나 하트의 사유를 최소한의 개입으로 되살리는 방식으로 편집하려 했다. 특히 제6절(재량discretion에 관하여)은 특별한 문제를 제기하였다. 우리는 그 첫 단락의 두 가지 버전을 발견했는데, 하나는 그 단락에서 끝나는 버전에 있었고, 다른 하나는 나머지 부분을 포함한 사본에 있었다. 잘려 있는 버전은 그의 최근 수정을 많이 포함한 사본에 있었으며, 하트가 이를 폐기한 적이 없었고, 후서 전반의 논의와도 잘 부합하였기에, 우리는 두 버전을 모두 출판하기로 결정하였고, 이어지지 않는 버전은 미주(endnote)로 실었다.

하트는 주로 참고문헌들로 구성된 주석(notes)을 타이핑하지 않았다. 그는

자필로 주석을 작성하였고, 그 주석의 단서는 가장 이른 시기의 타자본에서 가장 잘 추적할 수 있었다. 이후 그는 간혹 여백에 참고문헌을 덧붙이기도 했지만, 대체로 불완전한 형태였으며, 경우에 따라서는 단지 참고문헌을 추적할 필요가 있다는 표시만 있을 뿐이었다. 티머시 엔디컷(Timothy Endicott)은 모든 주석을 확인하고, 누락된 부분을 추적하여 보완했으며, 하트가 드워킨(Dworkin)을 인용하거나 그를 밀접하게 패러프레이즈(paraphrase)하면서도 출처를 명시하지 않은 경우에 대해 출처를 추가하였다. 엔디컷은 또한 인용이 정확하지 않았던 본문을 수정하였으며, 이러한 작업은 폭넓은 연구와 창의성을 필요로 했다. 그는 또한 본문의 여러 오류들을 앞서 밝힌 편집 방침에 따라 수정할 것을 제안하였고, 우리는 이를 감사히 반영하였다.

우리는 하트가 더 오랜 시간이 주어졌다면 본문을 더욱 다듬고 개선하였을 것이라는 점에 의심의 여지가 없다고 생각한다. 그러나 이번에 출판된 후기(postscript)는 드워킨의 여러 논변에 대한 하트의 신중한 응답을 담고 있다고 우리는 믿는다.

페넬로페 A. 불로흐 (Penelope A. Bulloch) 조셉 라즈 (Joseph Raz)

1994

2012년 제3판의 Leslie Green의 머리말(Preface to the Third Edition)

*The Concept of Law*는 허버트 하트(Herbert Hart)가 옥스퍼드 대학교(University of Oxford)에서 법학도들을 대상으로 진행한 법철학(jurisprudence) 입문 강의에 기반을 두고 있다. 이 책은 1961년 초판이 출간되자마자 영어로 저술된 법철학 분야에서 가장 영향력 있는 저작으로 자리매김하였다. 법학, 철학, 정치이론 분야의 학자들은 오늘날까지도 이 책의 논증을 발전시키고, 토대를 넓히며, 비판하고 있다. 동시에 이 책은 여전히 법철학 입문서로 널리 활용되고 있으며, 원어로든 다양한 번역본으로든 세계 곳곳의 학생들이 읽고 있다.

초판 출간 50주년이 가까워졌을 무렵, 옥스퍼드 대학출판부(Oxford University Press)는 새로운 판을 준비하는 가능성에 관해 나에게 제안을 해왔다. 1994년에 출간된 하트 사후의 제2판(posthumous second edition)은 페넬로페 불로흐(Penelope Bulloch)와 조셉 라즈(Joseph Raz)의 편집으로 이루어졌으며, 하트가 생전에 발표하지 않았던 로널드 드워킨(Ronald Dworkin)에 대한 반론을 바탕으로 한 후기(Postscript)를 포함하고 있었다. 그 판은 하트의 이론들 및 일반적인 법철학 논의에 대한 새로운 논쟁의 물결을 촉발시켰다. 이후 수차례 재쇄가 이루어진 뒤, 본문에 남아 있는 몇 가지 오류를 바로잡고 책의 디자인을 새롭게 구성할 시점이 되었다. 이로 인해 새로운 내용을 일부 포함시킬 수 있는 가능성도 열리게 되었다.

*The Concept of Law*는 변명할 필요 없는 저작이지만, 반세기가 지난 지금 더 이상 소개(introduction)가 필요하지 않다고는 말할 수 없다. 이번에 추가된 서론에서는 이 책의 주요 주제들을 개관하고, 몇 가지 비판적 논점을 간략히 스케치하며, 가장 중요한 것으로서 이 책의 기획 자체에 대한 몇몇 오해들을 미연에 방지하고자 한다. 하트는 본문 곳곳에 참고문헌, 설명, 추가 독서를 제시하는 주석(notes)을 덧붙였다. 이 주석들은 원형 그대로 유지되었다. 그러나 그 주석에서 인용된 많은 문헌들은 이미 시대에 뒤쳐졌고, 이후 수많은 저작들이 그의 논의를 계승하고 있다. 이에 따라 학생 독자들이 주요 논쟁 지점을 따라갈

수 있도록 새로운 주석을 추가하였다. 마지막으로, 과거의 연구들은 초판의 쪽수(pagination)에 따라 인용하고 있으나, 이제 초판 사본은 거의 유통되지 않고 있으며, 그 쪽수에 익숙한 사람들도 점차 줄어들고 있다. 따라서 나는 제2판의 쪽수를 따르기로 결정하였다.

서론(Introduction)은 내가 이전에 발표한 논문 「The Concept of Law Revisited」(*Michigan Law Review*, 1997년, 제94권, 1687쪽)에서 발췌한 자료를 활용하고 있다. 이 프로젝트를 처음 제안하고 여러 중요한 시점마다 귀중한 조언을 아끼지 않았던 옥스퍼드 대학출판부의 알렉스 플래치(Alex Flach)에게 깊이 감사드린다. 내 동료 존 피니스(John Finnis)는 하트의 본문에 대한 오류 수정에 도움을 주었고, 톰 애덤스(Tom Adams)는 주석 작업을 위한 자료 조사에 협력해 주었다. 두 사람 모두에게 따뜻한 감사를 전한다. 그리고 서론을 읽고 논평해 준 드니즈 레옴(Denise Réaume)에게 특히 깊이 감사드린다.

레슬리 그린(Leslie Green)

옥스퍼드, 베일리얼 칼리지(Balliol College)

2012년 트리니티(Trinity 2012)

2012년 제3판의 Leslie Green의 서론

(INTRODUCTION)

1. 하트의 메시지(HART'S MESSAGE)

법(law)은 사회적 구성물(social construction)이다. 그것은 역사적으로 우연히 특정 사회들에 나타난 특징이며, 제도를 통해 운영되는 체계적인 사회적 통제(social control)의 등장을 통해 그 모습을 드러낸다. 어떤 면에서 법은 관습(custom)을 대체하지만, 또 다른 면에서는 관습에 의존한다. 법은 인간의 행위를 지시하고 평가하는 일차적 규칙(primary rules)들과, 이러한 일차적 규칙을 식별하고(identify), 시행하며(enforce), 변경(change)하는 방법에 관한 이차적 사회규칙(secondary social rules)으로 이루어진 하나의 체계다. 이러한 구조는 특정한 맥락에서 유익할 수 있지만, 항상 일정한 대가를 수반한다. 왜냐하면 그것은 부정의(injustice)의 위험과, 그 사회 구성원들을 그들의 삶을 지배하는 가장 중요한 규범들로부터 소외시키는 위험을 동반하기 때문이다. 따라서 법에 대해 우리가 취해야 할 적절한 태도는 경계(caution)이지, 찬양(celebration)이 아니다. 더욱이 법은 때로 자신에게 없는 객관성(objectivity)을 가장하기도 한다. 왜냐하면 판사들이 무엇이라고 말하든 실제로는 그들이 법을 창출하는 강력한 권한을 행사하고 있기 때문이다. 따라서 법과 재판(adjudication)은 정치적이다(political). 그리고 다른 방식으로, 법이론(legal theory) 역시 정치적이다. ‘순수한 법이론(pure theory of law)’이란 존재할 수 없다. 법 자체의 개념들만으로 구성된 법철학(jurisprudence)은 법의 본성을 이해하기에 충분하지 않다. 법철학은 사회이론(social theory)과 철학적 탐구(philosophic inquiry)에서 도움을 받아야 한다. 이런 점에서 법철학은 법률가나 법학 교수들의 고유 영역도 아니며, 심지어 그들에게 자연스러운 활동이라 보기도 어렵다. 법철학은 보다 일반적인 정치이론(political theory)의 일부일 뿐이다. 그 가치는 고객에게 법률 자문을 제공하거나 사안들의 결정에 있는 것이 아니라, 우리 문화와 제도들을 이해하고, 그것들에 대한 도덕적 평가(moral assessment)를 정초하는 데 있다.

이러한 평가는 법의 본성뿐 아니라 도덕성(morality)의 본성에도 민감해야 한다. 도덕성은 복수적이고 상충하는 가치들로 구성되어 있기 때문이다.

이상은 현대 법철학에서 가장 영향력 있는 저작 중 하나인 H. L. A. 하트의 법의 개념(The Concept of Law)의 핵심 사상들이다. 그러나 다른 중요한 책들과 마찬가지로, 하트의 책도 실제로 읽은 것보다는 풍문(rumour)을 통해 알려진 경우가 많다. 그 책의 존재는 알고 있지만 그 내용을 진지하게 읽어보지 않은 이들에게는, 방금 소개한 요약이 낯설게 들릴지도 모른다. 그들이 들은 바에 따르면, 하트는 다음과 같은 생각을 가진 사람처럼 보인다: 법은 폐쇄적인 논리 체계인가? 법은 다른 사회질서가 가진 결함을 치유하는 하나의 사회적 성취인가? 법은 대체로 명확하며, 법원은 도덕적 가치와 무관하게 이를 적용해야 하는가? 법과 도덕은 개념적으로 구분되며, 반드시 분리되어야 하는가? 법철학은 가치로부터 자유롭고, ‘법(law)’과 같은 단어들의 진정한 의미를 탐구함으로써 그 진리를 밝힐 수 있는 학문인가?

이 모든 질문에 대한 간단한 대답은 “아니다.” 하트는 그런 생각을 갖고 있지 않다. 이러한 왜곡된 해석들은 크게 세 가지 원인에서 비롯된다. 첫째는 철학 전반에 걸쳐 자주 등장하는 난점이다. 하트가 다루는 문제들은 복잡하며, 참과 거짓 사이의 간극은 종종 미묘하거나 쉽게 간과될 수 있는 구분에 달려 있다. (예: 법과 도덕이 분리될 수 있다고 주장하는 것과, 법과 도덕이 실제로 분리되어 있다고 주장하는 것은 전혀 다른 이야기다.) 둘째는 역사적 요인이다. 반세기가 지난 지금, 책의 언어와 사례들은 사회적으로도, 철학적으로도 낯설게 느껴질 수 있다. 오늘날 ‘원시적(primitive)’ 사회질서라는 표현을 쓰는 이는 드물고, 어떤 것의 본질에 대한 설명을 그것의 개념에 대한 ‘해명(elucidation)’이라 부르지도 않는다. 셋째는 독자의 기대와 관련된다. 모든 책은 이른바 ‘암묵적 독자(implied reader)’를 전제로 한다. 하트의 책이 전제하는 독자는 우리가 가진 가장 중요한 정치 제도 중 하나인 ‘법’의 본성과, 그것이 도덕 및 강제력(coercive force)과 맺는 관계에 철학적으로 호기심을 가진 사람이다. 그러나 실제 독자는 반드시 그렇지는 않다. 일부 독자들은 법철학에서 실천적 조언을 기대한다. 예컨대 그들은 헌법을 어떻게 해석해야 하는지, 또는 어떤 사람이 판사가 되어야 하는지를 알고 싶어 한다. 그들은 법 이론에 관한 책이

요리 이론에 관한 책이 요리에 대해 해줄 수 있는 역할—즉 다양한 상황에 적용 가능한 일반적인 ‘방법론(how-to)’—을 수행할 것이라 기대하는 것이다.

하트의 책은 충분히 명료하므로 요약이 필요하지는 않지만, 그 주제들을 간략히 탐색해보는 일은 위와 같은 오해들을 방지하는 데 도움이 될 수 있다. 나는 그의 법과 사회규칙(social rules), 강제력(coercion), 도덕성(morality)에 관한 견해를 살펴본 뒤, 몇 가지 방법론적 논점을 간단히 언급할 것이다. 나는 중립적 태도를 취할 생각은 없다. 하트의 법이론은 일부는 옳고, 일부는 잘못되었으며, 여기저기서 약간은 난해하기도 하다. 그러나 다음에 이어지는 내용은 평가(appraisal)가 아니다. 나는 사람들이 흔히 빠지거나 오도되는 지점들을 강조하고, 몇몇 쟁점에 대해 비판적 논평을 덧붙이겠지만, 전체적인 평가는 독자의 몫으로 남겨두겠다.

2. 사회적 구성물로서의 법(LAW AS A SOCIAL CONSTRUCTION)

법(law)과 법체계(legal systems)는 자연(nature)의 산물이 아니라 인위적인 것(artifice)이다. 다시 말해, 그것들은 사회적 구성물(social constructions)이라고 할 수 있다. 그렇다고 해서 이 말이 특별히 중요하거나 주목할 만한 대비를 이룬다고 할 수 있을까? 어떤 이들은 모든 것이 사회적으로 구성된 것이기 때문에, 법도 사회적 구성물이라고 생각한다. 데리다(Derrida)는 “il n'y a pas de hors-texte”(텍스트 바깥은 없다)라는 표현으로 이를 비꼬았다. 만약 이 말이 이해 가능하다 하더라도, 법에 관한 논의에서는 무관한 말이다. 예를 들어, 누군가가 “인종(race)은 사회적 구성물이다”라고 말한 뒤, 그것을 “경찰봉(truncheons)이나 감옥(prisons)처럼 말이죠”라고 설명한다면 어떻게겠는가? 이는 마치 누군가가 신(God)은 존재하지 않는다고 말했는데, 알고 보니 그 사람은 개(dogs)조차 존재하지 않는다고 믿는다는 사실을 알게 되는 것과 같다. 내가 법이 사회적 구성물이라고 말할 때, 그것은 어떤 것들이 그렇지 않은 방식에서 그렇게 구성된 것이라는 뜻이다. 법은 사령(command)이나 규칙(rule)과 같은 제도적 사실(institutional facts)로 구성되어 있으며, 그것들은 인간들이 사고(thinking)

하고 행위(acting)함으로써 만들어낸 것이다.¹ 그러나 법은 사회적으로 구성되지 않은 물리적 우주 속에 존재하며, 또한 법은 사회적으로 구성되지 않은 인간들에 의해, 그리고 인간들을 위해 만들어진 것이다. 어쩌면 이 점은 너무 뻔한 말처럼 들릴 수 있다. 유행에 발맞추려는 듯이 ‘예절의 사회적 구성(social construction of etiquette)’에 대해 말할 수도 있겠지만, 예절(manners)이 관행(conventional)이라는 것은 누구나 알고 있는 일이지 굳이 강조할 필요가 없다.² 예절은 공동의 실천(common practice)에 의존하고, 나름의 역사(history)를 가지며, 지역마다 달라진다. 그렇다면 법도 이와 같다는 것은 자명한 진실 아닌가? 하지만 이 점을 다시 생각하게 만드는 유명한 스토아 학파(Stoic)의 자연법(natural law) 요약문을 보자:

진정한 법은 자연(Nature)과 일치하는 올바른 이성(right reason)이다. 그것은 보편적으로 적용되며, 변하지 않고 영원하다... 로마와 아테네에서 다른 법이 있을 수 없고, 현재와 미래에 서로 다른 법이 존재할 수 없으며, 오직 하나의 영원하고 불변하는 법만이 모든 민족과 모든 시대에 타당할 것이다...³

이 영원하고 보편적인 법은 누군가가 창조한 것도 아니고, 누군가가 바꿀 수 있는 것도 아니라고 말한다. 자연법(natural law)은 의지(will)의 문제가 아니라 이성(reason)의 문제이다. 이러한 전체 주장에 동의하는 법이론가는 드물지만, 그 중 일부에 동의하는 이들은 여전히 많다.⁴ 예컨대 로널드 드워킨(Ronald Dworkin)은 다음과 같이 주장한다. 우리 법은 조약(treaties), 관습(customs), 헌법(constitutions), 성문법(statutes), 사례(cases)에서 발견되는 규범들뿐 아니라, 그 규범들에 대한 최선의 정당화(best justification)를 제공하는

¹See eg. John Searle, *The Construction of Social Reality* (Allen Lane, 1995); and Neil MacCormick, *Institutions of Law: An Essay in Legal Theory* (Oxford University Press, 2007).

²Cf. Ian Hacking, *The Social Construction of What?* (Harvard University Press, 1999).

³Cicero, *De Re Republica* III. xii. 33, tr. C. W. Keyes (Harvard University Press, Loeb Classical Library, 1943) 211.

⁴Perhaps John Finnis comes closest, in his *Natural Law and Natural Rights* (2nd edn., Oxford University Press, 2011).

도덕적 원칙들(moral principles)도 포함한다는 것이다.⁵ 드워킨의 설명에 따르면, 도덕적 원칙들에 의해 정당화되는 대상은 사회적으로 구성된 것이지만, 그 정당화들 자체는 사회적으로 구성된 것이 아니다. 여기서 중요한 점은, 정당화(justification)는 사건(event)이 아니라는 것이다. 정당화를 믿거나(believing), 수용하거나(accepting), 주장(asserting)하는 행위는 사건이다. 하지만 드워킨은 법이 구성되는 것은, 단지 구성된 내용들과 사람들이 그것을 정당화라고 믿었거나, 수용했거나, 주장했기 때문이라고 말하지 않는다. 그는 그 내용들에 실제로 정당화가 되는 도덕적 원칙들이 더해져야 법이 구성된다고 주장한다. 만약 어떤 것이 법이 되기 위한 조건이 그것이 다른 어떤 법적 대상에 대한 최선의 도덕적 정당화(best moral justification)라는 사실이라고 믿는다면, 당신은 키케로(Cicero)와 마찬가지로, ‘올바른 이성(right reason)’의 요청이기 때문에 법의 지위를 갖는 법이 있다고 믿는 셈이다. 우리가 하는 어떤 일도 타당한 정당화(sound justification)를 부당한 것으로 만들 수 없다면, 우리는 바꿀 수 없는 법의 존재를 인정하게 된다. 또한 어떤 도덕 원칙이 어떤 제도를 정당화하는지는 누가 그것을 알고 있거나 믿는지 여부와 무관하다면, 아무도 들어본 적 없는 법—아주 많은 법—이 존재할 수 있게 된다. 도덕적 인식(moral knowledge)의 가능성에 따라, 아예 알 수조차 없는 법이 존재할 수도 있다.

하트(Hart)의 접근은 이러한 입장을 전면적으로 거부한다. 법 안에 존재하는 모든 것은 누군가, 혹은 어떤 집단이 그것을 고의적으로든 우연히든 그곳에 두었기 때문에 존재하는 것이다. 법은 모두 역사를 가지며, 모두 변화 가능하며, 모두 알려져 있거나 알려질 수 있는 것이다. 우리의 법 중 일부는 좋은 정당화(good justification)를 갖고, 일부는 그렇지 않으며, 정당화만으로는 결코 법을 성립시키기에 충분하지 않다. 법을 성립시키기 위해서는 실제 인간의 개입(actual human intervention)이 필요하다. 즉, 사령(command)이 내려지고, 규칙(rule)이 적용되고, 결정(decision)이 내려지고, 관습(custom)이 형성되고, 혹은 정당화(justification)가 승인되거나 주장되어야 한다.

⁵Ronald Dworkin, *Taking Rights Seriously* (Harvard University Press, 1978), chap. 4; Ronald Dworkin, *Law's Empire* (Harvard University Press, 1986), chaps. 2–3.

법철학자들은 인간의 개입(human interventions)으로 설정된 것들을 지칭하기 위해 오래된 용어를 사용하는 경우가 있다. 그들은 그것들을 ‘정립되었다(posited)’고 말한다. 모든 법이 정립된 것이라고 여기는 사람을 법실증주의자(legal positivist)라고 부르며, 사회구성주의자(social constructivist)는 그러한 법실증주의자의 일종이다. 그러나 모든 법실증주의자가 사회구성주의자인 것은 아니다. 한스 켈젠(Hans Kelsen)은 사회구성주의자가 아니었다. 그는 모든 법이 정립된 것이라고 생각했지만, 동시에 모든 법체계에는 정립된 것이 아니라 단지 ‘전제(presupposed)’된 규범(norm)이 적어도 하나는 포함된다고 보았다.⁶ 켈젠에 따르면, 법규범(legal norm)은 그것이 유효(valid)할 때에만 존재한다. 여기서 ‘유효하다(valid)’는 것은 그 규범의 대상자(subjects)가 그것에 따라야 한다(ought to conform)는 것을 의미한다. 그는 흄(Hume)과 칸트(Kant)의 뒤를 이어, ‘존재한다(is)’는 사실만으로는 ‘마땅하다(ought)’는 결론을 도출할 수 없다고 주장했다. 따라서 어떤 사회적 구성물(social construction)도, 혹은 그것들의 총합이라 할지라도, 규범(norm)이 될 수 없다. 규범을 만들어내기 위해서는, 사회 내에서의 근본적인 입법 과정(fundamental law-making processes)이 유효하다는 전제가 필요하다. 원초적 헌법(original constitution)이 진정한 권위를 가져야만 그 아래의 어떤 것도 권위를 가질 수 있다. 따라서 우리는 원초적 헌법 아래에서 만들어진 자료들을 법으로 간주하려면, 그 헌법이 구속력을 갖는다는 것을 전제(presuppose)해야 한다. 이제, 전제(presupposition)라는 것도 정당화(justification)와 마찬가지로 어떤 사건(event)이 아니다. 켈젠은, 법이 무엇을 요구하는지를 알기 위해서는 사람들이 실제로 무엇을 정립(posited)했는지를 알아야 한다는 점은 부정하지 않았다. 하지만 그는, 그들이 만들어낸 산물을 법으로서(as law) 이해하기 위해서는, 사회적이거나 역사적인 것이 아닌 어떤 요소가 더해져야 한다고 주장했다. 이 때문에 켈젠은 법실증주의자임에도 사회구성주의자는 아니다. 그는 우리가 사회적으로 구성된 규범들을 연구하는 방식—사회학적(sociological), 심리학적(psychological), 역사적(historical) 탐구—을 법철학(jurisprudence)에서는 ‘외부 요소(alien elements)’로 간주해야 한다고

⁶Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (Max Knight tr., 2nd edn., University of California Press, 1967) 193–205.

보았다.⁷

하트(Hart)는 켈젠의 이러한 견해 역시 거부한다.⁸ 법의 궁극적 기초는 정당화(justification)도 아니고 전제(presupposition)도 아니다. 그것은 사람들이 특정한 사고(thinking)와 행위(doing)를 함으로써 생겨나는 사회적 구성물(social construction)이다. 법철학(jurisprudence)의 역할은 이 구성물이 무엇인지, 그리고 그것이 일상의 사회적 사실들로부터 어떻게 구축(built up)되는지를 설명하는 것이다. 하트는 자신의 이 설명을 ‘기술적 사회학에 관한 하나의 에세이(an essay in descriptive sociology)’라고 부르기까지 한다(vi).⁹ 이것은 다소 과장된 표현일 수 있다. 이는 분석적 법철학(analytic legal philosophy)의 하나의 시도이지만, 이 시도는 이론적으로 예리한 법사회학(theoretically astute sociology of law)이 유용하게 사용할 수 있는 개념들을 활용한다. 그중 가장 중요한 것이 바로 사회적 규칙(social rule)이라는 개념이다.

(i) 법, 규칙, 관행 (Law, Rules, and Conventions)

하트는 원래 홉스(Hobbes), 벤담(Bentham), 오스틴(Austin)에게서 발견되는 초기의 법실증주의 설명을 거부한 뒤, 규칙(rules)이 법의 가장 중요한 구성요소라고 생각하게 되었다. 이들은 법을 명령(command), 위협(threat), 복종(obedience)으로 구성된 것이라고 보았다. 주권자(sovverign)란 대부분의 사람들의 습관적인 복종(habitual obedience)을 받지만, 자신은 아무에게도 습관적으로 복종하지 않는 개인이나 집단을 말한다. 법이란 주권자의 일반적 명령(general command)이며, 힘(force)의 위협에 의해 뒷받침된다.

1977년, 미셸 푸코(Michel Foucault)는 다음과 같이 말했다. “우리가 필요로 하는 것은 주권의 문제를 중심으로 세워진 정치철학이 아니다... 우리는 왕의 목을 쳐야 한다. 정치이론에서는 그것이 아직 끝나지 않았다.”¹⁰ 그러나 이

⁷Ibid. 1.

⁸See below, 292–3, and Hart’s essays ‘Kelsen Visited’ and ‘Kelsen’s Doctrine of the Unity of Law’ in H. L. A. Hart, *Essays in Jurisprudence and Philosophy* (Oxford University Press, 1983).

⁹Parenthetical page references are all to this volume.

¹⁰Michel Foucault, ‘Truth and Power’ in his *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972–1977* (Colin Gordon ed., Vintage, 1980) 121.

‘왕 살해’(regicide)의 소식은 이미 영국 해협을 건넌지도 모른다. 하트는 이미 오래 전에 그 작업을 끝마쳤기 때문이다. 하트는 『법의 개념』 제3장과 제4장에서 다음을 보여준다. 법은 모두 명령으로 구성되어 있지 않으며, 법체계는 반드시 어떤 개인이나 집단이 주권자의 속성을 가져야만 성립되는 것이 아니다. 법은 그것을 창조한 자들이 사라진 이후에도 계속 존재하며, 위협(threats)은 사람들에게 어떤 행위를 하도록 강제(oblige)할 수는 있지만, 의무(obligation)를 부여할 수는 없다. 결국 주권 이론에서 누락된 핵심은 사회적 규칙(social rule)의 개념이다. 우리가 규칙을 이해하게 되면, 우리는 그것이 주권, 권한(powers), 관할(jurisdiction), 유효성(validity), 권위(authority), 법원(courts), 법률(laws), 법체계(legal systems)—심지어 하트에 따르면 정의(justice)의 한 유형—을 설명하는 열쇠라는 것을 알게 될 것이다. 법(law) 자체는 사회적 규칙들의 결합(union)이다. 즉, 인간의 행위를 지도하기 위해 의무(duty)를 부과하거나 권한(power)을 부여하는 1차 규칙(primary rules)과, 1차 규칙을 식별하고(identification), 변경(alteration), 집행(enforcement)하기 위한 2차 규칙(secondary rules)의 결합이다. 이 2차 규칙들 중에서도, 궁극적인 승인 규칙(rule of recognition)은 특별한 중요성을 갖는다. 승인 규칙은 1차 규칙을 적용하는 역할을 맡은 사람들의 관습적 실천(customary practice)으로, 어떤 행위가 법을 형성하는지를 결정함으로써 법적 유효성(legal validity)의 기준(criteria)을 제공한다. 따라서 법체계의 근본 헌법(fundamental constitution)은 도덕적 정당화(moral justifications)나 논리적 전제(logical presuppositions)에 근거하는 것이 아니라, ‘법원(courts), 공무원(officials), 일반인(private persons)의 복합적 실천(complex practice)’에 의해 생성된 이 관습적 사회규칙(customary social rule)에 기반한다(107쪽). 하트는 영국의 승인 규칙(rule of recognition)이 다음과 같은 것이라고 제안한다. “여왕과 의회가 제정한 것은 곧 법이다(Whatever the Queen in Parliament enacts is law).” 의회의 제정물은, 그것이 도덕적으로 정당하다거나, 어떤 논리적 전제에 의해 정당화되었기 때문에 법인 것이 아니라, 실제로 시행되고 있는 관습적 규칙(customary rule)이 그것들을 법으로 인정하고 있기 때문에 법인 것이다.

그러므로 법은 사회적 규칙(social rules)으로 구성되어 있다. 그렇다면 규칙

(rules) 자체는 어떤가? 그것들 역시 사회적 구성물(social constructions)이며, 하트(Hart)는 그것들이 실천(practice)으로 이루어져 있다고 말한다. (이러한 입장을 흔히 ‘규칙에 대한 실천 이론(practice theory of rules)’이라 부른다.) 관습적 규칙(customary rules)은 ‘외적 측면(external aspect)’을 가지며, 이는 행동의 규칙성(behavioural regularity)으로 나타난다. 즉, 사람들은 공통된 방식으로 행동한다. (규칙의 성격에 따라, 이는 그 규칙의 요구에 부응하거나 또는 타인에게 그것을 적용하는 행위를 포함할 수 있다.) 규칙은 또한 ‘내적 측면(internal aspect)’을 갖는데, 이는 하트가 ‘수용(acceptance)’이라 부른 복합적인 태도를 포함한다. 수용이란, 그 규칙적 행태를 행동을 인도하고 평가하는 기준(standard)으로 삼으려는 의지로서, 특히 일치(conformity)를 칭찬하고 위반(breach)을 비판하며, 그러한 칭찬과 비판이 적절하다고 여기는 태도이다. 수용은 찬성(approval)을 요구하지 않는다. 그것은 사람들이 그 규칙에 대해 어떻게 느끼는가의 문제가 아니라, 그 규칙을 사용할 의사가 있는가의 문제이다. 사람들은 하트가 말하는 의미에서 규칙을 수용할 수 있다. 그 규칙이 좋다고 생각해서 수용할 수도 있고, 다른 사람을 기쁘게 하려고, 혹은 두려움이나 동조심(conformism) 때문에 수용할 수도 있다 (56-7, 115, 257쪽). 밀턴(Milton)의 말을 믿는다면, 사탄(Satan)조차도 그 규칙이 나쁘다고 생각하는 이유로 규칙을 수용할 수 있다. “악이여, 나의 선이 되어라(Evil be thou my good).” 중요한 것은 사람들이 특정 기준(standard)에 수렴(converge)하고, 그것을 행위의 지침으로 삼으며, 그렇게 함으로써 그것을 규범적인 것(normative)으로 대우한다는 점이다.

규칙에 대한 실천 이론(practice theory of rules)은 논쟁적이다. 몇 가지 난점을 살펴보고, 그런 뒤에 하트가 제기된 반론을 어떻게 회피하려 하는지를 살펴보자. 하트는 다음 두 가지를 만족시키는 규칙의 존재 테스트를 원했다. 첫째, 단순한 우연적 또는 습관적 행동 패턴과 진정한 규칙 준수를 구별할 수 있을 것. 둘째, 관습 규칙이 의무(obligatory) 또는 구속력을 가진(binding) 것으로 되는 것이 무엇을 의미하는지 설명할 수 있을 것. 그러나 실천 이론은 이 요구를 충족시키지 못한다.¹¹ 예컨대 규칙이지만 사회적 실천이 아닌 것들이

¹¹See Ronald Dworkin, *Taking Rights Seriously* (rev. edn., Harvard University

있다 (예: 개인의 규칙). 또한 사회적으로 받아들여지고 수용된 실천이지만 규칙은 아닌 것도 있다 (예: 권총강도에게 지갑을 넘겨주는 것이 일반적이고 수용된 실천일 수 있지만, 그것이 규칙인 것은 아니다). 그리고 어떤 규칙을 인용하는 것이, 단지 어떤 정당화가 존재한다고 여긴다는 표시가 아니라, 자기 행위의 정당화로서(as a justification) 제시될 수도 있다. 이는 실천 이론과 맞지 않는다. 더 나아가, 우리가 의무(obligation)라는 개념을 이해하는 데 사회적 규칙(social rule)이라는 개념이 반드시 필요한지도 명확하지 않다. 어떤 사람은 항공 여행에 대해 탄소 상쇄(carbon offsets)를 구매해야 할 의무가 있다고 믿을 수 있지만, 그런 것을 하는 공통의 실천이 존재한다고 가정하지 않을 수 있다.

하트는 이 책의 후기(Postscript)에서 이러한 비판들에 대응하기 위해 자신의 설명을 한정한다. 그는 이제 모든 규칙이 실천 규칙(practice rules)은 아니라고 인정하지만, 관행적 규칙(conventional rules)은 그렇고, 법은 그러한 규칙들에 기반한다고 말한다. 하트는 어떤 규칙이 관행적(conventional)이라고 하려면 “그 집단 구성원 각각이 그 규칙을 수용하는 이유 중에, 집단 전체의 일반적 일치(conformity)가 포함되어 있어야 한다”고 말한다 (255쪽). 예컨대, “우측 통행”의 규칙은 사람들이 대다수가 그렇게 하지 않는다면 따르지 않을 것이므로 관행이다. 반면, “졸릴 때 운전하지 말라”는 규칙은 해당되지 않는다. 왜냐하면 도로에 졸린 운전자가 많을수록 오히려 더욱 깨어 있어야 할 이유가 생기기 때문이다. 하트는 궁극적 승인 규칙(rule of recognition)이 하나의 관행이라고 본다. “영국 판사가 의회의 입법을 법의 원천으로 삼아 다른 원천들보다 우위에 둔다면, (또는 미국 판사가 헌법을 그런 원천으로 삼는다면) 그 이유는 그들의 사법적 동료들 역시 그렇게 해왔으며, 선배들도 그렇게 해왔기 때문이다”(267쪽). 법은 “판사들과 법률가들이 수용한 단지 하나의 관행적 승인 규칙(a mere conventional rule of recognition)”에 기반한다 (267쪽). 그러나 여기서 mere(단지)라는 표현은 삭제해야 할 것이다. 공직자들이 승인 규칙(rule of recognition)이나 다른 근본 규칙들을 따르는 유일한 이유가 다른 사람들도 그렇게 하기 때문이라고 보기는 어렵다. 예컨대 영국에서 의회 제정 법률(parliamentary statutes)

Press, 1978) 48–58; Joseph Raz, *Practical Reason and Norms* (2nd edn., Oxford University Press, 1999) 49–58.

이 최고 법원(supreme source of law)이라는 지위는, 그것이 최고로 간주되는 실천뿐 아니라, 이 실천이 민주적이라거나 우리 문화의 핵심이라는 신념에 의존하고 있을 수 있다. 미국의 경우, 헌법의 최고성은 단지 공동의 실천뿐 아니라, 그것이 정당한 정부형태를 구성한다는 믿음이나, 지혜로운 사람들이 제정한 것이므로 그것에 충실해야 한다는 믿음에 기초할 수 있다. 이러한 신념들이 반드시 올바른 필요는 없으며, 반드시 모든 사람에게 공유될 필요도 없다. 그러나 이러한 신념들은 일반적으로 공동 실천 기반의 이유들과 함께 존재한다. 하트가 말하는 의미에서 승인 규칙이 관행적이라고 하려면, 공직자들이 그것을 적용하는 다른 이유들이 무엇이든 간에, 그러한 공동 실천이 없었다면 그것을 적용하지 않았을 것이라는 조건이 충족되어야 한다.

이러한 수정을 감안하더라도, 또 다른 문제가 남는다.¹² 승인 규칙(rule of recognition)은 의무나 책무를 부과하는 규칙이다: 그것은 법의 원천을 식별할 뿐 아니라, 식별된 법을 판사들과 다른 이들이 적용하도록 지시한다. 실천 이론에 따르면, 사회적 규칙이 의무를 부과하려면 다음 세 가지 조건이 모두 충족되어야 한다(if and only if): (a) 그 규칙이 사회적으로 필요하다고 믿어져야 하며, (b) 강한 사회적 압력(social pressure)에 의해 강화되어야 하고, (c) 그 규칙이 규범-수범자(norm-subject)의 당면한 자기이익(self-interest)과 충돌할 수 있어야 한다(86-8쪽). 이러한 조건들이 이 경우 충족되는가? 이 조건들은 사실적(factual)이므로, 구체적인 사례마다 실제 조사가 필요하다. 일반적으로 보자면, 법원의 입장에서는 법의 기준(test)을 고정시키는 것이 필요하다고 여겨질 가능성이 높고, 이를 벗어난 행동은 강한 압력에 의해 교정될 것이다. (예를 들어, 미국 지방법원이 대법원의 모든 판결을 무시하고 샤리아법(Sharia)을 구속력 있는 법의 원천으로 적용한다면, 어떤 반응이 나타날지 상상해 보라.) 그러나 관행 규칙의 경우, 조건 (c)가 왜 충족되는지 확인하는 것은 더 어렵다. 특정한 관행 기준이 중요하다고 믿어질수록, 그것을 어길 유인은 오히려 줄어든다. 우리는 모두 좌측 통행이든 우측 통행이든 선택할 수 있지만, 공통된 실천이 존재하는

¹²For other doubts about Hart's argument on this point see Leslie Green, 'Positivism and Conventionalism' (1999) 12 Canadian Journal of Law and Jurisprudence 35; and Julie Dickson, 'Is the Rule of Recognition Really a Conventional Rule?' (2007) 27 Oxford Journal of Legal Studies 373.

상황에서는 그 반대편으로 운전할 유혹은 별로 없다. 일탈의 유혹은 일반적으로 공공재(public goods)에 관한 규칙, 즉 무임승차(free-riding)가 가능한 규칙에서 더 자주 발생한다. 하지만 규칙이 관행적인 경우, 의무와 욕망이 같은 방향으로 작용한다. 이때는 ‘의무 또는 책무와 이익 사이에 항상 존재하는 충돌 가능성(the standing possibility of conflict between obligation or duty and interest)’이 존재하지 않는다(87쪽). 위에서 말한 것처럼, 판사들은 서로 다른 승인 규칙들 사이에 선호(preferences)를 가질 수 있으며, 그 선호는 정당성(legitimacy) 등에 대한 견해를 반영할 수 있다. 그러나 모든 판사들의 기본적인 태도가 ‘균중과 함께 가고자 하는 욕망’이라면, 우리가 일반적으로 ‘의무’라고 부르는 규범적 긴장(normative push and pull)은 드물어질 것이다. 이 점에서 하트는 처음의 설명이 더 진실에 가까웠다: 판사들조차 일탈의 유혹을 받을 수 있지만, 그것은 또한 비판과 강한 복종 압력을 불러일으키는 계기가 된다. 안타깝게도, 이와 같은 비판과 압력은 규칙이 전혀 없는 경우, 단지 보편 적용 가능한 이유(reason of general application)가 존재하는 경우에도 마찬가지로 발생한다. 사회적 규칙(social rule)의 정확한 성격에 대한 논쟁은 여전히 계속되고 있으며, 하트의 일반적인 설명 틀 안에서 수용 가능한 다른 설명들도 있다.¹³ 그러나 단순한 실천 이론도, 하트의 관행주의적 수정안도, 그것들만으로는 충분하지 않다.

(ii) 규칙의 적용 범위(The Reach of Rules)

법 이론에서 규칙 기반 이론(rule-based theory)에 대한 독립적인 회의 근거는 그 범위(scope)에 관련된다. 사회적 규칙(social rules)이 법적 현상(legal phenomena)을 이해하는 데 필수적이라는 점이 입증된다고 하더라도, 그것만으로 충분한가? 그렇지 않다. 그 이유는 여러 가지다.

¹³For example: Joseph Raz, *Practical Reason and Norms*; Frederick F. Schauer, *Playing by the Rules: A Philosophical Examination of Rule-based Decision-making in Law and in Life* (Oxford University Press, 1993); Andrei Marmor, *Social Conventions: From Language to Law* (Princeton University Press, 2009); Scott J. Shapiro, *Legality* (Harvard University Press, 2011). A distinction between rules and standards is drawn in Henry M. Hart and Albert Sacks, *The Legal Process: Basic Problems in the Making and Application of Law* (W. N. Eskridge, Jr. and P. P. Frickey eds., Foundation Press, 1994) 139–41.

첫 번째 이유는 하트(Hart) 자신이 강조한 것이다. 모든 1차 및 2차 규칙(primary and secondary rules)의 체계가 법체계(legal system)인 것은 아니다. 예컨대, 북미 하키 리그(National Hockey League)에는 규칙 체계가 존재한다. 선수, 심판, 커미셔너의 행동을 지시하는 1차 규칙과, 공식 규칙에 대해 인정(recognition), 변경(change), 판정(adjudication)의 기능을 수행하는 2차 규칙들이 있다. 하지만 하키 규칙들은 법체계는 아니다. (물론 그것들이 법체계와 유사하다는 점은 누구도 부정하지 않는다.) 그러면 무엇이 빠져 있는가? 하키 규칙은 특수 목적(special-purpose)의 규칙이다. 하나의 게임만을 규율하는 반면, 법은 삶의 많은 부분을 규율할 수 있다. 그리고 법체계는 하키 규칙을 포함하여 하키 전반을 규율하지만, 하키 규칙은 법을 규율하지 않는다. 하트는 나아가, 법은 단지 포괄적으로 규율할 수 있는 것뿐 아니라, 실제로 재산(property), 계약(agreements), 폭력의 사용(use of force) 등을 포함하여 광범위한 사안들을 규율해야만 비로소 법체계라고 할 수 있다고 주장한다 (193-200쪽). 하트는 이를 법체계의 ‘최소한의 내용(minimum content)’이라 부르며, 이러한 내용을 규율하는 것이 인간 생존(human survival)을 증진시키고, 인간 생존이 (그는 당연하다는 듯) 도덕적으로 선(good)하다고 가정하기 때문에, 모든 법체계는 어떤 형태로든 선(good)을 지향한다고 본다. 따라서 법체계에 대해 ‘형식적(formal)’ 기준을 적용할 수 있는가의 문제는 무의미하다. 이것이 바로 서두에서 언급한 것처럼, 하트의 이론이 법체계를 논리나 수학의 형식 체계(formal system)처럼 간주한다고 생각하는 것이 잘못된 이유 중 하나다. 그리고 이 논점은 더 큰 함의를 갖는다. 어떤 것도 법이 되려면 어떤 법체계에 속해야 하기 때문에, 법 자체에 대해서도 순수하게 형식적인 기준이라는 것은 있을 수 없다. 법은 특정한 유형(kind)의 규범 체계(normative system) 속에서 일정한 역할을 수행하는 규칙(rules)인 것이다. 그리고 이 규범 체계는 부분적으로 그 내용(content)에 의해 구별된다.

두 번째 논점은 하나를 명확하게 해 준다. 어떤 학자들은 하트의 설명이 부정확하거나 불완전하다고 생각한다. 그 이유는 법체계에는 규칙 외의 다른 규범(norms)들이 존재한다는 것이다. 예컨대 ‘기준(standards)’이나 ‘원칙

(principles)'이 그러한 것이라 한다.¹⁴ 위에서 본 것처럼(xviii쪽 참조), 이러한 것이 법률의 도덕적 정당화(moral justifications)를 가리킨다고 본다면, 하트의 관점에서 그것들은 공식적으로 채택(adopted)되거나 승인(endorsed)되지 않는 법의 일부가 아니다. 그러나 '기준'과 '원칙'이라는 용어는 또한 융통성 있거나 반박 가능한(defeasible) 일반적 법 규범을 지칭하기 위해 흔히 사용된다. 이런 의미에서라면, 그것들은 하트의 이론에 쉽게 들어맞는다. 법이 어떤 쟁점에 미치는 영향을 알기 위해서는, 서로 교차하거나 충돌할 수 있는 여러 규칙들의 총합적 효과(net effect)를 이해해야 하며, 그 충돌을 해결할 수 있는 허용 가능한 방법(permissible way)은 하나 이상 존재할 수 있다. 이것이 반박 가능성(defeasibility)의 한 원천이다. 또 다른 원천은 하트가 제7장에서 설명했듯이, 모든 규칙은 일정 정도 모호하며(open-textured), 불명확한 부분이 존재한다는 사실이다. 어떤 경우에는 규칙의 적용이 명확하고, 어떤 경우에는 명백히 적용되지 않지만, 어떤 경우에는 적용 가능성은 있지만 명확하지 않다. 항소심 법원(appellate courts)의 업무 중 많은 부분이 바로 이러한 명확하지 않지만 법적으로는 논리 가능한(arguable) 사건들에 대한 판단을 포함한다. 이러한 의미에서 법의 불확정성(legal indeterminacy)은 규칙의 경계(margins)에서 발생하긴 하지만, 그 자체가 주변적 현상은 아니다. 이는 모든 법체계와 그 안의 모든 규칙의 특징이며, 그 결과로 “법원과 다른 공직자들의 재량(discretion) 영역이 넓고 중요하다”(136쪽)고 할 수 있다. 법원은 법을 권위적으로 적용하는 특별한 임무를 가지지만, 동시에 입법기관과 마찬가지로 새로운 법을 창출하는 임무도 수행한다. 이 법 창출적 기능을 언제, 어떻게 사용할지는 어떤 종류의 규칙도 단순히 적용하는 문제가 아니라 실천적 판단(practical judgement)을 요한다. 불확정성 해결에 있어 법원의 역할을 고려할 때, 오로지 또는 주로 항소심 법원이나 그 어떤 법원의 역할만을 통해 일반적인 법 이론을 구성하려는 것은 오도될 수 있다. '선택 효과(selection effect)'로 인해 법적 불확실성이 과도하게 강조될 위험이 있기 때문이다. 법이라는 개념이 너무 고정적(cut-and-dried)이라고 보고 그것이 실제 법의 유동적이며 논쟁적인 성격을 포착하지 못한다고

¹⁴A distinction between rules and principles is drawn in Ronald Dworkin, *Taking Rights Seriously* 22-8.

생각하는 이들은 이러한 함정에 빠지기 쉽다. 그들은 법원을 구성하는 비교적 확립된 규칙들이나, 사람들이 법원에 가지 않고도 자신의 행동을 결정할 때 사용하는 평범한 법 규칙들을 보지 못한다. 예컨대 도로 표지판의 “정지(Stop)”는 “깜빡이는 것을 멈추라”는 뜻이 아니라 “차를 멈추라”는 의미임을 운전자들은 알고 있다. 이를 위한 사법적 판결은 필요 없다. 이는 실제로 작동하는 법(law in action)의 전형적인 사례다.

세 번째 논점은 다음 사실을 상기시킨다. 즉, 법적 규칙 체계 안의 모든 요소가 어떤 종류의 규칙인 것은 아니라는 점이다. 예컨대 『1998년 영국 인권법(UK Human Rights Act)』 제6조는 다음과 같이 규정한다. “이 조항에서 ‘공공기관(public authority)’이란 다음을 포함한다: (a) 법원 또는 재판소, 그리고 (b) 그 기능 중 일부가 공적 성격(public nature)의 기능인 사람...” 이는 규칙인가? 그것은 정의(definition)이다. 하지만 정의가 언어 사용을 위한 규칙이라고 본다면? 그렇다면 이는 행위를 요구하거나 부여하거나 허용하지 않기 때문에 규범(norm)은 아닌 규칙(rule)일 것이다. 정의의 법적 역할은, 그것이 섹션 1에 나오는 규범(norm)인 규칙과 함께(along with) 어떻게 작동하는지를 보여줌으로써 설명된다. 예컨대 제1조는 이렇게 말한다. “공공기관은 관행 권리(Convention right)와 양립할 수 없는 방식으로 행동하는 것이 불법(unlawful)이다.” 그리고 불법 행위에 대한 구제는 다른 조항에 의해 제공된다. 이는 (함축적으로) 사람들에게 무엇을 하라고 지시하는 것이다. (‘불법’이라는 표현이 이 문맥에서 무엇을 의미하는지를 아는 것이 필요하다.) 이는 규칙이 아닌 규범인 법적 자료들을 다루는 방법이기도 하다. 예컨대 법원 판결은 종종 특정한 명령(order)으로 끝난다. 즉, 누군가에게 무엇을 하라, 지불하라, 또는 어떤 불이익을 감수하라는 지시(directive)다. 이러한 일회적 명령(one-off order)은 규칙이 아니라 개별 규범(individual norm)이다. 개별 규범만으로는 통치(govern)가 사실상 불가능하지만, 그것 없이는 통치는 논리적으로 불가능하다. 법원이 사람들의 법적 지위를 권위 있게 결정하려면, 특정한 사람들에게 구속력을 갖는 판단(ruling)을 내려야 한다. 따라서 규칙은 법과 법체계를 이해하는 데 필수적이지만, 그것만으로는 충분하지 않다. 우리는 규칙이 어떤 내용을 다루는지, 무엇을 하도록 기대되는지, 규칙과 함께 작동하는 다른 자료들이 무엇인지,

그리고 규칙에 의해 지배되지 않는 법적 의사결정이 무엇인지도 알아야 한다. 하트는 이러한 주제들 가운데 일부에 다른 것보다 더 많은 시간을 할애하긴 했지만, 이 모든 주제는 그의 이론 안에 수용 가능하다. 널리 퍼진 오해와 달리, 하트는 법이 단순히 규칙의 문제라고 말한 적이 없다. 또한 규칙이 모든 법적 현상을 설명한다고도 말하지 않았다. 사실 그는 그러한 오류를 경계한다. “기본 및 2차 규칙의 결합은 법의 많은 측면을 설명해 주기 때문에 중심적인 위치를 차지할 자격이 있다. 그러나 이것만으로 모든 문제를 밝힐 수는 없다... [이 결합은] 법체계의 중심에 있긴 하지만, 그것이 전부는 아니다...” (99쪽) 법철학(jurisprudence)은 이 밖의 여러 관심사들을 함께 고려해야 한다.

3. 법과 권한 (LAW AND POWER)

지금까지의 논의는 다음과 같다. 법(law)은 사회적 규칙(social rules)의 산물이며, 이러한 규칙들 역시 실천(practice)으로부터 구성된 것이다. 이는 결국 사회적 통제(social control)의 수단인 제도를 다소 안이하게 이해한 것처럼 들릴 수도 있다. 그렇다면 갈등(conflict), 강제(coercion), 권한(power)은 어떻게 되는가?

(i) 법에서의 분업(The Division of Labour in Law)

하트(Hart)는 법을 주권자(sovverign)의 명령이 위협(threats)을 수반하는 것으로 본 오스틴(Austin)의 상향적 피라미드식 관점(top-down, pyramidal view)에 반대한다. 이러한 관점이 조잡하다는 점은 널리 인정되지만, 일부는 그것이 일종의 경각심을 주었다고 보고, 하트가 법실증주의(legal positivism)를 보다 정교하게 만들었지만 그 강력함을 잃었다고 느낄 수도 있다. 법은 단지 합의(consensus)나 일치(agreement)에 관한 것이 아니라, 갈등(conflict)과 불일치(disagreement)에도 관한 것이다.¹⁵ 물론, 만약 이러한 주장이 항소심 법원(appellate courts)에서의 활동이 고도로 정치화되어 있고, 기존의 법을 적용한다기보다 논쟁 가

¹⁵On other aspects of this theme see Jeremy Waldron, *Law and Disagreement* (Oxford University Press, 1999).

능한 사건을 결정(settle)하는 것이 주된 활동이라는 익숙한 주장이라면, 이를 반대할 이유는 없다. 방금 전 우리는 이것이 하트의 이론과 어떻게 들어맞는지를 살펴보았다. 다만 하트는 최소한 어떤 수준의 합의가 제도가 작동을 시작하려면 필요하다고 본다. 적어도 ‘승인 규칙(rule of recognition)’은 무엇이 법을 구성하는 행위인지에 대한 합의 위에 성립되어야 한다. 하지만 누구의 합의란 말인가? 다음은 드워킨(Dworkin)이 하트의 이론을 재현한 방식이다:

법의 진정한 근거(grounds of law)는 전체 공동체가 하나의 근본적이고 포괄적인 규칙(master rule)을 수용(acceptance)하는 데 있다. (그는 이것을 ‘승인 규칙(rule of recognition)’이라 부른다)… 오스틴에게는 캘리포니아의 제한 속도가 55마일이라는 명제가 참인 이유가 단순히 그 규칙을 제정한 입법자들이 그곳을 지배하고 있기 때문이다. 반면 하트에게 그것이 참인 이유는, 캘리포니아 주민들이 주 및 연방 헌법의 권위 체계(authority scheme)를 수용해 왔고 계속 수용하고 있기 때문이다.¹⁶

이 설명이 ‘법의 근거(grounds)’를 설명하는 방식으로 문제 있다는 점은 분명하다. 캘리포니아의 많은 사람들은 주 및 연방 헌법의 권위 체계가 무엇인지 전혀 알지 못하며, 심지어 ‘주 헌법(state constitution)’이 존재한다는 사실조차 모르는 사람들도 있다. 또한 이 설명은 하트의 이론에 대한 해석으로도 문제가 있다. 하트에 따르면, 법 이전의(pre-legal) 사회에서 사회 규범(social norms)은 광범위한 지지 없이는 존재할 수 없다. “보다 단순한 구조(법이 형성되기 이전)에서는, 공직자들이 존재하지 않기 때문에, 규칙은 집단의 행동에 대한 결정적 기준을 설정하는 것으로서 널리 수용되어야 한다. 그곳에서는 ‘내면적 관점(internal point of view)’이 널리 퍼져 있지 않다면 논리적으로 규칙이 존재할 수 없다”(117쪽). 관습적 규칙(customary rules)은 일반적인 동의(general buy-in)를 필요로 한다. 그러나 “...일차 및 이차 규칙이 결합된 사회에서는... 규칙을 집단의 공통된 기준(common standards)으로 수용하는 것이, 단지 개인이 자발적으로 규칙을 따르는 것과는 분리될 수 있다. 극단적인 경우에는, ‘이것은

¹⁶Ronald Dworkin, Law's Empire 34.

유효한 규칙이다’라는 규범적 언어를 사용하는 내면적 관점이 오로지 공직자 세계에만 제한될 수 있다. 이러한 더 복잡한 체계에서는, 공직자들만이 유효성 기준(criteria of validity)을 수용하고 사용할 수도 있다. 이러한 사회는 한없이 순종적인 양 떼(sheeplike) 같을 수 있고, 결국 도살장으로 끌려갈 수도 있다. 그러나 그것이 존재할 수 없거나 법체제로 인정받을 수 없다고 생각할 근거는 거의 없다”(117쪽).

이 인용문을 길게 제시한 이유는, 그것이 법의 본질(nature of law)을 이해하는 데 핵심적인 점을 제시하며, 동시에 법이 그러한 본질을 지닌다는 사실의 정치적 의미를 보여주기 때문이다. 하트는 관습(custom)과 사회적 도덕성(social morality)은 의도적인 변화에 대해 면역(immunity)을 지니며, 점진적으로만 진화한다고 지적한다. 작은 규모의 안정된 공동체에서는 그것들이 제도를 운영하는 꽤 괜찮은 방식이다. 우리가 일상생활의 많은 부분을 그렇게 운영하는 것이 일반적이다. 그러나 규모가 크고 복잡한 사회는 규범(customs and other norms)을 공적으로 확인할 수 있고 즉시 변경할 수 있는, 보다 의도적인 사회 통제 메커니즘(deliberate mechanisms of social control)을 필요로 한다. 예컨대 통치자의 선언, 다수결 투표 등의 방식으로 말이다.

이러한 메커니즘은 제도화(institutionalization)를 통해 가능해진다. 즉, 규칙을 식별하고 변경하며 집행할 권한을 가진 특화된 기관(specialized organs)의 등장이다. 그 결과 나타나는 규범적 분업(division of normative labour)은 일종의 양면성을 지닌다. 그것은 이득과 비용을 모두 수반한다. “그 이득은 변화에 대한 적응력, 확실성(certainty), 효율성(efficiency) 등이고… 그 비용은, 중앙집중화된 권력이 집단적 지지 없이도 다수에게 억압(oppression)을 가할 수 있는 위험이다. 이는 보다 단순한 일차 규칙 체계에서는 발생할 수 없는 일이다”(202쪽). 따라서 법은 보편적으로 좋은 것도 아니고, 무조건 좋은 것도 아니다. 제도적 성격(institutional character)이 특정한 이득을 가능하게 하지만, 동시에 특정한 비용도 가능하게 한다. 이러한 비용은 법 없는 사회에서는 발생하지 않을 수 있는 것들이다. 하트가 위에서 논한 극단적인 사례까지 가지 않더라도, 법이 작동하는 일반적인 사회에서는 광범위한 사회적 합의보다는 좁은 공직자

집단의 합의에 더 의존한다.¹⁷ 법이 존재하기 위해 일반 대중에게 요구되는 것은, 해당 체계의 강제 규범(mandatory norms)에 대해 수동적으로 따르는 것(acquiescence) 이상은 거의 없다.

그렇다면, 법이 의존하는 합의는 절대 편안하거나 공동체적인 것이 아니다. 그것은 가치에 대한 일치(value agreement)를 전제로 하지 않으며, 법의 작동 속에서의 증대한 반대(dissent)를 배제하지도 않는다. 이것은 왜 “모든 법체계는 필연적으로 그 공동체의 가치를 표현한다”는 낭만적 신념이 잘못된 것인지를 보여준다. 정의롭고 소중한 법체계조차도, 결국에는 난해하고, 기술적이며, 그 지배 대상자들의 삶에서 멀어질 수 있다. 규범적 분업 때문에 법은 항상 ‘법률주의적(legalistic)’이 될 위험에 노출되어 있다. 모든 법철학자들은 법이 도덕적으로 오류 가능(morally fallible)하다는 사실에 동의한다. 하트의 특별한 기여는, 법이 실패하는 몇 가지 방식이 바로 그것이 사회 제도(social institution)라는 본질과 밀접하게 연결되어 있다는 점을 보여준 데 있다.

(ii) 강제와 권한(Coercion and Power)

법은 본질적으로 강제적 장치(coercive apparatus)라는 생각은 일반인의 직관과 잘 맞아떨어지며, 법철학(jurisprudence)에서도 오랫동안 인기를 끌어온 견해이다. 그러나 하트(Hart)는 이 견해가 잘못되었다고 본다. 모든 법체계(legal system)는 강제로 집행되지 않는 규범(norms)을 일부 포함하며, 심지어 전적으로 그러한 규범들로 구성된 법체계조차도 상상 가능하다고 한다(199-200쪽). 그렇다면 제재(sanction)가 없는 법은 무슨 의미가 있는가? 제재가 있는 법과 마찬가지로, 사람들의 행위를 지시(direct)하는 데 그 목적이 있다. 제재는 법의 플랜 B다. 플랜 A는 법의 대상자(subjects)들이 추가적인 감독 없이도 법에 자발적으로 따르도록 하는 것이다. 지시가 필요하지만 강화 동기(reinforcing motivation)는 필요하지 않은 경우에는 제재 없는 법이 그리 드문 것이 아니다.

¹⁷이는 구체적으로 어떤 공직자(official)가 중요한지, 그리고 ‘공직자’의 역할이 어떻게 규정되어야 하는지를 정확히 다루지 않는다. 일반적으로 말해, 하트(Hart)는 적어도 판사(judges)와 입법자(legislators)를 포함할 의도를 지니며, 이때 ‘공직자’는 법적 정의가 아니라 사회정치적(socio-political) 정의를 따른다.

예컨대 미국 연방법전(United States Code)에는 국기에 대한 예우를 지시하는 규범이 포함되어 있다. (“국기는 어떤 것도 받거나, 보관하거나, 운반하거나 전달하는 용기로 사용되어서는 안 된다.”¹⁸) 하지만 이 규범을 위반했을 경우 처벌 조항은 존재하지 않는다. 만약 인간 본성이 지금과 달랐다면, 모든 법 규범이 이와 같을 수도 있었을 것이다.

하지만 인간 본성이 지금과 같음에도 불구하고, 많은 법 규범은 제재로 뒷받침되지 않는다. 중요한 범주의 하나는 권한 부여 규범(power-conferring norms)이다. 즉, 법 규범 중에서 다른 법적 규범이나 지위를 변경할 수 있는 능력을 창출하는 규칙들이다. 예컨대, 입법, 법인 설립, 계약 체결, 혼인 등을 가능하게 하는 규칙들이 그러하다. 이러한 권한이 자발적인 것이라면(일반적으로 그렇다), 사람들은 그것을 행사할지 여부를 자유롭게 선택할 수 있다. 입법하거나, 법인을 설립하거나, 계약하거나, 혼인하려는 사람은 법이 정한 절차를 따르지 않으면 그 행위는 무효(null and void)가 된다. 예컨대, 법적 요건을 갖추지 못한 ‘혼인’은 무효다. 그러나 이를 따르지 않았다는 이유로 처벌을 받지 않는다. 그렇다면 무효 자체가 일종의 처벌이므로, 이 역시 강제적인 법이라고 보아야 할까? 하트는 그렇게 보아서는 안 되는 이유를 설명한다. 여기에는 두 가지 별개의 요소—무언가를 하라는 명령(order)과 그것을 위반했을 때의 제재(sanction)—가 존재하지 않기 때문이다. 아예 명령이 존재하지 않으며, 그 ‘제재’는 실제로는 권한 부여 규범 그 자체일 뿐이다. 켈젠(Kelsen)은 강제 이론(coercion theory)을 유지하기 위한 우회로(work-around)를 제안했다. 그는 권한 부여 규칙은 실제로는 법률의 조각(fragment)에 불과하므로, 그 안에 제재가 없다는 것은 놀라운 일이 아니라고 주장했다. 제재를 담고 있는 규범은, 예컨대 배우자를 부양할 의무와 같은 규범이며, 혼인에 관한 권한 부여 규칙은 누가 배우자인지 여부를 결정하는 것이라고 본다. 이리저리 따져보면 결국 모든 것은 강제로 환원된다(coercion). 하트는 이에 대해 흥미로운 방식으로 응답한다. 그는 켈젠의 재구성이 불가능하다거나 비논리적이라고 말하지 않는다. 다만 그것이 동기를 결여(unmotivated)하고, 법철학의 방법론적 제약(methodological constraint)에 어긋난다고 주장한다.

¹⁸4 U.S.C. § 8 (h).

“법이 사회 통제의 수단으로서 수행하는 주요 기능(principal functions)은 사적 소송(private litigation)이나 형사 기소(prosecutions)에서 나타나지 않는다. 그것들은 제도의 실패에 대비한 필수적이지만 보조적인 장치일 뿐이다. 법의 주요 기능은, 법이 법정 바깥에서 인생을 통제하고, 안내하고, 설계하는 다양한 방식에서 나타난다”(40쪽).

개별 법률(laws)로 법적 자료(legal material)를 나누는 데 있어서 본질주의적(essentialist), 즉 ‘형이상학적(metaphysical)’ 해답은 존재하지 않는다. 가장 좋은 접근 방식은, 법을 실제로 사용하는 사람들(대부분은 법정 밖에서 살아가는 사람들)에게 법이 어떻게 작용하는지를 이해할 수 있게 해주는 방식이다. 권한 부여 규칙은 의무를 부과하는 규칙과는 다르게 인식되고, 언급되고, 사용되며, 전혀 다른 이유로 가치가 부여된다. “그 특성이 다르다는 것을 보여줄 다른 기준이 무엇이 있겠는가?”(41쪽) 이 점은 하트의 방법론(method)의 정수를 보여준다. 홈스(Holmes)의 ‘나쁜 사람(bad man)’에게 법은 피해야 할 비용(costs)에 관한 것이며, 법률가에게 법은 가능한 법정 사건들과 거기에서 얻을 수 있는 수입료(legal costs)에 관한 것이다. 법이론들은 이러한 외눈박이(cyclopic) 관점에서 파생되어 왔다. 그들은 현실이긴 하지만 주변적인 요소(marginal)를 중심적인 것으로 간주하며, 법의 중요성이 드러나는 여러 차원을 납작하고 환원적인(flat and reductive) 그림 속에 지워버린다.

여기까지는 모두 타당한 주장이다. 그러나 만약 우리가 법이 사회 통제의 수단으로서 수행하는 모든 주요 기능을 고려하고자 한다면, 여기서 하트가 제시한 수준 이상으로 나아가야 한다. 권한 부여 규칙을 의무 부과 규칙으로 환원하거나, 무효(nullity)를 일종의 제재로 해석하려는 시도는 오류이지만, 권한 부여 규칙이 사회적 권한(social power)과 밀접하게 얽혀 있다는 점을 주목하는 것은 옳다. 그렇다면 애초에 우리는 왜 강제(coercion)에 관심을 갖는가? 그 하나의 이유는 책임(responsibility)과 관련되어 있다. 위협(threat)에 의해 어떤 일을 하게 된 사람은 일반적으로 그 행위에 대해 책임을 지지 않는다. 그 의지가 억압(overborne)되었기 때문이다. 물론 대부분의 법적 제재는 그렇게 극단적으로

가혹하지 않다(지속적인 불이행을 제외하면). 그럼에도 여전히 그것은 사람들의 유인구조(incentives)에 영향을 미치며, 이는 권한 부여 규칙에도 해당된다. 강제(coercion)는 법 권한의 날카로운 측면(hard edge)이고, 유인(incentivizing)과 표현(expressive) 기능은 법 규범의 부드러운 측면(soft edge)에 속한다.

다시 한 번, 혼인의 권한을 부여하는 규칙들을 떠올려보자. 이 규칙들은 일정한 조건 하에서만 해당 권한을 부여한다. 예전에는(그리고 어떤 지역에서는 여전히) 누구와 결혼할 수 있는지에 대해 인종이나 성별에 따른 제한이 존재했다. 인종이 다른 사람 사이의 결혼이나 동성 간의 결혼은 법적으로 무효였다. 하트가 제시한 이유들에 비추어 볼 때, 이것을 이성애적 또는 동인종적 관계를 ‘강요’한 강제라고 보는 것은 잘못된 것이다. 아무도 결혼을 반드시 해야 하는 것은 아니기 때문이다. 따라서 이런 법은 동성애 행위에 대한 형벌이나 도망 노예 법(fugitive slave laws)과는 다르다. 그러나 이러한 권한 부여 규칙(또는 그것들과 해석 규칙의 결합)에 의해 그러한 혼인이 무효가 된 것은 결코 우연한 결과나 의도하지 않은 부산물은 아니었다. 그것이 바로 해당 법의 목적이었다. 이러한 법은 명령이나 제재와 같은 조악한 수단에 의존하지 않고도 개인의 삶과 공동체의 문화를 형성하고자 했다. 그리고 실제로 어느 정도 성공했다. 따라서 하트가 호의적으로 ‘편의(facilities)’를 제공한다고 표현한 규칙들의 기능을 생각할 때, 우리는 이 점을 잊지 말아야 한다. 모든 법이 강제적인 것은 아니지만, 비강제적인 법 역시 강제적인 법과 동일한 기능을 수행할 수 있다. 즉, 사회 권한을 표현하고 그것을 유도하는 것이다. 이러한 기능은 법 규범의 내용(content)을 통해서도, 보다 일반적인 구조적 특징을 통해서도 작용한다. 예를 들어 자발적 권한(voluntary powers)은 자신의 의지를 행사할 수 있는 자에게 법적 통제권을 분배하고(individual powers), 개인적 권한은 그것을 개별 개인에게 분배한다. 이는 누구에게 무언가를 ‘강제’하지는 않지만, 그러한 법을 만들고 적용하는 이들이 의도했으며 예측 가능한 방식으로 사회 세계(social world)를 형성한다.

4. 법과 도덕 (LAW AND MORALITY)

이 책의 중심 문제 중 하나는 법과 도덕 간의 다형적(pluriform) 관계—즉 관습적 또는 ‘사회적 도덕’(social morality)과 이상적 또는 ‘비판적 도덕’(critical morality)—에 관한 것이다. 하트는 법과 도덕 사이에 일정한 분리(disjunction)가 존재한다고 강하게 주장한 것으로 유명하다. 그의 이론에 대해 아는 바가 거의 없는 사람조차도, 그가 역사적인 홈즈 강연에서 다음과 같이 말했음을 알고 있다: “법과 도덕 사이에는 필연적 연결이 없다(no necessary connection between law and morals).”¹⁹ 우리는 이미 위의 3 (i)에서, 법이 반드시 지배받는 인구가 실제로 승인하는 도덕적 가치들을 반영할 필요는 없다는 이유를 살펴보았다. 하지만 그들이 마땅히 따라야 할 도덕적 가치들과는 어떠한가? 하트는 이 경우에도 필연적 연결이 없다고 말하고자 하는가? 『법의 개념(The Concept of Law)』에서 그는 때때로 이 생각을 다른 방식으로 서술한다. 한 지점에서 그는 실증주의의 핵심 명제를 다음과 같이 묘사한다: “법이 도덕의 특정 요구들을 재현하거나 충족시킨다는 것은 결코 필연적 진리가 아니다”(185–6쪽). 이는 더 협소한 주장처럼 보인다: 모든 법이 건전한 도덕 기준을 ‘재현하거나 충족시켜야 한다’는 것을 요구하지 않으면서도, 법과 도덕 사이에 필연적 관계가 존재할 수 있는 것이다.

하트의 첫 번째이자 보다 광범위한 서술은, 그의 견해(즉, 법이 사회적 구성물이라는 견해)를 공유하는 이들 사이에서도 거의 지지를 얻지 못했다.²⁰ 법과 도덕이 모두 인간 행위를 규율한다는 것이 단순한 우연일 뿐이라고 보기는 어렵다. 인간이 어떻게 살아야 하는가에 대해 전혀 언급하지 않는 규범 체계는 법적 규범도 아니고, 도덕적 규범도 아니다. 이는 법과 도덕 사이의 필연적 연결 하나를 암시한다. 그리고 또 다른 연결들도 있다. 실제로 하트의 성숙한 이론은 법과 도덕 사이의 두 가지 흥미로운 필연적 연결을 더 승인한다. 하나는 법의 목적을 경유하며, 다른 하나는 법과 정의 간의 추정적 연결을 경유한다. 또한

¹⁹H. L. A. Hart, ‘Positivism and the Separation of Law and Morals’ (1958) 71 Harvard Law Review 593, at 601 n. 25.

²⁰See John Gardner, ‘Legal Positivism: 5½ Myths’, chap. 2 of his *Law as a Leap of Faith* (Oxford University Press, 2012); and Leslie Green, ‘Positivism and the Inseparability of Law and Morals’ (2008) 83 New York University Law Review 1035.

하트의 이론은, 많은 다른 실증주의자들이 인정하기를 꺼리는, 법과 도덕 간의 우연적 연결도 허용한다. 이 세 가지 주장은 분리 명제의 어떤 버전 못지않게 하트 이론에서 중요하다. 그러나 이 중 명확하게 타당한 것은 첫 번째 주장뿐이다.

(i) 법의 목적 (Law's Purpose)

법은 단순한 규칙의 체계가 아니라, 다양한 목적을 수행하는 체계이다. 토마스 아퀴나스는 법이 총체적 목적(overall purpose)을 가진다고 보았는데, 그는 이를 “공공선을 위한 이성적 명령(an ordinance of reason made for the common good)”이라고 정의하였다.²¹ 현대적 접근으로는, 법이 행위를 지도하기 위해, 공공선을 위한 활동을 조정하기 위해, 정의를 실현하기 위해, 혹은 강제력을 허용하기 위해 제정된다는 견해들이 있다.²² 이러한 주장은 법에 대한 이상적 제안이 아니라, 구성적 목적(constitutive aims)에 대한 주장으로 이해되어야 한다. 핵심 아이디어는 다음과 같다: 이러한 목적을 지니지 않은 사회적 통제 체계는 법체계라고 할 수 없으며, 이는 지식 추구를 목적으로 하지 않는 기관이 대학이 아닌 것과 같다. 구성적 목적을 갖는다는 것만으로는 도덕성과의 연결을 확립하지 않는다. 이는 그 목적이 무엇이냐에 달려 있다. 식기세척기가 설거지를 위해 존재하지 않는다면 식기세척기가 아니며, 설거지 능력은 식기세척기의 품질을 판단하는 주요 기준 중 하나다. 그러나 설거지는 일반적으로 도덕적으로 중요한 활동이 아니므로, 좋은 식기세척기가 곧 도덕적으로 좋은 식기세척기인 것은 아니다. 법의 구성적 목적에 대한 위의 제안들은 도덕적으로 중요한 것에서 도덕적으로 중립적인 것까지 다양하다. 정의 실현은 도덕적으로 선한 것이고, 행위 지도는 도덕적으로 중립적이며, 강제력 허용은 도덕적으로 모호하다.²³

²¹Summa Theologica II-I, q. 90 a. 4.

²²Guiding conduct: Lon L. Fuller, *The Morality of Law* (rev. edn., Yale University Press, 1969); coordinating activity: John Finnis, *Natural Law And Natural Rights* (Oxford University Press, 1980); doing justice: Michael Moore, 'Law as a Functional Kind,' in R. P. George ed., *Natural Law Theory: Contemporary Essays* (Oxford University Press, 1992) 221; licensing coercion: Ronald Dworkin, *Law's Empire* 93.

²³강제(coercion)를 허용한다는 것은, '현재 진행 중인 강제 행위에 대해 정당화(justification)를 제공한다'는 의미인가? 아니면 '정당화될 수 없는 강제가 발생하지

도덕성과의 연결은 또한 구성적 목적이 어느 정도 달성되는가에 달려 있다. 제9장에서 하트는, 인간 생존이 도덕적으로 선한 것이며, 생존을 지향하지 않는 규범 체계는 법체계가 될 수 없다고 전제한다. 또한 어떤 체계가 법체계로 존재하려면, 반드시 전 인구에게 항상은 아니더라도, 상당수에게 상당 시간 성과를 제공해야 한다(deliver the goods)고 본다. 일반적으로, 구성적 목적을 지닌 것들은 그 종류에 속할 자격을 박탈당하기 전까지 상당한 여지를 가진다. 고장이 났거나 결함이 있는 식기세척기도, 수정되거나 수리될 경우 설거지를 수행할 수 있는 능력이 있다면 여전히 식기세척기이다. 법체계도 마찬가지다. 법이 수행해야 할 기능을 제대로 수행하지 못하는 통합된 법률 체계라도 여전히 법체계로 간주될 수 있다. 이는 어떤 것을 지향한다(aim)는 것이 반드시 그것을 성취한다(succeeding)는 것을 요구하지 않는다는 사실에서 비롯된다.

이 문제에 대한 하트의 마지막 성찰에서는, 법이 생존을 지향할 필요조차 없다는 입장으로 선회한 듯하다. 그는 법이 어떤 흥미로운 구성적 목적도 지니지 않는다고 본 막스 베버(Max Weber)와 한스 켈젠(Hans Kelsen)의 입장에 동참한다. (켈젠은 “법은 목적이 아니라, 특정한 사회적 수단이다(Law is a means, a specific social means, not an end)”라고 말했다.²⁴) 하트는 이렇게 쓴다: “나는 법이 인간 행위를 지도하고, 그 행위에 대한 비판 기준을 제공하는 것 외에, 그 자체로 수행하는 보다 구체적인 목적을 찾는 것은 매우 헛된 일이라고 본다”(249 쪽). 여기에는 생존에 대한 언급이 없다. 그러나 하트가 이전의 ‘법은 생존을 촉진하는 목적을 가진다’는 주장을 철회한 것일 수도 있고, 혹은 법이 그러한 목적들에 의해 식별될 수 있다(identified)는 주장 자체를 부정하는 것일 수도 있다. 즉, 법체계들 사이에서 보편적이며 동시에 고유한 목적은 없다는 것이다. 법은 생존을 촉진하려는 목적을 가질 수 있고, 행위를 지도하거나 평가하려는 목적을 가질 수 있다. 그러나 이들 모두는 관습, 종교, 도덕 등과 법을 구분해 주지는 못한다. 오히려 이들은 상호 중첩되는 지점이다. 법과 도덕은 유사한 과업에 주목하며, 유사한 이유로 그러한 과업에 접근하고, 일부 유사한 기법을 않도록 보장한다’는 의미인가? 혹은 ‘정당화될 경우에만 사람들에게 강제를 가한다’는 의미인가?

²⁴Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (A. Wedberg tr., Harvard University Press, 1949) 20.

사용한다.

(ii) 법과 정의 (Law and Justice)

제8장에서 하트는 법과 도덕 사이의 놀라운 연결을 옹호한다. 그의 논증은 규칙 준수(rule-following)를 정의(justice)와 연결시키는데, 이때 둘 다 유사한 사례는 유사하게 대우되어야 한다는 생각을 공유한다. 실천 이론(practice theory)에 따르면, 일반 규칙(general rules)은 일정한 방식으로 그것에 부합하거나(conform) 반복적으로 적용되지 않으면 존재할 수 없다. 그런데 하트는 이 일관성(constancy) 자체가(itself) 일종의 정의라고 말한다. 그는 이렇게 쓴다: “[가장 혐오스러운 법조차도 정의롭게 적용될 수 있지만], 일반 법규칙을 적용한다는 개념 자체 안에는 적어도 정의의 씨앗(germ of justice)이 담겨 있다”(206쪽, cf. 160쪽). 이로부터, 모든 존재하는 법체계는 어떤 식으로든 정의를 실현한다고 결론지을 수 있다. 물론 이는 ‘실질적 정의(substantive justice)’가 아니다. 혐오스러운 법을 일관되게 적용하는 것이 그것의 혐오스러움을 보완하거나 완화하지는 못한다. 하지만 그러한 적용은 여전히 법 적용(application)에 있어서의 정의—즉 어떤 이들이 말하듯 ‘형식적 정의(formal justice)’—를 산출한다.²⁵ 이는 하나의 법이, 그 법이 스스로(그 판단이 옳든 그르든) 관련성 있다고 간주하는 방식으로 유사한 자들에게만, 그리고 전적으로 적용되어야 함을 요구한다. 그리고 이 요건은 ‘극도로 억압적인(hideously oppressive)’ 법이나, ‘권리를 박탈당한 노예(rightless slaves)’에게 어떤 작동 가능한 법체계의 최소한의 혜택조차도 부정하는 법에 대해서도 동일하게 적용된다.²⁶

나는 ‘혐오스러운(odious)’, ‘극도로 억압적인(hideously oppressive)’ 등의 하트의 표현을 인용한 바 있는데, 이는 그의 ‘정의의 씨앗(germ of justice)’이라는 논제가 얼마나 대담한지를 분명히 하기 위함이다. 적용에 있어서의 일관성은, 그 법이 단지 약간 부정의한 수준일 때는 납득 가능하게 느껴질 수도 있다.

²⁵David Lyons criticizes it under that label in ‘On Formal Justice’ (1973) 58 Cornell Law Review 833. Matthew Kramer defends it under the better label of ‘constancy’: Matthew Kramer, ‘Justice as Constancy’ (1997) 16 Law and Philosophy 561.

²⁶H. L. A. Hart, ‘Positivism and the Separation of Law and Morals’ 593, at 626.

예컨대, 정당화 목적에 비추어 과포괄적이거나 과소포괄적인 법-17세 미만 모두에게 운전을 금지하는 규범이 몇몇에게는 과도하게 금지하고, 또 다른 이들에게는 과도하게 허용하는 경우 등-이 그러하다. 완벽한 법은 없으며, 작지만 명백한 결함이 있는 법을 일관되게 적용할 이유는 여럿 있을 수 있다. 하지만 이것만으로는 하트의 주장을 정당화할 수 없다. 그는 이 논지가 혐오스러운 법에도 적용된다고 말하며, 우리가 실질적 정의, 형평성(equity), 자비(mercy), 혹은 제정신(sanity)을 허용하는 경우조차도, 우리는 그 과정에서 무언가 귀중한 것을 상실했음을 인식한다는 것이다: 우리는 적어도 하나의 측면에서는 부정의(injustice)를 저지른 셈이 된다.

그러나 이 ‘형식적(formal)’ 정의 개념에는 어딘가 이상한 구석이 있다. 결국, 정의의 형식(the form of justice)을 가진 모든 것이 반드시 정의의 한 형식(a form of justice)인 것은 아니다. 이는 낙타의 형식(the form of a camel)을 가진 것이 반드시 한 낙타(a camel)인 것이 아닌 것과 마찬가지다. 더 나아가, 정의 규범(norms of justice)과 부정의 규범(norms of injustice)은 그 형식에서 반드시 다르지 않다.²⁷ 예를 들어, “남성과 여성은 동등한 가치의 노동에 대해 동일한 보수를 받아야 한다”는 규범은 정의 규범이다. 반면, “남성과 여성은 동등한 가치의 노동에 대해 서로 다른 보수를 받아야 한다”는 규범은 부정의 규범이다. 두 규범은 동일한 형식을 가진다. 그렇다면 “모든 규칙을 그것의 적용대상에게만, 그리고 전원에게 적용하라”는 규범은 어떠한가? 이것은 “이미 친구로 삼기로 한 사람들에게만 친구로 대해라”는 규범과 동일한 형식을 갖는다. 후자의 규범은 정의의 규범인가? 이 경우, 한 규범이 정의인지, 부정의인지, 또는 둘 다 아닌지 여부를 형식만으로는 판단할 수 없다는 점이 분명해진다.

간통죄에 대해 유죄 판결을 받은 여성을 돌로 쳐죽이는 법이 존재하는 법 체계에서 일하는 판사를 상상해 보자. 이 법을 그 적용대상 모두에게 적용해야 할 이유가 있는가? 특별한 경우에는 가능할지도 모른다: 그가 그러지 않으면 생명의 위협을 받을 수 있고, 거부할 경우 폭동이나 더 많은 여성들의 희생이 야기될 수 있으며, 그는 이 법을 한 번 적용함으로써 신뢰를 확보해 이후 더

²⁷Following John Gardner, ‘The Virtue of Justice and the Character of Law’, chap. 10 of his *Law as a Leap of Faith*.

효과적으로 그것을 공격할 수 있을지도 모른다. 그러나 이런 법을 모든(all) 경우들에 일관되게 적용해야 할 이유가 있는가? 여기서는 법률 없이는 형벌 없다(*nulla poena sine lege*)라는 원칙 이상의 것이 필요하다. 그 원칙은 법을 위반하지 않은(have not) 사람을 처벌하지 말라는 것이지, 법을 위반한 모든 사람을 반드시 처벌하라는 것이 아니다(not). 이 조건은 우리의 가설적 사례에서 충족된다. 하지만 그 원칙은 법을 위반한(has) 모든 사람을 처벌하라고 말하지 않는다. 그렇게 하지 않는 것이 부정의인가? 만약 그렇다면, 누구에게 부정의란 말인가? 다른 유죄 여성들(돌로 맞아 죽게 될), 또는 이미 그렇게 처형당한 여성들의 가족들이, 모든 다른 유죄 여성들도 똑같이 혐오스럽게 대우받아야 한다고 요구할 자격이 있다는 주장은 납득하기 어렵다.

하트는 아마도 ‘형식적(formal)’ 정의를 두 가지 건전하지만 서로 관련 없는 아이디어와 혼동하고 있을 수 있다. 하나는, 정의와 부정의는 결과뿐 아니라 절차(procedures)에서도 나타날 수 있다는 것이다. 예컨대, 법적 분쟁에서 양 당사자의 의견을 청취해야 한다는 것은 자연법상 정의(natural justice)의 요건이다. 이러한 절차를 허용하지 않는 절차는 부정의하다. 하지만 부정의한 규칙 자체(itself)가 자연법상 정의를 침해할 수도 있다: 예컨대 법이 부자에게 가난한 사람보다 두 배의 변론 시간을 허용한다면, 그 법을 엄격히 적용하는 것은 자연법적 정의를 진전시키는 것이 아니라 후퇴시키는 것이다. 이와 관련된 또 다른 아이디어는, 규칙의 적용에 있어 우리는 불편부당(impartial)해야 하며, 판단자는 ‘편견, 이해관계, 또는 편견(prejudice, interest or caprice)’에 따라 행동해서는 안 된다는 것이다(161쪽). 이 주장 또한 옳지만, 부정의한 법을 해당 규정에 따라 적용하지 않으려는 사람에게 반드시 그러한 동기가 있다고 보기는 어렵다. 실제로 혐오스러운 법 자체가 편향적이거나 편협스러울 수 있으며, 그러한 법의 선택적 비적용은 오히려 가장 선한 동기에서 비롯된 것일 수 있다.

그렇다면 하트의 ‘정의의 씨앗(germ of justice)’ 논제로부터 우리가 구제할 수 있는 것은 있는가? 어쩌면 다음과 같은 점일 수 있다: 우리가 규칙 적용(rule-application)에 주목하게 될 때, 우리는 필연적으로 특정 사례들에 있어(in particular cases) 규칙이 어떻게 적용되어야 하는지를 고민하게 된다—즉, 사람들이 그러한 규칙 아래에서 실제로 어떻게 대우받고 있는지, 또는 대우받아야

하는지를 성찰하게 된다. 이는 단순한 총량적 물음(aggregate questions)이 아니라 분배적(distributive) 물음에 주목하게 만든다. 이는 오늘날 얼마나 많은 차별이 이루어지고 있는지를 묻는 데 그치지 않고, 누가 어떤 잘못에 대해 어떻게 처벌받고 있는지를 묻도록 요구한다. 사람들 사이의 혜택과 부담이 어떻게 배분되어야 하는가를 고민한다는 것은 정의에 대한 질문을 던지는 것이다. A가 마땅히 받아야 할 대우를 받았는지, 혹은 A와 B 사이의 대우 차이가 정당화될 수 있는지를 주의 깊게 고민하는 것은 정의에 대한 관심이다. 우리가 그러한 질문을 고려하고 결정할 수 있는 권한을 가진 법원과 같은 제도를 갖추고 있다면, 우리는 정의를 수행할 수 있는 제도를 갖춘 것이다. (물론, 부정의를 수행할 수도 있다.) 어쩌면, 크고 복잡한 사회에서는 정의를 실현하기 위해 그런 제도가 필수적일지도 모른다.

(iii) 법적 유효성과 도덕 원칙 (Legal Validity and Moral Principles)

법과 도덕 사이의 세 번째 접점은 다른 성격을 가진다. 하트는 도덕 원칙(moral principles)이 반드시 법의 근원이 되는 것은 아니지만, 법의 근원이 되는(are) 요소들에 의해 승인(authorized)된다면 법의 근원이 될 수 있다(could)는 점을 인정한다. 이를 다르게 표현하면, 하트는 승인 규칙(rule of recognition)이 필연적으로 사회적 구성물(social construction)이라는 점은 인정하지만, 그 승인 규칙이 사용하는 기준(criteria) 자체가 사회적 구성물일 필요는 없다고 본다는 것이다. 그는 도덕 원칙들이 가치 있는 원칙이기 때문에 혹은 기존의 법을 정당화하기 때문에 법이 된다고 생각하지는 않는다. 하지만 어떤 방식으로든 법 안에 포함된다면, 그것들은 법이 될 수 있다.

이 지점에서 하트는 구성주의 논제(constructivist thesis)의 두 해석 가운데 하나에 입장을 명확히 하는데, 그것은 흔히 ‘포괄적 법실증주의(inclusive legal positivism)’로 불리는 입장이다. 이 입장에 따르면 법의 근원(source of law)은 이상적 도덕(ideal morality)의 원칙을 포함할 수 있다. 하트는 반대로, 이를 허용하지 않는 ‘배타적 법실증주의(exclusive legal positivism)’에는 반대한다.²⁸

²⁸Hart calls his position ‘soft’ positivism, but ‘inclusive’ positivism is more perspicuous since it holds that law includes anything to which law refers.

그가 이 결론에 이르는 경로는 명확하게 되짚기 어렵다. 이는 그가 본문을 쓸 당시에는 이러한 대안들이 아직 명확히 구분되어 있지 않았기 때문이다. 하지만 후기(Postscript)에서 하트는 다음과 같은 결론에 도달한다: 법적 유효성(legal validity)은 어떤 규범(norm)의 ‘족보(pedigree)’—즉, ‘법이 법제 기관(legal institutions)에 의해 채택되거나 창출되는 방식에만 관련된 특성으로, 그 내용(content)과는 무관한 특성’—만으로 결정될 필요는 없다(247쪽).²⁹ 대신, 법적 유효성은 도덕적 적절성(moral propriety)에 의해 결정될 수 있다.

이 자리에서는 포괄적 법실증주의 논제 자체를 평가할 수 없다.³⁰ 그러나 하트가 이 논의에 끌고 들어온 혼동 하나를 제거하는 것은 의미 있다. 승인 규칙의 기준(criteria)이 도덕 원칙을 포함할 수 있는가라는 질문은, 이 기준들이 족보 기준(pedigree test)인가라는 질문과 동일하지 않다. ‘족보(pedigree)’와 대비되는 두 가지는 다음과 같다. 하나는 내용(substance)과의 대비이고, 다른 하나는 도덕성(morality)과의 대비다. 이 혼동은 ‘실질적 정의(substantive justice)’ 개념에서 보았듯이, ‘실질적(substantive)’이라는 표현이 ‘정당화된(justified)’ 혹은 ‘도덕적인(moral)’이라는 뜻으로 자주 사용되는 데서 비롯된다. 하트는 이러한 문제들을, 오스틴(Austin)의 견해—모든 법체계는 법적으로 무제한의 권력을 가진다는 주장—를 비판하면서 본문에서 제기한다. 오스틴주의자는, 입법자가 법을 제정하는 형식과 방식(manner and form)에 한해서는 제약을 받을 수 있다고 인정할 수 있을 것이다. 예컨대 고지와 토론의 요건, 또는 특별다수제 요건 등이 그것이다. 그러나 많은 성문헌법들은 그런 식으로는 설명할 수 없는 제약을 포함한다. 이들은 “입법권의 범위에서 특정 사안을 완전히 제외함으로써 실질적 제약(substantive limitations)을 부과한다”(68쪽). 이러한 제약은 ‘단지 도덕적(moral) 또는 관행적(conventional)’ 제약이 아니라 ‘법적’ 무능력(legal

²⁹The metaphor is first used by Ronald Dworkin, *Taking Rights Seriously* 17.

³⁰The theory is defended by W. J. Waluchow, *Inclusive Legal Positivism* (Oxford University Press, 1994), and by Jules Coleman, *The Practice of Principle: In Defence of a Pragmatist Approach to Legal Theory* (Oxford University Press, 2001). It is criticized by Joseph Raz, *Ethics in the Public Domain: Essays in the Morality of Law and Politics* (Oxford University Press, 1994), chaps. 9, 10; and Scott Shapiro, ‘On Hart’s Way Out’ (1998) 4 *Legal Theory* 469.

disabilities)이다(69쪽).³¹ 하트는 그 예로 미국 헌법 제16차 수정조항을 드는데, 이는 일부 내용으로 다음을 요구한다: “개인 인두세(capitation tax) 또는 기타 직접세(direct tax)는, 이 조항에 명시된 인구 조사 결과에 비례하지 않는 한, 부과될 수 없다.” 이는 분명히 형식 요건이 아니므로, 한 측면에서 보면 실질적이다(substantive). 하지만 하트는 또한 다음과 같이 말한다: “일부 법체계, 예컨대 미국에서는, 유효성의 궁극적 기준이 족보(pedigree)뿐 아니라 정의의 원칙이나 실질적 도덕 가치(substantive moral values)를 명시적으로 포함할 수 있으며, 이러한 것들이 법적 헌법 제약의 내용을 구성할 수 있다”(247쪽). 이것은 앞서 언급한 ‘실질적’ 개념과는 다소 다른 의미의 것이다. 다음은 가능한 승인 규칙의 조항들을 비교한 것이다:

(S1) 의회는 국교를 설립하는 어떤 법률도 제정할 수 없다.

(S2) 의회는 불공정한 법률을 제정할 수 없다.

(P1) 의회는 은밀하게 법률을 제정할 수 없다.

(P2) 의회는 불공정한 방식으로 법률을 제정할 수 없다.

규칙 (S1)과 (S2)는 유효성의 실질적 기준(substantive criteria of validity)을 설정하고, (P1)과 (P2)는 절차적 기준(procedural criteria)을 설정한다. 하지만 다른 방식으로도 짚지을 수 있다: (S2)와 (P2)는 도덕적 기준(moral criteria)을 설정하고, (S1)과 (P1)은 사실적 기준(factual criteria)을 설정한다. (이것이 반드시 명확히 결정가능한 기준을 설정한다는 뜻은 아니지만, 법률이 종교를 설립하는지 혹은 비밀리에 제정되었는지는 각각의 행위가 도덕적으로 타당한지 여부를 판단하지 않고도 확인할 수 있다.) 하지만 여기서 물어야 한다: (P2)는 또한 족보의 테스트(a test of pedigree)를 진술하는가? 그것은, 해당 기준을 적용하려면 제정된 법의 내용이 아니라, 제정 방식을 살펴보아야 한다는 의미에서는 족보 기준이다. 하지만 그것(P2)이 충족되었는지 여부(whether)를 알기 위해서는 제정 과정의 도덕적 적정성(moral propriety)에 대한 판단이 필요하다는 점에서는 족보 기준이 아니다. 따라서 ‘족보(pedigree)’라는 은유는

³¹여기서 하트는 ‘도덕적 또는 관행적(moral or conventional)’이라는 표현으로, 오스틴(Austin)이 법적 권한에 대한 ‘실정적 도덕(positive morality)’의 비법적(non-legal) 제약이라 부른 것과, 다이시(Dicey)가 말한 헌법적 ‘관행(conventions)’를 모두 포괄하고자 한다.

오해를 불러올 가능성이 크며, 우리는 이 개념을 버리고 사회적 사실(social fact)과 도덕 판단이 필요한 사안(moral judgement) 사이의 구분을 택해야 한다.

이 문제는 다음의 세 가지로 인해 더 복잡해진다. 첫 번째는 동음이의(homonymy) 문제다. 헌법이나 기타 문서에서 도덕적으로 들리는 용어들(terms)이 있다고 해서, 그것이 곧 법에 대한 도덕적 기준이 존재한다는 것을 시사하지는 않는다. 어떤 용어들은 법적 맥락에서, 관습적 도덕(customary morality)과 사법적 결정들(judicial decisions), 그리고 법적 해석의 전통에 의해 특수한 의미를 지니게 되거나 이미 그러한 의미를 가진다.³² 예를 들어 “모든 개인은 법 앞에 평등하다”라는 헌법 조항이 도덕적 평등이라는 이상을 지향하고 있는지 여부는 법원이 그것을 어떻게 해석하고 적용하는지를 보아야 알 수 있다. 그리고 헌법 조항이 애초에 도덕적 이상을 표방했다 하더라도, 이후의 사법적 결정들은 그것에 사실적 불평등의 전형(factual paradigms)이나 복합적 기준(multi-prong doctrinal tests)을 덧붙이면서 점점 그것과 멀어질 수 있다. 이는 통상적인 법적 근거(source-based)의 유효성 판단이며, 그 원래의 추상적 도덕 이상이 여전히 작동하고 있는지조차 불분명할 수 있다.

두 번째 복잡성은 속존(supervenience)의 문제다. 예컨대 어떤 것이 ‘불공정하다(unfair)’고 말할 수 있다면, 그것이 불공정한 근거가 되는(in virtue of which) 사실들이 있을 것이며, 두 사건이 하나는 불공정하고 다른 하나는 공정할 수 있으려면, 양자 사이에 사실적 차이가 반드시 존재해야 한다는 것은 타당한 주장이다. 이제 어떤 헌법이 차별적인 법률을 금지한다고 하자. 여기서 ‘차별(discrimination)’이 도덕적으로 잘못된 것으로 이해된다면, 그것이 잘못된 이유가 일반적인 사회적 사실들—예컨대 결정을 내릴 당시의 의도, 결정이 다양한 사람들에게 미치는 상대적 영향 등—이라면, 이러한 사실들은 어떤 입장에서든 법 판단 기준의 일부가 될 수 있다. 배타적 법실증주의는 법 판단의 최종 기준에, 어떤 것이 공정하거나 불공정하다고 판단하는 데 사용되는 사실들이 포함될 수 없다고 주장하지 않는다. 그것은 오히려, 해당 사실들을 판단하기 위해 도덕적 속성에 대한 견해에 의존하지 않고도 해당 사실을 인지할 수 있어야 한다는 것만을 요구한다.

³²언제나 그렇듯, ‘통제됨(controlled)’이란 ‘완전히 통제됨’을 의미하지는 않는다.

세 번째 복잡성은 불확실성(uncertainty)이다. 하트는 입법자가 어떤 산업에 대해 ‘공정한 요금(fair rate)’만을 부과하도록 요구하는 사례를 고려한다(131-2쪽). 물론, 입법자가 명확히 고려한 극단적인 불공정 사례—예컨대 “공공에게 필수 서비스를 인질로 잡고 과도한 요금을 부과하는 경우”(131쪽)—는 분명히 포함될 수 있다. 하지만 사전에 구체적으로 명시하기 어렵고, 명시하는 것이 바람직하지도 않은 수많은 사례들이 존재한다:

이 경우들에서, 규칙을 제정하는 권한은 반드시 재량(discretion)을 행사해야 하며, 다양한 사례에서 제기되는 문제를 단 하나의 고유한 정답이 존재하는 것처럼 다룰 수는 없다. 오히려 그 해답은 많은 상충하는 이해관계들 사이에서의 합리적인 타협일 것이다 (131-2쪽).

적어도 ‘공정성(fairness)’이 불확실한 한, 해당 용어가 법률에 언급될 경우 법원은 재량(discretion)을 행사해야 한다. ‘공정한 요금(fair rate)’을 요구하는 입법자는 이러한 점을 인지하고 있을 것이며, 따라서 법원에 무제한적 권한이 아니라, 무엇이 불공정한지를 판단할 권한, 그리고 그 판단이 구속력(binding)을 가지도록 하는 권한을 부여한 것으로 이해되어야 한다. 그러나 Postscript에서는 상황이 다르게 묘사된다. 이곳에서 ‘적법절차(due process)’나 ‘평등(equality)’ 등의 헌법 조항은 도덕 원칙(moral principles)이 법에 편입된 사례로 제시된다. 그런데 이러한 조항들이 재량을 부여하는지 여부는, 이제는 그 불확정성의 정도가 아니라, 해당 조항과 관련된 분쟁을 해결하는 데 필요한 도덕적 판단이 ‘객관적 지위를 갖는지(objective standing)’ 여부에 따라 달려 있다고 설명된다(253-4쪽). 도덕적 판단이 객관적이라면, 불확실성을 해소하는 판결은 도덕 기준에 근거한 기존의 법(pre-existing law)을 적용하는 것에 불과하다. 반면 도덕적 판단이 객관적이지 않다면, 그러한 조항은 “법원에게 도덕에 따라 법을 창출하라(make law)는 지시를 내리는 것일 뿐이다”(254쪽). 하트는 법철학이 논쟁적인 형이상학적 윤리이론(meta-ethical theories)에 대한 입장을 가지는 것을 꺼려하므로, 이 문제는 열어둔 채로 남겨둔다.

만약 이 설명이 헌법 내 도덕적 언어가 일반 법률 내 도덕적 언어와 다르게 기

능하다고 암시한다면, 이는 설득력이 떨어진다. 성문헌법(written constitution)은 결국 특수한 형태의 법률일 뿐이다. 왜 일반 법률에서는 ‘공정성(fairness)’이라는 용어가 요구사항이 불확실할 경우 적어도 재량권을 부여한다고 보면서, 헌법에서는 예컨대 ‘근본적 정의(fundamental justice)’라는 용어가 재량권을 부여하는 것은 단지 그 요구사항이 불확실할 뿐 아니라, 또한(and) 그 불확실성에 대한 도덕적 판단이 ‘객관적이지(objective)’ 않을 때에만 해당된다고 보는가? 해당 문제에 대한 해명이 필요하다는 사실만으로 충분하지 않은가? 해당 판단의 기준이 무엇이든 간에 말이다. 헌법적 기본 원칙에 관한 문제에서는 단순 법률의 경우보다 재량이 더 문제적으로 보일 수는 있겠지만, 그렇다고 재량이 부재한다(absent)는 것을 의미하지는 않는다. 게다가 재량은 이분법적 개념이 아니다. 사실 기반 기준(fact-based criteria)은 재량적 판단에 대해 부분적으로(partial) 영향을 미칠 수 있다. 이는 켈젠(Kelsen)의 은유처럼, 단지 판단이 적합해야 하는 ‘틀(frame)’을 제공하는 데 그치지 않고, 특정한 종류의 결정에 대해 비결정적(non-conclusive) 이유를 제공하는 방식으로도 작용할 수 있다.³³

하트가 자신의 입장을 옹호하는 가장 근접한 논변은 다음과 같다. 그는 ‘도덕적 정당성(moral propriety)’을 법의 판단 기준으로 삼는 가상의 헌법을 상정한다. 즉, 어떤 것이 잘못되었거나 부정의하거나 불공정한 경우, 그것은 결코 법으로 간주될 수 없다는 것이다. 그는 이러한 헌법 구조에 대해 ‘논리적으로 불가능할 것은 없다’고 말한다. “이러한 비범한 장치에 대한 반대는 ‘논리(logic)’ 때문이 아니라, 그러한 법적 유효성(validity) 기준들의 지나친 불명확성(gross indeterminacy) 때문일 것이다. 실제 헌법은 이런 형태로 문제를 자초하지는 않는다.”³⁴ 그러나 ‘논리(logic)’에 개념적 논변(conceptual argument)이 포함된다면, 이러한 구조에 대해 반대할 논변이 존재할 수 있다. 조셉 라즈(Joseph Raz)는, 이는 단순히 문제를 자초하는 정도가 아니라, 법이 그 스스로 주장하는 유형의 권위(authority)를 가질 수 없게 된다고 주장한다.³⁵ 모든 법은

³³Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* 350–1.

³⁴H. L. A. Hart, *Essays in Jurisprudence and Philosophy* 361.

³⁵Joseph Raz, *The Morality of Freedom* (Oxford University Press, 1986), chap. 2; *Ethics in the Public Domain*, chap. 10; and *Between Authority and Interpretation: On the Theory of Law and Practical Reason* (Oxford University Press, 2009), chap. 5.

정당한 권위를 주장하고 있으며, 그것이 정당한 권위를 가질 수 있는 종류의 것일 때에만 그 주장은 일관성을 가질 수 있다. 법의 주장은 공허하거나(hollow), 불성실하거나, 부정의하거나, 지혜롭지 못할 수는 있지만, 이해가능한(intelligible) 것이어야 한다. 실천적 권위(practical authorities)—법체계 역시 포함된다—의 역할은 사람들이 그들이 마땅히 해야 할 일을 따르도록 돕는 것이다.³⁶ 권위는 오직 그들의 명령(directives)이 그 이유(reason)에 기초할 때, 그리고 사람들이 그 명령을 따르려는 시도를 통해 그들에게 적용되는 이유(reason)에 더 잘 부합할 가능성이 있을 때만 그런 기능을 수행할 수 있다. 그리고 이는 오직 해당 명령이 그 이유 자체를 참조하지 않고도 식별될 수 있어야 가능한 일이다. 즉, 어떤 사람이 법이 무엇을 요구하는지를 알기 위해 먼저 자기가 무엇을 해야 하는지를 파악(figure out)해야만 한다면, 법은 그에게 어떤 도움도 줄 수 없다. 법률이 “서로 공정하게 대하라”고 명령하는 것만으로는 더 공정한 결과를 확보할 수 없고, 헌법이 “모든 사람은 평등하다”고 선언하는 것만으로 더 평등한 사회를 실현할 수 없다. 권위 있는 지침(authoritative direction)을 제공하려면, 법률과 헌법은 실제로 해당 개념들이 무엇을 요구하는지를 사람들에게 명시해야 한다. 이것이 라즈의 논변이다. 이는 분석법철학(analytical jurisprudence)에서 가장 많이 논의된 주장 중 하나이다. 이 논증에는 여러 단계가 있으며, 그 중 일부는 논쟁적이다. 그러나 이것은 하트가 ‘존재하지 않는다’고 선언한 유형의 논증이며, 우리가 하트의 견해를 받아들이기 전에 반드시 평가되어야 할 것이다.³⁷

포괄적 법실증주의(inclusive legal positivism)는 도덕성(morality)이 법적 논증에서 적절한 역할을 하려면, 초대받아야 한다(invited)는 점을 시사하는 것으로 보인다. 하트는 유효성의 궁극적 기준(ultimate criteria of validity)을 통해

³⁶이는 단지 그들이 이기적(selfish) 이익에 부합하는 행동이거나, 자신이 이유(reason) 있다고 생각(think) 하는 행동이 아니라, 그들이 ‘객관적으로(objective)’ 이유가 있는 행위를 의미한다.

³⁷게다가 이후의 한 논문에서 하트 자신도 이 입장의 몇 가지 핵심 개념을 수용한다. 참고: H. L. A. Hart, 「Commands and Authoritative Legal Reasons」, *Essays on Bentham* (Oxford University Press, 1982).

그러한 초대(invitation)를 발행한다.³⁸ 그러나 과연 초대가 정말 필요한가?³⁹ 누구도 법률이 논리적 추론(logical inference)이나 산술(arithmetic)의 원리에 의존할 수 있는 것은 법이 그러한 원리를 특별히 인정했기 때문이라고 생각하지 않는다. 누구도 영어 문법의 규칙이 영국 법의 승인 규칙(rule of recognition)에 포함되어야 한다고 주장하지 않는다. 그렇다면 어쩌면 초대는 필요하지 않은지도 모른다. 그리고 도덕 원칙 역시 이러한 다른 기준들처럼 이미 법원에 자연스럽게 자리 잡고 있을 수 있다. 만약 그렇다면, 하트는 존재하지 않는 문제에 대한 해법을 제안하고 있는 것일지도 모른다.

5. 사실(fact), 가치(value), 방법(method)

하트(Hart)는 (Preface)에서 이 책의 목적이 “법(law), 강제(coercion), 도덕(morality)을 서로 다른 것이지만 관련된 사회적 현상(social phenomena)으로 이해하는 데 기여”하는 것이라 말한다. 그는 법학자들이 이 책을 “법철학의 분석적 접근(analytical jurisprudence)”으로 간주할 것이라 예측하면서, 이는 “법이나 법정책에 대한 비판이 아니라 법사고의 일반적 틀을 명료화(clarification)하는 데 관심이 있기 때문”이라고 한다. 그는 또한 이 책을 “기술적 사회학(descriptive sociology)에 대한 에세이로도 생각할 수 있다”고 말한다 (vi). 우리는 이 발언들을 어떻게 해석해야 할까?

(i) 법철학(jurisprudence)과 사회학(sociology)

현장조사도, 통계모형도, 심지어 법 사례조차 거의 제시하지 않는 이 책을 사회학이라 부르기는 어렵다. 하트는 훗날 되돌아보며 이 책이 사회학의 한 종류(kind) 라기보다는, 사회학을 위한 일종의 준비작업(preparatory)이라 말했어야 했다고 한다⁴⁰. 이 다섯 단어는 불필요한 논란을 일으켜왔다. 그러나 그의

³⁸토니 오노레(Tony Honore)는 법이 제기하는 도덕적 주장(moral claims)을 통해 그러한 요청(invitation)이 이루어진다고 본다. 참고: 「The Necessary Connection between Law and Morality」, (2002) Oxford Journal of Legal Studies 22:489.

³⁹See Joseph Raz, *Between Authority and Interpretation*, chap. 7.

⁴⁰David Sugarman, ‘Hart Interviewed: H. L. A. Hart in Conversation with David Sugarman’ (2005) 32 *Journal of Law and Society* 267, 291.

요지는 단순하다. 하트의 방법론은 기술적 사회학의 방법들과 마찬가지로(like), 사실(facts)에 대해 책임을 지되, 그것들에 대해 도덕적이거나 정치적인 입장을 취하지 않는다는 점을 강조하는 것이다. 그는 법철학의 주장을 검토할 때, 법 세계에 대한 지식 있는 사람의 이해에 의거해 살펴보라고 독자에게 거듭 요청한다. 정말 법규칙(legal rules)이라는 것이 존재하는가? 직접 보라(136). 모든 법체계가 무제한 권력을 가진 주권자(sovvereign)를 전제하는가? 직접 보라. 선형적(a priori) 이론과 법에 대한 보통의 지식 사이에 충돌이 있다면, 후자를 따라야 한다. 그것은 수정이 필요할 수도 있고, 일정한 규율이 필요할 수도 있지만, 출발점으로 삼아야 한다. 이 책의 경험적 기반(empirical basis)은 그보다 정교하지 않지만, 기술적 사회학처럼 경험적 기반을 갖는다. 정의(definitions)나 공리(axioms)로부터 시작하여 법에 대한 필연적 진리들을 도출하려 하지 않는다. 법이 어떻게 되어야 하는가에 대한 도덕적 명제에서 출발하여 법이 실제로 어떠한가에 대한 결론을 이끌어내려 하지도 않는다.

기술적 사회학은 양적, 질적 측면에서 일상적 지식을 넘어서 관찰(observations)을 시도한다. 그것은 종종 이 관찰들을 일반화하거나 더 야심차게는 예측으로 통합하려 한다. 하지만 하트는 그러지 않는다. 그는 우리가 이미 알고 있는 기본적인 것들만을 다룬다. 그는 법의 본성을 설명하는 이론을 제시하는데, 그것은 기존의 영향력 있는 이론들과 달리 이러한 사실들과 일관된 방식으로 작동한다고 주장한다. 그의 이론은 법사회학적 데이터를 대규모로 수집하여 얻어진 일반화 집합이 아니며, 어떠한 예측도 시도하지 않는다. 그렇다면 그것이 우리가 이미 알고 있는 것에 어떤 가치를 더하는가? 그것을 더 깊이 이해하게 함으로써이다. 그것은 보통의 사실들 사이의 놀라운 관계들, 그 사실들이 전제하는 미처 인식되지 않은 조건들, 그리고 특히 특정 사실들이 지니는 더 넓은 함의를 보여준다. 물론 설명(explanation)과 이해(understanding) 사이에는 명확한 경계가 없다. 법사회학과 법철학의 풍부한 연구들은 둘 다를 수행한다. 이해란 법에 대한 설명적 혹은 예측적 탐구의 경쟁물이 아니다. 또한 그것은 누가 무엇을 어떻게 연구해야 하는지를 규율하는 허가제도도 아니다. 그것은 그 자체의 고유한 활동이다.

이것은 분석적 법철학(analytic jurisprudence)과 법사회학이 대체로 병행

적으로 운영될 수 있음을 시사한다. 그렇다면 하트가 언급한, 전자가 때로는 후자에 대한 준비작업이 될 수 있다는 주장은 어떤 근거를 가질 수 있을까? 켈젠(Kelsen)은 “사회학적 법학(sociological jurisprudence)은 법 개념을 전제로 한다. 그 법 개념은 규범적 법학(normative jurisprudence)에 의해 정의된다”고 말했다⁴¹. 그의 기본 생각은, 사회학이 법 제도나 실천을 연구하고 일반화하려면 그것들을 확보하고(with them) 시작해야 한다는 것이다. 권한 부여 규칙(power-conferring rules)이 사회적으로 어떤 영향을 미치는지에 관심이 있다면, 무엇이 그러한 규칙인지 먼저 판단할 수 있어야 한다. 이를 위해서는 ‘규범적 법철학’이 필요하다. 또 다른 예로, 사회학자들이 법의 지배(rule of law)의 실증적 지표(empirical measures)를 개발하고자 한다면, 그것들이 유효한(valid) 측정치인지 판단하려면 법의 지배란 무엇인지부터 알아야 한다. 내가 보기엔, 주요 지표들 중 어느 것도 특정 관할권의 법이 소급적이지 않거나, 모호하지 않거나, 상호 충돌하지 않는 정도를 측정하려 하지 않는다—그러나 이것들은 모두 법의 지배의 핵심 요건들이다⁴². 그럼에도 몇몇 지표들은 다양한 국가에서 사유 재산의 보장이나 계약 자유의 정도를 측정하고, 그것이 클수록 법의 지배 점수를 높게 준다. 이는 명백한 정치적 편향을 드러내며, 동시에 개념적 혼란을 의미한다. 법의 지배 개념에는 논쟁의 여지가 있지만, 그것을 ‘자본주의의 전제 조건’으로 여긴다면 해당 개념에 대한 이해는 매우 빈약한 것이다. 이에 대해 적어도 이러한 실증 지표들이 신뢰할 수 있으며, 관련 변수들과 상관관계가 있고, 법과 사회에 대한 다른 지식들과 연속선상에 있다는 반론이 있을 수 있다⁴³. 그럼에도 법사회학이 관련 개념이 가리키는 핵심에서 너무 멀어진다면, 그것은 주제를 바꾼 셈이다. 어떤 경우에는 주제를 바꿔야 할 수도 있다—자연과학의 진보는 때때로 존재론을 폐기하고 새로 시작하는 방식으로 이루어졌다. 그러나

⁴¹Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* 178. ‘Normative’ here means ‘having to do with norms’, not ‘morally appraisive’.

⁴²For a review some attempts at an index, and the problems in constructing one, see Tom Ginsburg, ‘Pitfalls of Measuring the Rule of Law’ (2011) 3 *Hague Journal on the Rule of Law* 269.

⁴³For a spirited defence of a social-scientific approach to jurisprudence see Brian Leiter, *Naturalizing Jurisprudence: Essays on American Legal Realism and Naturalism in Legal Philosophy* (Oxford University Press, 2007).

사회과학의 진보가 우리가 익숙한 법의 존재론(규칙, 의무, 권한, 법원 등)을 폐기해야 한다면, 그것은 더 이상 ‘법’의 사회학이 아닐 것이다. 그렇다면 법철학(jurisprudence)은 여전히 우선성을 가진다.

우리가 ‘법의 법리학적 개념(juristic concept of law)’과 그 관련 개념들을 계속 유지하고자 한다면, 하트가 약속한 깊은 이해는 어떻게 도달할 수 있는가? 어디서 시작해야 하는가? 하트는 종종 우리에게 특정 사례를 어떻게 판단하거나 분류할 것인지 질문함으로써 우리 자신의 일상적 지식을 이끌어내려 하고, 때때로 그는 우리가 무엇이라고 말할(say) 것인지를 묻는 방식으로 그 작업을(that) 수행한다. 이것이 하트의 법철학을 의미론(semantic)의 한 분야로 만드려고 볼 수 있을까? 하트는 철학의 ‘언어적 전환(linguistic turn)’에 영향을 받았고, 스스로 그 옹호자라 여겼다⁴⁴. 특히 그는 옥스퍼드에서 J. L. 오스틴(J. L. Austin)과 길버트 라일(Gilbert Ryle)이 전개한 일상 언어철학에 영향을 받았다⁴⁵. 그럼에도 이 책의 연대기적 위치와 철학적 계보를 고려할 때 가장 눈에 띄는 점은 『법의 개념(The Concept of Law)』에 언어분석이 거의 없다(little)는 것이다. 언어는 다양한 기능을 가지며, 문장은 맥락을 가지며, 일부 이론들은 개념의 사용기준(criteria)을 제시한다고 말할 수 있다는 점이 언급된다. 몇몇 지점에서 언어적 구별이 강조되긴 한다. (하트는 ‘강요당하다(be obliged)’와 ‘의무를 지다(be obligated)’ 사이에는 차이가 있으며, ‘규칙에 따라 행위한다’는 것과 ‘규칙을 가지고 있다’는 것 사이에도 차이가 있다고 주장한다.) 하지만 그것뿐이다. 언어철학자들의 이론 구성에 대한 적대감은 보이지 않는다. ‘법체계(legal system)’라는 개념이 가족 유사성(family resemblance) 개념이라는 식의 주장도 없다. 오히려 하트는 법체계가 되기 위한 필요충분조건(necessary and sufficient conditions)까지 제시한다! 그는 이 문제나 법철학의 다른 핵심 문제를 단어의 의미에 호소하는 방식으로 접근하지 않는다. 하트는 반복적으로 언어적

⁴⁴See Richard Rorty ed., *The Linguistic Turn: Recent Essays in Philosophical Method* (University of Chicago Press, 1967).

⁴⁵그리고 후기 비트겐슈타인(later Wittgenstein), 특히 그의 제자 프리드리히 바이스만(Friedrich Waismann)을 통해 수용된 견해도 참고할 수 있다. 하트와 그 당시 옥스퍼드 철학자들과의 개인적·지적 관계에 대한 통찰력 있는 논의는 니콜라 레이시(Nicola Lacey), *A Life of H. L. A. Hart: The Nightmare and the Noble Dream* (Oxford University Press, 2004)을 참조하라.

접근 방식의 무용함을 경고한다. “‘법이란 무엇인가?’라는 질문에 대해 ‘법’이나 ‘법체계’라는 단어의 사용에 관한 기존 관행을 상기시키는 것으로 답하는 것은,” 그는 말한다, “‘쓸모없다’” (5). 더 넓은 개념과 좁은 개념 중 어느 것을 택할 것인지를 판단하려면 의미론(semantics) 이상의 것이 필요하다. “이 문제를 단지 언어 사용의 적절성 문제로 본다면 우리는 이 문제를 충분히 다룰 수 없다”(209). 만약 누군가가 법철학의 방법론(methodology)에 관한 책을 쓰고자 한다면, 이 경고들과 동시에 책 전체에 드러나는 언어철학에 대한 호의적 태도를 조화롭게 해석할 필요가 있을 것이다. 그러나 하트는 어떤 방법론에 관한 책도 쓰고 있지 않다.

이 책의 제목을 포함하여 책 전반에 드러나는 수사적 표현은 언어철학의 색채를 띠고 있음은 부인할 수 없다. 그러나 좋은 사상사가는 표현 형식보다 내용에 주목해야 한다. 철학자가 자신이 무엇을 하고 있다고 생각했는지, 말했는지, 실제로 무엇을 했는지는 서로 다를 수 있다. (데이비드 흄(David Hume)은 정치학이 과학이 될 수 있다고 말했지만, 논고(Treatise)나 탐구(Enquiry) 어느 곳에서도 단 하나의 실험이나 증명을 제시하지 않았다.) 현대 철학의 수사적 스타일은 하트의 것과 매우 다르며, 하트의 스타일은 다시 벤담(Bentham)의 것과 매우 달랐다. 이러한 차이가 실제 기법의 차이를 얼마나 반영하는지는 분명하지 않다.

(ii) 명료화(clarification)와 비판(criticism)

이 책은 하트(Hart)가 ‘일반적이고 기술적인(general and descriptive)’ 법이론(legal theory)이라 부르는 유형을 옹호한다 (239-240). 그는 이것이 영국법(English law), 관습법(common law), 자본주의적 법(capitalist law)에 대한 이론이 아니라, 법 그 자체(as such)에 대한 이론이라고 말한다. 이 이론은 “도덕적으로 중립(morally neutral)이며 정당화 목적(justificatory aims)을 지니지 않는다. 즉, 내가 법에 대해 일반적으로 설명하는 형태나 구조에 대해 도덕적 혹은 기타의 근거에서 이를 정당화하거나 칭찬하려는 목적은 없다”고 밝히며, 낙관적으로 다음과 같이 덧붙인다. “다만 나는 이러한 구조들에 대한 명확한

이해가 법에 대한 유익한 도덕적 비판의 중요한 전제라고 생각한다”(240).

이 책이 정당화의 목적을 결여한다고 해서, 그것이 곧 도덕적으로 중립적이라는 의미는 아니다. 어쩌면 도덕적 편향이 무의식적으로 스며들 수 있다. 일부 사람들은 묘사(description)라는 것이 단순히 해당 대상에 관한 사실(facts)의 목록 이상일 수밖에 없다고 보고, 이런 점에서 이 책에도 도덕적 요소가 개입되었다고 본다. 관찰(observation)은 이론을 전제하며, 관찰에 기반한 묘사는 가치를 전제한다; 따라서 기술적 법철학(descriptive legal philosophy)은 불가능하다는 것이다. 그러나 이는 성급한 일반화이다. 사실의 명제(statement of fact)는 참(true) 혹은 거짓(false)으로 평가될 수 있다. 반면 묘사는 일반적으로 참이나 거짓으로 평가되지 않고, 유익하거나 무익한(helpful or unhelpful), 통찰력 있는지 여부(illuminating or unilluminating) 등으로 판단된다. 어떤 대상이나 사태(state of affairs)에 대해서도 가능한 묘사는 무한하다. 왜냐하면 각각에 관한 사실이 무한하기 때문이다. 실제의 묘사는 그에 관한 모든 사실의 목록이 아니라, 어떤 이유에서 중요하거나, 두드러지거나, 관련 있거나, 흥미롭다고 여겨지는 사실들의 선별(selection)과 배열(arrangement)이다. 모든 묘사는 특정한 가치들에 의해 전제되거나, 그 가치들의 관점에서 이루어진다. 그러나 이로부터 묘사를 제시하는 사람이 그러한 가치들을 승인하거나, 그것들이 도덕적 가치(moral values)라는 결론이 반드시 도출되지 않는다. 예컨대 사건 관리시스템(case-management system)을 ‘비효율적(inefficient)’이라 묘사하는 것은 가치중립적이지 않다. 이는 해당 시스템의 어떤 특징에 주목하게 만든다. 그러나 이러한 선별(selection)의 이유가 반드시 화자가 효율성(efficiency)을 가치 있다고 보거나, 더 나아가 가장 중요한 가치라고 보거나, 도덕적 가치라고 생각해서일 필요는 없다. 그는 청중이 그것을 중요한 것으로 본다고 생각하거나, 일반 사람들이 그러하다고 보거나, 해당 시스템을 사용하는 판사들이 그렇게 본다고 추측해서 그렇게 말할 수도 있다. 가능한 경우는 다양하다.

비판자들이 하트의 기술적 기획에 도덕적 요소의 스며듦을 감지한다고 여기는 지점을 하나 살펴보는 것도 유익할 수 있다. 그는 자신의 주된 논증을 허구의 사회발전사(fictional history of social development)를 통해 전개하는 것으로 잘 알려져 있다(91-99). 우리는 ‘원시적(primitive)’ 사회에서 출발한다. 이 사회에

서는 사회질서(social order)가 무엇을 해야 하는지에 대한 합의(consensus)를 통해 유지된다. 그러나 사회 변화와 함께 이 합의들은 불확실하게 되고(static), 정태적이며, 비효율적으로 된다. 이 결함들(defects)은 법이 등장하면서 보완되며, 법은 승인 규칙(rule of recognition), 변경규칙(rule of change), 재판규칙(rule of adjudication)과 같은 이차적 규칙들(secondary rules)을 통해 확실성(certainty), 역동성(dynamism), 효율성(efficiency)을 부여한다. 이렇게 ‘발전된(developed)’ 혹은 ‘복잡한(complex)’ 사회에서 우리는 더 나은 조건을 누리게 된다. 이 지점에서 비판자들이 반박에 나선다⁴⁶: 하트는 어떻게 법이 ‘결함’을 치유한다고 말하면서도, 법의 정당성에 대해서는 중립적이라고 할 수 있는가? 그는 어떻게 전(前)법적(pre-legal) 사회를 ‘원시적’이라고 부르면서도, 그것을 암묵적으로 비난하지 않는다고 말할 수 있는가?

이 문맥에서 ‘원시적(primitive)’이라는 말은 명백히 단순(simple)하다는 의미이며, 어리석거나 야만적(barbaric)이라는 뜻은 아니다. 그리고 단순한 사회들이 법을 가지지 않는 이유는 그들이 문명화되지 않아서가 아니라, 법이 필요하지(need) 않기 때문이다. 인간 본성이나 사회라는 것의 구조 속에 법이 필수라는 요소는 없다; 실제로 많은 사회가 법 없이도 잘 작동해왔다(91). 국제 영역에서도 볼 수 있듯, 고도로 체계화된 규칙 체계는 “필수품이 아니라 사치품”이다(235). 단순한 형태의 사회질서는 실제로 잘 작동한다. 예컨대 사회가 작고 안정적이며, 사회적·이념적으로 통합되어 있을 때 그러하다(91). 그러나 “이 외의 조건에서는 그러한 단순한 사회통제의 형태는 결함을 드러내며, 다양한 방식으로 보완될 필요가 있다”(92). 여기서 주목할 점은, 첫째로, 문제 삼는 ‘결함(defect)’은 도덕적 악(moral vice)이 아니라, 사회 통제 메커니즘의 기능적 결함(functional deficit)이라는 것이다. 이러한 결함이 도덕적으로 유감스러운 것인지 여부는, 그 통제 메커니즘이 선(good)을 향하는가, 악(evil)을 향하는가에 달려 있다. 더 효율적인 사회 통제가 도덕적으로 나쁜 것일 수도 있다. 둘째로, 결함이 있는 것은 단순한 사회 자체라기보다는, 통치 방식과 사회 복잡성 사이의 불일치이다. 결함은 낯선 사람들로 구성된 큰 사회를, 친구들로 이루어진 작

⁴⁶ Among many pouncers, see Stephen Guest, ‘Two Strands in Hart’s Concept of Law’ in Stephen Guest ed., *Positivism Today* (Dartmouth, 1996) 29.

은 사회처럼 다스리려 할 때 나타난다—일부 현대 공동체주의(communitarian) 정치이론의 오류처럼. 여기에는 단순한 사회(법이 없는)와 복잡한 사회(법이 있는) 사이에서 후자를 반드시 선호해야 한다는 어떠한 제안도 존재하지 않는다.

그러므로 이 논변은 하트가 추구한 중립성을 포기한 것으로 비난될 수 없다. 물론 하트는 이차적 규칙들의 등장에 주목하지만, 그것은 그가 그것이 중요하고 핵심적인 사실이라고 보기 때문이다. 그러나 그것이 바람직하다고 생각하기 때문은 아니다. 오히려 그는 위에서 본 것처럼, 그것이 도덕적으로 위험하다고 생각한다. 아이러니하게도, 편향은 오히려 하트의 논변을 일종의 근대주의적 승리론(modernist triumphalism)으로 해석하는 사람들 쪽에서 나타난다. 그들은 어떤 사회가 법체계를 결여하고 있다면, 그것은 근대의 성취 중 하나를 결여한 것이라고 본다. 따라서 ‘원시적’ 사회가 문명화되지 않았다고 보는 것은 편협하고 모욕적인 생각이므로, 후건부정법(modus tollens)에 따라, 모든 사회는 법체계를 가져야 한다. 그리고 어떠한 법철학이든 이러한 사회들을 법체계들로써(as) 간주하지 않는다면, 그것은 근대적 또는 서구적 법에 편향된 것이다. 이러한 논변의 구조는 놀랍다. 그것은 모든 사회가 법을 가져야 한다는 명제로부터 시작하여, 모든 사회가 실제로 법을 가지고 있다는 결론을 도출한다. 이 추론은 명백히 타당하지 않다(invalid). 또한 이는 하트가 거부한 전제를 바탕으로 한다. 그는 법에 대해 특별한 열정을 공유하지 않기 때문에, 그것이 어디에나 존재한다고 믿어야 할 필요를 느끼지 않는다.

이와 유사한 논점은 제10장에서 하트가 국제법(international law)을 체계(system)가 아니라 규칙들의 집합(set of rules)으로 규정하는 데에도 적용된다. 그는 국제법이 단순한 사회질서와 유사한 점이 있다고 본다. 국제법학자들은 분개한다. 하트는 국제법에 대해 ‘낮은 점수’를 주며, 그것을 특별한 것으로 대우하기보다는 ‘이단(outcast)’처럼 취급한다고 본다⁴⁷. 그들은 자신들의 학문 분야의 지위에 대해 걱정하는 나머지, 이 장의 핵심이 오히려 국제법을 옹호하고(defend) 있다는 점은 거의 눈치채지 못한다—즉, 중앙 주권자나 강제적 관할권이 없다는 이유로 국제법이 법이 아니라고 보는 잘못된 주장으로부터 국제법을

⁴⁷Ian Brownlie, ‘The Reality and Efficacy of International Law’ (1981) 52 British Yearbook of International Law 1, 7–8.

방어하고자 한 것이다. 하트는 국제법이 매우 체계적이라고는 보기 어렵다고 본다. 그는 국제법에서 전체적인 승인 규칙(rule of recognition) 같은 것을 발견하지 못한다. 그러나 그가 다른 이차적 규칙들이 존재할 가능성을 배제하는 것은 아니다. 예컨대 어떤 실체(entity)가 국가(state)인지 여부나 조약(treaty)을 채택하기 위한 요건 등에 관한 규칙들이 그것이다. 흥미롭게도, 국제법 자체에 관해 기술할 때(즉, 국제법 이론에 대해 논하지 않고 실제 국제질서에 대해 기술할 때), 국제법학자들 스스로도 그 핵심 규칙들 중 많은 것이 적용 유효성(effectiveness)이 부분적이며, 중요한 규범들에 대한 기준이 불안정하고, 재판제도들이 목적별로 분산되어 있으며, 국제법의 여러 영역이 여전히 이상적 수준에 머물러 있다는 것을 기꺼이 인정한다. 그러나 법의 체계성(systematization)은 본질적으로 정도의 문제(matter of degree)이며, 오늘날 국제법이 1961년보다 더 체계화되어 있다고 보는 것이 타당할 수 있다⁴⁸. 그렇다고 해서 그것이 국내법체계(domestic legal systems)와 동등하다고 보기는 어렵다. 하트가 이 점을 지적한다고 해서, 그가 국제법을 비판하거나 베스트팔렌식 국가주의(Westphalian statism)를 찬양하는 것은 아니다. 그는 국제법이 국내법과 유사한 점, 그리고 그렇지 않은 점을 이해하려는 것이다.

이 모든 것이 『법의 개념(The Concept of Law)』이라는 책이 정치적 도덕성(political morality)에 대한 일정한 관점을 전제로 구성되어 있다는 사실을 부인하는 것은 아니다. 이 책에는 하트의 밀적 자유주의(Millian liberalism)나 민주적 사회주의(democratic socialism)에 대한 직접적인 논의는 많지 않다. 그러나 그의 또 다른 도덕적 신념, 즉 가치 다원주의(value pluralism)의 뚜렷한 흔적이 있다. 그의 친구 아이제이아 벌린(Isaiah Berlin)처럼⁴⁹, 하트는 선(good)은 본질적으로 다원적(plural)이며, 실제 세계는 정당한 가치들 사이에서도 충돌이 자주 발생한다고 본다. 하나의 정당한 이익이 또 다른 이익의 희생을 통해 얻어질 수 있다는 것이다. 하트는 따라서 공리주의(utilitarianism)나 복지경제학(welfare

⁴⁸For a review of some of the issues see the editors' introduction to Samantha Besson and John Tasioulas eds., *The Philosophy of International Law* (Oxford University Press, 2010) 1–13, and sources therein cited.

⁴⁹Isaiah Berlin, *Four Essays on Liberty* (Oxford University Press, 1969), and also his 'On Value Pluralism' (1998) *New York Review of Books*, vol. XLV No. 8.

economics)에서 나타나는 축소적 일원론(reductive monism), 즉 궁극적으로 추구해야 할 가치는 오직 하나뿐이라는 입장에 반대한다. 동시에, 다양한 가치를 인정하되 이들이 ‘적절히 해석되면’ 결코 충돌하지 않는다고 주장하는 비축소적 일원론(nonreductive monism)에도 반대한다⁵⁰. 그는 “법과 법의 집행에는 다양한 종류의 탁월성(excellences)이 있을 수도, 없을 수도 있다”고 하며(157), 정의(justice)조차도 그러한 탁월성들 중 하나일 뿐이라고 말한다. 그의 가치 다원주의는 법적 추론에 대한 언급에서도 분명히 드러난다. “특히 중요한 헌법적 문제에 관한 사법적 판단(judicial decision)은 종종 도덕적 가치들 간의 선택을 포함하며, 단 하나의 뛰어난 도덕 원칙의 적용만으로 설명되지 않는다”(204). 이 점은 사법적 추론(judicial reasoning)에 깊은 함의를 지닌다. “이러한 원칙들이 다수 존재할 수 있기 때문에, 특정한 [사법적] 판단이 유일하게 정당하다는 것을 입증(demonstrate)할 수는 없다…” (205).

6. 요점(THE POINT)

하트(Hart)의 구상에 따라 하나의 일반 법이론(general jurisprudence)이 성공적으로 전개될 수 있다고 가정해 보자. 그렇다면 왜 그런 수고를 들여야 하는가? 이 책의 사상들과 씨름하는 일은 현대 법철학의 방대한 문헌에 입장하기 위한 일종의 입장료가 되어버렸다. 이 책은 과거 철학 저작들에 대한 유익한 논의를 포함하고 있다. 하지만 우리는 법이론서(jurisprudence)를 다른(other) 법이론서에 대해 알기 위해 주로 읽어야 한다는 생각에 대해, 그 누구보다 강력히 반대한 인물이 바로 하트 자신이다. 『법의 개념(The Concept of Law)』에는 학술 주석(scholarly notes)이 거의 없으며, 그나마도 책의 맨 뒤로 밀려 있으며, 그것들은 차라리 나중에 읽으라고 권고한다:

나는 이러한 배열이, 법이론에 관한 책이란 기본적으로 다른 책들에 무엇이 들어 있는지를 배우기 위한 책이라는 믿음을 약화시키는 것을 바란다. 이 믿음을 저술하는 사람이 갖고 있다면, 그 학문은

⁵⁰이 입장에 대한 가장 지속적인 옹호는 로널드 드워킨(Ronald Dworkin), *Justice for Hedgehogs* (Harvard University Press, 2011)을 보라.

거의 진전을 이루지 못할 것이며, 독자가 그 믿음을 갖고 있다면,
그 학문의 교육적 가치는 극히 제한된 수준에 머물 것이다 (vii쪽).

그러나 그러한 장애물을 제거하는 것이 의미 있으려면, 그 학문 영역 자체의 진보가 그 자체로 의미가 있을 경우에만 그렇다. 하트식의 분석적 법철학(analytic legal philosophy)은 특정 목적에 국한되지 않는 일반적 가치(non-specific value)를 지닌다: 그것은 면밀한 독해(close reading), 명료한 사고(clear thinking), 정밀한 논증(careful argument)을 중시하고 증진시킨다. 이러한 능력들은 유용한 기술이며, 교육적으로도 가치가 있다. 그러나 이를 습득할 방법은 많고, 굳이 법이론 연구가 그 가장 빠르거나 쉬운 길이라고 볼 이유는 없다.

일반 법이론에 대한 진정한 변론(apology)은 다음과 같은 주장이다: 법은 중요한 사회 제도(social institution)이며, 이와 같은 제도에 대한 심층적 이해는 그 자체로 가치가 있다. 우리는 법의 본성을 이해하고자 한다. 그것은 시장(market)이나 가족(family)의 본성을 이해하고자 하는 이유와 같다. 그렇다고 해서 우리가 시장이나 가족보다 법에 집중해야 한다는 주장이 성립하는 것은 아니며, 더 나아가 법을 더 깊이 이해하는 일이 법 관련 행동을 예측하거나 법과 제도를 개혁하는 일보다 더 중요하다는 것을 입증하는 것도 아니다. 그러나 이러한 대안들 중 어떤 것도 법이론만의 고유한 가치를 약화시키지는 않는다.

어떤 사람들은 법이론서를 읽으며 삶과 법에 대한 지침을 기대한다. 어떤 사람들은 그 지침을 제공하고자 법이론서를 쓴다. (마키아벨리처럼, 군주의 귀를 사로잡기 위해 쓰는 경우도 포함해서.) 만약 이것이 독자의 목적이라면, 일반 법이론은 실망을 안겨줄 수도 있다. 그것이 일종의 고급 ‘법정 조언서(high-brow amicus curiae brief)’로서 영향력을 행사한 예는 거의 없다. 물론 하나의 법정 판결(court case)이 법이론적 명제(jurisprudential theses)를 제기하거나 의존하는 경우는 있을 수 있다. 실제로 어떤 판결에서는 판사들이 법의 유효성(validity)과 실효성(efficacy) 사이의 관계, 벌금(penalty)과 세금(tax)의 차이, 혹은 법과 관습(custom)의 차이 등에 대해 의견을 제시한다. 그러나 그런 경우에도 법원은 지역적 교의적 제약(local doctrinal constraints) 내에서 해답을 모색하려 하며, 이 제약은 법철학이 반드시 따라야 할 것은 아니다. 우리는

사회 관습질서(customary social order)와 법체계(legal system)를 구별할 수 있는 충분한 이론적 근거를 가지고 있다. 그러나 특정한 법체계가 원주민 관습(aboriginal custom)을 하나의 독립된 법체제로 간주할 수도 있다. 그렇다면 그것이 하트의 이론을 반박하는가? 전혀 그렇지 않다. 「어업법(Fisheries Act)」이 포경(whaling)을 규제한다고 해서 고래(whale)가 물고기(fish)가 아니라는 확신이 흔들릴 이유는 없다. (그렇다고 해서 어업법에 잘못이 있다는 뜻도 아니다.)

역사적으로 볼 때, 『법의 개념』은 영미권에서 정치철학(political philosophy)이 부흥하던 전환기에 위치한 저작이다. 초판 출간 이후, 학계의 관심은 비교적 빠르게 가치 문제(value questions)로 옮겨갔다. 다음 세대의 주요 저작들은 정의(justice), 자유(liberty), 평등(equality)과 같은 개념들에 초점을 맞추었고, 법 제도나 구조에 대한 관심은 줄어들었다⁵¹. 하트의 책은 평가적 문제들(evaluative issues)을 결눈질하듯 살펴보긴 하지만—실제로 정의에 관해서도 일정한 논의가 있다—전반적으로 그것은 제도와 구조에 대한 책이다. 그리고 이러한 이유 때문에, 또 기술적 접근방식을 일관되게 유지하려는 태도 때문에, 이 책은 흔히 논변가들(advocates)의 단골 비난을 받는다: “불모적이다(sterile)” 혹은 “지루하다(boring)”는 것이다. 이러한 비난은 어떻게 이해해야 할까? 그것은 지적 편협성(intellectual narrowness)을 드러낼 뿐 아니라, 자기 성찰의 부족도 나타낸다. 법이 의심의 여지 없이(unquestionably) 흥미롭다고 생각하고, 다른 사안들도 어떤 소송의 가능성과 관련된 방식으로 설명되어야만 흥미롭게 여겨진다는 것은, 일종의 법률가적 자만이다—(이는 어떤 질문이 진정(really) 흥미로운 질문이 되기 위해서는 고객이 그 해답에 돈을 지불할 의사가 있어야 한다는 생각과 크게 다르지 않다.)

로널드 드워킨(Ronald Dworkin)은 “법철학(jurisprudence)은 중요하다. 왜냐하면 판사들이 어떻게 판결을 내리는지가 중요하기 때문이다”라고 썼다⁵². 그는 훨씬 이전에도 다음과 같이 썼다: “법원이 내리는 결정에 대해 일반적으로

⁵¹이 주제가 응용 도덕철학(applied moral philosophy)의 방향으로 지나치게 나아갔다는 제안은 제레미 월드론(Jeremy Waldron), 「Political Political Theory: An Oxford Inaugural Lecture」, <http://ssrn.com/abstract=2060344>에서 제시된다.

⁵²Ronald Dworkin, Law's Empire 1.

좋은 이유란 무엇인가? 이것이야말로 법철학의 그(the) 질문이다...”⁵³. 하트는 단지 가치 다원주의자(value pluralist)일 뿐 아니라, 지적 다원주의자(intellectual pluralist)이기도 하다. 그는 결론을 향해 직행하는 경쟁에 참여하지 않는다. 이 책의 제1장은 ‘지속되는 질문들(Persistent Questions)’이라는 제목이며, 복수형이다. 그 질문들은 다음과 같다: 법은 강제적 위협(coercive threats)과 어떤 관계에 있는가? 법의 의무적 강제력(obligatory force)은 어떤 의미를 가지며, 그것은 도덕적 의무(moral obligation)와 어떤 관계를 가지는가? 사회 규칙(social rules)이란 무엇이며, 법은 어떤 방식으로 규칙에 관한 것인가? 그러나 이들 중 어느 것도 법철학의 그(the) 질문이 아니다. 이들은 모두 법철학의 질문들(questions)일 뿐이다. 그렇다면 이 질문들은 흥미로운가? 물론 흥미롭다. 그러나 단순한 진실은, 사람들은 서로 다른 것에 흥미를 느낀다는 것이다. 데이비드 흄(David Hume)은 자신의 삶을 회고하며 이렇게 적었다: “나의 학구적 성향, 절제된 생활, 근면한 태도 때문에 가족은 법률이 내게 적합한 직업이라고 생각했다. 그러나 나는 철학과 일반 학문 외에는 도저히 흥미를 느끼지 못했다...”⁵⁴. 흄은 법을 도저히 견딜 수 없을 만큼 지루하게 여겼다. 그는 혼자가 아니다. 분명 그 반대의 기호를 가진 이들도 있다. 그러나 지적 취향이 어떻든 간에, 누구나 깨달을 수 있는 점은 다음과 같다—그리고 흄도 분명히 깨달았던 점이다: ‘흥미롭다’는 것은 대상 그 자체의 성질이 아니라, 대상과 한 개인 사이의 관계 속에서 발생하는 성질이다. 하트의 법철학은 소송과의 관련성은 제한적일 수 있지만, 그 문제 자체의 본질적 중요성을 인식하는 사람들, 혹은 더 넓은 정치적 관심을 지닌 사람들에게는 분명 흥미를 유발할 수 있다. 법정에서는 ‘당해 사안의 법(the law)이 무엇인가’를 아는 것이 ‘법(law)이 무엇인가’를 아는 것보다 중요하다. 그러나 법정 밖에서는, 하트가 상기시키듯이 실제의 법적 실천(law-in-action)의 대부분이 이루어지는 곳이며, 이때 법의 본질에 대한 질문이 제자리를 찾는다. 우리는 법을 통치 수단(governance)으로 삼아 무엇을 기대할 수 있는가? 그것의 이점은 무엇이며 위협은 무엇인가? 법의 지배(rule of law)를 왜 가치 있게 여겨

⁵³Ronald Dworkin, ‘Does Law Have a Function? A Comment on the Two-Level Theory of Decision’ (1965) 74 Yale Law Journal 640.

⁵⁴David Hume, ‘My Own Life’ in his Essays, Moral, Political and Literary, E. F. Miller, ed. (Liberty Press, 1987).

야 하는가? 우리는 법에 복종해야 하는가? 만약 그렇다면, 어디까지 복종해야 하는가? 그리고 물론, 우리는 왜 법을 가져야 하는가? 이런 질문을 던지는 사람, 혹은 더 이상 이런 질문을 피할 수 없다고 느끼는 사람이라면 누구든, 그 해답을 찾기 위해 일반 법이론의 도움을 필요로 하게 된다. 하트가 그 작업을 이렇게 훌륭하게 시작해 두었다는 것은 우리에게 정말로 행운이다.

Contents

1961년 제1판의 하트의 머리말(PREFACE)	i
1994년 제2판의 Bulloch와 Raz의 편집자 주(Editors' Note)	iii
2012년 제3판의 Leslie Green의 머리말(Preface to the Third Edition)	vi
2012년 제3판의 Leslie Green의 서론(INTRODUCTION)	viii
1. 하트의 메시지(HART'S MESSAGE)	viii
2. 사회적 구성물로서의 법(LAW AS A SOCIAL CONSTRUCTION)	x
3. 법과 권한 (LAW AND POWER)	xxiii
4. 법과 도덕 (LAW AND MORALITY)	xxx
5. 사실(fact), 가치(value), 방법(method)	xliii
6. 요점(THE POINT)	lii
I. 지속되는 질문들	1
1. 법이론의 난제들	1
2. 세 가지 반복되는 쟁점들	6
3. 정의(Definition)	14
주석(Notes)	19
CHAPTER I 주석	19
CHAPTER I 제3판 주석	22
II. 법(Laws), 사령(Commands), 그리고 명령(Orders)	25
1. 명법의 다양성(Varieties of Imperatives)	25
2. 법(law)과 강압적 명령(coercive orders)	28
CHAPTER II 주석	34

CHAPTER II 제3판 주석	37
III. 법의 다양성	39
1. 법의 내용	40
2. 적용 범위	54
3. 기원의 방식	57
CHAPTER III 주석	63
CHAPTER III 제3판 주석	67
IV. 주권자와 수범자(SOVEREIGN AND SUBJECT)	69
1. 복종의 습관과 법의 연속성	70
2. 법의 지속성	81
3. 입법권에 대한 법적 한계	85
4. 입법기관 뒤의 주권자	90
CHAPTER IV 주석	98
CHAPTER IV 제3판 주석	100
V. 1차 규칙과 2차 규칙의 결합으로서의 법	103
1. 새로운 출발	103
2. 규범적 의무(obligation)의 개념	105
3. 법의 구성요소 (The Elements of Law)	116
CHAPTER V 주석	125
CHAPTER V 제3판 주석 (CHAPTER V 3rd ed. NOTES)	127
VI. 법체계의 기초(THE FOUNDATIONS OF A LEGAL SYSTEM)	129
1. 승인 규칙과 법적 유효성(RULE OF RECOGNITION AND LE- GAL VALIDITY)	129
2. 새로운 질문들(New Questions)	140
3. 법체계의 병리학	148
CHAPTER VI 주석	155
CHAPTER VI 제3판 주석	160
VII. 형식주의(Formalism)와 규칙 회의주의(Rule-Scepticism)	163
1. 법의 개방적 직조(The Open Texture of Law)	163

2. 규칙 회의주의(rule-scepticism)의 여러 형태	175
3. 사법적 결정에서의 최종성(Finality)과 무오류성(Infallibility)	181
4. 승인 규칙의 불확실성 (UNCERTAINTY IN THE RULE OF RECOGNITION)	188
CHAPTER VII 주석	197
CHAPTER VII 제3판 주석	200
VIII. 정의(Justice)와 도덕성(Morality)	203
1. 정의의 원칙들 (Principles of Justice)	205
2. 도덕적 의무(Moral Obligation)와 법적 의무(Legal Obligation)	216
3. 도덕 이상(Moral Ideals)과 사회적 비판(Social Criticism)	230
CHAPTER VIII 주석	236
CHAPTER VIII 제3판 주석	238
IX. 법과 도덕 (Laws and Morals)	241
1. 자연법과 법실증주의 (Natural Law and Legal Positivism)	241
2. 자연법의 최소 내용 (The Minimum Content of Natural Law)	249
3. 법적 유효성과 도덕적 가치	256
CHAPTER IX 주석	271
CHAPTER IX 제3판 주석	273
X. 국제법(INTERNATIONAL LAW)	277
1. 의심의 근원(SOURCES OF DOUBT)	277
2. 의무와 제재(OBLIGATIONS AND SANCTIONS)	280
3. 의무와 국가의 주권(OBLIGATION AND THE SOVEREIGNTY OF STATES)	284
4. 국제법과 도덕(INTERNATIONAL LAW AND MORALITY)	292
5. 형식 및 내용의 유사성(Analogies of Form and Content)	297
CHAPTER X 주석	304
CHAPTER X 제3판 주석	306
후기(POSTSCRIPT)	308
서론(INTRODUCTORY)	308

1. 법이론의 본성(THE NATURE OF LEGAL THEORY)	309
2. 법실증주의의 본성	315
3. 규칙의 본성(The Nature of Rules)	326
4. 원칙과 승인 규칙(Rule of Recognition)	336
5. 법과 도덕 (LAW AND MORALITY)	341
6. 사법적 재량(Judicial Discretion)	345
POSTSCRIPT 주석	350
POSTSCRIPT 제3판 주석	350

I. 지속되는 질문들

1. 법이론의 난제들

‘법(law)이란 무엇인가?’라는 질문만큼 오랫동안 제기되어 왔고, 진지한 사상가들에 의해 이렇게 다양하고 기묘하며 때로는 역설적인 방식으로 답변되어 온 인간 사회에 관한 질문은 거의 없다. 고전 및 중세의 법 ‘본성(nature)’에 관한 사유를 제쳐두고, 지난 150년 동안의 법이론만을 살펴보더라도, 우리는 다른 어떤 독립된 학문 분야에서도 찾아볼 수 없는 독특한 상황을 발견하게 된다. ‘화학이란 무엇인가?’ 또는 ‘의학이란 무엇인가?’라는 질문에 대해 이처럼 방대한 문헌이 헌신된 예는 없다. 이러한 과학들을 배우는 학생은 교과서의 첫 페이지에 나오는 몇 줄의 설명 정도만 접할 뿐이며, 거기서 제시되는 답변은 법학도에게 주어지는 답변과는 매우 다르다. 그 누구도 의학이란 ‘의사가 병에 대해 하는 일’이라거나 ‘의사가 무엇을 할 것인지를 예측하는 것’이라고 굳이 주장하지 않는다. 또한 일반적으로 화학의 핵심적이고 특징적인 일부로 간주되는, 예컨대 산(acid)에 대한 연구가 사실은 화학이 아니라고 말하지도 않는다. 그러나 법의 경우에는 이처럼 기묘하게 보이는 주장들이 종종 제기되어 왔으며, 단순히 제기되었을 뿐만 아니라, 그것이 법의 본질적 성격에 대한 오랜 오해를 벗겨낸 진리를 제시하는 것인 양 열정적으로, 또 때로는 웅변적으로 주장되기도 했다.

‘공직자들이 분쟁에 대해 하는 일이 곧 ... 법이다’;¹ ‘법이란 법원이 무엇을 할 것인지에 대한 예언이다 ... 그것이 내가 말하는 법이다’;² 제정법(statutes)은 ‘법의 부분이 아니라 ... 법의 원천(sources of Law)이다’;³ ‘헌법법(constitutional law)은 단지 실정적 도덕(positive morality)일 뿐이다’;⁴ ‘도둑질하지 말라; 누군가가 도둑질을 하면 그는 처벌받을 것이다. (p. 2) ... 만약 어떤 규범이 존재

¹Llewellyn, *The Bramble Bush* (2nd edn., 1951), p. 9.

²O. W. Holmes, ‘The Path of the Law’ in *Collected Papers* (1920), p. 173.

³J. C. Gray, *The Nature and Sources of the Law* (1902), s. 276.

⁴Austin, *The Province of Jurisprudence Determined* (1832), Lecture VI (1954 edn., p. 259).

한다면, 첫 번째 규범은 두 번째 규범에 포함되어 있으며, 두 번째 규범이야말로 유일한 진정한 규범이다 … 법이란 제재(sanction)를 규정하는 1차 규범(primary norm)이다.’⁵

이들은 법의 본성에 관해 제기된 수많은 주장(assertions)과 부정(denials) 중 일부일 뿐이며, 적어도 처음 보았을 때는 낯설고 역설적으로 보인다. 이들 중 일부는 우리의 깊은 신념과 충돌하는 듯하며 쉽게 반박될 수 있는 것처럼 보인다. 그래서 우리는 다음과 같이 말하고 싶은 유혹을 느낀다. ‘제정법은 분명히 법이다. 적어도 법의 한 종류이며, 다른 종류들도 있을 수 있다’: ‘공직자나 법원이 무엇을 하는지가 곧 법이라는 것은 말이 안 된다. 왜냐하면 공직자나 법원을 만들기 위해서는 법이 먼저 존재해야 하기 때문이다’.

그러나 이러한 역설적으로 보이는 발언들은 상식의 명백한 사실을 의심하는 데 종사하는 몽상가나 전문 철학자들에 의해 제기된 것이 아니다. 그것은 오랜 기간 법에 대해 성찰해온 이들, 즉 주로 법을 가르치거나 실무에서 다루거나, 때로는 판사로서 법을 집행하는 것을 직업으로 삼은 법률가들(lawyers)의 성찰의 산물이다. 더 나아가, 그들이 말한 것들은 실제로 그들의 시대와 맥락에서 법에 대한 우리의 이해를 심화시켰다. 이와 같은 주장들은 그 문맥 안에서 이해될 때, 계몽적이면서도 동시에 당혹스럽다: 그것들은 차가운 정의(definition)라기보다는, 법에 대한 어떤 진리를 지나치게 과장한 표현이며, 그 진리는 오랫동안 간과되어 왔던 것이다. 이러한 주장은 우리가 이전에는 보지 못했던 법의 측면을 보게 하는 빛을 비추지만, 그 빛이 너무 강렬한 나머지 나머지 부분을 가려버리고, 결국 전체를 명확히 파악하지 못하게 만든다.

책 속에서 끝없이 이어지는 이러한 이론적 논쟁과는 대조적으로, 대부분의 사람들은 ‘법’의 사례를 쉽게, 자신 있게 들 수 있는 능력을 지니고 있다. 대부분의 영국인은 살인을 금지하거나, 소득세 납부를 요구하거나, 유효한 유언장을 작성하기 위해 필요한 절차를 규정하는 법이 있다는 사실을 알고 있다. 영어 단어 ‘law’를 처음 접하는 어린이 또는 외국인을 제외하면, 거의 모든 사람들은 이와 같은 예시들을 얼마든지 더 많이 들 수 있다. 그리고 대부분의 사람들은 더 나아가, 어떤 것이 영국법인지 알아내는 방법에 대해서도 적어도 개요 정도는

⁵Kelsen, *General Theory of Law and State* (1949), p. 61.

설명할 수 있다. 사람들은 전문가에게 자문할 수 있으며, 이와 관련된 모든 질문에 대해 최종적인 권위를 가진 법원이 있다는 사실을 알고 있다. (p. 3) 이보다 더 많은 사실들이 일반적으로 널리 알려져 있다. 대부분의 교육받은 사람들은 영국의 법들이 일종의 체계(system)를 이루고 있다는 인식을 가지고 있다. 또 프랑스, 미국, 소련 등 – 심지어 독립된 ‘국가(country)’로 간주되는 세계의 거의 모든 지역에는, 중요한 차이가 있음에도 불구하고 대체로 구조가 유사한 법체계(legal systems)가 존재한다는 사실도 알고 있다. 만약 이러한 사실들을 모른 채 교육을 마쳤다면, 그 교육은 심각하게 실패한 것이며, 다른 법체계들 간의 유사점을 말할 수 있다고 해서 그것이 대단한 교양의 표시라고 보기도 어렵다. 어느 정도 교육을 받은 사람이라면 누구나 다음과 같이 기본적 골격을 통해 그 핵심 요소들을 식별할 수 있어야 한다. 그것들은 다음과 같은 요소들로 구성된다: (i) 특정한 유형의 행위를 금지하거나 명령하고 이를 위반할 경우 제재를 가하는 규칙들; (ii) 특정한 방식으로 타인에게 피해를 준 경우 배상을 요구하는 규칙들; (iii) 유언, 계약 또는 권리를 부여하고 의무를 생성하는 기타 약정을 유효하게 만들기 위해 필요한 절차를 규정하는 규칙들; (iv) 이러한 규칙이 무엇인지, 언제 위반되었는지를 판단하고, 제재나 배상의 액수를 결정하는 법원(courts); (v) 새로운 규칙을 제정하고 기존 규칙을 폐지하는 입법기관(legislature).

만약 이러한 사실들이 일반적으로 잘 알려져 있다면, ‘법이란 무엇인가?’라는 질문이 왜 그토록 지속되어 왔으며, 그에 대해 이처럼 다양하고도 비범한 답변들이 제시되어 온 이유는 무엇일까? 이는 아마도 현대 국가들의 법체계(legal systems)와 같이, 누구도 이성적으로는 의심하지 않는 분명한 표준 사례들 외에도, 그 ‘법적 성격(legal quality)’에 대해 교육받은 일반인들뿐만 아니라 심지어 법률가들조차도 주저하는 의심스러운 사례들이 존재하기 때문일 것이다. 원시법(primitive law)과 국제법(international law)은 그러한 의심스러운 사례들 중 대표적이며, 이들에 대해 일반적으로 통용되는 ‘법(law)’이라는 단어 사용의 적절성에 의문을 제기할 만한 이유들이 존재한다고 많은 이들이 느껴 왔다. 비록 그 이유들이 결정적인 경우는 드물지만 말이다. 이와 같은 의문스러운 또는 이견이 가능한 사례들의 존재는 실제로 오랜 기간 이어져 온, 다소 불모의 논쟁을 야기해 왔으나, 그렇다고 해서 그것이 ‘법이란 무엇인가?’라는 지속적인

질문에서 나타나는 법의 일반적 성격에 대한 난해함 전체를 설명할 수는 없다. 이러한 사례들이 그 난제의 뿌리가 아니라는 점은 두 가지 이유로 명확하다.

첫째, 이러한 사례들에서 주저함이 느껴지는 이유는 자명하다. 국제법은 입법기관(legislature)이 없고, 국가들은 (p. 4) 사전 동의 없이는 국제법정에 회부될 수 없으며, 중앙집중적이고 효과적인 제재 체계도 존재하지 않는다. 일부 원시법의 유형들, 그리고 이들로부터 현대 법체계가 점차 진화했을지도 모를 경우들도 이와 유사하게 이러한 요소들을 결여하고 있다. 그리고 이러한 사례들이 표준 사례로부터 이 점에서 벗어난다는 사실이 그것들을 의심스러운 것으로 보이게 만든다는 점은 누구에게나 명확하다. 이 점에는 아무런 신비로움이 없다.

둘째, ‘법(law)’이나 ‘법체계(legal system)’ 처럼 복잡한 용어들만이 명백한 표준 사례와 논란이 되는 경계 사례를 모두 포함하게 된다는 점은 특이한 일이 아니다. 이제는 잘 알려진 사실이지만(한때는 충분히 강조되지 않았지만), 우리가 인간 삶이나 세계의 특징들을 분류할 때 사용하는 거의 모든 일반 용어들에 있어서도 이와 같은 구분은 필수적이다. 때로는, 어떤 표현의 사용에 있어 명백하고 표준적인 사례(또는 전형적 사례)와 의심스러운 사례들 간의 차이는 단지 정도의 차이일 뿐이다. 머리가 반짝이는 매끈한 두피를 가진 사람은 명백히 대머리(bald)이고, 무성한 머리숱을 가진 사람은 명백히 그렇지 않지만, 여기저기 머리칼이 드문드문 있는 제3의 사람을 대머리라고 할 수 있는지에 대해서는 실용적인 쟁점이 걸려 있다면 끝없이 논쟁될 수 있을 것이다.

때로는 표준 사례로부터의 벗어남이 단순한 정도 차이가 아니라, 실제로는 여러 가지 별개의 요소들이 보통 함께 나타나는 복합적 사례에서 일부 요소가 결여된 경우에 발생한다. 예를 들어, 수상비행기(flying boat)는 ‘선박(vessel)’인가? 퀸(queen) 없이 진행되는 체스 게임은 여전히 ‘체스(chess)’인가? 이러한 질문들은 표준 사례의 구성에 대해 성찰하고 이를 명시화하게끔 유도하기 때문에 교훈적일 수 있다. 그러나 이른바 경계적(borderline) 특성이 너무도 일반적인 현상이기 때문에, 법에 대한 오랜 논쟁을 그것만으로 설명할 수는 없다는 점도 분명하다. 더구나, 가장 유명하고 논쟁적인 법이론들 중 오직 소수만이 ‘원시법’이나 ‘국제법’이라는 표현을 해당 사례에 적용하는 것이 적절한지에

초점을 맞추고 있을 뿐이다.

사람들이 법의 사례들을 인식하고 인용할 수 있는 일반적 능력과, 법체계의 표준 사례에 대해 일반적으로 알려진 사실들을 고려해보면, (p. 5) ‘법이란 무엇인가?’라는 지속적인 질문을 그저 이미 익숙한 것들을 상기시키는 방식으로 간단히 끝낼 수 있을 것처럼 보이기도 한다. 우리가 (앞서 3쪽에서) 한 교육받은 사람의 입을 빌려 낙관적으로 제시한 지방법체계(municipal legal system)의 핵심 요소에 대한 개요를 반복하는 방식으로 말이다. 우리는 이렇게 말할 수 있을 것이다. ‘이것이 “법(law)”과 “법체계(legal system)”라는 말로 의미되는 표준 사례이다. 이 표준 사례들 외에도, 사회적 삶 속에는 이러한 주요 특징 중 일부를 공유하면서도 다른 일부는 결여한 제도적 구조들이 존재한다. 이것들은 법으로 분류하는 것이 적절한지에 대해 결정적 논거가 존재하지 않는 논쟁적 사례들이다.’

이러한 방식은 간결하고 명료하다는 장점은 있겠지만, 그 외에는 특별히 추천할 만한 점이 없다. 무엇보다도, ‘법이란 무엇인가?’라는 질문에 대해 가장 크게 당혹감을 느끼는 이들은 이 요약적 답변이 제시하는 익숙한 사실들을 잊었거나, 그것을 상기시켜야 할 만큼 몰랐던 이들이 아니다. 이 질문을 지속시켜 온 깊은 당혹감은 무지나 망각, 혹은 ‘법(law)’이라는 단어가 통상 지시하는 현상을 인식할 능력 부족 때문이 아니다. 더 나아가, 우리가 제시한 법체계에 대한 요약적 설명을 검토해 보면, 그것은 다양한 종류의 법률들이 일반적으로 함께 작동한다는 사실 외에 거의 아무것도 주장하지 않는다. 이는 요약 설명 속에서 법체계의 전형적 요소로 등장하는 ‘법원(court)’과 ‘입법기관(legislature)’ 자체가 법의 산물이기 때문이다. 어떤 사람이 사건을 재판할 수 있는 관할권(jurisdiction)이나 법을 제정할 수 있는 권한(authority)을 부여하는 일정한 유형의 법률이 있을 때에만, 그것은 법원이나 입법기관이 된다.

따라서 이러한 질문에 대한 간단한 접근법은, 결국 ‘법’과 ‘법체계’라는 단어 사용을 지배하는 기존의 관습들을 상기시키는 것 이상은 하지 못하므로 무의미하다. 분명히 가장 바람직한 접근은, ‘법이란 무엇인가?’라는 질문에 선불리 답변하기보다는, 그 질문을 제기하거나 답하려 했던 사람들이, 비록 법에 대한 친숙함이나 사례를 식별하는 능력은 의심할 여지 없이 충분함에도 불구하고,

실제로 무엇에 대해 당혹감을 느껴왔는지를 먼저 파악하는 것이다. 그들은 무엇을 더 알고 싶어 하며, 왜 그것을 알고 싶어 하는가? 이 질문에 대해서는 일반적 수준에서의 답변이 가능하다. 왜냐하면 법의 본성에 관해 논박과 반론의 지속적 중심이 되어 온 몇 가지 반복되는 주요 주제들이 존재하며, (p. 6) 이것들이 앞서 언급한 바와 같은 과장되고 역설적인 주장들을 촉발시켜 왔기 때문이다. 법의 본성에 대한 사유는 길고 복잡한 역사를 지니고 있지만, 회고해 보면 그것은 거의 끊임없이 소수의 핵심적인 쟁점들에 집중되어 있었음을 알 수 있다. 이러한 쟁점들은 단순히 학술적 논의의 즐거움을 위해 자의적으로 선택되거나 창작된 것이 아니다. 그것들은 모든 시대에 걸쳐 법에 대해 자연스럽게 오해를 낳기 쉬운 측면들에 관련된 것이며, 따라서 법에 대해 견고한 이해와 전문성을 갖춘 사람 깊은 사람의 마음속에서도 혼란과 그에 따른 명확성에 대한 요구가 공존할 수밖에 없는 지점들이기 때문이다.

2. 세 가지 반복되는 쟁점들

여기에서는 그러한 주요 반복 쟁점들 중 세 가지를 구분하고, 왜 그것들이 결국 법의 정의(definition)에 대한 요구나 ‘법이란 무엇인가?’라는 질문의 형태로, 혹은 더 모호한 방식의 질문인 ‘법의 본성(nature) 또는 본질(essence)이 무엇인가?’라는 형태로 통합되어 나타나는지를 이후에 설명할 것이다.

이 세 가지 쟁점 중 두 가지는 다음과 같은 방식으로 제기된다. 언제, 어디서나 법의 가장 두드러진 일반적 특징은, 법이 존재한다는 것은 어떤 종류의 인간 행위가 더 이상 선택 사항이 아니라, 어떤 의미에서는 의무적(obligatory)이라는 것이다. 그러나 이처럼 겉보기에는 단순한 법의 특징은 실제로는 단순하지 않다. 왜냐하면, 선택 불가능하고 의무적인 행위의 영역 내에서도 우리는 서로 다른 형식을 구분할 수 있기 때문이다. 가장 단순한 의미에서 어떤 행위가 더 이상 선택사항이 아니게 되는 경우는, 한 사람이 다른 사람에게 어떤 행동을 하도록 강요하는 상황이다. 이때 신체가 실제로 밀리거나 당겨지는 식의 물리적 강제가 있는 것이 아니라, 거부할 경우 불쾌한 결과가 따를 것이라는 협박(threat)에 의해 강요되는 경우이다. 예컨대, 권총강도가 희생자에게 지갑을

건네라고 명령하고, 거부할 경우 총을 쏘겠다고 위협하는 경우, 희생자가 순응한다면 우리는 그가 강요(obliged) 되었다고 말한다. 어떤 이들에게는, 이러한 상황 – 한 사람이 위협을 수반하는 명령(order)을 내리고, 이 의미에서 타인을 강요하여 따르게 하는 상황 – 에서야말로 법의 본질(essence), 또는 최소한 ‘법학(jurisprudence)의 열쇠’가 있다고 보이기도 한다.⁶ 이는 (p. 7) 영국의 법철학에 지대한 영향을 끼친 오스틴(Austin)의 분석이 출발한 지점이다.

물론, 법체계가 이러한 측면을 포함하는 경우가 자주 있다는 점에는 의심의 여지가 없다. 특정한 행위를 범죄로 선언하고, 그 행위에 대해 어떤 처벌이 부과되는지를 명시하는 형벌 제정법(penal statute)은 일종의 확대된 ‘총 든 권총강도’ 상황처럼 보일 수도 있으며, 유일한 차이점은 그 명령이 특정한 개인에게가 아니라, 그러한 명령을 관습적으로 따르는 집단 전체를 향하고 있다는 점뿐일 수도 있다. 그러나 법의 복잡한 현상을 이처럼 단순한 요소로 환원하려는 시도는 매력적으로 보일 수 있음에도, 면밀히 살펴보면, 그러한 환원은 오히려 왜곡이며 혼란의 원천이 되어 왔다. 형벌 제정법의 경우조차도, 이 단순한 용어로 분석하는 것이 가장 설득력 있어 보일 때조차 그러하다. 그렇다면 법과 법적 의무(legal obligation)는 협박에 뒷받침된 명령과 어떻게 다르며, 어떠한 관련을 갖는가? 이것이야말로 항상 ‘법이란 무엇인가?’라는 질문 속에 잠재해 있는 핵심 쟁점이었다.

두 번째 쟁점은 또 다른 방식으로 어떤 행위가 선택 사항이 아니라 의무적일 수 있다는 점에서 제기된다. 도덕 규칙(moral rules)은 개인의 자율적 선택 영역에서 특정한 행위를 제외시키고, 그에게 의무(obligation)를 부과한다. 마치 법체계가 위협을 수반한 명령의 단순한 사례들과 밀접하게 연결된 요소들을 포함하고 있는 것처럼, 그것은 또한 도덕성과 관련된 특정한 측면들과도 밀접하게 연관된 요소들을 명백히 포함하고 있다. 두 경우 모두, 그 관계를 정확히 규정하는 데 어려움이 있으며, 그 명백한 유사성을 실제 ‘동일성(identity)’으로 착각하려는 유혹이 존재한다. 법과 도덕은 공통된 어휘를 공유할 뿐만 아니라, 법적·도덕적 의무, 권리, 책임이라는 표현들이 양쪽 모두에 존재한다. 그리고 모든 지방법체계는 특정한 근본적 도덕 명령들의 실질을 재현한다. 살인이나

⁶Austin, op. cit., Lecture I, p. 13. He adds ‘and morals’.

무분별한 폭력 사용은 법과 도덕의 금지가 일치하는 가장 명백한 예에 불과하다. 게다가, ‘정의(justice)’라는 하나의 개념은 두 영역을 연결해주는 것으로 보인다. 정의는 법에 특히 적합한 덕목일 뿐만 아니라, 가장 ‘법적인’ 덕목이기도 하다. 우리는 ‘법에 따른 정의(justice according to law)’를 생각하고 말하면서도, 법 자체의 정의로움 혹은 부정의(justice or injustice of the laws) 역시 논한다.

이러한 사실들은, 법은 도덕(morality)이나 정의(justice)의 한 ‘분야(branch)’로 이해하는 것이 가장 적절하며, 명령과 위협의 통합이라기보다는 도덕 또는 정의 원칙과의 일치(congruence)가 (p. 8) 법의 ‘본질(essence)’이라는 견해를 지지하는 듯하다. 이러한 견해는 중세 스콜라 자연법 이론(scholastic theories of natural law)뿐 아니라 오스틴으로부터 계승된 법실증주의(legal positivism)를 비판하는 일부 현대 법이론에도 특징적으로 나타난다. 그러나 이와 같이 법을 도덕과 밀접하게 동일시하려는 이론들 역시, 결국에는 서로 다른 유형의 의무적 행위를 혼동하는 경향이 있으며, 법 규칙과 도덕 규칙 간의 종류 차이와 그 요구사항의 차이를 충분히 설명하지 못하는 경향이 있다. 이러한 차이들은 유사성과 수렴만큼이나 중요하다. 따라서 ‘부정의한 법은 법이 아니다(an unjust law is not a law)’⁷라는 주장은, ‘제정법은 법이 아니다’ 또는 ‘헌법법은 법이 아니다’라는 주장 못지않게 과장되고 역설적인 울림을 가진다. 법이론의 역사는 이러한 극단 사이의 진동을 보여주는 특징을 갖는다. 도덕과 법이 동일한 권리와 의무의 어휘를 공유한다는 사실로부터 잘못된 결론을 끌어낸 것에 불과하다고 본 사람들은, 그것에 대해 똑같이 과장되고 역설적인 방식으로 반박하곤 했다. ‘법이란 법원이 실제로 무엇을 할 것인지에 대한 예언이며, 그것 이상으로 허세를 부릴 것은 아무것도 아니다.’⁸

세 번째 주요 쟁점은 ‘법이란 무엇인가?’라는 질문을 끊임없이 자극하는 보다 일반적인 문제이다. 언뜻 보기에는, 법체계(legal system)가 규칙들(rules)로 구성되어 있다는 주장은 거의 의심받을 일도, 이해하기 어려운 일도 없어 보인다. 위협을 수반한 명령의 개념에서 법 이해의 열쇠를 찾는 이들이든, 혹은

⁷ ‘Nam mihi lex esse non videtur quae justa non fuerit’: St. Augustine I, De Libero Arbitrio; Aquinas, Summa Theologica, 1–11, Qu. 95 Art. 2; Qu. 96 Art. 4.

⁸ Holmes, loc. cit.

도덕(morality)이나 정의(justice)와의 관계에서 그것을 찾는 이들이든 모두, 법이 규칙을 포함하거나, 아니면 상당 부분 규칙으로 구성된다고 말한다. 그러나 이처럼 별 문제가 없어 보이는 개념에 대한 불만, 혼란, 불확실성이야말로 법의 본질(nature)에 대한 당혹감의 핵심을 이루고 있다. 규칙이란 무엇인가? 규칙이 존재한다고 말하는 것은 무슨 의미인가? 법원은 정말로 규칙을 적용하는가, 아니면 단지 그런 척을 하는 것인가? 이 개념에 대해 질문이 제기되기 시작하면—특히 20세기 법철학에서 그러하였듯이—의견의 심각한 분열이 나타난다. 우리는 여기서 그것들을 간략히 개요만 제시할 것이다.

(p. 9) 규칙에 여러 다른 유형이 존재한다는 점은 물론 참이다. 이것은 단지 법적 규칙 외에도 예절의 규칙, 언어의 규칙, 게임과 동호회의 규칙 등이 존재한다는 명백한 의미에서뿐 아니라, 더 미묘한 의미에서도 그러하다. 즉, 한 영역 내에서도 규칙이라 불리는 것들은 서로 다른 방식으로 발생할 수 있으며, 관련된 행위와의 관계에서도 매우 다를 수 있다. 예컨대 법 내에서도 어떤 규칙은 입법(legislation)을 통해 만들어지지만, 다른 규칙은 그러한 의도된 행위에 의해 만들어지지 않는다. 더 중요한 것은, 어떤 규칙은 강제적(mandatory)으로, 사람들에게 그들의 의사와 무관하게 폭력을 자제하거나 세금을 납부하는 등의 행동을 요구한다는 점이다. 반면, 결혼, 유언, 계약을 성립시키기 위한 절차나 형식, 요건을 규정하는 규칙은 사람들이 자신이 원하는 바를 실현하기 위해 무엇을 해야 하는지를 지시한다. 이 두 가지 유형의 규칙 간의 대조는 게임의 규칙에서도 발견된다. 예컨대, 반칙(foul play)이나 심판에 대한 욕설을 금지하는 규칙과, 점수를 얻거나 승리하기 위해 무엇을 해야 하는지를 명시하는 규칙이 그것이다. 그러나 이러한 복잡성을 잠시 제쳐두고, 형사법(criminal law)의 전형적 사례인 첫 번째 유형의 규칙만 고려하더라도, 이 단순한 강제 규칙이 존재한다는 진술의 의미에 대해서는 현대의 많은 학자들 사이에서도 견해가 크게 갈린다. 어떤 이들은 이 개념을 극히 불가해한 것으로 간주한다.

처음에 우리는 이 단순한 강제 규칙 개념에 대해 아마도 자연스럽게 다음과 같은 설명을 하고 싶어질 것이다: 규칙이 존재한다는 것은 단지 어떤 집단의 사람들, 혹은 그들 대부분이 특정한 상황에서 ‘규칙으로서(as a rule)’ 즉, 일반적으로(generally) 유사한 방식으로 행동한다는 것을 의미한다. 예컨대, 영국에

교회 안에서 모자가 금지되거나, ‘God Save the Queen’이 연주될 때 일어서는 규칙이 존재한다고 말하는 것은, 이 설명에 따르면, 단지 대부분의 사람들이 그러한 행동을 일반적으로 수행한다는 의미일 뿐이다. 하지만 분명 이것만으로는 부족하다. 이런 설명은 부분적으로는 의미를 담고 있지만, 사회 집단 내의 단순한 행동 수렴만으로는 ‘규칙’이 존재한다고 할 수 없다. 예컨대 모든 이들이 아침마다 차를 마시거나 매주 영화관에 간다고 해도, 그것을 요구하는(requiring)는 규칙이 있는 것은 아니다. 단순한 행동 수렴과 (p. 10) 사회 규칙의 존재는 언어적으로도 차이를 드러낸다. 후자를 묘사할 때 우리는 (꼭 사용해야 하는 것은 아니지만) ‘must’, ‘should’, ‘ought to’ 같은 표현을 사용하게 되며, 이는 전자의 경우 사용하면 오해를 불러일으킬 수 있다. 예컨대 영국에서는 매주 영화관에 가야 한다(must)거나 가야만 마땅하다(ought to or should)는 규칙은 없다. 단지 사람들이 정기적으로 영화관을 찾는 것뿐이다. 그러나 교회에서는 남자가 모자를 벗어야 한다는 규칙은 존재한다(is).

그렇다면 단순한 행동 수렴과, ‘must’, ‘should’, ‘ought to’ 같은 단어로 표현되는 규칙의 존재 사이의 핵심적 차이는 무엇인가? 이 점에 대해 법이론가들은 특히 오늘날 들어 의견이 크게 나뉘고 있다. 이 쟁점이 전면화된 데에는 여러 요인이 작용했다. 법적 규칙의 경우, 이 핵심적 차이—즉 ‘must’나 ‘ought’ 요소—는 특정한 행위로부터의 일탈이 적대적 반응을 초래할 가능성, 그리고 법적 규칙의 경우에는 공직자에 의해 처벌될 가능성에 있다고 종종 여겨진다. 반면 매주 영화관에 가는 것과 같은 단순한 집단 습관(group habits)의 경우, 이러한 일탈은 처벌은 물론 질책조차 유발하지 않는다. 그러나 특정한 행동을 요구하는 규칙이 존재하는 경우, 그것이 법적이지 않더라도(예: 교회에서 모자를 벗어야 하는 규칙), 그러한 일탈은 대개 일정한 반발을 유발하게 된다. 법적 규칙의 경우, 이와 같은 결과는 예측 가능하고 제도적으로 조직되어 있으나, 비법적 규칙의 경우에는 비슷한 반응이 예상되더라도 조직화되어 있지는 않다.

처벌의 예측 가능성(predictability of punishment)이 법규범(legal rules)의 중요한 측면이라는 것은 명백하다. 그러나 이를 사회규범(social rule)이 존재한다는 진술이 의미하는 바의 전부로 받아들이거나, 규범에 수반되는 ‘~해야 한다’(must 또는 ought)의 요소를 설명하는 것으로 받아들이는 것은 불가능하다. 이와

같은 예측적 설명(predictive account)에 대해서는 많은 비판이 제기되어 왔지만, 그중 특히 스칸디나비아의 한 법이론 학파 전체의 특징을 이루는 비판은 주목할 만하다. 그 비판은 다음과 같다. 범규범으로부터의 일탈(deviation)을 처벌하는 판사나 공직자(official)의 (또는 비법적(non-legal) 규범으로부터의 일탈을 꾸짖거나 비판하는 사인(private person)의) 행위를 면밀히 살펴보면, (p. 11) 이 행위들 속에서 규범(rule)은 예측적 설명이 전혀 설명하지 못하는 방식으로 작동하고 있다는 것이다. 즉, 판사는 처벌을 내릴 때 그 규범을 자신의 지침(guide)으로 삼고, 규범의 위반을 자신의 이유(reason)이며 정당화(justification)의 근거로 삼는다. 그는 그 규범을 ‘자신과 다른 이들이 그러한 일탈을 처벌할 가능성이 있다’는 진술(statement)로 보지 않는다. 물론 제3자의 관찰자(spectator)는 규범을 그러한 방식으로 볼 수는 있겠지만, 판사에게는 그러한 예측 가능성은 자신의 목적과 무관하며, 규범이 지침이자 정당화의 근거라는 점이 본질적이다. 이와 같은 구조는 비법적 규범의 위반에 대해 이루어지는 비공식적인 질책(informal reproofs)에서도 마찬가지로 나타난다. 이러한 질책들 또한 단지 예측 가능한 반응(predicted reactions)에 그치지 않으며, 오히려 규범의 존재가 그 반응을 지도(guide)하고 정당화(justify)한다고 여겨지는 것이다. 따라서 우리는 어떤 사람이 규범을 위반했기 때문에(because) 그를 질책하거나 처벌한다고 말한다. 이는 단순히 우리가 그를 질책하거나 처벌할 가능성(probability)이 있었음을 말하는 것이 아니다.

그런데 이러한 예측적 설명(predictive account)에 대한 비판을 제기한 학자들 가운데 일부는, 이 문제에 여전히 모호함이 존재한다고 고백한다. 명료하고 확고한 사실적(factual) 용어로 분석하기 어려운 어떤 요소가 존재한다는 것이다. 규칙(rule)이라는 것이, 반복적이고 따라서 예측 가능한 처벌(punishment)이나 질책(reproof)을 동반하는 일탈 행위에 대한 반응 외에, 단순한 집단 습관(group habit)과는 구별되는 무엇을 내포하고 있을 수(can) 있는가? 분명히 파악 가능한 이러한 사실들 이외에, 판사가 스스로 처벌을 정당화하거나 그 이유(reason)를 제공받는 어떤 추가적인 요소가 정말 존재하는가? 바로 이 추가 요소를 명확히 설명하기 어려운 점 때문에, 이러한 비판자들은 이 지점에서 모든 규칙에 관한 논의와 ‘must’, ‘ought’, ‘should’와 같은 단어의 사용은 혼란

을 내포하고 있으며, 아마도 그것이 사람들의 눈에 중요해 보이게 만들지만, 실제로는 합리적 근거가 없다고 주장하게 된다. 이러한 비판자들의 입장에 따르면, 우리는 단지 어떤 규칙 속에 특정한 행위를 해야만 한다(binds us)는 무엇인가가 존재한다고 생각할(think) 뿐이며, 그 행위를 수행함에 있어 자신을 지도(guide)하거나 정당화(justify)해주는 무언가가 있다고 믿는 것은 일종의 착각에 불과하다. 비록 유용한 착각일 수는 있겠지만, 그럼에도 그것은 환상이라는 것이다. 이들이 주장하기로는, 집단행동(group behaviour)의 명확히 확인 가능한 사실들과, 일탈에 대한 예측 가능한 반응이라는 사실을 넘어서 존재하는 것은 단지 우리가 규범에 따라 행동해야 한다는 강력한 강제감(compulsion)과, 규범을 따르지 않는 자에게 대항해야 한다는 내면의 감정(feelings)일 뿐이다. 우리는 이러한 감정을 감정 그 자체로 인식하지 못하고, 외부에 있는 어떤 것, 즉 이러한 행위를 인도하고 통제하는 우주의 어떤 보이지 않는 (p. 12) 구성 요소가 존재한다고 상상한다. 이와 같은 믿음은 허구(fiction)의 영역에 속하며, 법이란 원래부터 그러한 허구와 연루되어 왔다고 흔히 말해진다. 오직 우리가 이러한 허구를 채택했기 때문에만, 우리는 정부가 ‘사람이 아니라 법에 의해 지배된다 (government of laws not men)’는 진지한 진술을 할 수 있는 것이다. 이러한 유형의 비판은, 그 긍정적 주장의 타당성 여부와 무관하게, 적어도 사회규범 (social rules)과 단순한 일치적 습관(convergent habits of behaviour) 사이의 구별에 대한 보다 명확한 해명을 요청하는 것이다. 이 구별은 법을 이해하는 데 있어 결정적이며, 본서의 초기 장들 상당 부분이 바로 이 문제를 다루고 있다.

그러나 법규범의 성격에 대한 회의(scepticism)가 항상, 구속력 있는 규칙(binding rule)이라는 개념 자체를 혼란스럽거나 허구적이라 비판하는 극단적 형태로만 나타나는 것은 아니다. 오히려 영국과 미국에서 가장 널리 퍼져 있는 회의적 시각은, 법체계(legal system)가 전적으로(wholly), 혹은 심지어 주로(primarily) 규칙들로 구성되어 있다는 관점을 재검토하라고 요청한다. 물론 법원(courts)은 그들의 판결(judgments)을, 그 결정이 고정되고 명확한 의미를 가진 사전 규칙(predetermined rules)의 필연적 귀결인 것처럼 보이도록 구성한다. 아주 단순한 사건에서는 그럴 수도 있다. 그러나 법원을 곤란하게 만드는 대다수의 사건들에서는, 그러한 규칙이 담겨 있다고 주장되는 성문법(statutes)

이나 선례(precedents) 어느 것도 오직 하나의 결과만을 허용하지 않는다. 중요한 사건들의 대부분에서 판사(judge)는 선택의 여지 없이 결론에 도달하는 것이 아니라, 언제나 대안을 놓고 선택해야 한다. 그는 하나의 법률 조항에 주어질 수 있는 여러 가지 의미들 중에서 선택해야 하며, 특정 선례가 ‘의미하는 바’(amounts to)에 대해 경쟁하는 해석들 중에서 결정해야 한다. 단지 판사는 법을 ‘창조(makes)’ 하는 것이 아니라 ‘발견(finds)’ 한다는 전통적 관념만이 이러한 사실을 은폐하고, 마치 그들의 판결이 사전에 존재하던 명료한 규칙으로부터 자연스럽게 연역(deduction)된 것처럼 보이게 만든다. 법규범(legal rules)들은 중심(core)에는 누구도 이견을 제기하지 않는 명확한 의미를 가질 수 있으며, 어떤 경우에는 그 규칙의 의미에 대해 분쟁이 발생한다는 것을 상상하기조차 어려울 수 있다. 예를 들어, 1837년 유언법(Wills Act) 제9조(s. 9)는 유언장(will)에는 두 명의 증인(witnesses)이 있어야 한다고 규정하고 있는데, 이는 해석상의 문제를 거의 일으킬 것 같지 않다. 그러나 모든 규칙은 그 가장자리(penumbra)에는 불확실성(uncertainty)이 존재하며, 이 영역에서는 판사가 대안들 사이에서 선택을 해야 한다. 유언자가(will-maker 또는 testator) 유언장에 서명(sign)해야 한다는 유언법의 단순해 보이는 조항조차도 특정 상황에서는 해석상의 의문을 제기할 수 있다. 유언자가 가명을(pseudonym) 사용했다면? 다른 사람의 손에 의해 손이 유도되었다면? 이니셜만 기입했다면? (p. 13) 자신의 이름을 정확히 적었지만 마지막 페이지 하단이 아니라 첫 번째 페이지 상단에 적었다면? 이 모든 경우가 법규범의 의미 내에서 ‘서명’(signing)에 해당하는가?

만약 이러한 정도의 불확실성이 사적인 민사법(private law)의 일상적 영역에서도 발생할 수 있다면, “어떠한 사람도 적법절차(due process of law) 없이 생명, 자유 또는 재산을 박탈당해서는 안 된다”고 규정하는, 미국 연방헌법(Federal Constitution)의 제5조 및 제14조 수정조항(Fifth and Fourteenth Amendments)과 같은 장엄한 표현(magniloquent phrases) 속에서는 훨씬 더 큰 불확실성이 존재하지 않겠는가? 이에 대해 한 저자⁹는 다음과 같이 말한 바 있다. 이 표현의 진정한 의미는 실은 매우 분명하다는 것이다. 즉, “어떤 w는 x 또는 y 없이 z

⁹J. D. March, ‘Sociological Jurisprudence Revisited’, 8 Stanford Law Review (1956), p. 518.

의 조건 하에서만 가능하다”는 의미이며, 여기서 w, x, y, 그리고 z는 매우 넓은 범위 내의 어떤 값이든 가질 수 있다. 이야기의 끝을 장식하듯, 회의론자들은 우리에게 다음 사실을 상기시킨다. 규칙들이 불확실할 뿐만 아니라, 법원의 해석은 권위적(authoritative)일 뿐 아니라 최종적(final)일 수도 있다는 것이다. 이러한 모든 점을 고려할 때, 법을 본질적으로 규칙의 문제로 간주하는 관념은 지나치게 과장된 것이며, 어쩌면 그 자체로 하나의 오류가 아닌가? 이러한 사유는 앞서 인용한 역설적 부정(paradoxical denial)으로 이어진다. 즉, “성문법(statutes)은 법의 근원(sources)이지, 그 자체가 법의 일부는 아니다.”¹⁰

3. 정의(Definition)

여기 이제 세 가지 반복되는 쟁점이 있다. 첫째, 법은 위협을 수반한 명령과 어떻게 구별되며 어떤 관계에 있는가? 둘째, 법적 의무(legal obligation)는 도덕적 의무(moral obligation)와 어떻게 구별되며 어떤 관계에 있는가? 셋째, 규칙(rules)이란 무엇이며, 법은 어느 정도까지 규칙의 문제인가? 이 세 가지 쟁점에 대한 의심과 당혹을 해소하려는 것이 ‘법의 본성(nature)’에 대한 대부분의 사유의 주된 목적이었다. 이제 왜 이러한 사유들이 대개 ‘법의 정의(definition)’에 대한 탐구로 여겨져 왔는지, 또 익숙한 정의의 형식들이 왜 지속되는 난점과 의문들을 거의 해결하지 못했는지도 알 수 있다. 정의라는 말이 암시하듯, 정의는 본질적으로 구분선을 긋는 일, 즉 언어가 독립된 단어로 구별해 온 서로 다른 사물의 종류를 나누는 일이다. 이러한 구분선의 필요는, 일상에서 그 단어를 아무 문제 없이 사용하는 사람이라 할지라도, 자신이 감지하는 구별이 어떤 것인지 명확히 말하거나 (p. 14) 설명하지 못할 때 자주 나타난다. 우리 모두는 때때로 이러한 곤경에 빠진다. ‘코끼리는 보면 알겠는데 설명은 못하겠다’는 사람의 상황이 그것이다. 성 아우구스티누스(St. Augustine)의 시간 개념에 대한 유명한 말¹¹도 같은 곤경을 표현한 것이다. “그렇다면 시간은 무엇인가? 아무도 묻지 않으면 나는 안다. 그러나 누군가 그것을 설명하라 하면 나는 모른다.” 많은 숙련된 법률가들도 이와 같은 방식으로 느껴 왔다. 즉, 그들은 법을 알고

¹⁰Gray, loc. cit.

¹¹Confessiones, xiv. 17.

있지만, 법과 다른 사물과의 관계에 대해 설명할 수 없는 많은 것들이 있으며, 그것을 완전히 이해하지는 못한다고 느낀다. 마치 익숙한 도심에서 목적지까지 길은 잘 찾아가지만, 다른 사람에게 그 길을 설명해줄 수는 없는 사람과 같다. 정의를 요구하는 사람은 자신이 어렴풋이 감지하고 있는 법과 다른 사물들 사이의 관계를 명확히 보여주는 지도가 필요한 것이다.

이러한 경우, 단어의 정의는 그런 지도를 제공할 수 있다. 그것은 한편으로 우리가 어떤 단어를 사용할 때 암묵적으로 따르는 원리를 명시적으로 드러내며, 동시에 우리가 그 단어를 적용하는 현상들과 다른 현상들 간의 관계를 드러낸다. 정의가 ‘단지 말뿐’이거나 ‘단어에 관한 것일 뿐’이라는 말도 있지만, 그것이 일상적으로 사용되는 표현일 때는 특히 오해를 불러올 수 있다. 삼각형을 ‘세 개의 직선으로 이루어진 도형’이라거나, 코끼리를 ‘두꺼운 피부, 상아, 코를 가진 네발짐승’으로 정의하는 경우조차, 비록 겸손한 수준일지라도, 그 단어의 표준적 사용법과 그 단어가 가리키는 대상을 모두 가르쳐준다. 이러한 익숙한 유형의 정의는 두 가지 기능을 동시에 수행한다. 하나는 그 단어를 다른 잘 알려진 용어들로 번역하는 코드나 공식(formula)을 제공하고, 다른 하나는 그 단어가 어떤 종류의 대상에 사용되는지를 알려주며, 그것이 더 넓은 범주의 것들과 공유하는 특징들과, 같은 범주 내 다른 것들과 구별되는 특징들을 함께 제시한다. 이러한 정의를 탐색하고 찾아낼 때, 우리는 ‘단지 단어들을 들여다보는 것’이 아니라, ‘우리가 단어로 지칭하고자 하는 실재를 함께 바라보게 된다. 단어에 대한 감각을 날카롭게 함으로써, 우리가 말하는 현상에 대한 인식 역시 날카롭게 되는 것이다.’¹²

(p. 15) 이러한 정의 형식은 (per genus et differentiam, 즉 속(genus)과 종차(differentia)를 통한 정의) 삼각형이나 코끼리 같은 단순한 사례에서 볼 수 있으며, 가장 단순하면서도 어떤 이들에게는 가장 만족스러운 정의 방식이다. 왜냐하면 그것은 정의된 단어를 언제든지 대체할 수 있는 표현을 제공해 주기 때문이다. 하지만 이 정의 형식은 항상 사용 가능한 것도 아니며, 사용 가능 하더라도 항상 유익한 것도 아니다. 그것의 성공은 특정한 조건들이 충족될

¹²J. L. Austin, ‘A Plea for Excuses’, Proceedings of the Aristotelian Society, vol. 57 (1956–7), p. 8.

때에만 가능하다. 그 중에서도 가장 중요한 조건은, 우리가 그 특성을 분명히 이해하고 있는 더 넓은 범주, 즉 속(genus)이 존재해야 한다는 것이다. 정의는 우리가 알고 있는 일반적인 것들 속에서 어떤 특수한 하위 범주를 위치시키는 것이기 때문이다. 그런데 그 속 자체에 대해 모호하거나 혼란스러운 개념만 갖고 있다면, 그 속의 일원이 무엇인지를 알려주는 정의는 아무런 도움이 되지 못한다. 이 조건은 법의 경우에 이러한 정의 형식을 쓸모없게 만든다. 법이 속하는 친숙하고 잘 이해된 일반 범주라는 것이 존재하지 않기 때문이다. 법의 정의에 있어 가장 뚜렷한 후보는 ‘행동 규칙(rules of behaviour)’이라는 일반 범주일 것이다. 그러나 우리가 이미 본 바와 같이, 규칙의 개념 자체가 법의 개념만큼이나 난해하기 때문에, 법을 규칙의 일종으로 파악하는 정의는 법에 대한 이해를 더 이상 나아가게 하지 못한다. 법을 익숙하고 잘 이해된 일반 항목 속의 하위 항목으로 위치시키는 데 성공하는 정의 형식보다 더 근본적인 무언가가 요구된다.

그러나 법의 경우, 이러한 단순 정의 방식의 유용성을 방해하는 더 큰 장애물들이 있다. 일반 표현을 이러한 방식으로 정의할 수 있다는 가정은, 정의하고자 하는 것의 모든 사례가 그 표현이 지시하는 공통된 특성을 지닌다는 암묵적 전제 위에 놓여 있다. 물론, 비교적 초급 단계에서조차 경계 사례(borderline cases)의 존재는 우리의 주의를 끌게 되며, 이는 일반 용어의 여러 사례들이 동일한 특성을 가진다는 전제가 하나의 독단적인 명제일 수 있음을 보여준다. 흔히 일상어, 심지어 기술적 용어의 사용조차도 상당히 ‘열려(open)’ 있어서, 통상 함께 수반되는 특성들 중 일부만 가진 사례에도 용어가 확장 적용되는 것을 금지하지 않는다. 우리가 이미 본 바와 같이, 국제법(international law)이나 특정 형태의 원시법(primitive law)에 대해 그러한 확장에 찬성하거나 반대하는 주장 모두 일리가 있다. 더 중요한 (p. 16) 점은, 그러한 경계 사례 외에도 일반 용어의 여러 사례들은 단순 정의 방식이 전제하는 것과는 전혀 다른 방식으로 서로 연결되어 있다는 사실이다. 예컨대 ‘발(foot)’이라는 말이 사람에게도, 산의 밑부분에도 사용되는 경우처럼, 유추(analogy)를 통해 연결될 수 있다. 또는 각기 다른 방식으로 중심 요소에 관계된 경우도 있다. 예컨대 ‘건강하다(healthy)’는 말은 사람뿐 아니라 피부, 아침 운동에도 쓰이는데, 이 중 피부는

건강함의 징후(sign)이고, 운동은 원인(cause)이다. 다시 말해, 이들은 중심 개념을 기준으로 서로 다른 방식으로 관련되어 있다. 또는—아마도 법체계를 구성하는 다양한 규칙 유형을 통일시키는 원리와 유사한 방식으로—각 사례가 하나의 복합 활동의 서로 다른 구성 요소들일 수 있다. ‘철도(railway)’라는 형용사는 기차뿐 아니라 선로, 역, 짐꾼, 철도회사 등에 쓰이며, 이들은 이와 같은 통일 원리에 따라 연결되어 있다.

물론, 여기서 논의한 단순하고 전통적인 정의 형식 이외에도 다양한 정의 방식이 존재한다. 그러나 우리가 앞서 확인한 세 가지 핵심 쟁점의 성격을 떠올려보면, ‘법이란 무엇인가?’라는 반복되는 질문에 대해 만족스러운 답변을 줄 수 있을 만큼 간결한 정의는 존재할 수 없다는 것이 분명하다. 이 쟁점들은 서로 너무 다르며, 그 각각이 너무 근본적이기 때문에, 그러한 방식으로 해결될 수 없다. 간결한 정의를 제시하려는 시도들의 역사 자체가 이를 보여준다. 그럼에도 이 세 가지 쟁점을 하나의 질문, 또는 정의 요청으로 묶으려는 본능은 잘못된 것이 아니었다. 왜냐하면 우리는 이 책의 진행 과정에서, 이 세 가지에 대한 공통된 답변의 일부를 이루는 중심 요소들을 분리해내고 그 특징을 규명하는 것이 가능하다는 것을 보여줄 것이기 때문이다. 이 요소들이 무엇이며, 왜 이 책에서 그토록 중요한 위치를 부여받는지, 먼저 오스틴(Austin)이 제시한 단순한 ‘위험을 수반한 사령(command)’ 개념에서 법 이해의 열쇠를 찾으려는 이론의 결함을 자세히 고찰해 봄으로써 가장 잘 드러날 것이다. 이 단순 명령 이론의 문제점을 비판적으로 분석하는 것이 다음 세 장(chapters)의 주된 과제이다. (p. 17) 우리가 이 이론을 먼저 비판하고, 그 주요 경쟁자인 ‘법은 도덕과 필연적 연결을 갖는다’는 전통적 이론을 이후 장에서 다루기로 한 것은, 현대 법이론이 발전해온 역사적 순서를 의도적으로 무시한 것이다. 왜냐하면 도덕과의 연결을 강조하는 이 경쟁 이론은 오스틴보다도 앞선 벤담(Bentham) 시대부터 존재해 왔으며, 오스틴 자신이 주요 비판 대상으로 삼은 바 있기 때문이다. 만일 이러한 비역사적 접근에 대해 변명이 필요하다면, 그것은 이 단순 명령 이론의 오류들이 오히려 더 복잡한 경쟁 이론들의 오류보다 진리에 더 가까운 방향을 가리키기 때문이라고 하겠다.

이 책의 여러 부분에서는 ‘법’ 또는 ‘법체계’라는 표현의 적용 가능성에

대해 법이론가들이 의문을 품어온 경계 사례들에 대한 논의가 등장할 것이다. 하지만 이러한 의문들에 대한 해답은 이 책의 부차적 관심일 뿐이다. 이 책의 목적은 ‘법’이라는 단어의 적절한 사용 여부를 판단하기 위한 규칙을 제시하는 정의를 제공하는 데 있는 것이 아니다. 그것은 오히려 지방법체계(municipal legal system)의 고유한 구조에 대한 분석을 개선하고, 법, 강제(coercion), 도덕이라는 사회 현상의 유형들 사이의 유사성과 차이를 더 잘 이해하도록 함으로써 법이론을 진전시키는 데 있다. 이 책의 다음 세 장에서의 비판적 논의 과정에서 확인되고, 제5장과 제6장에서 자세히 설명될 일련의 요소들은 바로 이러한 목적을 위해 기능하며, 책의 나머지 부분에서 그 역할이 입증된다. 이러한 이유로, 이 요소들은 법 개념의 핵심 요소들이자, 법 개념의 명료화를 위한 가장 중요한 요소들로 간주된다.

주석(Notes)

이 책의 본문은 자족적인(self-contained) 구조를 가지고 있으므로, 독자는 각 장을 처음부터 끝까지 읽은 뒤에 이 주석 부분을 참고하는 것이 가장 좋을 수 있다. 본문의 각주는 인용문의 출처, 그리고 인용된 사례(case)나 법령(statute)에 대한 간단한 정보만을 제공한다. 이에 반해, 다음의 주석들은 다음과 같은 세 가지 유형의 내용을 독자의 주위에 환기시키기 위해 마련되었다: (i) 본문에 제시된 일반적 진술에 대한 추가적인 예시나 사례; (ii) 본문에서 채택하거나 언급한 견해를 더 확장하거나 비판한 문헌; (iii) 본문에서 제기된 물음들에 대한 추가적인 탐구를 위한 제안. 이 책 자체에 대한 모든 인용은 장 번호와 절 번호만으로 간단히 표기한다 (예: 제1장 제1절). 다음은 본문에 사용된 주요 약어(abbreviation)들이다:

Austin, The Province	오스틴, 『법철학의 관할 범위(<i>The Province of Jurisprudence Determined</i>)』 (하트 편, 런던, 1954)
Austin, The Lectures	오스틴, 『실정법 철학 강의(<i>Lectures on the Philosophy of Positive Law</i>)』
Kelsen, General Theory	켈젠, 『법과 국가의 일반이론(<i>General Theory of Law and State</i>)』
BYBIL	영국 국제법 연보(<i>British Year Book of International Law</i>)
HLR	하버드 로 리뷰(<i>Harvard Law Review</i>)
LQR	법 분기별 리뷰(<i>Law Quarterly Review</i>)
MLR	현대 법 리뷰(<i>Modern Law Review</i>)
PAS	아리스토텔레스 학회 발표집(<i>Proceedings of the Aristotelian Society</i>)

CHAPTER I 주석

1-2쪽. Llewellyn, Holmes, Gray, Austin, Kelsen의 인용문들은 모두, 저자의 견해에 따르면, 일반적인 법률 용어에 의해 가려졌거나 이전의 이론가들에 의해 과도하게 간과된 법의 어떤 측면을 강조하기 위해 사용된 역설적이거나 과장된 표현이다. 중요한 법학자에 관해서는, 그가 한 법에 대한 진술이 문자 그대로 참인지 거짓인지를 판단하기에 앞서, (1) 그가 자신의 진술을 뒷받침하기 위해 제시한 구체적 이유와, (2)

그 진술이 대체하고자 한 법 개념 또는 법 이론을 먼저 검토하는 것이 종종 유익하다.

간과된 진리를 강조하는 수단으로서, 이와 유사한 역설적 또는 과장된 주장 방식은 철학에서도 흔히 볼 수 있다. J. Wisdom, 'Metaphysics and Verification' (*Philosophy and Psychoanalysis*, 1953); Frank, *Law and the Modern Mind* (런던, 1949), 부록 VII ('Notes on Fictions') 참조.

이 페이지들에 인용된 다섯 개의 주장 속에 담긴 이론들은 다음에서 분석된다: 제7장 제2·3절 (Holmes, Gray, Llewellyn), 제4장 제3·4절 (Austin), 제3장 제1절 35-42쪽 (Kelsen).

4쪽. 표준 사례와 경계 사례. 여기서 언급된 언어적 특징은 일반적으로 제7장 제1절 '법의 개방적 직조(The Open Texture of Law)'에서 논의된다. 이 특징은 '법', '국가', '범죄' 등의 일반 용어에 대한 정의가 명시적으로 요구될 때뿐만 아니라, 일반적 용어로 구성된 규칙을 특정 사례에 적용할 때 사용되는 추론의 성격을 규정하려는 시도에서도 염두에 두어야 한다. 이 언어적 특징의 중요성을 강조한 법학자들로는 다음이 있다: Austin, *The Province*, Lecture VI, 202-207쪽, 및 *Lectures in Jurisprudence* (5판, 1885), 997쪽 ('Note on Interpretation'); Glanville Williams, 'International Law and the Controversy Concerning the Word "Law"', 22 *BYBIL* (1945); 'Language in the Law' (5편의 논문), 61 및 62 *LQR* (1945-6). 단, 후자의 경우 J. Wisdom이 *Philosophy and Psycho-Analysis* (1953) 수록 논문 'Gods' 및 'Philosophy, Metaphysics and Psycho-Analysis'에서 제시한 비평 참조.

6쪽. Austin의 의무 개념. *The Province*, Lecture I, 14-18쪽; *The Lectures*, Lecture 22, 23 참조. 의무 개념과, '의무를 가진 것(having an obligation)'과 '강제에 의해 강요 받는 것(being obliged)' 사이의 차이는 제5장 제2절에서 자세히 분석된다. Austin의 분석에 대한 주석은 제2장 아래, 282쪽 참조.

8쪽. 법적 의무와 도덕적 의무. 법이 도덕과의 연결을 통해 가장 잘 이해된다는 주장은 제8·9장에서 분석된다. 이 주장은 매우 다양한 형태를 띤다. 고전 및 중세 스콜라 자연법 이론에서처럼, 이 주장은 근본적인 도덕적 구별이 인간 이성에 의해 발견 가능한 '객관적 진리'라는 주장을 수반하기도 하지만, 법과 도덕의 상호의존성을 강조하면서도 도덕의 본성에 대해 이런 관점을 채택하지 않는 법학자들도 많다. 제9장 주석, 아래 302쪽 참조.

10쪽. 스칸디나비아 법이론과 구속 규칙 개념. 영어 독자에게 가장 중요한 이 학파의 저작은 Hägerström (1868-1939), *Inquiries into the Nature of Law and Morals* (Broad 번역, 1953), 그리고 Olivecrona, *Law as Fact* (1939)이다. Olivecrona는 법 규칙의 성

격에 대한 그들의 견해를 가장 명확히 서술하고 있다. 그는 미국 법학자들이 선호한 법 규칙에 대한 예측적 분석을 비판하는데 (op. cit. 85-88쪽, 213-215쪽), 이 비판은 Kelsen, *General Theory* (165쪽 이하, 'The Prediction of the Legal Function')에 나타난 유사한 비판과 비교할 가치가 있다. 이 두 법학자가 많은 점에서 견해를 공유하면서도 왜 규칙의 성격에 대해 전혀 다른 결론에 도달하는지를 묻는 것도 흥미롭다. 스칸디나비아 학파에 대한 비판으로는 다음을 참조: Hart, Hägerström 서평, *Philosophy* 제30권 (1955); 'Scandinavian Realism', *Cambridge Law Journal* (1959); Marshall, 'Law in a Cold Climate', *Juridical Review* (1956).

12쪽. 미국 법이론에서의 규칙 회의론(rule-scepticism). 제7장 제1·2절 '형식주의와 규칙 회의론(Formalism and Rule-scepticism)' 참조. 여기서는 이른바 '법 현실주의(Legal Realism)'로 알려진 주요 이론들이 검토된다.

12-13쪽. 일상어 의미에 대한 의심. 'sign(표지)' 또는 'signature(서명)'의 의미에 관한 사례로는 *Halsbury, Laws of England* (2판) 제34권, 제165-169절 및 *In the Estate of Cook* (1960), 1 AER 689 및 그에 인용된 사례 참조.

13쪽. 정의. 정의의 형식과 기능에 대한 현대 일반 이론은 Robinson, *Definition* (옥스퍼드, 1952) 참조. 전통적인 *per genus et differentiam* 정의 방식의 한계는 Bentham, *Fragment on Government* (제5장 제6절 주석), Ogden, *Bentham's Theory of Fictions* (75-104쪽) 참조. Hart, 'Definition and Theory in Jurisprudence', 70 *LQR* (1954); Cohen and Hart, 'Theory and Definition in Jurisprudence,' *PAS* 보충권 제29권 (1955)도 참조.

'법(law)' 개념에 대한 정의는 다음을 참조: Glanville Williams, 앞서 인용한 저작; R. Wollheim, 'The Nature of Law', 2 *Political Studies* (1954); Kantorowicz, *The Definition of Law* (1958), 특히 제1장. 일상적으로 의심 없이 사용되는 용어에 대해서도 정의가 왜 필요한지, 그리고 그것이 어떤 명료화 기능을 수행할 수 있는지를 보여주는 일반 논의로는 다음을 참조: Ryle, *Philosophical Arguments* (1945); Austin, 'A Plea for Excuses', 57 *PAS* (1956-7), 15쪽 이하.

15쪽. 일반 용어와 공통 속성. 어떤 일반 용어(예: '법', '국가', '국민', '범죄', '선', '정의')가 정확히 사용되기 위해서는 그 용어가 적용되는 사례들이 모두 '공통된 속성'을 공유해야 한다는 무비판적인 믿음은 많은 혼란을 초래해 왔다. 법철학에서는, 그러한 용어를 다양한 사물에 적용하는 유일하게 정당한 이유는 공통된 속성의 존재라는 가정 아래, 정의를 위해 공통 속성을 찾아내려는 헛된 시도에 많은 시간과 창의를 낭비되어 왔다(예: Glanville Williams, 앞서 인용). 다만, 일반 용어의 성격에 대한 이러한 잘못된 이해가 항상, 이 저자가 말하는 바와 같은 '언어적 질문'과 사실 문제 간의 혼동까지

수반하는 것은 아니라는 점에 주의해야 한다.

법적, 도덕적, 정치적 용어들에 있어, 일반 용어의 여러 사례들이 어떻게 상이하게 관련될 수 있는지를 이해하는 것은 특히 중요하다. 유추적 관계에 대해서는 Aristotle, *Nicomachean Ethics* 제1권 제6장('good'의 다양한 사례들이 이와 같은 관계로 연결되어 있다고 암시) 참조; Austin, *The Province*, Lecture V, 119-124쪽. 중심 사례와의 다른 방식의 관계(예: 'healthy')에 대해서는 Aristotle, *Categories* 제1장 및 *Topics* 제1권 제15장, 제2권 제9장의 '파생어(paronyms)' 사례들 참조. '가족 유사성(family resemblance)' 개념에 대해서는 Wittgenstein, *Philosophical Investigations*, 제1부, 제66-76절 참조. 제8장 제1절 '정의(just)' 개념 구조에 대한 논의도 비교 참조. Wittgenstein의 조언(op. cit., 제66절)은 법적·정치적 용어 분석에서 특히 적절하다. 그는 '게임(game)'이라는 단어의 정의를 논하면서 이렇게 말했다. "‘게임’이라 불리는 것들 사이에 반드시 공통 점이 있어야 한다고 말하지 말고, 보라 그리고 살펴보라. 그러면 그 모든 것들에 공통된 무언가가 있는 것이 아니라, 유사성, 관계, 일련의 연속체들이 있을 뿐임을 보게 될 것이다."

CHAPTER I 제3판 주석

Hart 자신의 주석은 이 판에서도 변경 없이 유지되었다. 그것들은 여전히 그의 논증의 미묘한 차이, 본문에서 충분히 다루어지지 않은 사유, 다른 이들과의 입장 비교 등을 이해하는 데 유용하다. 그러나 학술적 자료로서 이 주석들은 종종 후속 연구들에 의해 대체된다. 아래는 Hart의 논증을 확장하거나 비판하는 최근 영어권 연구들에 대한 안내이며, 문헌이 방대하기 때문에 포괄성을 목표로 하지 않고, 학생들에게 특히 유용할 수 있는 일부 항목만을 제시한다. 가능하다면 Hart와 지속적으로 논쟁을 벌였던 인물들, 또는 그의 저작을 직접 분석·계승한 학자들의 저작을 중심으로 선정했다. Hart의 법철학에 대한 일반 연구는 매우 많으며, 권위 있는 단행본 두 권은 다음과 같다: Neil MacCormick, *H. L. A. Hart* (2판, Stanford University Press, 2008; 이하의 모든 쪽수 표기는 1판, 1981 기준), Michael D. Bayles, *Hart's Legal Philosophy: An Examination* (Kluwer Academic, 1992). 간결한 개요로는 Joseph Raz의 부고문 'H. L. A. Hart (1907-1992)' (1993) *Utilitas* 제5권 145쪽이 있다. Hart의 생애와 지적 배경은 Nicola Lacey, *A Life of H. L. A. Hart: The Nightmare and the Noble Dream* (Oxford University Press, 2004) 참조.

3-4쪽. 법에 관한 일반적 이해(*common knowledge*). 일반인의 이해와 자기 이해(*self-understanding*)가 법이론에 가지는 중요성에 대해서는 Joseph Raz, *Between*

Authority and Interpretation (Oxford University Press, 2009), 제2장 참조.

4쪽. 법체계의 경계 사례(*borderline cases*). Hart의 요지는, 법에 대한 철학적 논쟁은 일반적으로 경계 사례의 존재에서 비롯되는 것이 아니라는 것이다. Ronald Dworkin도 이 점에 동의한다: *Law's Empire* (Harvard University Press, 1986), 40-43쪽 참조. 국내법체계가 법의 중심 사례인지 여부에 의문을 제기하는 견해로는 다음을 참조: John Griffiths, 'What is Legal Pluralism?' (1986) *Journal of Legal Pluralism & Unofficial Law* 제24권 1쪽; William Twining, *General Jurisprudence: Understanding Law from a Global Perspective* (Cambridge University Press, 2009), 제4장; Keith Culver and Michael Giudice, *Legality's Borders* (Oxford University Press, 2010).

6-13쪽. 반복되는 쟁점들(*recurrent issues*). Hart는 이후 법철학의 과제를 약간 다르게 보게 되었다. 그는 1967년에 본서에서 다른 쟁점들에 추가하여 법적 추론(*legal reasoning*)의 문제와 법 비판(*criticism of law*)의 문제들-법을 평가할 적절한 기준, 법의 도덕적 권위의 근거 등-을 법철학의 주요 과제로 포함시켰다. 관련 논의는 *Essays in Jurisprudence and Philosophy* (Oxford University Press, 1983), 제3장 'Problems of the Philosophy of Law' 참조.

법이론의 과제를 상반된 방식으로 제시하는 견해들은 다음에서 찾아볼 수 있다: Ronald Dworkin, *Taking Rights Seriously* (개정판, Harvard University Press, 1978), 14-16쪽; Ronald Dworkin, *Law's Empire*, 1-6쪽; John Finnis, *Natural Law and Natural Rights* (2판, Oxford University Press, 2011), 제1장; Hugh Collins, *Marxism and Law* (Oxford University Press, 1984), 제1장. Hart의 과제 목록에 대한 평가로는 Leslie Green, 'General Jurisprudence: A 25th Anniversary Essay' (2005) *Oxford Journal of Legal Studies* 제25권 565쪽 참조.

14쪽. 단어와 대상 간의 관계. P. M. S. Hacker, 'Hart's Philosophy of Law', in P. M. S. Hacker and J. Raz eds., *Law, Morality, and Society: Essays in Honour of H. L. A. Hart* (Oxford University Press, 1977), 특히 2-12쪽 참조. Neil MacCormick, *H. L. A. Hart*, 12-19쪽도 참조. Dworkin은 Hart가 "법률가들이 모두 법적 명제를 판단할 때 특정한 언어적 기준을 따르고 있다"고 본다고 해석했으며, 이는 *Law's Empire* 45-46쪽에서 '의미의 독침(*semantic sting*)' 논변의 기초를 이룬다. 이 측면에 대한 비판은 다음에서도 볼 수 있다: Nicos Stavropoulos, 'Hart's Semantics', in Jules Coleman ed., *Hart's Postscript* (Oxford University Press, 2001); Brian Leiter, 'Beyond the Hart/Dworkin Debate: The Methodology Problem in Jurisprudence', (2003) *American Journal of Jurisprudence* 제48권 17쪽, 특히 43-51쪽.

‘법(law)’이라는 단어의 의미론적 분석은 Jules Coleman and Ori Simchen, ‘Law’ (2003) *Legal Theory* 제9권 1쪽 참조. 법철학이 과연 의미론(semantics)과 관계가 있는지에 대한 의문은 Joseph Raz, *Ethics in the Public Domain* (개정판, Oxford University Press, 1995), 제9장, 특히 195-198쪽 및 *Between Authority and Interpretation*, 49-59쪽 참조. 정치이론의 언어학적 접근에 대한 일반적 회의론은 David Miller, ‘Linguistic Philosophy and Political Theory’, in David Miller and Larry Siedentop eds., *The Nature of Political Theory* (Oxford University Press, 1983) 참조.

15-16쪽. 속·종차에 따른 정의(*per genus et differentiam*). Hart의 입장에 대한 비판은 P. M. S. Hacker, ‘Definition in Jurisprudence’ (1969) *Philosophical Quarterly* 제19권 343쪽 참조.

16쪽. 공통된 요소 집합. 이 요소들은 91-99쪽에서 제시된다. 이것이 ‘법’이나 ‘법체계’에 대한 개념 분석(*conceptual analysis*)을 이루는지 여부는, 그러한 분석이 무엇을 요구한다고 보는가에 달려 있다. 비교문헌으로는 Frank Jackson, *From Metaphysics to Ethics: A Defense of Conceptual Analysis* (Oxford University Press, 1998), Colin McGinn, *Truth by Analysis: Games, Names, and Philosophy* (Oxford University Press, 2012), 특히 제2장 참조. Hart류의 이론과 사회학적 이론 간의 관계에 대해서는 다음을 참조: H. L. A. Hart, ‘Analytical Jurisprudence in Mid-Twentieth Century: A Reply to Professor Bodenheimer’ (1956) *University of Pennsylvania Law Review* 제105권 953쪽; M. Krygier, ‘“The Concept of Law” and Social Theory’ (1982) *Oxford Journal of Legal Studies* 제2권 155쪽; B. Z. Tamanaha, ‘Socio-Legal Positivism and a General Jurisprudence’ (2001) *Oxford Journal of Legal Studies* 제21권 1쪽; Denis Galligan, ‘Legal Theory and Empirical Research’, in Peter Cane and Herbert Kritzer eds., *Oxford Handbook of Empirical Legal Research* (Oxford University Press, 2010).

II. 법(Laws), 사령(Commands), 그리고 명령(Orders)

1. 명법의 다양성(Varieties of Imperatives)

법(law)의 개념을 사령(command)과 습관(habit)이라는 외견상 단순한 요소들로 분석하려는 가장 명확하고 철저한 시도는 오스틴(Austin)이 『법학의 범위는 어떻게 결정되는가(Province of Jurisprudence Determined)』에서 보여준 것이다. 이 장과 다음 두 장에서 우리는 본질적으로 오스틴의 이론과 동일하지만 몇몇 지점에서는 다소 차이를 보일 수도 있는 입장을 서술하고 비판할 것이다. 우리의 주요 관심은 오스틴 개인에 있지 않고, 결함에도 불구하고 지속적인 매력을 지니는 특정 유형의 이론이 가진 정당성에 있다. 따라서 오스틴의 의미가 불분명하거나 그의 견해가 일관되지 않아 보이는 지점에서는 이를 무시하고 명확하고 일관된 입장을 서술하는 데 주저하지 않았다. 또한 오스틴이 비판을 어떻게 반박할 수 있을지에 관해 암시만 제공한 경우, 우리는 이후 이론가들(Kelsen 등)이 취한 접근 방식 일부를 따라 그 이론을 가능한 강한 형태로 구성하고 비판할 수 있도록 발전시켰다.

사회생활의 여러 다양한 상황에서, 한 사람이 다른 사람에게 어떤 행위를 하거나 하지 않기를 바라는 바람을 표현하는 경우가 있다. 이 바람이 단순한 흥미로운 정보 제공이나 의도적 자기노출이 아니라, 상대방이 그 표현된 바람에 따라 행동하기를 의도하여 표명되는 경우, 영어를 포함한 많은 언어들에서는 (비록 필수는 아니지만) 명령법(imperative mood)이라 불리는 특별한 언어형식을 사용하는 것이 관습적이다. 예컨대 ‘집에 가라!’(Go home!), ‘이리 와!’(Come here!), ‘멈춰!’(Stop!), ‘그를 죽이지 마라!’(Do not kill him!) 등이 그러하다. 이러한 명령법 형태로 타인을 부르는 사회적 상황은 매우 다양하며, 몇 가지 익숙한 범주를 통해 주요 유형들이 반복되는 것이 확인된다. 예를 들어 ‘소금 좀 주세요’는 보통 단순한 요청(request)이다. 일반적으로 화자가 어떤 서비스를 제공할 수 있는 상대방에게 말하며, 이행하지 않을 경우 어떤 긴급함이나 결과에

대한 암시도 포함되지 않기 때문이다. ‘나를 (p. 19) 죽이지 마시오’는 상대방의 자비에 의존하거나 상대방이 자신을 구할 수 있는 곤란한 상황에 처한 경우의 애원(plea)으로 발화된다. 반면에 ‘움직이지 마!’는 경우에 따라 경고(warning)가 된다. 예컨대 화자가 상대방에게 다가오는 위험(풀숲의 뱀 등)을 알고 있고, 가만히 있는 것이 그 위험을 피하는 데 도움이 되는 상황이 그렇다.

명령법 형식이 사용되는 사회적 상황의 다양성은 그 수가 많을 뿐 아니라, 서로 자연스럽게 경계를 이루며 이어지기도 한다. ‘애원’, ‘요청’, ‘경고’와 같은 용어들은 단지 거친 구별을 가능케 할 뿐이다. 이 가운데 가장 중요한 상황은 ‘명법(imperative)’이라는 용어가 특히 적절하게 적용되는 경우이다. 이는 다음과 같은 사례로 잘 드러난다. 권총강도가 은행 직원에게 “돈을 내놓지 않으면 쏠겠다”고 말하는 경우이다. 여기서 우리가 ‘돈을 내놓으라’고 은행 직원에게 단순히 요청하거나(asking) 애원하는(pleading with) 것이 아니라 권총강도가 명령하고(ordering) 있다고 말하게 되는 결정적인 특징은, 화자가 자신의 바람을 관철하기 위해 일반인이 해롭거나 불쾌하게 여길 만한 일을 하겠다고 위협함으로써, 돈을 가지고 있는 것이 해당 직원에게 훨씬 덜 매력적인 선택지가 되도록 만든다는 점이다. 만약 권총강도가 자신의 의도를 성공시킨다면, 우리는 그가 직원을 강압했다(coerced)고 말하며, 직원이 어떤 의미에서 권총강도의 권한(power) 하에 있었다고 말하게 된다. 이와 같은 경우에는 언어적으로 미묘한 문제들이 발생할 수 있다. 우리는 ‘권총강도가 직원에게 돈을 내놓으라고 명령했다(ordered)’고 말할 수 있고, ‘직원이 복종했다(obeyed)’고도 할 수 있다. 그러나 ‘권총강도가 직원에게 돈을 내놓으라는 명령을 내렸다(gave an order)’고 말하는 것은 다소 오해를 낳을 수 있다. 이 표현은 군대식 표현처럼 들리며, 일정한 명령(order)을 내릴 권리나 권위(authority)가 있는 것으로 암시하기 때문이다. 그러나 ‘권총강도가 자신의 부하에게 문을 지키라고 명령을 내렸다(gave an order)’는 식의 표현은 자연스럽다.

우리는 여기서 이러한 미묘한 차이들에 대해 깊이 들어갈 필요는 없다. 비록 ‘명령(order)’이나 ‘복종(obedience)’이라는 단어에는 종종 권위(authority)와 그에 대한 존중(respect)이 내포되어 있지만, 우리는 ‘위협에 의해 뒷받침되는 명령(orders backed by threats)’ 또는 ‘강압적 명령(coercive orders)’이라는 표현을,

권총강도의 명령처럼 단지 위협에 의해서만 뒷받침되는 명령을 지칭하는 데 사용할 것이다. 그리고 우리는 ‘복종(obedience)’ 또는 ‘복종하다(obey)’라는 표현을 그러한 명령에 따르는 경우까지 포함하는 의미로 사용할 것이다. 그러나 오스틴의 사령(command) 개념이 법학자들에게 끼친 큰 영향을 고려할 때, (p. 20) 단순히 해악의 위협만으로 복종을 강제하는 상황은 우리가 자연스럽게 ‘사령’이라고 부르는 상황이 아니라는(not) 점은 분명히 짚어야 한다. 이 단어는 군사적 맥락 외에는 흔히 사용되지 않으며, 사령이라는 표현에는 일반적으로 다음과 같은 강한 함의가 따라붙는다. 즉, 군대나 제자 집단처럼 상대적으로 안정된 위계 조직이 존재하고, 그 속에서 사령자는 우월한 지위에 있다는 것이다. 일반적으로는 하사관이 아니라 장군(general)이 사령자(commander)로서 사령을 내리는 것이며, 이러한 특수한 우위의 다른 형태도 이와 같은 방식으로 표현된다. 예컨대 신약성경에서 예수가 제자들에게 사령(command)한 것으로 표현되는 경우가 그러하다. 더 중요한 점은—그리고 이는 다양한 형태의 명법(imperative) 사이에서 핵심적인 구분이다—사령이 존재하는 경우라고 해서 항상 불복종 시 해악이 가해질 수 있다는 위협(threat)이 내재해 있어야 하는 것은 아니라는 점이다. 사령은 본질적으로 사람에 대한 해악을 가할 권한(power)이 아니라, 권위(authority)를 행사하는 것이며, 비록 해악의 위협과 결합될 수는 있어도, 사령(command)은 본질적으로 공포가 아니라 권위에 대한 존중을 호소하는 행위이다.

명백하게도, 사령(command)이라는 개념은 권위(authority)와 매우 강하게 연관되어 있기 때문에, 단순히 위협에 의해 뒷받침되는 권총강도의 명령(order) 보다는 법(law)의 개념에 훨씬 더 가깝다. 그럼에도 불구하고, 오스틴(Austin)은 앞 단락에서 지적된 구분을 무시하고 후자의 경우를 사령(command)이라고 오도하게 부르고 있다. 그러나 사령(command)은 우리의 목적에는 오히려 법에 너무 가까운 개념이다. 왜냐하면 법(law)에 내재된 권위(authority)의 요소는 법이 무엇인지 쉽게 설명하기 어렵게 만드는 장애물 가운데 하나이기 때문이다. 그러므로 우리는 법을 해명함에 있어, 동일하게 권위를 포함하고 있는 사령(command)의 개념을 유익하게 사용할 수 없다. 오히려 오스틴의 분석은 여러 결점에도 불구하고 하나의 장점을 지닌다. 즉, 권총강도(gunman)의 상황에 등

장하는 요소들은 권위의 요소와 달리 그 자체로 모호하지 않으며 복잡한 설명을 요하지 않는다. 이러한 이유로 우리는 오스틴을 따라 법의 개념을 그로부터 구성해보려 할 것이다. 다만 우리는 오스틴처럼 그것이 성공하리라 기대하기 보다는, 실패를 통해 배우기를 희망할 것이다.

2. 법(law)과 강압적 명령(coercive orders)

현대 국가와 같은 복잡하고 대규모의 사회에서도, 공식적인 인물이 개인과 직접 마주하여 무언가를 하라고 명령(order)하는 상황은 종종 존재한다. 예컨대 경찰관이 (p. 21) 특정 운전자에게 정지하라고 하거나, 특정 거지에게 자리를 옮기라고 명령(order)하는 경우가 있다. 그러나 이러한 단순한 상황들은 법이 기능하는 표준적 방식이 아니며, 그럴 수도 없다. 단지 사회의 모든 구성원에게 그들이 해야 할 모든 행위가 각각 공식적이고 개별적으로 통지되어야 한다면, 이를 보장하기 위해 필요한 공무원의 수를 어느 사회도 감당할 수 없기 때문이다. 대신 이러한 개별화된 통제 방식은 예외적이거나, 특정인을 지명하지 않고 특정 행위도 직접 지시하지 않는 일반적인 지시 형식을 보완하거나 강화하는 부수적 수단에 불과하다. 따라서 (법의 모든 다양성들 중에서도 위협에 의해 뒷받침되는 명령(order)과 가장 유사한) 형사 법규(criminal statute)의 기준(standard) 형식조차도 다음의 두 가지 측면에서 일반적(general)이다; 즉, 그것은 일반적인 행위 유형을 지시하고, 그러한 지시가 자신에게 적용됨을 이해하고 이를 준수할 것으로 기대되는 일반적인 사람의 범주에 적용된다. 이때 공무원이 개별인을 대상으로 직접 대면하여 전달하는 지시는 부차적이다: 만약 일반 지시를 어떤 개인이 따르지 않을 경우, 공무원은 그의 주의를 환기시키고 준수를 요구할 수 있으며(세무 공무원이 그러하듯), 또는 불복종이 공식적으로 확인되고 기록되어, 위협된 처벌이 법원에 의해 부과될 수 있다.

따라서 법적 통제는 본질적으로, 비록 예외는 있지만, 이러한 이중의 의미에서 일반적(general)인 지시에 의한 통제이다. 이것이 우리가 법의 특성을 재현하기 위해 권총강도의 단순한 모델에 추가해야 할 첫 번째 요소이다. 영향을 받는 사람의 범위와 그 범위가 표시되는 방식은 서로 다른 법체계, 혹은 심지어

서로 다른 법률에 따라 다양할 수 있다. 현대 국가에서는 특별한 확대 또는 축소의 지시가 없는 한, 일반 법률은 해당 영토 내의 모든 사람에게 적용된다고 이해된다. 교회법(canon law)에서도 이와 유사하게, 특정한 경우를 제외하면 교회의 모든 구성원이 법의 적용 대상이라고 일반적으로 이해된다. 모든 경우에서 특정 법률의 적용 범위는 해당 법률의 해석과 일반적인 이해에 의해 결정된다. 이 지점에서 주목할 만한 것은, 오스틴을 포함한 여러 법학자들이 법이 특정 집단의 사람들에게 향하여 있다(addressed)고 말하지만,¹³ 이러한 표현은 (p. 22) 실제로 존재하지 않는 대면 상황(face-to-face situation)과의 유사성을 암시하기 때문에 오해를 불러일으킬 수 있다는 점이다. 사람들에게 무언가를 하도록 명령(order)하는 것은 일종의 의사소통 방식으로, 실제로 그들의 주의를 끌거나(attracting their attention) 그것을 끌기 위한 조치를 취하는 것을 포함한다. 그러나 사람들을 위해 법을 제정하는 것에는 그러한 절차가 따르지 않는다. 예컨대 권총강도는 ‘그 지폐를 내놔라’라고 발화함으로써, 동시에 직원이 무언가를 하길 바란다는 자신의 의사를 표현하고, 그것을 직원의 주위에 도달하게 만든다. 만약 권총강도가 빈 방에서 같은 말을 했을 뿐이라면, 그는 결코 직원을 지칭(address)한 것이 아니며, 직원에게 어떤 행위를 하라고 명령(order)한 것도 아니다. 우리는 단지 그가 ‘그 지폐를 내놔라’는 말을 했다고 서술할 수 있을 뿐이다. 이 점에서 법 제정은 타인에게 무언가를 하도록 명령하는 행위와 다르며, 법에 대한 모델로서 이러한 단순한 개념을 사용할 때는 이 차이를 반드시 고려해야 한다. 실제로 법은 제정된 직후 적용 대상자의 주위에 최대한 신속히 도달하는 것이 바람직하다. 입법자의 법 제정 목적은 일반적으로 이것이 이루어지지 않으면 달성될 수 없기 때문에, 법체계는 종종 공포(promulgation)에 관한 특별 규정을 통해 이를 보장한다. 그러나 이러한 절차가 이루어지기 이전에도 법은 법으로서 완결될 수 있으며, 아예 공포되지 않았더라도 여전히 법일 수 있다. 별도의 규정이 없다면, 법은 그 영향을 받는 사람들이 스스로 법이 무엇이며, 그 법이 자신에게 적용되는지를 파악해야 하는 상황에서도 유효하게 성립한다. 일반적으로 법이 특정한 사람들에게 ‘향해 있다(addressed)’고 말할 때 의미하는 바는, 그 사람들이 해당 법률이 적용되는 대상자들이라는 것이다.

¹³ ‘Addressed to the community at large’, Austin, above, p. 1 n. 4 at p. 22.

즉, 법률이 일정한 방식으로 행동하라고 요구하는 대상이라는 뜻이다. 만약 우리가 여기서 ‘향하다(addressed)’는 단어를 사용할 경우, 법 제정과 대면 명령 간의 중요한 차이를 간과할 위험이 있으며, 동시에 두 개의 상이한 질문—‘그 법은 누구에게 적용되는가?’와 ‘그 법은 누구에게 공포되었는가?’—를 혼동할 수 있다.

이러한 일반성(generality)의 특성을 도입하는 것 외에도, 우리가 법이 존재하는 상황을 설명하기 위한 타당한 모델을 얻고자 한다면, 권총강도 상황에 대해 보다 근본적인 변경이 필요하다. 물론 어떤 의미에서 권총강도는 은행 직원보다 우위를 점한다. 그것은 (p. 23) 권총강도가 단기간이지만 위협을 가할 수 있는 능력을 가지며, 이는 은행 직원이 그가 지시받은 특정 행위를 수행하게 만들 가능성이 있기 때문이다. 이 둘 사이에는 이러한 일시적 강압 관계 외에 다른 어떤 우위-열위 관계도 존재하지 않는다. 그러나 권총강도의 목적에는 그것으로 충분할 수 있다. ‘그 지폐를 내놓지 않으면 쏠 것이다’는 단순한 대면 명령은 그 상황에서 끝나버린다. 권총강도는 은행 직원에게 (자신의 부하들에게는 가능할지 몰라도) 반복적으로 지켜야 할 지속적 명령(standing orders)을 내리지 않는다. 그러나 법은 본질적으로 이러한 ‘지속성(standing)’ 또는 항구적 성격을 지닌다. 따라서 우리가 위협에 의해 뒷받침되는 명령(order)을 법이 무엇인가를 설명하는 개념으로 사용하고자 한다면, 반드시 법이 지니는 이러한 지속적 성격을 재현하려는 노력이 필요하다.

다음과 같은 가정이 필요하다. 즉, 일반적 명령(order)이 적용되는 사람들 사이에, 해당 명령에 불복종할 경우 그에 따른 위협이 실행될 가능성이 있다는 일반적인 믿음이 존재해야 하며, 이는 단지 그 명령이 처음 공포될 때에만이 아니라, 그 명령이 철회되거나 폐지될 때까지 지속적으로 유지되어야 한다. 이러한 불복종의 결과에 대한 지속적인 믿음은, 원래의 명령들이 계속해서 살아 있으며 ‘지속적(standing)’인 상태를 유지한다고 말할 수 있게 해준다. 다만, 우리가 뒤에서 보게 되듯이, 법의 지속적 성격(persistent quality)을 이러한 단순한 개념으로 분석하는 데는 어려움이 있다. 실제로, 많은 수의 사람들에게 영향을 미치는 이와 같은 지속적 명령이 실행될 가능성에 대한 일반적인 믿음이 존재하려면, 단순한 권총강도(gunman) 상황에서는 재현할 수 없는 많은 요소들이

결합되어야 할 수도 있다. 즉, 이와 같은 위협을 실제로 집행할 수 있는 권한이 존재한다고 믿기 위해서는, 상당수의 인구가 단지 위협을 두려워해서가 아니라 자발적으로 순종하고, 불복종자에 대한 위협의 집행에 협력할 의사가 있어야만 할 수도 있다.

이러한 위협이 실행될 가능성에 대한 일반적인 믿음의 근거가 무엇이든 간에, 법이 존재하는 안정된 상황과 유사한 모델을 구성하기 위해, 우리는 권총강도 상황에 또 하나의 필수적 요소를 추가해야 한다. 즉, 동기가 무엇이든 간에, 대부분의 명령들이 해당되는 사람들에게 의해 불복종보다 더 자주 복종된다는 점을 가정해야 한다. 우리는 이를 오스틴(Austin)을 따라 (p. 24) ‘일반적 복종 습관(general habit of obedience)’이라고 부를 것이며, 그와 함께, 이 개념이 법의 여러 다른 측면들과 마찬가지로 본질적으로 모호하거나 불분명한 개념이라는 점을 지적할 것이다. 얼마나 많은 사람들이 얼마나 많은 일반 명령에 얼마 동안 복종해야 법이 존재한다고 볼 수 있는가는, 대머리로 간주되기 위해 사람이 얼마나 적은 머리카락을 가져야 하는가 하는 질문만큼이나 명확한 답이 없는 문제이다. 그러나 이와 같은 일반 복종의 사실 안에야말로, 법과 권총강도의 단순한 명령(order) 사이의 결정적인 구별이 존재한다. 단기간 동안 한 사람이 다른 사람에 대해 가지는 일시적 우위는 본래 법의 상대적 지속성과 안정성에 반대되는 것으로 여겨지며, 실제로 대부분의 법체계에서는 권총강도가 가지는 이와 같은 단기적 강압력을 행사하는 것 자체가 형사범죄를 구성한다. 그렇다면, 위협에 의해 뒷받침되는 일반 명령에 대한 일반적이고 습관적인 복종이라는 이 단순하지만 인정컨대 모호한 개념이, 실제 법체계가 가지는 안정성과 연속성을 충분히 재현해낼 수 있는 것인지 살펴보아야 한다.

우리가 권총강도 상황이라는 단순한 모델에 점차 요소를 덧붙여 구성한, 위협에 의해 뒷받침되고 일반적으로 복종되는 일반 명령의 개념은, 분명히 근대 국가의 입법기관에 의해 제정된 형사 법규(penal statute)에 가장 가까운 법의 형태이다. 그러나 이러한 형사 법규와는 명백히 매우 다른 듯 보이는 다른 유형의 법도 존재하며, 우리는 이후에 이들 또한 실상은 단지 이러한 형식의 복잡하거나 위장된 변형일 뿐이라는 주장에 대해 살펴볼 것이다. 그러나 우리가 일반적으로 복종되는 일반 명령이라는 구성된 모델을 통해 형사 법규의 특성조차 재현하고

자 한다면, 명령을 내리는 사람에 대해 좀 더 구체적인 설명이 필요하다. 근대 국가의 법체계는 그 영토 내에서의 일정한 최고성(supremacy)과 다른 법체계로부터의 독립성(independence)이라는 특징을 지닌다. 이러한 개념들은 단순히 보일 수 있지만 실제로는 그렇지 않으며, 우리가 일상적 상식(common-sense) 수준에서 이해하는 바를 표현하자면 다음과 같다. 영국법, 프랑스법, 또는 여타 근대 국가의 법은 비교적 명확한 지리적 경계를 가진 영토 내에 거주하는 인구의 행위를 규율한다. 각 국가의 영토 내에는 (p. 25) 위협에 의해 뒷받침되는 일반 명령을 내리고 이에 대해 습관적 복종을 받는 여러 개인 또는 집단이 있을 수 있다. 그러나 우리는 이들 가운데 일부(예컨대 런던시의회(LCC)나 위임입법(delegated legislation)을 행사하는 장관 등)를 하위(subordinate) 입법자로서 영국 의회 내의 여왕(Queen in Parliament)과 구분해야 하며, 여왕은 최고(supreme) 입법자이다. 이 관계는 습관의 용어로도 설명될 수 있다. 즉, 여왕은 법을 제정할 때 아무에게도 습관적으로 복종하지 않으며, 하위 입법자들은 법에 의해 규정된 범위 내에서 행동함으로써 여왕의 대리인(agent)으로 간주된다. 만약 이들이 그러한 범위를 넘어서 행동한다면, 우리는 더 이상 하나의 영국법 체계를 갖는 것이 아니라 복수의 법체계를 갖게 될 것이다. 그러나 실제로는 여왕이 이와 같은 의미에서 영토 내의 모든 사람에 대해 최고 권위를 가지며, 다른 기관들이 그렇지 않기 때문에, 우리는 영국 내에서 하나의 단일한 체계를 갖고 있으며, 그 안에서 최고와 하위 요소의 위계를 구별할 수 있는 것이다.

여왕이 다른 사람의 명령을 습관적으로 복종하지 않는다(not)는 이와 같은 부정적 성격의 설명은, 서로 다른 국가들의 독립된 법체계에 대해 우리가 사용하는 독립성(independence)의 개념을 대략적으로 정의해 준다. 예컨대 소비에트 연방의 최고 입법기관은 여왕의 명령에 복종하는 습관을 가지지 않으며, 여왕이 소비에트 연방에 관해 제정한 어떠한 법률도(비록 그것이 영국법의 일부가 될 수는 있겠지만) 소비에트 법의 일부가 되지는 않는다. 그러한 법률이 소비에트 연방의 법이 되기 위해서는 소비에트 입법기관이 여왕의 명령에 습관적으로 복종해야 할 것이다.

이러한 단순한 설명에 따르면(우리는 이후 이를 비판적으로 검토할 것이다), 법체계가 존재하는 곳에서는 어디에나 일반적으로 복종되는 위협에 의해 뒷받

침된 일반 명령을 발령하는 개인 또는 집단이 있어야 하며, 그 위협이 불복종 시에 실제로 실행될 것이라는 일반적인 믿음이 존재해야 한다. 이러한 개인 또는 집단은 내부적으로는 최고(supreme)이며 외부적으로는 독립(independent)적이어야 한다. 오스틴을 따라 이러한 최고이자 독립적인 개인이나 집단을 주권자(sov​er​eign)라고 부른다면, 어떤 국가의 법도 주권자 또는 그에게 복종하는 하위 입법자들이 발한, 위협에 의해 뒷받침된 일반 명령으로 구성된다고 할 수 있다.

CHAPTER II 주석

18쪽. 명법(imperative)의 다양성. 명법을 ‘명령(order)’, ‘간청(plea)’, ‘논평(comment)’ 등으로 분류하는 것은, 사회적 상황, 당사자들 사이의 관계, 힘의 사용에 대한 의도와 같은 여러 요소에 의존하며, 이는 사실상 아직 거의 탐구되지 않은 주제이다. 명법에 관한 대부분의 철학적 논의는 (1) 명법 언어와 서술(indicative) 혹은 기술(descriptive) 언어 간의 관계 및 전자를 후자로 환원할 수 있는 가능성에 관한 문제(예: Bohnert, 「The Semiotic Status of Commands」, *Philosophy of Science* 제12권 (1945))나, (2) 명법들 사이에 어떤 연역적 관계가 존재하는지 여부에 관한 문제(예: Hare, 「Imperative Sentences」, *Mind* 제58권 (1949), 또한 *The Language of Morals* (1952); Hofstadter and McKinsey, 「The Logic of Imperatives」, *Philosophy of Science* 제6권 (1939); Hall, *What is Value* (1952), 제6장; Ross, 「Imperatives and Logic」, *Philosophy of Science* 제11권 (1944))에 집중되어 있다. 이러한 논리적 문제에 대한 연구는 중요하지만, 사회적 맥락에 따라 명법의 다양한 유형을 식별하는 작업 역시 큰 필요성이 있다. 문법적 명령형(imperative mood) 문장이 어떤 표준적 상황에서 일반적으로 ‘명령(order)’, ‘간청(plea)’, ‘요청(request)’, ‘사령(command)’, ‘지시(directions)’, ‘설명(instructions)’ 등으로 분류되는지를 묻는 것은, 단순히 언어에 관한 사실을 밝히는 것이 아니라, 언어 속에 드러나는 다양한 사회적 상황과 관계들 사이의 유사성과 차이를 파악하는 방법이기도 하다. 이러한 구별에 대한 인식은 법, 도덕, 사회학의 연구에 매우 중요하다.

18쪽. 명법은 타인이 어떤 행위를 하거나 하지 않기를 바라는 바를 표현한 것. 언어에서 명령형의 표준적 사용을 이와 같이 설명할 때, 주의해야 할 점은 화자가 단순히 타인이 특정 방식으로 행동하길 바란다는 자신의 의사를 정보로서 드러내는 경우와, 그 발화를 통해 실제로 상대방이 그렇게 행동하도록 유도하려는 의도를 지닌 경우를 구분해야 한다는 것이다. 전자의 경우에는 통상 명령형이 아니라 평서형(indicative mood)이 적절하다(이 구분에 대해서는 Hägerström, *Inquiries into the Nature of Law and Morals*, 제3장, §4, 116-126쪽 참조). 그러나 화자의 발화 목적이 상대방이 자신의 의도대로 행동하는 것이라고 해서, 그것만으로 명령형의 표준적 사용을 설명하기에는 부족하다. 왜냐하면, 화자가 단순히 그와 같은 목적을 갖는 것뿐만 아니라, 상대방이 그러한 목적이 있음을 인식하고, 그에 따라 영향을 받아 행동하기를 바라는 의도도 함께 갖고 있어야 하기 때문이다. 이러한 복합적인 요소는 본문에서는 생략되었으나, 이에 대해서는 Grice, 「Meaning」, *Philosophical Review* 제66권 (1957), Hart, 「Signs and Words」, *The Philosophical Quarterly* 제2권 (1952)을 참조하라.

19쪽. 권총강도(gunman) 상황, 명령(order), 복종(obedience). ‘명법(imperative)’

이라는 일반 개념을 분석함에 있어 직면하는 어려움 중 하나는, 명령(order), 사령(command), 요청(request) 등의 다양한 유형들에 공통된 요소, 즉 타인이 어떤 행동을 하거나 하지 않기를 바라는 의도의 표현을 가리키는 단어가 존재하지 않는다는 점이다. 이와 마찬가지로, 그러한 행동을 실제로 수행하거나 자제하는 것을 지칭하는 단일 단어도 없다. ‘명령(order)’, ‘요구(demand)’, ‘복종(obedience)’, ‘이행(compliance)’과 같은 자연스러운 표현들은, 각각이 통상 사용되는 특수한 상황의 성격에 의해 그 의미가 영향을 받는다. 가장 중립적으로 보이는 ‘지시하기(telling to)’라는 표현조차, 어느 한쪽이 다른 쪽에 대해 일정한 우위를 점하고 있다는 뉘앙스를 담고 있다. 권총강도 상황을 설명하기 위해, 우리는 ‘명령(order)’과 ‘복종(obedience)’이라는 표현을 선택했는데, 이는 권총강도가 은행원에게 돈을 건네라고 명령하였다(ordered)고 말하거나, 은행원이 이에 복종하였다(obeyed)고 말하는 것이 자연스럽기 때문이다. 물론, 추상 명사인 ‘명령(order)’과 ‘복종(obedience)’이라는 표현은 이 상황을 묘사하기 위해 자연스럽게 쓰이지는 않을 수 있다. 왜냐하면 전자에는 일정한 권위(authority)의 뉘앙스가 내포되어 있고, 후자는 종종 미덕으로 간주되기 때문이다. 그러나 강압적 명령(coercive orders)으로서의 법 이론을 설명하고 비판하는 데 있어, 우리는 이러한 권위나 당위의 함축 없이 ‘명령(order)’과 ‘복종(obedience)’이라는 명사 및, ‘명령하다(order)’와 ‘복종하다(obey)’라는 동사를 사용하였다. 이는 단지 편의상 선택된 것이며, 어떠한 쟁점에 대해 결론을 미리 내리는 것은 아니다. 벤담(Bentham)은 (*Fragment of Government*, 제1장, 제12절 주석에서), 오스틴(Austin)은 (*The Province*, 14쪽에서) 이러한 방식으로 ‘복종(obedience)’이라는 용어를 사용하였다. 벤담은 여기서 언급된 모든 어려움을 인식하고 있었으며, 이에 대해서는 *Of Laws in General*, 298쪽 주석(a) 참조.

20쪽. 사령(command)으로서의 법, 그리고 오스틴(Austin) 이론과의 관계. 본 장의 제2절에서 구성된 강제적 명령(coercive orders)으로서의 법에 관한 단순 모델은 오스틴의 『법철학의 원리(The Province of Jurisprudence Determined)』에서의 이론과 다음과 같은 점에서 다르다.

(a) 용어 사용. 본문에서 설명된 이유로 인해, ‘사령(command)’이라는 용어 대신 ‘위협이 뒷받침된 명령(order backed by threats)’ 혹은 ‘강제적 명령(coercive orders)’이라는 표현이 사용되었다.

(b) 법의 일반성. 오스틴은 (같은 책, 19쪽) ‘법(laws)’과 ‘개별 사령(particular commands)’을 구분하며, 사령(command)은 그것이 “일반적인 행위나 금지를 의무화한다면” 법 또는 규칙이라 주장한다. 이 관점에 따르면, 사령이 비록 주권자(sov​er​eign)에 의해 단 한 명의 개인에게 ‘주소(addressed)’ 되었더라도, 그것이 단일한 행위가 아닌

어떤 행위 유형 또는 종류에 대한 의무를 부과한다면, 법으로 간주될 수 있다. 본문의 법체계 모델에서는 명령들이 일반적이며, 이는 그것들이 개인들의 범주에 적용되고, 행위의 범주를 지시한다는 이중적 의미에서이다.

(c) 공포(*fear*)와 의무(*obligation*). 오스틴은 때때로 어떤 사람이 실제로 제재(*sanc-tion*)를 두려워할 경우에만 의무를 지닌다고 암시한다(같은 책, 15쪽과 24쪽 및 『강의록』 제22장 (5판), 444쪽: “그는 해악에 노출되어 있으며 그것을 두려워하기 때문에 구속되거나(*bound*) 의무를 지닌다(*obliged*)”). 그러나 그의 주요 주장은, 그 사람이 그것을 두려워하든 말든, “아주 작은 해악에 처할 아주 작은 가능성”만으로도 충분하다는 것이다(『*The Province*』, 16쪽). 강제적 명령으로서의 법의 모델에서는, 단지 불복종이 위협된 해악으로 이어질 가능성이 있다는 일반적인 믿음이 존재해야 한다는 조건만을 설정한다.

(d) 권한(*power*)과 법적 의무. 이와 유사하게, 사령(*command*)과 의무(*obligation*)를 분석하면서, 오스틴은 처음에는 사령의 발령자가 실제로 해악을 가할 능력을 가져야 한다고 제안한다(즉 ‘할 수 있고, 하려는 *willing*’ 자이어야 한다). 하지만 이후에는 그 요건을 “아주 작은 해악의 아주 작은 가능성”으로 약화시킨다(같은 책, 14쪽, 16쪽). 이러한 오스틴의 정의상의 모호성에 대해서는 하트(Hart), 「법적·도덕적 의무」, Melden 편 『도덕철학 에세이』(1958), 제5장 §2 참조.

(e) 예외 사례들. 오스틴은 선언적 법(*declaratory laws*), 허용적 법(*permissive laws*, 예: 폐지 규정), 불완전한 법(*imperfect laws*)을 그의 사령 중심의 일반적 법 정의의 예외로 간주한다(같은 책, 25-29쪽). 본 장 본문에서는 이 점을 고려하지 않았다.

(f) 입법부와 주권자. 오스틴은 민주주의에서 유권자(*electorate*)가 입법부에 있는 대표자들이 아니라 주권자 집단을 구성하거나 그 일부를 이룬다고 보았다. 비록 영국에서는 유권자가 자신의 주권을 행사하는 유일한 방식이 대표자들을 선출하고 나머지 주권적 권한을 그들에게 위임하는 것이지만 말이다. 그는 ‘정확하게 말하면’ 이러한 입장이 옳다고 주장했으나, 모든 헌법학자들이 그러하듯이 의회(*parliament*)가 주권을 가진다고도 말했다(같은 책, 강의 VI, 228-235쪽). 본문의 논의에서는 의회와 같은 입법부를 주권자와 동일시하고 있으나, 이에 대한 정밀한 분석은 제4장 §4를 참조하라.

(g) 오스틴 이론의 세부 보완과 수정. 본서의 후속 장들에서는, 오스틴 이론을 방어하기 위해 사용된 몇몇 개념들이 자세히 검토되며, 이들은 본 장에서 구성된 모델에는 포함되어 있지 않다. 이들 개념은 오스틴이 직접 도입한 것이나, 경우에 따라서는 개략적 또는 미완의 형태로만 제시되었으며, 켈젠(Kelsen)과 같은 후속 이론가들의 주장을 예견하는 요소도 있다. 여기에는 다음 개념들이 포함된다: ‘묵시적 사령(*tacit command*)’

(제3장 §3, 45쪽 및 제4장 §2, 64쪽 참조), 무효(nullity)를 하나의 제재(sanction)로 보는 견해(제3장 §1), '진정한 법'은 제재를 적용하도록 공직자에게 요구하는 규칙이라는 이론(제3장 §1), 유권자를 비상적 주권 입법기관으로 보는 관점(제4장 §4), 주권자의 통일성과 지속성 개념(제4장 §4, 76쪽). 오스틴에 대한 평가에 있어서는 W. L. Morison, 「법실증주의에 대한 몇 가지 신화(Some Myth about Positivism)」, *Yale Law Journal* 제 68권(1958)을 참조하라. 이는 오스틴에 대한 초기 학자들의 심각한 오해들을 바로잡는다. 또한 A. Agnelli, 『존 오스틴: 법실증주의의 기원에 대하여(John Austin alle origini del positivismo giuridico)』(1959), 제5장도 참고하라.

CHAPTER II 제3판 주석

18쪽. 오스틴(Austin)의 이론. 하트(Hart)는 여기서 오스틴 이론의 단순화된 재구성을 다루고 있음을 명확히 하고 있다(오스틴의 이론 자체도 벤담(Bentham)의 이론의 단순화 버전이다). 오스틴 자신의 견해에 대해서는 다음 문헌들을 참조하라: W. L. Morison, 『존 오스틴(John Austin)』(스탠퍼드 대학 출판부, 1982); W. E. Rumble, 『존 오스틴의 사상: 법이론, 식민지 개혁, 영국 헌정(John Austin: Jurisprudence, Colonial Reform, and the British Constitution)』(에슬론 출판사, 1985). 18세기 후반부터 19세기 중반까지의 영국 법사상 전반에 대해서는 마이클 롭번(Michael Lobban), 『보통법과 영국 법이론 1760-1850(The Common Law and English Jurisprudence 1760-1850)』(옥스퍼드 대학 출판부, 1991)를 참고하라.

18-20쪽. 명법(imperatives)으로서의 법. 이 주제에 대해서는 닐 매코믹(Neil MacCormick), 「법적 의무와 명법 오류(Legal Obligation and the Imperative Fallacy)」, A. W. B. 심프슨 편 『옥스퍼드 법이론 에세이 제2집(Oxford Essays in Jurisprudence, 2nd series)』(옥스퍼드 대학 출판부, 1973)도 참조하라. 하트 자신의 이론 속에도 일종의 명법적 이론(imperative theory)이 남아 있다고 지적한 것으로는 G. J. 포스테마(G. J. Postema), 「사령으로서의 법: 현대 법이론 속 사령 모델(Law as Command: The Model of Command in Modern Jurisprudence)」, (2001) *Philosophical Issues* 제11권 470쪽을 참고하라. 명법적 이론의 요소들을 방어하고자 한 시도들로는 매튜 H. 크레이머(Matthew H. Kramer), 『법실증주의의 옹호: 불필요한 장식을 걷어낸 법(In Defense of Legal Positivism: Law Without Trimmings)』(옥스퍼드 대학 출판부, 1999), 83-87쪽; 로버트 레이든슨(Robert Ladenson), 「홉스적 법개념의 옹호(In Defense of a Hobbesian Conception of Law)」, (1980) *Philosophy and Public Affairs* 제9권 134쪽 등을 참조하라.

20-22쪽. 법의 일반성(generality). 일반성 개념에 대한 풍부한(thicker) 해석과 얇은

(thinner) 해석을 비교하고자 한다면 다음을 참조하라: 프리드리히 하이에크(Friedrich Hayek), 『법, 입법, 자유(Law, Legislation, and Liberty)』 제1권 (시카고 대학 출판부, 1973), 제2장; 론 L. 풀러(Lon L. Fuller), 『법의 도덕성(The Morality of Law)』 개정판 (예일 대학 출판부, 1969), 46쪽 이하; 티모시 엔디콧(Timothy Endicott), 「법의 일반성(The Generality of Law)」, 루이스 두아르트 달메이다(Luís Duarte d'Almeida), 안드레아 돌체티(Andrea Dolcetti), 제임스 에드워즈(James Edwards) 편 『『법 개념』 읽기(Reading *The Concept of Law*)』 (하트 출판사, 2013).

24-25쪽. 최고성과 독립성(*Supremacy and Independence*). 이 주제에 대해서는 조셉 라즈(Joseph Raz), 『법체계 개념(The Concept of a Legal System)』 제2판 (옥스퍼드 대학 출판부, 1980), 제1장도 함께 참고하라.

III. 법의 다양성

현대의 법체계, 예컨대 영국법에서 발견되는 다양한 법의 종류들을 앞 장에서 구성한 강제 명령이라는 단순한 모델과 비교해보면, 무수한 이의들이 즉시 떠오른다. 모든 법이 사람들에게 어떤 일을 하거나 하지 말라고 명령하는 것은 분명 아니다. 유언, 계약, 결혼을 할 수 있는 사적 권한을 개인에게 부여하는 법이나, 판사에게 재판 권한을, 장관에게 규칙 제정 권한을, 지방 자치 단체에게 조례 제정 권한을 부여하는 법을 그렇게 분류하는 것은 오해를 불러일으키는 것 아닐까? 모든 법이 제정된 것도 아니며, 모두가 어떤 사람의 바람을 표현한 것—우리 모델에서처럼 일반 명령의 형태로—도 아니다. 대부분의 법체계에서 관습이 일정한 자리를 차지한다는 점에서 이는 사실과 다르다. 법률은, 그것이 의도적으로 제정된 것일지라도, 반드시 타인에게만 적용되는 명령이어야만 하는가? 입법자가 자신에게도 구속력을 갖는 법률을 제정하는 경우는 없지 않은가? 마지막으로, 제정된 법이 법이기 위해서는 반드시 어떤 입법자의 실제 바람이나 의도, 소망을 표현해야만 하는가? 만약 법안이 적절한 절차를 거쳐 통과되었지만 (영국의 재정법 조항 중 많은 경우가 그렇듯) 표결에 참여한 사람들이 그것이 무슨 의미인지조차 몰랐다면, 그것은 법이 아닌가?

이러한 이의들은 가능한 수많은 반론들 중에서 가장 중요한 것들이다. 분명히 원래의 단순한 모델에 일정한 수정을 가해야만 이러한 반론에 대응할 수 있을 것이며, 그 모든 반론을 수용한 뒤에는 위협에 의해 뒷받침된 일반 명령이라는 개념이 원형을 알아볼 수 없을 정도로 변형되어 있을 수도 있다.

우리가 언급한 반론들은 세 가지 주요 부류로 나눌 수 있다. 일부는 법의 내용에 관한 것이고, 다른 일부는 법의 기원 방식, 그리고 나머지는 법의 적용 범위에 관한 것이다. 모든 법체계는—적어도 겉보기에는—이 세 가지 사항 중 하나 이상에 있어 우리가 설정한 일반 명령 모델과는 다른 법들을 포함하고 있는 것처럼 보인다. 이 장의 나머지 부분에서는 이러한 세 가지 유형의 반론을 각각 따로 고찰할 것이다. 그리고 다음 장에서는 이보다 더 근본적인 비판, (p. 27) 즉 내용, 기원 방식, 적용 범위와 관련된 반론들을 넘어서, 이 모델이 전제하는 바—즉 최고권위자이자 독립된 주권자가 일반적으로 복종받는다는 관념—가

실제 법체계에서는 거의 대응되는 것이 없다는 점에서, 이 전체 개념 자체가 오해를 불러일으킨다는 비판을 다루기로 하겠다.

1. 법의 내용

형법은 우리가 복종하거나 위반하는 대상이며, 그 규칙이 요구하는 바는 ‘의무’라고 불린다. 이를 위반하면 우리는 법을 ‘어긴(break)’ 것이며, 그 행위는 법적으로 ‘잘못(wrong)’, ‘의무 위반(breach of duty)’, 혹은 ‘범죄(offence)’라 불린다. 형사 법령이 수행하는 사회적 기능은 특정 행위 유형을 피하거나 실행해야 하는 것으로 설정하고 정의하는 데 있으며, 이는 그 법이 적용되는 자의 의사와 무관하다. 형법이 위반되었을 때 부과되는 형벌 또는 ‘제재(sanction)’는 (형벌이 다른 목적을 지닐 수도 있지만) 이러한 행위를 하지 않도록 유인하는 하나의 동기를 제공하려는 것이다. 이 모든 점에서 형법과 그 제재는 우리 모델의 위협에 의해 뒷받침된 일반 명령과 강한 유사성을 갖는다. 이러한 일반 명령과 불법행위법(tort law) 사이에도 일정한 유사성이 존재하는데, 후자는 본질적으로 타인의 행위로 인해 피해를 입은 개인에게 보상을 제공하는 것을 주목적으로 한다. 여기서도 어떤 행위 유형이 법적으로 문제 삼을 수 있는 잘못(actionable wrong)이 되는지를 결정하는 규칙들은 개인에게, 그 의사와 무관하게, 해당 행위를 하지 말라는 ‘의무(duties)’(혹은 드물게는 ‘법적 의무(obligations)’)를 부과하는 것으로 서술된다. 이러한 행위는 ‘의무 위반(breach of duty)’이라 불리며, 보상이나 기타 법적 구제수단은 ‘제재(sanction)’라 불린다. 그러나 법 중에는 이러한 위협에 의해 뒷받침된 명령과의 유사성이 전혀 성립하지 않는 중요한 부류가 존재하며, 이는 전혀 다른 사회적 기능을 수행한다. 유효한 계약이나 유언, 결혼이 어떻게 성립하는지를 정의하는 법적 규칙들은 사람들이 원하든 원하지 않든 특정 방식으로 행동할 것을 요구하지 않는다. 이러한 법들은 의무나 책임을 부과하지 않으며, 대신 개인이 법이 정한 특정 절차와 조건에 따라 법적 권리와 의무의 구조를 창출할 수 있는 법적 권한(legal powers)을 부여함으로써 (p. 28) 자신의 소망을 실현할 수 있는 편의들(facilities)을 제공한다.

계약, 유언, 결혼 등을 통해 개인이 타인과의 법적 관계를 형성할 수 있는

이러한 권한의 부여는 법이 사회생활에 기여한 가장 위대한 성과 중 하나이며, 모든 법을 위협에 의한 명령으로 환원하여 설명하려는 관점에 의해 간과되어 왔다. 이러한 권한을 부여하는 법들과 형사 법령 사이의 기능적 차이는 우리가 이 부류의 법에 대해 일상적으로 사용하는 언어에서도 분명히 드러난다. 우리는 유언서를 작성할 때 1837년 유언법 제9조(s. 9 of the Wills Act, 1837)에 명시된 증인 수 요건을 ‘준수(compliance)’할 수도 있고 하지 않을 수도 있다. 준수하지 않을 경우, 우리가 작성한 문서는 권리와 의무를 창출하는 ‘유효(valid)’한 유언이 아니라 법적 ‘효력(force)’이나 ‘효과(effect)’가 없는 ‘무효(nullity)’가 된다. 그러나 그것이 무효라고 하여, 해당 법 조항을 준수하지 않은 것이 어떤 ‘의무나 책임의 위반(breach or violation of duty)’이거나 ‘범죄(offence)’가 되는 것은 아니며, 이를 그런 식으로 이해하는 것은 혼란을 초래할 수 있다.

사적 개인에게 법적 권한을 부여하는 다양한 법 규칙들을 살펴보면, 그들 자체도 서로 구분되는 유형들로 나뉜다는 것을 알 수 있다. 예컨대, 유언이나 계약을 할 수 있는 권한 뒤에는, 그 권한을 행사하는 자가 갖추어야 할 최소한의 개인적 자격—예를 들어 성인일 것, 정신적으로 온전할 것 등—에 관한 능력(capacity) 규칙들이 존재한다. 또 다른 규칙들은 그 권한이 행사되어야 하는 방식과 형식을 구체화하고, 유언이나 계약이 구두로 가능한지, 서면으로 해야 하는지, 서면이라면 어떤 형식으로 작성되고 증인이 있어야 하는지 등을 규정한다. 또 다른 규칙들은 그러한 법적 행위를 통해 창출될 수 있는 권리·의무 구조의 유형, 최대·최소 지속기간 등을 제한한다. 이러한 예로는 계약에 관한 공서양속 규칙이나, 유언·신탁에서의 축적금지 규칙들이 있다.

이후 우리는 “당신이 이것을 하고자 한다면, 이렇게 하라”고 말하는 권한 부여 법들을, “당신이 원하든 원하지 않든, 이렇게 하라”고 말하는 형법과 같은 위협 기반 명령과 동일시하려는 시도들을 살펴볼 것이다. 하지만 여기에서는, 이러한 사적 권한 부여 법들과는 대조적으로 공적(public) 혹은 공무상(official) 성격의 법적 권한을 부여하는 법들, (p. 29) 즉 사법, 입법, 행정이라는 정부의 세 영역(전통적으로 다소 모호하게 구분된 영역들)에서 발견되는 법들에 대해 살펴보겠다.

우선, 법원이 작동하는 데 배경이 되는 법들을 생각해 보자. 법원의 경우,

어떤 규칙들은 판사가 관할권을 행사할 수 있는 사안과 범위를 구체화하고, 우리는 이를 흔히 그가 특정 유형의 사건을 ‘재판할 권한(power to try)’을 가진다고 표현한다. 또 다른 규칙들은 판사의 임명 방식, 자격 요건, 임기 등을 규정하고, 또 다른 규칙들은 판사의 바람직한 행태에 대한 기준을 제시하거나 법정에서 따라야 할 절차를 정한다. 이러한 규칙들은 일종의 사법 법전(judicial code)을 형성하며, 1959년 카운티 법원법(County Courts Act, 1959), 1907년 형사항소법(Court of Criminal Appeal Act, 1907), 미국 연방법전 제28편(Title 28 of the United States Code) 등에서 그 예를 찾을 수 있다. 이러한 법령들에서 법원이 구성되고 정상적으로 작동하기 위한 다양한 규정들을 살펴보는 것은 유익하다. 이들 규정 중 상당수는 언뜻 보기에는 판사에게 무언가를 하거나 하지 말라고 명령하는 조항처럼 보이지 않는다. 물론, 법이 별도의 규칙을 통해 판사가 자신의 관할권을 넘어서는 행위나 금전적 이해관계가 있는 사건을 맡는 것을 금지하고, 이를 위반할 경우 처벌하는 것을 금할 수는 있지만, 이러한 규칙은 그에게 사법 권한을 부여하고 그의 관할권을 정의하는 규칙에 추가되는 성격을 갖는다. 권한을 부여하는 규칙의 주된 목적은 판사의 부적절한 행위를 억제하려는 것이 아니라, 법원의 결정이 유효하기 위한 조건과 한계를 규정하는 것이다.

이어서, 법원의 관할권 범위를 규정하는 전형적인 조항 하나를 간략히 살펴보는 것이 유익할 것이다. 가장 단순한 예로, 개정된 1959년 카운티 법원법에 따라 토지 반환 소송에 대한 관할권이 카운티 법원에 부여된 조항을 들 수 있다. 이 조항의 언어는 ‘명령’의 언어와는 매우 동떨어져 있으며 다음과 같다:

카운티 법원은, 문제된 토지의 연간 순과세가액이 100파운드를 초과하지 않을 경우, 해당 토지 반환 소송을 심리하고 판결할 수 있는 관할권을 갖는다.¹⁴

만약 카운티 법원 판사가 연간 가액이 100파운드를 초과하는 토지에 대해 관할권을 초과하여 재판하고 (p. 30) 이에 대해 명령을 내렸다면, 그 판사나 당사자들 중 누구도 범죄(offence)를 저지른 것은 아니다. 그러나 이 경우는

¹⁴Section 48 (1).

개인이 유언을 할 때 어떤 조건을 충족하지 않아 ‘무효(nullity)’가 되는 문서를 작성한 상황과는 다소 다르다. 예컨대 유언자가 서명하거나 두 명의 증인을 확보하지 않은 경우, 그가 작성한 문서는 어떠한 법적 지위나 효력도 갖지 못한다. 하지만 법원의 명령은, 설령 그것이 명백히 법원의 관할권 밖에 속하는 사안이라 할지라도, 이런 식으로 처리되지는 않는다. 공공 질서의 유지라는 관점에서, 상급 법원이 그 명령의 무효를 확정하기 전까지는 해당 결정이 법적 권위를 갖는 것으로 간주되는 것이 바람직하기 때문이다. 따라서 관할권 초과로 인한 명령이라 하더라도, 항소를 통해 무효화되기 전까지는 당사자들 간의 법적으로 유효한 명령으로 존속하며 집행된다. 그러나 그것은 법적 결함을 갖는다: 즉, 관할권 부족으로 인해 항소를 통해 무효화(quashed)될 가능성이 있다. 영국에서 통상 ‘파기(reversal)’와 ‘무효화(quashing)’ 사이에는 중요한 차이가 있다는 점은 주목할 만하다. 하급심의 판결이 파기되는 경우, 그것은 해당 판사가 적용한 법률 해석이나 사실 판단이 잘못되었다고 간주되기 때문이다. 반면, 관할권 부족으로 무효화되는 판결은 이 두 측면에서 아무런 문제가 없을 수 있다. 잘못된 것은 판사가 무엇을(what) 말했는가 또는 명령했는가가 아니라, 그러한 말이나 명령을 그가(his) 했다는 사실 자체이다. 즉, 그는 자신에게 법적으로 부여되지 않은 일을 행한 것이며, 다른 법원이라면 그럴 수 있었을지도 모른다. 단지 공공 질서 유지의 복잡성 때문에, 관할권을 초과하여 내려진 결정도 상급 법원이 무효를 선언하기 전까지는 유효한 것으로 간주될 뿐이다. 이 점에서, 사적 개인이 법적 권한을 행사할 때의 유효성 조건과 마찬가지로, 관할권 규칙에의 부합 여부는 ‘복종(obedience)’이나 ‘불복종(disobedience)’이라는 표현으로는 잘 설명되지 않으며, 이러한 표현은 형법과 같은 명령 유사 규칙의 경우에 보다 적절하다.

법률이 하위 입법 기관에게 입법권을 부여하는 경우 역시, 그러한 법규는 일반명령으로 환원될 수 없으며, (p. 31) 억지로 그렇게 환원할 경우 왜곡을 피할 수 없다. 이 경우에도 사적 권한의 행사처럼, 입법권을 부여하는 규정이 명시한 조건에 부합하는 것은 체스와 같은 게임에서의 ‘수’(move)와 같은 단계에 해당하며, 이는 체계가 개인들이 달성할 수 있도록 설정한 규칙에 의해 정의 가능한 결과를 가진다. 입법은 법적 권한의 행사이며, 이는 법적 권리와 의무를 창설하는 데 작용적—즉 효과적으로 기능한다. 부여 규칙의 조건에 부합하지

못할 경우, 그러한 행위는 효력을 갖지 못하며, 해당 목적에 있어 무효(nullity)가 된다.

입법권 행사의 근거가 되는 규정들은 법원의 사법권한을 구성하는 규정보다도 훨씬 다양하다. 왜냐하면 입법에 관한 다양한 측면들이 이를 통해 규율되어야 하기 때문이다. 예컨대, 일부 규칙은 입법권이 행사될 수 있는 주제를 명시하고, 다른 규칙은 입법기관의 구성원 자격이나 정체성을 명시하며, 또 다른 규칙은 입법의 형식 및 절차를 규정한다. 이들은 단지 관련된 사항 중 일부에 불과하다. 하위 입법 기관 또는 규칙 제정 기관의 권한을 부여하고 정의하는 법률, 예컨대 1882년 지방자치법(Municipal Corporations Act, 1882)과 같은 법령을 살펴보면 훨씬 더 많은 사항들이 드러난다. 이러한 규정들을 준수하지 못했을 때의 결과는 항상 동일하진 않지만, 적어도 어떤 규칙에 대해서는 이를 준수하지 않으면 입법권 행사의 시도가 무효로 간주되거나, 하급법원의 판결처럼 무효 선언 대상이 될 수 있다. 때때로 요구된 절차가 준수되었음을 입증하는 증명이 절차상 사항에 관해서는 결정적 효력을 갖도록 법적으로 규정되기도 하며, 자격을 갖추지 못한 자가 입법 절차에 참여할 경우, 특별 형법 규정에 따라 형사 처벌 대상이 되기도 한다. 그러나 이러한 복잡성에 의해 다소 가려지더라도, 입법권 행사 방식을 부여하고 정의하는 규칙들과 형법 규칙들—즉 위협에 의해 뒷받침되는 명령과 유사한 규칙들—사이에는 근본적인 차이가 존재한다.

일부 경우에는 이 두 유형의 규칙을 동일시하는 것이 기괴한 일일 수 있다. 입법기관에서 어떤 법안(a measure)이 요구되는 다수의 투표를 얻었고 그에 따라 통과되었다면, 그 법안에 찬성한 투표자들이 다수 결정을 요구하는 법에 ‘복종한(obeyed)’ 것이 아니고, (p. 32) 반대한 이들 역시 법에 ‘복종했’거나 ‘불복종한(disobeyed)’ 것이 아니다. 만일 그 법안이 필요한 다수에 도달하지 못하여 통과되지 못했다면, 이 역시 마찬가지이다. 이러한 규칙들의 기능적 차이는, 형법 규칙과 관련된 행위에 사용하는 용어들을 이곳에 적용하는 것을 원천적으로 불가능하게 만든다.

현대 법체계에 포함된 다양한 법규들을 포괄적으로 분류하고, 그것들을 모두 하나의 단순한 유형으로 환원됨에 틀림없다(must)는 편견 없이 이를 체계화하는 작업은 아직 완수되지 않았다. 우리가 지금까지 수행한 것은, 위협에 의해

뒷받침되는 명령과 유사한 의무 부과적 법규들과, 권한을 부여하는 법규들을 매우 거칠게 구별한 것에 불과하다. 그러나 여기까지의 논의만으로도, 법체계의 특수한 특징 중 일부는 바로 이러한 유형의 규칙을 통해 공적 및 사적 법적 권한의 행사를 가능케 하는 데 있다는 점이 드러났다고 할 수 있다. 만일 이러한 독자적인 유형의 규칙들이 존재하지 않는다면, 우리의 사회생활에서 가장 익숙한 개념들 중 일부는 존재하지 못할 것이다. 왜냐하면 그러한 개념들은 논리적으로 이러한 규칙들의 존재를 전제하기 때문이다. 형벌법과 같이 강제력을 동반하는 명령형 규칙이 존재하지 않는다면 범죄나 위반, 살인이나 절도라는 개념 또한 존재할 수 없으며, 마찬가지로 권한 부여 규칙이 없다면 매매, 증여, 유언, 혼인 등의 개념도 존재할 수 없다. 이러한 것들은—법원의 명령이나 입법기관의 법제정과 마찬가지로—법적 권한의 유효한 행사로 이루어진 것이기 때문이다.

그럼에도 불구하고, 법이론에서의 통일성에 대한 강박은 여전히 강력하다. 이는 결코 부끄러운 것이 아니므로, 우리는 위대한 법학자들에 의해 제시된 두 가지 대안 논증들을 고찰해보아야 한다. 이 두 논증은 우리가 강조한 법의 유형 간 구별이 피상적이거나 실제로는 존재하지 않는 것이며, 결국 모든 규칙은 위협에 의해 뒷받침되는 명령 개념으로 분석 가능하다는 점을 보여주하고자 한다. 오래 지속되어온 법이론 대부분이 그렇듯, 이 논증들에도 일정한 진실이 담겨 있다. 우리가 구별한 두 유형의 법규 사이에는 실제로 유사성이 존재하기 때문이다. 양쪽 경우 모두, 특정 행위는 규칙에 비추어 ‘법적으로 올바른’ 혹은 ‘잘못된’ 행위로 (p. 33) 평가될 수 있다. 예컨대 유언장을 작성하는 행위에 관한 권한 부여 규칙이나, 폭행을 금지하고 처벌하는 형법 규칙 모두는, 특정 행위를 이러한 방식으로 비판적으로 평가하는 기준(standards)을 구성한다. 이 점만 보더라도, 이들 모두를 ‘규칙’이라 부를 수 있는 이유가 암시되어 있다. 더 나아가, 권한 부여 규칙은 의무를 부과하는 규칙들과는 다르지만, 그러한 규칙들—즉 위협에 의해 뒷받침되는 명령에 유사한 규칙들—과 항상 관계를 맺고 있다는 점이 중요하다. 왜냐하면 권한 부여 규칙들이 부여하는 권한은, 결국 후자의 규칙들을 만들어내거나, 그러한 규칙이 적용되지 않던 특정 개인에게 새로운 의무를 부과할 수 있는 권한이기 때문이다. 이는 입법권이 부여된 경우 가장 분명히 드러나며, 뒤이어 논의하겠지만, 다른 법적 권한의 경우에도 마찬가지로

이다. 이러한 점에서, 어느 정도의 부정확성을 감수한다면, 형법 규칙은 의무를 부과하고, 권한 부여 규칙은 의무를 생성하는 조리법(recipes)이라고 말할 수도 있을 것이다.

제재로서의 무효(Nullity as a sanction)

첫 번째 논변은, 두 종류의 규칙이 본질적으로 동일하며 둘 다 강제 명령(coercive orders)의 성격을 갖는다는 점을 보이려는 시도로, 권한 행사에 필수적인 조건이 충족되지 않을 때 발생하는 ‘무효(nullity)’에 주목한다. 이 논변에 따르면, 무효란 형법상의 처벌처럼, 규칙 위반에 대해 법이 부과하는 위협된 해악(threatened evil) 또는 제재(sanction)와 마찬가지로 이해될 수 있다는 것이다. 물론 어떤 경우에는 그러한 제재가 단지 약간의 불편에 불과할 수도 있다는 점은 인식된다. 이러한 시각에서 우리는 다음과 같은 사례를 바라보도록 요청받는다. 즉, 어떤 사람이 자신에게 한 약속을 법적으로 강제 가능한 계약(contract)으로서 이행시키려 하지만, 그 약속이 인영(seal)이 없고, 자신이 대가를 제공하지 않았기 때문에, 그 서면 약속이 법적으로는 무효라는 사실을 뒤늦게 깨닫고 낙담하는 경우이다. 이와 유사하게, 두 명의 증인이 없는 유언장은 효력이 없다는 규칙은, 유언자(testator)로 하여금 Wills Act 제9조를 준수하도록 유도한다는 점에서, 우리가 형법의 처벌을 생각하며 그것을 준수하게 되는 것과 마찬가지로 주장된다.

이러한 무효와 심리적 요인(예: 법적 효력 발생에 대한 기대의 좌절) 간의 연관성이 어떤 경우에 존재함을 부정할 수는 없다. 그럼에도 불구하고, 제재(sanction)의 개념을 무효(nullity)로까지 확장하는 것은 (p. 34) 혼란의 원인이자 징후라 할 수 있다. 이에 대한 사소한 반론들은 이미 잘 알려져 있다. 예컨대, 어떤 경우에는 무효가 그 조건을 충족시키지 못한 당사자에게 해악이 아닐 수도 있다. 판사는 자기의 명령(order)의 유효성에 대해 아무런 물질적 관심이 없거나 무관심할 수 있으며, 계약상 상대방이 미성년자이거나 특정 계약에 요구되는 서면 기재 요건을 충족하지 않았다는 이유로 계약이 구속력을 갖지 않는 경우, 피고는 이를 ‘위협된 해악’이나 ‘제재’로 인식하지 않을 수도 있다. 그러나

이러한 사소한 반례들은 약간의 기지로 극복할 수 있다고 치더라도, 보다 본질적인 이유에서, 무효는 규칙이 금지하는 행위를 억제하기 위한 유인으로서의 처벌과 동일시될 수 없다. 형법 규칙의 경우, 우리는 다음 두 요소를 식별하고 구분할 수 있다: (1) 규칙이 금지하는 특정 유형의 행위, (2) 그것을 억제하기 위한 제재. 그러나 이러한 관점에서, 법적 형식 요건을 충족하지 않은 약속을 주고받는 것과 같은 사회적으로 바람직한 행위를 어떻게 설명할 수 있을까? 계약서 형식을 요구하는 법 규칙은 그러한 행위를 금지하거나 억제하려는 것이 아니라, 단지 그것들에 법적 인식을 부여하지 않을 뿐이다. 더욱이, 입법 조치가 필요한 정족수를 얻지 못해 법으로서의 지위를 획득하지 못하는 사실을 제재라고 간주하는 것은 더욱 부조리하다. 형법상의 제재와 이러한 사실을 동일시하는 것은, 마치 득점(goal)이나 출루(run)를 제외한 모든 움직임을 제거하려는 것으로 점수 규칙을 이해하는 것과 같다. 이것이 성공한다면 게임은 존재할 수 없게 될 것이다. 그러나 권한 부여 규칙(power-conferring rules)을 사람들로 하여금 특정한 방식으로 행동하게 만들기 위한 도구로 보고, ‘무효’를 복종의 동기로 추가하는 방식으로 해석할 때에만, 우리는 이 규칙들을 위협에 기반한 명령으로 동일시할 수 있다.

무효(nullity)를 형법상의 제재(threatened evil or sanction)와 유사한 것으로 간주하는 데서 발생하는 혼란은 다음 방식으로도 드러낼 수 있다. 형법 규칙의 경우, 설령 어떠한 처벌이나 해악이 위협되지 않는다고 하더라도, 그런 규칙들이 존재할 수 있으며 또 존재하는 것이 바람직할 수 있다는 점에서, 논리적으로 이러한 규칙은 성립 가능하다. 물론 이러한 경우 그것이 법적(legal) 규칙인지에 대해서는 논쟁이 있을 수 있지만, 우리는 (p. 35) 특정한 행위를 금지하는 규칙과, 그 규칙 위반 시 부과되는 처벌 규정을 명확히 구분할 수 있으며, 전자의 규칙이 후자의 처벌 없이도 존재할 수 있다고 상정할 수 있다. 즉, 우리는 제재를 제거한 후에도 여전히 유지될 수 있는 행위의 기준(standard of behaviour)을 상정할 수 있다. 그러나 유효한 유언을 위해 필요한 증인의 참여와 같은 조건을 요구하는 규칙과, 그것을 따르지 않았을 때의 ‘무효’라는 이른바 제재 사이에는 그러한 논리적 구분이 성립하지 않는다. 이 경우, 만약 이러한 필수 조건을 따르지 않아도 무효가 되지 않는다면, 그러한 규칙 자체는 비법적 규칙(non-legal rule)

로서조차 존재한다고 말할 수 없게 된다. 무효 규정은 이러한 유형의 규칙에서 처벌이 의무 부과 규칙에 결합된 방식과는 달리, 그 규칙 자체의 부분(part)이다. 만약 공 사이로 골대를 통과시키지 못하는 것이 ‘득점 실패(nullity of not scoring)’를 의미하지 않는다면, 득점 규칙 자체가 존재한다고 말할 수 없을 것이다.

우리가 비판한 이 논변은, 권한 부여 규칙(power-conferring rules)과 강제 명령(coercive orders)이 본질적으로 동일하다는 점을 입증하고자 하는 시도이며, 그 수단으로는 제재 또는 위협된 해악의 의미를 확장하여(widening), 그러한 규칙을 따르지 않을 경우 법적 행위가 무효가 된다는 점까지 포함시키려는 것이다. 반면, 다음에서 살펴볼 두 번째 논변은 전혀 다른, 오히려 정반대의 입장을 취한다. 이 논변은 이러한 규칙들이 강제 명령의 일종이라는 점을 보여주려 하기보다는, 아예 그것들을 ‘법(law)’의 범주에서 배제하려 한다. 이는 그러한 규칙을 제외하기 위해 단어 ‘법’의 의미를 좁히는 것이다(narrows). 이 논변은 다양한 법학자들 사이에서 다소 차이는 있지만 유사한 형태로 나타난다. 그 일반적 형식은 다음과 같다. 즉, 통상적인 언어 사용이나 일상적 표현에서 ‘완전한 법 규칙(complete rules of law)’이라고 간주되는 것들이, 실제로는 강제 규칙(coercive rules)의 단편(fragment)에 지나지 않으며, 오직 강제 규칙만이 ‘진정한(genuine)’ 법 규칙이라는 주장을 내세우는 것이다.

법의 일부 조각으로서의 권한부여 규칙(Power-conferring rules)

이 논증의 극단적인 형태에서는 형법(criminal law)의 규칙들조차, 그것들이 흔히 표현되는 문구로 보았을 때, 진정한 법(law)이 아니라고 부정하게 된다. 이와 같은 형태로 이 논증을 채택한 인물이 켈젠(Kelsen)이다. 그는 다음과 같이 말한다. “법이란 제재(sanction)를 명하는 기본규범(primary norm)이다.”¹⁵ 살인을 금지하는 법은 존재하지 않는다: 오직 (p. 36) 살인을 저지른 자에게 특정한 상황에서 특정한 제재를 가하도록 공무원(official)에게 명하는 법만이 있을 뿐이다. 이러한 관점에서, 일반 시민의 행위를 지도하기 위해 설계되었다

¹⁵General Theory of Law and State, p. 63. See above, p. 2.

고 여겨지는 법의 내용은, 실제로는 시민이 아닌 공무원에게 지시되는 규칙의 전건 또는 “if-절”에 불과하며, 그 규칙은 특정 조건이 충족되면 특정 제재를 가하도록 명령한다. 이 관점에 따르면, 모든 진정한 법은 공무원에게 제재를 적용하라는 조건적 명령이다. 이들은 모두 다음과 같은 형식을 갖는다. “어떤 종류 X의 행위가 행해지거나 생략되거나 발생한 경우, 그러면 Y 종류의 제재를 가하라.”

이러한 전건 또는 if-절의 점차적인 정교화를 통해, 사적 또는 공적 권한의 부여 및 그 행사 방식에 관한 규칙들을 포함한 모든 유형의 법규칙은 이와 같은 조건적 형식으로 재진술될 수 있다. 예컨대, 유언장법(Wills Act)의 두 명의 증인을 요구하는 규정은 다음과 같이 표현될 수 있다. 유언의 규정을 위반하고 유산을 지급하지 않는 집행자(executor)에게 법원이 제재를 가하도록 명하는 다양한 지시들에 공통적으로 포함된 부분으로서 말이다. 즉, “(if and only if) 이러한 규정을 담은 적법한 증인의 유언장이 있고 만약 ... 라면, 그에게 제재를 가해야 한다.” 이와 유사하게, 법원의 관할권(jurisdiction)의 범위를 명시하는 규칙 또한 제재를 적용하기 전에 충족되어야 할 조건의 공통 요소로 나타날 수 있다. 또한, 입법 권한을 부여하고 입법의 방식과 형식을 정의하는 규칙들(헌법에서 최고의 입법기관에 대해 규정하는 조항 포함) 또한 조건의 충족 여부에 따라 법원이 법률에 명시된 제재를 적용해야 한다는 것을 명시하는 조건절로 재구성될 수 있다. 따라서 이 이론은 실질을 형식에서 분리하여, ‘의회 내 여왕이 제정한 것이 법이다’라는 영국 헌정 형식이나, 미국 헌법의 의회의 입법권에 대한 규정은 단지 법원이 제재를 적용해야 할 일반 조건을 명시하는 것일 뿐이라는 점을 보여준다. 이러한 형식들은 본질적으로 “if-절”이며, 완전한 규칙이 아니다. 즉, “만약(if) 의회 내 여왕이 그렇게 제정하였다면 ...” 또는 “만약(if) 의회가 헌법에 명시된 한도 내에서 그렇게 제정하였다면 ...”이라는 형식은 법원이 제재를 가하거나 특정 행위를 처벌하도록 지시하는 수많은 명령의 조건에 해당한다.

(p. 37) 이는 매우 정교하고 흥미로운 이론으로, 다양한 일반적 형식과 표현에 의해 가려져 있던 법의 진정한 통일적인 본성을 드러내려는 시도이다. 이 이론의 결함들을 살펴보기 전에 먼저 주목할 점은, 이 극단적인 형태의 이론

에서는 법을 단지 명령과 제재(threats of sanctions)로 구성된 것으로 보는 초기 개념에서 벗어나, 공무원에게 제재를 가하도록 명령하는 것으로 중심 개념이 이동한다는 점이다. 이 관점에서는 모든 법 위반에 대해 제재가 규정되어 있어야 할 필요는 없다. 다만, 모든 ‘진정한’ 법이 어떤 제재의 적용을 명령하고 있으면 충분하다. 따라서 이러한 지시를 무시한 공무원이 처벌되지 않을 수도 있으며, 실제로도 많은 법체계에서 그러하다.

이 일반 이론은, 앞서 말했듯이, 두 가지 형태로 존재할 수 있는데, 하나는 다른 것보다 덜 극단적이다. 덜 극단적인 형태에서는, 많은 사람들이 직관적으로 더 수용 가능한 것으로 여기는 원래의 법 개념—즉, 일반 시민을 포함한 사람들에게 위협(threats)을 동반한 명령이 내려지는 구조—이 적어도 상식적으로 시민의 행위를 주로 대상으로 삼는 규칙들에 대해서는 유지된다. 이 보다 온건한 견해에 따르면, 형법의 규칙들은 그것 자체로 법이며, 다른 완전한 규칙의 일부 조각으로 재구성될 필요가 없다. 왜냐하면 그것들은 이미 위협을 동반한 명령이기 때문이다. 그러나 다른 경우에는 재구성이 필요하다. 사인(private individuals)에게 법적 권한을 부여하는 규칙들은, 이 온건한 이론에서도, 더 극단적인 이론에서와 마찬가지로, 진정한 완전한 법—위협을 동반한 명령—의 단편(fragment)에 불과하다. 이러한 진정한 법은 다음과 같은 질문을 통해 발견된다. 즉, 어떤 사람에게 법이 무언가를 하라고 명령하며, 이를 따르지 않을 경우 어떤 제재가 부과되는가? 이러한 질문에 따라, 1837년 유언장법(Wills Act)의 증인 규정이나, 사인에게 권한을 부여하고 그 유효한 행사의 조건을 정의하는 다른 규칙들은, 궁극적으로 그러한 법적 의무가 발생하는 조건 중 일부를 명시하는 것으로 재구성될 수 있다. 이들은 조건적 명령의 전건 또는 ‘if-절’의 일부로서, 위협을 동반하거나 의무를 부과하는 규칙의 일부로 나타난다. 예컨대, “(If and only if) 유언자가 서명하고 두 명의 증인이 명시된 방식으로 입회하여 유언장을 작성하였고 (p. 38) 만약 … 라면, 집행자(또는 다른 법적 대표자)는 유언의 조항을 이행해야 한다.” 계약의 성립과 관련된 규칙들도 마찬가지로, 특정 조건이 충족되었거나 특정한 말이나 행위가 있었을 경우(예: 당사자가 성년이며 인장을 통해 약속했거나 고려사항을 제공받았을 경우), 계약상 이행해야 할 행위를 하도록 명령하는 규칙의 단편으로 나타나게 된다.

입법 권한을 부여하는 규칙들(헌법에 있는 최고 입법기관 관련 조항 포함)을 ‘진정한’ 규칙의 단편으로 재구성하는 작업도, 이 이론의 더 극단적인 버전에서 설명된 36쪽의 방식과 유사하게 수행될 수 있다. 단지 차이점은, 보다 온건한 견해에서는 권한부여 규칙들이 일반 시민에게 위협을 통해 어떤 행위를 하도록 명령하는 규칙의 전건 또는 if-절로 나타나는 반면, 더 극단적인 이론에서는 공무원에게 제재를 가하도록 지시하는 규칙의 if-절로만 나타난다는 것이다.

이 이론의 두 가지 버전은 모두 외견상 서로 다른 다양한 법 규칙들을 하나의 형식으로 환원하려 시도하며, 이 형식이 법의 정수를 전달한다고 주장한다. 양자는 서로 다른 방식으로 제재를 중심 요소로 삼으며, 만일 제재 없는 법이 충분히 개념 가능하다는 점이 입증된다면, 양자 모두 실패하게 된다. 이 일반적인 반론은 후에 다루기로 하고, 여기서는 이 두 이론 모두에 제기할 수 있는 특정한 비판을 전개할 것이다. 그것은 이 이론들이 모든 법을 통일된 패턴으로 환원하는 데서 오는 통일성의 쾌감을 지나치게 높은 대가로 구매한다는 점이다. 즉, 서로 다른 유형의 법 규칙들이 수행하는 사회적 기능의 차이를 왜곡하고 있다는 것이다. 이 점은 이 이론의 두 형태 모두에 해당하지만, 특히 극단적인 형태가 요구하는 형법의 재구성에서 가장 뚜렷하게 나타난다.

통일성의 대가로서의 왜곡

이러한 재구성(recasting)에 의해 발생하는 왜곡(distortion)은 주목할 가치가 있다. 이는 법(law)의 여러 측면을 비추어 주기 때문이다. 사회를 통제하는 방식은 다양하지만, 형법(criminal law)의 고유한 방식은 규칙(rules)을 통해 특정한 유형의 행위를 전 사회 구성원 전체 혹은 특정 집단에 대한 지침(standards)으로 지정하는 것이다: 이들은 공식적인 담당자(official)의 도움이나 개입 없이도 (p. 39) 규칙을 이해하고, 규칙이 자신에게 적용된다는 점을 인식하며, 이에 따르도록 기대된다. 오직 법이 위반되어 이러한 법의 일차적 기능이 실패할 때에만, 담당자들이 위반 사실을 식별하고 예정된 제재(sanction)를 부과하는 문제에 관여하게 된다. 이 방식이, 교통 경찰이 운전자에게 주는 개별적이고 대면적인 명령과 비교해 고유한 점은, 사회 구성원들이 스스로 규칙을 발견하고

그에 따라 자신의 행동을 조정해야 한다는 것이다. 이 의미에서 그들은 규칙을 스스로에게 ‘적용(apply)’ 하는 것이며, 규칙에 덧붙여진 제재가 순응의 동기를 제공한다. 만약 우리가 규칙의 기능을, 불복종(disobedience)의 경우 법원이 제재를 부과해야 한다는 규칙에 초점을 맞추거나 그것을 중심으로 삼아 이해한다면, 이러한 규칙이 작동하는 고유한 방식을 가리게 된다. 이러한 후자의 규칙들은 필수 불가결할 수 있으나, 어디까지나 부차적인 것이다.

형법의 실질 규칙(substantive rules)이 그 기능—그리고 넓은 의미에서 그 의미—을 단지 제재 체계를 운영하는 담당자들만이 아니라, 공적 직무를 수행하지 않는 일반 시민들이 일상생활 속에서 따를 수 있도록 인도하는 데에 둔다는 관점은, 핵심적인 구별을 포기하고 법이라는 사회 통제 수단의 고유한 성격을 흐리지 않고서는 제거될 수 없다. 예컨대 범죄에 대한 처벌로서의 벌금(fine)은 특정 행위 양식에 부과되는 세금(tax)과 동일하지 않다. 비록 둘 다 같은 금전적 손실을 초래하라는 지시를 담당자에게 내린다는 점에서는 유사하더라도 말이다. 이 둘을 구분짓는 핵심은, 첫 번째는 일반 시민의 행위를 인도하기 위해 설정된 규칙을 위반하는 의무 위반(breach of duty), 즉 범죄(offence)를 수반한다는 점이다. 물론 이러한 구분은 특정 상황에서는 모호해질 수 있다. 예컨대 세금이 세수(revenue) 목적이 아니라 해당 행위를 억제하려는 목적으로 부과되기도 한다. 그러나 이 경우, 법은 해당 행위를 범죄화할 때처럼 명시적으로 그 행위를 중단할 것을 지시하지는 않는다. 반대로 어떤 형사 범죄에 대한 벌금이 화폐 가치 하락으로 너무 작아질 경우, 사람들은 이를 기꺼이 지불하게 되고, ‘단순한 세금일 뿐’이라는 인식이 생기며 ‘위반’은 빈번해진다. 이러한 맥락에서는, 해당 규칙이 형법 대부분처럼 진지하게 따를 행위 기준이라는 감각 자체가 사라진 것이다.

(p. 40) 이와 같은 이론을 옹호하는 사람들은 종종, 법을 제재 부과의 지시라는 형식으로 재구성함으로써 명료성을 얻는다고 주장한다. 이는 ‘나쁜 사람(bad man)’이 법에 대해 알고 싶어하는 바를 분명히 해준다는 것이다. 그럴 수도 있으나, 이론에 대한 충분한 방어가 되지는 않는다. 법은 ‘무엇을 해야 하는지 알려주기만 하면 따를 의사가 있는 당황한 사람(puzzled man)’이나 ‘무지한 사람(ignorant man)’, 혹은 ‘자신의 일을 계획하고자 하는 사람’에게 더

중점을 두어야 하는 것 아닌가? 물론 법을 제대로 이해하기 위해서는 법원이 제재를 적용하는 방식도 중요하다. 하지만 이로 인해 법을 이해한다는 것이 법정에서 벌어지는 일만을 아는 것으로 협소화되어서는 안 된다. 법이 사회 통제 수단으로서 수행하는 주요 기능은 사적 소송(private litigation)이나 형사 기소(prosecution)에서가 아니라, 법이 법정 밖의 삶을 어떻게 통제하고, 인도하며, 계획하도록 작용하는 다양한 방식에서 나타난다.

이러한 이론의 극단적 형태가 일으키는 ‘주된 것과 부차적인 것의 전도(inversion of ancillary and principal)’는 다음과 같은 사례에 비유할 수 있다. 어떤 이론가가 크리켓이나 야구의 규칙을 살피며, 규칙들이 단지 용어와 관행적 표현 때문에 구별되어 왔을 뿐 사실상 모두 동일한 유형의 규칙이라고 주장한다고 하자. 이 이론가는 “모든 규칙은 실제로는(really) 특정 조건 하에서 담당자가 특정한 일을 하도록 지시하는 규칙이다”라고 주장할 수 있다. 예를 들어 “타격 후의 특정 동작은 ‘출루(run)’가 된다”거나 “포구되면 아웃(out)이다”는 규칙은, 실상은 각각 득점 기록원(scorer)에게 ‘출루’를 기록하라고, 심판(umpire)에게 퇴장을 명하라고 지시하는 복합 규칙에 불과하다는 것이다. 그러나 이에 대한 자연스러운 반론은, 이러한 식의 규칙 일원화는 규칙들이 실제로 어떻게 작동하는지, 선수들이 목적 지향적 활동을 이끌기 위해 어떻게 사용하는지를 숨기며, 규칙이 본래 협력적이면서 경쟁적인 사회적 활동인 게임 속에서 수행하는 기능을 흐린다는 것이다.

이 이론의 덜 극단적인 형태는, 의무를 부과하는 형법(p. 41) 및 다른 모든 법은 건드리지 않는다. 이들은 이미 강제 명령의 단순한 모델에 부합하기 때문이다. 그러나 이론은 권한을 부여하거나 행사 방식 정의에 관한 모든 규칙을 단일한 형태로 축소하려 한다. 그러나 여기서도 동일한 비판이 제기될 수 있다. 만약 우리가 법을, 단지 의무가 부과되는 사람들의 관점에서만 바라보고, 법의 다른 모든 측면을 그들에게 의무가 발생하는 조건으로 환원한다면, 우리는 의무 만큼이나 법의 고유하고 사회적으로 가치 있는 요소들을 단순히 부차적인 것으로 취급하게 된다. 사적 권한(private powers)을 부여하는 규칙은, 이를 제대로 이해하려면, 그것을 행사하는 사람들의 관점에서 살펴보아야 한다. 그럴 때, 이러한 규칙은 단순한 강제 통제를 넘어서 사회생활에 도입된 추가적 요소로

드러난다. 이러한 권한은 일반 시민으로 하여금 단순한 의무 수납자가 아니라, 일종의 사적 입법자(private legislator)가 되게 한다. 시민은 자신의 계약, 신탁(trusts), 유언(wills), 기타 권리와 의무 구조 내에서 법의 경로를 정할 수 있는 권한을 가진 존재가 되는 것이다. 이처럼 특별한 방식으로 사용되며 고유한 혜택을 제공하는 규칙이, 단순히 의무를 부과하는 규칙과 동일하게 취급되어야 할 이유는 무엇인가? 이 권한 부여 규칙들은 사회생활 속에서 의무 규칙과는 전혀 다르게 인식되고, 언급되며, 사용되고, 다른 이유로 가치 있게 여겨진다. 그렇다면 이러한 특성을 구별하는 기준은 무엇이 있을 수 있는가?

입법 및 사법 권한을 부여하고 정의하는 규칙들을, 단지 의무가 발생하는 조건으로 환원하는 접근은 공적 영역에서도 유사한 왜곡을 낳는다. 이러한 권한을 행사하여 법적 효력을 가진 법령이나 명령을 만드는 사람들은, 단순한 의무 수행이나 강제 통제에 복종하는 것과는 전혀 다른 목적 지향적 활동을 수행하고 있다. 이러한 규칙들을 단지 의무 규칙의 파편이나 측면으로 나타내는 것은, 사적 영역에서보다도 더 심하게, 법의 고유한 특성과 그 틀 내에서 가능한 활동의 다양성을 흐리게 만든다. 사회에 입법자가 새로운 의무 규칙을 도입하거나 (p. 42) 기존 규칙을 변경하도록 허용하는 규칙, 그리고 판사가 어떤 규칙이 위반되었는지를 판단할 수 있도록 하는 규칙을 도입한 것은, 바퀴의 발명에 비견될 만큼 중요한 진보였다. 이는 단지 중요한 발전일 뿐 아니라, 우리가 제5장에서 논의하듯, 전(前)법적(pre-legal) 세계에서 법적 세계(legal world)로 넘어가는 결정적 전환으로 간주될 수 있는 발전이기도 하다.

2. 적용 범위

형벌법(penal statute)은 다양한 법의 형태 중에서도 단순한 강제 명령(coercive orders)의 모델에 가장 가까운 형태임이 분명하다. 하지만 이러한 법조차도, 이 절에서 살펴보듯, 이 모델이 우리에게서 가리게 만드는 특유의 성질을 지니고 있다. 그리고 우리는 이 모델의 영향력을 떨쳐내기 전까지 그것들을 제대로 이해하지 못할 것이다. 위협(threats)을 동반한 명령(order)은 본질적으로 타인(others)이 어떤 행동을 하거나 하지 않기를 바라는 소망의 표현이다. 물론, 입

법이 이러한 오직 타인 지향적인(other-regarding) 형태를 취하는 것도 가능하다. 입법권을 가진 절대군주(absolute monarch)는 일부 체제에서 자신이 만든 법의 적용대상에서 항상 제외되는 존재로 간주될 수 있다. 민주주의 체제에서도, 법을 만든 이들에게는 적용되지 않고 법에서 명시한 특정 계층에만 적용되는 법이 제정될 수 있다. 그러나 어떤 법의 적용 범위(range of application)는 언제나 그 법의 해석(interpretation)에 달려 있다. 해석 결과, 입법자가 법 적용 대상에서 제외될 수도 있고 그렇지 않을 수도 있다. 물론, 현대에는 법을 만든 사람들에게도 법적 의무(legal obligations)를 부과하는 입법이 자주 이루어진다. 단순히 타인(others)에게 위협을 통해 무언가를 하게 하는 명령과 구분되는 입법은, 얼마든지 스스로에게 구속력을 부여하는(self-binding) 힘을 가질 수 있다. 입법은 본질적으로(essentially) 타인 지향적일 필요가 없다. 이러한 법적 현상은, 우리가 법을 항상 법 위에 서 있는 어떤 사람이 법 아래에 있는 다른 사람들을 위해 정한 것이라고 보는 모델의 영향력 하에 있을 때에만 난해한 것으로 여겨진다.

이러한 수직적(vertical) 또는 ‘상층에서 하층으로(top-to-bottom)’의 법제정 이미지—그 단순성으로 인해 매우 매력적인 이 이미지는—입법자(legislator)를 그의 공적 지위(capacity)에서는 한 사람으로, 사적 지위에서는 또 다른 사람으로 구별함으로써만 현실과 조화시킬 수 있다. 입법자는 첫 번째 지위에서 행동함으로써, 두 번째 지위(자신의 사적 지위)를 포함하여 타인들에게 의무를 부과하는 법을 제정하게 된다. 이러한 표현 방식에는 문제가 없지만, (p. 43) 우리가 제4장에서 보게 될 바와 같이, 이러한 지위(capacities)의 개념은 강제 명령으로 환원될 수 없는 권한 부여 규칙(power-conferring rules of law)을 전제로 해야만 비로소 이해 가능하다. 한편으로는, 이러한 복잡한 장치 자체가 사실상 전혀 필요 없다는 점도 주목할 필요가 있다. 우리는 입법의 자기구속적 성격(self-binding quality)을 이 장치를 동원하지 않고도 설명할 수 있다. 우리의 일상생활과 법제도 속에는 이를 훨씬 더 잘 이해할 수 있게 해주는 것이 존재하기 때문이다. 그것은 바로 약속(promise)의 작용이다. 강제 명령보다도 오히려 약속은 법의 여러 특성을 이해하는 데 있어 훨씬 더 나은 모델이 될 수 있다.

약속하기란, 약속하는 사람(promisor)에게 의무를 발생시키는 말을 하는

것이다. 이러한 말이 그런 효과를 가지려면, 적절한 인물이 적절한 상황에서 (즉, 자신의 위치를 이해하고 정신이 온전하며 다양한 외적 압력에서 자유로운 경우) 특정한 말을 사용하면, 그 말을 사용한 사람은 그 내용대로 행동해야 한다는 규칙이 존재해야 한다. 그러므로 우리가 약속을 할 때, 우리는 규칙에 의해 부여된 ‘권한(a power)’을 행사하여, 자신에게 의무를 부과하고 타인에게 권리를 부여함으로써 자신의 도덕적 상황을 변화시키는 특정 절차를 사용하는 것이다. 이 과정은 다음과 같은 비유로도 설명할 수 있다. 약속자 내부에 두 인물이 있다고 상정하고, 한 인물은 의무를 만드는 자의 지위에서, 다른 인물은 그 의무에 속박되는 자의 지위에서 행동한다고 하며, 전자가 후자에게 무언가를 명령한다고 생각하는 것이다. 그러나 이는 가능한 상정일 뿐, 도움이 되는 설명 방식은 아니다.

입법의 자기구속력을 이해하는 데 있어서도, 우리는 이와 같은 장치를 생략할 수 있다. 법을 만드는 행위는 약속을 만드는 행위와 마찬가지로, 특정한 과정을 지배하는 규칙의 존재를 전제로 한다. 이러한 규칙에 의해 정당하게 자격을 부여받은 사람이, 그 절차에 따라 말하거나 글로 쓴 내용은, 명시적이든 묵시적이든 해당 범위에 포함되는 모든 사람에게 법적 의무를 발생시킨다. 이에는 입법 과정에 참여한 사람들도 포함될 수 있다.

물론, 입법과 약속 사이에는 자기구속력을 설명해주는 유비(analogy)가 존재하긴 하지만, 둘 사이에는 많은 차이점도 있다. 입법을 규율하는 규칙은 훨씬 더 복잡하며, 약속이 지니는 쌍방성(bilateral character)은 입법에는 없다. 일반적으로 약속에는 그것이 향하는(to whom) 특별한 지위를 가진 상대방—즉 약속을 받은 사람(promisee)—이 있으며, 이 사람은 (p. 44) 그 이행에 대한 특별한, 때로는 유일한 권리를 가진다. 이러한 점에서, 입법의 자기구속적 측면과 더 밀접한 유비를 제공하는 것은, 영국법에서 인식되는 다른 형태의 자기의무 부과 방식일 수 있다. 예컨대 어떤 사람이 자신이 특정 재산의 신탁자(trustee)임을 선언하는 경우가 그러하다. 그럼에도 일반적으로 말해, 법 제정을 통한 법의 생성은 특정한 법적 의무를 창출하는 이러한 사적 방식들을 통해 가장 잘 이해될 수 있다.

강제 명령 또는 규칙이라는 모델에 대한 가장 필요한 교정적 관점은, 입법

을 사회 전체가 따를 일반적 행위 기준(*general standards of behaviour*)의 도입 혹은 수정으로 새롭게 개념화하는 것이다. 입법자는 반드시 타인에게 명령을 내리는 자—즉 자신이 하는 일의 적용 범위 밖에 있는 자—처럼 행동하는 것은 아니다. 그는 약속을 하는 사람(*the giver of a promise*)처럼, 규칙에 의해 부여된 권한을 행사하는 자이다. 그리고 종종, 약속자(*promisor*)가 반드시 그러해야 (*must*) 하듯이, 그 자신도 그 권한의 적용 범위 안에 포함될 수 있다.

3. 기원의 방식

지금까지 우리는 법의 다양한 형태 중에서도, 강제 명령(*coercive orders*)과 유사한 점이 두드러지는 제정법(*statute*)에 논의를 국한해 왔다. 앞서 강조한 차이점들에도 불구하고, 제정법은 강제 명령과 하나의 뚜렷한 유사점을 지닌다. 즉, 법의 제정(*enactment*)은, 명령을 내리는 행위와 마찬가지로, 의도적이고 특정한 시점에 이루어지는 행위이다(*is a deliberate datable act*). 입법에 참여하는 자들은 의식적으로 법을 만드는 절차를 작동시키며, 이는 마치 명령을 내리는 자가 자신의 의도를 인식시키고 복종을 확보하기 위해 특정한 표현을 의도적으로 사용하는 것과 유사하다. 이러한 이유로, 법을 강제 명령의 모델로 분석하는 이론들은 모든 법이 결국 이 점에서 입법과 유사한 형태를 가지며, 그 법적 지위를 의도적인 법 창조 행위(*law-creating act*)에 기인한다고 주장한다. 이 주장을 가장 명백하게 거스르는 법 유형은 관습(*custom*)이다. 그러나 관습이 ‘진정한 법(*real law*)’ 인가에 관한 논의는, 다음의 두 가지 문제를 분리하지 못했기 때문에 종종 혼란스럽게 진행되어 왔다. 첫 번째 문제는, ‘관습 그 자체로서(*custom as such*)’ 법이 될 수 있는가이다. 관습 그 자체가 법이 아니라는 부정에는, 어떤 사회든 다수의 관습이 존재하지만 그 모두가 법의 일부는 아니라는 단순한 진리가 담겨 있다. 예컨대 여성에게 모자를 벗지 않는 것은 법 규칙 위반이 아니며, 법적으로는 단지 허용(*permitted*)된 행동일 뿐이다. 이것은, 관습이 법이 되기 위해서는 반드시 (p. 45) 특정 법체계 내에서 ‘법으로서 인식(*legal recognition*)’ 되어야 하는 관습의 하나여야 함을 보여준다. 두 번째 문제는, ‘법적 인식(*legal recognition*)’이라는 표현의 의미이다. 하나의 관습이 법으로 인식된다는 것은

무엇을 의미하는가? 강제 명령의 모델이 요구하듯, 이는 누군가—예컨대 ‘주권자(the sovereign)’ 혹은 그의 대리인(agent)—가 그 관습을 따르라고 명령하였기 때문인가? 그렇다면 그 관습의 법적 지위는, 이러한 점에서 입법 행위와 유사한 어떤 것에 근거한다는 뜻인가?

현대 사회에서 관습은 그다지 중요한 법의 ‘원천(source)’이 아니다. 대개는 종속적(subordinate) 지위에 있으며, 이는 입법부가 법률로 관습 규칙의 법적 지위를 박탈할 수 있다는 의미이다. 또한 많은 법체계에서 법원이 어떤 관습이 법적 인식을 받을 수 있는지를 판단할 때 적용하는 기준은 ‘합리성(reasonableness)’과 같은 유동적인 개념을 포함한다. 이러한 점 때문에, 법원이 관습을 수용하거나 배제할 때 거의 무제한적 재량(discretion)을 행사한다고 보는 견해에 일정한 근거가 있다. 그럼에도 불구하고, 관습이 법적 지위를 갖는 이유가 법원이나 입법부 또는 주권자가 그러한 ‘명령’을 내렸기 때문이라고 말하는 것은, 지나치게 확장된 의미의 ‘명령’ 개념을 전제하지 않고서는 유지될 수 없는 이론을 받아들이는 것이다.

이러한 법적 인식(legal recognition)이라는 교리를 제시하기 위해, 우리는 강제 명령 모델에서 주권자(the sovereign)가 수행하는 역할을 상기해야 한다. 이 이론에 따르면, 법은 주권자 혹은 그가 대신하여 명령을 내리도록 지명한 하급자의 명령이다. 첫 번째 경우, 법은 ‘명령(order)’이라는 가장 문자적인 의미로 주권자의 명령에 의해 만들어진다. 두 번째 경우, 하급자가 내린 명령은, 그것이 다시 주권자의 명령에 근거한 것일 때만 법으로 간주될 수 있다. 이 하급자는 주권자로부터 명령을 내릴 권한을 위임받아야 한다. 때때로 이러한 권한은, 예컨대 장관에게 특정 주제에 대해 ‘명령을 내리도록(make orders)’ 지시하는 명시적 명령(express direction)을 통해 부여된다. 그러나 이 이론이 여기서 멈춘다면 현실을 설명하지 못하게 되므로, 이 이론은 확장되어 주권자가 자신의 의사를 보다 간접적으로 표현하는 경우도 있다고 주장하게 된다. 그의 명령은 ‘묵시적(tacit)’일 수 있다. 즉, 주권자가 명시적인 명령을 내리지 않더라도, 그의 하급자들이 국민에게 명령을 내리고 불복종에 대해 처벌할 때 그에 개입하지 않음으로써, 주권자는 국민이 특정한 일을 하기를 바란다는 의사를 나타내는 것이다.

(p. 46) ‘묵시적 명령(tacit order)’의 개념을 가능한 명확하게 설명하기 위해 군사적 예시를 들어보자. 어느 하사가 자신보다 상급자의 명령에는 늘 복종 하면서, 부하 병사들에게 특정한 잡무(fatigues)를 지시하고, 명령 불복종 시 벌을 준다. 그 장군은 이 사실을 알고도 이를 허용한다. 만약 장군이 하사에게 잡무를 중지하라고 명령했다면, 그는 따랐을 것이다. 이러한 상황에서는, 장군이 병사들이 잡무를 수행하길 원한다는 의사를 묵시적으로 표현했다고 볼 수 있다. 개입할 수 있었지만 하지 않았다는 점에서, 그 침묵은 마치 그가 잡무를 명령했을 때 사용했을지도 모를 말을 대체하는 것이다.

이러한 시각에서 우리는 법체계 내에서 법적 지위를 가진 관습 규칙들을 바라보도록 요청받는다. 법원이 구체적 사건에 그것을 적용하기 전까지, 이러한 규칙들은 단지(mere) 관습일 뿐이며, 어떤 의미에서도 법은 아니다. 법원이 그 규칙들을 사용하고, 그것에 따라 명령을 내리며, 그것이 집행될 때 비로소 이 규칙들은 법적 인식(legal recognition)을 받는다. 이때 개입할 수도 있었지만 개입하지 않은 주권자는, 법관들이 기존 관습에 기초해 내린 명령을 국민이 따르도록 묵시적으로 명령한 셈이 되는 것이다.

이러한 관습(custom)의 법적 지위에 대한 설명은 두 가지 상이한 비판에 직면한다. 첫 번째 비판은, 관습 규칙이 소송(litigation)에서 사용되기 전까지는 법적 지위를 전혀 갖지 못한다는 것이 반드시(necessarily) 참은 아니라는 점이다. 이러한 주장이 ‘반드시’ 그렇다고 말하는 경우, 이는 단순한 독단(dogma)이거나, 법체계에 따라 그럴 수도 있는 경우와 반드시 그런 경우를 구분하지 못하는 데서 비롯된다. 만일 특정 방식으로 제정된 제정법(statutes)이, 법원이 구체적 사건에서 이를 적용하기 이전에도 법으로 간주된다면, 일정한 기준을 만족하는 관습 역시 마찬가지로 법이 될 수 없는가? 입법자의 제정은 법이라는 일반 원칙을 법원이 구속력 있게 받아들이듯이, 일정한 유형의 관습 역시 법이라는 또 다른 일반 원칙을 법원이 구속력 있게 인식한다고 보는 것이 왜 불합리한가? 어떤 사건이 발생했을 때, 법원이 관습을 마치 제정법처럼, 이미 법이기 때문에 적용하는 것이라고 주장하는 것이 어째서 말이 되지 않는가? 물론 어떤 법체계에서는, 관습 규칙이 법으로서의 지위를 가지기 위해서는 반드시 법원이 그것을 그렇게 선언해야 한다고 규정할 수도 있다(possible). 그러나

이것은 단지 하나의(one) 가능성일 뿐이며, 법원이 그와 같은 재량권(discretion)을 갖지 않는 체계의 가능성을 배제할 수는 없다. 그렇다면 (p. 47) 관습 규칙은 반드시 법원에 의해 적용되기 전에는 법이 될 수 없다(cannot)는 일반적 주장을 어찌 확립할 수 있겠는가?

이러한 반론들에 대한 답변은 종종, 단지 “무언가가 법이 되기 위해서는 반드시 어떤 사람이 그것이 법이라고 명령(order) 해야 한다”는 독단을 되풀이하는 데 그친다. 이와 같은 입장에서, 법원이 제정법과 관습에 대해 취하는 관계가 유사하다는 주장은 거부된다. 이유는, 제정법은 법원이 적용하기 전에 이미 ‘명령’되었지만, 관습은 그렇지 않다는 것이다. 좀 더 비독단적인 논증들도, 특정 법체계의 구체적인 규정을 지나치게 일반화하기 때문에 설득력을 갖지 못한다. 예컨대, 영국법에서는 어떤 관습이 ‘합리성(reasonableness)’ 기준을 통과하지 못하면 법원에 의해 거부될 수 있다는 사실을 들어, 관습이 법원이 적용하기 전까지는 법이 아니라고 말한다. 하지만 이것은 기껏해야 영국법에서의 관습에 관해 무언가를 말해줄 뿐이다. 그것조차도 확실하지 않다. 왜냐하면, 일부 주장과 달리, 법원이 ‘합리적인’ 관습만을 적용하도록 구속되어 있는 체계와, 법원이 전적인 재량으로 관습을 수용 또는 배제하는 체계를 구별하는 것이 무의미하다고 단정할 수는 없기 때문이다.

두 번째, 보다 근본적인 비판은 다음과 같다. 관습이 법이 될 경우, 그것이 주권자의 묵시적 명령(tacit order)에 의해 법적 지위를 갖게 된다는 주장은 설득력이 없다. 비록 개별 사건에서 법원이 그것을 집행하기 전까지는 관습이 법이 아니라고 인식한다 하더라도, 주권자가 개입하지 않았다는 사실만으로 그가 해당 규칙의 준수를 원했다는 의사 표현으로 해석할 수 있는가? 심지어 앞서 46 쪽에서 언급된 매우 단순한 군사적 예시에서도, 장군이 하사의 명령에 개입하지 않았다는 사실로부터 그 명령이 이행되기를 바랐다고 반드시 추론할 수는 없다. 그는 단지 유능한 부하를 달래고자 했거나, 병사들이 어떻게든 잡무를 피하길 바랐을 수도 있다. 물론 경우에 따라, 장군이 해당 잡무가 수행되기를 바랐다고 추론할 수도 있을 것이다. 하지만 그렇다 하더라도, 그 추론의 중요한 근거는 장군이 명령의 존재를 알고 있었으며, 그것을 숙고할 시간도 있었고, 그럼에도 불구하고 아무 행동도 하지 않기로 결정했다는 사실이다. 그러나 현대 국가에서

관습의 법적 지위를 설명하기 위해 주권자의 의사가 묵시적으로 표현되었다는 개념을 사용하는 것은 매우 부적절하다. 현대 국가에서는, 우리가 주권자를 최고 입법기관(supreme legislature)이나 유권자(electorate)로 식별한다 하더라도, 그 ‘주권자’에게 그러한 지식, 숙고, 비개입하기로 하는 결정을 (p. 48) 귀속시키는 것이 거의 불가능하다. 대부분의 법체계에서 관습은 제정법보다 하위의 법원천이라는 점은 사실이다. 이는 입법부가 언제든지 그 법적 지위를 박탈할 수 있다(could)는 뜻이다. 그러나 입법부가 그렇게 하지 않았다는 사실이 곧 입법부의 의사(wish)를 반영한다고 말할 수는 없다. 입법부가 법원이 적용하는 관습 규칙에 관심을 기울이는 경우는 드물며, 유권자의 관심은 그보다 훨씬 더 드물다. 그러므로 이들의 ‘비개입’은, 장군이 하사의 명령에 개입하지 않은 경우와 비교될 수 없다. 하사의 사례에서조차, 우리가 장군의 의사를 그렇게 추론하려면 상당한 근거가 필요한 것이다.

그렇다면, 관습의 법적 인식(legal recognition)은 도대체 무엇을 의미하는가? 만약 그것이 특정 사건에 관습을 적용한 법원의 명령이나, 최고 입법기관의 묵시적 명령에 의한 것이 아니라면, 관습 규칙은 어떻게 법적 지위를 가지는가? 법원이 그것을 적용하기 전에, 제정법과 마찬가지로 법일 수 있는 이유는 무엇인가? 이러한 질문들은, 우리가 다음 장에서 상세히 검토할 “법이 존재하려면, 반드시 어떤 주권적 인물의 일반 명령—명시적이든 묵시적이든—이 존재해야 한다”는 교리를 분석하기 전까지는 완전히 답변될 수 없다. 그에 앞서, 이 장의 결론을 다음과 같이 요약할 수 있다:

법을 강제 명령의 체계로 보는 이론은 처음부터 다음과 같은 세 가지 점에서 이 모델에 들어맞지 않는 법의 다양성에 직면한다. 첫째, 형벌법조차도 타인에게 내리는 명령과는 적용 범위가 다른 경우가 많다. 왜냐하면 이러한 법은 다른 사람뿐 아니라 그 법을 제정한 사람에게도 의무를 부과할 수 있기 때문이다. 둘째, 다른 제정법들은 명령과는 달리 특정 행위를 요구하지 않고, 오히려 권한(power)을 부여하는 기능을 수행한다. 이러한 법들은 의무를 부과하기보다는, 법의 강제적 틀 내에서 법적 권리와 의무를 자율적으로 창출할 수 있는 수단을 제공한다. 셋째, 비록 제정법의 제정은 여러 면에서 명령과 유사할 수 있으나, 일부 법 규칙은 관습에서 유래하며, 의도적인 법 창조 행위에 그 지위를 의존하

지 않는다.

이러한 비판들에 맞서기 위해 다양한 우회적 장치들이 제안되어 왔다. 악(惡)의 위협 또는 ‘제재(sanction)’라는 단순한 개념은 법적 행위의 무효(nullity)까지 포함하도록 확장되었고, (p. 49) 법적 규칙의 개념은 권한을 부여하는 규칙을 법의 단편(fragment)으로 치부하여 제외하도록 좁혀졌으며, 입법자의 자기 구속 문제는 한 사람 안에 두 인물이 있다고 가정하는 방식으로 해결되었다. 나아가, 명령의 개념 자체도 언어적 표현에서 하급자의 명령에 대한 비개입이라는 ‘묵시적 표현’으로 확장되었다. 이러한 장치들의 교묘함에도 불구하고, 위협에 의해 뒷받침되는 명령의 모델은 오히려 법의 본질을 가리는 경향이 있다. 법의 다양성을 이러한 단일하고 단순한 형태로 환원하려는 노력은, 허위의 통일성(spurious uniformity)을 법에 강요하게 된다. 사실, 제5장에서 주장하겠지만, 법의 가장 핵심적인 특성—혹은 적어도 결정적인 특성 중 하나—은 바로 다양한 유형의 규칙이 융합되어 있다는 데에 있을지도 모른다.

CHAPTER III 주석

26쪽. 법의 다양한 형태(*The varieties of law*). 법에 대한 일반적 정의를 추구하는 과정에서, 서로 다른 유형의 법 규칙들 사이에 존재하는 형식과 기능상의 차이가 가려지게 되었다. 이 책의 주된 논증은, 의무(duty)를 부과하는 규칙과 권한(power)을 부여하는 규칙 사이의 차이가 법철학(jurisprudence)에서 결정적으로 중요하다는 것이다. 법은 이 두 가지 상이한 유형의 규칙이 결합된 것(union)으로 이해될 때 가장 잘 설명된다. 따라서 본 장에서는 법 규칙 유형들 사이의 주요 구분으로 이 점을 강조하고 있지만, 다른 여러 구분 역시 가능하며, 어떤 목적에서는 반드시 이루어져야 한다. 보다 다양한 사회적 기능을 반영하는 법의 분류는, 그 언어적 형식에도 자주 드러나며, 이에 관해서는 Daube의 *Forms of Roman Legislation* (1956)을 참조할 수 있다.

27쪽. 형사법과 민사법에서의 의무(*Duties in criminal and civil law*). 의무 부과 규칙과 권한 부여 규칙 사이의 구분에 주의를 집중하기 위해, 우리는 형법상의 의무와 불법행위법(tort) 및 계약법(contract)상의 의무 간의 많은 차이들을 생략하였다. 이러한 차이에 주목한 일부 이론가들은, 계약이나 불법행위의 경우에 특정 행위를 이행하거나 금지할 '1차(primary)' 또는 '선행(antecedent)' 의무는 실체가 없으며, 진정한 의무는 특정한 사정(예: 이른바 1차 의무 불이행) 하에서 손해배상을 하도록 하는 구제(remedial) 또는 제재적(sanctioning) 의무뿐이라고 주장하기도 한다. 이에 대해서는 Holmes의 *The Common Law* 제8장을 참조하되, Buckland의 *Some Reflections on Jurisprudence* 96쪽과 *The Nature of Contractual Obligation*, *Cambridge Law Journal* 제8권(1944년)에서의 비판을 함께 참고하라. 또한 Jenks의 *The New Jurisprudence* 179쪽도 참조할 것.

27쪽. 의무(obligation)와 의무(duty). 영미법(Anglo-American Law)에서는 이 두 용어가 현재 대체로 동의어로 사용되지만, 형법이 '의무(obligations)'를 부과한다고 말하는 것은 (법의 요구 사항에 대한 추상적 논의, 예컨대 도덕적 의무와 법적 의무의 분석 같은 경우를 제외하면) 일반적이지 않다. 변호사들은 여전히 계약상의 의무나 불법행위 후 손해배상 의무 등처럼 특정 개인이 다른 특정 개인에 대해 가지는 권리(right in personam)가 존재하는 경우에 'obligation'이라는 단어를 가장 흔히 사용한다. 그 외의 경우에는 'duty'라는 표현이 보다 일반적이다. 이는 현대 영어법에서, 로마법의 *obligatio*가 특정한 개인들 사이를 묶는 법적 유대(vinculum juris)라는 본래 의미에서 살아남은 유일한 흔적이다. (Salmond, *Jurisprudence*, 제11판, 제10장 260쪽 및 제21장 참조; 또한 본서 제5장 제2절 참조).

28쪽. 권한 부여 규칙(Power-conferring rules). 대륙법계의 법이론에서는 법적 권한을 부여하는 규칙들을 종종 '권능 규범(norms of competence)'이라 부른다. (Kelsen,

General Theory, 90쪽, A. Ross, *On Law and Justice* (1958), 34, 50-59, 203-225쪽 참조). Ross는 사적 권능(private competence)과 공적 권능(social competence)을 구분하며, 이에 따라 계약과 같은 사적 행위와 공적 법행위를 구별한다. 그는 또한 권능 규범은 의무를 명령하지 않는다고 지적한다. “권능 규범은 그 자체로는 직접적인 지시(directive)가 아니며, 의무로서 절차를 명령하지 않는다. … 권능 규범은 권능을 가진 자에게 그 권한을 행사해야 한다고 말하지 않는다.” (위 책, 207쪽). 그러나 이러한 구분에도 불구하고, Ross는 본 장에서 비판된 관점을 받아들인다. 즉, 그는 권능 규범도 결국 ‘행위 규범(norms of conduct)’으로 환원될 수 있다고 주장하며, 두 유형의 규범은 모두 “법원을 향한 지시(directives to the Courts)”로 해석되어야 한다고 본다. (같은 책, 33쪽).

이 장의 본문에서 다양한 시도를 비판하며 제시한 논점은, 이러한 두 규칙 유형 간의 구분을 없애거나 단지 피상적인 차이에 불과하다고 보는 입장들이 갖는 문제점에 있다. 이러한 구분이 중요한 의미를 갖는 다른 사회적 삶의 양태들을 고려하는 것도 유익하다. 도덕(morals)에서, 어떤 사람이 구속력 있는 약속을 했는지를 판단하는 모호한 규칙들은, 개인에게 제한된 도덕적 입법권을 부여하는 기능을 하며, 강제적 의무 규칙과는 구분될 필요가 있다 (Melden, ‘On Promising’, *Mind* 제65권 (1956); Austin, ‘Other Minds’, *PAS* 보충권 20권 (1946), *Logic and Language* 2집에 재수록; Hart, ‘Legal and Moral Obligation’, Melden 편, *Essays on Moral Philosophy* 참조). 복잡한 게임의 규칙들도 이 관점에서 유익하게 분석될 수 있다. 일부 규칙은 형법처럼 특정 행위를 금지하고 위반 시 제재를 가한다 (예: 반칙 행위나 심판에 대한 무례). 또 다른 규칙들은 심판, 기록원, 주심 등의 경기 담당자들의 관할권(jurisdiction)을 정의한다. 다시 다른 규칙들은 득점 조건을 규정한다 (예: 득점(goal)이나 출루(run)). 출루나 득점을 위한 조건을 충족하는 것은 경기에서 승리를 향한 결정적 단계이며, 이를 충족하지 못한 것은 득점 실패이며, 이 관점에서 ‘무효(nullity)’로 간주된다. 여기에는 표면적으로 서로 다른 유형의 규칙들이 존재하며, 이들은 게임 내에서 다양한 기능을 수행한다. 그러나 어떤 이론가는 이러한 규칙들이 모두 하나의 유형으로 환원될 수 있으며, 환원되어야 한다고 주장할 수도 있다. 예컨대 득점 실패라는 무효는 금지된 행위에 대한 제재(sanction)로 간주될 수도 있고, 혹은 모든 규칙은 특정 조건 하에서 경기 담당자들에게 특정 행동을 하도록 지시하는 것으로 해석될 수 있다는 것이다 (예: 점수를 기록하거나 선수를 퇴장시키는 것). 그러나 이러한 방식으로 두 유형의 규칙을 하나로 환원하는 것은, 규칙들의 고유한 성격을 흐리게 만들며, 게임에서 중심적인 요소를 단지 부차적인 요소에 종속시키는 결과를 낳는다. 따라서 본 장에서 비판한 환원주의적 법이론들이,

사회 활동의 한 체계로서 법이 구성하는 법 규칙들의 다양한 기능들을 유사하게 은폐하고 있는지, 다시금 숙고할 필요가 있다.

29쪽. 사법권을 부여하는 규칙과 판사에게 의무를 부과하는 추가 규칙 동일한 행위가 관할권을 초과한 행위(excess of jurisdiction)로 간주되어 사법 결정이 무효(nullity)로 취소될 수 있는 동시에, 판사가 자신의 관할권을 넘지 않도록 요구하는 특별한 규칙의 위반으로 간주될 수 있다고 해도, 이 두 규칙 유형의 구분은 여전히 유지된다. 예컨대, 판사가 자신의 관할권을 넘어 사건을 심리하거나 그 결정이 무효화될 다른 방식으로 행동하는 것을 방지하기 위한 금지명령(injunction)이 인식된다면, 혹은 그러한 행위에 대해 제재(penalty)가 규정되어 있다면 이러한 경우에 해당한다. 마찬가지로, 법적으로 자격이 없는 인물이 공적 절차에 참여한 경우, 그 절차를 무효화시킬 뿐만 아니라 해당 인물에게 제재를 가할 수 있다. (이와 관련된 제재에 대해서는 *Local Government Act 1933*, 제76조 및 *Rands v. Oldroyd* (1958), 3 AER 344 참조. 다만 이 법은 지방정부의 절차가 구성원 자격의 결함으로 인해 무효가 되지는 않는다고 규정함—같은 법, 제3부, 부속서 III, 제5항).

33쪽. 제재로서의 무효(nullity as a sanction) Austin은 *The Lectures* 제23강에서 이 개념을 채택하였으나, 별도로 전개하지는 않았다. 이에 대한 비판은 Buckland, 앞서 인용한 책의 제10장에서 참조하라.

35쪽. 권한 부여 규칙을 의무 부과 규칙의 단편으로 보는 이론 이 이론의 극단적인 형태는 Kelsen이 전개한 것으로, 법의 기본 규칙(primary rules of law)은 법원이나 공적 기관이 일정 조건 하에서 제재를 부과해야 한다는 규칙이라는 견해와 함께 제시된다 (*General Theory*, 58–63쪽; 헌법 관련 논의는 143–144쪽 참조). 그는 “헌법 규범은 독립적이고 완결된 규범이 아니라, 법원이나 기타 기관이 적용해야 할 모든 법 규범의 내재적 부분(intrinsic parts)이다”라고 주장한다. 이러한 교리는 법을 정적(static) 방식으로 설명할 때에만 성립하는 것으로 제한되며, 동적(dynamic) 방식과는 구별된다 (같은 책, 144쪽). Kelsen의 논의는 또한 다음과 같이 복잡해진다. 즉, 그는 계약 체결 권한 등 사적 권한을 부여하는 규칙의 경우, 계약에 의해 생성되는 ‘이차 규범(secondary norm)’ 또는 의무는 “단순한 법이론상의 보조적 구성물이 아니다”라고 주장한다 (같은 책, 90쪽, 137쪽). 그럼에도 본질적으로 Kelsen의 이론은 본 장에서 비판된 이론에 속한다. 보다 단순한 형태로는 Ross의 주장을 참조할 수 있다: “권능 규범은 간접적 형식의 행위 규범이다”(Ross, 같은 책, 50쪽). 모든 규칙을 의무 부과 규칙으로 환원하는 보다 온건한 이론으로는 Bentham의 *Of Laws in General*, 제16장 및 부록 A-B 참조.

39쪽. 법적 의무를 예측으로, 제재를 행위에 대한 세금으로 보는 이론 이 두 이론은

Holmes의 “The Path of the Law” (1897, *Collected Legal Papers*)를 참조하라. Holmes는 의무 개념이 도덕적 의무와 혼동되었다고 보고, 그것을 “냉소적 산(acid of cynicism)”에 담귀 씻어내야 한다고 주장하였다. “우리는 ‘의무(duty)’라는 단어에 도덕에서 끌어온 모든 내용을 채워 넣는다” (같은 책, 173쪽). 그러나 법 규칙을 행위 기준(standards of conduct)으로 간주하는 관점은, 그것들을 도덕 기준과 동일시할 필요는 없다 (제5장 제2절 참조). Holmes가 ‘나쁜 사람(Bad Man)’이 어떤 일을 할 경우 불쾌한 결과를 겪게 될 것이라는 ‘예언(prophecy)’으로서 의무를 정의한 데 대한 비판은 A. H. Campbell의 Frank 저서 *Courts on Trial*에 대한 서평, *Modern Law Review* 제13권(1950), 그리고 본서 제5장 제2절, 제7장 제2절과 제3절에서 확인할 수 있다.

미국 연방대법원은 제1조 제8절(의회에 과세 권한을 부여하는 미국 헌법 조항) 적용에 있어서 벌금(penalty)과 세금(tax)을 구별하는 데 어려움을 겪어왔다. 참조: *Charles C. Steward Machine Co. v. Davis*, 301 U.S. 548 (1937).

41쪽. 개인은 의무 수납자인 동시에 사적 입법자임 Kelsen의 법적 능력(legal capacity)과 사적 자율성(private autonomy) 논의와 비교하라 (*General Theory*, 90쪽, 136쪽).

42쪽. 입법자가 자신을 구속하는 입법(*Legislation binding the legislator*) 명령이나 사령은 언제나 타인에게 적용되는 것이라는 전제에 기반하여 명령 이론(imperative theories of law)을 비판하는 논의는 Baier의 *The Moral Point of View* (1958), 136–139쪽을 참조하라. 그러나 일부 철학자들은 자기지향 명령(self-addressed command)의 개념을 수용하며, 이를 1인칭 도덕 판단(first-person moral judgments) 분석에도 적용한다. (Hare, *The Language of Morals*, 제11–12장에서 ‘Ought’ 논의 참조). 본문에서 입법과 약속의 유비를 제시한 부분은 Kelsen, *General Theory*, 36쪽도 함께 보라.

45쪽. 관습과 묵시적 사령(*Custom and tacit commands*) 본문에서 비판된 교리는 Austin의 것으로, *The Province of Jurisprudence Determined*, 제1강 30–33쪽 및 *The Lectures*, 제30강 참조. 묵시적 사령(tacit command) 개념을 사용하여 명령 이론과 조화되게 다양한 법 형태의 인식을 설명하는 시도는 Bentham의 *Of Laws in General*, 21쪽에서 제시된 ‘수용(adoption)’ 및 ‘수습(susception)’ 이론을 참조하라. 또한 Morison, ‘Some Myth about Positivism’, *Yale Law Journal* 제68권 (1958) 및 본서 제4장 제2절도 참고. 묵시적 사령 개념에 대한 비판은 Gray, *The Nature and Sources of the Law*, §§ 193–199 참조.

49쪽. 명령 이론과 법령 해석(*Imperative theories and statutory interpretation*) 법이 본질적으로 명령(order)이며, 따라서 입법자의 의지(will) 또는 의도의 표현이라는 교

리는, 본장에서 제기한 것 외에도 다양한 비판에 직면한다. 어떤 비판자들은, 이러한 교리가 법령 해석의 과업을 ‘입법자의 의도(the intention of the legislator)’를 찾는 것으로 오도하였다고 본다. 그러나 입법자가 복합적이고 인위적인 집단(body)일 경우, 그 의도를 찾거나 증명하는 데 어려움이 있을 뿐 아니라, “입법자의 의도”라는 표현 자체에 명확한 의미가 없을 수 있다. 관련 논의는 Hägerström, *Inquiries into the Nature of Law and Morals*, 제3장 74-97쪽 참조. 입법 의도라는 개념에 포함된 허구에 대해서는 Payne, ‘The Intention of the Legislature in the Interpretation of Statute’, *Current Legal Problems* (1956) 참조. 입법자의 ‘의지(will)’ 개념에 대한 논의는 Kelsen, *General Theory*, 33쪽도 함께 보라.

CHAPTER III 제3판 주석

27-32쪽. 권한 부여 규칙(Power conferring rules). Hart는 『벤담에 대한 에세이: 법철학과 정치이론』(*Essays on Bentham: Jurisprudence and Political Theory*, 옥스퍼드대 출판부, 1982) 제8장 “법적 권한(Legal Powers)”에서 자신의 견해를 수정하였다. 권한 부여 규칙에 대한 보다 일반적인 논의로는 Joseph Raz의 『실천적 이유와 규범(Practical Reason and Norms)』(제2판, 옥스퍼드대 출판부, 1990) 97-106쪽을 참조하라. 또한 Joseph Raz와 D. N. MacCormick 간의 「자발적 의무와 규범적 권한」(‘Voluntary Obligation and Normative Powers’)에 대한 심포지엄도 참고할 것 (1972년 아리스토텔레스 학회 회보 보충판, 제46권, 59쪽). 공적 권한(public powers)에 대해서는 G. H. Von Wright, 『규범과 행위(Norm and Action)』(Humanities Press, 1963) 제10장을 참조하고, 또한 Eugenio Bulygin, 「권능 규범에 관하여」(*On Norms of Competence*) (1992) *Law and Philosophy* 제 11권 201쪽도 참고할 수 있다.

32쪽. 법의 분류법(Taxonomy of laws). 보다 정교한 분류 체계에 대해서는 A. M. Honoré의 「실질적 법률(Real Laws)」을 참조하라. 이 글은 P. M. S. Hacker와 J. Raz가 편집한 『법, 도덕, 그리고 사회(Law, Morality and Society)』에 수록되어 있다.

38-39쪽. 제재와 법의 사회적 기능(Sanctions and the social functions of law). Hans Oberdiek, 「법과 법체계를 이해하는 데 있어 제재와 강제 의 역할」(*The Role of Sanctions and Coercion in Understanding Law and Legal Systems*) (1976) *American Journal of Jurisprudence* 제71권 21쪽 참조. Joseph Raz, 『실천적 이유와 규범』 157-162쪽, John Finnis, 『자연법과 자연권(Natural Law and Natural Rights)』 266-270쪽, Grant Lamond, 「강제와 법의 본성」(*Coercion and the Nature of Law*) (2001) *Legal Theory* 제7권 35쪽, Frederick Schauer, 「Austin이 결국 옳았는가?—법 이론에서 제재의 역할」(*Was Austin*

Right After All? On the Role of Sanctions in a Theory of Law) (2010) *Ratio Juris* 제23권 1 쪽도 참조할 것. 법이 강제를 ‘허용’ 하는 방식으로 기능한다고 보는 견해에 대해서는 Ronald Dworkin, 『법의 제국(*Law's Empire*)』 제3장을 참조하라. 특히 92-94쪽을 주목할 것.

38-42쪽. ‘나쁜 사람’의 관점(*The ‘bad man’s’ point of view*). William Twining, 「‘나쁜 사람’ 다시 보기」(*The Bad Man Revisited*) Stephen Perry는 Hart의 이론이 ‘나쁜 사람’의 관점을 배제할 철학적 자원을 갖추고 있지 않다고 비판한다. 그의 글 「Holmes 대 Hart: 법이론에서의 나쁜 사람」(*Holmes versus Hart: The Bad Man in Legal Theory*)은 Steven J. Burton 편, 『법의 길과 그 영향: 올리버 웬델 홈즈 주니어의 유산』(*The Path of the Law and Its Influence: The Legacy of Oliver Wendell Holmes Jr.*), 캠브리지대 출판부, 2000년에 수록되어 있다. 법을 전적으로 유인 수단(*incentivizing device*)으로 이해하려는 시도는 특히 경제학자들 사이에서 지속되고 있다. 관련 저작으로는 Richard Posner의 『법경제학(*Economic Analysis of Law*)』(제8판, Aspen Publishers, 2010)과 『법철학의 문제들(*The Problems of Jurisprudence*)』(하버드대 출판부, 1990)이 있다. 가장 정교한 논의는 Lewis A. Kornhauser, 「법의 규범성」(*The Normativity of Law*) (1999) *American Law and Economics Review* 제1권 3쪽 참조.

44-49쪽. 관습법(*custom*)과 법의 원천으로서의 관습 John Gardner, 『법은 신념의 도약이다(*Law as a Leap of Faith*)』 제3장 「일부 법의 유형(*Some Types of Law*)」 참조. 또한 Amanda Perreau-Saussine과 James B. Murphy 편집, 『관습법의 본성: 법적, 역사적, 철학적 관점(*The Nature of Customary Law: Legal, Historical and Philosophical Perspectives*)』(케임브리지대 출판부, 2007)의 수록 논문들도 참고할 것. Dworkin은 Hart가 그의 승인 규칙(*rule of recognition*) 이론에 비추어 관습을 일관되게 설명할 수 없다고 비판한다. 관련 논의는 *Taking Rights Seriously*, 41-44쪽 참조.

IV. 주권자와 수범자(SOVEREIGN AND SUBJECT)

법을 강제 명령(coercive orders)의 단순한 모델로 보는 관점을 비판하는 데 있어서, 지금까지 우리는 이러한 관점에 따르면 모든 사회의 법을 구성한다고 여겨지는 ‘일반 명령(general orders)’을 발하는 주권자(sovereign)라는 인물 또는 집단에 대한 문제를 제기하지 않았다. 사실, 위협에 의해 뒷받침되는 명령이라는 개념이 법의 다양한 유형을 설명하는 데 적절한지에 대해 논할 때, 우리는 잠정적으로 다음과 같은 전제를 받아들였다. 즉, 법이 존재하는 어떤 사회든, 구성원 대부분이 어떤 특정한 인물 또는 집단의 명령에 습관적으로 복종(habit of obedience)하고, 그 인물 또는 집단은 다른 누구의 명령에도 습관적으로 복종하지 않는다는 식으로 정의되는, 그러한 주권자가 실제로 존재한다는 점이다.

이제 우리는, 모든 법체계의 기반에 대한 일반 이론으로서 이 교설을 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있다. 왜냐하면, 비록 이 이론은 극단적으로 단순한 형식을 갖추고 있지만, 주권 이론(doctrine of sovereignty)은 결코 그 중요성이 단순하지 않기 때문이다. 이 이론은 다음과 같이 주장한다. 즉, 어떤 인간 사회든 법이 존재하는 곳에는, 정치적 형태가 아무리 다양하더라도, 민주주의든 절대군주제든, 그 표면 아래에는 항상 복종을 습관적으로 행하는 수범자(subjects)와 다른 누구에게도 복종하지 않는 주권자 사이의 단순한 관계가 잠재되어 있다는 것이다. 이러한 수직 구조(sovereign-subject structure)는, 이 이론에 따르면, 법을 가진 사회라면 반드시 갖추어야 하는 필수 구성 요소이며, 이는 마치 인간에게 척추(backbone)가 필수적인 것과 마찬가지이다. 만약 이 구조가 존재한다면, 우리는 그 사회를 주권자와 함께 하나의 독립된 국가(state)라고 부를 수 있으며, 그 사회의 법(its law)에 대해서도 말할 수 있다. 반대로, 이 구조가 존재하지 않는다면, 이 이론에 따르면, 위와 같은 표현들 자체가 성립하지 않는다. 왜냐하면, 주권자와 수범자의 관계는 이러한 개념들 자체의 의미를 구성하는 일부이기 때문이다.

이 이론에서 특히 중요한 두 가지 핵심 요소가 있으며, 본 장 전체에서 제

시될 비판의 방향을 개괄하기 위해 여기서 일반적인 형태로 먼저 제시해두고자 한다. 첫 번째는, 복종의 습관(a habit of obedience) 개념이다. 이 이론에 따르면, (p. 51) 주권자의 법이 적용되는 자들에게 요구되는 것은 오직 그 습관뿐이다. 여기서 우리는 다음과 같은 문제를 제기할 것이다. 입법권이 서로 다른 입법자들에게 연속적으로 계승되는 법의 권위의 연속성(continuity)과, 법을 제정한 사람과 그에게 복종했던 사람들이 모두 사라진 이후의 법의 지속성(persistence)을 단지 습관만으로 설명할 수 있는가? 두 번째는, 주권자가 법 위에 있는 지위(legally unlimited status)에 대한 문제이다. 주권자는 타인을 위해 법을 만들고, 타인에게 법적 의무나 ‘제한(limitations)’을 부과하지만, 그는 자신은 어떤 법에도 구속되지 않는 존재라고 주장된다. 여기서 우리는, 법이 존재하기 위해 최고 입법자가 법적으로 무제한적인 존재여야 하는가, 그리고 입법 권력에 법적인 한계가 존재하거나 존재하지 않는 현상을 단지 복종과 습관이라는 이 이론의 요소만으로 설명할 수 있는지를 살펴볼 것이다.

1. 복종의 습관과 법의 연속성

복종(obedience)이라는 개념은, 겉보기에 단순해 보이고 분석 없이 자주 사용되지만, 결코 단순한 것이 아니다. 우리는 이미 앞서 지적했던 복잡성—즉, ‘복종’이라는 말이 흔히 단순히 위협에 따른 명령 이행이 아니라, 권위(authority)에 대한 존중까지를 내포한다는 점—은 여기서 제외하고 논의할 것이다¹⁶. 그럼에도 불구하고, 한 사람이 다른 사람에게 얼굴을 맞대고 내리는 단일 명령(single order)의 경우조차, 그 명령의 발화와 그에 따른 특정 행위 사이에 어떤 관계가 존재해야 그것을 ‘복종’이라 부를 수 있는지를 정확히 기술하는 일은 결코 쉽지 않다. 예컨대, 명령을 받지 않았더라도 명령받은 것과 동일한 행동을 했을 인물에 대해, 과연 그 행위를 복종이라고 할 수 있는가? 이러한 어려움은 특히 법의 경우에 두드러진다. 어떤 법들은 사람들이 원래는 생각조차 하지 않았을 행동을 금지하는 경우도 있다. 이러한 문제들이 해결되기 전까지는, 한 나라의 법에 대한 ‘일반적인 복종 습관’이라는 개념 자체가 상당히 불분명한 상태로 남을

¹⁶See p. 19 above.

수밖에 없다. 그러나 지금의 목적을 위해, ‘습관(habit)’과 ‘복종(obedience)’이라는 단어가 비교적 명백하게 적용될 수 있을 것 같은 매우 단순한 사례를 상정해보자.

(p. 52) 우리는, 한 인구 집단이 일정한 영토에 거주하며, 그곳에서 한 절대 군주(Rex)가 매우 오랫동안 통치하고 있다고 가정하자. Rex는 다양한 행동을 요구하거나 금지하는 위협을 동반한 일반 명령을 통해 사람들을 통제하고 있으며, 이러한 명령은 사람들이 원래는 하지 않을 행동을 하게 만들고, 반대로 원래 하려던 행동을 하지 못하게 만든다. 통치 초기에는 문제도 있었지만, 시간이 흐르면서 사회는 안정되었고, 일반적으로 사람들은 Rex의 명령에 따르는 것으로 간주된다. Rex의 요구가 종종 부담스럽고, 불복종하고 처벌받을 위험을 감수하고자 하는 유혹도 상당하므로, 이 경우 복종이 이루어지더라도 그것이 ‘습관적(habitual)’이라거나 ‘습관(habit)’이라는 단어가 일반적으로 함의하는 바를 완전히 충족한다고 보기 어렵다. 어떤 법에 대한 준수는 실제로 문자 그대로 ‘습관화’될 수도 있다. 예컨대, 영국인에게 좌측차로운행(driving on the left-hand side)은 그러한 습득된 습관의 전형(paradigm)일 수 있다. 그러나 세금을 납부하라는 법처럼, 강한 내적 성향에 반하는 법의 경우, 우리가 결국 그것을 따르게 된다 하더라도 그 준수는 무심하고 노력 없는 자동성이라는 습관의 특성을 결여한다. 그럼에도 불구하고, Rex에 대한 복종에는 습관의 전형적 요소는 결여되더라도, 다른 중요한 요소들이 존재한다. 예컨대 “그 사람은 아침에 신문을 읽는 습관이 있다”고 말할 수 있으려면, 그는 일정 기간 동안 그 행동을 반복해왔으며, 앞으로도 반복할 가능성이 높아야 한다. 만약 그렇다면, 우리의 가상 사회에서는, 초기 혼란기를 지난 어느 시점 이후 대부분의 사람들이 일반적으로 Rex의 명령을 따랐으며, 앞으로도 그럴 가능성이 높다고 말할 수 있을 것이다.

여기서 주목할 점은, Rex의 통치 하에서의 이 사회적 상황에 대한 설명에 따르면, 복종의 습관(habit of obedience)은 Rex와 각 수범자 간의 개별적 관계라는 점이다. 각 개인은, Rex가 여러 사람에게 내린 명령 중 자신에게 해당하는 것을 규칙적으로 수행한다. 우리가 “이 인구 전체(population)가 그런 습관을 갖고 있다”고 말할 경우, 이는 “사람들이 토요일 밤마다 주점에 가는 습관이

있다”고 말할 때와 마찬가지로, 단지 대다수 사람들의 습관이 수렴(convergent)한다는 의미일 뿐이다. 즉, 그들 각각이 Rex의 명령에 복종하듯, 각각이 토요일 밤마다 주점을 찾는 것이다.

이러한 매우 단순한 상황에서 주권자 Rex를 구성하는 데 공동체로부터 요구되는 것은, 인구 각자의 개별적인 복종 행위뿐이라는 점에 주목할 필요가 있다. 각자는 자신에게 주어진 역할로서 단지 복종하면 된다. 그리고 (p. 53) 복종이 정기적으로 다가오는 한, 공동체 내 누구도 Rex에 대한 자신의 복종이나 타인의 복종이 어떤 의미에서든 정당한지, 적절한지, 또는 정당하게 요구된 것인지에 대해 견해를 가질 필요도, 이를 표현할 필요도 없다. 우리가 위에서 묘사한 사회는 ‘복종의 습관(habit of obedience)’이라는 개념을 가능한 한 문자 그대로 적용하기 위해 상정된 매우 단순한 사회이며, 실상 이 정도로 단순한 사회가 실제로 존재한 적이 있을 가능성은 거의 없다. 또한 분명히 이 사회는 ‘원시적’이지도 않다. 왜냐하면 원시 사회는 Rex 같은 절대군주에 대해 거의 알지 못하며, 그 구성원들은 단순히 복종하는 데 그치지 않고, 복종의 정당성에 대한 명확한 견해를 갖기 때문이다. 그럼에도 불구하고, Rex 하의 공동체는 최소한 Rex의 생애 동안에는 법에 의해 통치되는 사회가 갖는 여러 중요한 특징들을 분명히 지닌다. 이 사회는 심지어 일정한 통일성(unity)도 갖고 있으며, 따라서 이를 하나의 ‘국가(state)’라 부를 수 있을 것이다. 이 통일성은 구성원들이 동일한 인물에게 복종한다는 사실에서 비롯되며, 그 복종이 정당한지에 대해 견해가 있는지는 상관없다.

이제 다음과 같은 상황을 가정해보자. Rex가 성공적인 통치를 마치고 사망하고, 그의 아들 Rex II가 새롭게 일반 명령들을 내리기 시작한다. Rex I에 대한 복종이 그 생전에 일반적 습관(general habit)이었다는 사실만으로는, Rex II가 습관적으로 복종받게 되리라는 가능성조차 보장하지 못한다. 따라서 만약 우리가 의존할 수 있는 것이 Rex I에 대한 복종이라는 사실과 그가 계속 통치했다면 그가(he) 계속 복종받았을 것이라는 가능성뿐이라면, 우리는 Rex II가 내린 첫 번째 명령에 대해 Rex I의 마지막 명령에 대해 말할 수 있었던 바—즉 그것이 주권자에 의해 내려진 것이므로 곧 법이다—를 말할 수 없다. Rex II에 대한 복종 습관은 아직 형성되지 않았기 때문이다. 이 이론에 따르면, Rex II가

실제로 Rex I처럼 복종을 받게 되는지를 지켜보아야 하며, 그때에야 비로소 Rex II가 주권자이고 그의 명령이 법이라는 말을 할 수 있게 된다. Rex II는 애초부터 주권자가 되는 것이 아니다. 그의 명령이 일정 시간 동안 복종받았다는 사실이 확인된 뒤에야, 우리는 복종의 습관이 형성되었다고 말할 수 있을 것이다. 그리고 그때에야 비로소, Rex II의 그 이후 명령은 발효되는 순간부터, 복종 여부와 관계없이 이미 법이라고 말할 수 있게 된다. 이 단계에 도달하기 전까지는, 어떤 법도 제정될 수 없는 권력 공백기(interregnum)가 존재하게 된다.

물론 이러한 상황은 현실에서 가능하며, 불안정한 시기에는 실제로 벌어 지기도 한다. 그러나 연속성의 단절(discontinuity)이 가져올 위험은 분명하며, 일반적으로는 이러한 위험을 피하려 한다. 그 대신, (p. 54) 심지어 절대군주 제에서조차도, 한 입법자에서 다른 입법자로의 이행을 중단 없이 연결시키기 위한 규칙들이 존재하는 것이 법체계의 특징이다. 이러한 규칙들은 사전에(in advance) 후계자를 지정하거나, 후계자의 자격 요건과 결정 방식을 일반적인 형태로 규정한다. 현대 민주주의에서 이러한 자격 요건은 매우 복잡하며, 자주 바뀌는 구성원들로 이루어진 입법기관의 구성을 규율한다. 하지만 우리가 상정한 단순한 군주제 상황에서도, 연속성 유지를 위해 필요한 규칙들의 본질은 여전히 파악할 수 있다. 예컨대 규칙이 장남이 계승하게 되어 있다고 규정한다면, Rex II는 Rex I의 뒤를 이을 자격(title)을 갖게 된다. 그는 Rex I의 사망과 함께 법을 제정할 권리(right)를 갖게 되며, 그의 첫 명령이 발해질 때, 그 명령은 그에 대한 복종 습관이 형성되기 전이라 하더라도 이미 법이라는 충분한 이유가 있을 수 있다. 실제로는 그러한 복종 관계가 전혀 형성되지 않을 수도 있다. 그럼에도 불구하고 그의 말은 법이 될 수 있다. Rex II는 첫 명령을 내린 직후 죽을 수도 있으며, 그러면 그는 복종을 받을 시간조차 없었을 것이다. 그럼에도 그는 법을 제정할 권리(right)를 가졌으며, 그의 명령은 법일 수 있다.

개별 입법자들이 교체되는 가운데에서도 법 제정 권한의 연속성을 설명하기 위해 우리는 흔히 ‘계승 규칙(rule of succession)’, ‘자격(title)’, ‘계승할 권리(right to succeed)’, ‘법 제정 권리(right to make law)’와 같은 표현을 사용한다. 그러나 이 표현들을 사용하는 순간, 우리는 이미 복종의 습관(habit of obedience)이라는 개념만으로는 설명할 수 없는 새로운 요소들을 도입하게 된다. 이 요소

들은 바로, Rex I의 단순한 법 세계를 주권 이론의 규정대로 구성할 때 우리가 기반으로 삼았던 것들과는 본질적으로 다르다. 왜냐하면 그 세계에서는 규칙도, 권리도, 자격도 존재하지 않았고, 따라서 계승할 권리나 자격은 더더군다나(a fortiori) 없기 때문이다. 존재하는 것은 단지 Rex I가 명령을 내렸고, 그 명령들이 습관적으로 복종되었다는 사실뿐이었다. Rex를 생전에 주권자로 구성하고, 그의 명령을 법으로 만드는 데에는 그것만으로 충분했다. 그러나 그의 후계자가 권리(rights)를 가진다고 말하기 위해서는, 그것만으로는 부족하다. 실제로 복종의 습관이라는 개념은, 한 입법자가 다른 입법자로 교체되는 모든 정상적인 법체계에서 관찰되는 연속성을 설명하는 데 두 가지 방식에서 실패한다. 첫째, 어떤 입법자의 명령에 대한 복종의 습관만으로는, (p. 55) 새로운 입법자에게 구 입법자를 대신할 어떤 권리(right)도 부여할 수 없다. 둘째, 이전 입법자에 대한 습관적 복종만으로는, 새 입법자의 명령이 복종될 것이라는 가능성을 뒷받침하거나 추정할 근거가 될 수 없다. 만약 이러한 권리와 추정이 계승 순간에 존재해야 한다면, 이전 입법자의 통치 기간 동안, 사회 내부 어딘가에 복종 습관만으로는 설명할 수 없는 더 일반적인 복합적 사회적 실천이 존재했어야 한다. 그것은 곧, 새 입법자가 계승할 자격이 있다는 규칙(rule)이 받아들여졌음(acceptance)을 의미한다.

그렇다면 이러한 보다 더 복합적인 실천(more complex practice)이란 무엇인가? ‘규칙의 수용(acceptance of a rule)’이란 무엇인가? 여기서 우리는 제1장에서 이미 개괄해 두었던 탐구를 다시 이어가야 한다. 이 질문에 답하기 위해 우리는 한동안 법 규칙의 특수한 경우에서 벗어나야 한다. 습관(habit)과 규칙(rule)은 어떻게 다른가? 사람들이 토요일 밤마다 영화관에 가는 습관이 있다고 말하는 것과, 교회에 들어설 때 남성은 반드시 모자를 벗어야 한다는 규칙이 있다고 말하는 것 사이에는 어떤 차이가 있는가? 우리는 이미 제1장에서 이러한 유형의 규칙을 분석하기 위해 반드시 도입되어야 할 몇 가지 요소들을 언급한 바 있으며, 이제는 그 분석을 한 걸음 더 진전시켜야 할 것이다.

사회적 규칙과 습관 사이에는 확실히 하나의 유사점이 존재한다. 두 경우 모두에서 문제 되는 행위(예: 교회에서 모자를 벗는 행위)는 반드시 전반적으로 일반적이어야 하며, 반드시 항상 반복될 필요는 없다. 즉, 기회가 생기면 대다수

집단 구성원이 그 행위를 반복한다는 점에서 “그들은 그것을 규칙으로써(as a rule) 한다”고 말하는 표현은 바로 이 의미를 담고 있다. 하지만 이러한 유사성이 있음에도 불구하고, 양자 사이에는 세 가지 중요한 차이점이 있다.

첫째, 집단이 어떤 습관(habit)을 갖고 있다고 하기 위해서는, 단지 그들의 행동이 실제로 수렴(converge)하면 충분하다. 즉, 정형화된 행위에서 벗어나는 일이 있어도 그것이 어떤 비판의 대상이 될 필요는 없다. 그러나 행동의 일반적 수렴 또는 일치만으로는, 그 행동을 요구하는 규칙이 존재한다고 말하기에 충분하지 않다. 규칙이 있는 경우에는, 그로부터의 이탈은 일반적으로 실수(lapse) 또는 과오(fault)로 간주되어 비판의 대상이 되고, 이탈이 예상될 경우 동조를 요구하는 압력이 발생한다. 이러한 비판과 압력의 양상은 규칙의 유형에 따라 다양하다.

둘째, 이러한 규칙이 존재하는 경우에는, 실제로 이러한 비판이 이루어질 뿐만 아니라, 규범에서 이탈했다는 사실 자체가 그러한 비판을 할 하나의 좋은 이유(good reason)로 일반적으로 받아들여진다. 이탈에 대한 비판은 (p. 56) 이런 의미에서 정당하거나(legitimate) 정당화된(justified) 것으로 간주되며, 이탈이 예고될 때 기준에 따라 행동할 것을 요구하는 것도 마찬가지이다. 나아가, 소수의 완고한 위반자들을 제외하면, 이러한 비판과 요구는 그것을 하는 사람들뿐만 아니라 그것을 받는 사람들에게 의해서도 일반적으로 정당하거나, 또는 좋은 이유로 제기된 것으로 간주된다. 집단이 어떤 규칙을 갖고 있다고 말하기 위해서는, 얼마나 많은 사람들이 이처럼 규범적 기준을 기준으로 비판하고, 얼마나 자주 그리고 얼마나 오랫동안 그렇게 해야 하는지에 대해 명확한 기준은 없다. 이 문제는 어느 정도 머리카락이 빠져야 ‘대머리’라고 할 수 있는지에 대해 고민하는 것과 마찬가지로 너무 엄밀하게 따질 필요는 없다. 우리가 기억해야 할 것은, 한 집단에 특정한 규칙이 존재한다는 진술은, 그 규칙을 위반할 뿐 아니라 그 규칙을 자기 자신이나 타인에 대한 기준으로 받아들이기를 거부하는 소수의 존재와도 양립할 수 있다는 점이다.

셋째로, 사회 규칙과 습관을 구분짓는 특징은 앞서 언급된 내용에 이미 암시되어 있지만, 이것은 너무도 중요하며 법철학 내에서 자주 간과되거나 잘못 표현되기 때문에 여기서 보다 자세히 설명할 필요가 있다. 우리는 이 책 전반에

걸쳐 이 특징을 규칙의 내적 측면(internal aspect)이라고 부를 것이다. 습관이 사회 집단 내에 일반적으로 퍼져 있을 경우, 그러한 일반성은 단지 그 집단 구성원의 관찰 가능한 행동에 대한 사실적 진술일 뿐이다. 그러한 습관이 존재하기 위해서, 집단 구성원 중 어느 누구도 그러한 일반적인 행위를 의식할 필요도 없으며, 그 행위가 일반적이라는 사실을 인식할 필요조차 없다. 더군다나, 그것을 유지하거나 교육하려는 의도를 가질 필요도 없다. 단지 각자가 자기 몫으로서, 다른 사람들과 동일한 방식으로 행동하면 그만이다. 이에 비해, 사회 규칙이 존재하려면 최소한 일부는 그 행위를 집단 전체가 따라야 할 일반적 기준으로 간주해야 한다. 사회 규칙은 사회적 습관과 공유하는 외적 측면(즉 관찰 가능한 정형화된 행동) 외에, 내적 측면을 추가로 가진다.

이러한 규칙의 내적 측면은 어떤 게임의 규칙에서 쉽게 예시할 수 있다. 체스 플레이어들은 단지 외부 관찰자가 “퀸은 저렇게 움직이는구나”라고 기록할 수 있을 정도로 비슷한 방식으로 퀸을 움직이는 습관만 갖고 있는 것이 아니다. 이에 더해, (p. 57) 그들은 이 행동 양식에 대해 성찰적이고 비판적인 태도를 취한다. 즉, 그것을 체스를 두는 사람 모두가 따라야 할 기준으로 본다. 각자는 단지 퀸을 일정한 방식으로 움직이는 것에 그치지 않고, 모두가 그렇게 해야 한다고 생각한다. 이러한 생각은, 다른 사람이 규칙을 어기거나 어길 가능성이 있을 때, 그를 비판하고 동조를 요구하는 방식으로 표현되며, 다른 사람이 자신에게 비판이나 요구를 할 때 이를 정당한 것으로 받아들이는 방식에서도 드러난다. 이러한 비판, 요구, 수용의 표현에는 다양한 규범적 언어(normative language)가 사용된다. 예컨대 “퀸을 그렇게 움직이면 안 됐어(I/You ought not to have moved the Queen like that)”, “그렇게 해야 해(I/You must do that)”, “그건 맞아(That is right)”, “그건 틀렸어(That is wrong)” 등이 이에 해당한다.

규칙의 내적 측면은 종종 외적으로 관찰 가능한 물리적 행동과 대조되는 단순한 ‘감정’의 문제로 잘못 표현되곤 한다. 물론, 어떤 규칙이 사회 집단에 의해 일반적으로 받아들여지고, 사회적 비판이나 동조 압력으로 일반적으로 뒷받침될 경우, 개인들은 종종 제한이나 강요와 유사한 심리적 경험을 하게 될 수도 있다. 사람들이 “이렇게 해야 할 것 같다”고 말할 때, 실제로 이런 경험을 가리킬 수도 있다. 그러나 이러한 감정은 ‘구속력을 갖는 규칙’의 존재에 필

수적이지도, 충분하지도 않다. 어떤 사람이 어떤 규칙을 받아들이면서도 그에 대해 ‘강제당하는 느낌’을 전혀 경험하지 않는다고 말하는 데에는 모순이 없다. 필요한 것은 특정한 행동 양식에 대해 공통 기준(common standard)으로서 비판적이고 성찰적인 태도를 갖는 것이며, 이러한 태도는 (자기비판을 포함한) 비판, 동조 요구, 그리고 이러한 비판과 요구가 정당하다는 수용의 형태로 나타난다. 이러한 행위들은 모두 “~해야 한다(ought, must, should)”나 “옳다, 그르다(right, wrong)”와 같은 규범적 용어(normative terminology)로 표현된다.

이러한 특징들이야말로 사회 규칙을 단순한 집단적 습관과 구분 짓는 핵심 요소들이다. 이 점들을 염두에 두고, 우리는 다시 법으로 돌아갈 수 있다. 우리는 어떤 사회 집단이, 교회에서 모자를 벗는 것처럼 특정한 행동을 기준으로 삼는 규칙뿐 아니라, 보다 간접적인 방식으로 행동 기준을 식별할 수 있도록 해주는 규칙을 가지고 있다고 가정할 수 있다. 이 규칙은 특정한 사람(예: Rex)의 말(구두 또는 문서)에 따라 어떤 행동을 해야 한다고 정하는 것이다. 이 규칙의 가장 단순한 형태는, (p. 58) Rex가 어떤 방식으로든 특정한 행동을 요구하면 그것이 곧 해야 할 일이라는 식이다. 이 규칙이 받아들여진다면, 단순한 복종 습관만을 기반으로 Rex의 권위를 설명했던 최초의 상황은 전환된다. 이제 Rex는 단지 실제로 무엇을 해야 할지를 지정하는 것에 그치지 않고, 그것을 지정할 권리(the right)를 갖게 된다. 그의 명령이 일반적으로 복종될 뿐 아니라, 그에게 복종하는 것이 옳다(it is right to obey him)는 점도 일반적으로 받아들여지게 된다. 이제 Rex는 단순한 권력자가 아니라, 집단의 삶에 새로운 행동 기준을 도입할 입법자(legislator)로서의 권한(authority)을 갖게 된다. 그리고 이제 우리는 단순한 ‘명령’이 아니라 ‘기준’을 다루고 있으므로, 그가 자신이 만든 입법에 구속될 수 있어야 한다고 말할 이유도 전혀 없다.

이러한 입법 권위를 뒷받침하는 사회적 실천들은, 교회에서 모자를 벗는 행위와 같은 단순하고 직접적인 행위 규칙들(이제는 단지 관습 규칙으로 구분할 수 있음)을 뒷받침하는 관행과 본질적으로 동일하다. 그리고 이들은 일반적인 습관과 동일한 방식으로 구분된다. 이제 Rex의 말(word)은 하나의 행동 기준이 되므로, 그가 지정한 행위에서의 이탈은 비판의 대상이 된다. 그의 말은 이제 비판과 동조 요구를 정당화하는 것으로 일반적으로 참조되고 수용된다.

이러한 규칙들이 입법 권위의 연속성을 어떻게 설명해주는지를 이해하기 위해서는, 새로운 입법자가 아직 입법을 시작하기도 전에, 그가 어떤 부류(class)나 일련의 사람들의 일원으로서 그런 권리를 가진다고 부여하는 확고한 규칙이 존재함이 분명한 경우를 생각해보면 된다. 예를 들어, Rex I의 생존 기간 동안에도, 사람들이 복종해야 할 인물이 단지 Rex I 개인에 국한되지 않고, 일정 방식으로 자격을 갖춘 사람(예: 특정 조상의 직계 후손 중 최고령 생존자)이 되어야 한다는 규칙이 일반적으로 수용되어 있을 수 있다. 이 경우 Rex I은 특정 시점에 자격을 갖춘 사람에 불과하다. 이러한 규칙은 Rex I에 대한 단순한 복종 습관과는 달리, 미래의 가능한 입법자들을 현재의 입법자와 함께 참조하기 때문에 미래를 향한 규칙이다.

이러한 규칙의 수용, 즉 그 존재는 Rex I의 생존 기간 동안 그에 대한 복종으로 나타나기도 하지만, 일반 규칙에 따른 그의 자격에 의해 복종이 정당하다는 인식으로도 나타난다. 바로 이 점에서, (p. 59) 특정 시점에 집단이 수용하는 규칙이 미래의 입법권 계승자에 대한 일반적 기준을 명시함으로써, 그 후계자가 아직 입법을 시작하기 전임에도 불구하고 입법할 권리를 갖고 있다는 법적 진술과, 그가 전임자처럼 복종을 받을 가능성이 있다는 사실적 진술 모두(both)를 가능하게 해 주기 때문이다.

물론, 한 시점에서 사회가 어떤 규칙을 수용했다고 해서 그 규칙의 연속적 존재가 보장(guarantee)되는 것은 아니다. 혁명이 일어날 수 있고, 사회는 더 이상 그 규칙을 수용하지 않을 수도 있다. 이러한 일은 Rex I이 재위 중일 때나 Rex II로의 이행 시점에서 발생할 수 있으며, 그런 경우 Rex I은 권위를 잃거나 Rex II는 권위를 획득하지 못하게 된다. 상황이 명확하지 않을 수도 있다. 단순한 반란인지, 이전 규칙의 일시적 중단인지, 혹은 완전한 폐기인지가 불분명한 중간적 혼란 상태가 존재할 수 있기 때문이다. 그러나 원칙적으로는 이 문제는 명확하다. 새로운 입법자가 입법할 권리를 갖고 있다는 진술은, 그가 그러한 권리를 갖도록 규정하는 규칙이 사회 집단 내에 존재하고 있다는 것을 전제로 한다. 만일 이 규칙이 그 이전의 입법자 Rex I의 생존 기간 동안 수용되었고, Rex I 역시 이 규칙에 의해 자격을 부여받았던 것이 명백하다면, 반대되는 증거가 없는 한, 이 규칙은 폐기되지 않았고 여전히 유효하다고 가정할 수 있다. 이는

야구 경기에서 점수 기록원이 전 이닝 이후 규칙이 바뀌었다는 증거가 없다면, 새 타자가 기록한 점수를 종전 방식대로 인식하는 연속성과 유사하다.

Rex I과 Rex II의 단순한 법 세계에 대한 고찰만으로도, 대부분의 법 체계에서 나타나는 입법 권위의 연속성이, 단순한 습관적 복종의 사실과는 다른 방식으로, 규칙의 수용이라는 사회적 실천 형태에 기반하고 있음을 보여주기에 충분하다. 이 논증을 다음과 같이 요약할 수 있다. Rex처럼 일반 명령이 습관적으로 복종받는 인물을 입법자라고 부르고, 그의 명령을 법이라고 부르는 것을 인식한다고 하더라도, 이러한 입법자들이 연속적으로 등장하는 상황에서 단순한 복종 습관만으로는 후계자의 계승 권리(right)와 그로 인한 입법 권력의 연속성을 설명하기에 충분하지 않다. 첫째, (p. 60) 습관은 ‘규범적’이지 않기 때문에 어떤 권리나 권위를 누구에게도 부여할 수 없다. 둘째, 한 개인에 대한 복종 습관은 미래의 계승 입법자 계층 전체를 참조하거나, 이들에게 복종할 가능성을 제시할 수 없지만, 규칙은 그것이 가능하다. 따라서 한 입법자에 대한 복종 습관이 있다는 사실만으로는 그 후계자가 법을 만들 권리를 가진다고 진술할 근거도, 그가 복종받을 것이라는 사실적 진술의 근거도 제공하지 못한다.

이 시점에서, 이후 장에서 보다 본격적으로 다룰 중요한 쟁점을 주목할 필요가 있다. 이는 Austin의 이론이 가진 강점 중 하나를 이룬다. 우리는 수용된 규칙과 습관 사이의 본질적인 차이를 밝히기 위해 매우 단순한 형태의 사회를 가정했다. 이제 주권 이론의 이 측면을 마무리하기 전에, 입법 권한을 부여하는 규칙의 수용이라는 우리의 설명이 현대 국가에도 얼마나 적용될 수 있을지를 검토해보아야 한다. 우리는 단순 사회를 논하면서 마치 일반 대중이 단지 법에 복종할 뿐만 아니라, 법 제정자의 계승을 정당화하는 규칙을 이해하고 수용하고 있는 것처럼 말했다. 단순 사회에서는 실제로 그럴 수도 있다. 하지만 현대 국가에서는, 아무리 법을 잘 지키는 사람일지라도, 끊임없이 구성원이 바뀌는 입법 기관의 구성 자격을 정하는 규칙을 명확히 인식하고 있다고 생각하는 것은 말이 되지 않는다. 이러한 규칙들을 대중이 ‘수용한다’고 말하는 것은, 작은 부족 사회의 구성원이 연속적인 추장의 권위를 정하는 규칙을 수용하는 것과 동일한 방식으로 시민들이 헌법적 사항을 이해하고 있다는 가정을 필요로 한다. 하지만 시민 대중에게 그 수준의 이해를 기대하는 것은 부적절하며, 우리는 그와

같은 이해를 공식 담당자나 전문가들에게만 요구하면 된다. 즉, 법이 무엇인지 판정할 책임을 지닌 법원, 그리고 시민이 법에 대해 알고자 할 때 상담하는 법률가들이 그것이다.

이러한 단순 부족 사회와 현대 국가 사이의 차이는 주목할 가치가 있다. 그렇다면 다음과 같은 문제를 어떻게 이해해야 할까? 즉, 수많은 입법자가 바뀌는 과정 속에서도 의회의 여왕의 입법 권위의 연속성이 일정한 기본 규칙 또는 규칙들에 대한 일반적 수용에 기반한다고 말할 수 있는가? 명백히 이 경우의 ‘일반적 수용’은 (p. 61) 복합적인 현상이며, 공식 담당자들과 일반 시민들 사이에 나뉘어져 있고, 이들은 서로 다른 방식으로 법 체계의 존재(existence)에 기여한다. 체계의 공식 담당자들은 입법 권한을 부여하는 기본 규칙들을 명시적으로 인식한다고 말할 수 있다. 입법자는 자신이 법을 제정할 수 있도록 부여된 규칙에 따라 입법함으로써 이를 인식하고, 법원은 그러한 자격이 부여된 이들이 만든 법을 자신들이 적용할 법으로 식별함으로써 이를 인식하며, 법률 전문가들은 그러한 법을 기준 삼아 일반 시민들을 안내함으로써 인식한다. 일반 시민들은 이 모든 공식적 작용의 결과를 묵인하고 따름으로써 자신의 수용을 드러낸다. 그들은 이러한 방식으로 만들어지고 식별된 법을 지키며, 그 법에 의해 부여된 권리들을 주장하고, 권한을 행사한다. 그러나 그들은 그러한 법이 어디서 비롯되었는지, 누가 만들었는지를 거의 알지 못할 수도 있다. 어떤 사람은 그 법에 대해 “그게 법이야”라는 것 외에 아무것도 모를 수도 있다. 그 법은 그들이 하고자 하는 일을 금지하며, 만일 이를 어기면 경찰에게 체포되고 판사에 의해 징역형을 선고받을 수 있다는 것만 안다. 법 체계의 존재라는 복합적인 현상 속에서 이러한 수동적 측면을 강조하는 이론은, 법이란 결국 명령과 그것을 뒷받침하는 위협에 대한 습관적 복종에서 비롯된다는 주장을 통해 우리의 사고를 현실적 기반 위에 놓도록 강요한다는 점에서 강점을 가진다. 그러나 이 이론의 약점은, 그것이 법 체계의 다른 측면—보다 능동적인 측면, 즉 법을 만들고, 식별하고, 적용하는 공식 담당자 및 전문가의 작용—을 흐리거나 왜곡한다는 데 있다. 이 두 측면 모두를 함께 고려할 때에만, 우리는 법 체계라는 이 복합적인 사회 현상을 그 실상 그대로 볼 수 있을 것이다.

2. 법의 지속성

1944년, 한 여성이 영국에서 점을 친 혐의로 기소되어, 1735년 제정된 「주술법(Witchcraft Act)」을 위반한 혐의로 유죄 판결을 받았다.¹⁷ 이는 매우 생생한 예이지만, 동시에 매우 익숙한 법적 현상의 한 단면이다. 수세기 전에 제정된 법령이 오늘날까지도 여전히 유효한 법일 수 있다는 것이다. 그러나 아무리 익숙하더라도, 이러한 방식으로 법이 지속되는 현상은 법을 단지 (p. 62) 습관적으로 복종하는 사람의 명령으로 보는 단순한 구도로는 설명될 수 없다. 사실 여기서 우리는 방금 앞에서 다룬 주제와는 정반대의 문제를 마주하고 있다. 앞에서의 문제는, 입법자의 지위에 새로 오른 사람이 아직 습관적인 복종을 받기 전에 그가 제정한 첫 번째 법이 어떻게 이미(already) 법으로 간주될 수 있는가 하는 것이었다. 여기서는 반대로, 오래 전에 죽은 입법자가 만든 법이, 더 이상 그에게 복종하는 사람들도 존재하지 않는 사회에서 어떻게 여전히(still) 법으로 남을 수 있는가 하는 것이 문제다. 앞의 경우처럼, 단순한 구도에서는 입법자의 생존 기간 동안에만 시야를 제한하면 아무런 문제가 생기지 않는다. 실제로 이는 「주술법」이 왜 영국에서는 법이지만, 그 내용이 프랑스 시민이 프랑스에서 점을 치는 행위까지 포함한다고 하더라도 프랑스에서는 법이 아니었는지를 잘 설명해 준다. 단순한 설명은 이렇다: 영국에서는 이 법을 제정한 사람들에 대한 복종의 습관이 있었지만, 프랑스에서는 그러한 습관이 없었다. 그러므로 이 법은 영국에서는 법이지만 프랑스에서는 아니었다는 것이다.

하지만 우리는 법을 제정한 사람의 생존 기간으로 시야를 제한할 수 없다. 왜냐하면 우리가 설명해야 하는 특징은 바로 법이 제정자와 그에 습관적으로 복종하는 사람들로부터 살아남는 끈질긴(obdurate) 능력에 있기 때문이다. 만약 동시대 프랑스인들에게 「주술법(Witchcraft Act)」이 적용되지 않았던 것처럼, 20세기 영국인인 우리에게 이 법이 여전히 유효한 법이라고 한다면, 그 이유는 무엇인가? 아무리 언어를 억지로 끌어다 써도, 20세기 영국인이 조지 2세와 그의 의회에 습관적으로 복종한다고 말할 수는 없다. 이런 점에서, 지금의 영국인과 당시의 프랑스인은 똑같다: 둘 다 이 법을 만든 사람에게 복종하지

¹⁷R. v. Duncan[1944] 1 KB 713.

않으며, 복종의 적도 없다. 설령 「주술법」이 그 재위 기간 중 유일하게 남은 법이라 하더라도, 그 법은 여전히 오늘날 영국법으로서 유효하다. 왜 여전히 법인가(Why law still?)라는 문제에 대한 해답은, 원칙적으로 왜 이미 법인가(Why law already?)라는 첫 번째 문제에 대한 해답과 동일하며, 이는 ‘주권자에 대한 복종의 습관’이라는 지나치게 단순한 개념을 대체하여, 사회 구성원들에게 행동의 기준을 제시할 자격이 있는—즉 입법할 권리(right)를 가진—어떤 계층(class)나 일련의 사람들을 특징하는 현재 통용되는 근본 규칙(fundamental rules)의 개념을 채택하는 것이다. 이러한 규칙은 현재 실존해야 하지만, 어떤 의미에서는 그 지칭 대상에 있어 시간성을 초월할 수도 있다. 다시 말해, 그 규칙은 (p. 63) 미래의 입법자에 대한 규범적 권한을 가리킬 수 있을 뿐 아니라, 과거 입법자의 작용에도 소급하여 지칭될 수 있다.

이것을 Rex 왕조의 단순한 모델로 설명하면 다음과 같다. Rex I, II, III로 이어지는 입법자의 계열 각각은 모두 동일한 일반 규칙에 따라, 즉 특정 조상의 직계 후손 중 최고령자라는 자격에 따라 입법권을 부여받는다. 한 입법자가 죽더라도 그의 입법 행위는 살아남는다. 왜냐하면 이 행위는 그가 언제 살았는지와 무관하게, 후대의 사회 구성원들에 의해 지속적으로 존중되는 일반 규칙 위에 기반하고 있기 때문이다. 이 단순한 사례에서는 Rex I, II, III 모두가 동일한 규칙 하에 입법을 통해 행동 기준을 설정할 권리를 지닌다. 대부분의 실제 법체계에서는 사정이 그렇게 단순하지 않다. 과거 입법을 법으로 인식하게 해주는 현재의 수용된 규칙이, 동시대의 입법을 인식하는 규칙과 다를 수 있기 때문이다. 하지만 이러한 기저 규칙이 현재 수용되고 있다면, 과거 법이 여전히 유효하다는 사실은, 마치 첫 라운드에서의 심판 판정이 마지막 라운드 결과에 동일하게 반영되는 것처럼, 더 이상 신비로운 일이 아니다. 그럼에도 불구하고, 이러한 과거·현재·미래의 입법자 모두에게 입법권을 부여하는 규칙이 수용되고 있다는 개념은, 단순히 현재 입법자에 대한 복종 습관이라는 개념보다 훨씬 더 정교하고 복합적인 것이다. 그렇다면 우리는 이 복잡성을 제거할 수 있을까? 즉, 명령에 대한 복종이라는 단순한 개념을 어떤 영리한 방식으로 확장함으로써, 법의 지속성이 결국에는 현재 주권자에 대한 습관적 복종이라는 더 단순한 사실에 의존한다고 설명할 수 있을까?

이러한 시도를 실제로 한 사례가 있다. Hobbes는 (이후 Bentham과 Austin이 이를 따랐다) 이렇게 말하였다: “입법자란, 법이 처음으로 제정된 자가 아니라, 법이 지금도 계속해서 법으로 남아 있게 하는 자이다.”¹⁸ 만약 우리가 규칙이라는 개념을 제거하고 습관이라는 단순한 개념만을 사용한다면, 입법자의 “권위”는 “권력”과는 어떻게 구별될 수 있는가? 하지만 이 인용문에서 표현된 일반적 (p. 64) 논변은 분명하다. 그것은 다음과 같다: 「주술법」과 같은 법이 역사적으로는 과거의 주권자에 의해 제정되었을지라도, 이 법이 현재(20세기 영국)에서 법으로서의 지위를 가지는 것은, 현재의 주권자가 이를 법으로 인식하고 있기 때문이라는 것이다. 이러한 인식은 지금 살아있는 입법자가 새로운 법령을 명시적으로(explicit) 제정하는 경우와는 달리, 과거 입법에 대해 암묵적으로(tacit) 주권자의 의지를 표현하는 방식으로 나타난다. 즉, 주권자는 이 오래된 법령이 그의 대리인(법원이나 행정부)에 의해 집행되는 것에 대해 개입하지 않고 있다는 사실 그 자체가, 그 법이 여전히 유효함을 보여주는 암묵적 인식으로 간주되는 것이다.

이는 물론 우리가 이미 다룬 묵시적 명령(tacit orders) 이론과 동일한 것이다. 이 이론은, 어느 누구에 의해서도 명시적으로 명령된 적이 없어 보이는 관습 규칙들이 어떻게 법적 지위를 갖는지를 설명하기 위해 제시되었다. 우리가 제3장에서 이 이론에 대해 제기한 비판들은, 그것이 과거의 입법이 여전히 법으로 인식되는 현상을 설명하기 위해 사용될 때에는 오히려 더욱 분명하게 적용된다. 왜냐하면, 법원이 부당한 관습 규칙을 기각할 수 있는 폭넓은 재량을 가지고 있다는 점에서, 특정 사건에 법원이 그것을 실제로 적용하기 전까지는 그 관습 규칙이 법적 지위를 갖지 않는다는 전제가 일정 부분 설득력을 가질 수는 있다. 그러나 과거의 ‘주권자’가 제정한 제정법(statute)이, 그것이 특정 사건에 법원에 의해 실제로 적용되고 현재의 주권자가 이에 동의(묵인)하기 전까지는 법이 아니다 라는 주장은 거의 설득력이 없다. 만약 이 이론이 옳다면, 다음과 같은 결론이 뒤따르게 된다: 법원이 과거 법령을 집행하는 이유는 그것이 이미 법이기 때문이 아니라는 것이다. 그러나 이 결론은, 현재 입법자가 과거 입법을 폐지할 수 있는 권한이 있음에도 그 권한을 행사하지 않았다는 사실만으로 도

¹⁸Leviathan, chap. xxvi.

출하기에는 터무니없는 것이다. 빅토리아 시대의 법률과 오늘날 여왕과 의회가 제정한 법률은 분명히 현재 영국법에서 동일한 법적 지위를 가진다. 양자는 모두, 해당 사건이 법원에 제기되기 이전부터 이미 법이며, 그러한 사건이 실제로 발생했을 때 법원은 이미 법인 그것들을 적용하는 것이다. 이러한 경우에서, 법은 법원에 의해 적용된 이후에야 법이 되는 것이 아니다. 그리고 양자 모두 그 법적 지위는, 그것들이 제정된 인물이 살아 있든 아니든, 현재 수용되고 있는 규칙에 따라 그들의 입법이 권위 있는 것으로 인식되고 있기 때문에 발생하는 것이다.

(p. 65) 과거 제정법이 여전히 법적 지위를 갖는 이유가 현재 입법자가 그것의 법원 적용을 묵인하고 있기 때문이라는 이론의 비밀관성은, 이 이론이 법원이 왜 어떤 빅토리아 시대 법률이 아직 폐지되지 않아 여전히 법이며, 어떤 법률은 에드워드 7세 시대에 폐지되었기 때문에 더 이상 법이 아님을 구별할 수 있는지를 전혀 설명하지 못한다는 데에서 가장 잘 드러난다. 명백히, 법원(그리고 그 법체계를 이해하고 있는 모든 법률가나 일반 시민)은 과거와 현재의 입법 행위를 모두 포괄하는 어떤 기본 규칙을 기준으로 삼아 어떤 것이 법인지 판단한다. 법원은 어느 법률이 현재 주권자에 의해 묵시적으로 사령되었고 다른 법률은 그렇지 않다는 지식을 바탕으로 두 법률을 구별하지 않는다.

다시 말해, 우리가 지금 비판하고 있는 이 이론의 유일한 미덕이라 할 만한 것은, 현실적인 요소를 희미하게 상기시켜 준다는 점뿐이다. 그것은 곧, 어떤 입법 행위—과거의 것이든 현재의 것이든(past or present)—가 권위 있는 것으로 간주되기 위해서는, 법원 등을 포함한 그 법체계의 공적 담당자들이 그와 같은 규칙을 받아들여야 한다는 점이다. 그러나 이러한 소박한 현실주의는 종종 법현실주의(Legal Realism)라는 이론으로 과도하게 확대된다. 이 이론의 주요 내용은 후속 장에서 자세히 논의되며,¹⁹ 어떤 판본에서는 법원이 실제로 적용하기 전에는 어떤(no) 제정법도 법이 아니라고 주장한다. 하지만 “만약 제정법이 법이 되기 위해서는, 법원이 특정 입법 행위가 법을 성립시킨다고 하는 규칙을 수용해야 한다”는 사실은, “법은 법원이 개별 사건에서 실제로 적용하기 전에는 법이 아니다”라는 잘못된 이론과는 결정적으로 다르다. 물론 일부 법실증주의적

¹⁹See pp. 136–47 below.

사실주의 이론은 우리가 지금 비판한 것보다 훨씬 더 나아간다. 그들은 심지어 현재의(present) 주권자가 만든 법률조차도 법원이 실제로 적용하기 전까지는 법적 지위를 가질 수 없다고 주장하기까지 한다. 하지만 어떤 이론은, 완전한 사실주의 이론에까지 이르지 않는 반면, 현재의 주권자가 만든 제정법은 법원이 적용하기 전에도 법이지만, 과거의 주권자가 만든 법은 그렇지 않다고 주장한다. 이 입장은 (p. 66) 양쪽의 최악의 단점을 모두 안고 있으며, 실제로는 매우 부조리하다. 이런 중간 지대의 입장은 유지될 수 없다. 왜냐하면 현재의 주권자가 만든 법과, 폐지되지 않은 과거 주권자의 법 사이에는 법적 지위에 있어 어떤 차이도 존재하지 않기 때문이다. 결국 둘 다—즉 과거와 현재의 주권자가 제정한 법 모두가—(대부분의 법률가들이 인식하듯이) 법원이 특정 사건에 적용하기 전부터 이미 법이거나, 아니면 (현실주의 이론이 주장하듯이) 둘 다 법이 아니다. 중간은 없다.

3. 입법권에 대한 법적 한계

주권 이론에서, 수법자의 일반적인 복종 습관은 주권자에게는 그러한 습관이 없음을 전제로 한다. 주권자는 수법자를 위해 법을 만들며, 그 법은 어떠한 법의 구속도 받지 않는 위치에서 제정된다. 그의 입법 권한에는 법적으로 어떠한 한계도 존재하지 않으며 존재할 수도 없다. 여기서 중요한 점은, 주권자의 법적 무제한 권한은 정의상 그러하다는 것이다. 이 이론은 단지 다음과 같이 주장할 뿐이다: 입법권에 법적 한계가 존재하려면, 입법자는 그가 습관적으로 복종하는 또 다른 입법자의 명령 하에 있어야 한다. 그러나 그런 경우 그는 더 이상 주권자가 아니다. 주권자라면 그는 다른 누구의 명령도 따르지 않으며, 따라서 그의 입법 권한에는 법적 한계가 존재할 수 없다. 이 이론의 중요성은 이러한 정의들과 그 간단한 필연적 결과들—즉, 현실에 대해 아무것도 말해주지 않는—에 있는 것이 아니다. 그것의 중요성은 다음과 같은 주장에 있다: 법이 존재하는 모든 사회에는 이러한 속성을 갖는 주권자가 존재한다. 우리는 법적이거나 정치적인 형식, 즉 모든 법적 권한은 제한되고 어떤 인물이나 집단도 주권자처럼 법 밖에 존재하지 않는 것처럼 보이는 형식 너머를 바라봐야 할

수도 있다. 그러나 이 이론에 따르면, 우리가 집요하게 추적한다면 결국 그 형식 너머의 실재를 발견할 수 있을 것이다.

우리는 이 이론이 실제로 주장하는 것보다 더 약하거나 더 강한 주장을 한다고 잘못 해석해서는 안 된다. 이 이론은 단순히 “어떤(some) 사회에서는 법적 한계를 받지 않는 주권자가 존재한다”고 말하는 것이 아니라, 모든 사회에서 법이 존재한다면 그러한 주권자도 반드시 존재한다고 말한다. 반면, 이 이론은 “주권자의 권한에는 어떤 제한도 존재하지 않는다”고 주장하는 것이 아니라, 오직 “어떤 법적(legal) 한계도 없다”고만 말한다. 따라서 실제로 주권자는 입법권을 행사할 때 민의(民意)에 따라 자제할 수도 있다. (p. 67) 이는 민심을 거스른 결과에 대한 두려움 때문일 수도 있고, 자신이 도덕적으로 이를 존중해야 한다고 생각하기 때문일 수도 있다. 여러 요인들이 그에게 영향을 미칠 수 있으며, 민중의 반란에 대한 공포나 도덕적 신념이 그로 하여금 본래 하려던 입법을 하지 않게 만든다면, 그는 이러한 요인들을 자신의 권한에 대한 ‘제한’으로 인식하고 표현할 수도 있다. 그러나 이러한 것들은 법적 한계가 아니다. 그는 그러한 입법을 자제할 법적 의무를 지지 않으며, 법원이 어떤 입법이 주권자의 법인지 판단할 때에도, 그 법이 민의나 도덕의 요구와 일치하지 않는다는 논증만으로 그것을 법이 아니라고 판단하지 않는다. 주권자가 그렇게 명령하지 않은 이상은.

이 이론의 매력은 일반적인 법 이론으로서 두 가지 중요한 질문에 대해 간명한 형태로 해답을 제공하는 데 있다. 우리가 어떤 인물이 반복적으로 복종을 받고 있으나 그 자신은 누구에게도 복종하지 않는다는 사실을 알게 되면, 우리는 두 가지를 할 수 있게 된다. 첫째, 우리는 그 인물의 일반 명령 속에서 한 사회의 법을 식별할 수 있으며, 그 사회 구성원의 삶을 지배하고 있는 도덕적이거나 단순한 관습적 규칙들과 법을 구별할 수 있다. 둘째, 우리는 그 법이 독립적인 법체계의 일부인지, 아니면 상위 체계에 종속된 일부인지를 구별할 수 있다.

이 이론에 따르면, 의회 속의 여왕(Queen in Parliament)은 하나의 연속적인 입법 주체로 간주될 수 있으며, 바로 이 점에서 의회의 주권성이 성립한다고 한다. 이 믿음의 정확성에 대해서는 제6장에서 다룰 몇 가지 측면이 있지만, 최소한 상상 속의 간단한 세계인 렉스(Rex) 1세의 예에서는 이 이론이 요구하는

바를 일관되게 재현할 수 있다. 현대 국가라는 더 복잡한 사례를 고려하기 전에 이를 살펴보는 것은 유익하다. 왜냐하면 이 이론의 전제가 지닌 전체적 함의는 이러한 단순한 맥락에서 가장 잘 드러나기 때문이다. 우리가 1절에서 “복종 습관(habits of obedience)” 개념에 대해 제기했던 비판을 수용하려면, 이 상황을 습관이 아닌 규칙(rules)의 관점에서 구성할 수 있다. 이런 전제하에서 우리는 다음과 같은 사회를 상상할 수 있다. 법원, 공무원, 시민이 모두 다음의 규칙을 일반적으로 수용하고 있는 사회이다: “렉스(Rex)가 무엇인가를 명령하면, 그의 말은 이 집단에 대한 행동 기준이 된다.” 여기서 렉스가 자신의 (p. 68) ‘사적’ 바람-예컨대 아내나 정부(情婦)에게 내리는 사적인 명령-을 공식적인 법으로 간주되지 않게 하고자 할 수 있기 때문에, 그의 명령들 중에서 공적인 입법 행위와 사적인 명령을 구별하기 위한 보조 규칙들이 존재할 수도 있다. 이러한 보조 규칙은 군주가 입법할 때는 반드시 특정 형식을 사용해야 하며, 사적으로는 그렇지 않아도 된다는 내용을 담는다. 이러한 “입법의 방식과 형식에 관한 규칙들”은 그 기능을 다하기 위해 진지하게 받아들여져야 하며, 때때로 렉스에게 불편함을 줄 수도 있다. 그럼에도 불구하고, 우리는 이 규칙들을 법적 규칙으로 분류할 수 있지만, 그것을 입법 권한에 대한 제한으로 보지는 않아도 된다. 왜냐하면 렉스가 요구된 형식을 따르기만 한다면, 그가 입법을 통해 자신의 바람을 실현할 수 없는 수범자는 존재하지 않기 때문이다. 다시 말해, 입법 권한의 “형식”은 규율될 수 있으나, 그 “영역”은 법에 의해 제한되지 않는다.

이 이론에 대한 일반 법 이론으로서의 반론은 다음과 같다. 상상 속 사회의 렉스(Rex)처럼 법적 한계에 따르지 않는 주권자의 존재는, 법의 존재에 필요한 전제조건이 아니다. 이를 입증하기 위해 논쟁의 여지가 있는 법 체계들을 들 필요는 없다. 우리의 논증은, 입법 기관이 없다는 이유로 어떤 이들은 법이라는 명칭 자체를 부정하고자 하는 관습법 체계나 국제법 체계에서 도출된 것이 아니다. 이러한 사례에 호소할 필요는 전혀 없다. 왜냐하면, 법적으로 무제한적인 주권자라는 개념은, 입법 기관이 존재하더라도 그 최고 입법 권한이 종종 제한되어 있는 현대 국가들에서의 법의 성격을 왜곡하기 때문이다. 그리고 그런 국가들에서 법이 존재한다는 점은 누구도 부정하지 않을 것이다. 현대 국가에서는, 단지 입법의 형식과 방식을 규정하는 데 그치지 않고(이런 규정은 ‘제한’

이라고 부르지 않아도 괜찮을 수 있다), 입법 권한의 범위 자체에서 아예 특정한 사안을 제외하는 실체적 제한을 통해 입법 기관의 권한을 제약하는 성문헌법이 존재하기도 한다. 이러한 경우, 입법 권한은 실질적인 법적 제한을 받는다.

다시 말해, 복잡한 현대 국가의 사례를 살펴보기 전에, 간단한 렉스(Rex)의 세계에서 “그의 입법권에 대한 법적 한계”가 실제로 무엇을 의미하는지, 그리고 그것이 왜 개념적으로 완전히 일관된 생각인지 먼저 살펴보는 것이 유익하다.

렉스가 최고 입법자인 단순 사회에서는, 다음과 같은 규칙이 (문서로 된 헌법에 명시되어 있든 아니든) 수용될 수 있다. “렉스의 법은, 원주민을 영토 밖으로 추방하거나 재판 없이 구금하도록 규정하는 경우에는 유효하지 않으며, 그러한 법률은 모두 (p. 69) 무효로 간주되어야 한다.” 이처럼 렉스의 입법 권한이 어떤 사안에 대해서는 배제된다면, 이 제한은 비록 우리가 그러한 헌법적 규칙을 굳이 ‘하나의 법(a law)’이라고 부르기를 꺼려한다 하더라도, 분명히 법적 제한이라 불릴 수 있다. 이는, 렉스가 자신의 기호에 반하더라도 민의나 도덕에 따라 입법을 자제할 수 있는 것과는 다르다. 민의나 도덕을 무시하더라도 그의 입법은 무효가 되지 않는다. 그러나 위와 같은 구체적 제한을 무시하면, 그 입법은 무효가 된다. 따라서 법원은 그러한 제한 규정을 단순히 도덕적인 또는 사실상의(de facto) 한계와는 다른 방식으로 고려하게 된다. 그럼에도 불구하고, 이러한 법적 제한이 있다고 해서 렉스가 그 범위 내에서 제정한 법이 법이 아니라고 할 이유는 없으며, 그의 사회는 분명히 독립적인 법체계를 가진다.

우리는 이러한 상상의 단순한 사례를 좀 더 자세히 들여다볼 필요가 있다. 그래야만 이러한 유형의 법적 제한이 정확히 무엇인지 분명해지기 때문이다. 우리는 종종 렉스의 입장을 다음과 같이 표현할 수 있다: “그는 재판 없이 구금을 부여하는 법을 제정할 수 없다(cannot).” 이때의 “~할 수 없다(cannot)”는 표현은, 어떤 사람이 어떤 것을 하지 않아야 할 법적 의무(legal duty)나 도덕적 의무(obligation)를 지고 있다는 의미와는 다르다. 후자의 의미에서 “할 수 없다(cannot)”가 사용되는 경우는 예를 들어 “자전거를 인도에서 탈 수 없다(You cannot ride a bicycle on the pavement.)”고 말하는 경우이다. 최고 입법자의 권한을 실질적으로 제한하는 헌법은, 입법자에게 특정 방식의 입법을 시도하지 말라는 법적 의무를 부과하지는 않는다(또는 반드시 부과할 필요는 없다). 그

대신, 그런 입법은 무효가 된다고 규정할 수 있다. 이런 경우 입법자에게 부과되는 것은 법적 의무(duties)가 아니라, 법적 무능력(disabilities)이다. 따라서 여기서 ‘제한(limits)’이란 것은 의무의 존재(the presence of duty)가 아니라 법적 권한의 부재(the absence of legal power)를 의미한다.

이러한 렉스의 입법권에 대한 제한은 헌법적인 것이라고 볼 수 있지만, 단지 관행이나 도덕에 불과하여 법원이 고려하지 않는 사항들은 아니다. 이러한 제한은 입법 권한을 부여하는 규칙의 일부이며, 법원은 입법의 유효성을 판단할 때 이를 기준으로 삼기 때문에 필수적으로 관련된다. 하지만 이러한 제한이 법적임에도 불구하고, 그것의 존재 여부는 렉스가 어떤 타인의 명령에 반복적으로 복종하는지의 여부로는 설명될 수 없다. 렉스는 그러한 제한을 받아들이고, 그를 (p. 70) 회피하려 하지 않을 수도 있으며, 그렇다 하더라도 그는 누구에게도 습관적으로 복종하지 않는다. 그는 단지 유효한 법을 만들기 위한 조건을 충족할 뿐이다. 반대로, 그가 이러한 제한을 회피하려고 노력하여 그에 반하는 명령을 내린다 하더라도, 그는 누구의 법을 위반한 것도 아니고, 어떤 상위 입법자의 명령을 어긴 것도 아니다. 그는 법적 의무를 위반하지는 않았지만, 유효한 법을 만들지 못한 것이다. 반대로, 렉스가 입법할 자격을 갖는다는 헌법 규칙에 렉스의 권한을 제한하는 법적 제한이 전혀 없다면, 렉스가 인접 국가의 왕인 티라누스(Tyrannus)의 명령에 반복적으로 복종한다고 해도, 그 사실만으로는 렉스의 법이 법으로서의 지위를 상실하게 하거나, 그것이 티라누스의 최고 권위 하에 있는 종속 체계의 일부라는 것을 증명할 수는 없다.

앞서 논의한 명백한 고찰들은, 비록 단순한 주권 이론에 의해 자주 가려져 있지만, 법체계의 기초를 이해하는 데 있어 결정적으로 중요한 여러 사항들을 확립해 준다. 이를 다음과 같이 요약할 수 있다: 첫째, 입법 권한에 대한 법적 제한은 입법자에게 어떤 상위 입법자의 명령에 복종하라는 의무를 부과하는 것이 아니라, 입법 자격을 부여하는 규칙에 포함된 무능력(disabilities)의 형태로 존재한다.

둘째, 어떤 법률 제정이 유효한 법인지 입증하기 위해, 그것이 어떤 ‘주권자’ 혹은 ‘무제한적’ 입법자에 의해 명시적 또는 묵시적으로 제정된 것임을 추적할 필요는 없다. 여기서 ‘무제한적’이라는 말은, 그의 입법 권한이 법적으로 제한받

지 않는다는 의미이거나, 그가 다른 누구에게도 습관적으로 복종하지 않는다는 의미일 수 있다. 그러나 우리가 실제로 해야 할 일은, 해당 제정 행위가 현존하는 규칙에 따라 입법 자격을 갖춘 입법자에 의해 이루어진 것이며, 그 규칙에 어떤 제한이 없다거나, 적어도 해당 제정행위에는 적용되지 않는 제한만이 존재함을 보여주는 것이다.

셋째, 어떤 체계가 독립된 법체계인지 판별하기 위해, 그 최고 입법자가 법적으로 무제한적이거나, 타인에게 습관적으로 복종하지 않는다는 점을 보여줄 필요는 없다. 필요한 것은 단지, 그 입법자를 자격화하는 규칙들이, 다른 영토에 대해서도 권한을 가진 자들에게 우월한 권위를 부여하지 않는다는 사실을 보여주는 것이다. 반대로, 그가 외부 권위에 복종하지 않는다고 해서, 곧바로 그가 자기 영토 내에서 무제한적 권한을 가진다는 뜻은 아니다.

넷째, 법적으로 무제한적인 입법 권한과, (p. 71) 제한은 있지만 그 체계 내에서 최고 권한을 갖는 입법자는 구분되어야 한다. 렉스는 헌법에 의해 일정한 제한을 받는다 하더라도, 그의 입법이 다른 모든 입법을 폐지할 수 있는 의미에서 그 나라 법에 의해 인식되는 최고 입법 권한을 가질 수 있다.

다섯째, 그리고 마지막으로, 입법자의 입법 권한에 대한 제한 규칙의 존재 여부는 핵심적인 반면, 그 입법자가 타인에게 습관적으로 복종하는 습관이 있는지 여부는, 기껏해야 간접적인 증거로서만 일정한 의미를 갖는다. 만약 입법자가 다른 사람에게 습관적으로 복종하지 않는다는 것이 사실이라면, 이는 때때로 그 입법자의 권한이 다른 이의 권위에 헌법적 혹은 법적으로 종속되지 않을 수 있다는 점에 대한 약간의, 그러나 결코 결정적인 것은 아닌, 증거로 기능할 수 있다. 마찬가지로, 그 입법자가 실제로 어떤 다른 사람에게 습관적으로 복종한다는 사실 역시, 그의 입법 권한이 어떤 규칙 아래에서 다른 사람의 권위에 종속되어 있음을 나타내는 일정한 증거가 될 수 있다.

4. 입법기관 뒤의 주권자

현대 세계에는, 일반적으로 해당 법체계 내에서 최고 입법기관으로 간주되는 기관이 입법권의 행사에 있어서 법적 제한을 받는 많은 법체계들이 존재한다.

그럼에도 불구하고, 그러한 입법기관이 제한된 권한 범위 내에서 제정한 법률은 명백히 법이라는 데에 법률가와 법이론가 모두가 동의할 것이다. 이러한 경우, “법이 존재하는 모든 곳에는 법적으로 제한될 수 없는 주권자가 존재한다”는 이론을 고수하기 위해서는, 우리는 법적으로 제한된 입법기관 너머에 그러한 주권자를 찾아야만 한다. 과연 그러한 주권자가 실제로 존재하는지는 지금 우리가 살펴보아야 할 문제이다.

우리는 잠시 동안, 모든 법체계가 어떤 형태로든(반드시 성문 헌법을 통해서가 아니라 하더라도) 반드시 마련하고 있는, 입법자의 자격과 입법의 ‘형식과 절차’에 대한 규정을 무시해도 좋다. 이러한 규정들은, 입법기관의 정체성과 입법을 하기 위해 반드시 충족되어야 하는 요건들을 명시하는 것으로 간주될 수 있으며, 입법권의 범위에 대한 법적 제한으로 보기보다는 오히려 절차 규정이라고 할 수 있다. 그러나 실제로는, 남아프리카공화국의 경험이 보여주듯²⁰, (p. 72) 단순한 ‘형식과 절차’에 관한 규정과 실질적인 제한(such as 제한 가능한 입법 내용)을 구별하는 일반적인 기준을 제시하는 것이 쉽지 않다. 실질적 제한의 명확한 예시는, 미국이나 호주와 같은 연방국가의 헌법에서 찾을 수 있다. 이들 헌법은 중앙정부와 주정부 사이의 권한 분할뿐만 아니라, 개인의 권리를 특정 방식으로 보호하며, 이러한 내용은 일반적인 입법 절차를 통해 변경될 수 없다. 이러한 경우, 주 혹은 연방 입법기관이 권한 분할이나 헌법에 의해 보호된 개인 권리와 상충하거나 이를 변경하려는 법률을 제정할 경우, 해당 법률은 초과 권한(*ultra vires*)으로 간주되어 위헌 판단을 받을 수 있으며, 그 충돌 범위 내에서 법원에 의해 무효로 선언된다. 입법권에 대한 이러한 법적 제한 중 가장 유명한 사례는 미국 헌법 수정 제5조이다. 이 조항은, 다른 내용을 포함하여, “누구도 적법한 절차 없이 생명, 자유 또는 재산을 박탈당해서는 안 된다”고 규정하고 있으며, 이에 따라 연방 의회(Congress)가 제정한 법률이 해당 수정 조항 또는 헌법이 부과한 다른 제한과 충돌한다고 판단될 경우, 법원은 해당 법률을 무효로 선언하였다.

물론, 헌법이 입법기관의 작용을 제한하는 방식에는 여러 장치들이 존재한다. 예컨대 스위스에서는 연방 내 구성 주의 권리나 개인의 권리와 관련된 일부

²⁰See *Harris v. Dönges*[1952] 1 TLR 1245.

헌법 조항들이 의무적인 형식으로 표현되어 있음에도 불구하고, 단지 ‘정치적 선언’ 혹은 권고적 조항으로 간주되어 법원은 연방 입법기관의 입법행위가 헌법 규정과 명백히 충돌하더라도 이를 심사하거나 무효화할 권한을 가지지 않는다²¹. 미국에서도 일부 헌법 조항은 ‘정치적 질문(political question)’을 제기한다고 해석되어, 그 범주에 속하는 사건에서는 법원이 해당 법률이 헌법을 위반했는지를 판단하지 않는다.

입법기관의 일반적 작용에 대한 법적 제한이 헌법에 의해 부과되는 경우, 그 제한이 특정한 법적 변형으로부터 면제되는지는 (p. 73) 헌법이 규정한 개정 절차의 성격에 따라 달라진다. 대부분의 헌법은 특별 절차를 통해 일반 입법기관과는 다른 기관이 개정 권한을 행사하거나, 동일한 입법기관이 특별한 방식으로 개정 절차를 운영하도록 규정하고 있다. 미국 헌법 제5조는 각 주 의회의 4분의 3 또는 4분의 3의 주에서 개최된 특별 회의에서 개정을 비준하도록 규정한 첫 번째 유형의 예이며, 1909년 남아프리카법(South Africa Act) 제152조는 두 번째 유형의 예에 해당한다. 그러나 모든 헌법이 개정권(amending power)을 포함하고 있는 것은 아니며, 경우에 따라 헌법이 특정 입법 제한 조항들을 개정권의 범위 밖에 두기도 한다. 미국 헌법에서도 이러한 제한의 예를 찾아볼 수 있는데(일부는 오늘날 더는 실질적 의미를 갖지 않지만), 제5조는 “1808년 이전에 이루어진 어떠한 개정도 제1조 제9절 제1항 및 제4항에 어떤 방식으로든 영향을 미쳐서는 안 되며, 어떠한 주도 그 동의 없이 상원의 평등한 표결권을 박탈당해서는 안 된다”고 규정하고 있다.

입법기관이 헌법에 의해 제한을 받고 있으며, 이 제한이 입법기관의 구성원들이 특별 절차를 통해 이를 제거할 수 있는 경우(예: 남아프리카)에는, 그 기관이 이론상 요구되는 ‘법적으로 제한될 수 없는 주권자’로 동일시될 여지가 있다. 그러나 이론이 설명하기 곤란한 사례는, 입법기관에 대한 제한이 오직 특별 기관에 부여된 개정권을 통해서만 해제될 수 있는 경우(예: 미국), 또는 아예 어떠한 개정권의 범위로도 제한 조항이 해제될 수 없는 경우이다.

이러한 사례들을 일관되게 설명하려는 이론의 주장을 평가하기 위해, 우리는 흔히 간과되지만 중요한 사실을 상기해야 한다. 즉, 오스틴은 이론을 전개함에

²¹See Art. 113 of the Constitution of Switzerland.

있어, 심지어 잉글랜드의 경우에도 입법기관과 주권자를 동일시하지 않았다(not)는 점이다. 이는 의회의 여왕(the Queen in Parliament)이 일반적으로 입법권에 법적 제한을 받지 않는다는 (p. 74) 통념에 따라 ‘견고한(rigid)’ 헌법에 의해 제한되는 의회(Congress)나 다른 입법기관들과는 달리 종종 ‘주권적 입법기관(a sovereign legislature)’의 전형으로 인용된다는 점에서 주목할 만하다. 그럼에도 불구하고, 오스틴의 견해는 민주정치체제에서 선출된 대표들은 주권자의 일원이 아니라 단지 수탁자(trustee)에 불과하다는 것이었다. 따라서 잉글랜드에서 “정확히 말하자면, 하원의 의원들은 자신들을 선출하고 임명한 집단의 단순한 수탁자이며, 결과적으로 주권은 항상 국왕, 귀족원, 그리고 하원의 선거권을 가진 유권자 집단에 속한다”는 것이다²². 마찬가지로 그는, 미국의 경우 각각 주의 주권과 연방 통합으로부터 발생하는 더 큰 국가의 주권은, 각 주 정부가 하나의 통합된 집단으로 구성된다는 의미에서, 주의 일반 입법기관이 아니라 이 입법기관을 임명하는 시민 집단에 귀속된다고 보았다²³.

이러한 관점에서 보면, 일반 입법기관이 법적 제한을 받지 않는 법체제와 입법기관이 법적 제한을 받는 법체제의 차이는, 주권적 유권자(electorate)가 자신의 주권 권한을 행사하는 방식의 차이에 불과한 것으로 보인다. 이 이론에 따르면, 영국에서 유권자들이 주권의 일부를 행사하는 유일한 직접적 방식은 국회의원들을 선출하여 의회에 보내고, 그들에게 자신의 주권적 권한을 위임하는 것이다. 이 위임은 어느 의미에서는 절대적인데, 그 이유는 비록 유권자들이 그러한 권한을 남용하지 않기를 의원들에게 기대하고 그러한 신탁(trust)을 부여하긴 하지만, 이 신탁은 도덕적 제재의 문제일 뿐이며, 입법권에 대한 법적 제한과는 달리 법원이 관여하지 않기 때문이다. 이에 반해, 미국을 포함한 일반 입법기관이 법적으로 제한을 받는 모든 민주국가에서는, 유권자 집단이 자신의 주권을 단지 대리인을 선출하는 것으로만 행사하는 데 그치지 않고, 그들에게 법적 제한을 부과한다. 이 경우 유권자는 ‘비상적이고 상위의 입법기관(extraordinary and ulterior legislature)’으로 간주될 수 있으며, 이는 법적으로 ‘구속된(bound)’ 일반 입법기관보다 우위에 있다. 따라서 충돌이 발생할 경우,

²² Austin, *Province of Jurisprudence Determined*, Lecture VI, pp. 230–1.

²³ *Ibid.*, p. 251.

법원은 일반 입법기관의 법률을 무효로 선언한다. 이와 같이, 이론이 요구하는 바와 같이, 법적 제한을 받지 않는 주권자는 바로 유권자(electorate)에 있다고 할 수 있다.

(p. 75) 이러한 이론의 확장된 적용에서 볼 때, 초기의 단순한 주권자 개념은 일정한 정교화(sophistication)를 겪었으며, 어쩌면 근본적인 변형까지 이루었다고 할 수 있다. 주권자를 “사회의 대다수가 습관적으로 복종하는 자(person or persons)”라고 묘사한 정의는, 이 장의 제1절에서 보았듯이, 가장 단순한 형태의 사회—즉, 입법자로서의 후계에 대한 규정 없이 Rex가 절대군주였던 경우—에서는 거의 문자 그대로 적용될 수 있었다. 하지만 일단 후계에 대한 규정이 마련되면, 입법권의 연속성이라는 현대 법체계의 핵심적 특성은 더 이상 단순한 복종 습관의 틀로 설명될 수 없으며, 계승자가 실제로 복종받기 이전부터 입법권을 가질 자격이 있다는 ‘수용된 규칙(accepted rule)’이라는 개념이 필요해진다. 그러나 현재와 같은 방식으로 민주국가의 유권자와 주권자를 동일시하는 것은, 만약 ‘복종 습관(habit of obedience)’이나 ‘사람 또는 사람들(person or persons)’이라는 핵심 개념에 대해 단순한 경우와는 전혀 다른 의미를 부여하지 않는 한, 전혀 타당성을 가질 수 없다. 그리고 이러한 새로운 의미는 ‘수용된 규칙’ 개념을 은밀하게 도입하지 않고는 명확히 정의될 수 없다. 단순한 복종 습관과 명령이라는 도식만으로는 이러한 경우를 충분히 설명할 수 없다.

이 점은 여러 방식으로 입증될 수 있지만, 가장 분명하게 드러나는 예는 다음과 같은 경우이다. 유권자에서 유아와 정신적 결함자를 제외한 모든 구성원이 포함되어 있는 민주주의 사회에서는, 유권자 자체가 인구의 ‘대다수(bulk)’를 구성한다. 또는, 모든 성인이 투표권을 가진 단순한 사회집단을 상상해 보자. 이러한 경우 유권자를 주권자로 간주하고, 원래 이론의 단순한 정의를 적용하려 하면, 우리는 결국 사회의 ‘대다수’가 스스로에게 습관적으로 복종한다고 말하게 된다. 따라서 “법적으로 제한을 받지 않는 주권자가 명령을 내리고, 수범자들은 이에 습관적으로 복종한다”는 명확한 사회 구도는 사라지고, 다수에 의해 내려진 명령에 다수가 복종하거나, 전체 구성원에 의해 내려진 명령에 전체가 복종한다는 모호한 이미지로 대체된다. 그러나 이것은 더 이상 원래 의미의 ‘명령(orders)’(타인(others)이 특정 방식으로 행동하길 의도한 표현)도 아니고,

‘복종(obedience)’도 아니다.

이러한 비판에 대응하기 위해, 사회 구성원이 개인으로서의 사적 자격과 유권자 또는 (p. 76) 입법자로서의 공적 자격을 구분하는 방식이 제안될 수 있다. 이러한 구분은 충분히 이해 가능하며, 실제로 많은 법적·정치적 현상이 이와 같은 방식으로 가장 자연스럽게 설명되기도 한다. 그러나 이 구분은, 우리가 한 걸음 더 나아가 공적 자격의 개인들이 별개의 인격(another person)을 구성하며, 이 인격이 습관적으로 복종받는다고 말한다 해도, 주권 이론을 구제할 수는 없다. 왜냐하면, 어떤 사람들 집단이 대리인을 선출하거나 명령을 발한 것이 ‘개인으로서’가 아니라 ‘공적 자격으로서’ 이루어진 것이라고 말할 때, 그 의미는 결국 특정 규칙 하에서의 자격 요건(qualifications)과, 유효한 선거나 법률을 성립시키기 위해 따라야 하는 규칙에 대한 준수로만 설명될 수 있기 때문이다. 오직 이러한 규칙들을 통해서만 우리는 어떤 행위를 선거나 법 제정으로 식별할 수 있다. 이러한 행위들은, 우리가 개인의 구술 혹은 문서 명령을 그 사람에게 귀속시키는 데 사용하는 단순하고 자연스러운 기준을 통해서가 아니라, 해당 규칙들을 통해서만 그 집단의 행위로 간주된다.

그렇다면 이러한 규칙들이 ‘존재한다’는 것은 무엇을 의미하는가? 이러한 규칙들은, 구성원들이 유권자 집단으로서 기능하기 위해 무엇을 해야 하는지를 정의하며(따라서 이론상 주권자로 간주되기 위해 필요한 조건이기도 하다), 따라서 이 규칙들 자체는 주권자가 발한 명령의 지위를 가질 수 없다. 왜냐하면, 주권자가 발한 명령으로 간주되기 위해서는, 그 이전에 이러한 규칙이 이미 존재하고, 그것이 준수되어야만 하기 때문이다.

그렇다면 우리는 이러한 규칙들이 단지 인구의 복종의 습관(habits)을 기술하는 일부에 불과하다고 말할 수 있을까? 만약 주권자가 단일한 개인이고, 사회의 대다수 구성원들이 그가 특정한 방식—예를 들어 서명되고 증인된 문서의 형태—으로 명령을 내리는 경우에만, 그리고 그럴 때에만, (if, and only if) 그에게 복종한다면, (제1절에서 ‘습관’ 개념의 사용에 대한 반론을 고려하면서도) 우리는 그가 반드시 그러한 방식으로 입법해야 한다는 규칙이 단지 그 사회의 복종 습관을 기술하는 일부라고 말할 수도 있을 것이다. 즉, 구성원들이 이러한 방식으로 명령이 주어졌을 때(when) 그에게 습관적으로 복종한다는 것이다.

하지만 주권자가 그러한 규칙과 무관하게 독립적으로 식별될 수 없는 경우, 우리는 그 규칙들을 단순히 사회가 주권자에게 습관적으로 복종하는 조건이라고 설명할 수 없다. 그 규칙들은 주권자를 성립시키는(constitutive) 것이지, 주권자에 대한 복종 습관을 기술할 때 부차적으로 (p. 77) 언급해야 할 사항이 아니다. 따라서 우리는 현재 논의 중인 사례에서 유권자의 절차를 규정하는 규칙들이, 사회 구성원들이 단순히 개인으로서 자신들에게 복종하는 조건들을 나타낸다고 말할 수 없다. 왜냐하면 ‘자신을 유권자 집단으로서’ 복종한다는 말은, 규칙과는 독립적으로 식별 가능한 어떤 인격체를 가리키는 것이 아니기 때문이다. 그것은 유권자들이 대리인을 선출할 때 해당 규칙을 준수했다는 사실을 요약하여 표현한 것에 불과하다. 기껏해야 (제1절에서 제기된 반론을 감안하여) 우리는 그 규칙들이 선출된 자들(elected persons)이 습관적으로 복종받는 조건을 설정한다고 말할 수 있을 것이다. 그러나 이렇게 되면 우리는 주권자가 유권자가 아니라 입법기관이라고 보는 이론의 형태로 다시 돌아가게 되고, 그 입법기관이 입법권 행사에 있어 법적 제한을 받을 수 있다는 점에서 비롯된 모든 난점들이 여전히 해결되지 않은 채 남게 된다.

이러한 이론에 대해 반대하는 논변들은, 이 장의 앞 절들에서 제시된 반론들과 마찬가지로, 단순히 세부사항에서 오류를 지적하는 데 그치는 것이 아니라, 명령, 습관, 복종이라는 단순한 개념들만으로는 법의 분석에 충분하지 않다는 근본적인 비판에 해당한다. 이 대신 요구되는 것은, 특정한 방식으로 절차를 준수함으로써 입법할 자격을 갖춘 자에게 권한을 부여하는 규칙의 개념이며, 그 권한은 제한적일 수도, 무제한일 수도 있다.

이러한 이론의 일반적인 개념적 부적절성과는 별개로, 일반적으로 최고 입법기관으로 여겨지는 기구가 실제로는 법적 제한을 받는다는 사실을 이론에 끌어들이려는 시도에는 수많은 부가적 반론들이 제기될 수 있다. 만약 이러한 경우에 주권자가 유권자와 동일하다고 본다면, 설령 유권자가 보통 입법기관의 제한을 제거할 수 있는 무제한적 수정 권한(amending power)을 갖고 있다 하더라도, 과연 그러한 제한이 유권자가 보통 입법기관에게 명령을 내렸고 그것을 입법기관이 습관적으로 복종한다는 의미에서 법적 제한이 되는 것인지 묻지 않을 수 없다. 우리는 이 시점에서, 입법권에 대한 법적 제한을 명령으로, 나아가

그것에 부과된 의무(duties)로 오해한다는 일반적인 반론을 잠시 보류해 둘 수 있다. 그러나 그럼에도 불구하고, 우리는 그러한 제한들이 유권자가 묵시적으로 (tacitly) 입법기관에게 이행하라고 명령한 의무들이라고 간주할 수 있는가? 앞장들에서 제기된, ‘묵시적 명령’이라는 개념에 대한 모든 반론들은 이곳에서도 더욱 강력하게 적용된다. 미국 헌법처럼 복잡한 절차를 (p. 78) 요하는 수정 권한을 실제로 행사하지 않았다는 것은 유권자의 의사를 반영한다기보다는, 그들의 무지 또는 무관심을 반영하는 경우가 훨씬 더 많다. 이는, 자신이 병사들이 병장의 말에 따르고 있다는 사실을 알고 있으므로 암묵적으로 그렇게 하라고 명령했다고 그럴싸하게 간주될 수 있는 장군의 사례와는 매우 거리가 멀다.

또한, 만약 입법기관에 대한 일부 제한이 유권자에게 부여된 수정 권한의 범위 자체를 완전히 벗어나는 경우라면, 이론의 틀 안에서 우리는 무엇이라고 말할 수 있는가? 이는 단순히 상상 가능한 경우가 아니라 실제 존재하는 경우이다. 이 경우 유권자조차 법적 제한을 받게 되며, 비록 그것이 ‘비상 입법기관 (extraordinary legislature)’이라 불린다 해도, 법적 제한을 받지 않는 존재는 아니므로 주권자도 아니다. 이 경우 우리는, 그 사회가 이러한 제한들에 대해 반란을 일으키지 못했기 때문에, 사회 전체가 주권자이고, 이 제한들을 사회 전체(it)가 묵시적으로 명령한 것이라고 말해야 하는가? 이것은 혁명과 입법의 구분을 무의미하게 만들기 때문에, 그 자체로 이 해석을 기각해야 할 충분한 이유가 된다. 결국, 유권자를 주권자로 간주하는 이론은 최선의 경우, 유권자가 존재하는 민주주의 체제 내에서만 법적으로 제한된 입법기관의 존재를 설명해 줄 수 있다. 그러나 Rex와 같은 세습 군주가 법적으로 제한된 동시에 체제 내에서 최고인 입법 권한을 가질 수 있다는 개념에는 전혀 모순이 없다.

CHAPTER IV 주석

50쪽. 오스틴의 주권 이론. 본 장에서 검토된 주권 이론은 오스틴이 『법학의 영역』(*The Province*) 제5강과 제6강에서 전개한 것이다. 우리는 오스틴이 단지 일정한 형식적 정의들이나 법체계를 논리적으로 배열하기 위한 추상적 도식을 제시한 것이 아니라, 영국이나 미국과 같은 법이 존재하는 모든 사회에서는 오스틴이 정의한 속성을 갖춘 주권자가 어딘가에 반드시 존재한다는 사실 주장(*factual claim*)을 하고 있다고 해석했다. 다만 이러한 주권자의 존재는 다양한 헌법적·법적 형식들에 의해 가려질 수 있다. 일부 이론가들은 오스틴을 달리 해석하여 그가 그러한 사실 주장을 한 것이 아니라고 본다(예: 스톤, 『법의 영역과 기능』, 제2장 및 제6장, 특히 60, 61, 138, 155쪽. 여기서 오스틴이 여러 공동체에서 주권자를 식별하려 한 시도는 그의 본래 목적에서 벗어난 무의미한 일탈로 다뤄진다). 이러한 해석에 대한 비판은 Morison, “Some Myth about Positivism”, loc. cit., 217-222쪽 참조. 또한 시드그윅, 『정치의 요소들』, 부록(A) “오스틴의 주권 이론에 대하여”도 참조.

54쪽. 오스틴 이론에서 입법 권한의 연속성. 『법학의 영역』에서 오스틴이 ‘계승의 방식으로 주권을 취득하는 자’에 대해 간략히 언급한 부분(제5강, 152-154쪽)은 암시적이지만 불분명하다. 오스틴은 변화하는 개인들이 주권을 계승함으로써 주권의 연속성을 설명하려면, ‘습관적 복종(habitual obedience)’과 ‘사령(commands)’이라는 핵심 개념 외에 무언가 추가적인 요소가 필요하다는 점을 시사하는 듯하지만, 그 추가 요소를 명확히 밝히지는 않는다. 그는 이 맥락에서 ‘자격(title)’, ‘계승에 대한 청구권(claims)’, 그리고 ‘정당한 자격(*legitimate title*)’이라는 표현을 사용하지만, 이러한 표현들은 통상적으로 어떤 규칙(rule)의 존재—즉, 계승을 규율하는 규칙—을 함축하며, 단순히 연속되는 주권자에 대한 복종 습관만으로 설명될 수 없다. 오스틴이 사용하는 ‘일반적 자격(*generic title*)’ 또는 ‘일반적 방식(*generic mode*)’이라는 개념의 설명은, 『법학의 영역』 제5강 145-155쪽에서 전개되는 주권자의 ‘확정성(*determinate*)’이라는 개념에서 도출된다. 여기서 그는 주권자가 개별적으로, 예를 들어 이름으로 식별되는 경우와, 어떤 일반적 서술(*generic description*)에 부합하는 자로 식별되는 경우를 구분한다. 예컨대 세습 군주제에서는 일반적 서술이 ‘어떤 조상의 생존한 장남’일 수 있고, 의회 민주주의에서는 훨씬 복잡한 서술이 입법기관 구성원의 자격 조건을 반영하게 된다.

오스틴의 입장은, 어떤 인물이 이러한 ‘일반적 서술’에 부합할 경우 그는 계승할 ‘자격’이나 ‘권리’를 갖게 된다고 보는 것이다. 그러나 여기서 ‘서술(*description*)’이라는 말이 규칙(rule)을 뜻하는 것이 아니라면, 이 설명은 충분하지 않다. 왜냐하면

구성원들이 단순히 사실상 일정한 서술에 부합하는 자에게 복종하는 경우와, 그러한 자에게 복종해야 한다는 규칙이 받아들여진 경우는 명백히 구별되기 때문이다. 이는 사람들이 체스 기물을 특정 방식으로 움직이는 습관을 갖고 있는 경우와, 그 방식이 ‘옳은’ 방식이라는 규칙을 받아들인 경우의 차이와 유사하다. 누군가가 계승할 ‘권리’ 또는 ‘자격’을 가지려면, 계승을 규정하는 규칙이 있어야 한다. 오스틴의 ‘일반적 서술’ 이론은 이러한 규칙을 대체할 수는 없지만, 오히려 그러한 규칙의 필요성을 드러낸다. 오스틴이 입법 자격을 부여하는 규칙 개념을 인식하지 않은 점에 대한 유사한 비판으로는 그레이의 『법의 본성과 원천』 제3장, 특히 §151-157 참조. 제5장에서 오스틴이 주권자의 통일성과 법인격적(*corporate, collegial*) 성격을 설명한 부분도 같은 결함을 안고 있다(본 장 §4 참조).

55쪽. 규칙과 습관. 여기서 강조된 규칙의 내면적 측면(*internal aspect*)은 제5장 §2(p.88), §3(p.98), 제6장 §1, 제7장 §3에서 더 논의된다. 또한 Hart, “Theory and Definition in Jurisprudence”, 29 *PAS* Supplementary vol. (1955), 247-250쪽도 참고. 유사한 관점으로는 Winch, 『사회과학의 개념』(1958), 제2장 57-65쪽, 제3장 84-94쪽, 그리고 Piddington, “Malinowski의 욕구 이론”, 『인간과 문화』(Firth 편) 참조.

60쪽. 헌법의 기본 규칙에 대한 일반적 수용. 헌법의 수용, 나아가 법체계의 존재와 관련하여, 공무원과 민간 시민들이 법 규칙에 대해 보이는 다양한 태도들은 제5장 §2 (88-91쪽), 제6장 §2 (114-117쪽)에서 더 깊이 논의된다. 또한 Jennings, 『헌법법』(3판) 부록 3: “법 이론에 대한 노트” 참조.

63쪽. 흡스와 묵시적 사령 이론. 앞선 제3장 §3 및 해당 주석 참조. 또한 Sidgwick, 『정치의 요소들』 부록 A. 현대 입법기관의 제정법조차도 집행되기 전까지는 법이 아니라고 보는 유사한 ‘현실주의적’ 이론으로는 Gray, 『법의 본성과 원천』 제4장, J. Frank, 『법과 현대정신』 제13장 참조.

66쪽. 입법 권한에 대한 법적 제한. 오스틴과는 달리 벤담은 최고 권력이 ‘명시적 합의(*express convention*)’에 의해 제한될 수 있으며, 그 합의를 위반하여 제정된 법률은 무효가 될 수 있다고 보았다. 이에 대해서는 『정부에 관한 단편』(*A Fragment on Government*) 제4장 제26, 34-38절 참조. 오스틴이 주권자의 권한에 법적 제한이 있을 수 없다는 논변은, 그러한 제한을 받는다는 것은 곧 *의무(*duty*)*를 지는 것이라는 전제에 있다. 이에 대해서는 『법학의 영역』(*The Province*) 제6장, 254-268쪽 참조. 그러나 실제로 입법 권한에 대한 제한은 의무가 아니라 *무능력(*disabilities*)*에 해당한다(이에 대해서는 호펠드, 『법 개념의 기초』(*Fundamental Legal Conceptions*, 1923), 제1장 참조).

68쪽. 입법의 방식 및 형식에 관한 규정. 이러한 규정들을 입법 권한에 대한 실질적 제한과 구별하는 것이 어렵다는 점은 제7장 제4절, 149-152쪽에서 추가로 논의된다. 주권 기관의 역량을 ‘정의하는 것’과 ‘제한하는 것’ 사이의 구분에 대한 포괄적 논의는 마셜, 『의회 주권과 영연방』(*Parliamentary Sovereignty and the Commonwealth*, 1957), 제1-6장 참조.

72쪽. 헌법적 안전장치와 사법 심사. 사법 심사가 허용되지 않는 헌법에 대해서는 휘어, 『현대 헌법』(*Modern Constitutions*) 제7장 참조. 여기에 해당하는 국가는 (주법을 제외한) 스위스, 제3공화국 시기의 프랑스, 네덜란드, 스웨덴 등이 포함된다. 미국 대법원이 ‘정치적 문제(political questions)’를 야기하는 위헌 주장에 대해 판결을 거부한 사례로는 루터 대 보든(*Luther v. Borden*), 7 Howard 1, 12 L. Ed. 581 (1849) 참조. 프랑크퍼터의 「대법원」, 『사회과학 백과사전』 제14권, 474-476쪽도 참조.

74쪽. ‘예외적 입법기관(extraordinary legislature)’으로서의 유권자. 많은 체계에서 통상적 입법기관이 법적 제한을 받는다는 비판을 피하려는 시도로 오스틴이 이 개념을 사용한 것에 대해서는 『법학의 영역』 제6강, 222-233쪽 및 245-251쪽 참조.

76쪽. 입법자의 사적 자격과 공적 자격. 오스틴은 종종 주권 기관의 구성원을 ‘개별적으로 고려했을 때’와 ‘구성원으로서 또는 법인적·주권적 자격으로 고려했을 때’를 구분한다(『법학의 영역』 제6강, 261-266쪽). 그러나 이 구분은 주권 기관의 입법 활동을 규율하는 규칙 개념을 수반한다. 오스틴은 이러한 공적 또는 집합적 자격 개념을 ‘일반적 서술(generic description)’이라는 불충분한 용어로 설명하려고 암시만 할 뿐이다(54쪽 주석 참조).

78쪽. 개헌 권한의 제한 범위. 미국 헌법 제5조의 단서 조항 참조. 독일 연방공화국의 기본법(1949년) 제1조와 제20조는 제79조 제3항이 부여한 개헌 권한의 범위 밖에 놓여 있다. 터키 헌법(1945년)의 제1조 및 제102조도 참조.

CHAPTER IV 제3판 주석

44-49쪽. 관습(custom)과 법의 원천. 존 가드너(John Gardner)의 『법은 신념의 도약이다(Law as a Leap of Faith)』(옥스퍼드 대학 출판부, 2012) 제3장 “Some Types of Law” 참조. 또한 아만다 페로-소신(Amanda Perreau-Saussine)과 제임스 머피(James B. Murphy) 편, 『관습법의 본성: 법적·역사적·철학적 관점(The Nature of Customary Law: Legal, Historical and Philosophical Perspectives)』(케임브리지 대학 출판부, 2007)의 논문들도 참조할 것. 드워킨(Dworkin)은 하트가 승인 규칙(rule of recognition)의 이론에 따라 관습을 일관되게 설명할 수 없다고 주장한다. (*Taking Rights Seriously*,

41-44쪽 참조.)

55-57쪽. 사회 규칙의 본성에 대하여. 하트의 '실천 이론(practice theory)'에 대한 비판은 다음 저작들을 참조할 것: G. J. 워녹(G. J. Warnock), 『도덕성의 대상(The Object of Morality)』(메튜언, 1971) 제4장; 로널드 드워킨(Ronald Dworkin), 『권리를 진지하게 대하기(Taking Rights Seriously)』 48-58쪽; 조셉 라즈(Joseph Raz), 『실천적 이성과 규범(Practical Reason and Norms)』 49-58쪽.

하트는 이후의 저술에서 사령에 관한 사고를 발전시켜 규칙에 대한 또 다른 견해를 제안하였다. 그는 사령이 '결정적인(peremptory)' 것으로서, 즉 "청자가 어떤 행위를 할 것인지에 대해 그 장단점을 독자적으로 숙고하는 것을 차단하거나 차단하려는 의도를 가진 것"이며, 또한 '내용 독립적(content-independent)'으로, "실행될 행위의 성격이나 본질에 관계없이 이유로 기능하도록 의도된 것"이라고 말한다. 그는 이어, "사회에서 사령자의 발언이 결정적인 행위 이유(peremptory reasons for action)로 일반적으로 승인되는 것은 사회 규칙의 존재와 동일하다"고 주장한다(H. L. A. Hart, 「사령과 권위 있는 법적 이유(Commands and Authoritative Legal Reasons)」, 『벤담에 관한 에세이(Essays on Bentham)』 제10장, 258쪽 참조). 하트는 '법적·도덕적 의무(Legal and Moral Obligation)'라는 논문에서 '내용 독립적 이유' 개념을 처음 도입하였으며, 이는 A. I. 멜든(A. I. Melden) 편 『도덕철학 에세이(Essays in Moral Philosophy)』(워싱턴 대학 출판부, 1958), 82-107쪽에 수록되어 있다. 이 개념은 라즈의 『자유의 도덕성(The Morality of Freedom)』(옥스퍼드 대학 출판부, 1986) 제2장에서, 그리고 레슬리 그린(Leslie Green)의 『국가의 권위(The Authority of the State)』(옥스퍼드 대학 출판부, 1990), 36-42쪽에서 더욱 발전되었으며, P. 마크위크(P. Markwick)의 「법과 내용 독립적 이유(Law and Content-Independent Reasons)」(*Oxford Journal of Legal Studies*, 2000년 제20권, 579쪽)에서는 비판받았다.

56-58쪽. 법의 '내면적 측면'(internal aspect). 하트는 종종 '내면적 관점(internal point of view)'과 '내면적 측면(internal aspect)'을 혼용해서 사용한다(예: 88-89쪽 참조). 이 일반 개념에 대해서는 닐 매클리크(Neil MacCormick), 『H. L. A. Hart』 29-40쪽 참조. 이 개념의 모호성에 대한 논의로는 스티븐 페리(Stephen Perry), 「하트의 사회 규칙과 법의 기초: 내면적 관점의 해방(Hart on Social Rules and the Foundations of Law: Liberating the Internal Point of View)」(*Fordham Law Review*, 2006년 제75권, 1171쪽), 스콧 샤피로(Scott J. Shapiro), 「내면적 관점이란 무엇인가?(What is the Internal Point of View?)」(*Fordham Law Review*, 2006년 제75권, 1157쪽) 참조. 법이론에서 이 개념의 방법론적 중요성은 라즈, 『권위와 해석 사이(Between Authority and Interpretation)』

제2장에서 논의된다. 이 방법론적 주장에 대한 비판으로는 스티븐 페리, 「법이론에서의 해석과 방법론(Interpretation and Methodology in Legal Theory)」, 안드레이 마머(Andrei Marmor) 편 『법과 해석(Law and Interpretation)』(옥스퍼드 대학 출판부, 1997), 존 피니스(John Finnis), 『자연법과 자연권(Natural Law and Natural Rights)』 제1장 등이 있다. 피니스의 비판은 줄리 딕슨(Julie Dickson), 『평가와 법이론(Evaluation and Legal Theory)』(하트 출판사, 2001), 제2-4장에서 면밀히 분석된다.

66-71쪽. 입법권에 대한 법적 제한. 하트는 『벤담에 관한 에세이(*Essays on Bentham*)』 제9장 「주권과 법적으로 제한된 정부(Sovereignty and Legally Limited Government)」에서 벤담이 입법 제한을 이해하려 한 시도를 분석한다. 오스틴의 무제한성(ilimitability) 개념에 대한 라즈의 비판은 『법체계의 개념(The Concept of a Legal System)』 제2장에서 다루어진다. 오스틴의 분석이 헌법이론에 미치는 함의에 대해서는 제프리 마셜(Geoffrey Marshall), 『헌법 이론(Constitutional Theory)』(옥스퍼드 대학 출판부, 1980), 제1, 3장 참조.

V. 1차 규칙과 2차 규칙의 결합으로서의 법

1. 새로운 출발

앞선 세 장에서 우리는 법을 주권자의 강제 명령으로 이해하는 단순한 모형이 법체계의 주요한 특징들을 재현하는 데 여러 결정적인 지점에서 실패했다는 점을 확인하였다. 이를 입증하기 위해, 이전 비평가들이 그랬던 것처럼 국제법이나 원시적 법체계와 같은—법이라 부르기엔 논란의 여지가 있는 경계사례—를 끌어올 필요는 없었다. 대신 우리는 현대 국가의 국내법에서 익숙하게 발견되는 특징들을 지목하였고, 이러한 특징들이 지나치게 단순화된 이 이론에서는 왜곡되거나 아예 설명조차 되지 않는다는 점을 보였다.

이 이론이 실패한 주요 방식들은 다시 요약할 가치가 있을 정도로 교육적이다. 첫째, 법의 여러 형태 가운데 특히 형법 조항은 특정 행위를 금지하거나 강제하고 이를 위반할 경우 처벌을 부과하므로, 명령과 위협의 형태를 가장 잘 닮아 있다. 그러나 이러한 법 조항 역시, 그것을 제정한 이들에게도 동일하게 적용된다는 점에서 단순한 명령과는 중요한 면에서 다르다. 둘째, 법에는 재판권이나 입법권과 같은 공적 권한을 부여하거나, 법적 관계를 창설하거나 수정할 수 있는 사적 권한을 부여하는 규칙들이 있다. 이러한 규칙들을 단순한 위협을 수반한 명령으로 해석하는 것은 터무니없는 일이다. 셋째, 법 규칙 중에는 명시적인 명령이나 처방과 유사한 방식으로 생성되지 않는 경우도 있어, 명령으로서는 설명할 수 없는 생성방식을 가진 규칙들이 존재한다. 마지막으로, 법을, 습관적으로 복종을 받고 모든 법적 제약으로부터 필연적으로 면제되는, 주권자의 관점에서 분석하려는 시도는 현대 법체계의 핵심인 입법 권한의 연속성을 설명하지 못하며, 주권자의 위치에 현대 국가의 유권자나 입법기관을 대입하려는 시도도 실패한다.

(p. 80) 이와 같이 법을 주권자의 강제 명령으로 개념화하는 방식에 대한 비판 과정에서, 우리는 이 단순한 이론을 구제하기 위해 덧붙여졌던 여러 보조 개념들도 함께 검토하였다. 그러나 이들 역시 실패하였다. 예컨대 ‘암묵적 명령 (tacit order)’이라는 개념은, 부하의 명령에 간섭하지 않는 장군처럼 매우 단순한

상황에서는 어느 정도 의미를 가질 수 있을지 몰라도, 현대 법체계의 복잡한 현실에는 적용되지 않는다. 또 다른 보조 수단들은, 예컨대 권한 부여 규칙을 단지 의무 부과 규칙의 일부로 취급하거나, 모든 법 규칙을 단지 공무원에게 향하는 규칙으로 간주하는 식이다. 그러나 이러한 해석은 실제 사회생활에서 이러한 규칙들이 어떻게 언급되고, 사유되고, 사용되는지를 왜곡하며, 마치 경기의 모든 규칙이 실제로는 심판과 기록원을 향한 지시라는 주장과 별반 다르지 않다. 입법자가 자기 자신에게 법을 적용할 수 있다는 점을 기존 이론과 조화시키기 위해 제안된 또 다른 장치는, 입법자를 ‘공적 지위’에서 다른 사람들(그 속에는 사적 자격의 자기 자신도 포함됨)에게 명령을 내리는 단일 인격(one person)으로 구성하는 방식이었다. 이 장치는 그 자체로는 논리적 결함이 없지만, 본래 이 이론에는 포함되지 않은 요소를 도입해야만 작동할 수 있다. 그것은 바로 입법이 유효하게 성립되기 위해 따라야 할 요건을 규정하는 규칙의 개념이다. 입법자는 그러한 규칙을 준수할 때에만 공적 지위를 갖게 되며, 사적 인격과 구별되는 별개의 인격으로 기능할 수 있다.

이러한 이유로 앞선 세 장은 실패의 기록이며, 우리는 명백히 새로운 출발이 필요하다. 그러나 이 실패는 매우 유익한 것이기도 하다. 이론이 사실과 맞지 않는 지점마다, 그 실패가 왜 필연적이었는지, 또 더 나은 이론을 위해 무엇이 필요한지를 개략적으로나마 확인할 수 있었기 때문이다. 이러한 실패의 근본 원인은, 해당 이론이 구성되는 데 사용된 요소들—즉 명령, 복종, 습관, 위협—이 규칙이라는 개념을 포함하지 않으며, 그러한 요소들을 조합해도 규칙의 개념을 산출할 수 없다는 점에 있다. 하지만 규칙 없이는 법의 가장 기초적인 형태조차도 설명할 수 없다. 물론 규칙이라는 개념은 결코 단순한 것이 아니다. 우리는 이미 제3장에서, 법체계의 복잡성을 제대로 설명하기 위해서는 (p. 81) 서로 관련되지만 구별되는 두 종류의 규칙을 식별할 필요가 있음을 보았다. 그 중 첫 번째 유형, 즉 기본적인거나 1차적인 유형은, 개인들이 원하든 원하지 않든 특정한 행위를 하거나 하지 않도록 요구하는 규칙이다. 다른 유형은 이 첫 번째 유형에 일종의 기생적으로, 또는 2차적으로 존재하는 규칙이다. 이 2차 규칙은 개인들이 특정한 말을 하거나 행동을 함으로써 새로운 1차 규칙을 창출하거나 기존 규칙을 폐기하거나 수정할 수 있도록 해준다. 또는 이 규칙들은 1차 규칙이

어떻게 적용되고 운영될지를 결정하거나 통제하는 기능을 한다. 1차 규칙은 의무를 부과하며, 2차 규칙은 공적 또는 사적 권한을 부여한다. 1차 규칙은 신체적 행위나 변화와 관련된 행동을 대상으로 하며, 2차 규칙은 단지 물리적 변화에 그치지 않고 의무나 권리의 생성 및 변경을 초래하는 작용(operation)을 대상으로 한다.

우리는 이미 특정한 사회 집단 내에서 이 두 가지 유형의 규칙이 존재한다는 주장의 의미에 대해 예비적으로 분석한 바 있다. 이 장에서는 그러한 분석을 좀 더 발전시킬 뿐만 아니라, 이 두 유형의 규칙의 결합 속에 오스틴이 강제 명령이라는 개념에서 잘못 발견하였다고 주장했던 바로 그 것—즉 “법철학의 열쇠”—가 실은 여기 담겨 있다는 주장을 펼칠 것이다. 물론 우리는 ‘법’이라는 단어가 ‘적절하게’ 사용되는 모든 사례에서 이러한 1차 및 2차 규칙의 결합이 반드시 존재한다고 주장하려는 것은 아니다. 실제로 ‘법’이라는 단어가 사용되는 다양한 사례들은 그러한 단순하고 일관된 구조로 묶이지 않으며, 오히려 중심 사례와 형태나 내용 면에서의 유사성에 기초한 간접적인 관련성들에 의해 연결되어 있다. 우리가 이 장과 이후의 장들에서 시도할 것은, 그간 법의 본질을 정의하려는 노력 속에서 가장 난해하고도 회피되었던 법의 여러 특징들이 이 두 종류의 규칙과 그 상호작용을 이해할 때 가장 명확하게 설명될 수 있다는 점을 보여주는 것이다. 우리는 이 두 요소의 결합에 중심적인 지위를 부여하는데, 그것이야말로 법사유의 틀을 구성하는 개념들을 해명하는 데 있어서 강력한 설명력을 발휘하기 때문이다. ‘법’이라는 용어가 외견상 이질적인 다양한 사례들에 대해 사용될 수 있다는 점의 정당화는 부차적인 문제이며, 이 중심 요소들이 충분히 이해된 후에야 비로소 그 문제를 다룰 수 있다.

2. 규범적 의무(obligation)의 개념

(p. 82) 법을 강제명령(coercive orders)으로 이해하는 이론은 여러 오류에도 불구하고, “법이 존재하는 곳에서는 인간 행위가 어떤 의미에서는 선택 불가능하고(non-optional), 의무적(obligatory)이 된다”는 사실을 정확히 인식하고 출발했다는 점에서 타당한 기초 위에 서 있다. 이러한 출발점 선택은 영감 있는

판단이었으며, 본 장에서 우리가 새롭게 구성하고자 하는 1차 규칙(primary rules)과 2차 규칙(secondary rules)의 상호작용에 기초한 법 이론 역시 동일한 통찰에서 출발할 것이다. 그러나 바로 이 첫 단계에서, 우리는 강제명령 이론의 오류들로부터 아마도 가장 많은 교훈을 얻을 수 있다.

이제 “총기 권총강도 상황(the gunman situation)”을 떠올려보자. A는 B에게 돈을 건네라고 명령하고, 그렇지 않으면 총을 쏠 것이라고 위협한다. 강제명령 이론에 따르면, 이 상황은 일반적인 의미에서 규범적 의무(obligation) 또는 행위 의무(duty)의 개념을 잘 보여준다. 이 이론은 법적 의무(legal obligation)가 이 상황을 확장한 형태로 존재한다고 본다. 즉, A는 습관적으로 복종받는 주권자(sov​er​eign)여야 하고, 그의 명령은 단일 행위가 아닌 일반적인 행위방식(courses of conduct)을 규정해야 한다. 총기 권총강도 상황이 규범적 의무(obligation)의 의미를 잘 드러낸다는 주장의 그럴듯함은, 우리가 이 상황에서 B가 A의 요구에 응했다면 “B는 돈을 건넬 수밖에 없었다(obliged)”고 말할 것이라는 점에 있다. 그러나 동시에, 이 사실들에 기초하여 “B는 돈을 건넬 규범적 의무(obligation)를 지니고 있었다”거나 “행위 의무(duty)를 지니고 있었다”고 말한다면, 이는 명백한 잘못된 기술이 된다. 따라서 처음부터 우리는 규범적 의무의 개념을 이해하기 위해 다른 무엇인가가 필요하다는 점이 명백하다. “어떤 사람이 어떤 행위를 할 수밖에 없었다(was obliged to do something)”는 언명과 “그 사람은 그 행위를 할 규범적 의무를 가졌다(had an obligation)”는 진술 사이에는, 아직 설명되지 않은 차이가 존재한다. 첫 번째 진술은 주로 어떤 행위가 수행된 데 있어서의 신념(beliefs)과 동기(motives)에 관한 설명이다. 예컨대 “B는 돈을 건넬 수밖에 없었다”는 진술은, 총기 권총강도 상황에서처럼, 그가 돈을 건네지 않는다면 해를 입거나 불쾌한 결과가 발생할 것이라고 믿었으며, 그 결과를 피하고자 돈을 건넸다는 의미일 수 있다. 이러한 경우, 불복종했을 때 발생할 결과의 전망은, 그가 원래 선호했던 행위(즉 돈을 지내는 것)를 덜 선택할만하게 만든 것이다.

이러한 어떤 일을 하지 않을 수 없음의 개념(the notion of being obliged to do something)을 설명함에 있어, 두 가지 요소가 약간의 복잡성을 더한다. 첫째, 위협된 해악이 일반적 (p. 83) 판단에 비추어봤을 때 사소한 것으로 여겨지거나,

명령을 따르는 것이 B 자신이나 타인에게 중대한 피해를 야기한다면—예컨대 A가 단지 B를 꼬집겠다고 위협한 경우—우리는 B가 돈을 건넬 수밖에 없었다고 생각하지 않을 것이다. 둘째, A가 심각한 해악을 실현할 수 있거나 실제로 실현할 것이라는 합리적 근거가 없다면, 마찬가지로 우리는 B가 돈을 건넬 수밖에 없었다고 말하지 않을 수 있다. 이처럼 이 개념(this notion)에는 해악의 상대적 중대성이나 실현 가능성에 대한 일반적 판단이 암묵적으로 포함되어 있다. 하지만 누군가가 타인의 명령에 “복종할 수밖에 없었다(was obliged)”는 진술은 기본적으로 행위의 신념과 동기에 관한 심리적 설명(psychological statement)이다. 반면, 누군가에게 “~할 규범적 의무가 있었다(had an obligation)”는 진술은 완전히 다른 종류의 진술이며, 이 차이를 보여주는 여러 징후가 있다. 예컨대 총기 권총강도 상황에서의 B의 행위나 신념, 동기에 대한 사실들은, 그가 “돈을 건넬 수밖에 없었다(obliged)”는 진술을 정당화하기에는 충분하지만, 그가 “돈을 건넬 규범적 의무(obligation)를 지녔다”는 진술을 정당화하기에는 충분하지 않다(not sufficient). 더 나아가, 믿음이나 동기와 관련된 사실들은 “그에게 ~할 규범적 의무가 있었다”는 진술이 참이기 위한 필수 조건도 아니다(not necessary). 예컨대 누군가에게 진실을 말하거나 군 복무에 응할 규범적 의무(had an obligation)가 있다고 말할 때, 그가 이를 전혀 믿지 않았고(그것이 타당하든 아니든), 불복종하더라도 어떠한 제재도 받지 않으리라고 여겼다 하더라도, 그 의무에 관한 진술은 여전히 참일 수 있다. 또한 “그에게 그러한 의무가 있었다(had an obligation)”는 진술은 실제로 그가 복무했는지 여부와 무관하게 성립하지만, “그는 복무할 수밖에 없었다(was obliged)”는 진술은 일반적으로 그가 실제로 그렇게 행동했다는 함축을 담고 있다.

일부 이론가들—그중에는 오스틴(Austin)도 있다—은, 개인의 신념이나 공포, 동기가 규범적 의무의 존재 여부와 무관하다는 점을 인식하고, 이 개념을 주관적 심리상태가 아닌 불복종 시 제재나 해악을 입을 가능성(chance)이나 있을 법함(likelihood)의 관점에서 정의하였다. 이러한 해석은 규범적 의무에 관한 진술을 심리적 진술이 아닌, 처벌을 받을 가능성에 대한 예측(predictions) 또는 해악을 입을 확률에 대한 평가(assessments)로 간주하는 것이다. 후대의 많은 이론가들은 이러한 해석을 (p. 84) 일종의 계시처럼 받아들였고, 이처럼

모호한 개념을 ‘과학에서 사용되는 명확하고 엄격한 실증적 언어(hard, empirical terms)’로 재진술한 것으로 간주하였다. 심지어는 규범적 의무나 행위의무를 ‘관찰 가능한 세계의 너머 혹은 이면에 존재하는 불가사의한 실체’로 보는 형이상학적 개념들에 대한 유일한 대안처럼 받아들여지기도 하였다. 그러나 규범적 의무에 관한 진술을 단순한 예측으로 해석하는 이러한 관점은 여러 이유에서 거부되어야 하며, 이는 사실 불분명한 형이상학(opaque metaphysics)에 대한 유일한 대안이 아니다.

가장 근본적인 반론은 다음과 같다. 규칙(rule)이 존재하는 경우, 이를 위반하는 행위는 단지 “적대적 반응이 따를 것”이라는 예측의 근거일 뿐만 아니라, 실제로 그러한 반응이나 제재를 정당화(justify)하는 이유(reason)가 된다는 점이다. 우리는 이미 제4장에서 규칙의 내적 측면(the internal aspect of rules)에 대한 간과에 주목하였고, 이 장에서 그 논의를 더 구체적으로 전개할 것이다.

그러나 규범적 의무(obligation)에 대한 예측적 해석(predictive interpretation)에는 두 번째이자 보다 단순한 반론이 있다. 만약 “어떤 사람에게 규범적 의무가 있다(had an obligation)”는 진술이 “그 사람이(he) 불복종할 경우 고통을 겪을 가능성이 있다(he was likely to suffer in the event of disobedience)”는 의미라면, 예컨대 “그가 군 복무에 응할 규범적 의무를 지니고 있다”면서 동시에 “그가 관찰권 밖으로 도피했거나, 경찰이나 법원을 성공적으로 매수하여, 발각되거나 처벌당할 가능성이 전혀 없다”고 말하는 것은 모순이 되어야 할 것이다. 그러나 실제로 그러한 말을 하는 데에는 아무런 모순이 없으며, 이러한 진술은 실제로 자주 행해지며 이해된다.

물론, 일반적인 법체계에서 제재(sanctions)가 상당한 비율로 실제 부과되기 때문에, 범법자는 대체로 처벌 위협을 감수하게 된다. 따라서 보통 “그에게 규범적 의무가 있다”는 진술과 “불복종 시 고통을 겪을 가능성이 있다”는 진술은 동시에 참이 되는 경우가 많다. 실제로 이 두 진술 사이의 연결은 단순한 동시적 참보다 더 강하다. 적어도 국내법 체계(a municipal system)에서는, 일반적으로 제재가 위반자에게 부과될 가능성이 없다면, 특정한 개인의 의무에 대한 진술을 하는 것 자체가 별다른 의미를 갖지 않게 된다. 이러한 의미에서, 의무 진술은 일종의 제재 체계의 정상적 작동에 대한 (p. 85) 믿음을 전제(presuppose)한다고

볼 수 있다. 이는 마치 크리켓 경기에서 “그는 아웃이다(he is out)”라는 진술이 “선수, 심판, 기록원들이 통상적인 절차를 밟을 것”이라는 것을 단언하지는 않지만 전제하듯이 말이다. 그럼에도 불구하고, 개별 사례(individual cases)에서는 “어떤 사람이 어떤 규칙 하에 규범적 의무를 지닌다(had an obligation under some rule)”는 진술과 “그가 불복종으로 인해 고통을 겪을 가능성이 있다”는 예측이 서로 불일치할 수 있다(diverge)는 점을 이해하는 것이 규범적 의무 개념 이해에 있어 결정적으로 중요하다.

규범적 의무(obligation)는 총기 권총강도 상황(gunman situation)에서 발견될 수 없다는 것은 명백하다. 다만, “~할 수밖에 없음(being obliged)”이라는 보다 단순한 개념은 그 상황의 구성요소들로부터 정의될 수 있을지도 모른다. 우리가 규범적 의무를 법적 형태로 이해하기에 앞서 그 일반적 개념을 파악하고자 한다면, 사회적 규칙(social rules)이 존재하는, 총기 권총강도 상황과는 다른 사회적 맥락을 살펴보아야 한다. 왜냐하면 이러한 맥락은 한 개인이 어떤 규범적 의무를 지닌다는 진술의 의미를 두 가지 방식으로 풍부하게 해석하도록 돕기 때문이다. 첫째, 특정한 유형의 행위를 행동 기준(standard)으로 만드는 사회 규칙의 존재는, 이러한 규범적 의무 진술에 대해 통상적으로는 언급되지 않지만 반드시 요구되는 전제 맥락(background or proper context)이다. 둘째, 이러한 진술의 고유한 기능은 어떤 개인의 사례가 일반 규칙의 적용 대상에 해당함을 지적함으로써 일반 규칙을 특정인에게 적용(apply a general rule to a particular person)하는 데 있다. 우리는 이미 제4장에서, 어떤 사회 규칙이 존재한다는 것은 규칙에 따른 반복적 행위(regular conduct)와 그 행위를 행동 기준으로 간주하는 고유한 태도(distinctive attitude)의 결합임을 본 바 있다. 우리는 또한 사회적 습관(social habits)과 사회 규칙 사이의 주된 차이점이 무엇인지, 그리고 어떻게 다양한 규범적 어휘-예컨대 ‘~해야 한다(ought)’, ‘반드시 해야 한다(must)’, ‘그렇게 하는 것이 마땅하다(should)’-가 행동 기준 및 그로부터의 이탈(deviations)을 강조하고, 이를 근거로 요구(demands), 비판(criticisms), 인식(acknowledgements)을 구성하는 데 사용되는지를 확인하였다. 이러한 규범적 어휘(normative vocabulary)들 중 ‘obligation(규범적 의무)’과 ‘duty(행위의무)’는 중요한 하위 범주(sub-class)를 형성하며, 보통 다른 어휘들에는 포함되지

않는 몇 가지 함의를 지닌다. 따라서, 사회 규칙과 단순한 습관을 구분하는 일반적인 요소를 이해하는 것은 규범적 의무나 행위의무 개념을 이해하기 위해 반드시 필요하지만, 그것만으로는 충분하지 않다.

누군가에게 “규범적 의무가 있다(has an obligation)” 또는 “그는 규범적 의무를 지고 있다(is under an obligation)”는 진술은 확실히 규칙의 존재를 암시한다. 그러나 규칙이 존재하는 모든 경우에 그 규칙이 요구하는 행동 기준이 (p. 86) 의무(obligation)라는 틀에서 인식되는 것은 아니다. 예컨대 “그는 그렇게 했어야 했다(He ought to have)”와 “그는 그렇게 할 규범적 의무가 있었다(He had an obligation to)”는 표현은, 비록 둘 다 어떤 행동 기준에 대한 암묵적 참조(implicit reference to existing standards)를 포함하거나 일반 규칙으로부터 특정 사례에 대한 결론을 이끌어낼 때 사용된다는 점에서는 유사하지만, 항상 호환 가능한(interchangeable) 표현은 아니다. 예절(etiquette)이나 올바른 언어습관(correct speech)의 규칙은 분명히 규칙이다. 단지 반복적 습관이나 행위의 일관성 이상의 것으로서, 가르쳐지고 유지되기 위해 노력되며, 자기 자신이나 타인의 행동을 평가하고 비판할 때 규범적 어휘로 표현된다. 예를 들어 “모자를 벗는 것이 예의다(You ought to take your hat off)”라거나, “‘you was’라고 말하는 것은 잘못이다(It is wrong to say ‘you was’)”와 같은 진술이 그 예이다. 그러나 이러한 규칙들과 관련하여 ‘obligation(규범적 의무)’이나 ‘duty(행위의무)’라는 단어를 사용하는 것은 단순히 문체적으로 부자연스러울 뿐 아니라, 사회적 상황을 오도(misdescribe)하는 것이다. 물론 규범적 의무 규칙과 그렇지 않은 규칙을 구분하는 경계는 경우에 따라 모호할 수 있으나, 그 구분의 핵심 기준(main rationale of the distinction)은 비교적 명확하다.

어떤 규칙이 규범적 의무(obligation)를 부과한다고 인식되고 표현되는 것은, 일반적인 준수 요구가 강력(insistent)하고, 그 규칙을 위반하거나 위반할 위험이 있는 사람들에게 가해지는 사회적 압력(social pressure)이 큰 경우이다. 이러한 규칙은 전적으로 관습(customary)에 기원할 수도 있다. 다시 말해, 규칙 위반에 대해 중심화된 제재 시스템이 존재하지 않을 수도 있으며, 사회적 압력은 단지 광범위하고 확산된 적대적 또는 비판적 반응의 형태로 나타날 수 있으며, 그것이 물리적 제재에까지 이르지 않을 수도 있다. 이 사회적 압력은 단지 비난

(disapproval)의 언어적 표현이나 위반된 규칙에 대한 개인의 존중(respect)에 호소하는 것에 그칠 수도 있으며, 부끄러움(shame), 후회(remorse), 죄책감(guilt) 등의 감정 작용에 크게 의존할 수도 있다. 이러한 마지막 유형의 압력이 작동할 때, 우리는 그 규칙을 사회집단의 도덕성(morality)의 일부로 분류하고, 그에 따른 의무를 도덕적 의무(moral obligation)로 분류하고자 하는 경향이 있다. 반대로, 압력의 형태 가운데 물리적 제재(physical sanctions)가 두드러지거나 통상적인 경우—비록 그것이 공식적인 행정관에 의해 명확히 규정되거나 집행되지 않고, 지역 사회 전체에 맡겨진 상태일지라도—그 규칙은 원시적 또는 초기 형태의 법(rudimentary form of law)으로 분류될 것이다. 물론, 명백히 동일한 규범적 행위 기준(rules of conduct) 뒤에 이 두 유형의 강한 사회적 압력이 동시에 존재하는 경우도 있을 수 있다. 이때 두 압력 중 어느 하나가 본질적이고 나머지가 (p. 87) 부차적인 것인지에 대한 명확한 판단이 없을 수 있으며, 따라서 그 규칙이 도덕규칙(moral rule)인지 아니면 초기 형태의 법률규칙(rudimentary legal rule)인지에 대한 판단은 애초에 성립되지 않을 수도 있다. 그러나 지금 이 논의에서는 법과 도덕의 경계를 긋는 문제에 매달릴 필요는 없다. 중요한 점은, 어떤 규칙이 의무를 발생시킨다고 여겨지게 되는 핵심 요인은 그 규칙을 뒷받침하는 사회적 압력의 중요성 또는 심각성(seriousness)에 대한 인식이라는 점이다.

이러한 핵심 요인과 자연스럽게 결합되는 두 가지 특징이 규범적 의무 개념에는 있다. 첫째, 이렇게 심각한 사회적 압력에 의해 지지되는 규칙들은 사회생활의 유지 또는 그것의 매우 소중한 어떤 측면을 위해 필수적(necessary)이라고 여겨지기 때문에 중요하다고 간주된다. 예컨대 폭력의 자유로운 사용을 제한하는 규칙처럼 자명하게 필수적인 규칙들은 일반적으로 규범적 의무(obligation)의 틀 속에서 이해된다. 마찬가지로, 정직(honesty), 진실성(truth), 약속 이행(keeping promises)을 요구하거나, 사회집단 내에서 특정한 역할(role) 또는 기능(function)을 수행하는 사람에게 요구되는 행동을 규정하는 규칙들도 ‘의무(obligation)’ 또는 보다 자주 ‘행위의무(duty)’의 범주로 여겨진다. 둘째, 이러한 규칙들이 요구하는 행동은 일반적으로 타인에게 이익을 주지만, 그것이 그 의무를 지닌 사람의 욕구와 충돌할 수 있다는 점이 보편적으로 인식된다.

이로 인해, 규범적 의무(obligations)와 행위의무(duties)는 통상 희생(sacrifice) 또는 욕망의 절제(renunciation)를 수반하는 것으로 여겨지며, 모든 사회에서 의무와 개인적 이해관계 간의 잠재적 충돌 가능성은 법률가와 도덕철학자 모두가 인식하는 상식적 전제(truism)로 자리 잡고 있다.

‘obligation(의무)’이라는 단어에 묻혀 있는 비유적 도상(figurative image)은, 의무를 지닌 자를 구속하는 끈(bond)이라는 이미지이고, ‘duty(행위의무)’에는 채무(debt)라는 유사한 개념이 잠재되어 있다. 이러한 비유는 다음의 세 가지 요소—(1) 심각한 사회적 압력, (2) 사회적 필수성, (3) 이익과 의무의 잠재적 갈등—에 의해 설명될 수 있으며, 이들은 규범적·행위적 의무 규칙을 기타 규칙들과 구분하는 기준이 된다. 이러한 이미지는 법사상 전반에 걸쳐 흔히 등장한다. 이 도상에서, 사회적 압력은 의무를 지닌 사람들을 구속하여(fetter) 그들이 원하는 행동을 자유롭게 하지 못하게 하는 사슬(chain)처럼 작용한다. 이 사슬의 다른 끝은 때로는 공동체 전체 혹은 그 공식 대표자가 쥐고 있으며, 그들은 의무 이행을 강제하거나, 불이행 시 제재를 부과한다. 때로는 이 사슬의 끝이 개별 시민에게 맡겨져 있어, 그가 의무 이행이나 그에 상응하는 대가를 요구할지 말지를 선택할 수 있도록 되어 있다. 전자의 경우는 형사법(criminal law)상의 의무를, 후자의 경우는 민사법(civil law)상의 의무를 대표하며, 이때 우리는 일반적으로 (p. 88) 사인(private individuals)이 권리(rights)를 가지고 있으며 그것이 타인의 의무에 상응(correlative)한다고 여긴다.

이러한 비유는 자연스럽고 때로는 통찰력을 제공할 수 있지만, 우리가 다음과 같은 오해에 빠지지 않도록 주의해야 한다: 끈, 의무의 본질이란 의무를 지닌 사람이 느끼는 강제감(compulsion)이나 압박감(pressure)이라는 잘못된 개념이다. 규범적 의무 규칙은 일반적으로 강한 사회적 압력에 의해 지지되지만, 그렇다고 해서 어떤 규칙 하에서 규범적 의무를 지닌다는 것이 곧 그 사람이 압박을 느낀다는 것과 동일한 것은 아니다. 따라서 어떤 강성의 사기범(hardened swindler)에 대해 “그는 월세를 낼 규범적 의무를 지니고 있었지만 아무런 압박도 느끼지 않은 채 도망쳤다”고 말하는 것은 모순이 아니다. 그리고 실제로 그런 경우는 자주 있다. ‘의무감을 느낀다(feel obliged)’는 것과 ‘규범적 의무를 지닌다(have an obligation)’는 것은 서로 다른 것이며, 비록 자주 함께

나타날 수는 있지만, 이 둘을 동일시하는 것은 제3장에서 우리가 주목했던 규칙의 내적 측면(the internal aspect of rules)을 심리적 감정(psychological feelings)의 용어로 잘못 해석하는 것이다.

실제로, 규칙의 내적 측면(the internal aspect of rules)은 우리가 예측 이론(predictive theory)의 주장들을 최종적으로 해명하기 전에 반드시 다시 언급해야 할 개념이다. 왜냐하면, 이 이론의 옹호자는 다음과 같은 질문을 제기할 수 있기 때문이다. 만약 사회적 압력(social pressure)이 규범적 의무 규칙의 매우 중요한 특징이라면, 왜 우리는 이 예측 이론의 부적절성(inadequacy)을 그렇게 강조하려 하는가? 이 이론은 오히려 그 특징을 중심에 두고, 의무(obligation)를 특정한 행위 양식에서의 이탈(deviation)에 대해 예고된 처벌(threatened punishment)이나 적대적 반응(hostile reaction)이 뒤따를 가능성(likelihood)로 정의하고 있기 때문이다. 의무 진술(statement of obligation)을, 이탈에 대한 적대적 반응이 나타날 가능성에 대한 예측 또는 평가(prediction or assessment of chances)로 분석하는 것과, 우리가 주장하는 바—즉, 이러한 진술이 규칙 위반이 일반적으로 적대적 반응을 불러일으키는 배경을 전제하긴 하지만, 이 진술의 고유한 용도(characteristic use)는 그것을 예측(predict)하는 것이 아니라 특정인의 사안이 해당 규칙 아래에 속함을 말하는 것이라는 주장—이 둘 사이의 차이는 사소해 보일 수도 있다. 그러나 실제로는, 이 차이는 결코 사소한 것이 아니다. 사실, 이 차이의 중요성을 파악하지 못하면 우리는 규칙의 존재가 전제하는 인간의 사고, 언어, 행위의 독자적 양식(distinctive style of human thought, speech, and action) 전체를 제대로 이해할 수 없다. 이러한 양식은 사회의 규범적 구조(normative structure)를 구성하는 핵심이기 때문이다.

다음의 대조는 ‘규칙의 내적 측면’과 (p. 89) ‘외적 측면’이라는 용어를 다시 활용하여, 이 구분이 법 개념뿐 아니라 사회 구조 전반을 이해하는 데 얼마나 중요한지를 분명히 보여줄 수 있을 것이다. 어떤 사회 집단이 특정한 행동 규칙(rules of conduct)을 가지고 있다는 사실은, 서로 밀접히 연관되면서도 성격이 다른 여러 종류의 진술(assertion)을 가능하게 한다. 즉, 어떤 사람은 이 규칙에 대해 단순한 관찰자(observer)로서—자신은 그것을 수용하지 않으면서—관여할 수도 있고, 또 어떤 사람은 그 규칙을 행동의 지침(guide to conduct)으로 사용

하는 집단의 구성원(member)으로서 관여할 수도 있다. 우리는 이 두 입장을 각각 ‘외적 관점(external point of view)’과 ‘내적 관점(internal point of view)’이라 부를 수 있다. 외적 관점에서 제시되는 진술들도 유형상 다양할 수 있다. 왜냐하면, 어떤 관찰자는 스스로 규칙을 받아들이지는 않지만, 그 집단이 그 규칙을 수용한다는 점을 진술할 수 있으며, 이는 곧 그들이(they) 내적 관점에서 해당 규칙에 어떻게 관여하고 있는지를 외부에서 언급하는 방식이기 때문이다. 그러나 그 규칙이 게임의 규칙(game rules)—예를 들어 체스나 크리켓과 같은—이든, 도덕적 규칙(moral rules)이든, 법적 규칙(legal rules)이든 간에, 우리는 선택적으로 그 집단의 내적 관점을 언급조차 하지 않는 관찰자의 입장을 취할 수도 있다. 이러한 순수한 외부 관찰자는, 규칙에 대한 동의 여부에는 관심이 없고, 다만 관찰 가능한 행동의 규칙적 반복(regularities of observable behaviour)을 기록하는 데 만족한다. 이 규칙적 반복은 규칙 준수(conformity)를 구성하는 한 요소이며, 규칙 이탈(deviations)에 대해 나타나는 적대적 반응, 비난(reproofs), 또는 처벌(punishments)이라는 또 다른 반복적 행태 역시 기록의 대상이 된다. 이러한 관찰자가 일정 시간이 지난 후, 관찰을 통해 규칙 이탈과 적대적 반응 간의 상관관계(correlation)를 확인하고, 그 결과로 집단의 일반적 행동 양식으로부터 이탈하는 경우 적대적 반응이나 처벌을 받을 가능성을 상당히 정확하게 예측하거나 그 확률을 평가할 수 있게 되는 것은 얼마든지 가능하다. 그러한 지식은, 해당 집단에 대해 많은 것을 드러낼 수 있을 뿐 아니라, 그러한 정보를 갖지 않고 집단 내에 살려는 사람이 겪게 될 불쾌한 결과(unpleasant consequences)를 피하며 그들과 함께 살아갈 수 있는 능력을 그에게 부여할 수 있다.

그러나 만일 관찰자가 이러한 극단적인 외적 관점(external point of view)에 철저히 머무르며, 그 규칙을 수용하는 집단 구성원들이 자신들의 규칙적인 행동을 어떻게 바라보는지를 전혀 설명하지 않는다면, 그는 그들의 삶을 규칙의 관점에서 기술할 수 없으며, 따라서 규칙에 의존하는 개념들, 즉 의무(obligation)나 책임(duty)의 개념을 사용할 수도 없다. 그의 기술은 오로지 관찰 가능한 행동의 규칙성(observable regularities of conduct), 예측(predictions), 확률(probabilities), 징후(signs)의 용어로만 이루어질 것이다. 이러한 관찰자에게

있어, (p. 90) 집단 구성원이 정상적인 행동에서 벗어나는 행위(deviation)를 할 경우, 그것은 그저 적대적인 반응이 뒤따를 가능성이 있다는 신호에 불과하다. 그의 관점은 마치 어떤 이가 분주한 거리에서 일정 시간 동안 교통 신호등의 작동을 관찰한 후, 신호등이 빨간불로 바뀌면 차량이 멈출 가능성이 높다고만 말하는 것과 같다. 그는 신호등을, 마치 구름이 비가 올 것이라는 징후(a sign that)인 것과 마찬가지로, 단지 사람들이 특정한 방식으로 행동할 것이라는 자연적 징후(a natural sign that)로만 취급한다. 그러나 이렇게 함으로써, 그는 자신이 관찰하고 있는 사람들의 사회적 삶의 한 전체 차원(a whole dimension of the social life)을 놓치게 된다. 왜냐하면, 그 사람들에게 있어서 빨간불은 단지 다른 사람들이 멈출 것이라는 신호가 아니라, 자신이 멈추어야 할 신호(a signal for them to stop)이며, 빨간불일 때 정지해야 한다는 행동 기준이자 의무가 되는 규칙에 따라 행동해야 할 하나의 이유(a reason)가 되기 때문이다. 이러한 사실을 언급하는 것은 그 집단이 자기 자신의 행동을 어떻게 이해하고 있는지를 기술하는 것이며, 이는 곧 내적 관점에서 본 규칙의 내적 측면(the internal aspect of rules seen from their internal point of view)에 해당한다.

외적 관점은 집단 내 특정 구성원들, 즉 그 규칙을 거부하고, 오직 그것을 위반 시 불쾌한 결과가 따를 것으로 판단할 경우에만 관심을 가지는 자들의 삶에서 규칙이 작동하는 방식을 상당히 비슷하게 재현할 수 있다. 이들 관점에서 규칙에 대한 표현은 다음과 같은 형식을 취할 것이다: “나는 그렇게 할 수밖에 없었어(I was obliged to do it)”, “만약 … 한다면, 나는 불이익을 입게 될 거야(I am likely to suffer for it if…)”, “만약 … 하면, 너는 아마 문제가 생길 거야(You will probably suffer for it if…)”, “만약 … 하면, 그들은 너에게 그렇게 할 거야(They will do that to you if…)”. 그러나 이들은 “나는 의무가 있다(I had an obligation)” 또는 “너는 의무가 있다(You have an obligation)”와 같은 표현을 사용할 필요는 없다. 이러한 표현들은 자신과 타인의 행동을 내적 관점에서 바라보는 자들에게만 필요한 표현이기 때문이다. 반면, 행동의 관찰 가능한 규칙성에만 주목하는 외적 관점은, 규칙이 어떻게 규칙으로서 사회 구성원의 삶에 작용하는지, 특히 그것이 대부분의 사회 구성원들, 즉 공무원, 법률가, 일반 시민들의 삶에서 어떤 상황에서든 사회생활의 지침(guide to conduct)으로

작동하고, 권리 주장, 요구, 인식, 비판, 처벌의 근거가 되는 방식은 재현할 수 없다. 이들에게 있어 규칙 위반이란, 단순히 적대적 반응이 따를 것이라는 예측의 근거가 아니라, 그러한 적대적 반응의 이유(reason for hostility)이다.

어떠한 특정 시점에서든, 법적 규칙이건 다른 규칙이건, 규칙에 따라 살아가는 사회의 삶은 (p. 91) 일반적으로 다음 두 부류 사이의 긴장(tension)으로 구성된다. 한편으로는 규칙을 수용하고 자발적으로 그 규칙의 유지에 협력하며, 자기 자신과 타인의 행동을 규칙의 관점에서 이해하는 자들이 있고, 다른 한편으로는 규칙을 거부하고, 그것을 단지 처벌 가능성의 징후로서만 고려하는 자들이 있다. 어떠한 법이론이든, 사실의 복잡성(complexity of the facts)에 충실하고자 한다면 반드시 이 두 관점을 모두 고려해야 하며, 어느 하나를 마치 존재하지 않는 것처럼 정의 내림으로써 제거해서는 안 된다. 아마도, 우리가 예측 이론에 대해 제기한 모든 비판을 가장 잘 요약할 수 있는 말은 다음과 같은 비판(accusation)일 것이다. 즉, 예측 이론은 의무 규칙(obligatory rules)의 내적 측면을 사실상 제거해버린다.

3. 법의 구성요소 (The Elements of Law)

물론 우리는 입법기관도, 법원도, 어떠한 종류의 공무원도 존재하지 않는 사회를 상상할 수 있다. 실제로, 원시 공동체에 관한 많은 연구들은 이러한 가능성이 단지 상상 속의 것이 아니라 실제로 실현되고 있다고 주장하며, 오직 집단이 자기 자신의 전형적 행동양식에 대해 가지는 일반적인 태도만을 사회 통제의 수단으로 삼는 사회의 삶을 상세히 묘사하고 있다. 우리는 앞서 이러한 태도를 의무 규칙(rules of obligation)의 기준으로 삼은 바 있다. 이러한 사회 구조는 흔히 ‘관습(custom)’에 기반한 것이라고 불리지만, 우리는 이 용어를 사용하지 않을 것이다. 왜냐하면 ‘관습’이라는 표현은 종종 그러한 규칙들이 매우 오래되었으며, 다른 규칙들보다 약한 사회적 압력만으로 지지되고 있다는 암시를 포함하기 때문이다. 이러한 함의를 피하기 위해 우리는 이러한 사회 구조를 일차적 의무 규칙(primary rules of obligation)의 구조라 부를 것이다. 만약 어떤 사회가 오직 이러한 일차적 규칙들에 의해서만 운영된다고 한다면, 인간 본성과 우리가

살아가는 세계에 대한 몇 가지 자명한 진리를 전제할 때, 그 사회가 유지되기 위해서는 반드시 충족되어야 할 몇 가지 조건들이 명백히 존재한다. 첫 번째 조건은, 그 규칙들 속에 반드시 어떤 형태로든 폭력, 절도, 기만의 자유로운 사용에 대한 제한(restrictions on the free use of violence, theft, and deception)이 포함되어야 한다는 것이다. 인간은 이러한 행위들에 쉽게 유혹되지만, 서로 가까이 공존하며 살아가기 위해서는 일반적으로 이를 억제해야 한다. 실제로, 우리가 알고 있는 원시 사회들에서는 항상 이러한 규칙들이 존재하며, 동시에 공동체의 삶을 위해 개인에게 다양한 긍정적 의무(positive duties)—예컨대, 서비스를 제공하거나 공공의 삶에 기여하도록 요구하는 의무—를 부과하는 여러 규칙들도 존재한다. 둘째, 이러한 사회에서도 (p. 92) 앞서 기술한 바와 같이 규칙을 수용하는 자들과, 사회적 압력에 대한 두려움이 작동할 때만 규칙을 준수하는 자들 사이에 긴장이 존재할 수 있다. 그러나 만약 그 사회가 신체적 힘이 대체로 균등한 사람들로 이루어진 느슨하게 조직된 집단이라면, 후자의 부류가 다수를 차지해서는 안 된다. 왜냐하면 그렇지 않다면 규칙을 거부하는 자들이 두려워할 사회적 압력이 너무 적기 때문이다. 이 역시 우리가 알고 있는 원시 공동체들에 의해 확인된다. 그 사회들에는 물론 이탈자(dissidents)나 범법자(malefactors)가 존재하지만, 대다수는 규칙을 내적 관점에서 수용하며 살아간다.

그러나 우리의 현재 목적에서 더 중요한 고려 사항은 다음과 같다. 오직 혈연, 공동 감정, 공동 신념에 의해 긴밀히 연결되어 있고, 안정된 환경에 놓여 있는 소규모 공동체만이 이러한 비공식 규칙(unofficial rules)의 체계 아래에서 성공적으로 살아갈 수 있다는 것은 명백하다. 이와 다른 조건들에서는, 이러한 단순한 형태의 사회 통제는 결함이 생기기 마련이며, 다양한 방식으로 보완될 필요가 있다. 우선, 그러한 사회에서 집단이 살아가는 규칙들은 하나의 체계(system)를 이루지 못하고, 단지 분리된 여러 기준들의 집합에 불과할 것이다. 이 규칙들을 서로 식별하거나 공통적으로 표시해주는 어떠한 표지도 존재하지 않을 것이며, 물론 그것들이 어떤 특정 인간 집단이 수용한 규칙들이라는 점 외에는 공통점이 없을 것이다. 이 점에서 그러한 규칙들은 우리의 예절 규칙(rules of etiquette)과 유사할 것이다. 그러므로, 만약 어떤 규칙이 실제로 무

엇인지 또는 어떤 규칙의 정확한 범위(scope)에 대해 의문이 생길 경우, 이를 해결하기 위한 절차(procedure)는 존재하지 않게 된다. 즉, 이를 위해 권위를 가진 문헌(authoritative text)이나, 그 문제에 대해 권위를 가지고 해석을 내릴 수 있는 공적인 인물(official)이 참조 대상이 될 수는 없다. 왜냐하면, 그러한 절차 자체와 문헌이나 인물을 권위 있는 것으로 인식하는 것 자체가, 의무나 책임의 규칙들과는 다른 유형의 규칙의 존재를 전제로 하기 때문이다. 여기서 말하는 의무 규칙은 가설적으로 (ex hypothesi) 집단이 갖는 유일한 규칙이다. 이러한 단순한 사회 구조에서의 결함을 우리는 불확실성(uncertainty)이라고 부를 수 있다.

두 번째 결함은 규칙들의 정적(static) 성격이다. 이러한 사회에서 규칙이 변화하는 유일한 방식은 느린 진화적 과정일 것이다. 즉, 한때 선택적으로 여겨졌던 행위 양식이 점차 습관화되거나 통상적인 것으로 되었다가 결국 의무적인 것으로 전환되거나, 반대로 한때 엄격히 제재되던 일탈이 점차 용인되고 마침내는 눈에 띄지 않게 되는 식이다. 이러한 사회에서는 기존의 (p. 93) 규칙을 폐지하거나 새로운 규칙을 도입함으로써 규칙을 의도적으로 변화시키는 수단이 존재하지 않는다. 왜냐하면 그러한 변화의 가능성 자체가, 해당 사회가 오직 그 규범적 생활을 유지하는 데 사용하는 일차적 의무 규칙(primary rules of obligation)과는 다른 종류의 규칙이 존재함을 전제하기 때문이다. 극단적인 경우에는, 이러한 규칙들이 보다 근본적인 의미에서 정태적일 수 있다. 이러한 상황은 현실의 어느 공동체에서도 완전히 실현된 적은 없을지 모르지만, 그 결함을 해결하기 위한 장치는 ‘법’의 특성을 잘 보여주므로 고려할 가치가 있다. 이러한 극단적 사례에서는, 일반 규칙들을 의도적으로 변경하는 수단이 전혀 없을 뿐 아니라, 어떤 특정한 사안에서 발생하는 의무들조차도 어떤 개인의 의도적인 선택에 의해 수정되거나 변형될 수 없다. 각 개인은 단지 일정한 행위를 하거나 하지 않을 고정된 의무(duties)를 가지며 살아간다. 실제로 이러한 의무 이행으로부터 다른 사람들이 혜택을 얻는 경우는 자주 발생할 수 있지만, 만약 오직 일차적 의무 규칙만 존재한다면, 그 의무를 면제하거나 그 이익을 다른 사람에게 이전할 수 있는 권한은 존재하지 않게 된다. 왜냐하면 이러한 면제(release)나 이전(transfer)의 작동은 일차적 규칙 하에서 개인들이 갖는 초기

지위를 변화시키는 것이며, 이런 변화가 가능하려면, 일차적 규칙과는 다른 종류의 규칙이 존재해야 하기 때문이다.

이 단순한 사회 형태의 세 번째 결함은 규칙이 유지되는 방식인 확산된 사회적 압력(diffuse social pressure)의 비효율성(inefficiency)이다. 어떤 규칙이 위반되었는지 여부를 두고 분쟁이 발생하는 것은 불가피하며, 특별한 권한을 가진 기관이 존재하지 않는 한, 이러한 분쟁은 소규모 사회를 제외하고는 끝없이 계속될 것이다. 이러한 최종적이고 권위 있는 결정(authoritative determination)의 부재는 또 다른 약점과 구분되어야 한다. 그것은 규칙 위반에 대한 처벌 또는 물리적 노력이나 강제력의 행사를 수반하는 다른 형태의 사회적 압력이 특별한 기관에 의해 집행되는 것이 아니라, 그 영향을 받는 개인들이나 공동체 전체에 맡겨진다는 점이다. 자명한 사실이지만, 위반자를 찾아내고 처벌하기 위해 조직되지 않은 집단이 들이는 시간의 낭비와, 제재의 공식 독점(monopoly of sanctions)이 부재할 때 발생할 수 있는 복수심의 불씨(vendetta)는 심각한 문제를 초래할 수 있다. 그러나 법의 역사에서 강하게 시사하는 바는, 규칙 위반 사실을 권위 있게 확정해주는 공식 기관의 부재가 (p. 94) 이보다 훨씬 더 심각한 결함이라는 점이다. 실제로 많은 사회들이 이러한 결함에 대해서는 비교적 이른 시기에 해결책을 마련해 온 반면, 앞서 언급한 다른 결함들은 그렇지 않기 때문이다.

이러한 세 가지 주요 결함에 대한 해결책은, 이 단순한 사회 구조를 일차적 의무 규칙(primary rules of obligation)만으로 운영하는 대신, 전혀 다른 유형의 규칙, 즉 이차적 규칙(secondary rules)을 보완적으로 도입하는 데 있다. 각각의 결함에 대한 해결책은 그 자체로 전(前)법적 상태(pre-legal)에서 법적 세계(legal world)로 나아가는 하나의 단계로 간주될 수 있다. 왜냐하면 이러한 각각의 해결책은 법을 구성하는 다양한 요소들을 수반하며, 이 세 가지 해결책이 모두 결합될 경우, 일차적 규칙 체계를 분명한 법 체계로 전환시킬 수 있기 때문이다. 우리는 이제 각각의 해결책을 차례로 살펴보고, 왜 법을 일차적 의무 규칙과 이차적 규칙의 결합으로 가장 명료하게 규정할 수 있는지를 설명할 것이다. 그러나 그 전에 다음과 같은 일반 사항들을 지적해두어야 한다. 이러한 해결책들은 각각, 또 일차적 규칙들과도 확실히 다른 성격의 규칙들을 도입하는 것이며, 그럼에도

불구하고 공통된 중요한 특징을 가지며 서로 다양한 방식으로 연결되어 있다. 따라서 이차적 규칙들은 모두 일차적 규칙들과는 다른 수준(level)에 존재한다고 말할 수 있는데, 왜냐하면 이차적 규칙들은 일차적 규칙과는 달리, 그들은 모두 그런 일차적 규칙들에 대한(about) 것들이기 때문이다. 일차적 규칙이 어떤 개인이 해야 하거나 하지 말아야 할 행위에 관한 것이라면, 이차적 규칙은 일차적 규칙의 존재, 도입, 폐지, 변경, 위반 사실의 확정 방식에 관한 것이다.

일차적 규칙 체계의 불확실성(uncertainty)에 대한 가장 단순한 해결책은, 우리가 ‘승인 규칙(rule of recognition)’이라 부를 규칙을 도입하는 것이다. 이 규칙은, 어떤 규칙이 특정한 성질 혹은 여러 성질을 지녔을 경우, 그 규칙이 해당 집단의 규칙으로서 사회적 압력에 의해 지지되어야 함을 결정짓는 결정적인 긍정적 징표(conclusive affirmative indication)로 받아들여질 수 있도록 한다. 이러한 승인 규칙의 존재는 실로 다양한 형태를 취할 수 있으며, 단순하거나 복잡할 수 있다. 예컨대, 많은 사회들의 초기 법체계에서 승인 규칙은 단지 권위 있는 규칙 목록이나 문서가 문서로 작성되었거나 공공 기념비에 새겨져 있다는 것에 불과할 수 있다. 물론 역사적으로 보면, 법 이전 상태에서 법의 상태로 나아가는 이러한 단계는 여러 구별 가능한 단계들로 이루어질 수 있으며, (p. 95) 그 첫 번째 단계는 기존의 비문서화된 규칙들을 기록(writing)으로 전환하는 것일 수 있다. 이는 매우 중요한 단계이긴 하나, 결정적인 단계는 아니다. 결정적인 것은, 그 기록물이나 새겨진 문구에 대한 권위의(authoritative) 인식, 즉 해당 기록물이 규칙의 존재에 대한 의문을 해결하는 적절한(proper) 수단이라는 인식이다. 이러한 인식이 있는 곳에는 가장 단순한 형태의 이차적 규칙, 즉 일차적 의무 규칙을 결정적으로 식별하기 위한 규칙이 존재한다고 할 수 있다.

발전된 법체계에서는 승인 규칙(rules of recognition)이 당연히 더 복잡하다. 규칙을 식별할 때 단지 특정한 문서나 목록을 참조하는 데 그치지 않고, 일차적 규칙이 갖는 어떤 일반적 특성을 기준으로 한다. 예컨대, 특정한 기관에 의해 제정되었다는 사실, 장기간에 걸친 관습적 실행, 혹은 판결과의 연관성 등이 그 기준이 될 수 있다. 더 나아가, 이러한 일반적 특성이 둘 이상 규칙의 인식 기준으로 작용할 경우, 이들 사이의 충돌 가능성을 고려하여 우선순위의 체계가

마련되기도 한다. 예컨대, 관습이나 선례가 제정법(statute)에 종속된다고 간주되며, 제정법은 ‘상위의 법원(source)’으로 간주된다. 이와 같은 복잡성은 현대 법체계에서의 승인 규칙이 단순히 권위 있는 문서를 수용하는 것과는 매우 다른 것처럼 보이게 만든다. 그러나 그 가장 단순한 형태조차도 그러한 규칙은 법의 특징적 요소들을 많이 포함하고 있다. 즉, 권위 있는 징표(authoritative mark)를 제공함으로써, 초보적인 형태로나마 법체계라는 개념을 도입한다. 이제 규칙들은 단지 분리되고 연결되지 않은 집합이 아니라, 단순하지만 통일된 체계를 구성하게 된다. 또한, 특정한 규칙이 권위 있는 규칙 목록에 등재되어 있다는 속성을 가진 것으로 식별되는 단순한 행위를 통해, 우리는 법적 유효성이라는 개념의 싹(germ)을 볼 수 있다.

일차 규칙 체계의 정적(static) 속성에 대한 해결책은 우리가 ‘변경의 규칙(rules of change)’이라고 부를 규칙의 도입이다. 이러한 규칙의 가장 단순한 형태는, 어떤 개인 또는 개인들의 집단에게 새로운 일차적 규칙을 도입하거나 기존의 규칙을 폐지할 수 있는 권한을 부여하는 것이다. 이미 제4장에서 주장했듯이, 입법의 제정이나 폐지를 이해할 때에는 단순히 위협에 의해 뒷받침된 명령의 개념이 아니라, 이와 같은 변경 규칙의 개념으로 이해해야 한다. 이러한 (p. 96) 변경 규칙들은 단순할 수도, 복잡할 수도 있다. 부여되는 권한은 제한 없이 광범위할 수도 있고, 다양한 방식으로 제한될 수도 있다. 또한, 이러한 규칙은 입법권을 행사할 자를 특정할 뿐 아니라, 입법 시 따라야 할 절차를 더 엄격하거나 유연하게 정의할 수도 있다. 이 변경 규칙과 승인 규칙 사이에는 매우 긴밀한 연관성이 있음이 명백하다. 변경 규칙이 존재하는 경우, 승인 규칙은 반드시 입법을 규칙 식별의 기준으로 포함하게 되지만, 입법 절차의 모든 세부 사항을 포함해야 하는 것은 아니다. 통상적으로는 공식 증명서나 공인된 사본이 정당한 제정이 이루어졌다는 충분한 증거로 간주된다. 물론, 만약 어떤 사회 구조가 너무 단순해서 법의 유일한 ‘원천(source)’이 입법뿐이라면, 승인 규칙은 단순히 제정 행위(enactment) 자체를 규칙의 유일한 식별 기준 또는 유효성의 기준으로 명시할 것이다. 이는 제4장에서 묘사된 가상 왕국 Rex I의 사례에서 볼 수 있다. 그곳에서의 승인 규칙은 단순히 “Rex I가 제정한 것은 모두 법이다”라는 것이다.

우리는 이미 일차적 규칙 하에서 개인들이 갖는 초기 지위(initial positions)를 변경할 수 있도록 개인에게 권한을 부여하는 규칙들—즉, 사적 권한 부여 규칙들—에 대해 어느 정도 상세히 설명한 바 있다. 이러한 규칙이 없다면, 사회는 법이 부여하는 주요 편익들 중 일부를 상실하게 된다. 이 규칙들이 가능하게 하는 행위는 유언, 계약, 재산의 이전 등이며, 이들은 자발적으로 형성되는 권리와 의무의 구조로서, 법 하의 삶을 대표하는 제도들이다. 물론, 약속이라는 도덕적 제도 역시 이러한 기초적인 형태의 권한 부여 규칙에 의해 뒷받침된다. 이러한 규칙들과 입법 개념에 포함된 변경 규칙들 사이의 유사성은 명확하다. Kelsen과 같은 최근의 이론들이 보여주듯이, 계약 체결이나 재산 이전 행위를 ‘개인이 행사하는 제한된 입법 권한의 실행’으로 간주함으로써, 계약 또는 재산 제도에서 우리가 경험하는 많은 혼란스러운 특징들이 명료해질 수 있다.

일차적 규칙 체계의 비효율성(inefficiency)을 해결하기 위한 세 번째 보완수단은, 특정한 경우에 일차적 규칙이 위반되었는지 여부를 권위 있게 결정할 수 있는 권한을 개인에게 부여하는 이차적 규칙들이다. (p. 97) 이 최소한의 형태의 판결(adjudication)은, 바로 이러한 결정 행위를 말하며, 이 권한을 부여하는 이차 규칙들을 우리는 ‘판결 규칙(rules of adjudication)’이라 부를 것이다. 이러한 판결 규칙은 누가 판결할 것인지를 식별할 뿐 아니라, 어떤 절차를 따라야 하는지도 정의한다. 다른 이차 규칙들과 마찬가지로, 이 규칙들 역시 일차적 규칙과는 다른 수준에 존재한다. 물론, 판결자에게 판결 의무를 부과하는 추가 규칙들에 의해 보강될 수는 있지만, 이 규칙들 자체는 의무를 부과하는 것이 아니라, 판결 권한(judicial powers)과 판결에 대한 특별한 지위(special status)를 부여한다. 다시 말해, 이러한 규칙은 다른 이차 규칙들과 마찬가지로, 법관, 법원, 관할권(jurisdiction), 판결(judgment)과 같은 중요한 법 개념들을 정의한다. 이러한 유사성 외에도, 판결 규칙은 다른 이차 규칙들과 긴밀한 연결성을 가진다. 실제로 판결 규칙을 가진 체계는 필연적으로 기본적인 수준에서라도 승인 규칙을 수반하게 된다. 왜냐하면, 법원이 어떤 규칙이 위반되었는지를 권위 있게 판단할 수 있다면, 그 판단은 해당 규칙이 무엇인지에 대한 권위 있는 판단이기도 하기 때문이다. 따라서 관할권을 부여하는 규칙은 승인 규칙이기도 하며, 법원의 판결을 통해 일차 규칙을 식별하게 되고, 그러한 판결들은 결국

‘법의 원천(source)’이 된다. 물론, 이러한 형태의 승인 규칙은 기본적으로 불완전한 것이다. 권위 있는 문서나 법령집처럼 일반화된 용어로 작성되지 않을 수 있으며, 규칙을 식별하는 권위 있는 지침으로서의 활용은 개별 판결로부터 일반 규칙을 도출하는 불안정한 추론에 의존하게 된다. 이때 그 신뢰성은 해석자의 역량이나 판사들의 일관성에 따라 달라질 수밖에 없다.

사실상 거의 모든 법체제에서 사법 권한(judicial powers)은 일차 규칙 위반 여부에 대한 권위 있는 사실판단(authoritative determinations)으로만 제한되지 않는다. 대부분의 법체제는 일정한 시간이 지난 후, 사회적 압력을 더 중앙집중화함으로써 생기는 이점을 인식하게 되었으며, 개인에 의한 물리적 처벌이나 폭력적 자력구제(self-help)의 사용을 부분적으로 금지하였다. 대신, 그들은 일차적 의무 규칙(primary rules of obligation)을 추가적인 이차 규칙들로 보완하여, 위반에 대한 처벌을 명시하거나 적어도 제한하였고, (p. 98) 위반 사실이 확인된 경우에는 판사에게 다른 공무원들에 의해 처벌이 적용되도록 지시할 수 있는 독점적 권한을 부여하였다. 이와 같은 이차 규칙들은 그 체계의 공식적인 중앙 ‘제재(sanctions)’ 수단을 제공한다.

이제 우리는 의무를 규정하는 일차 규칙과 인식, 변경, 판결에 관한 이차 규칙들이 결합하여 형성한 구조 전체를 조망해볼 수 있다. 이 구조는 단지 법체제의 핵심일 뿐만 아니라, 법학자나 정치이론가를 혼란스럽게 해온 많은 문제들을 분석하기 위한 가장 강력한 도구이기도 하다.

법률가가 전문적으로 다루는 의무, 권리, 유효성(validity), 법의 원천(source of law), 입법(legislation), 관할권(jurisdiction), 제재(sanction)와 같은 명확히 법적인 개념들은 이 구조의 요소들로 가장 잘 해명될 수 있다. 뿐만 아니라 법과 정치이론의 경계를 가로지르는 개념들—국가(state), 권위(authority), 공무원(official)의 개념—도 이와 같은 분석이 있어야 그 여전히 남아 있는 개념적 불투명성이 제거될 수 있다. 이처럼 일차 및 이차 규칙의 관점에서 개념들을 분석하는 방식이 강력한 설명력을 가지는 이유는 어렵지 않게 찾을 수 있다. 법적 및 정치적 개념을 둘러싼 모호성과 왜곡의 대부분은, 우리가 ‘내부적 관점(the internal point of view)’이라 불려온 것에 대한 참조가 본질적으로 요구된다는 사실을 간과한 데서 비롯된다. 이 관점은 단순히 규칙에 부합하는 행위를 기록

하거나 예측하는 것에 머무르지 않고, 자신과 타인의 행위를 평가하는 기준으로 규칙을 사용하는(use) 사람들의 관점이다. 이 관점은 통상적인 분석보다 훨씬 더 세심한 주의를 요한다. 일차 규칙만으로 구성된 단순한 체계에서는, 내부적 관점은 가장 단순한 형태로 나타난다. 즉, 규칙은 비판의 근거로 사용되며, 규칙 준수에 대한 요구, 사회적 압력, 그리고 처벌을 정당화하는 토대로 기능한다. 의무(obligation)와 책임(duty)이라는 기본 개념의 분석에는 이와 같은 내부 관점의 가장 기초적인 표현에 대한 언급이 필수적이다. 그러나 여기에 이차 규칙이 추가되면, 내부적 관점에서 행해지는 언사와 행위의 범위는 훨씬 더 확장되고 다양화된다. 이 확장과 함께 입법, 관할권, 유효성, 그리고 공적·사적 법적 권한(legal powers) 등의 새로운 개념들이 등장하며, 이 개념들 또한 내부적 관점을 참조하지 않고는 해명될 수 없다. (p. 99) 이들 개념은 항상 일상적이거나 ‘과학적’인 사실 진술 또는 예측 담론으로 환원하려는 유혹에 노출된다. 하지만 그렇게 되면 이들 개념의 외부적 측면만을 재현할 수 있을 뿐이다. 이들의 고유한 내부적 측면을 제대로 이해하기 위해서는, 입법자(legislator)의 법제 행위, 법원의 판결(adjudication), 사적이거나 공적인 권한의 행사, 그리고 기타 ‘법 속의 행위(acts-in-the-law)’들이 이차 규칙과 어떻게 관련되는지를 파악해야 한다.

다음 장에서는, 법의 유효성(validity)과 법의 원천(source of law)이라는 개념들, 그리고 주권 이론(doctrines of sovereignty)에 내포된 오류 속에 잠재된 진리들이 승인 규칙(recognition rules)의 관점에서 어떻게 재정식화되고 명료화될 수 있는지를 살펴볼 것이다. 그러나 이 장을 마무리하면서 하나의 경고를 덧붙이고자 한다. 비록 일차 규칙과 이차 규칙의 결합이 법의 여러 측면을 설명하는 데 있어 중심적인 위치를 차지하며 그럴 만한 충분한 자격이 있지만, 이것만으로 법의 모든 문제를 밝힐 수는 없다. 일차 및 이차 규칙의 통합은 법체계의 중심부에 위치하지만, 그 자체가 전체는 아니며, 우리가 중심에서 벗어나 주변부로 나아갈 때에는, 이후 장들에서 제시될 다른 성격의 요소들을 수용할 필요가 있다.

CHAPTER V 주석

83쪽. 위협된 해악의 가능성으로서의 의무(*obligation*). ‘예측적(predictive)’ 분석으로서의 의무 개념에 대해서는 다음을 보라: 오스틴(Austin), *The Province* 제1강, 15-24쪽, 및 *The Lectures* 제22강; 벤담(Bentham), *A Fragment on Government* 제5장, 특히 제6절 및 그에 대한 주석; 홀스(Holmes), *The Path of the Law*. 오스틴의 분석에 대한 비판으로는 Hart, 「Legal and Moral Obligation」 (*Essays in Moral Philosophy*, 편집: Melden) 참조. 일반적인 의무 개념에 대해서는 Nowell-Smith, *Ethics* (1954), 제14장 참조.

87쪽. 의무와 ‘법적 유대(*vinculum juris*)’의 형상. A. H. Campbell, *The Structure of Stairs Institute* (Glasgow, 1954), 31쪽 참조. ‘의무(duty)’는 프랑스어 *devoir*를 통해 라틴어 *debitum*에서 유래하였다. 따라서 이 개념에는 채무(debt)의 잠재적 의미가 내포되어 있다.

88쪽. 의무와 강제성(*compulsion*)에 대한 감정. 로스(Ross)는 유효성(validity) 개념을 두 요소—즉 규칙의 효력(effectiveness)과 “그 규칙이 동기를 부여하는 방식, 즉 사회적 구속력(socially binding)을 갖는 방식”—으로 분석한다. 이는 의무 개념을 경험된 행동 패턴에 수반되는 정신적 경험이라는 관점에서 분석하는 것이다. 이에 대해서는 Ross, *On Law and Justice*, 제1, 2장을 비롯하여 *Kritik der sogenannten praktischen Erkenntniss* (1933), 280쪽 참조. 의무 개념과 감정과의 관계에 대한 상세한 논의는 Hägerström, *Inquiries into the Nature of Law and Morals*, 127-200쪽 참조. 이에 대한 논평으로는 Broad, 「Hägerström’s Account of Sense of Duty and Certain Allied Experiences」, *Philosophy* 제26권 (1951); Hart, 「Scandinavian Realism」, *Cambridge Law Journal* (1959), 236-240쪽 참조.

86쪽. 규칙의 내부적 측면(*internal aspect of rules*). 관찰자의 외부적 예측 관점과 규칙을 수용하고 이를 지침으로 삼는 자들의 내부적 관점 간의 대조는, 비록 이와 같은 용어를 사용하지는 않았지만, Dickinson, 「Legal Rules. Their Function in the Process of Decision」, *University of Pennsylvania Law Review* 제79권, 833쪽 (1931)에서 언급된다. 또한 L. J. Cohen, *The Principles of World Citizenship* (1954), 제3장 참조. 외부 관점, 즉 관찰자가 자신이 관찰하는 사회의 규칙을 수용하지 않을 때 취하게 되는 입장에서, 다음과 같은 여러 유형의 진술이 가능하다는 점에 주목할 필요가 있다: (i) 그는 규칙을 따르는 이들의 행동 양식을 단지 습관으로서 기록할 수 있으며, 이 행동 양식이 사회 구성원들에게 정당한 행위 기준으로 간주된다는 점은 언급하지 않을 수 있다. (ii) 그는 또한 그러한 전형적인 행동 양식에서 벗어나는 행위에 대해 통상적으로 나타나는 적대적 반응을 습관으로 기록할 수 있으며, 이런 반응이 해당 사회의 구성원들에게

정당한 반응(reason or justification)으로 간주된다는 점은 생략할 수 있다. (iii) 그는 그러한 관찰 가능한 행동 및 반응의 규칙성과 더불어, 사회 구성원들이 어떤 규칙들을 행위 기준으로 수용하고 있다는 사실도 기록할 수 있으며, 나아가 그들이 보이는 행위 및 반응들이 그 규칙에 의해 요구되거나 정당화된다고 인식된다는 사실까지도 기술할 수 있다. 여기서 중요한 것은, 사회 구성원들이 어떤 규칙을 수용하고 있다는 사실을 진술하는 외부적 진술과 그 규칙을 자신이 수용하는 입장에서 진술하는 내부적 진술을 구별하는 것이다. 참고문헌: Wedberg, 「Some Problems on the Logical Analysis of Legal Science」, *Theoria* 제17권 (1951); Hart, 「Theory and Definition in Jurisprudence」, *Proceedings of the Aristotelian Society* 보충집 제29권 (1955), 247-250쪽. 또한 제6장 제1절, 102-105쪽 및 109-110쪽 참조.

91쪽. 원시 공동체에서의 관습규칙(*Customary rules*). 입법기관과 재판기관, 그리고 중앙집중적으로 조직된 제재(sanction) 체계가 전혀 존재하지 않았던 사회는 극히 드물다. 이와 같은 상태에 가장 근접한 사례에 대한 연구로는 다음을 참조하라: Malinowski, *Crime and Custom in Savage Society*; A. S. Diamond, *Primitive Law* (1935), 제18장; Llewellyn and Hoebel, *The Cheyenne Way* (1941).

94쪽. 조직화된 제재 없이 이루어지는 재판(*Adjudication without organized sanctions*). 결정을 강제할 수 있는 중앙집중적 제재 체계는 없지만, 분쟁 해결을 위한 기초적인 형태의 재판 절차는 존재하는 원시 사회에 대해서는 다음을 참조하라: Evans-Pritchard, *The Nuer* (1940), 117쪽 이하에서 다루는 ‘질서 있는 무정부 상태(ordered anarchy)’, 이는 Gluckman, *The Judicial Process among the Barotse* (1955), 262쪽에 인용됨. 로마법에서는 민사 판결을 강제할 수 있는 국가 기구가 마련되기 훨씬 이전부터 정교한 소송 체계가 존재했다. 후기 제정 로마 이전까지는, 원고가 소송에서 승소하더라도 피고가 자발적으로 이행하지 않으면 원고가 스스로 피고 또는 그의 재산을 압류해야 했다. 이에 대해서는 Schulz, *Classical Roman Law*, 26쪽 참조.

94쪽. 비법적 상태에서 법적 세계로의 이행(*The step from the pre-legal into the legal world*). 이 주제에 대해서는 Baier, 「Law and Custom」, *The Moral Point of View*, 127-133쪽 참조.

94쪽. 승인 규칙(*rule of recognition*). 법체계 내에서 이 요소가 갖는 역할과 Kelsen의 기본규범(*Grundnorm*)과의 관계에 대해서는 제6장 제1절 및 제10장 제5절과 그에 대한 주석 참조.

95쪽. 규칙의 권위 있는 문헌(*authoritative texts of rules*). 전해지는 바에 따르면, 로마에서는 평민(Plebeians)이 법률의 권위 있는 문헌화를 요구한 결과, ‘12표법’이

시장 광장에 청동판으로 게시되었다고 한다. 현존하는 빈약한 증거로 보건대, 이 12 표법은 전통적 관습규칙에서 크게 벗어나지는 않았던 것으로 보인다.

96쪽. 계약, 유언 등과 같은 행위를 입법 권한의 행사로 이해하기(*Contracts, wills, &c., as the exercise of legislative powers*). 이러한 비교에 대해서는 Kelsen, *General Theory*, 136쪽에서 ‘법을 창출하는 행위(law creating act)’로서의 법률행위(legal transaction)를 다룬 논의 참조.

CHAPTER V 제3판 주석 (CHAPTER V 3rd ed. NOTES)

80-81쪽. 1차 규칙(primary rules)과 2차 규칙(secondary rules) Hart는 이 구별을 일관되지 않게 사용하여 다음과 같은 다양한 차이를 지칭한다: (a) 규범의 유형 (81쪽: 1차 규칙은 의무를 부과하고, 2차 규칙은 권한을 부여함), (b) 지배 대상 (94, 97쪽: 1차 규칙은 행위를 지배하고, 2차 규칙은 규칙을 지배함), (c) 사회적 기능 (40-41쪽: 1차 규칙은 행동을 지시하고, 2차 규칙은 제도적 수단을 제공함), (d) 중요도 (91, 235쪽: 1차 규칙은 인간 사회에 필수적이며, 2차 규칙은 유용하지만 필수는 아님), (e) 발생 순서 (91, 95쪽: 1차 규칙이 먼저 등장하고, 2차 규칙은 그 이후에 생김). 이러한 변형은 다음의 저자들에 의해 지적된 바 있다: Colin Tapper, 「Powers and Secondary Rules of Change」, A. W. B. Simpson (편), *Oxford Essays in Jurisprudence*, 248-68쪽; Neil MacCormick, H. L. A. Hart, 103-6쪽; Joseph Raz, *The Authority of Law* (Oxford University Press, 1979), 177-9쪽; P. M. S. Hacker, 「Hart's Philosophy of Law」, P. M. S. Hacker 및 Joseph Raz (편), *Law, Morality, and Society*, 19-21쪽.

82-87쪽. 의무(obligations)의 성격 Hart가 언급한 언어적 사용례(82쪽)는 의문이 제기될 수 있다. 이에 대해선 Edgar Page, 「On Being Obligated」 (1973), *Mind* 제82권, 283쪽 참조. 또한 86-87쪽의 분석은 규칙이 ‘의무를 발생시키는 것으로 여겨지는’ 상황에 대한 서술임을 유의해야 한다(87쪽, 강조 추가). 즉, 이는 정당화적 분석이 아니다. 또한 Hart에게 있어 의무를 부과하는 규칙과 그렇지 않은 규칙의 구별은 정도의 문제이다. 즉, 이는 규칙에 대한 순응을 강요하는 사회적 압력이 얼마나 강한지, 그리고 그 규칙이 얼마나 중요한 것으로 여겨지는지에 달려 있다.

Hart는 이 문제를 *Essays on Bentham* 제6장 「Legal Duty and Obligation」에서 다시 다룬다. 여기서 그는 Bentham의 입장을 검토하고 Dworkin과 Raz의 비판에 응답한다. 이 글에서 그는 법적 의무 진술은 “그 의무를 가진 행위 주체가 수행해야 하거나 부과되어야 하는 행위들을 지시하며, 이는 그들에게 정당하게 요구되거나 강제될 수 있다는 의미에서 그러하다”고 주장한다(160쪽). 이러한 주장이 그가 앞서 제시한 설명과

어떻게 연결되는지는 불분명하다.

88-91쪽. 예측 이론과 ‘외적 관점(*external point of view*)’ 법적 의무에 대한 진술은 일반적으로 이론적(즉, 행위 예측적)이 아니라 실천적(즉, 행위 지시적)을 목적으로 한다. Hart는 이러한 점을 포착하기 위해 법을 ‘의무 부과적 규칙’을 수용하는 자의 ‘내적 관점’에서 이해해야 한다고 본다(위의 56-58쪽 주석 참조). 이에 대해 Kelsen은 의무와 행위 사이의 관계를 귀속(*imputation*)이라는 *sui generis* 원칙을 통해 이해할 것을 제안한다. (*Pure Theory of Law*, Max Knight 번역, University of California Press, 1967, 75-81쪽). Raz는 이를 ‘분리된(*detached*) 법적 관점’에서 이해해야 한다고 제안한다 (*Practical Reason and Norms*, 170-177쪽). 이와 관련된 유익한 논의는 Kevin Toh, 「Raz on Detachment, Acceptance and Describability」 (2007), *Oxford Journal of Legal Studies* 제27권, 403쪽 참조.

91-98쪽. 법의 발생(*emergence of law*) 법 이전(*pre-legal*) 상태에서 법적 사회로 이행하는 Hart의 주장에 내포된 방법론적 전제를 검토한 연구로는 Neil MacCormick, *H. L. A. Hart*, 제9장 특히 106-108쪽을 참조하라. 이에 대비되는 입장은 John Finnis, *Natural Law and Natural Rights*, 제1장 특히 6-18쪽 참조. ‘단순한 사회 질서(*simple social orders*)’에서의 ‘결함(*defects*)’이라는 개념에 대해서는 이 책의 서론에서 Leslie Green이 논의한 내용을 참고하라 (xlix-1쪽).

VI. 법체계의 기초(THE FOUNDATIONS OF A LEGAL SYSTEM)

1. 승인 규칙과 법적 유효성(RULE OF RECOGNITION AND LEGAL VALIDITY)

제4장에서 비판된 이론에 따르면, 법체계의 기초는 다음과 같은 사회적 상황에 존재한다: 즉, 한 사회 집단의 다수가 위협을 수반한 주권자(sov^{er}ign)의 명령에 습관적으로 복종하고, 이 주권자(들)는 자신은 아무에게도 복종하지 않는다는 상황이다. 이 이론에서 이러한 사회적 상황은 법의 존재에 대한 필요충분조건이다. 우리는 이미 근대적 국내법 체계의 몇몇 두드러진 특징들을 설명하는 데 있어 이 이론이 무력하다는 점을 상세히 보여주었다. 그럼에도 불구하고, 이 이론이 여전히 많은 사상가들에게 영향을 끼치고 있는 사실은 이 이론이 흐릿하고 오도된 형태로나마 법의 중요한 측면들에 관한 몇몇 진리를 담고 있음을 시사한다. 그러나 이러한 진리들은, 제2차적 승인 규칙이 수용되어 의무에 관한 제1차 규칙을 식별하기 위해 사용되는 보다 복잡한 사회적 상황을 통해서만 명확히 제시될 수 있으며, 그 중요성도 올바르게 평가될 수 있다. 이러한 상황이야말로 법체계의 기초라 불릴 자격이 있는 것이다. 본 장에서는 이러한 상황의 다양한 구성 요소들을 살펴볼 것이다. 이 구성 요소들은 주권이론을 비롯한 여러 이론들 속에서 오직 부분적으로 혹은 잘못 표현된 바 있다.

이러한 승인 규칙(rule of recognition)이 수용되는 곳이라면 어디서든, 사인과 공직자 모두에게 의무를 규정하는 제1차 규칙들을 식별하기 위한 권위 있는 기준(criteria)이 제공된다. 우리가 보았듯이, 이러한 기준은 여러 형태를 취할 수 있다: 권위 있는 문헌에 대한 참조, 입법적 제정, 관습적 실천, 특정인의 일반적 선언, 혹은 특정 사례에 대한 과거의 사법 결정 등이 이에 해당한다. 제4장에서 묘사한 Rex I의 세계와 같이, 오직 그가 제정한 것만이 법이며, 그의 입법 권한에 대해 관습이나 헌법적(p. 101) 문서에 의한 제한이 전혀 없는 아주 단순한 체계에서는, 법을 식별하기 위한 유일한 기준은 단순히 Rex I의 제정

사실 그 자체일 것이다. 이러한 단순한 형태의 승인 규칙의 존재는 공직자나 사인들이 이 기준을 통해 규칙을 식별하는 일반적 실천을 통해 드러난다. 현대의 법체계처럼 법의 ‘원천(source)’이 복수인 경우, 승인 규칙은 그에 상응하여 더욱 복잡하다. 법을 식별하기 위한 기준은 다수 존재하며, 보통 성문헌법, 입법부의 제정, 그리고 선례 등을 포함한다. 대부분의 경우 이러한 기준들 간의 충돌 가능성을 고려하여 상대적 상하 관계가 설정된다. 우리의 법체계에서 ‘보통법(common law)’이 ‘제정법(statute)’에 종속되는 것도 바로 이러한 방식이다.

한 기준이 다른 기준에 대해 상대적으로 종속(subordination)되어 있다는 점과 파생(derivation)된다는 개념은 명확히 구별되어야 한다. 이 둘을 혼동함으로써, 모든 법이 본질적으로 혹은 ‘실질적으로’(심지어 ‘암묵적으로’라도) 입법의 산물이라는 견해에 잘못된 정당성이 부여되기도 한다. 우리의 법체계에서 관습과 선례는 입법에 종속되어 있다. 즉, 관습법 및 보통법 규칙들은 법률에 의해 그 법적 지위를 박탈당할 수 있다. 그러나 이 규칙들이 가지는 법적 지위(비록 그것이 불안정하더라도)는 입법 권한의 ‘암묵적’ 행사에 기인하는 것이 아니라, 이들에 대해 독립적이면서도 종속적인 위치를 부여하는 승인 규칙이 수용된 데서 비롯된 것이다. 단순한 체계의 경우와 마찬가지로, 이렇게 복잡한 승인 규칙의 존재는 그러한 기준에 따라 규칙을 식별하는 일반적 실천 속에서 나타난다.

법체계의 일상적 운영에서 승인 규칙은 규칙의 형태로 명시적으로 표현되는 경우가 드물다. 다만, 영국의 법원은 가끔 법의 한 기준이 다른 기준에 대해 가지는 상대적 위치를 일반적 용어로 언명하기도 하는데, 예컨대 의회 제정법이 다른 법원이나 법의 ‘원천’보다 우위에 있음을 선언하는 경우가 그러하다. 대부분의 경우 승인 규칙은 언명되지 않지만, 법원이나 공직자, 사인 및 그 조언자들이 구체적 규칙을 식별하는 방식 속에서 그 존재는 드러난다(shown). 물론 법원이 이러한 기준들을 사용하는 방식과 일반인이 사용하는 방식에는 차이가 있다. 법원이 특정한 규칙이 법으로서 정확히 식별되었다는 전제 하에 특정 (p. 102) 결론에 도달할 경우, 그 판단은 다른 규칙들에 의해 특별한 권위를 부여받는다. 이 점에서, 그리고 다른 많은 점에서, 법체계의 승인 규칙은 게임의 득점 규칙과 유사하다. 게임이 진행되는 동안 점수를 구성하는 활동(예:

득점, 골 등)을 규정하는 일반 규칙은 좀처럼 명시적으로 언급되지 않으며, 대신 경기자와 심판들이 승부에 영향을 미치는 각 장면을 식별하는 데 그것을 사용(use)한다. 이 경우에도 심판(umpire)이나 득점 집계자(scorer)의 선언은 다른 규칙들에 의해 특별한 권위를 가진 것으로 간주된다. 더 나아가, 양 경우 모두 이러한 권위 있는 규칙 적용과, 해당 규칙의 명백한 의미에 대한 일반적 이해 사이에 충돌이 발생할 수 있다. 우리가 뒤에서 살펴보겠지만, 이러한 복잡성은 이와 같은 종류의 규칙 체계가 존재한다는 것이 무엇을 의미하는지를 설명하는 모든 이론에서 반드시 다루어져야 할 문제이다.

이처럼 법원의 판결이나 다른 주체들에 의한 구체적 규칙의 식별에 있어 명시되지 않은 승인 규칙이 사용된다는 점은 내적 관점(internal point of view)의 특징이다. 그러한 방식으로 규칙을 사용하는 사람들은, 그것들을 행위 지침으로서 받아들이는 자신들의 태도를 드러낸다. 그리고 이러한 태도와 함께, 외적 관점에서 자연스럽게 사용되는 표현과는 다른 특유의 어휘가 수반된다. 아마도 가장 단순한 예는 “~은 법이다(It is the law that ~)”라는 표현일 것이다. 이 표현은 단지 법관들만이 아니라, 법체계 아래에서 살아가는 일반 시민들조차 어떤 특정 규칙을 법체계의 일부로 식별할 때 사용한다. 이 표현은 “아웃(Out)”이나 “골(Goal)”이라는 말처럼, 어떤 상황을 판단함에 있어 그 목적에 적합하다고 인식된 규칙을 다른 이들과 함께 공유하고 있음을 드러내는 언어이다. 이러한 규칙의 공유적 수용이라는 태도는, 단지 어떤 사회 집단이 특정 규칙을 수용하고 있다고 외부에서(ab extra) 기록(record)할 뿐, 자신은 그것을 수용하지 않는 관찰자의 태도와는 대조된다. 외적 관점의 자연스러운 표현은 “~은 법이다(It is the law that ~)”가 아니라, “영국에서는 의회가 제정하는 모든 것을 법으로 인식한다(In England they recognize as law ... whatever the Queen in Parliament enacts)”이다. 우리는 전자를 내적 진술(internal statement)이라고 부를 것이다. 왜냐하면 이것은 내적 관점을 드러내며, 승인 규칙이 수용되고 있다는 사실을 진술하지 않으면서도 이를 적용하여 특정 규칙을 유효한 것으로 식별하는 이가 사용하는 자연스러운 언어이기 때문이다. (p. 103) 반면, 후자는 외적 진술(external statement)이라 부르며, 이는 승인 규칙을 자신은 수용하지 않지만 다른 이들이 수용하고 있다는 사실을 진술하는 외부 관찰자의 자연스러

운 언어이다.

이처럼 수용된 승인 규칙(rule of recognition)을 사용하여 내적 진술(internal statements)을 행하는 것이, 그 규칙이 수용되었다는 외적 사실 진술(external statement of fact)과 명확히 구별되어 이해된다면, 법적 ‘유효성(validity)’ 개념과 관련된 많은 혼란은 사라진다. 왜냐하면 ‘유효(valid)’라는 단어는—항상은 아니지만—대부분 바로 이와 같은 내적 진술 속에서 사용되기 때문이다. 즉, 그것은 어떤 특정 규칙에 대해, 명시되지는 않았지만 수용된 승인 규칙을 적용하여, 그 규칙이 법체계의 일부임을 인식하는 방식이다. 어떤 규칙이 유효하다고 말하는 것은, 그것이 승인 규칙이 제공하는 모든 기준을 통과했으며, 따라서 해당 법체계의 규칙이라는 점을 인식하는 것이다. 실제로 우리는 “특정 규칙이 유효하다고 말하는 것”은 “그 규칙이 승인 규칙이 제공하는 모든 기준을 충족시킨다는 것”을 의미한다고 간단히 말할 수 있다. 이 설명이 부정확한 것은, 그러한 진술의 내적 성격(internal character)을 흐릴 수 있다는 점에서만이다. 즉, 크리켓 선수의 “아웃(Out)”이라는 말처럼, 이러한 유효성 진술은 일반적으로 말하는 사람과 그 외 다른 사람들이 수용한 승인 규칙을 특정 사안에 적용하는 것이며, 그것이 충족되었다고 명시적으로 진술하는 것은 아니다.

법적 유효성 개념과 관련된 몇몇 혼란들은 유효성과 법의 ‘실효성(efficacy)’ 사이의 관계와 관련되어 있다고 말해진다. 만약 ‘실효성’이란 개념이, “특정 행동을 요구하는 법 규칙이 대부분의 경우 준수된다”는 사실을 의미한다면, 특정 규칙의 유효성과 그 규칙의(its) 실효성 사이에는 필연적 연결이 없다는 것이 명백하다. 다만, 해당 법체계의 승인 규칙 자체가, 어떤 규칙이 오랫동안 실효성을 상실했을 경우 그것은 더 이상 법체계의 규칙으로 간주되지 않는다는 조항(종종 ‘폐기 규칙(rule of obsolescence)’이라 불림)을 포함하고 있는 경우는 예외다.

특정 규칙의 실효성 결여는, 그것이 유효성 판단에 영향을 줄 수도 있고 그렇지 않을 수도 있다는 점에서 구별되어야 한다. 우리는 전체 법체계의 규칙들에 대한 전반적인 무시(disdain)와 구별해야 한다. 이러한 무시는 너무나 전면적이고 장기간에 걸친 것일 수 있어서, 새로운 체계의 경우에는 해당 체계가 그 집단의 법체계로서 결코 성립된 적이 없었다고 말할 수 있고, 한때

성립되었던 체계의 경우에는 그것이 해당 집단의 법체계로서 더 이상 존재하지 않는다고 말하게 된다. 이 두 경우 모두, 체계의 규칙을 기준으로 (p. 104) 내적 진술을 행하는 데 필요한 일반적 맥락이나 배경이 결여된다. 이러한 경우, 특정 인물의 권리와 의무를 해당 법체계의 제1차 규칙에 따라 판단하거나, 해당 체계의 승인 규칙에 따라 어떤 규칙의 유효성을 평가하는 일은 전반적으로 무의미(pointless)하다. 결코 실제로 작동된 적이 없거나, 이미 폐기된 규칙 체계를 억지로 적용하려는 것은, 아래에서 언급할 특별한 상황이 아닌 한, 결코 수용된 적이 없거나 이미 폐기된 게임의 득점 규칙을 기준으로 경기의 진척 상황을 평가하려는 것만큼이나 헛된 일이다.

특정 규칙의 유효성에 관한 내적 진술을 행하는 자는, 해당 법체계가 전반적으로 실효적이라는 외적 사실 진술(external statement of fact)의 진실성을 전제한다(presuppose)고 말할 수 있다. 왜냐하면 내적 진술의 통상적 사용은 이러한 일반 실효성의 맥락에서 이루어지기 때문이다. 그러나 유효성 진술이 “그 법체계가 일반적으로 실효적이라는 것”을 의미한다고 말하는 것은 옳지 않다. 왜냐하면, 어떤 법체계가 결코 성립된 적이 없거나 이미 폐기된 상태라면, 해당 체계의 규칙이 유효하다고 말하는 것은 보통은 무의미하거나 공허한 행위 이긴 하지만, 그렇다고 해서 그러한 유효성 진술이 의미 없는 것은 아니며, 항상 무의미한 것도 아니기 때문이다. 로마법(Roman Law)을 가르치는 한 생생한 방식은 그 체계가 아직도 실효적인 것처럼(as if) 말하면서, 특정 규칙의 유효성에 대해 논하고 문제를 그 기준에 따라 해결하는 것이다. 또한, 혁명에 의해 파괴된 옛 사회질서를 회복하려는 희망을 간직하고 새로운 질서를 거부하려는 이들이 취하는 한 방식은, 옛 체제의 법적 유효성 기준을 고수하는 것이다. 이는, 예컨대 러시아의 구체제를 지지하던 백계 러시아인(White Russian)이, 황제정 러시아(Tsarist Russia) 하에서 유효했던 상속 규칙(rule of descent)을 근거로 여전히 자신의 재산권을 주장하는 행위 속에 묵시적으로 드러나 있다.

어떤 법체계의 특정 규칙이 유효하다는 내적 진술(internal statement)과, 그 법체계가 전반적으로 실효적이라는 외적 사실 진술(external statement of fact) 사이의 통상적인 문맥적 연결을 이해하면, “어떤 규칙이 유효하다고 주장하는 것은 그것이 법원이나 다른 공적 행위에 의해 집행될 것이라고 예측하는 것이다”

라는 일반적인 이론을 올바른 관점에서 파악할 수 있게 된다. 이러한 이론은 여러 면에서 우리가 지난 장에서 검토하고 기각했던 의무에 대한 예측적 분석(predictive analysis of obligation)과 유사하다. 두 경우 모두에서, 이러한 예측적 이론을 제시하는 동기는 다음과 같은 확신 때문이다. 즉, 그렇게 하지 않으면 형이상학적 해석(metaphysical interpretation)을 피할 수 없으며, 유효성에 관한 진술은 반드시 경험적 수단으로는 탐지할 수 없는 신비한 속성을 (p. 105) 부여하는 것이 되거나, 아니면 단지 공적 행위자들의 미래 행동에 대한 예측일 수밖에 없다는 것이다. 두 경우 모두에서, 이러한 이론이 그럴듯하게 보이는 이유는 동일한 중요한 사실 때문이다. 즉, 관찰자가 기록할 수 있는 외적 사실 진술이 진실이라는 점—즉, 해당 법체계가 전반적으로 실효적이며 향후에도 계속 실효적일 가능성이 크다는 사실—은, 규칙을 수용하고 의무 또는 유효성에 관한 내적 진술을 행하는 자가 통상적으로 전제하는 바이기 때문이다. 이 둘은 분명히 매우 밀접하게 연관되어 있다. 그러나, 두 경우 모두에서 이 이론이 범하는 오류는 동일하다. 즉, 내적 진술의 고유한 성격을 무시하고 이를 공적 행위에 관한 외적 진술로 간주하는 것이다.

이 오류는 판사가 어떤 규칙이 유효하다고 진술할 때, 그 진술이 사법적 판결에서 어떻게 기능하는지를 고려하면 즉시 드러난다. 왜냐하면, 이 경우에도 판사는 해당 법체계가 전반적으로 실효적이라는 점을 전제하긴 하지만 그것을 진술하지는 않으며, 무엇보다도 그는 자신의 행동이나 타 공직자의 행동을 예측하려는 데 관심이 없다. 판사가 “이 규칙은 유효하다”고 말하는 것은, 자신의 법원이 어떤 규칙을 법으로 간주할지를 식별하기 위한 기준을 해당 규칙이 충족한다는 점을 인식하는 내적 진술(internal statement)이며, 그것은 자신의 결정에 대한, 예언(prophecy)이 아니라, 이유(reason)의 일부를 구성한다. 물론 개인이 “이 규칙은 유효하다”고 진술하는 경우에는, 그러한 진술이 예측이라는 해석이 좀 더 그럴듯하게 여겨질 수도 있다. 왜냐하면, 어떤 규칙의 유효성 혹은 무효성에 대한 비공식적인 진술이 법원의 판결과 충돌하는 경우, 그러한 진술은 철회되어야 한다고 말하는 것이 종종 타당하기 때문이다. 그러나, 우리가 제7장에서 공식적 선언과 규칙의 명확한 요구사항 사이의 이러한 충돌의 의미를 탐구할 때 보게 되겠지만, 이때 그 진술이 “잘못된(wrong) 것으로 판명되었기

때문에” 철회된다고 단정적으로 말하는 것은 독단일 수 있다. 왜냐하면, 어떤 진술을 철회해야 하는 이유는 그것이 잘못되었기 때문일 수 있지만, 잘못된 방식에는 이보다 더 다양한 방식들이 있으며, 반드시 “법원이 어떻게 말할 것인가를 잘못 예측(predicted)했기 때문”인 것은 아니기 때문이다.

다른 규칙들의 유효성을 평가하기 위한 기준들을 제공하는 승인 규칙(rule of recognition)은 중요한 의미에서 궁극적(ultimate) 규칙이다. 이 점은 우리가 곧 명확히 해설하려 한다. 그리고 통상 그렇듯이 여러 기준들이 상대적 종속성이나 우위의 서열로 정렬되어 있는 경우, 그 중 하나는 최고의(supreme) 기준이 된다. (p. 106) 승인 규칙의 궁극성(ultimacy)과 그 기준 중 하나의 최고성(supremacy)에 관한 이러한 개념들은 주의 깊게 다룰 만한 가치가 있다. 우리는 이 개념들을, 앞서 우리가 기각했던 이론—즉, 모든 법체계에는, 설령 그것이 법적 형식 너머에 숨어 있다 하더라도, 반드시 법적으로 무제한인 입법 주권자가 존재해야 한다는 이론—으로부터 분리해내는 것이 중요하다.

이 두 개념, 즉 최고의 기준(supreme criterion)과 궁극적 규칙(ultimate rule) 중에서, 전자는 정의하기가 더 쉽다. 어떤 유효성 기준 또는 법의 원천(source)이 최고의 것이라는 것은, 다른 기준에 의거하여 식별된 규칙과 충돌하더라도 여전히 그것을 근거로 식별된 규칙은 법체계의 규칙으로 인식받는 반면, 반대로 그 다른 기준들에 의거하여 식별된 규칙은 그 최고 기준에 의거하여 식별된 규칙과 충돌할 경우 법체계의 규칙으로 인식받지 못한다는 뜻이다. 우리가 이미 사용한 ‘상위(superior)’와 ‘하위(subordinate)’ 기준이라는 개념도 유사한 방식으로 비교적 설명될 수 있다. 여기서 분명한 것은, ‘상위’나 ‘최고’ 기준이라는 개념은 단지 상대적인(relative) 순위를 의미하는 것이며, 법적으로 무제한인(unlimited) 입법 권한을 함축하지 않는다는 것이다. 그럼에도 불구하고, 특히 법이론 내에서는 ‘최고(supreme)’와 ‘무제한(unlimited)’이라는 개념이 쉽게 혼동된다. 이 혼동의 한 가지 이유는, 보다 단순한 형태의 법체계에서는 ‘궁극적 승인 규칙(ultimate rule of recognition)’, ‘최고 기준(supreme criterion)’, ‘법적으로 무제한인 입법기관’이라는 개념들이 서로 수렴하는 듯이 보이기 때문이다. 예컨대, 입법기관이 어떤 헌법적 제한에도 구속되지 않고, 다른 모든 법의 원천에서 유래한 규칙들을 법적 지위를 박탈할 수 있는 권한을 가지고 있다면, 그러한

체계에서의 승인 규칙은 “해당 입법기관의 제정”이 유효성의 최고 기준이라는 내용을 포함하게 된다. 헌법 이론에 따르면, 영국(United Kingdom)이 바로 그러한 구조를 가지고 있다. 하지만, 미국(United States)과 같이, 법적으로 무제한인 입법기관이 존재하지 않는 체계에서도, 완전히 정당한 방식으로 유효성 기준의 집합을 제공하는 궁극적인 승인 규칙(ultimate rule of recognition)이 존재할 수 있다. 예를 들어, 통상의 입법기관의 입법권이 어떤 개헌 절차로도 수정할 수 없는 헌법 조항에 의해 제한되어 있다면, 설령 그 개헌권이 존재하지 않거나 일부 조항이 개정 불가능한 상태라 하더라도, 해당 체계에는 여전히 입법기관조차 무제한이 아니며, 궁극적 승인 규칙과, 그 안에 포함된 최고 기준이 존재하게 되는 것이다.

(p. 107) 승인 규칙(rule of recognition)이 법체계의 궁극적(ultimate) 규칙이라는 의미는, 매우 익숙한 법적 추론의 연쇄를 따라가 보면 가장 잘 이해할 수 있다. 어떤 제안된 규칙이 법적으로 유효한지 여부가 문제될 경우, 우리는 그 질문에 답하기 위해 다른 규칙이 제공하는 유효성 기준을 사용해야 한다. 예를 들어, “이 옥스퍼드셔 주 의회(Oxfordshire County Council)의 조례는 유효한가?”라는 질문이 제기되면, 이에 대해 “그 조례는 보건부 장관(Minister of Health)이 제정한 법령 명령(statutory order)에 따라 부여된 권한을 행사하여, 해당 절차에 따라 제정된 것이기 때문에 유효하다”고 대답할 수 있다. 이 첫 번째 단계에서, 해당 법령 명령이 그 조례의 유효성을 평가하는 기준을 제공한다. 실무상으로는 더 나아갈 필요가 없을 수도 있지만, 그럼에도 더 나아갈 여지는 항상 존재한다. 우리는 다시 법령 명령의 유효성 자체를 의문시하고, 이를 해당 장관에게 그러한 명령을 제정할 권한을 부여한 법률(statute)을 기준으로 평가할 수 있다. 마지막으로, 그 법률의 유효성에 대해서도 의문을 제기하고, “의회에서 여왕이 제정한 법률은 곧 법이다”라는 규칙을 기준으로 평가할 수 있다면, 우리는 유효성에 관한 탐구에서 마침내 멈추게 된다. 왜냐하면, 우리는 이 규칙에 도달했기 때문이다. 이 규칙은 중간 단계의 법령 명령이나 법률처럼 다른 규칙들의 유효성을 평가하는 기준을 제공하지만, 그들과는 달리 자신의 유효성을 평가하는 기준이 되는 다른 규칙은 존재하지 않는다.

물론 이 궁극 규칙(ultimate rule)에 대해서도 제기할 수 있는 질문들은 많다.

예컨대, “영국에서 법원, 입법기관, 공직자 또는 일반 시민들의 실천이 실제로 이 규칙을 궁극적 승인 규칙으로 사용하고 있는가?” 혹은 “지금까지 우리가 해 온 법적 추론은 이제는 폐기된 어떤 체계의 유효성 기준에 기반한 무의미한 놀이였는가?”와 같은 질문이 가능하다. 우리는 또한 이러한 규칙을 기초로 삼는 법체계가 만족스러운 형태인가를 물을 수도 있다. 그것은 해악보다 선을 더 많이 낳는가? 실리적인 이유에서 지지할 만한가? 도덕적으로 지지해야 할 의무가 있는가? 이러한 질문들은 분명히 매우 중요하다. 그러나 이처럼 승인 규칙에 대해 묻는 경우, 우리는 더 이상 그 규칙을 이용해 다른 규칙들의 유효성을 평가할 때처럼 동일한 종류의 질문을 하고 있는 것이 아니다. 우리가 어떤 특정 제정법(enactment)이 유효하다고 말하면서 “의회에서 여왕이 제정한 것은 법이다”라는 규칙을 충족했기 때문이라고 말할 때와, “영국에서는 이 마지막 규칙이 법원, 공직자, 일반인들에 의해 궁극적 승인 규칙으로 사용된다”고 말할 때 사이에는 차이가 있는데, (p. 108) 우리는 전자의 경우, 체계 내 규칙의 유효성을 진술하는 내적 진술(internal statement)을 하고 있는 반면, 후자의 경우에는 그 체계를 받아들이지 않더라도 체계의 관찰자가 할 수 있는 외적 사실 진술(external statement of fact)로 전환한 것이다. 마찬가지로, 어떤 제정법이 유효하다고 말하는 것에서 출발하여 “그 체계의 승인 규칙은 훌륭하며, 그 규칙에 기초한 체계는 지지할 가치가 있다”고 말하게 되면, 우리는 유효성에 관한 진술에서 가치 판단의 진술(statement of value)로 옮겨간 것이다.

일부 학자들은 승인 규칙의 법적 궁극성을 강조하며, 이것을 다음과 같이 표현하기도 한다. 즉, 체계 내 다른 규칙들의 유효성은 승인 규칙을 기준으로 입증(demonstrated)될 수 있지만, 승인 규칙 자체의 유효성은 입증될 수 없고 단지 ‘가정되거나(postulated)’, ‘전제되거나(assumed)’, 또는 하나의 ‘가설(hypothesis)’일 뿐이라는 것이다. 그러나 이러한 표현은 심각하게 오해를 불러일으킬 수 있다. 일상적인 법체계에서 판사, 변호사, 일반 시민이 특정 규칙에 대해 법적 유효성을 진술할 때, 그 진술에는 실제로 일정한 전제가 담겨 있다. 그들은 체계의 승인 규칙을 수용하는 자의 관점에서 내린 법에 대한 내적 진술(internal statement of law)을 하고 있으며, 그 진술 속에는 해당 체계에 대한 외적 사실 진술로 표현될 수 있는 많은 것들이 생략되어 있다. 그렇게 생략된

것들이 곧, 법적 유효성에 관한 진술의 통상적인 배경 또는 문맥(context)을 이루며, 따라서 그것들이 해당 진술에 의해 ‘전제(presupposed)’ 된다고 말해지는 것이다. 그러나 이 전제된 것들이 정확히 무엇인지, 그리고 그 성격이 무엇인지 명확히 파악하는 것이 중요하다. 이 전제된 요소들은 두 가지로 구성된다. 첫째, 어떤 사람이 어떤 법 규칙(예컨대 특정 법률)이 유효하다고 진지하게 주장한다면, 그는 그 법률의 유효성을 판단하는 데 적절한 기준으로 받아들여지는 승인 규칙을 스스로 사용하고 있다는 것이다. 둘째, 그가 특정 법률의 유효성을 평가하기 위해 사용하고 있는 그 승인 규칙은, 단지 그 개인이 받아들인 것일 뿐만 아니라, 실제로 그 법체계의 일반적인 작동에서 법원 등 구성원들에 의해 실제로 받아들여지고 사용되고 있는 승인 규칙이어야 한다는 것이다. 만약 이 두 번째 전제의 진실성에 의문이 제기된다면, 실제 실천을 통해 이를 입증할 수 있다. 즉, 법원이 무엇을 법으로 간주하는지를 식별하는 방식과, 그러한 식별을 구성원들이 일반적으로 수용하거나 묵인하고 있는지를 살펴보면 된다.

이 두 전제 중 어느 것도, 입증할 수 없는 ‘유효성(validity)’에 대한 ‘가정(assumption)’으로 제대로 설명될 수는 없다. 우리는 ‘유효성’이라는 단어를 오직 (p. 109) 규칙 체계 내부(within)에서 어떤 규칙이 그 체계의 구성원으로서의 지위를 갖기 위해 승인 규칙(rule of recognition)에 의해 제공된 특정 기준을 충족해야 할 때, 그러한 질문에 답하기 위해서만 필요로 하며, 대체로 그러한 경우에만 사용한다. 승인 규칙 자체의 유효성에 대해서는 이러한 질문이 제기될 수 없다. 그것은 유효하거나 무효한 것이 아니라, 단지 그러한 방식으로 사용되기에 적절한 것으로 받아들여질 뿐이다. 이러한 단순한 사실을 “그 규칙의 유효성은 ‘가정되었지만 입증될 수 없다’”고 모호하게 표현하는 것은, 파리의 표준 미터 자(metre bar)가 미터 단위 측정의 최종 기준이라는 점에서, 그것 자체가 정확하다는 것을 ‘우리가 가정하지만 결코 입증할 수 없다’고 말하는 것과 같다.

보다 심각한 문제는, 궁극적인 승인 규칙의 유효성에 대한 ‘가정’이라는 표현이, 법률가들의 유효성 진술이 전제하는 두 번째 전제—즉, 사실적(factual) 성격을 가진 전제—를 은폐한다는 점이다. 물론, 승인 규칙의 실제 존재를 구성하는, 판사, 공직자, 그리고 다른 사람들의 실천(practice)은 복합적인 문제

(a complex matter)이다. 우리는 나중에 보게 되겠지만, 이러한 유형의 규칙의 구체적 내용이나 범위, 심지어 그것의 존재 자체에 대해서도 명확하거나 결정적인 답을 내릴 수 없는 경우들이 분명히 있다. 그렇다 하더라도 ‘유효성의 가정(assuming the validity)’과 ‘이러한 규칙의 존재 전제(presupposing the existence)’를 구분하는 것은 중요하다. 최소한 그 구분이 없다면, 그러한 규칙이 존재한다(exists)고 말할 때 그 말의 의미 자체가 흐려지기 때문이다.

이전 장에서 스케치한 의무적 1차 규칙(primary rules of obligation)만으로 이루어진 단순한 체계에서는, 어떤 특정 규칙이 존재한다고 말하는 것은 오직 외부 관찰자가 할 수 있는 사실 진술(external statement of fact)에 해당한다. 즉, 그는 그 규칙들을 수용하지 않으면서도, 실제로 특정한 행동양식이 일반적으로 하나의 기준으로 받아들여지고 있으며, 단순히 습관이 일치(convergent habits)하는 데서 비롯된 것이 아니라 사회 규칙(social rule)의 특징을 갖추고 있는지를 확인함으로써 입증할 수 있다. 같은 방식으로 우리는 지금도 다음과 같은 주장, 즉 “영국에는 교회에 들어갈 때 모자를 벗어야 한다는 하나의 규칙이 존재한다”는 주장(법적 규칙은 아니지만)을 해석하고 검증해야 한다. 이러한 규칙들이 특정 사회 집단의 실제 실천에서 발견된다면, 그 유효성(validity)에 대해 따로 논의할 문제는 없다. 물론 그것들의 가치나 바람직함은 문제될 수 있겠지만 말이다. 일단 그것들의 존재가 사실로써 확립되면, 그것이 유효하다는 점을 인정하거나 부인하거나, 또는 우리가 (p. 110) 그것들의 유효성을 ‘가정하지만’ 보여줄 수 없다고 말하는 것은 문제를 혼란스럽게 할 뿐이다. 그러나 한편으로, 성숙한 법체계(mature legal system)에서는 승인 규칙을 포함하는 규칙 체계가 존재하며, 이로 인해 이제 어떤 규칙이 그 체계의 일원으로서 지위를 가지는지는 승인 규칙에 의해 제공되는 특정 기준을 충족하는지 여부에 달려 있게 된다. 이 경우에는 ‘존재한다(exists)’는 표현에 새로운 의미가 부여된다. 이 경우 규칙이 존재한다는 진술은, 단순한 관습적 규칙에서처럼 어떤 행동양식이 실천에서 일반적인 기준으로 수용되고 있다는 사실(fact)에 관한 외적 진술일 필요가 없다. 이제 그것은 내적 진술(internal statement)이 될 수 있고, 명시되지는 않았지만 받아들여진 승인 규칙을 적용하는 것이며, 그 의미는 대략적으로 “그 체계의 유효성 기준에 따라 유효하다(valid)”는 것과 다르지 않다. 그러나 이러한 점에

서, 그리고 다른 많은 점에서, 승인 규칙은 그 체계의 다른 규칙들과는 다르다. 승인 규칙이 존재한다는 주장은 오직 외적 사실 진술(external statement of fact)로만 가능하다. 왜냐하면 어떤 하위 규칙은 일반적으로 무시되더라도 여전히 유효하다는 의미에서 ‘존재할 수’ 있는 반면, 승인 규칙은 법을 특정 기준에 따라 식별하는 법원, 공직자, 일반 시민의 복합적이지만 대체로 일치하는 실천(practice)으로서만 존재하기 때문이다. 승인 규칙의 존재는 사실의 문제(a matter of fact)인 것이다.

2. 새로운 질문들(New Questions)

법체계의 기초(foundations)가 법적으로 무제한인 주권자에 대한 복종 습관(habit of obedience)에 있다고 보는 관점을 버리고, 대신 규칙 체계에 유효성(validity)의 기준(criteria)을 제공하는 궁극적 승인 규칙(ultimate rule of recognition) 개념으로 대체하게 되면, 우리는 흥미롭고 중요한 질문들의 범위와 마주하게 된다. 이러한 질문들은 비교적 새로운(new) 것들인데, 그 이유는 오랫동안 법철학(jurisprudence)과 정치이론(political theory)이 구시대적인 사유방식에 얽매어 있었기 때문에, 그동안 그러한 질문들이 가려져 있었기 때문이다. 이들은 또한 어려운 질문들이며, 충분한 답변을 위해서는 한편으로는 헌법법(constitutional law)의 몇몇 근본 문제들에 대한 이해가, 다른 한편으로는 법적 형식(legal forms)이 조용히 전환되고 변화하는 특유의 방식을 파악할 수 있는 통찰이 요구된다. 따라서 우리는 이 질문들을, 우리가 해왔듯이 법 개념의 해명에서 1차 규칙(primary rules)과 2차 규칙(secondary rules)의 결합에 중심적인 위치를 부여해야 한다는 주장과 관련되는 범위 내에서만 탐구할 것이다.

(p. 111) 첫 번째 난점은 분류(classification) 문제이다. 최종적으로 법을 식별하는 데 사용되는 규칙은, 법체계를 설명하기 위해 사용되는 관행적 범주들에 잘 들어맞지 않기 때문이다. 그런데도 이러한 범주들은 종종 포괄적인 것으로 간주된다. 예컨대, Dicey 이래로 영국의 헌법학자들은 다음과 같은 설명을 반복해왔다. 즉, 영국의 헌정 체제는 부분적으로는 엄밀한 의미의 법률(laws strictly so called)—즉, 제정법(statutes), 국왕령(orders in council), 선례

(precedents)에 구현된 규칙들—로 구성되고, 부분적으로는 단순한 용례(usages), 이해(understandings), 또는 관습(customs)인 관행(conventions)들로 구성된다 고 말이다. 후자에 해당하는 관행들에는, 예컨대 “여왕은 상원과 하원을 모두 통과한 법안에 대해 거부권을 행사할 수 없다”는 규칙과 같은 중요한 내용도 포함된다. 하지만 여왕이 반드시 동의해야 할 법적 의무는 존재하지 않으며, 그러한 규칙들은 법원이 법적 의무를 부과하는 것으로 간주하지 않기 때문에 관행들로 불린다. 그러나 “여왕이 의회(Queen in Parliament)에서 제정한 것은 법이다”라는 규칙은 이러한 두 범주 중 어느 쪽에도 명확히 속하지 않는다. 그것은 관행(convention)이 아닌데, 그 이유는 법원이 이 규칙과 가장 밀접하게 관련되어 있고, 그것을 사용하여 법을 식별하기 때문이다. 또한 그것은 ‘엄밀한 의미의 법률(laws strictly so called)’과 같은 수준의 규칙도 아니다. 왜냐하면, 그것은 오히려 그러한 법들을 식별하기 위해 사용되는 규칙이기 때문이다. 비록 그것이 법률로 제정되었다 하더라도, 그 자체를 법률의 수준으로 격하시킬 수는 없다. 왜냐하면 그러한 제정의 법적 지위는 필연적으로, 그 규칙이 제정 이전부터 독립적으로 존재하고 있었음을 전제로 하기 때문이다. 더욱이, 우리가 앞 절에서 보여주었듯이, 그것의 존재는 법률(statute)과는 달리 실제의 실천(actual practice) 안에 존재해야만 한다.

이러한 양상은 일부 사람들로부터 절망의 탄식을 자아낸다. “헌법의 근본 조항들이 정말로 법이라고 할 수 있으려면, 우리는 그것들이 진정 법이라는 것을 어떻게 증명할 수 있는가?” 이에 대해 다른 이들은 다음과 같이 응답한다. “모든 법체계의 바닥에는 법이 아닌 무언가가 있다. 그것은 ‘법 이전(pre-legal)’이거나, ‘법 바깥(meta-legal)’이거나, 단지 ‘정치적 사실(political fact)’일 뿐이다.” 이러한 불안감은, 어떤 법체계에서든 가장 중요한 요소 중 하나를 설명하기 위해 사용된 분류들이 지나치게 조잡하다는 신호이다. 승인 규칙을 ‘법(law)’이라고 부를 수 있는 이유는 다음과 같다. 즉, 다른 규칙들을 식별하기 위한 기준을 제공하는 규칙은 하나의 법체계를 정의짓는 특징(defining feature)으로 여겨질 수 있으며, 그 자체도 ‘법’이라고 부를 만한 가치가 있다는 점이다. 반면 그것을 ‘사실(fact)’이라 부를 수 있는 이유는, 그러한 규칙이 존재한다고 말하는 것은 실제로 (p. 112) ‘효력을 가진(efficacious)’ 체계 안에서 규칙들이 식별되는

방식에 관한 외적 사실 진술(external statement of an actual fact)이기 때문이다. 이 두 측면은 모두 주목할 가치가 있다. 그러나 우리가 이 두 측면 중 하나의 표지(label)—‘법’이나 ‘사실’이나—를 선택하는 방식으로서는 둘 다를 공정하게 다룰 수 없다. 대신 우리는 다음의 점을 기억해야 한다. 즉, 궁극적 승인 규칙(ultimate rule of recognition)은 두 관점에서 파악될 수 있다는 점이다. 첫째, 그것이 체계의 실제 실천 안에 존재한다는 외적 사실 진술의 관점이며, 둘째, 그것을 이용해 법을 식별하는 자들이 유효성(validity)을 진술하는 내적 관점(internal statements)의 관점이다.

두 번째 질문문은 특정 국가나 사회 집단 안에 법체계가 존재한다(exists)고 주장하는 것의 숨겨진 복잡성과 모호성(vagueness)에서 비롯된다. 우리가 이러한 주장을 할 때, 실제로는 서로 이질적인 여러 사회적 사실들(heterogeneous social facts)을 함께 묶은 압축적이고 혼합적인 형태(portmanteau form)의 진술을 하고 있는 것이다. 법률 및 정치 사유의 표준 용어들(standard terminology)은 종종 오해를 불러일으키는 이론의 그림자 아래 발전되어 왔기 때문에, 사실들을 지나치게 단순화하거나 왜곡하는 경향이 있다. 그러나 이러한 용어들이 제공하는 안경(spectacles)을 벗고 사실 그 자체를 바라보면, 법체계(legal system)는 인간과 유사하게, 어떤 단계에서는 아직 태어나지 않은 상태(unborn)에 있고, 또 어떤 단계에서는 아직 모체로부터 완전히 독립하지 않은 상태(not yet wholly independent)에 있으며, 이후 건강하고 독립적인 존재(healthy independent existence)를 누리다가, 쇠퇴(decay)하고 마침내 사망(die)하기도 한다는 것이 분명해진다. 이러한 ‘출생과 정상적 독립 존재 사이’, 또는 ‘그 독립된 존재와 죽음 사이’의 중간 단계들은 우리가 익숙하게 사용하는 법 현상에 대한 설명 방식을 어긋나게 만든다(put out of joint). 그러나 이 중간 단계들은 그만큼 우리가 일상적으로 “이 국가에는 법체계가 존재한다”라고 자신 있게 말할 때, 그 말이 내포하고 있는 온전한 복잡성을 부각시키기 때문에, 혼란스러울지라도 연구할 가치가 있다.

이 복잡성을 인식하는 한 가지 방법은, 법체계가 존재하기 위해 사회가 충족해야 할 최소 조건들을 구성하는 복잡한 사실들과의 관계 속에서, 오스틴적 단순 공식(simple, Austinian formula), 즉 “법적 명령에 대한 일반적 복종 습관

(general habit of obedience to orders)”이 정확히 어디에서 실패하거나 왜곡을 일으키는지를 살펴보는 것이다. 이 공식을 일정 부분 인식하여, 그것이 하나의 필수 조건을 지시하고 있다고 받아들일 수는 있다. 즉, 법이 어떤 의무(obligations)나 임무(duties)를 부과하는 경우, 해당 법은 일반적으로 준수되어야 하며, 적어도 일반적으로 위반되어서는 안 된다는 점이다. 그러나 이것은 어디까지나 ‘법체계의 최종 산물(end product)’이라는 측면, 즉 그것이 일반 시민에게 영향을 미치는 국면에만 해당하며, 법체계의 일상적 존재는 그 외에도 다음의 국면들을 포함한다. (p. 113) 즉, 법의 공식적 제정(official creation), 법의 공식적 식별(official identification), 그리고 법의 공식적 사용 및 적용(official use and application)이다. 이러한 법과의 관계는 오직 ‘복종(obedience)’이라는 단어를 일반적인 용법을 훨씬 넘어 확장해서 사용할 경우에만 그렇게 불릴 수 있다. 그렇지 않다면, 이러한 작동들은 복종이라는 개념으로 설명될 수 없다. 예컨대, 입법자들이 자신들에게 입법 권한을 부여하는 규칙들에 따라 법을 제정할 때, 그 규칙들에 복종하고 있다고 말할 수는 없다. 단, 그 규칙들이 준수를 의무화하는 법적 규칙들에 의해 강화되고 있다면, 예외적으로 ‘복종’이라고 표현할 수도 있을 것이다. 마찬가지로, 입법자가 그러한 권한 부여 규칙을 따르지 않았다고 해서, 그가 법을 ‘위반(disobey)’한 것은 아니다. 그는 단지 법을 만들어내는 데 실패했을 뿐이다. 또한, 판사들이 체계의 승인 규칙(rule of recognition)을 적용하여 어떤 법령(statute)이 유효한 법임을 인식하고, 그것을 분쟁 해결에 활용할 때, 이러한 행위를 ‘복종(obey)’이라고 표현하는 것도 부적절하다. 물론, 우리가 원한다면 복종이라는 단순한 용어를 다양한 방식으로 조작하여 이 사실들과 함께 유지할 수도 있다. 예컨대, 판사들이 일반적 유효성 기준(general criteria of validity)을 이용하여 법령을 식별하는 행위를 “헌법 창시자들(Founders of the Constitution)”의 명령에 복종한 것으로 표현할 수도 있다. 또는 그러한 창시자들이 존재하지 않는 경우에는, “비심리화된 사령(depsychologized command)”, 즉 사령자가 없는 사령에 복종한 것으로 표현할 수도 있다. 그러나 이 마지막 표현은, 진지하게 주목할 만한 주장이라기보다는 오히려 “삼촌이 없는 조카(a nephew without an uncle)”라는 표현과 마찬가지로 부적절한 것으로 간주되어야 할 것이다. 다른 대안은 법의 공식적인 측면 전체

를 시야에서 밀어내고, 입법과 판결에서 이루어지는 규칙 사용을 모두 생략한 채, 전체 관료 세계(official world)를 한 사람—즉 ‘주권자(the sovereign)’—으로 간주하고, 그 주권자가 다양한 대리인 또는 대변인(mouthpieces)을 통해 명령을 발하고, 시민들은 이를 습관적으로 복종한다고 간주하는 것이다. 그러나 이러한 설명은, 복잡한 사실들에 대해 아직도 기술이 요구되는 것을 임시적으로 압축한 편의적인 약어 표현(convenient shorthand)이거나, 파괴적으로 혼란을 야기하는 신화적 설명(a disastrously confusing piece of mythology)일 뿐이다.

법체계가 존재한다는 것을 습관적 복종(habitual obedience)이라는 기분 좋은 만큼 단순한 개념으로 설명하려는 시도가 실패한 데 대한 반작용으로, 그 반대의 오류를 범하는 일은 자연스러운 일이다. 즉, 법과의 관계에 있어 일반 시민이 갖는 전형적인 특징(비록 항상 그것만으로는 충분히 설명되지 않지만)을 너무 좁게 보고, 이번에는 오히려 공적 활동들—특히 사법적 태도(judicial attitude)나 법에 대한 관계—에서 나타나는 전형적인 특징을 일반화하여, 그것만으로 법체계를 가진 사회집단에서 반드시 존재해야 하는 것을 (p. 114) 충분히 설명할 수 있다고 간주하는 것이다. 이러한 오류는 사회 구성원의 대다수가 법에 대해 단순히 습관적으로 복종하는 상태라는 단순한 개념을, 그들이 법의 유효성을 최종적으로 평가하는 기준을 제시하는 궁극적 승인 규칙(rule of recognition)을 일반적으로 공유하고, 받아들이며, 그것을 구속력 있는 것으로 간주한다는 개념으로 대체하는 데서 비롯된다. 물론 우리는 3장에서 살펴본 것처럼, 법의 원천을 아는 지식과 이해가 사회 전반에 널리 퍼진 단순한 사회를 상상할 수 있다. 그곳에서는 ‘헌법(constitution)’이 너무 단순해서, 일반 시민뿐 아니라 공직자와 법률가들 역시 그 헌법을 알고 있으며 받아들이고 있다고 말해도 아무런 허위가 없을 것이다. ‘렉스 1세(Rex I)’의 단순한 세계에서는, 인구 다수가 그의 말에 단순히 습관적으로 복종한 것 그 이상이 있었다고 말할 수도 있다. 그 사회에서는 일반 시민과 공직자 모두가 렉스의 말(Rex’s word)을 사회 전체를 위한 유효한 법의 기준으로 규정하는 하나의 승인 규칙을 명시적이고 의식적인 방식으로 ‘수용(accepted)’하고 있었을 수 있다. 물론 그들이 수행해야 할 역할과 해당 규칙에 따라 식별되는 법규에 대한 관계는 달랐겠지만 말이다. 그러나 이렇게 단순한 사회에서 가능한 상태를, 복잡한 현대 국가에서도 항상 또는

일반적으로 존재한다고 주장하는 것은 허구를 고집하는 일일 것이다. 실제로 현대 사회에서의 현실은 아마도 이렇다: 상당수의 일반 시민, 어쩌면 과반수는 법체계의 구조나 유효성 기준에 대한 일반적인 개념조차 가지고 있지 않다. 그가 복종하는 ‘법(the law)’은, 그가 단지 ‘법’이라고 알고 있는 어떤 것으로 남아 있을 뿐이다. 그는 여러 이유로 그 법에 복종할 수 있으며, 그 이유들 중 하나는 그러한 것이 자신에게 가장 이롭다는 지식일 수 있다. 그는 불복종 시 발생할 수 있는 일반적인 결과들—예컨대 자신을 체포할 수 있는 공직자들이 있고, 자신을 재판하여 법을 어겼다는 이유로 감옥에 보낼 수 있는 이들이 있다는 것—에 대해 인식하고 있을 것이다. 따라서 그 사회의 법체계의 유효성 기준에 따라 유효한 것으로 간주되는 법들이 인구 대다수에 의해 준수되고 있다면, 이는 특정한 법체계가 존재한다는 것을 입증하기에 충분한 증거라 할 수 있다.

그러나 법체계가 1차 규칙(primary rules)과 2차 규칙(secondary rules)의 복합적인 결합체(complex union)인 이상, 위에서 말한 증거만으로는 법체계의 존재에 포함되는 법과의 관계를 완전히 설명할 수는 없다. 여기에 반드시 추가되어야 할 것은 (p. 115) 바로 공직자들이 자신들에게 관련된 2차 규칙들과 맺는 관계에 대한 설명이다. 여기서 핵심적인 요소는 바로 다음과 같다. 즉, 체계의 유효성 기준(criteria of validity)을 담고 있는 승인 규칙(rule of recognition)을 공직자들이 하나의 통일된 방식으로 수용(official acceptance)하고 있어야 한다는 점이다. 그런데 이 지점에서, 일반 시민의 경우에 필수적인 최소 조건을 설명하기에는 적절했던 ‘일반적 복종(general obedience)’이라는 단순한 개념이 이제는 부적절해진다. 문제는 단순히 언어학적(linguistic)인 것이 아니다. 즉, ‘복종(obedience)’이라는 단어가 법원이든 다른 공직자든 이들이 2차 규칙을 규칙으로서 존중(respect)하는 방식을 자연스럽게 묘사하지 못한다는 점만이 핵심이 아니라는 것이다. 물론 필요하다면 ‘복종’ 대신, 일반 시민이 병역을 위해 출두하는 것과 판사가 “여왕과 의회가 제정한 것은 법이다”라는 전제 하에 특정 법령을 법으로 인식하는 것을 모두 포괄하는 표현—예컨대 ‘따르다(follow)’, ‘준수하다(comply)’, ‘부합하다(conform to)’—를 사용할 수도 있을 것이다. 그러나 이러한 모호한 포괄 용어(blanket terms)는, 우리가 법체계를 부르는 복잡한 사회적 현상의 존재에 필수적인 최소 조건들을 이해하는 데 반드시 파악해야

할 핵심적인 차이들을 오히려 가려버릴 뿐이다.

입법자가 자신들의 권한을 부여하는 규칙에 부합하여 입법 활동을 하거나, 법원이 수용된 궁극적 승인 규칙(ultimate rule of recognition)을 적용할 때, 이를 ‘복종(obedience)’이라고 묘사하는 것이 오해를 불러일으키는 이유는 다음과 같다. 어떤 규칙(또는 명령)에 복종한다고 해서, 그 수범자가 자신이 하는 일이 자기 자신뿐 아니라 다른 사람들에게도 옳은 일이라고 생각해야 할 필요는(need) 없다. 그는 자신이 하는 행동을 사회집단의 다른 구성원들에게도 적용되는 행동 기준을 실현하는 것으로 보지 않아도 된다. 그는 자신이 보이는 순응적 행위를 ‘옳다(right)’, ‘정당하다(correct)’, 또는 ‘의무적이다(obligatory)’라고 생각할 필요가 없다. 즉, 그의 태도에는 사회 규칙이 수용되거나 특정 행위 유형이 일반적 기준으로 간주될 때 수반되는 비판적 성격(critical character)이 전혀 없을 수 있다. 그는 그러한 규칙들을 자신에게 적용되는 모든 사람을 위한 기준으로 수용하는 내적 관점(internal point of view)을 공유하지 않을 수도 있다. 대신 그는 그 규칙을 단지 그에게(him) 요구되는 것, 즉 처벌 위협 하에 행동을 강제하는 것으로만 여길 수 있다. 그는 그저 결과에 대한 두려움 때문에, 혹은 관성에 따라 복종할 수 있으며, 자신이나 타인이 그것을 따를 의무가 있다고 여기지 않고, 규칙을 여기는 자신이나 타인을 비판할 의향도 없을 수 있다. 하지만, (p. 116) 모든 일반 시민이 규칙에 복종할 때 가질 수도 있는 (may) 이러한 개인적인 차원의 관심만으로는, 법원이 자신이 다루는 규칙들에 대해 갖는 태도를 설명할 수 없다. 이는 특히 다른 규칙들의 유효성을 평가하는데 쓰이는 궁극적 승인 규칙(ultimate rule of recognition)의 경우에 분명하다. 이 규칙은, 존재하기 위해서 반드시 하나의 공적인(public), 공통의(common) 정당한 사법 판단의 기준(standard of correct judicial decision)으로서 내적 관점(internal point of view)에서 수용되어야 한다. 이는 단순히 각 판사가 자신 몫만 수행하며 ‘복종’하는 것으로 되어서는 안 된다. 그 법체계의 법원들 중 개별적인 법원이 때때로 이 규칙들로부터 이탈하는 일이 있을 수는 있으나, 일반적으로 그러한 이탈을 공통적이거나 공적인 기준(common or public standards)에서의 이탈(lapses)로 비판적으로 다루어야 한다. 이는 단지 법체계의 효율성이나 건전성과 관련된 문제가 아니라, 하나의 법체계(single legal system)가

존재한다고 말할 수 있기 위한 논리적으로 필수적인 조건(logically necessary condition)이다. 가령 어떤 판사들만이 ‘자기 몫만’ 수행하며 “여왕과 의회가 제정한 것은 법이다”라는 전제하에 행동하고, 다른 판사들이 이 승인 규칙을 존중하지 않아도 아무런 비판을 하지 않는다면, 법체계의 특유의 통일성 및 연속성(characteristic unity and continuity)은 사라지고 만다. 법체계는 바로 이 결정적인 지점에서 법적 유효성에 관한 공통된 기준(common standards of legal validity)이 수용되고 있을 때에만 비로소 존재할 수 있다. 이러한 사법적 행태의 변덕과, 평범한 사람이 서로 모순되는 사법 명령에 직면하게 될 때 결국 초래될 혼란 사이의 그 사이 구간에서, 우리는 그 상황을 어떻게 묘사해야 할지 난처할 것이다. 우리는 오직 그것이 평소에는 너무 자명해서 인식되지 않는 것들을 날카롭게 의식하게 해주기 때문에만 생각해볼 만한 가치가 있는 하나의 자연의 기이함(lusus naturae)과 마주하게 될 것이다.

따라서 하나의 법체계가 존재하기 위해 필요한 최소 조건은 두 가지이다. 첫째, 그 법체계의 궁극적 유효성 기준(ultimate criteria of validity)에 따라 유효한 것으로 간주되는 행위 규칙들(rules of behaviour)은 일반적으로 준수되어야 한다. 둘째, 법적 유효성 기준을 명시하는 승인 규칙(rule of recognition)과 변경 규칙(rules of change) 및 재판 규칙(rules of adjudication)은, 해당 체계의 공직자들 사이에서 공통의 공적인 공식 행위 기준(common public standards of official behaviour)으로 효과적으로 수용되어야 한다. 첫 번째 조건은 일반 시민들이 만족시킬 필요가 있는(need) 유일한 조건이다: 그들은 각자 ‘자기 몫만을’ 따로 복종할 수 있으며, 그 동기는 어떠한 상관없다; 물론 건강한 사회에서는 실제로 많은 시민들이 이 규칙들을 공통의 행동 기준으로 수용하고, 그것을 따를 의무를 인식하거나, 심지어 이러한 의무를 (p. 117) 헌법을 존중할 보다 일반적인 의무에서 도출하기도 할 것이다. 두 번째 조건은 법체계의 공직자들이 반드시 만족시켜야 한다. 그들은 해당 규칙들을 공식 행위의 공통된 기준(common standards of official behaviour)으로 간주하고, 자기 자신과 동료들의 이탈(deviations)을 비판적으로 평가해야 한다. 물론 여기에 덧붙여, 공직자가 개인적 자격에서 복종해야 하는 1차 규칙들도 많다는 점은 사실이다.

따라서 “법체계가 존재한다”는 명제는 이중적인 얼굴을 가진(Janus-faced)

진술이다. 한편으로는 일반 시민들의 복종을, 다른 한편으로는 공직자들이 2차 규칙을 공통적인 공식 행위 기준(critical common standards of official behaviour)으로 수용하는 것을 함께 가리킨다. 이러한 이중성에 놀랄 필요는 없다. 이것은 단지 법체계의 구성적 성격(composite character)—즉 단순하고 분권적인 비법적 사회 구조와 대비되는—을 반영하는 것일 뿐이다. 단지 1차 규칙만으로 구성된 더 단순한 사회 구조에서는, 공식 담당자가 존재하지 않기에, 해당 규칙들은 집단의 행위에 대한 비판적 기준으로서 널리 수용되어야 한다. 만약 그러한 경우에 내적 관점(internal point of view)이 널리 퍼져 있지 않다면, 논리적으로 규칙이 존재할 수 없다. 하지만, 우리가 주장해온 바와 같이, 법체계를 이해하는 가장 생산적인 방식은 1차 규칙과 2차 규칙의 결합(union of primary and secondary rules)으로 보는 것이며, 이 경우 집단 전체의 공통 기준으로서 규칙을 수용하는 일은, 일반 개인이 자신 몫으로 복종함으로써 그 규칙에 묵인하는 비교적 수동적인 태도와 분리될 수 있다. 극단적인 경우에는, 법적 언어의 특유의 규범적 사용(예: “이것은 유효한 규칙이다”)을 포함한 내적 관점이 오직 공직 사회 내부에만 존재할 수도 있다. 이처럼 보다 복잡한 체계에서는, 오직 공직자들만이 법적 유효성에 대한 체계의 기준을 수용하고 사용할 수 있다. 그러한 사회는 비극적으로 양 떼처럼(sheeplike) 행동하는 집단일 수 있고, 결국 도살장으로 향하게 될지도 모른다. 하지만 그 사회가 실제로 존재할 수 없다고 보거나, 그것이 법체계라는 명칭을 가질 수 없다고 단정할 이유는 별로 없다.

3. 법체계의 병리학

법체계의 존재를 입증하는 증거는 따라서 사회생활의 두 서로 다른 영역에서도 출되어야 한다. 우리가 “법체계가 존재한다”고 자신 있게 말할 수 있는 일반적인이고 문제되지 않는 경우는, 바로 이 두 영역이 (p. 118) 법에 대한 각자의 전형적 관심에서 서로 일치하는(congruent) 경우이다. 거칠게 말하자면, 다음과 같은 사실이 있다: 공직자 수준에서 유효한 것으로 인식되는 규칙들이 일반적으로 복종되고 있다. 그러나 때로는 공직자 영역이 사적 영역과 분리되어, 법원이 사용하는 유효성 기준에 따라 유효하다고 여겨지는 규칙들이 더 이상

일반적으로 복종받지 않는 경우도 생긴다. 이러한 일이 일어날 수 있는 다양한 방식은 법체계의 병리(pathology of legal systems)에 속하는데, 그것들은 우리가 외적 사실 진술로서 “법체계가 존재한다”고 말할 때 지시되는 복합적인 일치적 실천이 붕괴된 경우를 나타낸다. 이는 해당 체계 내부에서 우리가 내적 진술(internal statements)을 통해 법을 언명할 때 항상 전제하는 바가 부분적으로 실패한 경우이다. 이러한 붕괴는 다양한 혼란 요인의 산물일 수 있다. 예컨대, 지배권을 두고 집단 내부에서 경쟁하는 ‘혁명(revolution)’은 그 한 예이며, 이는 항상 기존 체계의 일부 법률을 위반하는 형태를 동반하지만, 반드시 새로운 헌법이나 법체계의 수립이 아니라 기존 체계 하에서 법적으로 인식되지 않은 새로운 공직자 집단의 대체에 그칠 수도 있다. ‘점령군에 의한 통치(enemy occupation)’도 또 다른 예로서, 이는 기존 체계 하에서의 권한 없이 외부에서 지배권을 주장하는 경우이며, 정치적 지배 의도를 가지지 않은 무정부 상태나 도적 집단에 의한 법질서의 단순 붕괴 역시 또 다른 경우이다.

이러한 각각의 경우에서, 법원이 해당 영토에서든 망명 상태에서든 기능 하면서, 한때 안정적으로 확립된 옛 체계의 유효성 기준을 여전히 사용하는 과도기적인 단계(half-way stages)가 있을 수 있다. 그러나 이러한 명령들이 실제로는 해당 영토에서 효력을 발휘하지 못하는 경우도 있다. 이러한 경우에 “법체계가 완전히 소멸되었다”고 말할 수 있는 시점은, 정확하게 결정할 수 있는 것이 아니다. 명백하게, 복구될 상당한 가능성이 있거나, 기존 체계의 혼란이 결과가 아직 확정되지 않은 전면적 전쟁의 일부 사건일 경우에는, 그 체계가 더 이상 존재하지 않는다는 무조건적인 주장은 정당화될 수 없다. 이는 바로 “법체계가 존재한다”는 명제가 충분히 폭넓고 일반적인 유형이기 때문이다. 이 명제는 일시적인 사건들에 의해 입증되거나 반박되는 것이 아니다.

물론 이러한 중단 이후에 법원과 국민 간의 정상적인(p. 119) 관계가 회복된 뒤에는 어려운 문제가 제기될 수 있다. 점령군의 축출이나 반란 정부의 패배 이후 망명 정부가 귀환하면, 그 중단의 시기에 해당 지역에서 무엇이 ‘법’이었는지, 혹은 무엇이 아니었는지에 대한 문제가 생긴다. 여기서 가장 중요한 점은, 이 문제가 사실(fact)의 문제가 아닐 수도 있다는 점이다. 만약 그것이 사실의 문제라면, 해당 중단이 너무나 장기적이고 완전했기 때문에 기존 법체계가 소멸되

있고 망명 귀환 시 유사한 새로운 체계가 수립되었다고 기술해야 하는지를 묻는 방식으로 해결되어야 할 것이다. 그러나 실제로는 이 문제는 국제법상의 문제로 제기되거나, 다소 역설적으로, 복귀 이후 존재하게 된 바로 그 법체계 내부의 문제로 제기될 수 있다. 후자의 경우, 복귀한 체계가 회고적으로, 그 체계가 계속해서 해당 지역의 법이었음을 선언하는 법률을 포함할 수도 있다—혹은 좀 더 솔직히 말해, 그 체계가 해당 시기 동안 법이었던 것으로 간주된다(deemed)고 선언할 수 있다. 이러한 선언은, 그 중단 기간이 사실로 판단되었을 경우 도달했을 결론과는 상당히 불일치해 보일 수 있음에도 불구하고, 여전히 존재할 수 있다. 그런 경우에, 해당 선언은 중단 기간 중 발생한 사건들과 거래들에 대해 법원이 적용해야 할 법을 결정하는 복귀 체계의 하나의 규칙으로서, 얼마든지 유효하게 존재할 수 있다.

이러한 상황에서 우리가 역설을 느끼게 되는 것은, 법체계가 스스로의 과거, 현재, 또는 미래의 존재 단계에 대해 ‘법이 무엇인가’를 진술할 때의 명제가, 외적 관점에서 제시되는 그 존재에 대한 사실 진술과 경쟁하는(rivals) 것으로 생각하기 때문이다. 자기지시(self-reference)의 겉보기에만 있는 수수께끼를 제외하면, 특정 시기에 법체계가 존재했음을 선언하는 현행 체계 내의 규정의 법적 지위는, 다른 국가에 존재하는 어떤 체계가 아직도 유효하다고 선언하는 법률과 본질적으로 다르지 않다. 물론 후자의 경우 실질적인 결과는 적을 수 있다. 예를 들어, 우리는 소련 영토에서 현재 존재하는 법체계가 차르 체제의 법체계가 아니라는 점을 분명히 알고 있다. 그러나 만약 영국 의회가 차르 시대 러시아의 법이 여전히 러시아 영토에서 유효하다고 선언하는 법률을 제정한다면, 이 법률은 의미와 법적 효과를 가지며, 이는 영국 법의 일부로서 소련(USSR)을 참조하는 조항이 될 것이다. (p. 120) 그러나 이는 앞서 언급한 사실 진술의 진위를 전혀 변경시키지 않는다. 그 법률의 효력과 의미는, 영국 법원이 적용할 법을 규정하고, 그 결과로 영국 내에서 러시아와 관련된 사안에 적용될 법을 정하는 것에 있다.

위와 정반대의 상황은, 새로운 법체계가 기존 체계의 모태로부터 탄생하는 흥미로운 전환기(fascinating moments of transition)에서 발견된다—어떤 경우에는 제왕절개(Caesarian operation)를 거쳐야 할 정도로. 최근의 영연방

(Commonwealth) 역사는 이러한 법체계의 발생학(embryology)에 대한 연구에 훌륭한 사례를 제공한다. 이 발전의 개략적이고 단순화된 윤곽은 다음과 같다. 한 시기의 시작점에서는, 어떤 식민지가 자치 입법부, 사법부, 행정부를 갖추고 있을 수 있다. 이 헌법 구조는 영국 의회의 법률에 의해 설정되었으며, 영국 의회는 해당 식민지에 대해 입법할 수 있는 완전한 법적 권한을 여전히 보유한다. 이 권한에는 자치 입법이나 헌법 조항을 포함하여 식민지에 적용되는 자국의 법률을 개정하거나 폐지할 수 있는 권한이 포함된다. 이 시점에서 식민지의 법체계는 명백히 더 넓은 법체계의 하위 부분이며, 이 체계는 궁극적 승인 규칙(ultimate rule of recognition)—즉, “여왕이 의회와 함께 제정한 것은 (특히 (inter alia)) 식민지에 대해서 법이다”—라는 기준으로 특징지어진다. 하지만 발전의 말미에 이르면, 궁극적 승인 규칙이 변화했음을 발견하게 된다. 즉, 이전 식민지의 법원이 이제 더 이상 웨스트민스터 의회가 제정한 법률에 대해 법적 권한을 인식하지 않게 된 것이다. 여전히 많은 헌법 구조가 웨스트민스터 의회의 원래 법률에 포함되어 있긴 하지만, 이는 이제 단지 역사적 사실일 뿐이다. 해당 법 조항은 더 이상 이 지역에서의 법적 지위를 그 의회로부터의 권위에 의존하지 않는다. 이전 식민지에서의 법체계는 이제 ‘지역적 뿌리(local root)’를 가지며, 유효성의 궁극적 기준을 지정하는 승인 규칙이 더 이상 타국의 입법 기관의 법률을 참조하지 않는다. 새로운 승인 규칙은 단지 그것이 현지의 사법 및 기타 공식적 행위에서 그러한 규칙으로 수용되고 사용된다는 사실에 기반한다. 따라서 그 지역 입법부의 구성이나 입법 절차, 구조가 여전히 원래 헌법에 의해 규정된 것이라 하더라도, 이제 그것은 (p. 121) 웨스트민스터 의회의 유효한 법률이 부여한 권한의 행사이기 때문에 유효한 것이 아니다. 그 입법은, 그것이 유효한 법률의 궁극적 기준으로 현지에서 수용된 승인 규칙(local rule of recognition)에 따라 이루어졌기 때문에, 유효하다.

이러한 발전은 여러 방식으로 달성될 수 있다. 모국 입법부는 일정 기간 동안 사실상 식민지의 동의 없이는 입법 권한을 행사하지 않다가, 마침내 해당 식민지에 대한 입법 권한을 포기함으로써 무대에서 퇴장할 수 있다. 이때 주목할 점은, 웨스트민스터 의회가 이와 같이 스스로의 권한을 불가역적으로 제한할 수 있는 법적 능력을 가지고 있는지를 영국 법원이 인식할지에 대해 이론적인

의문이 존재한다는 것이다. 반대로, 이러한 단절은 폭력을 통해서만 이루어질 수도 있다. 그러나 어느 경우이든, 이 발전의 말미에는 두 개의 독립된 법체계가 존재하게 된다. 이것은 하나의 사실적 진술이며, 비록 그것이 법체계의 존재에 관한 것이라 할지라도, 그렇다고 해서 덜 사실적인 것은 아니다. 이에 대한 주된 증거는, 이전 식민지에서는 현재 받아들여지고 사용되는 궁극적 승인 규칙이 더 이상 타 지역의 입법부 작용을 유효성의 기준으로 포함하지 않는다는 사실이다.

그런데 다시, 영연방(Commonwealth)의 역사에서 흥미로운 사례들이 보여 주듯이, 실질적으로는 식민지의 법체계가 이제 모국으로부터 독립되었음에도 불구하고, 모국의 법체계는 이 사실을 인식하지 않을 수도 있다. 여전히 영국 법의 일부로서, 웨스트민스터 의회가 식민지에 대해 입법할 권한을 보유하거나 법적으로 재취득할 수 있다는 관념이 유지될 수 있으며, 실제로 그러한 경우에, 만약 웨스트민스터 의회의 법률과 현지 입법부의 법률이 충돌하는 사건이 영국 법원에 회부된다면, 영국 법원은 이러한 관점을 따를 수도 있다. 이 경우, 영국법의 명제들은 사실과 충돌하는 듯 보인다. 식민지의 법은 사실상 독립된 법체계이며, 자체의 지역적 궁극적 승인 규칙을 가진 체계인데, 영국 법원은 이를 그렇게 인식하지 않는다(not). 사실상은 두 개의 법체계가 존재하지만, 영국법은 오직 하나만 존재한다고 주장한다. 그러나, 하나는 사실 진술이고 다른 하나는 (영국)법의 명제이기 때문에, 이 둘은 논리적으로 충돌하지 않는다. 이 입장을 명확히 하기 위해, 우리는 사실 진술이 진실이며, 영국법의 명제는 “영국법상 올바른(correction in English law)” 것이라고 말할 수 있다. (p. 122) 이러한 독립된 법체계의 존재 여부에 대한 사실적 진술(또는 부정)과 법적 명제 간의 구별은, 국제공법과 국내법 사이의 관계를 논할 때에도 반드시 유념해야 한다. 어떤 매우 기이한 이론들이 그럴듯해 보이는 유일한 이유는 이 구별을 무시하기 때문이다.

이러한 법체계의 병리학(pathology)과 발생학(embryology)에 대한 조잡한 개관을 마무리하려면, 이제 우리는, “하나의 법체계가 존재한다”는 무조건적 명제가 전제하는 정상 조건들의 일치가 부분적으로 실패하는 다른 형태들도 주목해야 한다. 법체계 내부에서 법에 대한 내적 진술이 행해질 때 일반적으로 전제되는, 관료들 간의 통일성(unity)은 부분적으로 붕괴될 수 있다. 헌법적

문제들—그리고 오직 그 문제들에 한해서—에 대해, 공식 세계 내부에서 분열이 발생하고 궁극적으로 사법부 내부의 분열로 이어질 수 있다. 법률을 식별하는데 사용되는 궁극적 기준에 대한 이러한 분열의 시작은 1954년 남아프리카 공화국에서 발생한 헌법적 위기에서 볼 수 있었으며, 이는 Harris 대 Dönges 사건으로 법원에 회부되었다. 여기서 입법부는 자신이 보유한 법적 권한에 대해 법원과는 다른 견해를 취하며 입법을 진행하였고, 법원은 이를 무효라고 선언하였다. 이에 대한 대응으로 입법부는, 자국 입법의 무효 판결에 대해 항소가 제기될 수 있도록 특별 항소 ‘법원’을 창설하였다. 이 법원은 실제로 그러한 항소를 심리하고 기존 법원의 판결을 뒤집었으며, 다시 기존 법원은 그 특별 법원을 창설한 입법을 무효라고 선언하고 해당 판결들을 법적으로 무효(nullity)라고 판시하였다. 만약 정부가 이러한 수단을 계속 고수했다면, 우리는 입법부의 권한과 법의 유효성 기준에 대한 두 견해 사이에서 무한 반복되는 진동 현상을 보았을 것이다. 법체계의 승인 규칙을 식별할 수 있게 하는 공식적—특히 사법적—조화의 정상 조건은 일시적으로 정지되었을 것이다. 그럼에도 불구하고, 이 헌법적 문제와 직접적으로 관련되지 않은 대부분의 법적 작용들은 이전과 마찬가지로 계속되었을 것이다. 만약 시민들이 분열되고, ‘법과 질서’가 (p. 123) 붕괴되지 않았다면, 원래의 법체계가 소멸했다고 말하는 것은 오해를 불러올 수 있다. 왜냐하면 ‘동일한 법체계(same legal system)’라는 표현은 너무 넓고 유연하기 때문에, 유효한 법의 모든(all) 원래 기준에 대한 공식적 합의가 유지되는 것을 그 체계가 ‘동일하다’고 인식하기 위한 필요조건으로 삼을 수는 없기 때문이다. 우리가 할 수 있는 최선은 지금까지 기술해온 방식대로 해당 상황을 설명하고, 그것을 하나의 표준 이하(substandard), 비정상적인 사례로 기록해 두는 것이다. 이 사례는 그 속에 법체계가 붕괴할 수 있는 잠재적 위협을 품고 있다.

이 마지막 사례는, 우리가 다음 장에서 논의하게 될 보다 넓은 주제의 경계로 우리를 이끈다. 이는 법체계의 궁극적 유효성 기준이라는 고차원적 헌법 문제와, 그 법체계의 ‘일반적인(ordinary)’ 법 양자 모두와 관련된다. 모든 규칙에는 특정 사례들을 일반적 용어의 사례로 인식하거나 분류하는 과정이 포함되며, 우리가 어떤 것을 규칙(rule)이라고 부를 준비가 되어 있는 모든 경우에 있어서, 분명히

해당 규칙이 적용되는 명확한 중심 사례들과, 그 적용 여부에 대해 긍정할 이유와 부정할 이유가 모두 존재하는 경계 사례들을 구별하는 것이 가능하다. 우리가 구체적인 상황들을 일반 규칙에 귀속시키려 할 때, 이와 같은 확실성의 핵(core of certainty)과 의문의 주변부(penumbra of doubt)라는 이중성은 결코 제거될 수 없다. 이로 인해 모든 규칙에는 모호함의 테두리, 곧 ‘개방적 직조(open texture)’가 부여되며, 이는 법을 식별하는 데 사용되는 궁극적 기준을 명시하는 승인 규칙(rule of recognition)에도, 하나의 특정한 성문 법률에도 마찬가지로 영향을 미칠 수 있다. 법의 이러한 측면은 흔히, 규칙이라는 틀로 법 개념을 해명하려는 시도가 오해를 낳을 수 있다는 점을 보여주는 것으로 간주된다. 현실의 상황을 외면한 채 이를 고집하는 것은 흔히 ‘개념주의(conceptualism)’나 ‘형식주의(formalism)’라는 낙인이 찍히곤 한다. 우리는 이제 이와 같은 비판의 타당성을 평가하는 논의로 넘어가게 될 것이다.

CHAPTER VI 주석

Page 100. 승인 규칙(rule of recognition)과 켈젠(Kelsen)의 ‘근본 규범(basic norm)’ 본서의 중심 논제 중 하나는, 법체계의 기초는 법적으로 무제한인 주권자에 대한 일반적 복종 습관(habit of obedience)에 있는 것이 아니라, 그 체계 내의 유효한 규칙을 식별하는 권위 있는 기준을 제공하는 궁극적 승인 규칙(ultimate rule of recognition)에 있다는 것이다. 이 논제는 켈젠의 근본 규범(basic norm) 개념과 일정 부분 유사하며, 더 나아가서는 셀몬드(Salmond)의 충분히 전개되지 않은 ‘궁극적 법 원칙(ultimate legal principles)’ 개념과도 가깝다(켈젠, *General Theory*, pp. 110-124, 131-134, 369-373, 395-396 참조; 셀몬드, *Jurisprudence*, 11판, p. 137 및 부록 I 참조). 그러나 본서는 켈젠과는 다른 용어 체계를 채택하였으며, 그 이유는 아래의 주요한 점들에서 본서의 입장이 켈젠과 다르기 때문이다.

1. 승인 규칙이 존재하는지, 또 그것의 내용—즉 주어진 법체계에서의 유효성 기준(criteria of validity)—이 무엇인지는, 본서 전반에서 경험적이면서도 복합적인 사실 문제(question of fact)로 간주된다. 이는 다음의 점이 사실이더라도 마찬가지이다: 즉, 법체계 내에서 활동하는 법률가가 특정 규칙이 유효하다고 주장할 때, 그는 이를 명시적으로 진술하지는 않지만(explicitly state), 해당 규칙의 유효성을 승인 규칙에 비추어 판단하였다는 사실을 암묵적으로 전제한다(tacitly presupposes). 만약 이 점에 대해 이의가 제기된다면, 그러한 암묵적 전제를 명시적으로 뒷받침할 수 있는 근거는 다음과 같은 사실에 호소하는 것이다. 즉, 법관과 공무원들이 자신들이 적용할 법을 식별할 때 실제로 따르는 실천에 호소해서 확립할 수 있다. 켈젠은 근본 규범을 ‘법학적 가설(juristic hypothesis)’(ibid. xv), ‘가설적(hypothetical)’(ibid. 396), ‘전제된 궁극 규칙(postulated ultimate rule)’(ibid. 113), ‘법학적 의식 내의 규칙(rule existing in the juristic consciousness)’(ibid. 116), ‘가정(an assumption)’(ibid. 396) 등으로 분류하는 용어를 사용한다. 그러나 이러한 표현들은, 이 책에서 강조되는 바와 같이 “법체계 내의 유효성 기준이 무엇인가”라는 물음이 사실에 관한 문제임을 오히려 혼동시키거나, 심지어는 그와 논리적으로 모순될 수도 있다. 그것은 사실에 관한 질문이지만, 하나의 규칙의 존재와 내용에 관한(about) 질문이다. Cf. 아고(Ago), “Positive Law and International Law,” *American Journal of International Law* 제51권 (1957), pp. 703-707.
2. 켈젠은 근본 규범의 유효성(validity)을 전제한다고 말한다. 그러나 본문(pp. 108-

110)에서 제시된 이유에 따르면, 일반적으로 수용된 승인 규칙에 관해 그 존재 여부와는 별도로 그 유효성 여부를 묻는 것은 부적절하며, 그런 질문 자체가 성립할 수 없다.

3. 켈젠의 근본 규범은 일종의 고정된 내용을 갖는다. 왜냐하면 그것은 모든 법 체계에 있어 단지 “헌법 또는 헌법을 최초로 정한 자들이 복종되어야 한다”는 규칙이기 때문이다(*General Theory*, pp. 115–116). 그러나 이러한 일관성과 단순성의 외관은 오해를 낳을 수 있다. 만약 하나의 헌법이 다양한 법원(law source)을 명시하며, 그 법체계 내의 법원들과 공무원들이 실제로 그 기준에 따라 법을 식별하고 있다면, 그러한 헌법은 수용된 것이며 실제로 존재하는 것이다. 이런 경우, 헌법 또는 그것을 제정한 자들이 복종되어야 한다는 별도의 규칙이 존재한다고 제안하는 것은 불필요한 중복처럼 보인다. 특히, 영국처럼 성문 헌법이 존재하지 않는 경우에는 더욱 그렇다. 이 경우, ‘헌법에 복종해야 한다’는 규칙은, 예컨대 “여왕과 의회의 제정에 따라 법이 식별된다”는 유효성 기준 규칙 외에 추가로 존재할 자리가 없어 보인다. 이 규칙 자체가 인식된 규칙이며, 그것을 ‘복종되어야 할 규칙’이라고 다시 말하는 것은 혼란을 초래할 뿐이다.
4. 켈젠의 견해에 따르면(*General Theory*, pp. 373–375, 408–410), 특정한 법규칙을 유효한 것으로 간주하면서 동시에 그 법규칙이 요구하는 행위를 금지하는 도덕규칙을 도덕적으로 구속력 있는 것으로 받아들이는 것은 논리적으로 불가능하다. 그러나 본서에서 제시한 법적 유효성에 대한 설명에서는 그러한 결과가 전혀 도출되지 않는다. ‘근본(basic) 규범’이라는 표현 대신 ‘승인 규칙(rule of recognition)’이라는 표현을 사용하는 이유 중 하나는, 법과 도덕 사이의 충돌에 관한 켈젠의 견해를 따를 어떤 입장도 전제하지 않기 위함이다.

Page 101. 법의 연원(sources of law). 일부 저자들은 법의 ‘형식적(formal)’ 또는 ‘법적(legal)’ 연원과 ‘역사적(historical)’ 또는 ‘실질적(material)’ 연원을 구분한다(Salmond, *Jurisprudence*, 11판, 제5장). Allen은 이 구분을 비판하지만(*Law in the Making*, 6판, p. 260), 이를 ‘연원(source)’이라는 단어의 두 가지 의미의 구분으로 해석하면 이 구분은 중요한 것이다(Kelsen, *General Theory*, pp. 131–132, 152–153 참조). 한 측면(즉 ‘실질적(material)’, ‘역사적(historical)’ 의미)에서 ‘연원’이란, 특정한 시간과 장소에서 하나의 법규칙이 존재하게 된 원인적 또는 역사적 영향력을 의미한다. 이 의미에서 현대 영국법의 특정 규칙들의 연원은 로마법 규칙일 수도 있고, 교회법 규칙이나 심지어 대중 도덕 규범일 수도 있다. 그러나 ‘법령(statute)’이 법의 연원이라고 말할 때, ‘연원’이라는 단어는 단순한 역사적·인과적 영향력을 뜻하는 것이 아니라, 해당 법체계에서

수용된 법적 유효성의 기준(criteria of legal validity) 중 하나를 가리킨다. 권한 있는 입법기관에 의해 법령으로 제정되었다는 사실은, 특정 법령 규칙이 단순히 존재하게 된 원인(cause)일 뿐 아니라 그것이 유효한 법(valid law)이라는 이유(reason)이다. 특정 법규칙의 역사적 원인과 유효성의 이유 사이의 이러한 구분은, 입법 행위, 관습적 실천, 선례 등을 유효한 법의 식별 기준으로 수용하는 승인 규칙(rule of recognition)이 체계 내에 존재할 때만 가능하다.

그러나 실제 실천에서는 역사적 또는 인과적 연원과 법적 또는 형식적 연원 간의 이 구분이 흐려지는 경우도 있으며, Allen과 같은 저자들이 이러한 구분을 비판하게 된 배경이 바로 여기에 있다. 어떤 법체계에서는 법령이 형식적 또는 법적 연원인 경우, 법원이 판결을 내릴 때 관련 법령을 참작할 의무가 있으며, 물론 법령의 문구를 해석하는 데 상당한 재량이 허용되기도 한다(제7장 제1절 참조). 그러나 때때로 판사에게 허용되는 것은 단순한 해석상의 재량을 넘어선다. 즉, 그가 특정 사건에 적용되는 법령이나 기타 형식적 연원이 없다고 판단할 경우, 그는 학설취찬(Digest)의 한 문헌이나 프랑스 법학자의 저술에 근거하여 판결을 내릴 수도 있다(예: Allen, *op. cit.*, p. 260 이하 참조). 해당 법체계가 그러한 연원을 사용하라고 필수적으로 요구하는(require) 것은 아니지만, 판사가 이를 참조하는 것은 정당하고 적절한 것으로 인식된다. 그러므로 이들 문헌은 단순한 역사적 또는 인과적 영향력을 넘어서는 것이며, 실제로는 '정당한 판결의 근거(good reasons)'로 인식되고 있는 것이다. 따라서 이러한 연원은 법률이나 법령과 같은 '강제적(mandatory)' 형식적·법적 연원과, 단순한 '역사적(material)' 연원 사이의 구분을 위해, '허용적(permissive) 법적 연원'이라 부를 수 있을 것이다.

Page 103. 법적 유효성과 실효성(Legal validity and efficacy). 켈젠은 전체적으로 실효적인 법질서의 실효성과 개별 규범의 실효성을 구분한다(*General Theory*, pp. 41-2, 118-22). 그에게 있어 하나의 규범이 유효하다는 것은, 만약 그리고 오직 그 경우에만(if, and only if), 그것이 전반적으로(on the whole) 실효적인 체계에 속할 때이다. 그는 이 견해를 좀 더 난해하게 다음과 같이 표현하기도 한다. 즉, 체계 전체의 실효성은 그 체계의 규칙 유효성에 대한 필요조건(*conditio sine qua non*)이지, 충분조건(*conditio per quam*)은 아니라고 말한다(*sed quaere*). 이 구분의 요점은 본서의 용어로 다음과 같이 정리될 수 있다. 법체계의 일반적인 실효성은 승인 규칙(rule of recognition)이 제공하는 유효성 기준은 아니지만, 체계 내의 어떤 규칙이 그 유효성 기준에 따라 유효한 규칙으로 식별될 때마다 언제나 암묵적으로 전제되며 명시적으로 진술되지는 않는다. 그리고 체계가 일반적으로 실효성을 갖추고 있지 않다면, 유효성에 관한 의미 있는 진술 자체가 불가능해진다. 본문의 입장은 이 점에서 켈젠과 다르다. 본서에서는 체계의

실효성이 유효성 진술이 이루어지는 정상적 맥락(*normal context*)이긴 하지만, 특별한 상황에서는 그 체계가 더 이상 실효적이지 않더라도 유효성 진술이 여전히 의미를 가질 수 있다고 주장한다(*ante*, p. 104 참조).

켈젠은 또한 관습폐지(*desuetudo*) 항목에서, 하나의 법체계가 특정 규칙의 유효성을 그 규칙의 지속적인 실효성에 의존하도록 할 가능성에 대해서도 논의한다. 이러한 경우, (개별 규칙의) 실효성은 체계의 유효성 기준 중 하나가 되며, 단순한 ‘전제(*presupposition*)’는 아니다(*op. cit.*, pp. 119–22).

Page 104. 유효성과 예측(*Validity and prediction*). 법이 유효하다는 진술은 미래의 사법적 행위와 그에 따른 특유의 동기 부여 감정에 대한 예측이라는 견해에 대해서는 Ross, *On Law and Justice*, 제1장 및 제2장 참조. 이에 대한 비판은 Hart, ‘Scandinavian Realism’ (*Cambridge Law Journal*, 1959년)을 보라.

Page 106. 개정권이 제한된 헌법(*Constitutions with limited amending powers*). 서독과 터키의 사례는 제4장 주석(*ante*, p. 290)을 참조하라.

Page 111. 관행적 범주와 헌정 구조(*Conventional categories and constitutional structures*). ‘법(*law*)’과 ‘관행(*convention*)’의 완전한 구분이라는 주장에 대해서는 Dicey, *Law of the Constitution*, 10판, pp. 23 이하; Wheare, *Modern Constitutions*, 제1장 참조.

Page 111. 승인 규칙(*rule of recognition*): 법인가 사실인가? 정치적 사실로 분류할 것인지에 대한 찬반 논증은 Wade, ‘The Basis of Legal Sovereignty’, *Cambridge Law Journal* (1955), 특히 p. 189, 그리고 Marshall, *Parliamentary Sovereignty and the Commonwealth*, pp. 43–46을 참조하라.

Page 112. 법체계의 존재, 습관적 복종, 승인 규칙의 수용(*The existence of a legal system, habitual obedience, and the acceptance of the rule of recognition*). 일반 시민의 복종과 공무원의 헌정 규칙 수용이라는 복합적 사회 현상을 지나치게 단순화할 위험에 대해서는 제4장 제1절, pp. 60–61 및 Hughes, ‘The Existence of a Legal System’, 35 *New York University LR* (1960), p. 1010 참조. 특히 본서의 Hart가 ‘Legal and Moral Obligation’ (*Essays in Moral Philosophy*, Melden 편, 1958)에서 사용한 용어에 대해 정당하게 비판한다.

Page 118. 법질서의 부분적 붕괴(*Partial breakdown of legal order*). 법체계가 완전히 정상적으로 존재하는 상태와 전혀 존재하지 않는 상태 사이의 많은 중간 상태들 중 극히 일부만이 본문에서 언급되었다. 혁명(*revolution*)에 대한 법적 관점에서의 논의는 Kelsen, *General Theory*, pp. 117 ff., 219 ff.를 참조하고, Cattaneo, *Il Concetto di Rivoluzione nella Scienza del Diritto* (1960)에서는 보다 자세히 다루어진다. 적의 점령에

의한 법체계의 중단은 다양한 형태를 띌 수 있으며, 이 중 일부는 국제법상으로 범주화되어 있다. 이에 대해서는 McNair, 'Municipal Effects of Belligerent Occupation', 57 LQR (1941), 그리고 Goodhart, 'An Apology for Jurisprudence' (*Interpretations of Modern Legal Philosophies*, pp. 288 ff.)의 이론적 논의를 참조하라.

Page 120. 법체계의 발생학(*The embryology of a legal system*). 식민지에서 도미니언으로의 발전 과정은 법이론 연구에 매우 유익한 분야로, Wheare, *The Statute of Westminster and Dominion Status*, 5th edn.에서 추적된다. 또한 Latham, *The Law and the Commonwealth* (1949)을 참조하라. Latham은 영연방(Commonwealth)의 헌정 발전을 '지역적 근거(local root)'를 가진 새로운 기본 규범의 성장이라는 관점에서 최초로 해석하였다. 또한 Marshall, 앞서 인용한 저서, 특히 캐나다에 대한 제7장을 참고하고, Wheare, *The Constitutional Structure of the Commonwealth* (1960), 제4장 '자생성(Autochthony)'도 참고하라.

Page 121. 입법권의 포기(*Renunciation of legislative power*). Westminster 법령 제4조의 법적 효력에 대한 논의는 Wheare, *The Statute of Westminster and Dominion Status*, 5th edn., pp. 297-8을 참조하라. 또한 *British Coal Corporation v. The King* (1935), AC 500; Dixon, 'The Law and the Constitution', 51 LQR (1935); Marshall, 앞서 인용한 저서, pp. 146 ff.; 그리고 제7장 제4절도 함께 보라.

Page 121. 모국 체계에 의해 인식되지 않은 독립(*Independence not recognized by the parent system*). 아일랜드 자유국(Irish Free State)에 대한 논의는 Wheare, 앞서 인용한 저서 참조; *Moore v. AG for the Irish Free State* (1935), AC 484; *Ryan v. Lennon* (1935), IRR 170 참조.

Page 121. 법체계의 존재에 관한 사실 명제와 법적 진술(*Factual assertions and statements of law concerning the existence of a legal system*). Kelsen은 국내법과 국제법 사이의 관계('국내법의 우위 또는 국제법의 우위')에 대한 자신의 설명(op. cit., pp. 373-83)에서, 법체계가 존재한다는 진술은 반드시 한 법체계가 다른 법체계에 대해 '유효하다(valid)'고 받아들이고 그와 하나의 체계를 이룬다고 보는 관점에서 이루어진 법적 진술이어야 한다고 전제한다. 이에 반해 상식적 견해에서는 국내법과 국제법을 별개의 법체계로 간주하며, 특정 법체계(국내법이든 국제법이든)가 존재한다는 진술을 사실 명제로 받아들인다. Kelsen에게는 이러한 견해가 용납될 수 없는 '다원주의(pluralism)'이다(Kelsen, loc. cit.; Jones, 'The "Pure" Theory of International Law', 16 BYBIL 1935 참조). 또한 Hart, 'Kelsen's Doctrine of the Unity of Law', *Ethics and Social Justice, Contemporary Philosophical Thought*, vol. 4 (New York, 1970) 참조.

Page 122. 남아프리카(South Africa). 남아프리카 헌정 위기에서 배울 수 있는 중요한 법이론적 교훈을 보다 심층적으로 검토하려면, Marshall, 앞서 인용한 저서, 제11장을 참조하라.

CHAPTER VI 제3판 주석

Pages 100-1. *Sources of law*. 법이 원천(sources)을 가진다는 사상이 갖는 이론적 중요성에 대해서는 Joseph Raz, *The Authority of Law*, chap. 3을 보라. 보통법(common law)과 관습(custom)을 법의 원천으로 다룬 논의는 Gerald J. Postema, *Bentham and the Common Law Tradition* (Oxford University Press, 1986) 및 John Gardner, 'Some Types of Law', 그의 저서 *Law as a Leap of Faith* 제3장을 참조하라.

Hart의 승인 규칙(rule of recognition) 개념에 대한 비판은 Joseph Raz, *The Concept of a Legal System*, chap. 8, 특히 pp. 197-200; Joseph Raz, *The Authority of Law*, chap. 5, 특히 pp. 90-97; Ronald Dworkin, *Taking Rights Seriously*, pp. 39-45, 62-68을 참조하라. 승인 규칙을 의미론적 교리로 해석한 그의 견해는 Ronald Dworkin, *Law's Empire*, pp. 31-35에서 볼 수 있다.

Pages 101-3. *The rule of recognition and the practice of the courts*. Hart에게 있어 최종 승인 규칙은 공직자(officials)의 실천들 속에 내재한다. 그런데 공직자가란 법에 의해 그렇게 규정된 자라면, 순환논증의 우려가 제기될 수 있다. 즉, 어떤 것이 법이라는 것은 승인 규칙에 의해 식별되는 것이며, 어떤 것이 승인 규칙이라는 것은 공직자에 의해 실천되는 것이며, 어떤 사람이 공직자라는 것은 법에 의해 그러한 권한을 부여받은 자라는 것이기 때문이다. 이에 대한 해결 방안은 Neil MacCormick, *H. L. A. Hart*, pp. 108-120; Michael Bayles, *Hart's Legal Philosophy*, pp. 81-83을 참조하라.

Pages 103-4. *Legal validity*. Hart는 '유효(validity)'라는 개념을 주로 체계 소속(system membership)의 문제로 다룬다. 이에 대비되는 견해로는 Kelsen, *Pure Theory of Law*, pp. 10-15, 193-195가 있다. 그는 "'유효(valid)'란 그 규범이 구속력을 가지며, 한 개인이 그 규범이 정한 방식으로 행위해야 한다는 것을 의미한다"(p. 193)고 말한다. 법적 맥락에서 '유효성(validity)'이라는 개념의 다양한 의미에 대해서는 J. W. Harris, *Law and Legal Science: An Inquiry into the Concepts Legal Rule and Legal System* (Oxford University Press, 1979), chap. 4를 참조하라. Hart의 유효성 개념에 대한 평가는 Joseph Raz, *The Authority of Law*, chap. 8에 실려 있다. 유효성의 정도(degrees of validity)라는 가능성에 대해서는 John Finnis, *Natural Law and Natural Rights*, pp. 276-281을 보라.

Pages 103-5. *The efficacy of law*. Hart의 유효성 정의는 의무적 규칙(mandatory

rules)에만 적용된다(“법률 규칙이 요구하는 행동이 대체로 지켜지는 사실”: p. 103). 그렇다면 허용적(permissive) 혹은 권한 부여 규칙(power-conferring rules)의 유효성은 어떻게 되는가? 이에 대해서는 Joseph Raz, *The Concept of a Legal System*, chap. 9; *The Authority of Law*, chap. 5, 특히 pp. 85-90을 참조하라. 또한 Gerald Postema, ‘Conformity, Custom, and Congruence: Rethinking the Efficacy of Law’, Matthew H. Kramer et al. 편, *The Legacy of H. L. A. Hart: Legal, Political, and Moral Philosophy* (Oxford University Press, 2008)도 함께 보라.

Pages 105-10. *The rule of recognition as ultimate and supreme*. Hart는 ‘승인 규칙(rule of recognition)’이라는 용어를 한 법체계 내의 다른 모든 규칙들의 유효성을 판단할 기준을 제공하면서도, 그 자체는 다른 어떤 규칙에 의해서도 정당화되지 않는 하나의 관습적 사회 규칙을 지칭하는 데 사용한다. 다음 사항에 유의하라.

- (1) 승인 규칙은 판사들과 기타 공직자들의 관습적 규칙이지, 법으로 제정된 것이 아니며 제정법(positive law)이 아니다. 특히, 그것은 공식 헌법이나 그 일부가 아니다. (그러한 헌법은 그 자체로 승인 규칙에 의해 유효성이 부여되어야 한다.) 이 점에 대해 혼란이 매우 많다. 이에 대한 논의로는 Kent Greenawalt, ‘The Rule of Recognition and the Constitution’ (1987) 85 *Michigan Law Review* 621; Matthew Adler and Kenneth Himma 편, *The Rule of Recognition and the U.S. Constitution* (Oxford University Press, 2009) 수록 논문들; John Gardner, ‘Can there be a Written Constitution’, Leslie Green and Brian Leiter 편, *Oxford Studies in Philosophy of Law*, vol. I (Oxford University Press, 2011) 및 그의 저서 *Law as a Leap of Faith* (Oxford University Press, 2012) 제4장을 참조하라.
- (2) Hart는 승인 규칙이 “그것이 그 집단의 규칙임을 결정적으로 긍정하는 지표(conclusive affirmative indication)를 제공하는 특징들”을 명시한다고 말하고(94쪽), 그것이 “기본 규칙들을 결정적으로 식별하는 규칙”(95쪽)이라고 말하지만, 이를 승인 규칙의 기준이 완전하고 결정적이라는 의미로 이해해서는 안 된다. 그는 그것을 명시적으로 부정한다(147-154쪽, 257-259쪽 참조).
- (3) Hart는 각 법체계에 정확히 하나의 승인 규칙이 존재한다고 아무런 논증 없이 전제한다. 그러나 이에 대해서는 Joseph Raz가 의문을 제기한다. *The Authority of Law*, 95-96쪽 참조.

Pages 114-16. *Officials and secondary rules*. 흔히 두 가지 서로 다른 질문이 혼동된다: (a) 승인 규칙을 구성하는 행위자는 누구인가? (b) 승인 규칙에 의해 규율되는

행위자는 누구인가? (a)에 답할 때 Hart는 때로 ‘공직자들(officials)’(115, 116쪽)을, 때로는 ‘판사들(judges)’(108, 116쪽, 256쪽 참조)을 언급한다. Joseph Raz는 판사와 같은 법 적용 공직자들이 특히 중요하다고 주장한다: *The Authority of Law*, chap. 6 참조. (b)에 관해서는 의문의 여지가 없다. 승인 규칙은 모든 공직자를 구속한다. 공직자 특히 법 적용 공직자의 우선성은 정치적 도덕의 교리가 아니라는 점에 유의하라. 법원이 실질적으로 끼치는 영향이 유감스러울 수 있다는 점도 Hart의 주장과 모순되지 않는다. 이에 대한 정치적 문제는 예컨대 Mark Tushnet, *Taking the Constitution Away from the Courts* (Princeton University Press, 1999)를 보라.

Pages 116–17. Obedience and the ordinary citizen. 이 부분은 Hart가 법을 사회 제도로 평가하는 맥락을 이해하는 데 핵심이 되는 대목이다. 그는 법이 도덕적 위험을 수반한다는 점뿐 아니라, 그 위험이 법의 본질과 밀접하게 연결되어 있다는 점을 주장한다. 이에 대한 논의로는 Jeremy Waldron, ‘All We Like Sheep’ (1999) 12 *Canadian Journal of Law and Jurisprudence* 169 및 Leslie Green, ‘Positivism and the Inseparability of Law and Morals’ (2008) 83 *New York University Law Review* 1035, 특히 1052–1054쪽을 참조하라.

Pages 117–23. Pathology of a legal system. John Finnis, ‘Revolutions and Continuity of Law’, 그의 저서 *Philosophy of Law: Collected Essays Volume IV* (Oxford University Press, 2011)의 제21장을 보라. 법체계 간 상호작용의 가능성에 대해서는 Neil McCormick, *Questioning Sovereignty: Law, State and Nation in the European Commonwealth* (Oxford University Press, 1999), chap. 7을 참조하라.

VII. 형식주의(Formalism)와 규칙 회의주의 (Rule-Scepticism)

1. 법의 개방적 직조(The Open Texture of Law)

어떤 대규모 집단에서든, 일반 규칙, 기준, 원칙은 사회 통제의 주요 수단이 되어야 하며, 각 개인에게 개별적으로 지시를 내리는 방식은 주요 수단이 될 수 없다. 수많은 개인들이 특정한 상황이 발생했을 때 어떤 행동을 요구받는지 이해할 수 있도록, 일반적인 행동 기준을 별도의 지시 없이도 전달할 수 없다면, 우리가 현재 법이라고 인식하는 것은 존재할 수 없을 것이다. 따라서 법은 필연적으로, 그러나 결코 전적으로는 아니며, 사람의 부류들(classes), 행위, 사물, 상황의 부류들(classes)을 지시하게 되며, 사회생활의 광범위한 영역에서 법이 성공적으로 작동하기 위해서는 사람들이 법이 설정한 일반적 범주에 따라 구체적인 행위, 사물, 상황을 인식할 수 있는 광범위한 능력이 분포되어 있어야 한다.

이러한 일반적인 행동 기준을, 적용될 각 상황에 앞서 전달하는 데 사용된 두 가지 주요한 방식이 있다. 언뜻 보기에 이 둘은 매우 달라 보이나, 각각은 분류어(classifying words)의 사용 정도에서 하나는 최대치, 다른 하나는 최소치를 나타낸다. 첫 번째 방식은 우리가 입법(legislation)이라고 부르는 것으로 대표되고, 두 번째는 선례(precedent)이다. 우리는 다음의 단순한 비법적 사례에서 이 두 방식의 차이를 볼 수 있다. 한 아버지가 교회에 가기 전에 아들에게 이렇게 말한다. “모든 남성과 소년은 교회에 들어갈 때 모자를 벗어야 한다.” 다른 아버지는 교회에 들어가며 모자를 벗고는 “봐라, 이런 상황에선 이렇게 행동하는 게 맞다”고 말한다.

예시를 통해 행동 기준을 전달하거나 가르치는 방식은 훨씬 더 정교한 형태를 취할 수도 있다. 우리의 사례는, 만약 아이가 특정한 상황에서 아버지가 교회에 들어갈 때 했던 행동을 옳은 행동의 예로 간주하라는 지시를 받은 것이 아니라, 아버지가 (p. 125) 스스로를 적절한 행동의 권위자로 간주하고, 아이

역시 그를 그렇게 보아 그의 행동을 관찰함으로써 어떻게 행동해야 할지를 배우려고 한다면, 보다 법적 의미에서의 선례 사용에 더 가까울 것이다. 법적 선례 사용에 좀 더 다가가기 위해서는, 그 아버지가 자신이나 타인 모두에게 있어 전통적인 행동 기준에 따르는 사람으로 인식되고, 새로운 행동 기준을 만들어내려는 것이 아니라는 점이 전제되어야 한다.

예시를 통한 전달 방식은 ‘내가 하는 대로 해라’와 같은 몇 가지 일반적인 언어적 지시가 동반되더라도, 의도된 의미에 대해 – 그것이 전달하려는 사람이 명확하게 떠올린 것일지라도 – 가능한 해석의 범위를 열어두고, 그로 인해 의문과 가능성을 남길 수 있다. 얼마나 많은 부분을 모방해야 하는가? 오른 손 대신 왼손을 사용해 모자를 벗는 것이 문제가 되는가? 천천히 하는 것과 재빠르게 하는 것 사이에 차이가 있는가? 모자를 좌석 아래에 두는 것, 교회 안에서 모자를 다시 쓰지 않는 것 등은 문제가 되는가? 이 모든 것은 아이가 스스로에게 물을 수 있는 보다 일반적인 질문의 다양한 변형이다. ‘내 행동이 그의 행동과 어떻게 유사해야 옳은 행동이 될까?’ ‘그의 행동 가운데 정확히 어떤 요소가 내 지침이 되어야 하는가?’ 예시를 이해하는 과정에서 아이는 그 행동의 어떤 측면에는 주목하고, 다른 측면은 간과한다. 그 과정에서 아이는 상식과, 어른들이 중요하다고 여기는 사물과 목적에 대한 일반적인 지식, 그리고 (교회에 가는 것과 같은) 상황의 일반적 성격과 그에 걸맞은 행동 유형에 대한 이해에 의해 인도된다.

권위 있는 예시들의 불확정성(indeterminacies)과 대조적으로, 명시적이고 일반적인 언어 형식(예: “모든 남성은 교회에 들어갈 때 모자를 벗어야 한다”)을 통한 일반 기준의 전달은 분명하고, 신뢰할 수 있으며, 확실한 것처럼 보인다. 행동의 일반적인 지침으로 삼아야 할 특징들은 여기서 명확하게 언어로 지시되며, 다른 요소들과 뒤섞인 구체적인 예시 속에 남겨지지 않고 언어적으로 추출되어 있다. 아이는 이후의 다른 상황에서 어떻게 행동해야 할지를 알아내기 위해, 더 이상 그 의도가 무엇인지, 또는 무엇이 인식받을 행동일지를 추측하지 않아도 된다. 아이는 자신의 행동이 그 예시와 어느 정도 유사해야 올바른 것인지 추측해야 할 필요가 없다. 대신, 아이는 향후 무엇을 언제 해야 할지를 알아낼 수 있는 언어적 설명을 갖고 있다. 그는 단지 명확한 언어 표현의 사례들을

인식하고, 구체적 사실들을 일반적인 분류 항목에 ‘포섭(subsume)’하여 단순한 삼단논법적 결론을 도출하기만 하면 된다. (p. 126) 그는 이제 위험을 감수하며 선택하거나, 더 권위 있는 지침을 찾아야 하는 선택지에 직면하지 않는다. 그는 스스로에게 적용할 수 있는 규칙(rule)을 갖고 있다.

20세기의 법이론(jurisprudence)의 많은 부분은, 권위 있는 예시(선례(precedent))를 통한 전달의 불확실성과 권위 있는 일반 언어(입법(legislation))를 통한 전달의 확실성 사이의 구분이 이 순진한 대비가 시사하는 것만큼 확고하지 않다는 중요한 사실을 점차 인식하거나(때때로는 과장되게) 강조해온 과정이었다. 언어적으로 정식화된 일반 규칙이 사용될 때조차, 그 규칙이 요구하는 행위의 형태에 관한 불확실성은 특정한 구체적 사례에서 발생할 수 있다. 구체적인 사실 상황은 일반 규칙의 적용 여부가 문제되는 사안의 사례로서 미리 서로 구분되고 표시되어 있는 것이 아니며, 규칙 자체가 나서서 스스로의 사례라고 주장할 수도 없다. 규칙의 영역뿐 아니라 모든 경험의 영역에서는, 일반 언어가 제공할 수 있는 지침에는 언어의 본성에 내재한 한계가 존재한다. 유사한 맥락에서 반복적으로 발생하며 일반적 표현이 분명히 적용되는 명백한 사례들(예: “무엇이 차량이라면, 자동차는 틀림없이 차량이다”)이 분명 존재하지만, 그 표현이 적용되는지 불분명한 사례들(예: “여기서 ‘차량(vehicle)’이라는 표현은 자전거나 비행기, 롤러스케이트도 포함하는가?”)도 있다. 후자의 경우는, 자연이나 인간의 발명에 의해 끊임없이 등장하며, 명백한 사례의 일부 특징만을 가지되 다른 특징은 결여한 사실 상황들이다. ‘해석의 규범(canons of interpretation)’은 이러한 불확실성을 줄일 수는 있어도 없앨 수는 없다. 왜냐하면 이 규범들 역시 언어 사용에 관한 일반 규칙들이며, 그 자체가 해석을 요하는 일반 용어들을 사용하기 때문이다. 이러한 규칙들 역시 다른 규칙들과 마찬가지로 자기 자신의 해석을 제공할 수 없다. 해석이 필요 없어 보이며 분류 용어의 적용 사례 인식이 문제없거나 ‘자동적’으로 보이는 명백한 사례들은, 사실 유사한 맥락에서 반복적으로 나타나는 친숙한 것들일 뿐이다. 이러한 경우에는 분류 용어의 적용에 대해 판단이 일치하는 일반적 합의가 존재한다.

만약 그러한 익숙하고 일반적으로 이의 제기되지 않는 사례들이 없다면, 일반 용어는 의사소통의 매체로서 무용지물이었을 것이다. 그러나 익숙한 사

례들에 대한 다양한 변형들은 여전히, (p. 127) 우리가 현재 언어 자원 속에 포함시킨 일반 용어들 아래로 분류(classification)되어야 한다. 여기서 일종의 의사소통의 위기(crisis in communication)가 촉발된다. 일반 용어를 사용하는 것과 사용을 거부하는 것 사이에 모두 합당한 이유가 존재하며, 그것을 사용할지 여부에 대해 분명한 관습이나 일반적 합의가 존재하지 않는다. 이러한 경우 의문을 해결하기 위해서는, 누군가가 개방적 직조 여러 대안들 사이에서 선택(choice)을 내려야 한다.

이 지점에서, 규칙이 표현된 권위 있는 일반 언어(general language)는 예시처럼 불확실하게만 지침을 제공할 수 있을 뿐이다. 규칙의 언어가 우리가 쉽게 인식 가능한 사례들을 단순히 골라낼 수 있도록 해준다는 감각은 이 지점에서 무너진다. 이때는 더 이상 ‘포섭(subsumption)’이나 삼단논법적 결론 도출이 무엇이 올바른 행동인지를 판단하는 추론의 핵심을 구성하지 않는다. 대신, 규칙의 언어는 이제 단지 하나의 권위 있는 예시(plain case)를 지시할 뿐이며, 그것은 선례(precedent)처럼 활용될 수 있다. 다만, 규칙의 언어는 주목해야 할 특징들을 선례보다 더 영구적이고 밀접하게 제한한다. 예컨대, 공원 내 차량 이용을 금지하는 규칙이 어떤 복합적인 상황에서 적용될 수 있는지 불확정적인 경우, 이 질문에 답해야 할 사람은 (선례를 활용하는 이와 마찬가지로) 현재의 사례가 명백한 사례와 ‘관련된(relevant)’ 측면에서 ‘충분히(sufficiently)’ 유사한지를 고려할 수밖에 없다. 언어가 남겨준 재량(discretion)은 매우 넓을 수 있다. 따라서 그가 규칙을 적용하더라도, 그 결론이 자의적이거나 비합리적인 것은 아니더라도, 실질적으로는 선택의 행위가 된다. 그는 법적으로 관련 있고 충분히 유사하다고 합리적으로 옹호할 수 있는 유사성 때문에 새로운 사례를 기존 사례의 연속선상에 추가하기로 선택하는 것이다. 법적 규칙의 경우, 유사성의 관련성(relevance)과 밀접성(closeness)을 판단하는 기준은, 법체계 전반에 걸친 복잡한 요소들과, 해당 규칙에 부여될 수 있는 목적 또는 목표에 따라 달라진다. 이를 규명하는 것은 곧 법적 추론(legal reasoning)에 특유한 요소들을 규명하는 것이다.

전달 수단으로 선례(precedent)나 입법(legislation) 중 어느 것이 선택되든, (p. 128) 이러한 기준들이 수많은 일반적인 사안들에서는 원활히 작동하더라도,

적용이 문제되는 어떤 지점에서는 불확정적(indeterminate)일 수밖에 없으며, 이로 인해 소위 개방적 직조(open texture)를 갖게 된다. 지금까지 우리는 입법의 경우에 한해 이를 인간 언어의 일반적 특징으로 제시해 왔다. 즉, 사실(fact)에 관한 소통에서 일반적 분류 용어를 사용하는 데 따르는 대가로, 경계 지점(borderline)에서의 불확실성을 감수해야 한다는 것이다. 영어와 같은 자연어(natural language)는 그렇게 사용될 때 본질적으로 개방적 직조를 지니며, 완전히 환원될 수 없다. 그러나 언어 자체가 현실적으로 개방적 직조를 갖는다는 점 외에도, 우리는 어떤 규칙이 특정한 사안에 적용되는지의 여부가 항상 사전에 결정되어 있으며, 실제 적용 시점에서는 개방적 직조 대안들 중에서 새롭게 선택할 필요가 전혀 없는, 그러한 세부적 규칙의 개념조차도 이상적 모델로 간직해서는 안 된다는 사실을 이해하는 것이 중요하다. 간단히 말하자면, 그 이유는 우리가 신이 아니라 인간이기 때문이다. 이는 인간 존재 조건(human predicament)의 특징이며, 따라서 입법 상황의 특징이기도 하다. 우리는 어떤 행위 영역을 개별적 지침 없이 일반 기준에 따라 사전에 명확히 규율하려고 할 때마다 두 가지 연결된 제약 아래 놓이게 된다. 첫 번째 제약은 사실(fact)에 대한 상대적인 무지(ignorance)이며, 두 번째는 목적(aim)의 상대적 불확정성(indeterminacy)이다. 만약 우리가 살아가는 세계가 유한한 수의 특성들만으로 구성되어 있고, 그 특성들이 결합될 수 있는 모든 방식이 우리에게 알려져 있다면, 모든 가능성에 대해 사전에 대비할 수 있었을 것이다. 우리는 개별 사례에 적용할 때 더 이상의 선택을 요구하지 않는 규칙들을 만들 수 있었을 것이다. 모든 것이 알려질 수 있고, 알려질 수 있다면, 모든 것에 대해 어떤 조치를 취하고 그것을 규칙으로 명시할 수 있다. 이것이 바로 ‘기계적 법학(mechanical jurisprudence)’에 적합한 세계일 것이다.

그러나 명백히, 이 세계는 우리의 세계가 아니다. 인간 입법자는 미래가 가져올 수 있는 모든 상황 조합을 그렇게 알 수 없다. 이러한 예측 불가능성은 곧 목적의 불확정성(indeterminacy of aim)을 수반하게 된다. 우리가 어떤 일반적 행동 규칙을 과감히 제정할 때(예: “공원에는 차량을 반입할 수 없다”는 규칙), (p. 129) 이때 사용되는 언어는 그 규칙의 범위 내에 포함되기 위해 어떤 조건들이 필수적인지를 고정하며, 그 범위에 확실히 포함된다고 판단되는

몇몇 명확한 사례들이 우리의 마음속에 떠오른다. 즉, 자동차, 버스, 오토바이 등은 전형적인(paradigm) 명백한 사례들(clear cases)이며, 이 지점에서 우리의 입법 목적은 명확하다. 우리는 평온함을 유지하는 것을 위해서, 적어도 이러한 사물들을 공원에서 제외하는 대가를 치르겠다고 결정한 것이다. 그러나 우리는 공원의 평온이라는 일반적인 목적을 처음에는 전혀 상정하지 않았거나 상정할 수 없었던 사례들(예: 전기로 움직이는 어린이용 장난감 자동차 등)과 결합시켜 보지 않았기 때문에, 이 방향에서는 우리의 목적이 불명확하다. 우리는 예상하지 못한 사례가 발생할 때 제기될 문제, 즉 공원의 어느 정도 평온함을 아이들이 이와 같은 물건을 사용하는 즐거움과 이해에 비해 희생할 것인지 아니면 방어할 것인지에 대해 결정을 내리지 않았다. 이러한 예기치 못한 사례가 실제로 발생했을 때 우리는 당면한 쟁점을 마주하게 되고, 그때 서로 경쟁하는 이해관계들 사이에서 우리에게 가장 만족스러운 방식을 선택함으로써 그 문제를 해결할 수 있다. 그렇게 함으로써 우리는 초기의 목적을 보다 명확하게 만들고, 부수적으로는 이 규칙의 목적상 어떤 일반 용어가 어떤 의미를 갖는지를 결정하게 된다.

법체계가 서로 다르거나 동일한 체계라도 시간에 따라 달라질 경우, 일반 규칙을 구체적 사례에 적용할 때 추가적인 선택의 필요성을 얼마나 더 인정하거나 무시하느냐는 다양할 수 있다. 법이론에서 형식주의(formalism) 또는 개념주의(conceptualism)로 알려진 병폐는, 언어로 정식화된 규칙에 대한 태도에서 비롯되며, 일반 규칙이 일단 수립되면 그 이후에는 더 이상의 선택의 필요성을 숨기거나 최소화하려는 경향을 말한다. 이를 수행하는 한 가지 방법은 규칙의 의미를 고정(freeze)시켜서, 규칙이 적용되는 모든 경우에 그 일반 용어들이 동일한 의미를 갖도록 만드는 것이다. 이를 위해 우리는 명백한 사례에 존재하는 특정한 특징들에 주목하고, 그러한 특징들이 어떤 사물이 규칙의 적용 대상이 되기 위해 반드시 갖추어야 할 필요조건이자 동시에 충분조건이라고 주장하게 된다. 이때 해당 사물이 어떤 다른 특징을 갖고 있든 없든, 또 그렇게 적용했을 때 사회적 결과가 어떠하든 관계없이 말이다. 이렇게 하는 것은 어느 정도의 확실성(certainty)이나 예측 가능성(predictability)을 확보하는 방식이지만, (p. 130) 동시에 우리가 그 구성을 알지 못하는 미래의 다양한 사례들에 대해 사전에, 어둠 속에서 미리 판단을 내려버리는 것과 같다. 이러한 방식은,

특정 규칙을 유지하거나 사회적 목적을 달성하려는 합리적 노력과 충돌할 수 있는 사례들을 규칙 적용 범위에 포함시키도록 우리를 강요할 수 있다. 그리고 이와 같은 사례들은, 우리가 그 의미를 더 덜 경직되게 정의했다라면, 언어의 개방적 직조에 따라 제외시킬 수도 있었던 사례들이다. 결국 우리의 분류 기준이 지나치게 경직되면, 우리가 그 규칙을 보유하거나 유지하려는 목적과 충돌하게 된다.

이 과정의 완성은 법학자들의 ‘개념의 천국(heaven of concepts)’이다. 이는 하나의 규칙(rule)의 모든 적용 사례에서뿐 아니라, 그 용어가 법체계 내의 다른 어떤 규칙에 나타나더라도 항상 동일한 의미를 부여받을 때 도달된다. 이렇게 되면 그 용어가 다양한 맥락에서 어떤 쟁점들과 관련되어 있는지를 고려하여 해석하려는 시도 자체가 전혀 필요 없고, 실제로 그러한 시도는 이뤄지지 않는다.

그러나 실제로 모든 법체계는 두 가지 사회적 필요 사이에서 서로 다른 방식으로 절충한다. 하나는 광범위한 행위 영역에 걸쳐 개인이 별도의 공식적 지침이나 사회적 쟁점에 대한 고려 없이도 스스로 적용할 수 있는 확정적인(certain) 규칙이 필요한 것이고, 다른 하나는 그러한 쟁점들이 실제로 발생한 구체적 사례에서야 비로소 적절히 이해되고 해결될 수 있기 때문에, 그것들을 후일에 정보에 기반한 공식적 선택에 맡겨 열어두어야 하는 필요이다. 어떤 법체계는 특정 시기에 확실성을 지나치게 중시한 나머지, 선례나 법률의 해석이 지나치게 형식적으로 되어, 유사성과 차이를 제대로 반영하지 못하게 된다. 이러한 유사성과 차이는 오직 사회적 목적(social aims)의 관점에서 사례를 검토할 때에만 비로소 드러나는 것이다. 반대로 다른 법체계나 시기에는, 선례(precedent)에 있어 법원이 지나치게 많은 문제를 언제나 열어 있고 수정 가능한 것으로 취급하고, 그 결과로 입법 언어가 – 비록 개방적 직조를 갖고 있긴 하지만 – 제공하는 한계마저도 충분히 존중하지 않는 경우가 있을 수 있다. 법이론(legal theory)은 이 문제에 있어 기묘한 역사를 가지고 있다. 그것은 법적 규칙의 불확정성(indeterminacies)을 무시하거나 과장하는 경향을 지니기 때문이다. 이러한 양극단을 오가는 진동에서 벗어나기 위해, 우리는 이러한 불확정성의 근본 원인인 미래에 대한 인간의 예측 불가능성(human inability to anticipate the future)이 (p. 131) 행위 영역마다 정도의 차이를 가지고 있다는

점을 상기할 필요가 있다. 법체계는 이에 대응하여 다양한 기술들을 통해 이러한 예측 불가능성에 적절히 대응하고 있다.

때로는, 법적으로 규율되어야 할 영역이 처음부터 인정된다. 그 영역은 개별 사례의 특성이 사회적으로 중요한 방식으로 매우 다양하게, 그리고 예측 불가능하게 달라지기 때문에, 입법자가 사전에 별도의 공식 지침 없이도 사례마다 일관되게 적용할 수 있는 규칙을 유용하게 구성할 수 없다는 것이다. 따라서 이러한 영역을 규율하기 위해 입법자는 매우 일반적인 기준(*general standards*)을 설정하고, 다양한 유형의 사례에 익숙한 행정 규칙 제정 기구(*administrative, rule-making body*)에 그러한 기준을 그 특별한 필요에 맞게 구체화하는 과제를 위임(*delegate*)한다. 예를 들어, 입법자는 어떤 산업에 대해 일정한 기준을 유지하도록 요구할 수 있다. 예컨대 공정한 요율(*fair rate*)만을 부과하거나 작업의 안전한 체계(*safe systems*)를 제공하라고 요구하는 것이다. 그러나 이러한 모호한 기준을 각각의 사업체가 스스로 적용하도록 두고, 사후적으로(*ex post facto*) 그것을 위반했는지 판단받도록 하는 것은 위험할 수 있다. 따라서 이러한 경우에는, 제재의 적용(*sanctions for violations*)을 행정 기구가 규제를 통해 특정 산업에 있어 ‘공정한 요율’ 또는 ‘안전한 체계’로 간주될 수 있는 것이 무엇인지 구체적으로 규정할 때까지 유보하는 것이 최선일 수 있다. 이러한 규칙 제정 권한(*rule-making power*)은, 특정 산업에 관한 사실(*fact*)에 대해 사법적 조사(*judicial inquiry*)와 관련된 찬반 논증의 청문(*hearing*)을 거친 이후에만 행사될 수 있는 형태일 수도 있다.

물론 매우 일반적인 기준(*general standards*)이 있더라도, 이를 만족하거나 만족하지 않는 명백하고 논쟁의 여지가 없는 사례들은 항상 존재한다. ‘공정한 요율(*fair rate*)’이나 ‘안전한 체계(*safe system*)’가 무엇인지에 대해 극단적인 경우들만큼은 처음부터(*ab initio*) 식별 가능하다. 즉, 무한히 다양한 사례들 중 한쪽 극단에는 공공에게 필수 서비스를 제공하면서 기업가에게 막대한 이윤을 안겨주는, 지나치게 높은 요율이 있을 수 있다. 반대편 극단에는 사업 운영 자체의 유인을 제공하지 못할 정도로 낮은 요율이 있다. 이 두 극단은 각각 서로 다른 방식으로 요율 규제를 통해 우리가 달성하고자 하는 어떤 목적이든 좌절시키게 된다. 그러나 이들은 단지 여러 요인의 범위 중 극단에 해당하며,

실제로는 좀처럼 마주치지 않는다. 그 사이에는 어려운 실제 사례들이 존재하며, 이것들이 주된 관심 대상이 된다. 관련 요인의 조합 중 예측 가능한 것들은 많지 않으며, 이로 인해 ‘공정한 요율’이나 ‘안전한 체계’라는 초기 목표는 상대적으로 불확정적(indeterminate)일 수밖에 없고, 그에 따라 추가적인 공식적 (p. 132) 선택(official choice)이 요구된다. 이러한 경우, 규칙 제정 권한(rule-making authority)은 명백히 재량(discretion)을 행사해야 하며, 다양한 사례에서 제기 되는 쟁점을 마치 하나의 유일하게 정답이 있는 문제로 다룰 수는 없다. 오히려 많은 상충되는 이해관계 사이에서의 합리적인 타협(resonable compromise)으로 받아들여질 수 있는 해답이 필요하다.

이와 유사한 두 번째 기술은, 규율하고자 하는 영역이 특정 행위들의 범주를 식별해 이를 일률적으로 시행하거나 금지하는 단순 규칙(simple rule)의 형태로 만들 수는 없지만, 다양한 상황들이 일반적인 경험 속의 익숙한 특성들을 포함 하는 경우에 사용된다. 이때 법은 ‘합리적인(reasonable)’ 것이 무엇인가에 대한 일반적 판단(common judgments)을 활용할 수 있다. 이러한 기술은 다양한 예측 불가능한 형태로 등장하는 사회적 요구들 사이의 균형을 사려 깊게 판단하여, 개인이 법원의 교정 가능성 하에 스스로 결정하도록 맡긴다. 이 경우, 개인은 사전에(before) 공식적으로 정의되지 않은 가변적 기준(variable standard)을 준수해야 하며, 자신이 이를 위반했는지를 사후적으로(ex post facto) 법원으로부터 비로소 배우게 된다. 이러한 사안에 대한 법원의 결정이 선례(precedent)로 간주될 경우, 이 가변적 기준의 명시는 행정기구의 위임 입법적 결정(delegated rulemaking power)과 매우 유사하게 작용한다. 물론 양자 간에는 분명한 차이 점도 존재한다.

영미법(Anglo-American law)에서 이러한 기술의 가장 유명한 예는 과실(negligence) 사건에서 ‘상당한 주의(due care)’의 기준을 사용하는 경우이다. 타인에게 신체적 피해를 가하지 않기 위해 합리적인 주의를 기울이지 않은 자에게 민사상 또는 경우에 따라 형사상의 제재가 가해질 수 있다. 그러나 구체적인 상황에서 ‘합리적인 주의(reasonable care)’ 또는 ‘상당한 주의(due care)’란 무엇인가? 물론 우리는 ‘정지하고, 살피고, 들으라(stop, look, and listen)’는 식의 전형적인 주의 사례를 제시할 수 있다. 그러나 우리는 모두, 주의가

요구되는 상황들이 매우 다양하다는 것과, ‘정지하고, 살피고, 들으라’ 외에도 또는 그 대신에, 많은 다른 조치들이 요구된다는 사실을 잘 알고 있다. 실제로 상황에 따라서는 ‘보는 것’이 위험을 피하는 데 아무 도움이 되지 않아, 위의 조치들만으로는 충분하지 않을 수도 있다. ‘합리적인 주의’ 기준을 적용할 때 우리가 추구하는 것은 다음 두 가지이다. (1) 실질적 피해를 방지할 수 있는 (p. 133) 예방 조치가 취해질 것, (2) 동시에 그 조치가 다른 정당한 이해관계들을 지나치게 희생시키지 않을 것. 예를 들어 ‘정지하고, 살피고, 들으라’는 방식은 일반적으로 별다른 희생 없이 이행할 수 있다. 단, 예외적으로 출혈이 심한 환자를 병원으로 이송 중인 경우처럼 긴급한 상황이라면 예외일 수 있다. 그러나 주의가 요구되는 사례는 워낙 다양한 조합의 상황들이 있을 수 있으므로, 우리가 어떤 상황이 발생할지 또는 그 상황에서 어떤 이해관계들이 얼마나 희생되어야 할지를 처음부터(ab initio) 예견할 수 없다. 따라서 우리는 구체적인 사례가 발생하기 이전에는, 피해를 줄이기 위해 어떤 가치나 이해관계를 희생시킬지에 대한 정확한 판단을 내릴 수 없다. 다시 말해, 사람들을 피해로부터 보호하고자 하는 우리의 목표는, 그것이 실제 경험을 통해 제시되는 가능성과 결합되기 전까지는 불확정적(indeterminate)이다. 그러나 일단 사례가 발생하면, 우리는 직면한 쟁점을 판단하여 결정해야 하며, 그러한 결정이 내려질 때, 우리의 초기 목표는 그에 비례하여(pro tanto) 보다 확정적인 것이 된다.

이 두 가지 기술(techniques)을 고려해 보면, 처음부터(ab initio) 특정한 행위를 요구하는 규칙(rule)에 의해, 가변적인 기준(variable standard)이 아니라, 오직 열린 직조(open texture)의 주변부에만 존재하는 방식으로 성공적으로 통제되고 있는 넓은 범주의 행위 영역의 특성이 더욱 뚜렷하게 드러난다. 이러한 영역은 다음과 같은 특징을 갖는다. 즉, 특정한 구별 가능한 행위(action), 사건(event), 또는 상태(state of affairs)는, 그것을 방지하거나 실현시키는 것이 우리에게 매우 실질적인 중요성을 갖고 있어서, 그것과 함께 나타나는 다른 많은 상황들이 그것에 대한 우리의 평가를 바꾸게 만들 가능성이 거의 없다는 점이다. 이의 가장 단순한 예는 인간을 살해하는 행위(killing of a human being)이다. 인간이 서로를 살해하는 상황은 매우 다양함에도 불구하고, 우리는 ‘인간 생명에 대한 존중(due respect for human life)’이라는 가변적 기준을 설정하기보다는, 살인을

금지하는 명시적 규칙을 만들 수 있다. 이는 왜냐하면, 생명을 보호해야 한다는 중요성에 대한 우리의 판단을 뒤집을 수 있는 요소가 거의 없기 때문이다. 거의 대부분의 경우, 살인은 동반된 다른 요소들보다 지배적인(dominates) 요소로 작용한다. 따라서 우리가 그것을 미리 ‘살인(killing)’으로 규정하여 배제할 때, 우리는 상호 저울질되어야 할 사안들을 맹목적으로 선입적으로 판단하는 것이 아니다. 물론 예외는 존재한다. 이 지배적인 요소를 뛰어넘는 요소들—정당방위(self-defence)나 기타 정당한 살해(justifiable homicide)의 형태들—이 존재한다. 그러나 이들 예외는 적고 비교적 단순한 용어로 식별 가능하며, 일반 규칙에 대한 예외로서 인정된다.

(p. 134) 여기에서 주목해야 할 점은, 이렇게 명확하게 식별 가능한 행위(action), 사건(event), 또는 상태(state of affairs)가 지배적인 지위를 가지는 것이, 어느 의미에서는 관습적(conventional)이거나 인위적(artificial)일 수 있으며, 인간 존재로서 우리에게 ‘자연적(natural)’이거나 ‘본질적(intrinsic)’인 중요성 때문만은 아니라는 것이다. 예를 들어 도로 교통 규칙(rule of the road)에서 어느 쪽으로 차를 몰도록 규정하는가, 또는 부동산 양도(conveyance)의 집행을 위해 어떤 형식을 요구하는가 하는 것은, 그 자체로는 중요하지 않다. (물론 그 범위에는 일정한 한계가 있다.) 그러나 이러한 사안들에 있어서 명확히 식별 가능한 일관된 절차가 존재해야 하고, 그 결과로 명확한 옳고 그름(right and wrong)이 설정되어야 한다는 점은 매우 중요하다. 일단 이러한 규칙이 법률로 도입되면, 소수의 예외를 제외하고는 그 규칙을 준수하는 것이 매우 중요해진다. 왜냐하면 이를 무효화할 수 있는 부수적 상황들은 거의 없고, 있더라도 명확히 식별되어 규칙으로 환원될 수 있기 때문이다. 영국의 부동산법(real property law)은 이러한 규칙의 측면을 매우 명확하게 보여준다.

권위 있는 사례(authoritative examples)를 통해 일반 규칙을 전달하는 방식은, 앞서 본 바와 같이, 보다 복잡한 유형의 불확정성(indeterminacies)을 수반한다. 선례(precedent)를 법적 유효성의 기준으로 인식한다는 것은, 법체계마다, 또는 동일한 체계에서도 시대에 따라, 서로 다른 의미를 지닌다. 영국의 ‘선례 이론(theory of precedent)’에 대한 설명은 특정 쟁점들에 있어 여전히 매우 논쟁적이다. 실제로 이 이론에서 사용되는 핵심 용어들, 즉 ‘판결 이유(ratio

decidendi), ‘중요 사실(material facts)’, ‘해석(interpretation)’ 등은 각각 그 자체로 불확실성의 주변부(penumbra)를 가지고 있다. 우리는 여기에서 새로운 일반 이론을 제시하려는 것이 아니라, 단지 입법(statute)의 경우에서처럼, 불확실성의 영역(open texture)과 그 안에서 이루어지는 창조적 판결 활동(creative judicial activity)을 간략히 특징지으려는 것이다.

영국법에서의 선례(precedent) 사용에 대한 정직한 기술은 다음과 같은 대조적인 사실 쌍들을 포함해야 한다. 첫째, 주어진 권위 있는 선례가 권위의 근거가 되는 규칙(rule)을 결정하는 단일한 방법은 존재하지 않는다. 그럼에도 불구하고, 판결된 사건의 압도적 다수에서는 거의 의심의 여지가 없다. 헤드노트(head-note)는 보통 충분히 정확하다. 둘째, 어떤 사건에서 도출된 규칙에 대해 권위 있는 또는 유일하게 정확한 형식(formulation)은 존재하지 않는다. 그러나 다른 한편으로, 어떤 선례가 후속 사건에 적용될 수 있는지를 둘러싼 쟁점이 있을 때, 주어진 형식이 적절하다는 데에 일반적으로 널리 합의가 이루어지곤 한다. 셋째, 선례에서 도출된 규칙이 갖는 어떤 권위적 지위(authoritative status)가 있더라도, 그것은 그 규칙에 구속받는 법원이 (p. 135) 다음 두 가지 형태의 창조적 또는 입법적 활동을 수행하는 것과 양립 가능하다. 한편으로, 후속 사건을 다루는 법원은 선례에서 도출된 규칙의 범위를 좁히거나, 이전에 고려되지 않았거나 또는 고려되었지만 미결로 남겨졌던 예외를 인정함으로써, 그 선례와는 반대되는 결정을 내릴 수 있다. 이른바 ‘구별(distinguishing)’이라는 이 과정은, 과거 사건과 현재 사건 사이에 법적으로 관련 있는 차이(legally relevant difference)를 찾아내는 것을 포함하며, 이러한 차이의 범주는 결코 전면적으로 결정될 수 없다. 다른 한편으로는, 과거 선례에서 도출된 규칙에 있는 제한을, 그것이 어떤 제정법(statute)이나 더 오래된 선례에 의해 요구되는 것이 아니라는 이유로 폐기하면서 선례를 따르는 경우도 있다. 이것은 곧 규칙을 확장하는(widening) 행위이다. 이러한 두 가지 형태의 입법적 활동이 선례의 구속력에 의해 가능하다는 점에도 불구하고, 영국의 선례 체계는 그 사용을 통해 방대한 수의 규칙들—중요한 것과 사소한 것 모두 포함하여—을 생산하였고, 이 규칙들은 이제 제정법상의 규칙만큼이나 명확하게(determinate) 되었다. 이 규칙들은 이제 의회 입법에 의해서만 변경될 수 있으며, 법원 스스로도 선례상의 규정이

‘형평성(the merits)’에 반하는 것처럼 보이는 사건에서 이 점을 자주 명시한다.

법의 개방적 직조(open texture)는, 실제로 많은 경우의 행위 영역에서 구체적인 상황을 고려하여 상충하는 이익들 사이의 균형을 잡기 위한 법원이나 공무원의 판단에 의한 발전이 요구된다는 것을 의미한다. 그럼에도 불구하고, 법의 삶(life of the law)은 상당히 큰 범위에서, 변동 가능한 기준(variable standards)의 적용과는 달리, 매 사건마다 새로운 판단을 요구하지 않고 공무원과 일반 개인 모두를 이끄는 명확한 규칙들에 의해 구성되어 있다. 이러한 사회생활의 현저한 사실은, 어떤 규칙(성문이든, 선례를 통해 전달된 것이든)의 적용 가능성에 대한 불확실성이 발생할 수 있다는 점에도 불구하고 여전히 유효하다. 규칙의 경계 지점에서, 그리고 선례 이론이 열어 놓은 영역에서, 법원은 행정부가 가변적 기준들을 정교화할 때 중앙에서 수행하는 것과 유사한 규칙 생성(rule-producing)의 기능을 수행한다. 선례 존중의 원칙(stare decisis)이 확고히 인정된 체계에서, 법원의 이 기능은 행정부의 위임된 규칙 제정권(delegated rule-making powers)의 행사와 매우 유사하다. 영국에서는 이 사실이 형식(form)에 의해 종종 가려진다. 왜냐하면 법원은 (p. 136) 그러한 창조적 기능을 부인하고, 법령 해석과 선례 사용의 적절한 임무는 각각 ‘입법자의 의도(intention of the legislature)’와 이미 존재하는 법률을 탐색하는 것이라고 주장하기 때문이다.

2. 규칙 회의주의(rule-scepticism)의 여러 형태

법의 개방적 직조(open texture)에 대해 다소 길게 논의한 이유는, 이 특징을 올바른 관점에서 이해하는 것이 중요하기 때문이다. 이 점을 정당하게 다루지 못하면, 항상 법의 다른 측면을 가리는 과장된 주장들이 유발될 것이다. 모든 법 체계에서, 처음에는 모호한 기준을 명확히 하거나, 성문의 불확실성을 해결하거나, 권위 있는 선례(authoritative precedent)를 통해 대략적으로만 전달된 규칙들을 발전시키고 한정하는 데 있어, 법원이나 기타 공무원의 재량(discretion)이 행사될 수 있는 넓고 중요한 영역이 남아 있다. 그러나 이러한 활동들이 아무리 중요하고 충분히 연구되지 않았더라도, 이 활동들이 일어나는 틀(framework)

과 그 주된 산출물이 바로 일반 규칙(general rules)이라는 사실을 가려서는 안 된다. 이러한 규칙들은 개인이 각각의 사건에서 그 적용을 스스로 파악할 수 있는 규칙들로, 더 이상의 공적 지시나 재량 판단을 필요로 하지 않는다.

규칙들이 법체계의 구조에서 중심적인 자리를 차지한다는 주장이 진지하게 의심받을 수 있다는 것은 다소 이상하게 보일 수 있다. 하지만 ‘규칙 회의주의(rule-scepticism)’, 즉 규칙에 대한 논의는 허구이며, 법은 단지 법원의 결정(decision)과 그에 대한 예측(prediction)으로만 이루어져 있다는 주장은, 법률가의 솔직함에 강력하게 호소할 수 있다. 이러한 주장이 모든 2차 규칙(secondary rules)과 1차 규칙(primary rules)을 포함하는 무제한적이고 일반적인 형식으로 진술될 경우, 그것은 사실상 전혀 일관성이 없다. 왜냐하면 법원의 결정이 존재한다는 주장은, 규칙이 전혀 존재하지 않는다는 주장과는 양립할 수 없기 때문이다. 우리가 앞서 보았듯이, 법원의 존재는 변화하는 개인들에게 관할권(jurisdiction)을 부여하고 그들의 결정을 권위 있는 것으로 만드는 2차 규칙의 존재를 전제로 한다. 만약 어떤 공동체의 사람들이 결정(decision)이나 그 결정에 대한 예측(prediction)의 개념은 이해하지만, 규칙(rule)의 개념은 이해하지 못한다면, 그들은 권위 있는(authoritative) 결정이라는 개념 자체를 갖지 못할 것이며, 따라서 법원이라는 개념도 갖지 못할 것이다. 그렇게 되면 사인의 결정과 법원의 결정을 구분할 아무런 기준도 없게 된다. 우리는 (p. 137) ‘습관적 복종(habitual obedience)’이라는 개념을 이용하여, 법원에 요구되는 권위 있는 관할권의 기초로서 결정의 예측 가능성이 가진 결함을 메우려 할 수 있을지도 모른다. 하지만 그렇게 하면 우리는, 입법권을 부여하는 규칙의 대체물로서 습관(habit)을 고려했던 제4장에서 드러난 바로 그 모든 한계를 다시 마주하게 될 것이다.

이 이론의 보다 온건한 형태에서는, 법원이 존재하려면 반드시 그것을 구성하는 법적 규칙들이 있어야 하며, 그런 규칙들은 따라서 단순히 법원의 결정을 예측하는 것만으로는 성립되지 않는다는 점을 인정할 수도 있다. 그러나 이러한 양보만으로는 실제로는 거의 아무런 진전을 이루기 어렵다. 왜냐하면 이러한 유형의 이론에서는, 제정법(statutes)은 법원이 적용하기 전까지는 법이 아니며 단지 법의 원천(sources)일 뿐이라는 주장이 핵심적으로 제기되기 때문이다.

그런데 이러한 주장은, 법원을 구성하는 데 필요한 규칙만이 유일한 규칙이라고 주장하는 것과 양립할 수 없다. 왜냐하면 변화하는 개인들로 구성되는 집단에 입법권을 부여하는 2차 규칙들도 있어야 하기 때문이다. 이 이론은 제정법(statutes)의 존재 자체를 부정하지는 않는다. 오히려 그것들을 ‘법의 원천(sources of law)’이라고 인정하면서, 단지 법원이 적용하기 전까지는 그것들이 법이 아니라고 주장할 뿐이다.

이러한 반론들은 중요하며, 경솔한 형태의 이론에 대해서는 정당하게 제기된 것이지만, 이 이론의 모든 형태에 적용되지는 않는다. 규칙 회의주의(rule-scepticism)는 사법적 또는 입법적 권한을 부여하는 2차 규칙(secondary rules)의 존재 자체를 부정하려는 것이 아니었을 수도 있으며, 이러한 규칙들이 단지 결정(decisions)이나 그 결정의 예측(predictions)에 불과하다고 주장하려는 의도가 아니었을 수도 있다. 분명히 이러한 유형의 이론이 가장 자주 의존해 온 사례들은, 의무를 부과하거나 사인에게 권리 또는 권한을 부여하는 규칙들에서 가져온 것이다. 그렇다고 하더라도, 만약 규칙이 존재하지 않는다는 주장이나, 소위 규칙이라고 불리는 것이 단지 법원의 결정을 예측하는 것일 뿐이라는 주장이 이와 같이 제한된 방식으로 제시된다고 하더라도, 그것이 명백히 거짓인 한 가지 의미가 있다. 즉, 근대 국가의 어떤 행위 영역에 관해서는, 개인들이 우리가 ‘내부적 관점(internal point of view)’이라고 불렀던 일련의 행동과 태도 전체를 실제로 보인다는 점은 의심의 여지가 없다. 법은 그들의 삶 속에서 단순히 습관이거나, 법원의 결정이나 다른 공직자의 행동을 예측하는 기초가 아니라, 수용된 법적 행위 기준(accepted legal standards of behaviour)으로 기능한다. 즉, 사람들은 단지 법이 요구하는 것을 (p. 138) 일정한 규칙성 아래 수행할 뿐만 아니라, 그것을 하나의 법적 행위 기준으로 간주하며, 다른 사람을 비판하거나 요구를 정당화할 때 그것을 참조하고, 다른 사람의 비판이나 요구를 수용할 때에도 그것을 인정한다. 사람들이 이러한 규칙들을 규범적인 방식으로 사용할 때, 그들은 물론 법원이나 공직자들이 일정한 규칙성 아래에서, 그리고 따라서 예측 가능한 방식으로 계속해서 판결하고 행동할 것이라고 가정한다. 그러나 개인들이 외부적 관점(external point of view)에만 머물러, 단지 법원의 판결이나 제재의 가능성을 기록하고 예측하는 데에만 그치지 않는다는 것은

분명한 사회적 사실이다. 그 대신 그들은 행동의 지침으로서 법을 공유적으로 수용한다는 점을 규범적 언어로 끊임없이 표현하고 있다. 우리는 제3장에서 ‘의무(obligation)’와 같은 규범적 용어들이란 단지 공적 행위의 예측을 의미하는 것에 불과하다는 주장에 대해 상세히 검토하였다. 만약 우리가 제시한 논증이 옳다면, 그러한 주장은 거짓이며, 법적 규칙들은 사회 속에서 규칙으로서 기능한다. 그것들은 습관이나 예측을 묘사한 것이 아니라, 실제로 규칙으로 사용되고 있다(used). 물론 이러한 규칙들은 개방적 직조(open texture)를 가지므로, 그 개방성이 드러나는 지점에서는, 개인들이 다만 법원이 어떻게 판결할지를 예측하고 거기에 맞추어 자신의 행동을 조정할 수 있을 뿐이다.

규칙 회의주의는 심각하게 검토할 가치가 있지만, 그것은 오직 사법적 판결(judicial decision)에서의 규칙의 기능에 대한 이론으로 한정될 때만 그렇다. 이러한 형태에서, 앞서 지적한 모든 반론들을 인정하면서도, 이 이론은 법원에 관한 한 개방적 직조의 영역을 제한할 수 있는 아무런 것이 없다는 점을 주장한다. 따라서 판사들이 자신이 내리는 판결에 규칙에 의해 ‘구속된다(bound)’고 보는 것은 거짓이거나, 심지어 무의미하다는 것이다. 판사들은 다른 사람들이 오랜 시간 동안 그들의 결정을 규칙으로 삼아 살아갈 수 있을 정도로 충분히 예측 가능한 규칙성과 통일성을 가지고 행동할 수는 있다. 심지어 판사들은 자신이 특정한 방식으로 판결할 때 일종의 강제감(compulsion)을 느낄 수도 있으며, 그러한 감정들조차 예측 가능할 수도 있다. 그러나 그 이상으로는, 판사들이 어떤 규칙을 관찰하고 있다고 특징지을 수 있는 것은 없다. 법원이 자신들의 행동 기준으로 삼는 어떤 규범도 존재하지 않으며, 따라서 그들의 행동에서 규칙의 수용에 특징적인 내부적 관점은 드러나지 않는다는 것이다.

이 이론의 이러한 형태는 매우 다양한 성격과 중요도를 지닌 근거들로부터 지지를 얻는다. 규칙 회의주의자는 (p. 139) 때로는 실망한 절대주의자(absolutist)이다. 그는 규칙들이 형식주의자의 이상세계(formalist's heaven)에서처럼 완전한 것이 아니며, 인간이 신처럼 되어 모든 가능한 사실의 조합을 미리 예측할 수 있는 세계 – 다시 말해 규칙이 본질적으로 개방적 직조를 가질 필요가 없는 세계 – 에서와 같은 모습이 아니라는 점을 발견한 것이다. 회의주의자가 규칙의 존재라는 것을 도달 불가능한 이상(ideal)으로 간주하고

있다면, 그리고 소위 규칙이라 불리는 것이 그 이상에 부합하지 않는다는 것을 발견할 때, 그는 실망을 ‘규칙이라는 것은 존재하지 않는다’ 혹은 ‘존재할 수 없다’는 주장으로 표현하게 되는 것이다. 이렇게 해서, 판사들이 사건을 판결할 때 자신들을 구속한다고 주장하는 규칙들이 개방적 직조를 갖고 있으며, 그 예외가 사전에 완전히 규정될 수 없다는 사실, 그리고 판사가 그 규칙으로부터 벗어나더라도 물리적 제재(physical sanction)를 받지 않는다는 사실 등은 회의주의자의 주장을 뒷받침하는 데 자주 이용된다. 이 사실들은 다음과 같은 방식으로 강조된다. “규칙이란 것은 판사들이 어떻게 행동할지를 예측하는 데에 유용한 만큼만 중요하다. 그것이 규칙의 전부이며, 이외에는 예쁜 장난감(pretty playthings)에 불과하다.”²⁴

이와 같이 논변하는 것은 현실의 어떤 영역에서도 규칙(rule)이 실제로 무엇인지 간과하는 것이다. 이는 우리에게 다음과 같은 딜레마를 제시하는 것처럼 보인다. 즉, “규칙은 형식주의자의 천국(formalist’s heaven)에서와 같이 존재하여 족쇄처럼 구속력이 있거나, 아니면 규칙은 전혀 존재하지 않고 단지 예측 가능한 판결이나 행동 양식이 있을 뿐이다.” 그러나 이것은 분명히 거짓된 딜레마다. 우리는 친구에게 내일 방문하겠다고 약속(promise)한다. 그런데 그 날이 되자, 그 약속을 지키는 것이 위급한 병자에 대한 돌봄을 소홀히 하는 것을 의미하게 된다. 이러한 상황이 약속을 지키지 않는 정당한 이유로 받아들여진다고 해서, ‘약속은 지켜야 한다’는 규칙이 존재하지 않고 단지 일정한 규칙성이 존재할 뿐이라는 것을 의미하지는 않는다. 이러한 규칙에 예외가 있고, 그 예외들이 완전히 열거될 수 없다고 해서, 모든 상황에서 우리의 판단에 맡겨져 있고 결코 약속을 지켜야 할 의무가 없다는 결론이 나오는 것은 아니다. “~하지 않는다면(unless …)”으로 끝나는 규칙도 여전히 규칙이다.

때때로 법원을 구속하는 규칙의 존재는, 어떤 사람이 특정한 방식으로 행동함으로써 그러한 행동을 요구하는 규칙을 수용하였다는 사실이, 그 사람이 그러한 행동을 하기 전이나 하면서 거친 심리적 사고 과정과 (p. 140) 혼동되기 때문에 부정된다. 사람이 어떤 규칙을 구속력 있는 것으로 수용하고, 자신이나 다른 사람들이 임의로 바꿀 수 없는 것으로 여길 때 아주 흔히, 그는 주어진

²⁴Llewellyn, *The Bramble Bush* (2nd edn.), p. 9.

상황에서 그 규칙이 무엇을 요구하는지를 직관적으로 파악하고, 그 규칙 자체를 먼저 떠올리거나 그 요구사항을 숙고하지 않고도 그에 따라 행동할 수 있다. 우리가 체스에서 규칙에 따라 말을 옮기거나, 빨간 신호등에서 멈출 때, 우리의 규칙 준수 행동은 종종 규칙을 계산적으로 적용한 결과가 아니라 상황에 대한 직접적인 반응이다. 이러한 행동이 진정한 규칙의 적용이라는 것을 보여주는 증거는 그것이 특정한 상황 안에서 이루어졌다는 데 있다. 이 상황들 중 일부는 해당 행동 이전에 존재하고, 일부는 그 이후에 나타나며, 일부는 일반적이고 가설적인 방식으로만 진술될 수 있다. 우리가 행동하면서 규칙을 적용했다는 것을 보여주는 가장 중요한 요인은, 만약(if) 우리의 행동이 도전받는다면 우리는 그것을 규칙에 근거하여 정당화하려는 경향이 있다는 점이다. 그리고 규칙을 진정으로 수용하고 있다는 것은, 과거 및 이후의 일반적인 인정과 규칙 준수, 그리고 우리 자신이나 타인의 일탈에 대한 비판 속에서 드러날 수 있다. 이러한 혹은 유사한 증거에 비추어, 우리가 규칙을 ‘생각 없이’ 따르기 전에 “무엇이 옳은 일이며, 왜 그러한가?”라는 질문을 받았더라면, 우리는 정직하게 답한다면 그 규칙을 인용했을 것이라고 결론 내릴 수 있다. 우리의 행동이 이러한 상황들 속에 놓여 있다는 사실, 그리고 그것이 규칙에 대한 명시적 사고를 수반하지 않았다는 점이, 어떤 행위가 실제로 규칙의 준수인지, 단지 우연히 규칙과 일치한 것인지 구별하는 데 필요하다. 이처럼 우리는, 수용된 규칙의 준수로서의 성인 체스 플레이어의 움직임과, 단지 말을 올바른 자리에 밀어넣은 아기의 행동을 구별할 수 있다.

이것이 위장 혹은 ‘외형 꾸미기(window dressing)’가 불가능하거나 때때로 성공하지 않는다는 것을 의미하는 것은 아니다. 어떤 사람이 단지 사후적으로(ex post facto) 자신이 규칙에 따라 행동했다고 가장했는지를 판별하기 위한 테스트는, 모든 경험적 테스트와 마찬가지로 본질적으로 오류의 가능성을 내포하지만, 반드시 오류투성이인 것은 아니다. 어떤 사회에서는 판사들이 항상 먼저 직관적으로 혹은 ‘육감(by hunches)’으로 판결을 내린 후, 법률 규칙 목록에서 해당 사건과 비슷해 보이는 규칙을 단순히 선택할 수 있으며, 그런 다음 자신들의 판결이 바로 그 규칙에 의해 요구되었다고 주장할 수 있다. 그러나 그들의 다른 말이나 행동에서는 (p. 141) 그 규칙이 자신들에게 구속력 있는

것으로 받아들여졌다는 어떤 정황도 보이지 않을 수 있다. 일부 사법적 판결이 이러한 방식일 수는 있다. 하지만 대부분의 경우, 그러한 판결은 체스 플레이어의 수처럼, 판결 기준으로 의식적으로 수용된 규칙에 부합하려는 진지한 노력에 의해 이루어지거나, 혹은 직관적으로 결정되었더라도, 판사가 사전에 준수하려는 태도를 보였고, 그 사건과의 관련성이 일반적으로 인정되는 규칙에 의해 정당화되었다는 점은 명백하다.

규칙 회의주의(rule-scepticism)의 마지막이자 가장 흥미로운 형태는, 법적 규칙의 개방성이나 많은 판결의 직관적 성격에 근거하지 않고, 법원의 판결이 ‘권위 있는 것(something authoritative)’이라는 독특한 지위를 갖는다는 사실에 기반한다. 그리고 최고심 법원(supreme tribunals)의 경우에는 그 판결이 ‘최종적(final)’이라는 점에 기반한다. 이 이론 형태는, 우리가 다음 절에서 다룰 것이며, 호들리(Hoadly) 주교의 유명한 구절에 암묵적으로 내포되어 있다. 이 구절은 그레이(Gray)의 저서 *The Nature and Sources of Law*에서 자주 반복된다. “말로 하건 글로 쓰건, 어떤 법을 해석할 절대적 권위(absolute authority)를 지닌 자가 있다면, 그는 모든 면에서 입법자(lawgiver)이지, 그것을 처음 말하거나 쓴 사람이 아니다.”

3. 사법적 결정에서의 최종성(Finality)과 무오류성(Infallibility)

최고심 법원(supreme tribunal)은 법이 무엇인지를 말하는 데 있어서 최종적인 발언권(last word)을 가진다. 그리고 그것이 법이 무엇인지 말했다면, 그 법원이 ‘틀렸다(wrong)’고 말하는 진술은 그 체계 내에서는 아무런 결과도 초래하지 않는다. 그로 인해 누구의 권리나 의무도 변경되지 않는다. 물론 그러한 판결은 입법(legislation)을 통해 법적 효력을 박탈당할 수 있다. 그러나 입법이 필요하다는 바로 그 사실 자체가, 법 관점에서 볼 때 ‘그 법원의 판결이 틀렸다’는 진술이 공허하다는 점을 보여준다. 이러한 사실을 고려해보면, 최고심 법원의 판결에 있어 ‘최종성’과 ‘무오류성’ 사이를 구분하는 것이 형식주의적(pedantic)인 것처럼 보이게 된다. 이로부터 다음과 같은 규칙에 구속되는 판결이라는 관념 자체를 부정하는 이론의 또 다른 형태가 도출된다. 곧, “법(또는 헌법)은

법원이 그것이 무엇이라 말하는 것이다(the law (or the constitution) is what the courts say it is).”

이러한 이론 형태의 가장 흥미롭고 교육적인 특징은 “법(또는 헌법)은 법원이 말하는 바와 같다”는 문장 속에 있는 애매성(ambiguity)을 활용하고 있다는 점이며, 일관성을 유지하려면 (p. 142) 이 이론은 비공식적인 법 진술과 법원의 공식적인 법 진술 사이의 관계를 반드시 설명해야 한다. 이러한 모호성을 이해하기 위해, 우리는 우선 게임의 사례에서 이와 유사한 경우를 살펴볼 것이다. 많은 경쟁 게임은 공식적인 득점기록자(scorer) 없이 진행된다. 경쟁적인 이해관계가 있음에도 불구하고, 참가자들은 특정한 득점 규칙을 개별 사례에 적용하는 데 있어 대체로 잘 해낸다. 그들은 보통 그들의 판단에 대해 합의하며, 해결되지 않은 분쟁은 드물다. 공식적인 득점기록자가 제도화되기 전, 한 플레이어가 득점을 진술하는 것은, 그가 정직하다면, 해당 게임에서 받아들여지는 특정 득점 규칙을 참조하여 게임의 진행 상황을 평가하려는 노력으로 볼 수 있다. 이러한 득점 진술은 득점 규칙을 적용하는 내적 진술(internal statement)이다. 이러한 진술은 일반적으로 참가자들이 규칙을 준수하고 그 위반에 이의를 제기할 것이라는 전제를 포함하지만, 그 자체가 이러한 사실들의 진술이나 예측은 아니다.

관습 체계에서 성숙한 법 체계로 전환되는 변화와 마찬가지로, 게임에 득점기록자를 제도화하도록 하는 2차 규칙(secondary rules)이 추가되면, 그 판정이 최종적이라는 지위를 갖게 되어 시스템 안에 새로운 종류의 내적 진술이 도입된다. 왜냐하면, 플레이어들의 득점 진술과는 달리, 득점기록자의 판정은 2차 규칙에 의해 반박 불가능한 지위를 부여받기 때문이다. 이런(this) 의미에서, 게임의 목적에 한정하면 “득점은 득점기록자가 말하는 것이다(the score is what the scorer says it is)”는 명제가 참이 된다. 그러나 중요한 점은 득점 규칙(scoring rule)은 여전히 예전과 동일하며, 득점기록자의 임무는 그것을 최선을 다해 적용하는 것이다. “득점은 득점기록자가 말하는 것이다”는 문장이, 득점을 매기는 규칙이란 전혀 존재하지 않고 오직 득점기록자의 재량에 따라 적용되는 것뿐이라는 의미로 해석된다면, 그것은 거짓이다. 물론 그러한 규칙을 가진 게임이 존재할 수도 있으며, 득점기록자의 재량이 어느 정도 일관성을 가지고

행사된다면 약간의 재미를 느낄 수도 있을 것이다. 하지만 그것은 완전히 다른 게임일 것이다. 우리는 그러한 게임을 “득점기록자의 재량 게임(the game of scorer's discretion)”이라고 부를 수 있다.

득점기록자가 가져오는 신속하고 최종적인 분쟁 해결이라는 장점은 대가를 치르고 얻어지는 것이라는 점은 분명하다. 득점기록자의 제도는 참가자들에게 딜레마를 안겨줄 수 있다. 즉, 이전과 같이 득점 규칙에 따라 게임이 규율되기를 바라는 욕구와, 그 규칙의 적용이 의심스러울 때 그것에 대해 최종적이고 권위 있는 판정을 받기를 바라는 욕구는 서로 충돌할 수 있다. 득점기록자는 정직한 실수를 (p. 143) 저지를 수도 있고, 술에 취했을 수도 있으며, 득점 규칙을 최선을 다해 적용해야 한다는 의무를 고의적으로 위반할 수도 있다. 그는 이러한 여러 이유로 인해, 실제로 타자가 전혀 움직이지 않았는데도 ‘득점(run)’을 기록할 수 있다. 그의 판정을 상위 권위에 항소(appeal)함으로써 수정할 수 있도록 제도화할 수도 있다. 그러나 이것은 결국 어딘가에서 최종적이고 권위 있는 판정으로 끝나야 하며, 이는 오류를 범할 수 있는 인간이 내리는 것이므로 정직한 실수, 남용, 또는 위반의 위험을 항상 수반하게 된다. 모든 규칙 위반을 수정할 수 있도록 또 다른 규칙을 마련하는 것은 불가능하다.

권위를 가진 기관(authority)이 규칙(rule)을 최종적이고 권위 있게 적용하도록 설정될 경우 발생할 수 있는 위험은 어떤 영역에서든 현실화될 수 있다. 이러한 위험은 게임이라는 소박한 영역에서도 현실화될 수 있는데, 그 경우조차도 고려할 가치가 있다. 왜냐하면 그것은 이와 같은 형태의 권위(authority)가 사용되는 모든 상황에서 이해를 위해 반드시 필요한 몇 가지 구분을, 규칙 회의론자(rule-sceptic)가 무시하고 있음을 특히 명료하게 보여주기 때문이다. 공식 득점기록자(official scorer)가 제도화되고 그의 득점판단이 최종적으로 확정되었을 때, 플레이어 또는 다른 비공식 인물(non-official)이 하는 득점 진술은 게임 내에서 아무런 지위를 갖지 못한다. 그것은 게임 결과에 대해 무관하며, 득점기록자의 진술과 일치한다면 그만이고, 충돌한다면 게임 결과 계산에서 무시되어야 한다. 그러나 이러한 명백한 사실들은, 만약 플레이어의 진술이 득점기록자의 판정을 예측(prediction)한 것이라고 분류된다면 왜곡되는 것이다. 그리고 이 진술이 득점기록자의 판정과 충돌할 경우 무시되는 이유를, 그것이

예측이었는데 결과적으로 틀렸기 때문이라고 설명하는 것은 터무니없는 일이다. 공식 득점기록자가 도입된 이후에도, 플레이어가 자신만의 득점 진술을 하는 행위는 예전과 동일하다. 즉, 가능한 한 최선을 다해 해당 게임에서 받아들여진 득점 규칙에 따라 게임의 진행 상황을 평가하는 것이다. 이것은 득점기록자 자신이, 자신의 직무를 충실히 이행하는 한, 수행하고 있는 바로 그 일이다. 양자 간의 차이는 한쪽이 다른 쪽이 무엇을 말할지를 예측하고 있다는 데 있는 것이 아니라, 플레이어의 진술은 득점 규칙의 비공식적인 적용(unofficial application)이며, 따라서 게임 결과 산출에는 아무런 의미를 갖지 않지만, 득점기록자의 진술은 권위 있고 최종적인 것이라는 데 있다. 중요한 점은, 만약 플레이되고 있는 게임이 ‘득점기록자의 재량(scorer’s discretion)’ 게임이라면, 비공식 진술과 공식 진술 사이의 관계는 (p. 144) 반드시 달라질 수밖에 없다는 것이다. 그 경우, 플레이어의 진술은 실제로 득점기록자의 판정을 예측하려는 (would) 시도일 뿐만 아니라, 그 외의 다른 무엇도 될 수(could) 없다. 왜냐하면, 그 경우에 “득점은 득점기록자가 말하는 것이다(the score is what the scorer says it is)”라는 명제 자체가 득점 규칙(rule)이기 때문이다. 그런 게임에서는 득점기록자의 공식 행위와 별도로 존재하는 ‘비공식’ 득점 진술이 존재할 가능성 자체가 사라진다. 그러면 득점기록자의 판정은 최종적일 뿐만 아니라 무오류(infallible)하게 되며—사실상 그 판정이 무오류인지 아닌지를 묻는 것 자체가 무의미해진다. 왜냐하면, 그가 무엇을 ‘옳게’ 또는 ‘그르게’ 판단했다는 것을 말할 수 있는 기준 자체가 존재하지 않기 때문이다. 그러나 일반적인 게임에서 “득점은 득점기록자가 말하는 것이다”는 득점 규칙이 아니라, 특정한 사례에 득점 규칙을 적용하는 득점기록자의 판단이 권위 있고 최종적임을 규정하는 규칙이다.

이러한 권위적 결정(authoritative decision)의 사례에서 배울 수 있는 두 번째 교훈은 보다 근본적인 사안에 관련된다. 우리는 정상적인 게임(normal game)과 ‘득점기록자의 재량’ 게임을 구분할 수 있다. 그 이유는 득점 규칙이, 다른 모든 규칙과 마찬가지로 득점기록자가 선택을 행사해야 하는 개방적 직조(open texture)를 포함하더라도, 확정된 의미의 핵심(core of settled meaning)을 여전히 가지고 있기 때문이다. 이 확정된 의미야말로 득점기록자가 자유롭게

이탈할 수 없는 것이며, 그 범위 내에서는 플레이어가 득점에 대해 비공식적으로 진술할 때나, 득점기록자가 공식적으로 판정할 때나, 옳고 그름의 기준으로 작용한다. 바로 이 점이, 득점기록자의 판정은 비록 최종적이지만 무오류적인 것은 아니라는 진술을 참되게 만든다. 법도 마찬가지이다.

어느 정도까지는, 득점기록자가 내린 몇몇 판정이 명백히 잘못되었다는 사실이 게임의 지속성과 모순되지 않는다. 그러한 판정들은 명백히 옳은 판정들과 마찬가지로 유효하다. 하지만 잘못된 결정들에 대한 관용(tolerance)의 범위가 일정 한계를 넘어서게 되면, 동일한 게임이 계속되고 있다고 말하는 것이 더 이상 가능하지 않게 된다. 이 점은 법체계에 있어서도 중요한 유비(analogue)를 제공한다. 고립적이거나 예외적인 공적 일탈(official aberrations)이 용인된다고 해서, 그것만으로 크리켓이나 야구 게임이 더 이상 유지되지 않는다고 말할 수는 없다. 그러나 만약 그러한 일탈이 빈번해지거나, 득점기록자가 득점 규칙 자체를 거부한다면, 어느 시점에서는 플레이어들이 더 이상 득점기록자의 일탈적 판정을 받아들이지 않게 될 것이고, 만약 그들이 받아들인다면, 그 게임은 더 이상 원래의 게임이 아닐 것이다. 그것은 더 이상 크리켓이나 야구가 아니라, ‘득점기록자의 재량(scorer’s discretion)’이 되는 것이다. 왜냐하면 일반적으로, 규칙의 개방된 직조가 득점기록자에게 허용하는 범위가 어느 정도이든 간에, 그들의 결과가 해당 규칙의 명백한 의미(plain meaning)에 따라 평가되어야 한다는 점이 (p. 145) 그러한 게임들을 정의하는 특징(defining feature)이기 때문이다. 어떤 가상적인 상황에서는 실제로 지금 이 게임은 ‘득점기록자의 재량’이었다고 말할 수 있을 것이다. 그러나 모든 게임에서 득점기록자의 판정이 최종적이라는 사실만으로, 모든 게임이 그런 재량 이라고 말할 수는 없다.

이러한 구분들은, 특정 사안에서 법이 무엇인지를 최종적이고 권위 있게 말하는 법원의 결정이 갖는 고유한 지위에 기반한 규칙회의론(rule-scepticism)의 형태를 평가할 때 반드시 유념해야 한다. 법의 개방적 직조(open texture)는 법원에게, 득점기록자(scorer)에게 주어지는 권한보다 훨씬 더 광범위하고 중요한 법 창조의 권한을 남겨둔다. 득점기록자의 판정은 법을 창출하는 선례(precedent)로 사용되지 않지만, 법원이 어떤 결정을 내리든—그것이 규칙의 중심부에 속해 모두에게 명백한 사항이든, 논쟁의 여지가 있는 주변부에 속한

사항이든—그 결정은 입법에 의해 변경되기 전까지는 유효하다. 그리고 입법의 해석에 대해서도 다시 법원이 동일하게 최종적 권위를 지닌다. 그럼에도 불구하고, 일단 법원 체계를 구성한 뒤에 법이란 무엇이든지 대법원이 적당하다고 여기는 것이라고 규정하는 헌법과, 실제의 미국 헌법—혹은 여타 현대 국가의 헌법—사이에는 여전히 구분이 존재한다. “헌법(또는 법)은 판사가 말하는 것이다(the constitution (or the law) is whatever the judges say it is)”라는 명제가 이 구분을 부정하는 의미로 해석된다면, 그것은 거짓이다. 어느 특정 시점에서조차, 대법원의 판사들조차도, 그들이 소속된 체계의 일부이며, 그 체계의 규칙은 중심부에서는 충분히 명확하여 올바른 판결의 기준을 제공한다. 법원은 이러한 규칙들을 자신들이 자유롭게 무시할 수 있는 것이 아니라, 자신들의 결정권 행사에서 준수해야 할 것으로 간주한다. 개별 판사가 직무를 수행하게 될 때는, 득점기록자가 자기 직무를 맡을 때와 마찬가지로, 예컨대 “여왕과 의회의 공동 제정은 법이다”라는 규칙과 같은 규칙이 전통으로서 정립되어 있으며, 그 규칙이 직무 수행의 기준으로 받아들여지고 있음을 발견하게 된다. 이 기준은 판사의 창조적 활동을 허용하면서도 동시에 그 활동을 제약한다. 이러한 기준은, 실제로 해당 시대의 대부분 판사들이 그것을 준수하지 않는다면 존속할 수 없다. 왜냐하면 그러한 기준의 존재란 결국 그것이 올바른 판결의 기준으로 받아들여지고 사용되는 데서 비롯되기 때문이다. 하지만 이러한 사실이, 그 기준을 사용하는 판사가 곧 그것의 제정자(author)이며, 호들리(Hoadly)의 표현을 빌리자면 “마음대로 결정할 권한이 있는 입법자(lawgiver)”라는 것을 (p. 146) 의미하지는 않는다. 판사의 준수는 기준의 유지를 위해 필요하지만, 그 기준을 만드는 것은 아니다.

물론 가능성은 있다. 즉, 판결을 최종적이고 권위 있는 것으로 만드는 규칙의 보호막(shield) 뒤에서, 판사들이 기존의 규칙을 공동으로 거부하고, 심지어 가장 명확한 의회법(Acts of Parliament)조차도 자신들의 판결에 제약을 가하는 것으로 간주하지 않을 수 있다. 만약 다수의 판결이 이와 같은 성격을 가지며, 그것이 받아들여진다면, 이는 마치 크리켓 게임이 ‘득점기록자의 재량’ 게임으로 전환된 것과 유사하게 체계가 전환된 것이라 할 수 있다. 그러나 이러한 전환의 가능성이 상존한다고 해서, 현재의 체계가 이미 그러한 전환이 이루어진

것과 동일하다는 것을 뜻하지는 않는다. 어떤 규칙도 그 위반이나 부정(배격, repudiation)으로부터 보장받을 수는 없다. 왜냐하면 인간이 심리적으로나 물리적으로 규칙을 위반하거나 부정하는 것을 불가능하게 만드는 것은 아니기 때문이다. 그리고 만약 충분히 많은 사람들이 그것을 오랫동안 위반하거나 부정한다면, 그 규칙은 존재를 멈추게 될 것이다. 그러나 특정한 시점에서 규칙이 존재한다는 것은, 그것이 파괴되지 않을 수 있다는 불가능한 보장을 요구하는 것이 아니다. 어떤 시점에 “판사는 의회법 또는 연방법(Congress)의 법률을 법으로 받아들여야 한다”는 규칙이 존재한다고 말하려면, 첫째, 이 요구사항에 대한 일반적 준수가 존재하고, 개별 판사가 이탈하거나 이를 부정하는 경우는 드물다는 사실이 전제되어야 한다. 둘째, 그러한 일이 발생하거나 발생할 경우, 그것은 대다수에게 심각한 비판의 대상이 되며 잘못된 것으로 간주되어야 한다. 비록 그 결과로서 특정 사건에 내려진 결정은, 판결의 최종성(finality)에 관한 규칙 때문에 입법을 통해서만 무효화할 수 있으며, 그 결정의 정당성이 아니라 유효성을 인정해야 한다 할지라도 말이다. 사람들이 자신의 약속을 전부 어길 수도 있다는 것은 논리적으로 가능하다. 처음에는 그것이 잘못된 행동이라는 의식을 가지고 그러다가 나중에는 그러한 의식도 없이 행할 수 있다. 그런 경우, 약속을 지켜야 한다는 규칙은 더 이상 존재하지 않게 될 것이다. 하지만 이런 상정은, 현재 약속을 지켜야 한다는 규칙이 존재하지 않는다는 주장이나, 약속이 실제로 구속력을 갖지 않는다는 주장을 뒷받침하는 데는 전혀 충분하지 않다. 판사에 관한 평행한 논변—즉, 그들이 현재의 체계를 파괴하도록 공모할 가능성에 기반한 주장은—그보다 더 나은 설득력을 갖고 있지는 않다.

우리가 규칙회의론(rule-scepticism)의 논의를 마무리하기 전에, 법률 규칙이란 법원의 판결을 예측(prediction)하는 것에 불과하다는 이 견해의 긍정적 주장에 대해 마지막으로 언급해야 한다. 이 주장에 진실성이 얼마간 있을 수는 있지만, (p. 147) 그것이 적용될 수 있는 것은 어디까지나 민간인(private individuals)이나 그들의 법률 자문인이 제시하는 법률 진술(law statements)의 경우에 한정된다는 점은 명백하며, 자주 지적된 바 있다. 이러한 주장은 법원 자체의 법률 규칙 진술에는 적용되지 않는다. 법원의 법률 진술은, 일부 급진적 현실주의자들(extremes ‘Realists’)이 주장하듯, 전적으로 자유로운 재량 행사를

은폐하는 말의 외피(verbal covering)이거나, 아니면 법원이 진심으로 올바른 판단의 기준으로 간주하고 있는 규칙을 공식적으로 정식화(formulate)한 것이어야만 한다. 반면, 법원 판결에 대한 예측(prediction)은 법에서 분명히 중요한 자리를 차지한다. 개방적 직조(open texture)의 영역에 이르면, 어떤 사안에 대해 “법이 무엇인가?”라는 질문에 대해 우리가 유용하게 제시할 수 있는 것은 법원이 어떻게 판단할지를 조심스럽게 예측하는 것일 수밖에 없는 경우가 많다. 더욱이, 규칙이 무엇을 요구하는지가 모두에게 명백한 경우조차도, 그것은 종종 법원의 판결을 예측하는 방식으로 표현되곤 한다. 그러나 이 경우, 특히 후자의 경우에 있어서는, 그리고 전자에 있어서는 경우에 따라, 이러한 예측이 가능하다는 것은 법원이 법적 규칙을 예측의 대상(predictions)으로서가 아니라, 판단 시 따라야 할 기준(standards)으로 간주한다는 사실에 기반하고 있다는 점에 유의해야 한다. 이러한 규칙은, 그 개방적 직조에도 불구하고, 법원의 재량을 배제하지는 못하더라도 제한할 만큼은 충분히 명확하다. 따라서, 많은 경우 법원이 어떤 결정을 내릴지를 예측하는 것은, 마치 체스 플레이어가 비숍(bishop)을 대각선으로 움직일 것이라고 예측하는 것과 같다. 그러한 예측은 궁극적으로 규칙의 비예측적(non-predictive) 측면과, 그 규칙이 예측의 대상이 되는 당사자들에 의해 수용되고 있는 기준으로서의 내부적 관점(internal point of view)에 대한 이해에 바탕을 둔다. 이것은 이미 제5장에서 강조한 사실—즉, 어떤 사회 집단이 규칙이 존재한다는 사실은 예측을 가능하고 종종 신뢰할 수 있게 만들지만, 그 존재 자체가 예측으로 환원될 수는 없다는 점—의 또 다른 측면에 불과하다.

4. 승인 규칙의 불확실성 (UNCERTAINTY IN THE RULE OF RECOGNITION)

형식주의(Formalism)와 규칙회의론(rule-scepticism)은 법이론(juristic theory)의 스킬라(Scylla)와 카립디스(Charybdis)라 할 수 있다. 이들은 서로를 교정해주는 한에서는 유익하나, 모두 심대한 과장에 해당하며, 진실은 그 사이 어딘가에 있다. 사실 여기에서 시도할 수 없는 많은 작업들이 필요하다. 특히

이 중간 경로를 정보성 있게 특징짓고, 제정법(statute)이나 선례(precedent)의 개방적 직조(open texture)가 법원에게 남겨준 창조적 기능을 수행하는 데 있어 법원이 통상적으로 사용하는 다양한 추론 유형들을 보여줄 필요가 있다. 그러나 우리는 (p. 148) 이미 이 장에서 충분히 논의하였기에, 제6장 마지막에서 보류했던 중요한 주제로 이제 유익하게 돌아갈 수 있다. 이 주제는 개별 법규칙의 불확실성에 관한 것이 아니라, 승인 규칙(rule of recognition)의 불확실성, 곧 법원이 유효한 법 규칙을 식별할 때 사용하는 궁극적 기준들의 불확실성과 관련된 것이다. 특정한 규칙의 불확실성과, 그것이 체계 내 규칙으로 식별될 수 있도록 해주는 기준의 불확실성 사이의 구분은, 모든 경우에 명확하지는 않다. 그러나 이러한 구분은 해당 규칙이 권위 있는 문구를 가진 제정법일 때 가장 뚜렷하게 드러난다. 법률의 문구와 그것이 특정 사안에서 요구하는 바는 완전히 명백할 수 있다. 그럼에도 불구하고, 입법부가 이러한 방식으로 입법할 권한이 있는지 여부에 대한 의문이 제기될 수 있다. 때로 이러한 의문을 해결하는 데는 단지 입법 권한을 부여한 또 다른 법규칙의 해석만으로 충분하며, 이 두 번째 규칙의 유효성에는 의심이 존재하지 않을 수 있다. 예를 들어, 하위 입법기관(subordinate authority)에 의해 제정된 법령의 유효성이 문제되는 경우, 모법(parent Act of Parliament)이 그 기관에 부여한 입법권의 의미에 의문이 제기될 수 있다. 이는 단지 특정 제정법이 가지는 불확실성이나 개방적 직조의 사례일 뿐이며, 근본적인 문제를 제기하지는 않는다.

이러한 통상적 문제들과 구분되는 것이 바로 최고 입법기관(supreme legislature) 자체의 법적 권한(legal competence)에 관한 문제들이다. 이는 법적 유효성의 궁극적 기준(ultimate criteria of legal validity)을 다루는 것이며, 비록 최고 입법기관의 권한을 명시하는 성문헌법(written constitution)이 없는 우리 체계와 같은 법제도에서도 발생할 수 있다. 압도적 다수의 경우에서, “여왕과 의회가 제정한 것은 모두 법이다(Whatever the Queen in Parliament enacts is law)”라는 문구는 의회의 법적 권한에 관한 규칙을 적절히 표현하는 것으로 받아들여지며, 이는 유효한 법규칙을 식별하기 위한 궁극적 기준으로 수용된다. 비록 이렇게 식별된 규칙들이 주변부에 있을지라도 말이다. 하지만 이 문구의 의미나 범위에 대해 의문이 제기될 수 있으며, “의회가 제정한 것(enacted by

Parliament)”이 무엇을 의미하는지를 우리는 물을 수 있고, 이러한 의문은 법원이 해결할 수 있다. 이러한 사실로부터, 법체계 내에서 법원이 차지하는 위치에 대해 어떤 추론을 할 수 있을까? 법체계의 기초는 유효성 기준을 명시하는 승인 규칙이 수용되고 있다는 테제(thesis)에 어떤 수정을 가해야 하는가?

(p. 149) 이러한 질문에 답하기 위해, 우리는 영국의 의회주권(parliamentary sovereignty) 원리에 관한 몇 가지 측면을 고찰할 것이다. 물론 유사한 의문은 어느 체계에서든 법적 유효성의 궁극적 기준에 대해 제기될 수 있다. 오스틴 주의(Austinian doctrine)의 영향 아래, 법이란 본질적으로 법적으로 구속받지 않는 의지의 산물이라고 본 전통적 헌법이론가들은, 어떤 입법기관이 반드시 존재해야 하며, 그것이 외부로부터(ab extra) 부과된 법적 제약뿐 아니라 자기 자신의 과거 입법으로부터도 항상 자유로운 상태여야 한다고 논하였다. 이러한 의미에서 의회가 주권적이라는 점은 이제 확립된 것으로 간주되며, 한 의회가 다음 의회(‘후속자들’)가 자신의 입법을 폐지하지 못하도록 할 수 없다는 원칙은 법원이 유효한 법규칙을 식별할 때 사용하는 궁극적 승인 규칙의 일부를 구성한다. 하지만 우리는 다음의 사실을 분명히 보아야 한다. 즉, 논리적 필연성(logical necessity)–더군다나 자연적 필연성(natural necessity)–이 이러한 의회가 존재해야 한다고 명령하는 것은 아니다. 그것은 단지 우리가 법적 유효성의 기준으로 수용해 온 여러 가능성 중 하나에 불과하다. 이외에도 ‘주권(sov­ereignty)’이라는 이름에 더욱 부합할 수 있는 또 다른 원칙이 존재할 수 있다. 그것은 바로 의회가 자신의 후속자들의 입법권을 되돌릴 수 없을 정도로 제한할 수 없는 것이 아니라(not), 오히려 그러한 더 넓은 자기제한적 권한(self-limiting power)을 가져야 한다는 원칙이다. 그렇게 된다면, 의회는 역사상 단 한 번일지라도 현재 확립된 원리가 허용하는 것보다 더 광범위한 입법권을 행사할 수 있게 되는 것이다. 의회가 자신의 모든 존재 순간마다–심지어 스스로가 부과한 제약으로부터도–법적 제한에서 자유로워야 한다는 요구는, 결국 법적 전능(legal omnipotence)이라는 모호한 개념에 대한 해석 중 하나에 불과하다. 이 해석은 사실상, 후속 의회들의 입법권을 침해하지 않는 범위 내에서는 연속적인 전능(continuing omnipotence)을, 그리고 단 한 번 행사할 수 있는 무제한의 자기포섭적 전능(self-embracing omnipotence) 중 하나를 선택하는

것이다. 이 두 가지 전능 개념은 신학에서의 전능한 신에 관한 두 개념과 평행을 이룬다. 한편으로는 자신의 존재의 모든 순간에 동일한 권능을 유지하며 그것을 제한할 수 없는 신이 있고, 다른 한편으로는 자신의 전능함을 (p. 150) 장래를 위해 스스로 폐기할 수 있는 신이 있다. 우리의 의회가 어떠한 형태—지속적인 또는 자기포섭적인—의 전능을 갖는가는, 법을 식별하는 궁극적 기준으로 어떤 규칙이 수용되고 있는지를 둘러싼 경험적(empirical) 질문이다. 그것은 비록 법체계의 기반에 놓인 규칙에 관한 질문이기는 하지만, 특정 시점에서, 적어도 어떤 점들에 있어서는, 상당히 결정적인 답이 존재할 수 있는 사실(fact)의 문제이다. 그리고 이 점은 현재 수용된 규칙이 바로 ‘지속적 주권(continuing sovereignty)’이라는 사실에서 명확하게 드러난다. 즉, 의회는 자신의 법률을 폐지로부터 보호할 수 없다.

그러나 모든 규칙이 그러하듯, 의회주권(parliamentary sovereignty)의 규칙이 이 지점에서는 명확하다고 해서 그것이 모든 지점에서 명확하다는 것을 의미하지는 않는다. 현재로서는 분명하게 옳거나 그르다고 판단할 수 없는 질문들이 제기될 수 있으며, 이들은 결국 이 문제에 대해 권위를 부여받은 어떤 이의 선택(choice)에 의해 비로소 해결될 수 있다. 의회주권의 규칙 내에 존재하는 이러한 불확정성(indeterminacies)은 다음과 같은 방식으로 드러난다. 현재의 규칙 하에서는, 의회는 향후 의회의 입법 범위에서 어떤 주제를 영구히 제외할 수 없다는 점이 인정되고 있다. 그러나 단순히 그러한 시도를 담은 법률(enactment)과, 의회가 어떤 주제에 대해 입법할 수 있는 가능성을 완전히 닫지는 않되 입법의 ‘형식과 절차(manner and form)’를 변경하려는 법률 사이에는 구분이 가능하다. 후자의 경우, 예컨대 특정 이슈에 대해서는 양원(House of Commons and Lords)이 합동으로 통과시키거나 국민투표(plebiscite)로 인식하지 않으면 법률로서 효력이 없다는 식으로 규정할 수 있다. 이러한 규정은 다시, 같은 특별 절차를 거쳐야만 폐지될 수 있다는 조항으로 ‘강화(entrench)’될 수도 있다. 이러한 입법 절차상의 부분적 변경은, 현재 규칙이 명시하고 있는 ‘의회는 후속 의회의 권한을 영구히 제한할 수 없다’는 원칙과도 양립 가능할 수 있다. 왜냐하면 이때 의회는 후속 의회를 구속(bind)한다기보다는, 특정 이슈에 관한 한(quoad) 후속 의회를 소멸시켜 해당 사안에 대한 입법권을 새로운 특별기구로 이전한

셈이 되기 때문이다. 이와 같이 말할 수도 있다. 이러한 특수 사안과 관련하여, 의회는 후속 의회를 ‘구속’하거나 ‘제약’하거나 지속적 전능성을 약화시킨 것이 아니라, 오히려 ‘의회’의 개념과 입법을 위한 요건 자체를 재정의(redefine)한 것이라고 말이다.

명백히, 이러한 장치가 유효하다면, 의회는 (p. 151) 그것을 통해 현재의 ‘의회는 후속 의회를 구속할 수 없다’는 통설이 금지하는 것과 거의 동일한 결과를 실현할 수 있다. 실제로는, 의회가 입법할 수 있는 영역 자체를 축소하는 것과 단지 입법의 절차 및 형식을 변경하는 것 사이의 구분은 몇몇 경우에는 명확하더라도, 결국 이 두 범주는 서로 연속적으로 이어지게 된다. 예컨대 다음과 같은 경우를 상정해보자. 어느 법률이 기술자(Engineers)의 최저임금을 고정하고, 기술자의 급여에 관한 어떠한 법안도 기술자 노동조합(Engineers’ Union)의 결의 없이는 법으로서 효력을 가질 수 없다고 규정하고, 나아가 이러한 조항을 ‘강화(entrench)’했다고 하자. 이 법은 실질적으로는 임금을 ‘영구히(never)’ 고정하고 폐지를 전면적으로 금지한 법률이 실현할 수 있는 모든 것을 성취할 수 있을 것이다. 하지만 법률가들이 수궁할 법한 논증도 제시될 수 있다. 즉, 후자의 경우는 현재의 지속적 의회주권 원칙 하에서 무효이나, 전자는 무효가 아니라고 주장할 수 있다는 것이다. 이 논증의 단계들은, 의회가 할 수 있는 것에 관하여, 다음과 같이 점진적인 주장을 포함한다. 각 단계는 그 이전 단계보다 동의를 얻기 어렵지만, 유사한 전제를 공유한다. 이들 중 어떤 것도 틀렸다고 단정할 수 없고, 반대로 옳다고 자신 있게 받아들일 수도 없다. 왜냐하면 우리는 법체계에서 가장 근본적인 규칙의 개방적 직조 영역에 발을 들여놓은 것이기 때문이다. 여기에서는 어떤 순간에도 ‘정답’이 존재하는 것이 아니라, 단지 ‘답변들(answers)’만이 존재할 뿐이다.

따라서 다음과 같은 점은 받아들여질 수 있을 것이다. 즉, 의회는 현재의 의회 구조를 되돌릴 수 없을 정도로 변경할 수 있으며, 예컨대 상원의 존재 자체를 폐지함으로써 이를 달성할 수 있다는 것이다. 이는 1911년과 1949년의 의회법(Parliament Acts)들—일정한 입법에 대해 상원의 동의를 불필요하게 만든—을 넘어서는 것으로, 일부 학자들은 이들을 단지 여왕과 하원(Queen and Commons)에게 위임된, 철회 가능한 권한으로 해석하기도 한다. 또한 다음과

같은 주장도 받아들여질 수 있을 것이다. 다이시(A. V. Dicey)가 주장했듯이,²⁵ 의회는 자신에 대한 모든 권한을 종식시키고 향후 의회 선거에 관한 법률들을 폐지하는 법률을 통해 스스로를 완전히 해체할 수 있다는 것이다. 그렇다면, 의회는 자신의 모든 권한을 맨체스터 시의회(Manchester Corporation)와 같은 다른 기관으로 이전하는 법률을 제정하여 이러한 입법적 자살(legislative suicide) 기도할 수도 있을 것이다. 만일 의회가 이러한 일을 할 수 있다면, 그보다 더 제한적인 일은 할 수 없겠는가? 특정 사안에 대해 (p. 152) 더 이상 입법권을 행사할 수 없도록 하고, 그 권한을 자신과 또 다른 기관으로 구성된 복합적 실체(composite entity)에게 이전하는 것은 불가능한가? 이런 관점에서 본다면, 도미니언(Dominion)에 영향을 미치는 입법은 반드시 해당 도미니언의 동의를 필요로 한다고 규정한 《웨스트민스터 법령(Statute of Westminster)》 제4조(section 4)는, 사실상 의회의 도미니언 입법권 일부를 이전한 것일 수도 있다. 도미니언의 동의 없이 이 조항을 폐지할 수 있다는 주장은, 상키 경(Lord Sankey)이 말했듯이 “현실과 무관한 이론(theory which has no relation to realities)”일 수 있다. 나아가 그것은 나쁜 이론일 수도 있고—적어도 반대 입장보다 나은 것이 없는 이론일 수 있다. 마지막으로, 만일 의회가 이러한 방식으로 스스로를 재구성할 수 있다면, 기술자 노동조합(Engineers' Union)이 특정 유형의 입법에 있어서 필수적인 동의기관(consenting element)이 되도록 의회 스스로 규정하는 것은 왜 불가능하겠는가?

그러한 논증의 의심스러운 명제들 가운데 일부는, 명백히 잘못되었다고는 볼 수 없지만 의심스러운 단계들로 구성되어 있으며, 언젠가는 이 사안을 판단하게 된 법원이 이를 인식하거나 거부함으로써 그 의문점들에 대한 답을 내리게 될 가능성이 있다. 그때 우리는 그 질문들에 대한 해답을 가지게 될 것이며, 그 해답은 해당 법체계가 존속하는 한, 그 문제에 대해 제시될 수 있는 여러 답변 중 유일한 권위 있는(answer of unique authoritative status) 답이 될 것이다. 법원은 이 지점에서 유효한 법을 식별하기 위한 궁극적 규칙(ultimate rule)을 확정하게 되는 것이다. 이때 “헌법은 판사들이 말하는 것이 헌법이다(the constitution is what the judges say it is)”라는 말은 단지 최상급 법원의 특정 판결이 도전을

²⁵The Law of the Constitution(10th edn.), p. 68 n.

받지 않는다는 뜻만은 아니다(not). 처음 보기에는 이 장면이 모순(paradox)처럼 보일 수 있다. 즉, 법원이 창조적인 권한을 행사하여, 바로 자신들에게 판사로서의 관할권(jurisdiction)을 부여하는 법률의 유효성을 판단하는 궁극적 기준(ultimate criteria) 자체를 결정하고 있다는 것이다. 그렇다면 어떻게 헌법이 자신이 무엇인지를 말할 권한을 부여할 수 있단 말인가? 그러나 이러한 모순은 다음과 같은 사실을 기억하면 사라진다. 즉, 모든 규칙은 어떤 지점에서는 의문이 제기될 수 있지만, 모든 규칙이 모든 지점에서 의심스러워서는 안 된다는 것이 법체계의 존속을 위한 필수 조건이라는 점이다. 법원이 이러한 궁극적 유효성 기준에 관한 한계적 질문들(limiting questions)을 결정할 권위를 가지는 가능성은, 단지 그 당시에 이 기준들이 적용되는 광범위한 법 영역들—그 권위를 부여하는 규칙들을 포함하여—에 대하여는 별다른 의문이 제기되지 않는다는 사실에 근거한다. 다만 그 범위와 외연(scope and ambit)에 대해서는 의문이 제기될 수 있다는 것이다.

(p. 153) 하지만 이러한 대답은 어떤 이들에게는 그 문제를 지나치게 간단히 처리한 것처럼 보일 수 있다. 그것은 유효성의 기준을 규정하는 근본 규칙(fundamental rules)의 가장자리에 있는 법원의 활동을 지나치게 소극적으로 묘사하는 것처럼 보일 수 있다. 아마도 이는 그러한 활동을, 법원이 특정 법률의 불확정성을 해석하는 통상적인 사안에서의 창조적 선택 행위와 지나치게 동일시하고 있기 때문일 것이다. 물론 이러한 통상적 사례들은 모든 법체계에서 불가피하게 발생하는 것이며, 따라서 법원이 이러한 상황에서 두 가지 가능한 해석 가운데 하나를 선택할 수 있는 관할권을 가지고 있다고 보는 것이 당연하며, 이는 설사 법원이 이 선택을 발견(discovery)인 것처럼 위장하더라도 마찬가지다. 그러나 적어도 성문헌법(written constitution)이 존재하지 않는 경우에는, 유효성의 근본 기준(fundamental criteria of validity)에 대한 질문들은 종종 위에서 말한 것처럼 미리 예상된 사안(previously envisageable issue)의 성격을 가지지 않는(not) 것처럼 보인다. 그래서 이런 질문들이 제기될 경우, 법원이 이를 해결할 명확한 권한을 이미 기존 규칙 하에서 갖고 있다고 말하는 것은 자연스럽지 않다.

어떤 유형의 ‘형식주의적(formalist)’ 오류는, 법원의 모든 판단이 사전에

권한을 부여하는 일반 규칙에 의해 포괄되어 있다고 생각하는 데 있을지도 모른다. 그러한 관점에서는 법원의 창조적 권한도 항상(always) 위임된 입법 권한(delegated legislative power)의 한 형태일 뿐이라고 간주한다. 그러나 진실은 다음과 같을지도 모른다. 즉, 법원이 기존에 예상되지 않았던 사안들에 대하여 헌법상 가장 근본적인 규칙들에 관한 판결을 내릴 때, 그 결정이 내려진 후에야 비로소 그 결정을 내릴 권위(authority)가 인정되게 된다는 것이다. 이 경우에는, 성공만이 성공을 정당화할 뿐(all that succeeds is success)이다. 문제된 헌법적 사안이 사회를 너무 근본적으로 분열시키는 경우에는, 그러한 사안을 법적 판결로 처리하는 것이 불가능할 수도 있다. 남아프리카공화국(South Africa)의 1909년 남아프리카법(South Africa Act)에 규정된 강화 조항들(entrenched clauses)을 둘러싼 사안들은, 한때 법적 해결이 불가능할 정도로 분열적인 문제로 여겨진 적도 있었다. 그러나 보다 덜 중대한 사회적 문제들이 관여된 경우에는, 법의 근원을 다루는 매우 놀라운 법원의 입법행위(judicial law-making)조차도 조용히 수용(swallowed)될 수 있다. 이러한 경우에는, 종종 사후적(retrospect)으로 “법원이 그렇게 할 ‘내재적 권한(inherent power)’을 항상 가지고 있었다”고 말해지기도 하고, 실제로 그렇게 보이기도 한다. 하지만 만약 그에 대한 증거가 오직 “그 일이 성공했다는 사실” 뿐이라면, 이는 경건한 허구(pious fiction)일 수 있다.

영국 법원이 선례의 구속력에 관한 규칙들을 조작하는 방식은, (p. 154) 아마도 이러한 방식으로—즉, 권력을 주장하고 이를 실행에 옮기는 데 성공한 하나의 성공한 시도(successful bid)로 묘사되는 것이 가장 정직할 것이다. 이 경우, 권력은 사후적(ex post facto)으로 권위를 획득한다. 예컨대, 형사항소법원(Court of Criminal Appeal)이 Rex 대 Taylor 사건²⁶에서, 자신이 과거에 내린 선례를 억제하지 않아도 된다고 판시하기 전에는, 그 법원이 그러한 권한을 갖고 있는지 여부는 전적으로 미결(open)된 문제였을 것이다. 그러나 그 판결은 내려졌고, 지금은 법으로서 따르고 있다. 법원이 항상 그러한 방식으로 판단할 내재적 권한을 가졌다고 말하는 것은, 아마도 사태를 실제보다 더 정연하게 보이게 하려는 표현일 뿐일 것이다. 이처럼 이러한 가장 근본적인 것들의 경계에

²⁶[1950] 2 KB 368.

있는 지점에서는, 우리는 규칙회의론자(rule-sceptic)를 기꺼이 환영해야 한다. 다만 그는 자신이 가장자리에서만(fringe) 환영받는다는 점을 잊지 않아야 하며, 법원이 가장 기본적인 규칙들을 발전시킬 수 있는 가능성은, 주로 그들이 법의 광대한 중심 영역에서 의심의 여지 없이 규칙지배(rule-governed)된 작용을 해 왔다는 데서 얻은 권위(prestige) 덕분이라는 사실을 우리로 하여금 망각하게 만들어서는 안 된다.

CHAPTER VII 주석

125쪽. 규칙의 예시적 전달(*Communication of rules by examples*). 이러한 용어로 선례(precedent)의 사용을 특징지은 설명으로는 Levi의 “An Introduction to Legal Reasoning” 제1절, *University of Chicago Law Review* 제15권(1948년)을 보라. Wittgenstein은 *Philosophical Investigations* (특히 제1부 제208-238절)에서 규칙을 가르치고 따르는 개념에 대해 여러 중요한 통찰을 제시한다. Wittgenstein에 대한 논의는 Winch, *The Idea of a Social Science* 제24-33쪽, 91-93쪽 참조.

128쪽. 언어로 공식화된 규칙의 개방적 직조(*Open texture of verbally formulated rules*). 개방적 직조(open texture)의 개념에 대해서는 Waismann의 “Verifiability”, *Essays on Logic and Language* 제1권(Flew 편집), 제117-130쪽을 보라. 법적 추론과 관련한 논의로는 Dewey, “Logical Method and Law,” *Cornell Law Quarterly* 제10권(1924); Stone, *The Province and Function of Law*, 제6장; Hart, “Theory and Definition in Jurisprudence,” *Proceedings of the Aristotelian Society* 보충권 제29권(1955), 제258-264쪽; “Positivism and the Separation of Law and Morals,” *Harvard Law Review* 제71권(1958), 제606-612쪽 참조.

129쪽. 형식주의(*formalism*)와 개념주의(*conceptualism*). 법학에서 이 용어들과 거의 동의어로 사용되는 표현으로는 ‘기계적 또는 자동적 법학(mechanical or automatic jurisprudence)’, ‘개념의 법학(jurisprudence of conceptions)’, ‘논리의 과도한 사용(excessive use of logic)’ 등이 있다. 이와 관련하여 Pound, “Mechanical Jurisprudence,” *Columbia Law Review* 제8권(1908); *Interpretations of Legal History*, 제6장 참조. 이러한 용어들로 어떤 결함 또는 폐해가 지적되는지는 항상 명확하지 않다. 이에 관해서는 Jensen, *The Nature of Legal Argument*, 제1장, 그리고 Honoré의 서평, *Law Quarterly Review* 제74권(1958), 제296쪽; Hart, 위에 언급한 *Harvard Law Review* 제71권, 제608-612쪽을 참조.

131쪽. 법적 기준과 구체적 규칙(*Legal standards and specific rules*). 이러한 두 가지 법적 통제 형태의 성격과 상호 관계에 대한 가장 통찰력 있는 일반적 논의는 Dickinson, *Administrative Justice and the Supremacy of Law*, 제128-140쪽에 있다.

131쪽. 행정 규칙 제정을 통한 법적 기준의 이행(*Legal standards implemented by administrative rule-making*). 미국에서는 Interstate Commerce Commission, Federal Trade Commission 등 연방 규제기관들이 ‘공정 경쟁(fair competition)’, ‘공정하고 합리적인 요율(just and reasonable rates)’ 등의 광범위한 법적 기준을 이행하기 위한 규칙을 제정한다. (Schwartz, *An Introduction to American Administrative Law*, 제6-18쪽, 33-37

쪽 참조.) 영국에서도 이와 유사한 규칙 제정 기능이 행정부에 의해 수행되지만, 일반적으로 미국에서 익숙한 이해관계자에 대한 준사법적 심문(quasi-judicial hearing) 절차 없이 이루어진다. 예컨대, 1957년 *Factories Act* 제46조에 근거한 복지규정(Welfare Regulations), 같은 법 제60조에 의한 건축규정(Building Regulations)을 참조. 또한, 1947년 *Transport Act*에 따라 반대자의 의견을 청취한 후 ‘요금 체계(charges scheme)’를 결정할 수 있는 *Transport Tribunal*의 권한은 미국식 모델에 보다 근접해 있다.

132쪽. 주의의 기준(*Standards of care*). 주의의무(*duty of care*)의 구성요소에 대한 통찰력 있는 분석으로는 Learned Hand 판사의 판결문 *US v. Carroll Towing Co.* (1947), 159 F 2nd 169, 173쪽을 보라. 일반적인 기준을 구체적인 규칙으로 대체하는 바람직성에 대해서는 Holmes, *The Common Law*, 제3강, 제111-119쪽 참조. 이 견해에 대한 비판은 Dickinson, 앞의 책, 제146-150쪽에 제시되어 있다.

133쪽. 구체적 규칙에 의한 통제(*Control by specific rules*). 유연한 기준(*flexible standards*)보다는 엄격하고 고정된 규칙(*hard and fast rules*)이 적절한 통제 형태가 되는 조건에 대해서는 Dickinson, 앞의 책, 제128-132쪽, 제145-150쪽을 보라.

134쪽. 선례와 법원의 입법 활동(*Precedent and the legislative activity of Courts*). 영국법에서의 선례(*precedent in English law*)의 현대적 일반 설명으로는 R. Cross, *Precedent in English Law* (1961)을 보라. 본문에서 언급된 ‘협소화 과정(*narrowing process*)’의 잘 알려진 예시는 *L. & S. W. Railway Co. v. Gomm* (1880), 20 Ch.D. 562로, 이는 *Tulk v. Moxhay* (1848), 2 Ph. 774에서의 법리를 좁혀 적용하였다.

136쪽. 규칙 회의주의의 여러 유형(*Varieties of rule-scepticism*). 이 주제에 대한 미국 법학의 논의는 하나의 논쟁(*debate*)으로 읽을 때 특히 유익하다. 예컨대 *Law and the Modern Mind* (특히 제1장 및 부록 2, “Notes on Rule Fetishism and Realism”)에서의 Frank, *The Bramble Bush*에서의 Llewellyn의 논증은 다음과 같은 저작들을 배경으로 고려할 수 있다: Dickinson, “Legal Rules: Their Function in the Process of Decision,” *University of Pennsylvania Law Review* 제79권(1931); “The Law behind the Law,” *Columbia Law Review* 제29권(1929); “The Problem of the Unprovided Case,” *Recueil d’Études sur les sources de droit en l’honneur de F. Geny*, 제11권 제5장; Kantorowicz, “Some Rationalism about Realism,” *Yale Law Review* 제43권(1934).

139쪽. 실망한 절대주의자로서의 회의주의자(*The sceptic as a disappointed absolutist*). Miller, “Rules and Exceptions,” *International Journal of Ethics* 제66권(1956)을 보라.

140쪽. 규칙의 직관적 적용(*Intuitive application of rules*). Hutcheson, “The Judge-

ment Intuitive”; “The Function of the ‘Hunch’ in Judicial Decision,” *Cornell Law Quarterly* 제14권(1928)을 보라.

141쪽. ‘헌법이란 판사들이 말하는 그것이다(*The constitution is what the judges say it is*).’ 이 표현은 미국의 Hughes 대법원장(Chief Justice Hughes)에게서 유래한 것으로 보이며, Hendel, *Charles Evan Hughes and the Supreme Court* (1951), 제11-12쪽 참조. 그러나 Hughes 자신의 저작인 *The Defence Court of the United States* (1966년판) 제37, 41쪽에서는 헌법 해석에 있어 개인의 정치적 견해로부터 독립된 판사의 의무를 강조하고 있다.

149쪽. 의회 주권에 대한 대안적 분석(*Alternative analyses of the sovereignty of Parliament*). H. W. R. Wade, “The Basis of Legal Sovereignty,” *Cambridge Law Journal* (1955)을 보라. 이 견해는 Marshall, *Parliamentary Sovereignty and the Commonwealth*, 제4장과 제5장에서 비판받고 있다.

149쪽. 의회 주권과 신의 전능성(*Parliamentary sovereignty and divine omnipotence*). Mackie, “Evil and Omnipotence,” *Mind*, 1955년, 제211쪽 참조.

150쪽. 의회를 구속하는 것인가, 재정의하는 것인가(*Binding or redefining Parliament*). 이 구분에 관해서는 Friedmann, “Trethowan’s Case, Parliamentary Sovereignty and the Limits of Legal Change,” *Australian Law Journal* 제24권(1950); Cowen, “Legislature and Judiciary,” *Modern Law Review* 제15권(1952) 및 제16권(1953); Dixon, “The Law and the Constitution,” *Law Quarterly Review* 제51권(1935); Marshall, 앞의 책, 제4장을 보라.

151쪽. 1911년 및 1949년 의회법(*Parliament Acts 1911 and 1949*). 이들 법률이 위임 입법(*delegated legislation*)의 형식을 허용한 것으로 해석하는 견해는 H. W. R. Wade, 위 저작 및 Marshall, 위 저작 제44-46쪽 참조.

152쪽. 1931년 웨스트민스터 법령(*Statute of Westminster*), 제4조. 해당 조항의 제정이 도미니언에 대한 입법권을 그들의 동의 없이 되돌릴 수 없는 방식으로 종결시킬 수 없다는 견해가 다수설이다. *British Coal Corporation v. The King* (1935), AC 500; Wheare, *The Statute of Westminster and Dominion Status*, 제5판, 제297-298쪽; Marshall, 위 저작 제146-147쪽 참조. 이에 반하여, “한 번 부여된 자유는 철회될 수 없다(*Freedom once conferred cannot be revoked*)”는 견해는 남아프리카 법원에서 *Ndlwana v. Hofmeyr* (1937), AD 229, 제237쪽에서 표현된 바 있다.

CHAPTER VII 제3판 주석

124-128쪽. 법의 개방적 직조(*Open texture of law*). 일반적인 논의로는 Avishai Margalit, “Open Texture” (1979), *Meaning and Use* 제3권 141쪽을 보라. 하트(Hart)가 ‘개방적 직조(open texture)’ 개념을 어떻게 사용하는지에 대해서는 Brian Bix, *Law, Language, and Legal Determinacy* (Oxford University Press, 1993), 제1장을 참조하라. 법의 불확정성(indeterminacy)의 다른 근원들에 대해서는 Kelsen, *Pure Theory of Law*, 제348-356쪽을 참조. 불확정성과 그에 따른 재량(discretion)에 대한 드워킨(Dworkin)의 비판은 *Taking Rights Seriously* 제31-39쪽, 제4장, 제13장과 *A Matter of Principle* (Harvard University Press, 1986), 제5장에서 볼 수 있다. 드워킨의 이러한 비판은 David Brink, “Legal Theory, Legal Interpretation and Judicial Review” (1988), *Philosophy & Public Affairs* 제17권 105쪽 및 Nicos Stavropoulos, “Hart’s Semantics” in Jules Coleman 편, *Hart’s Postscript* 중 특히 제88-98쪽에서 긍정적으로 평가된다. 반면에 Andrei Marmor, *Interpretation and Legal Theory*, 제2판 (Hart Publishing, 2005), 제7장에서는 이 비판을 수용하지 않는다.

128-134쪽. 일반 규칙과 개별 사안(*General rules and particular cases*). 규칙 기반 결정(rule-based decision-making)의 본질에 대해서는 David Lyons, *Forms and Limits of Utilitarianism* (Oxford University Press, 1965), Frederick Schauer, *Playing By the Rules: A Philosophical Examination of Rule-Based Decision-Making in Law and in Life* (Oxford University Press, 1991), 특히 제5장, 그리고 Larry Alexander와 Emily Sherwin, *The Rule of Rules: Morality, Rules, and Dilemmas of Law* (Duke University Press, 2001), 제1장과 제2장을 참조하라.

128-129쪽. 전형적 사례(*Paradigm cases*). 전형적 사례가 수행하는 역할에 대한 하트의 이해를 옹호하는 논의로는 Timothy Endicott, *Vagueness in Law* (Oxford University Press, 2000), 제7장을 보라. 이에 반대하는 드워킨의 견해는 *Law’s Empire*, 제3장, 특히 제90-94쪽에 제시되어 있다. 이에 대한 응답으로는 Endicott, “Herbert Hart and the Semantic Sting” in Jules Coleman 편, *Hart’s Postscript* (Oxford University Press, 2001)을 보라.

129-130쪽. 형식주의(*Formalism*). ‘형식주의(formalism)’라는 용어는 다른 방식으로 사용된다. 관련 논의로는 Martin Stone, “Formalism” in Jules Coleman and Scott Shapiro 편, *The Oxford Handbook of Jurisprudence and Philosophy of Law* (Oxford University Press, 2002)을 참조하라.

130-132쪽. 불확정성과 재량(*Indeterminacy and discretion*). 법은, 지적 가능한

법적 질문에 대해 하나의 고유한(unique) 정당한 해답을 제공하지 못할 때, 즉 법이 불완전할 때 불확정적(indeterminate)이다. 이는 어떤 사건이 ‘어렵다(hard)’는 것과 동일하지 않다. 후자의 경우는 유일한 정답이 존재하나 그 정답이 분명하지 않거나, 또는 이에 대한 이견이 있는 경우이다. 또한 이는 법이 실제로(인과적으로) 판결을 결정짓는다는 주장과도 다르다. 법은 전적으로 확정적일 수 있지만 판사가 그것을 알지 못하거나, 알고도 적용하지 않을 수 있다. 법의 확정성(legal determinacy)은 판결의 예측 가능성(decisional predictability)을 함의하지 않는다. (비교: Brian Leiter, “Legal Indeterminacy” (1995), *Legal Theory* 제1권 481쪽) 하트가 옹호하는 것은 법의 정당화적 불확정성(justificatory indeterminacy)이다. 이에 반대하는 입장은 Ronald Dworkin, “No Right Answer?” in P. M. S. Hacker and Joseph Raz 편, *Law, Morality and Society*, 그리고 Ronald Dworkin, “On Gaps in the Law” in Paul Amselek and Neil MacCormick 편, *Controversies About Law’s Ontology* (Edinburgh University Press, 1991)에서 제시된다. 이에 대한 옹호는 Joseph Raz, *The Authority of Law*, 제4장에서 찾을 수 있다.

131-133쪽. 규칙과 가변적 기준(Rules and variable standards). 이 지점에서 하트(Hart)는 규칙(rule)을 도입할 것인가 여부(whether)에 대해 논의하는 것이 아니라, 다양한 상황에 적합한 어떤 종류(kind)의 규칙이 존재할 수 있는지를 논의하고 있다. 미국의 법률가들은, 헨리 하트(Henry Hart, H. L. A. Hart와는 무관)와 앨버트 삭스(Albert Sacks)의 영향을 받아, 때때로 ‘규칙(rules)’과 ‘기준(standards)’을 구분하지만, H. L. A. Hart에게 기준(standards)은 규칙의 한 유형이다. 이 구분에 대해서는 Henry M. Hart and Albert Sacks, *The Legal Process: Basic Problems in the Making and Application of Law* (W. N. Eskridge, Jr. and P. P. Frickey 편집, Foundation Press, 1994) 139-141쪽, 그리고 Pierre J. Schlag, “Rules and Standards” (1985) *UCLA Law Review* 제33권 379쪽을 참조하라. 마찬가지로, 흔히 ‘원칙(principles)’이라 불리는 것들도 하트의 규칙 개념에 포함되며, 그는 드워킨(Dworkin)이 *Taking Rights Seriously* 제22-28쪽에서 설정한 것과 같은 규칙과 원칙 간의 범주적 구분을 거부한다. 이에 대한 하트의 입장은 *Postscript* 제261-263쪽에 언급되어 있다. 관련 논의로는 Joseph Raz, “Legal Principles and the Limits of Law” (1972) *Yale Law Journal* 제81권 823쪽, Larry Alexander and Ken Kress, “Against Legal Principles” (1997) *Iowa Law Review* 제82권 739쪽을 참조하라.

134-135쪽. 선례(Precedent). 이 주제에 관한 문헌은 매우 풍부하다. 참고문헌으로는 다음을 보라: A. W. B. Simpson, “The Common Law and Legal Theory” in A. W. B. Simpson 편, *Oxford Essays in Jurisprudence*; Ronald Dworkin, *Taking Rights Seriously* 제110-123쪽; Neil MacCormick, *Legal Reasoning and Legal Theory* (수정판, Oxford Uni-

versity Press, 1994); Laurence Goldstein 편, *Precedent in Law* (Oxford University Press, 1987); Stephen Perry, “Judicial Obligation, Precedent and the Common Law” (1987) *Oxford Journal of Legal Studies* 제7권 215쪽; Frederick Schauer, “Precedent” (1987) *Stanford Law Review* 제39권 571쪽; Susan Hurley, “Coherence, Hypothetical Cases, and Precedent” (1990) *Oxford Journal of Legal Studies* 제10권 221쪽; Larry Alexander, “Precedent” in Dennis Patterson 편, *A Companion to the Philosophy of Law and Legal Theory* (Blackwell, 1996); Neil Duxbury, *The Nature and Authority of Precedent* (Cambridge University Press, 2008).

136–141쪽. 규칙회의주의의 다양한 유형들(*Varieties of rule scepticism*). 하트의 관련 에세이로는 “American Jurisprudence through English Eyes: The Nightmare and the Noble Dream” (*Essays in Jurisprudence and Philosophy*, 제4장)이 있다. 하트의 저작 이후 등장한 가장 저명한 규칙회의주의자(rule-sceptics)는 미국의 ‘비판법학(Critical Legal Studies, CLS)’ 운동의 법학자들이었다. 철학적으로는 덜 정교하지만 영향력 있는 논의로는 Roberto Unger, *The Critical Legal Studies Movement* (Harvard University Press, 1986), 특히 제1–14쪽, 그리고 Duncan Kennedy, *A Critique of Adjudication [fin de siècle]* (Harvard University Press, 1997)를 들 수 있다. 초기 CLS 문헌에 대한 비판적 논의는 Ken Kress, “Legal Indeterminacy” (1989) *California Law Review* 제77권 283쪽을 참조하라. 또한 John Finnis, “On the Critical Legal Studies Movement”, 그의 *Philosophy of Law* 제13장, Andrew Altman, *Critical Legal Studies: A Liberal Critique* (Princeton University Press, 1990)도 보라. Brian Leiter는 “Legal Realism and Legal Positivism Reconsidered”, 그의 *Naturalizing Jurisprudence* (Oxford University Press, 2007) 제2장에서 하트의 규칙회의주의 유형을 다룬다.

VIII. 정의(Justice)와 도덕성(Morality)

우리는 법을 사회 통제의 수단으로서 특징짓는 요소들을 설명하기 위해, 명령(order), 위협(threat), 복종(obedience), 습관(habits), 일반성(generality)이라는 개념들만으로는 구성할 수 없는 요소들을 도입할 필요가 있음을 확인하였다. 법의 특징적인 요소들은 이러한 단순한 개념들로 설명하려 할 때 심각하게 왜곡된다. 따라서 우리는 일반적인 습관(general habit)의 개념과 구별되는 사회적 규칙(social rule)의 개념을 도입하고, 규칙이 행위의 지침적이고 비판적인 기준으로 사용된다는 점에서 드러나는 규칙의 내적 측면(internal aspect)을 강조하였다. 이어서 우리는 규칙들 가운데 의무를 규정하는 일차적 규칙(primary rules of obligation)과, 승인·변경·재판에 관한 이차적 규칙들(secondary rules of recognition, change, and adjudication)을 구분하였다. 이 책의 중심 주제는, 법의 독특한 작동 방식들과 법사상의 틀을 구성하는 많은 개념들이 이러한 두 유형의 규칙 중 하나 또는 양자를 참조해야만 비로소 설명될 수 있으며, 이들 규칙의 결합이 비록 ‘법(law)’이라는 단어가 적절하게 사용되는 모든 경우에 항상 함께 존재하지는 않더라도, 법의 ‘본질(essence)’로 간주될 수 있다는 것이다. 우리가 이러한 결합에 중심적인 위치를 부여하는 정당화는 그것들이 사전의 정의처럼 기능하기 때문이 아니라, 그것들이 강력한 설명력을 갖기 때문이다.

이제 우리는 법의 ‘본질’(essence), ‘성격’(nature), 또는 ‘정의’(definition)에 대한 오래된 논의 속에서, 우리가 부적절하다고 판단한 단순한 명령 이론(simple imperative theory)에 가장 자주 반대되는 주장에 주목해야 한다. 그것은 다음과 같은 일반적 주장이다. 즉, 법과 도덕 사이에는 어떤 의미에서든 ‘필연적(necessary)’인 연결이 존재하며, 이 연결이야말로 법 개념을 분석하고 설명하려는 모든 시도에서 중심에 놓여야 한다는 것이다. 이러한 입장의 옹호자들은 우리가 제시한 단순 명령 이론에 대한 비판과 굳이 다투려 하지 않을 수도 있다. 그들은 오히려 이러한 비판이 유용한 진전이며, 위협에 의해 뒷받침된 명령보다는 1차 규칙과 2차 규칙의 결합이 법 이해의 출발점으로서 훨씬 더 중요하다는 데 동의할지도 (p. 156) 모른다. 그러나 그들은 여전히 이러한 요소들조차도 부차적인 것에 불과하며, 도덕과의 ‘필연적’ 관계를 명확히 하고

그것의 중심적 중요성을 인식하지 않는 한, 법 개념에 대한 이해를 오랫동안 흐려왔던 안개는 결코 걷히지 않을 것이라고 논증할 것이다. 이러한 관점에서 본다면, 법의 성격이 의심스럽거나 논쟁적인 사례는 단지 입법부, 강제 관할권을 가진 법원, 중앙 조직된 제재를 결여한 원시 사회의 법이나 국제법에만 국한되지 않는다. 오히려 이 관점에서 더 심각하게 문제되는 것은 판사, 경찰, 입법자(juge, gendarme et législateur)의 모든 요소를 갖추고 있음에도 불구하고 정의(justice)나 도덕(morality)의 몇 가지 근본적인 요건을 충족하지 못하는 국내 법체계들(municipal systems)이 과연 법으로 간주될 수 있는가 하는 것이다. 성 아우구스티누스(St. Augustine)의 말처럼²⁷, “정의 없는 국가란 확대된 도적 떼에 불과하지 않은가?”

법과 도덕 사이에 필연적 연결이 존재한다는 주장은 여러 중요한 변형들을 갖고 있으며, 그 중 많은 것들은 명료함이 결여되어 있다. ‘필연적’(necessary)이라는 용어와 ‘도덕’(morality)이라는 용어에는 다양한 해석 가능성이 존재하며, 옹호자든 비판자든 이러한 해석들이 항상 구별되거나 개별적으로 고려되어 온 것은 아니다. 이 관점의 가장 분명하고 아마도 가장 극단적인 표현은 토마스 주의(Thomist tradition)의 자연법(Natural Law) 전통에서 발견된다. 이 전통은 두 가지 주장을 포함한다. 첫째, 진정한 도덕 또는 정의의 원칙은 신적 기원을 가졌다고 하더라도 계시(revelation)의 도움 없이 인간의 이성으로 인해 발견될 수 있다는 것이다. 둘째, 이러한 원칙들과 충돌하는 인간이 만든 법(man-made laws)은 유효한 법이 아니라는 것이다. 즉, “부정의한 법은 법이 아니다(Lex iniusta non est lex).” 이 일반적 입장의 다른 변형들은 도덕 원칙의 지위나 법과 도덕 사이 충돌의 결과에 대해 서로 다른 견해를 취한다. 어떤 이들은 도덕성을 변하지 않는 행위 원칙이나 이성으로 발견 가능한 것으로 보지 않고, 사회마다 혹은 개인마다 달라질 수 있는 행위에 대한 인간의 태도 표현으로 본다. 이러한 유형의 이론들은 대개, 법과 도덕의 가장 근본적인 요건 사이에 충돌이 있다 하더라도 그것만으로는 규칙이 법의 지위를 (p. 157) 상실하게 만들 수 없다고 본다. 그들은 법과 도덕 사이의 ‘필연적’ 연결을 다른 방식으로 해석한다. 그들은 다음과 같이 주장한다. 즉, 하나의 법체계가 존재하려면, 법을 따를 도덕적

²⁷De Civitate Dei, IV, 4.

의무에 대한 광범위한 인정—비록 그것이 보편적일 필요는 없더라도—이 있어야 한다는 것이다. 물론 이러한 의무는 특정한 경우에는 더 강한 도덕적 의무, 예컨대 부정의한 법을 따르지 말아야 할 도덕적 의무에 의해 무효화될 수도 있다.

법과 도덕 사이에 필연적 연결이 존재한다는 다양한 이론들을 완전히 평가하기 위해서는 도덕 철학(moral philosophy)의 심층으로 들어가야 할 것이다. 그러나 그보다 덜한 작업만으로도 사려 깊은 독자에게 이러한 주장들의 진실성과 중요성에 대해 이성적인 견해를 형성할 수 있는 충분한 자료를 제공할 수 있다. 이를 위해 가장 필요한 것은 오랫동안 얽혀 있던 쟁점들을 구분하고 식별하는 것이다. 우리는 이 장과 다음 장에서 그 작업을 수행할 것이다. 첫 번째 쟁점은 도덕성(morality)의 일반 영역 안에서 ‘정의(justice)’라는 특정한 개념과 그것이 법과 특히 밀접한 관계를 갖는 이유를 설명하는 고유한 특성들에 관한 것이다. 두 번째 쟁점은 도덕 규칙과 원칙이 법 규칙뿐만 아니라 다른 모든 형태의 사회 규범 또는 행위 기준들과 구별되는 특성들에 관한 것이다. 이 두 가지 쟁점이 이 장의 주제이며, 다음 장의 주제는 법 규칙과 도덕이 서로 관계한다고 말할 수 있는 다양한 의미들과 방식들에 관한 것이다.

1. 정의의 원칙들 (Principles of Justice)

법률가들이 법이나 그 집행을 칭찬하거나 비판할 때 가장 자주 사용하는 용어는 ‘정의로운(just)’과 ‘부정의한(unjust)’이라는 단어이며, 종종 정의(justice)와 도덕(morality)의 개념이 서로 동일한 범위를 갖는 것처럼 서술하곤 한다. 정의가 법적 제도를 비판하는 데 있어 가장 중심적인 자리를 차지해야 하는 데는 분명한 이유들이 있다. 그러나 정의는 도덕의 한 독립된 영역이라는 점, 그리고 법과 법의 집행은 서로 다른 종류의 우수성을 가질 수도, 또는 결여할 수도 있다는 점을 분명히 인식하는 것이 중요하다. 일상적인 도덕 판단의 몇 가지 유형에 대해 조금만 반성해보아도 정의가 지니는 이러한 특수한 성격은 쉽게 드러난다. 예컨대, 자녀에게 극심한 학대를 저지른 사람에 대해 우리는 그가 도덕적으로 그릇된(wrong), 나쁜(bad), 심지어 사악한(wicked) 행위를 했다고 판단하거나,

자녀에 대한 도덕적 의무(obligation) 혹은 책무(duty)를 저버렸다고 (p. 158) 비판할 수 있다. 그러나 이러한 행위를 부정의하다(unjust)고 비판하는 것은 어색할 것이다. 이는 ‘unjust’라는 단어가 비난의 권총강도가 약하기 때문이 아니라, 정의 또는 부정의라는 표현이 지닌 도덕적 비판의 관점이 이 경우에 적절한 ‘wrong’, ‘bad’, 또는 ‘wicked’와 같은 일반적인 도덕 비판들과는 다르고 더 구체적이기 때문이다. ‘부정의하다(unjust)’는 표현은, 예를 들어 그 사람이 자녀들 가운데 하나만을 자의적으로 골라 동일한 잘못에 대해 더 엄하게 벌했거나, 그 아이가 실제로 잘못을 저질렀는지를 확인하지도 않고 처벌한 경우어야 비로소 적절해질 것이다. 마찬가지로, 개인 행위에 대한 비판에서 법에 대한 비판으로 관심을 옮길 경우에도, 우리는 ‘부모가 자녀를 학교에 보내도록 요구하는 법’을 칭찬하며 ‘좋은 법(good law)’이라 말할 수 있고, ‘정부 비판을 금지하는 법’에 대해 ‘나쁜 법(bad law)’이라며 반대할 수 있다. 그러나 이러한 비판들은 일반적으로 ‘정의(justice)’나 ‘부정의(injustice)’라는 용어로 표현되지는 않는다. 반면에, ‘부의 정도에 따라 세금 부담을 분배하는 법’을 찬성할 때 ‘정의롭다(just)’는 표현이 적절하고, ‘유색인종의 대중교통 또는 공원 이용을 금지하는 법’을 반대할 때 ‘부정의하다(unjust)’는 표현이 적절하다. ‘정의롭다(just)’와 ‘부정의하다(unjust)’는 ‘좋다(good)’나 ‘옳다(right)’ 또는 ‘나쁘다(bad)’나 ‘그르다(wrong)’보다 더 구체적인 도덕적 평가라는 점은 다음과 같은 사실에서 분명해진다. 즉, 우리는 어떤 법이 ‘정의롭기 때문에 좋다(good because it was just)’거나, ‘부정의하기 때문에 나쁘다(bad because it was unjust)’라고 말할 수는 있어도, ‘좋기 때문에 정의롭다(just because good)’거나, ‘나쁘기 때문에 부정의하다(unjust because bad)’라고 말할 수는 없기 때문이다.

정의의 고유한 특징들과 그것이 법과 맺는 특별한 관계는, 정의롭다(just)와 부정의하다(unjust)라는 용어로 이루어진 비판들의 대부분이 거의 동등하게 ‘공정하다(fair)’와 ‘불공정하다(unfair)’라는 용어로 전달될 수 있다는 사실을 관찰함으로써 드러나기 시작한다. 공정성(fairness)은 일반적 도덕성과 반드시 같은 범위를 가지지 않으며, 사회생활에서 주로 두 가지 상황에서 관련성을 갖는다. 첫째는, 단일한 개인의 행위가 아니라 집단(classes) 내의 개인들이 어떤 방식으로 대우받는지를 문제 삼는 경우이다. 이때 특정한 부담이나 혜택이

이들 사이에 분배되는데, 이때 공정하거나 불공정하다는 표현이 가장 적절하다. 이처럼 전형적으로 공정하거나 불공정한 것은 ‘몫(share)’이다. 둘째는, 어떤 피해가 발생하여 보상(compensation)이나 구제(redress)가 요구되는 경우이다. 물론 이러한 상황들이 (p. 159) 정의나 공정성의 판단이 이루어지는 유일한 맥락은 아니다. 우리는 분배(distributions)나 보상(compensations)뿐 아니라, 판사(judge)를 두고 ‘정의롭다(just)’ 또는 ‘부정의하다(unjust)’라고 하기도 하고, 재판(trial)을 두고 ‘공정하다(fair)’ 또는 ‘불공정하다(unfair)’라고 하며, 어떤 사람이 ‘정의롭게 유죄판결을 받았다(justly convicted)’거나 ‘부정의하게 유죄판결을 받았다(unjustly convicted)’고 말하기도 한다. 이러한 표현들은 정의 개념의 파생적 응용들인데, 이는 정의 개념이 분배와 보상의 문제에 일차적으로 적용된다는 점이 이해되면 설명이 가능하다.

정의 개념의 이러한 다양한 적용에 내재한 일반 원리는 다음과 같다. 즉, 개인들은 서로 간에 특정한 상대적 평등 또는 불평등의 지위를 가질 자격이 있으며, 사회생활의 부침 속에서 부담이나 혜택이 분배될 때 이것은 존중되어야 하며, 그러한 균형이 무너졌을 때는 회복되어야 한다. 이 때문에 정의는 전통적으로 균형(balance) 또는 비례(proportion)의 유지 또는 회복으로 간주되어 왔고, 그 주요한 격률은 흔히 ‘같은 것은 같게 대우하라(Treat like cases alike)’라고 표현된다. 다만 여기에 ‘다른 것은 다르게 대우하라(and treat different cases differently)’는 명제를 덧붙여야 한다. 따라서, 우리가 정의의 이름으로 유색인종이 공공 공원을 사용하는 것을 금지하는 법에 항의하는 이유는, 그러한 법이 공공 시설의 혜택을 인구에 분배함에 있어 모든 관련 측면에서 동일한 사람들 사이에 차별을 두기 때문에 ‘나쁜 법’이라는 것이다. 반대로, 어떤 법이 정의롭다(just)고 칭찬받는 경우, 예컨대 과세(taxation)에서 어떤 특수 계층에게 부여되던 특혜나 면제를 철회하는 법에 대해서는, 해당 특권 계층과 일반 시민 사이에 그와 같은 특별한 대우를 정당화할 수 있는 관련된 차이가 존재하지 않는다는 점이 핵심 판단이 된다. 이러한 간단한 예들만으로도, ‘같은 것은 같게, 다른 것은 다르게 대우하라(Treat like cases alike and different cases differently)’는 명제가 정의 개념의 핵심 요소라는 점은 분명하다. 그러나 그것만으로는 불완전하며, 추가적인 설명 없이는 행위에 대한 어떤 확정적인 지침도 제공할 수

없다. 왜냐하면 어떤 인간 집단도 어떤 측면에서는 서로 비슷하고, 또 다른 측면에서는 서로 다르기 때문이다. 그리고 관련된 유사점이나 차이점이 무엇인지를 설정하지 않는 한, ‘같은 것을 같게 대우하라’는 명제는 공허한 형식에 불과하다. 이를 실질화하기 위해서는, 주어진 목적에 비추어 어떤 경우들이 서로 유사한 것으로 간주되어야 하는지, 또 어떤 차이점이 관련성이 있는지를 알아야 한다. 이러한 추가적 설명 없이는 우리는 법률이나 기타 사회 제도를 부정의하다고 비판할 수 없다. 예컨대, 법이 살인을 금지하면서 (p. 160) 붉은 머리카락을 가진 살인자를 다른 살인자들과 동일하게 처벌하는 것은 부정의하지 않으며, 오히려 이들을 다르게 처벌한다면 그것이야말로 부정의일 것이다. 마찬가지로, 정신 이상자와 정상인을 구별하지 않고 동일하게 취급하는 것 또한 부정의일 것이다.

정의(justice) 개념의 구조에는 일정한 복잡성이 존재한다. 우리는 정의가 두 부분으로 구성되어 있다고 말할 수 있다. 하나는 ‘같은 것은 같게 대우하라 (Treat like cases alike)’는 격률로 요약되는 고정적이거나 일정한 요소이며, 다른 하나는 주어진 목적에 따라 어떤 경우들이 유사하거나 상이하다고 판단하는데 사용되는 유동적이거나 가변적인 기준이다. 이러한 점에서 정의는 진품(genuine), 키가 큰(tall), 따뜻한(warm)과 같은 개념들과 유사한데, 이들 개념 역시 적용 대상의 분류에 따라 달라지는 기준을 암묵적으로 포함하고 있다. 예컨대 키가 큰 어린이는 키가 작은 어른과 같은 키일 수 있고, 따뜻한 겨울은 추운 여름과 같은 온도일 수 있으며, 가짜 다이아몬드가 진품 골동품일 수도 있다. 그러나 정의는 이러한 개념들보다 훨씬 더 복잡한데, 이는 정의에 포함된 서로 다른 경우들 간의 관련성 있는 유사성이라는 유동적 기준이 적용 대상의 유형에 따라 달라질 뿐 아니라, 단일한 유형의 대상에 대해서조차도 그 기준이 종종 이전의 여지가 있기 때문이다.

실제로 특정한 경우들에서는, 정의로운 또는 부정의한 법적 제도를 비판하는데 있어 관련성이 있는 인간들 사이의 유사점과 차이점이 매우 분명한 경우도 있다. 이는 특히 법(law)의 정의 또는 부정의가 아니라, 법의 특정 사례에의 적용(application)의 정의 또는 부정의에 대해 논할 때 그러하다. 이러한 경우에는, 법을 집행하는 자가 반드시 고려해야 할 개인들 간의 관련성 있는 유사점과 차이점이 법 자체에 의해 결정된다. 살인죄에 관한 법이 정의롭게 적용되었다고

말하는 것은, 그 법이 법이 금지한 행위를 저지른 사람들 모두에게, 그리고 오직 그러한 사람들에게 공정하게 적용되었다는 뜻이다. 즉, 편견이나 사적 이해가 법 집행자가 이들을 ‘동등하게’ 다루는 것을 방해하지 않았다는 것이다. 이와 일관되게, ‘다른 쪽의 말을 들어라(audi alteram partem)’ 나 ‘자신의 사건에서는 판사가 될 수 없다(let no one be a judge in his own cause)’와 같은 절차적 기준은 정의의 요건으로 간주되며, 영국과 미국에서는 종종 자연법적 정의(Natural Justice)의 원칙으로 언급된다. 이는 이러한 절차들이 공정성(impartiality) 또는 객관성(objectivity)을 보장하고, 법이 법 자체가 정한 관련성 있는 기준에 따라 모든 해당자에게, 그리고 오직 그들에게만 적용되도록 하기 위해 설계되었기 때문이다.

(p. 161) 정의의 이러한 측면과 규칙(rule)에 따라 절차를 진행하는 개념 사이에는 명백히 밀접한 연결이 존재한다. 실제로, 서로 다른 사건들에 법을 정의롭게 적용한다는 것은, 편견, 사적 이해, 또는 변덕 없이, 동일한 일반 규칙이 적용되어야 한다는 주장 자체를 진지하게 받아들이는 것이라 말할 수도 있다. 이러한 정의로운 법 집행과 규칙 개념 사이의 긴밀한 연관성 때문에, 몇몇 저명한 사상가들은 정의를 법에 대한 순응(conformity to law)과 동일시하려는 유혹을 받기도 했다. 그러나 이는 ‘법(law)’이라는 개념에 특별히 넓은 의미가 부여되지 않는 한 분명한 오류이다. 왜냐하면 이러한 정의 개념은 정의라는 이름으로 가해지는 비판이 단지 특정 사건들에 대한 법의 집행에만 국한되는 것이 아니라, 법 자체가 정의롭거나 부정의하다는 비판의 대상이 되는 경우도 많다는 사실을 설명하지 못하기 때문이다. 실제로, 유색인종의 공원 출입을 금지하는 부정의한 법이, 오직 해당 법을 위반한 자들에게만 공정한 재판을 거쳐 처벌이 내려졌다는 점에서 정의롭게 집행되었다고 인정하는 데 아무런 모순은 없다.

이제 법의 집행이 아니라 법 자체가 정의로운지 부정의한지를 평가하는 문제로 전환하면, 법 자체가 법의 규칙들이 같은 것은 같게 대우함으로써 정의로우려면 어떤 유사점과 차이점을 개인들 사이에서 인식해야 하는지를 결정할 수는 없다는 점이 분명해진다. 여기에는 많은 의문과 논쟁의 여지가 있다. 일반적인 도덕적 및 정치적 관점의 근본적인 차이는, 어떤 인간의 특성이 법이

부정의하다는 비판에 관련성이 있는 것으로 간주되어야 하는지를 두고 타협 불가능한 의견 차이와 논쟁을 야기할 수 있다. 예컨대, 앞의 예에서 우리가 유색인종의 공원 출입을 금지하는 법을 부정의하다고 낙인찍은 것은, 적어도 그러한 공공 편의시설의 분배에 있어서 피부색의 차이는 관련성이 없다는 전제에 따른 것이다. 확실히 현대 사회에서, 피부색에 관계없이 인간은 모두 사고, 감정, 그리고 자기 통제의 능력을 지닌 존재라는 사실은 일반적으로(비록 보편적으로는 아니지만) 법이 고려해야 할 결정적인 유사점으로 받아들여진다. 이러한 이유로 대부분의 문명국가에서는 형사법(criminal law)이 (자유를 제한할 뿐 아니라 여러 해악으로부터 보호를 제공하는 것으로 간주되고), 민사법(civil law)이 (해악에 대한 구제를 제공하는 것으로 (p. 162) 간주되는 한에서), 이러한 부담과 혜택의 분배에 있어 인종이나 종교적 신념과 같은 특성에 따라 사람들을 차별한다면 이는 부정의하다는 데 광범위한 합의가 존재한다. 만일 법이 그러한 잘 알려진 인간적 편견의 초점들(foci) 대신, 키, 몸무게, 혹은 외모와 같은 명백히 무관한 요소들을 기준으로 차별한다면, 이는 부정의할 뿐 아니라 우스꽝스러운 일이 될 것이다. 예컨대, 국교회 신자에게는 사형을 면제해주고, 귀족만이 명예훼손으로 고소할 수 있으며, 유색인에 대한 폭행은 백인에 대한 폭행보다 덜 엄하게 처벌된다면, 대부분의 현대 사회에서는 이러한 법들은 정의의 이름으로 단죄될 것이다. 왜냐하면 인간은 본래 서로 동등하게 대우받아야 하며, 이러한 특권이나 면책은 어떠한 관련성 있는 근거도 없이 부여된 것이기 때문이다.

현대인에게는 인간이 본래 서로 동등하게 대우받아야 한다는 원칙이 매우 깊이 뿌리내려져 있어서, 법이 피부색이나 인종과 같은 기준에 따라 차별을 가하는 경우에도, 최소한 겉으로는 이 원칙을 수용하는 태도를 거의 보편적으로 보인다. 이러한 차별이 비판을 받을 경우, 차별을 옹호하는 측은 흔히 차별받는 계층이 특정한 본질적 인간 속성을 결여했거나 아직 그것을 개발하지 못했다고 주장한다. 또는 유감스럽긴 하나, 정의가 요구하는 평등한 대우의 원칙은, 더 큰 가치를 보존하기 위해—만약 그러한 차별이 이루어지지 않는다면 위협받을 가치—희생되어야 한다고 주장되기도 한다. 그러나 오늘날에는 이러한 겉치레적 태도가 일반화되었음에도 불구하고, 인간이 본래 서로 동등하게 대우받아야 한다는 원칙 자체를 대놓고 부정하며, 차별과 불평등을 정당화하기 위해 이와

같은 종종 기만적인 장치들에 의존하지 않는 도덕 체계를 상상하는 것은 충분히 가능하다. 이와 같은 체계에서는 인간이 자연스럽고 불변적으로 특정한 계급으로 나뉜다고 여겨지며, 어떤 자들은 본래 자유롭게 살도록 태어났고, 다른 자들은 그들의 노예로서—아리스토텔레스의 표현을 빌리자면 타인의 살아있는 도구(living instruments)로서—살도록 태어났다고 여길 수 있다. 이 경우 인간 상호 간의 본래적 평등(prima facie equality) 개념은 부재하게 된다. 이러한 견해의 흔적은 아리스토텔레스나 플라톤에게서 발견할 수 있으며, 그들조차도 노예제도를 정당화하기 위해서는 노예가 독립적으로 존재할 수 있는 능력이 결여되었거나, 선한 삶(good life)의 이상을 실현할 수 있는 능력이 자유인과는 다르다는 점을 보여주어야 한다는 암시를 주고 있다.

(p. 163) 그러므로 인간 사이의 관련성 있는 유사점과 차이점을 결정하는 기준은, 개인이나 사회의 근본적인 도덕적 관점에 따라 달라질 수 있음이 분명하다. 이러한 경우에는, 법의 정의성 또는 부정의성에 대한 판단은, 서로 다른 도덕 체계에 근거한 반론과 마주하게 된다. 그러나 어떤 법이 달성하고자 하는 목적이 명백한 경우, 그 목적에 비추어 어떤 유사점과 차이점이 정의로운 법이 인식해야 할 것인지가 명백해질 수 있으며, 그 경우에는 그 판단이 거의 이견의 여지가 없을 수 있다. 예컨대, 어떤 법이 빈곤 구제를 위한 것이라면, ‘같은 것은 같게 대우하라(Treat like cases alike)’는 원칙은 구제를 요구하는 이들의 필요(need)에 주목하는 것을 요구하게 될 것이다. 유사하게, 누진소득세를 통해 과세 대상자의 재산 수준에 따라 조정되는 과세 방식에서도 필요의 기준은 암묵적으로 수용되고 있다. 때로는, 특정 법이 다루는 기능과 관련하여 사람들의 역량들(capacities)이 관련성이 있는 기준이 된다. 선거권에서 배제되거나, 유언이나 계약을 체결할 수 있는 권한을 아동이나 정신질환자에게 부여하지 않는 법은, 이러한 자들이 이 제도를 이성적으로 활용할 수 있는 능력을 결여하고 있다고 간주되기 때문에 정의로운 것으로 간주된다. 이러한 차별은 명백히 관련성이 있는 근거에 기반한 것이지만, 성별이나 인종 간의 차별은 그렇지 않다. 물론 여성이나 유색인종은 백인 남성의 이성적 사고와 결정 능력을 결여하고 있다는 주장 아래, 여성과 유색인종의 종속을 옹호하려는 시도는 있어왔다. 그러나 이와 같은 주장은, 결국 특정 기능에 대한 동등한 능력이 정의의 기준이라는

점을 인정하는 것에 다름 아니며, 여성이나 유색인종이 이러한 능력을 결여하고 있다는 실질적 증거 없이 이 원칙에 단지 겉으로만 동의하고 있음을 드러내는 것에 불과하다.

지금까지 우리는 개인들 간에 부담과 혜택을 분배(distributing)하는 것으로 볼 수 있는 법의 정의 또는 부정의에 대해 살펴보았다. 그중 일부 혜택은 구호금이나 식량 배급처럼 유형적(tangible)인 것이고, 다른 일부는 형법이 제공하는 신체적 피해로부터의 보호나, 유언 또는 계약 능력에 관한 법률이 제공하는 제도적 수단, 혹은 참정권과 같은 무형적(intangible) 혜택이다. 이제 이러한 넓은 의미의 분배와는 구별되는, 한 사람이 다른 사람에게 가한 손해에 대한 보상(compensation)의 문제를 살펴보자. 이 경우 (p. 164) 정의로운 것과 정의의 핵심 격률인 ‘같은 것은 같게, 다른 것은 다르게 대우하라(Treat like cases alike and different cases differently)’ 사이의 연결은 분명 덜 직접적이다. 그러나 이 연결이 전혀 추적 불가능한 것은 아니며, 다음과 같은 방식으로 파악될 수 있다. 불법행위(tort)나 민사상 손해(civil injuries)에 대해 한 사람이 다른 사람에게 손해를 배상하도록 규정하는 법률들은 두 가지 이유로 부정의하다고 간주될 수 있다. 한편으로, 그것들이 불공정한 특권이나 면책(immunities)을 정립한다면 문제가 된다. 예컨대, 귀족만이 명예훼손으로 고소할 수 있다거나, 백인은 유색인에 대해 불법침입이나 폭행에 대해 책임을 지지 않는다면, 이러한 법률은 권리와 의무의 분배에 있어 공정한 분배 원칙을 명백히 위반하는 것이다.

그러한 법률의 악덕은 부당한 분배(maldistribution)에 있는 것이 아니라, 타인에게 가하는 것이 도덕적으로 그른 손해(injuries)에 대해 모든 이들에게 동일하게 보상을 거부한다는 데 있다. 이러한 부당한 구제 거부(redress)의 가장 노골적인(crudest) 사례는, 무분별한 신체적 해악에 대해 아무도 손해배상(damages)을 받을 수 없는 체계일 것이다. 주목할 가치가 있는 점은, 형사법(criminal law)이 이러한 폭행을 처벌하는 방식으로 금지한다 하더라도, 이러한 부정의(injustice)는 여전히 남는다는 것이다. 이처럼 노골적인 사례는 드물지만, 광고업자들이 이익을 얻는 경우가 많은 사생활 침해(invasions of privacy)에 대해 영국법이 보상을 제공하지 않는다는 점은, 종종 이러한 방식으로 비판되어 왔다. 도덕적으로 보상이 제공되어야 한다고 여겨지는 경우에 법이 이를 제공하

지 않는 것은, 불법행위법(tort law)이나 계약법(contract law)의 기교적 절차들(technicalities)이 도덕적으로 잘못된 행위를 통해 타인의 비용으로 ‘부당이득(unjust enrichment)’을 허용할 때, 그러한 절차에 대해 제기되는 부정의의 주요 비판 근거(gravamen)이 되기도 한다.

손해(injury)에 대한 보상(compensation)의 정의(正義) 또는 부정의(不正義)와, “유사한 사례는 동일하게, 상이한 사례는 다르게 다루라”(‘Treat like cases alike and different cases differently’)는 원칙 간의 연결 고리는, 법 밖에서 도덕적 신념(moral conviction)이 존재한다는 사실에 놓여 있다. 즉, 법이 관여하는 사람들은 특정 유형의 해악적 행동(harmful conduct)을 서로 자제할 권리(right)를 가진다는 신념이다. 이러한 상호적 권리와 의무의 구조는, 최소한 가장 뻔한(p. 165) 형태의 해악(harm)을 금지하는 방향으로 작용하며, 모든 사회 집단의 도덕성(morality)의 기반을 이루나, 그것의 전부는 아니다. 이 구조의 효과는, 자연적인 불평등을 상쇄하기 위해 개인들 사이에 도덕적이며, 어떤 의미에서는 인위적인 평등을 형성하는 데 있다. 도덕 규범(moral code)이, 더 강하거나 교활한 자라도 타인에게 강탈하거나 폭력을 행사하는 것을 금지할 때, 그들이 그러한 행위를 아무런 처벌 없이 수행할 수 있다 해도, 강자와 약자, 교활한 자와 단순한 자는 같은 수준에 놓이게 된다. 이들은 도덕적으로 동등한 경우로 간주되는 것이다. 따라서, 도덕성(morality)을 무시하고 자신의 힘을 이용하여 타인에게 해악(harm)을 가하는 강자는, 도덕적 질서(moral order), 즉 도덕 규범이 확립한 평등의 균형을 무너뜨리는 자로 인식된다. 이 경우 정의(justice)는, 그른행위자(wrongdoer)에 의해 교란된 도덕적 현상 유지 상태(moral status quo)를 가능한 한 회복할 것을 요구한다. 도둑질의 단순한 사례에서는, 이것은 단순히 훔친 물건을 돌려주는 것일 수 있다. 그리고 기타 손해에 대한 보상(compensation)은 이 원초적 관념의 확장이다. 타인을 신체적으로 손해(injury) 입힌 자는, 의도적으로든 부주의로든, 피해자(victim)로부터 무언가를 ‘가져간’ 것으로 간주된다. 그리고 그가 실제로 물리적으로 어떤 것을 가져간 것은 아니라 해도, 이 비유는 크게 부적절한 것은 아니다. 왜냐하면 그는 자신의 피해자를 희생시킴으로써 일정한 이익을 얻었기 때문이다. 설령 그것이 단지 해를 입히려는 욕망을 충족시켰거나, 적절한 주의의무(duty of care)를 이행하기 위한

불편을 감수하지 않은 것일 뿐이라 해도 그렇다. 그러므로 법이 정의(justice)가 요구하는 경우에 보상을 제공할 때, 그것은 간접적으로 ‘유사한 사례는 동일하게 다루라’는 원칙을 승인하는 것이며, 피해자와 그른행위자(wrongdoer)가 도덕적으로 동등한 지위에 있는 상태—즉 도덕적 현상 유지 상태(moral status quo)—가 교란된 후 이를 회복하려는 것이다. 또한 다음과 같은 도덕적 관점(moral outlook)도 상정할 수 있다. 즉, 개인을 이와 같은 사안에 있어 상호적 평등의 지위에 놓지 않는 관점이다. 예컨대, 어떤 도덕 규범이 야만인(Barbarians)의 그리스인(Greeks) 공격을 금지하면서, 동시에 그리스인의 야만인 공격은 허용할 수도 있다. 이러한 경우, 야만인은 자신이 입은 손해에 대해 보상받을 자격은 없지만, 그리스인에게 가한 손해에 대해서는 도덕적으로 보상할 의무가 있다고 여겨질 수 있다. 이 경우의 도덕 질서(moral order)는 피해자와 그른행위자 사이에 차이를 두고 그들을 다르게 다루는 불평등의 질서인 것이다. 이처럼 우리에게서는 혐오스러워 보이는 도덕 관점이라 하더라도, 그것을 반영하여 서로 다른 사례를 다르게 다루는 법이라면, 그 법은 정의롭다고 판단될 수 있다.

이러한 정의(justice)의 개요에서 우리는 그것의 보다 단순한 적용 사례들만을 다루었는데, 이는 정의로운 것으로 평가되는 법이 가지는 특정한 탁월성의 형식을 보여주기 위함이다. (p. 166) 이는 법이 가질 수 있는 다른 가치들과는 구별되며, 때로는 정의의 요구가 다른 가치들과 충돌할 수 있음을 의미한다. 예컨대, 범죄가 만연한 상황에서 법원이 특정 범죄자에게, 다른 유사한 사례들보다 더 엄격한 형벌을 선고하며 ‘경고의 목적’이라고 명시할 경우, 이는 사회의 일반적 안보나 복지를 위해 ‘유사한 사례를 동일하게 다루라’는 원칙을 희생시키는 것이다. 민사 사건에서는, 유사한 정의와 공공선 간의 충돌이 다음과 같이 나타난다. 도덕적으로는 부당한 행위(moral wrong)에 대해 보상이 요구된다 하더라도, 법은 이를 보장하지 않는다. 그 이유는 그러한 보상 집행이 증명의 어려움을 야기하거나, 법원을 과도하게 부담시키거나, 기업 활동을 부당하게 억제할 수 있기 때문이다. 어떤 사회든, 도덕적으로 그른 행위가 있었다 하더라도, 법 집행에 쓸 수 있는 자원에는 한계가 있다. 반대로, 법은 사회의 일반 복지(the general welfare of society)를 이유로, 어떤 사람이 타인에게 손해(injury)를 입혔을 경우 도덕적으로는 정당하지 않은 보상(compensation)을 강제할 수

있다. 이는 흔히 불법행위(tort) 책임이 고의(intent)나 과실(failure to take care)과 무관하게 성립하는 경우—즉, 무과실책임(strict liability)—에서 발생한다고 한다. 이러한 책임은 때로 다음과 같은 논거로 옹호된다. 즉, ‘사회’의 이익을 위해서는 우연히 손해를 입은 자들이 보상받는 것이 바람직하며, 이를 위한 가장 쉬운 방법은 그러한 사고를 유발한 활동에 종사한 자들에게 비용 부담을 지우는 것이다. 이들은 대개 충분한 자본력을 가지고 있으며, 보험에 가입할 수 있는 기회도 많다. 이러한 논거에서는 일반 복지에 대한 묵시적 호소가 존재하며, 이는 도덕적으로 받아들여질 수 있으며 때로는 ‘사회적 정의(social justice)’라 불리기도 하지만, 두 개인 간의 상태를 원래대로 회복시키는 것을 목표로 하는 기본적 정의(primary forms of justice)와는 구별된다.

정의 개념과 사회적 선(good) 또는 복지(welfare) 개념 사이의 중요한 접점이 여기서 주목되어야 한다. 사회적 변화나 법률 중 모든 개인에게 똑같이 이롭거나 받아들여지는 것은 극히 드물다. 경찰 보호나 도로 등 가장 기본적인 필요를 다루는 법만이 그러한 상태에 가까울 뿐이다. 대부분의 경우, 법은 어떤 인구 집단의 이익을 위해 다른 집단이 선호하는 것을 박탈하는 방식으로 작용한다. 예컨대, 빈곤층을 위한 복지는 (p. 167) 타인의 자산에서 충당되며, 전면적 의무 교육은 자녀를 사교육하려는 사람들의 자유를 제한할 뿐 아니라, 자금 조달을 위해 산업에 대한 자본 투자나 노후 연금, 무상 의료 서비스 등을 희생시킬 수 있다. 이처럼 상충하는 대안들 중 하나를 선택한 경우, 이는 ‘공공의 이익’(public good)이나 ‘공동선’(common good)을 위한 것이라는 이유로 정당화되곤 한다. 그러나 이러한 표현들이 실제로 무엇을 의미하는지는 명확하지 않다. 왜냐하면, 다양한 대안들이 공동선에 기여하는 정도를 측정할 수 있는 척도가 존재하지 않기 때문이다. 다만, 공동체의 모든 구성원의 이해관계를 사전에 고려하지 않고 이루어진 선택은 단지 당파적이고 부정의한 것으로 비판받을 여지가 있다. 그러나 입법 전에 모든 집단의 요구를 공정하게 고려한 결과로서 특정 집단의 요구가 다른 집단의 요구에 종속되었다면, 그러한(this) 비판에서 벗어나게 될 것이다.

실제로 어떤 사람들은, 서로 다른 계층이나 이해관계의 상충하는 요구들 사이의 선택이 ‘공동선을 위한 것’이라는 주장은, 단지 그러한 요구들이 사전에

공정하게 검토되었음을 의미하는 것일 뿐이라고 주장할 수도 있다. 이것이 참인지 여부와 무관하게, 이러한 의미의 정의(justice)는 공공선을 목표로 삼는 어떤 입법적 선택이라도 충족해야 할 최소한의 조건이라는 점은 명백하다. 여기서 우리는 분배적 정의(distributive justice)의 또 다른 측면을 보게 된다. 이는 앞서 다른 단순한 형태들과는 다르다. 왜냐하면 여기서 ‘분배’ 되는 것은 어떤 특정한 혜택 그 자체가 아니라, 서로 다른 혜택에 대한 상충하는 요구들에 대한 공정한 주의(attention)와 고려(consideration)이기 때문이다.

2. 도덕적 의무(Moral Obligation)와 법적 의무(Legal Obligation)

정의(Justice)는 도덕성(morality)의 한 영역을 구성하지만, 이는 주로 개인의 행동(conduct)보다는 집단(classes) 단위의 사람들이 어떻게 다루어지는가에 관한 문제에 집중된다. 이러한 점이 정의를 법 및 기타 공적 또는 사회적 제도에 대한 비판에 있어 특별한 적실성(relevance)을 부여한다. 정의는 가장 공적(public)이며, 가장 법률적인(legal) 덕목(virtues)이다. 그러나 정의의 원칙들(principles of justice)이 도덕성의 개념 전체를 다 포괄하지는 않으며, 도덕적 근거에서 이루어지는 법에 대한 모든 비판이 (p. 168) 정의의 이름으로 이루어지는 것도 아니다. 법이 특정한 행위를 요구하는데, 그것이 개인에게는 도덕적으로 그른(wrong) 것으로 금지되어 있거나, 반대로 도덕적으로 의무적인(obligatory) 행위를 금지할 때, 해당 법은 단순히 도덕적으로 나쁜 것으로 비판될 수 있다.

그러므로 우리는 도덕성에 속하며, 개인의 행동을 도덕적으로 의무적인 것으로 만드는 원칙들(principles), 규칙들(rules), 기준들(standards)의 일반적 성격을 정의할 필요가 있다. 여기서 두 가지 관련된 어려움이 우리 앞에 놓인다. 첫째, ‘도덕(morality)’이라는 용어와 그것과 유사하거나 거의 동의어인 ‘윤리(ethics)’ 같은 용어들은 그 자체로 상당한 정도의 모호성(vagueness) 또는 ‘열린 직조성(open texture)’을 갖는다. 어떤 형태의 원칙이나 규칙은 어떤 사람에게서 도덕적인 것으로 간주되지만, 다른 사람에게서는 그렇지 않을 수 있다. 둘째, 특정한 규칙이나 원칙들이 도덕성에 확실히 속한다고 공통적으로 받아들여지는 경우에도, 그것들의 지위(status) 또는 인간 지식과 경험의 전체 체계와의 관계

에 대해 철학적 불일치가 클 수 있다. 예컨대, 그것들은 인간에 의해 만들어진 것이 아니라 우주적 구조의 일부로 존재하며 인간 지성에 의해 발견되어야 하는 불변의 원칙들인가? 아니면, 변화하는 인간의 태도(attitudes), 선택(choices), 요구(demands), 또는 감정(feelings)의 표현인가? 이러한 입장은 도덕철학(moral philosophy)의 두 극단을 조야하게 제시한 것이다. 이들 사이에는 도덕성의 본성을 해명하려는 철학자들의 노력 속에서 발전된 복잡하고 미묘한 다양한 이론들이 존재한다.

이하에서는 이러한 철학적 난점들을 회피하고자 한다. 우리는 후속 논의에서²⁸ ‘중요성(Importance)’, ‘의도적 변화로부터의 면책(Immunity from deliberate change)’, ‘도덕적 위반의 자발적 성격(Voluntary character of moral offences)’, ‘도덕적 압력의 형식(The form of moral pressure)’이라는 네 가지 핵심적 특징을 식별할 것이다. 이 네 특징은, 도덕적이라 일반적으로 간주되는 행위 규범의 원칙들, 규칙들, 기준들에서 지속적으로 함께 발견되며, 사회 생활 또는 개인의 삶 속에서 이러한 기준들이 수행하는 중요한 기능의 서로 다른 측면들을 반영한다. 이 기능만으로도, 이 네 가지 특징을 가진 것을 따로 구분하여 논의하고, 특히 법률과 대비 및 비교할 정당한 이유가 된다. (p. 169) 더 나아가 도덕성이 이 네 가지 특징을 지닌다는 주장은, 그 지위(status) 또는 ‘근본적 성격(fundamental character)’에 대한 경쟁적 철학 이론들 사이에서 중립적인 입장을 유지한다. 대부분의, 아니 거의 모든 철학자들이 이 네 특징이 어떤 도덕 규칙이나 원칙에서든 반드시 요구된다고 인정할 것이지만, 도덕성이 왜 이러한 특징을 지니는가에 대한 해석이나 설명은 서로 다를 것이다. 물론 이 특징들이 필요조건일 뿐 충분조건은 아니며, 더 엄격한 기준에서는 도덕성에서 제외될 규칙이나 원칙들을 이들만으로는 구분할 수 없다는 반론도 제기될 수 있다. 우리는 이러한 반론이 근거하는 사실들을 언급하겠지만, ‘도덕성(morality)’이라는 용어의 보다 넓은 의미를 고수할 것이다. 그 이유는, 이 넓은 의미에서 지칭되는 것이 사회 및 개인의 삶에서 수행하는 구별 가능한 기능이 중요하며, 그 용례 또한 광범위하기 때문이다.

우선 우리는 어떤 사회의 ‘그(the) 도덕성’ 혹은 실제 사회 집단의 ‘수용된

²⁸Below, p. 173 ff.

(accepted)’ 또는 ‘관행적(conventional)’ 도덕성이라는 표현으로 지칭되는 사회적 현상을 고려할 것이다. 이 표현들은 특정 사회 내에서 널리 공유되는 행동 기준들을 의미하며, 이는 한 개인의 삶을 지배하지만 주변 사람들과 광범위하게 공유되지 않는 도덕 원칙들(moral principles)이나 도덕 이상(moral ideals)과 대조된다. 사회 집단이 공유하거나 수용한 도덕성의 기본 요소는, 우리가 앞선 제5장에서 의무(obligation)의 일반 개념을 설명할 때 정의했던 규칙들—즉 1차적 의무 규칙(primary rules of obligation)—로 구성된다. 이 규칙들은 다른 규칙들과 다음의 두 가지 점에서 구별된다. 첫째, 그것들은 강한 사회적 압력(social pressure)에 의해 뒷받침된다. 둘째, 그것들을 준수(compliance)하기 위해서는 개인의 이익이나 경향성(inclination)에 상당한 희생이 요구된다. 같은 장에서 우리는 그러한 규칙들이 유일한 사회적 통제 수단이었던 시기의 사회를 묘사한 바 있다. 이 단계에서는, 보다 발전된 사회에서 보이는 법률 규칙과 도덕 규칙 사이의 명확한 구분이 존재하지 않을 수 있다. 만약 어떤 규칙은 불복종에 대한 처벌(punishment)의 위협을 통해 유지되고, 다른 규칙은 규칙에 대한 (p. 170) 존중이나 죄책감(guilt), 후회(remorse)에의 호소를 통해 유지된다면, 그러한 구분의 초기 형태가 존재했을 수도 있다. 이러한 초기 단계를 지나 법 이전(pre-legal)의 상태에서 법의 세계로 이행하여, 인정(recognition), 판정(adjudication), 변경(change)의 규칙들을 포함하는 법규범 체계가 사회 통제 수단으로 포함되면, 법적 규칙과 비법적 규칙 간의 대비는 명확한 실체로 굳어진다. 공적 체계를 통해 식별된 1차적 의무 규칙들은 이제 공식적으로 인정되지 않는 다른 규칙들과 구분되어 존재하게 된다. 실제로 우리 사회는 물론, 이 단계에 도달한 모든 공동체에는 법 체계 밖에 존재하는 다양한 형태의 사회 규칙(social rules)과 기준들(standards)이 존재한다. 이들 중 일부만이 일반적으로 도덕적인 것이라 생각되거나 그렇게 표현되지만, 일부 법이론가들은 ‘도덕적인(moral)’이라는 용어를 모든 비법적 규칙에 적용하기도 한다.

이러한 비법적 규칙들은 다양한 방식으로 구분되거나 분류될 수 있다. 어떤 규칙은 특정한 행동 영역(예: 복장)에만 적용되거나, 숙고적으로 조성된 간헐적 활동(예: 의례, 게임)에만 적용된다. 어떤 규칙은 사회 집단 전체에 적용된다고 간주되며, 어떤 규칙은 특정 특성으로 구분되는 사회 계층이나, 제한된 목적을

위해 모이거나 결합한 소집단에만 적용된다. 어떤 규칙은 합의에 의해 구속력을 지니며 자발적 탈퇴를 허용하기도 하지만, 어떤 규칙은 합의나 숙고적 선택과 무관하게 발생한 것으로 여겨진다. 어떤 규칙이 위반되었을 때, 단순한 당위의 상기('옳은 일(right thing)'에 대한 지적)로 그치는 경우도 있고(예: 예절, 올바른 언어 사용), 심각한 비난(blame)이나 경멸(contempt), 혹은 그 공동체로부터의 더 길거나 짧은 배제(exclusion)로 이어지는 경우도 있다. 정확한 척도를 설정하기는 어렵지만, 이 규칙들에 부여되는 상대적 중요성은 그것들이 요구하는 사적 이익의 희생 정도와, 순응(conformity)을 요구하는 사회적 압력의 권총강도에 반영된다.

모든 법체계를 발전시킨 사회들에서는, 법 이외의 규칙들(non-legal rules) 가운데 극도로 중요한 것으로 여겨지며, 비록 결정적인 차이점들이 존재하더라도 법과 많은 유사성을 지니는 것들이 존재한다. 법률 규칙(legal rules)의 요구 사항을 표현할 때 사용되는 '권리(rights)', '의무(obligations)', '책무(duties)'의 어휘는, 종종 (p. 171) '도덕적(moral)'이라는 수식어를 덧붙여 이러한 규칙들이 요구하는 행위 또는 자제를 표현하는 데 사용된다. 모든 공동체에서는 법적 의무(legal obligation)와 도덕적 의무(moral obligation) 사이에 일정한 내용상의 중첩이 존재하며, 다만 법률 규칙은 그 요구가 보다 구체적이며, 보다 세부적인 예외 규정들에 의해 둘러싸여 있다는 점에서 도덕 규칙과 구별된다. 일반적으로, 도덕적 의무(moral obligation)와 책무(duty)는 많은 법률 규칙들처럼, 공동체의 생활 속에서 반복적으로 발생하는 상황에서 무엇을 해야 하거나 해서는 안 되는지를 다루며, 일부러 선택된 드문 행위나 간헐적 활동을 대상으로 하지 않는다. 이러한 규칙들이 요구하는 것은 자제(forbearance) 혹은 특수한 기술이나 지적 능력을 필요로 하지 않는 단순한 행위들이다. 도덕적 의무는 대부분의 법적 의무처럼, 정상적인 성인을 기준으로 이행 가능한 능력 범위 내에 있다. 이러한 도덕 규칙의 준수(compliance)는 법률 규칙의 준수와 마찬가지로 당연한 것으로 간주되며, 위반은 심각한 비난(blame)을 야기하지만, 도덕적 의무의 이행 역시, 법률의 준수처럼, 특별한 양심성(conscientiousness), 인내(endurance), 혹은 특별한 유혹에 대한 저항이 수반되지 않는 이상 칭찬의 대상이 되지 않는다. 도덕적 의무와 책무는 다양한 방식으로 분류될 수 있다. 일부는 사회 구성원 모

두가 아닌 특정하고 지속적인 기능이나 역할에 속한다. 예를 들어, 가장(father)이나 남편(husband)이 가족을 돌볼 의무는 이러한 범주에 속한다. 반면, 모든 정상적인 성인이 평생 동안 갖는 것으로 간주되는 일반적 의무들(e.g. 폭력을 삼갈 의무)도 있고, 특별한 인간관계에 들어감으로써 발생하는 특수한 의무들(e.g. 약속을 지킬 의무, 받은 호의를 되갚을 의무)도 있다.

이러한 가장 근본적인 유형의 도덕 규칙들에서 인정되는 의무(obligations)와 책무(duties)는 사회에 따라, 혹은 한 사회 내에서도 시대에 따라 달라질 수 있다. 그 중 일부는 집단의 건강이나 안전을 위한 것으로 여겨졌던, 실제로는 매우 잘못되었거나 미신적 믿음을 반영할 수도 있다. 어떤 사회에서는 아내가 남편의 장례 불 속에 몸을 던지는 것이 그녀의 책무로 여겨질 수 있으며, 또 다른 사회에서는 자살이 공동의 도덕성(common morality)에 반하는 행위로 간주될 수 있다. 도덕 규범(moral codes) 사이의 다양성은 각 사회의 독특하지만 실제적인 필요에서 비롯될 수도 있고, 미신이나 무지에서 비롯될 수도 있다. 그러나 법과 구별될 수 있는 수준에 이른 사회의 사회적 도덕성(social morality)은 (p. 172) 언제나 다음과 같은 일정한 의무와 책무를 포함한다. 그것은 사적 경향성(inclination)이나 이해(interest)의 희생을 요구하는데, 이러한 희생은 인간과 그들이 사는 세계가 여전히 익숙하고 자명한 몇 가지 특성을 유지하는 한, 어떤 사회든 생존을 위해 필수적이다. 사회생활에 자명하게 요구되는 규칙들 중에는 다음과 같은 것들이 있다: 폭력의 자유로운 사용을 금지하거나 적어도 제한하는 규칙, 타인과의 거래에서 일정한 정직(honesty)과 진실성(truthfulness)을 요구하는 규칙, 유형적 사물의 파괴 또는 타인으로부터의 강탈을 금지하는 규칙. 만약 이러한 가장 기본적인 규칙들의 준수가, 서로 가까이 살아가는 개인 집단 내에서 자명한 것으로 여겨지지 않는다면, 그 집단을 ‘사회(society)’라고 부르기에는 의문이 따를 것이며, 장기적으로 존속할 수 없다는 점은 분명할 것이다.

따라서 도덕 규칙과 법률 규칙 모두에 속하는 의무와 책무는, 그 공통된 어휘가 우연이 아님을 보여주는 몇 가지 주목할 만한 유사성을 지닌다. 이 유사성들은 다음과 같이 요약될 수 있다. 양자는 모두, 개인의 동의(consent)와 무관하게 구속력을 지닌 것으로 간주되며, 강한 사회적 압력(social pressure)

에 의해 준수가 요구된다. 법적이든 도덕적이든 의무의 준수는 칭찬의 대상이 아니라 사회생활의 최소한의 기여로서 당연한 것으로 간주된다. 또한, 법과 도덕은 모두, 삶 속에서 반복적으로 발생하는 상황에서의 개인의 행동을 규율하는 규칙들을 포함하며, 특별한 행위나 사건을 다루지 않는다. 그리고 양자 모두 특정 사회의 실제적 또는 상상된 필요에 특수한 측면을 포함할 수 있지만, 어느 인간 집단이든 함께 살아가기 위해 자명하게 충족해야 하는 요구들을 포함한다. 그러므로 신체나 재산에 대한 폭력 금지와 정직성 및 진실성에 대한 일정한 요구는 양자 모두에서 발견된다. 그럼에도 불구하고, 법과 도덕은 공유할 수 없는 특정한 특징들이 존재한다고 많은 이들이 인식해 왔다. 비록 법철학(jurisprudence)의 역사에서는 그러한 특징들을 명료하게 공식화하는 것이 가장 어려운 문제 중 하나였지만 말이다.

법과 도덕의 본질적인 차이를 요약적으로 전달하려는 가장 유명한 시도는 다음과 같은 이론이다. 법률 규칙은 오직 ‘외적(external)’ 행위만을 요구하며, (p. 173) 동기(motives), 의도(intentions), 기타 ‘내적(internal)’ 요소들에는 무관심하지만, 도덕은 특정한 외적 행위가 아니라 선한 의지(good will), 적절한 의도(proper intention), 혹은 동기(motive)만을 요구한다는 것이다. 그러나 이는 법과 도덕의 규칙들이 올바르게 이해된다면 결코 동일한 내용을 가질 수 없다는 놀라운 주장을 함의하며, 부분적으로 진실을 담고 있다 해도, 전체로서는 매우 오해를 불러일으킬 수 있다. 이 이론은 사실 도덕성의 몇 가지 중요한 특성, 특히 도덕적 비난(moral blame)과 법적 처벌(legal punishment)의 차이에서 잘못된 방식으로 도출된 추론이다. 만일 어떤 사람이 도덕 규칙이 금지한 행위를 하였거나, 그것이 요구하는 행위를 하지 않았다면, 그가 그렇게 한 것이 비의도적(unintentional)이었고, 모든 주의를 기울였음에도 불구하고 일어난 일이라면, 이는 도덕적(moral) 비난에 대한 정당한 면책(excuse)이 된다. 반면, 법률 체계나 관습(custom)은 ‘무과실 책임(strict liability)’ 규칙을 포함할 수 있으며, 이에 따라 규칙을 고의 없이 위반한 자도 처벌 대상이 될 수 있다. 따라서 ‘무과실 책임’이라는 개념은 도덕성 영역에서는 거의 자기모순에 가까운 개념이지만, 법 체계에서는 단지 비판 가능한 개념일 수 있다. 그러나 이것이 곧 도덕이 오직 선한 의지, 의도 또는 동기만을 요구한다는 것을 의미하지는 않는다. 오히려

그렇게 주장하는 것은, 우리가 이후에 보여줄 바와 같이, 면책(excuse)이라는 개념과 행위의 정당화(justification) 개념을 혼동하는 것이다.

그럼에도 불구하고, 이 혼란스러운 논변 속에는 주목할 만한 어떤 요소가 희화화되어 있다. 즉, 법(law)과 도덕(morals) 사이의 차이가 하나는 ‘내적(internal)’이고 다른 하나는 ‘외적(external)’이라는 대조와 연결되어 있다는 막연한 감각은, 법과 도덕에 관한 사유에서 반복적으로 등장하는 주제로서 전혀 근거 없는 것으로 치부될 수는 없다. 이 감각을 단순히 폐기하기보다는, 우리는 그것을 도덕성(morality)을 법률 규칙들(legal rules)뿐 아니라 다른 형태의 사회 규칙들(social rules)로부터도 구분하기 위한 네 가지 핵심적이고 상호 연관된 특징들로 이루어진 간결한 진술(compendious statement)로 간주하여 다루고자 한다.

- (i) 중요성(Importance). 도덕 규칙이나 기준(moral rule or standard)의 본질적 특징 중 하나가 그것을 유지하는 것이 매우 중요하다고 간주된다는 점이라는 진술은, 자명한(truistic) 동시에 모호한 것처럼 보일 수 있다. 그러나 이 특징은 어느 사회 집단이나 개인의 도덕성을 충실하게 설명하는 데 빠질 수 없는 요소이며, 그보다 더 정밀하게 정의될 수도 없다. 이 특징은 여러 방식으로 드러난다. 첫째, 도덕 기준들은 그것이 제한하는 강한 정념(passions)의 충동을 제어하면서, (p. 174) 상당한 개인적 이해의 희생을 대가로 유지된다. 둘째, 개인적 사례에서의 순응(conformity)을 확보하기 위한 것이든, 사회 전체 구성원에게 도덕 기준이 당연한 것으로 교육되고 전달되도록 하기 위한 것이든, 강한 사회적 압력(social pressure)이 가해진다. 셋째, 도덕 기준이 일반적으로 수용되지 않을 경우, 개인의 삶에서 광범위하고 불쾌한 변화가 발생할 것이라는 일반적 인식이 존재한다. 도덕성과 대조적으로, 품행(deportment), 예절(manners), 복장(dress) 규칙, 그리고 일부(하지만 전부는 아닌) 법률 규칙들은 심각한 중요성의 척도에서 상대적으로 낮은 위치를 차지한다. 이러한 규칙들은 지키기 번거로울 수는 있으나 큰 희생을 요구하지는 않으며, 그에 대한 순응을 강하게 요구하는 압력이 존재하지 않고, 그것들이 지켜지지 않거

나 변경되더라도 사회생활의 다른 영역에 큰 변화가 초래되지는 않는다. 도덕 규칙의 유지에 부여되는 이러한 중요성의 대부분은 이성주의적(rationalistic) 관점에서 비교적 간단하게 설명될 수 있다. 도덕 규칙들이 그것에 구속된 자의 사적 이해를 희생하도록 요구한다 하더라도, 그것들의 준수는 모든 이가 공동으로 누리는 핵심적 이익을 확보해준다. 이는 두 가지 방식으로 작용한다. 하나는, 도덕 규칙들이 개인들을 명백한 해악(obvious harm)으로부터 직접 보호하고, 다른 하나는 견딜 만하고 질서 있는 사회의 구조를 유지한다는 점이다. 이처럼 도덕성의 사회적 측면(social morality)은 명백한 해악으로부터의 보호라는 관점에서 이성적으로 옹호될 수 있지만, 이러한 단순한 공리주의적(utilitarian) 설명이 언제나 가능한 것은 아니다. 그리고 그것이 가능한 경우에도, 도덕성에 의해 살아가는 사람들의 관점을 충분히 대표한다고 보기는 어렵다. 실제로, 어떤 사회에서든 도덕성의 가장 두드러진 부분 중 하나는 성적 행동(sexual behaviour)에 관한 규칙들로 구성되며, 그 규칙들에 부여되는 중요성이 그것들이 금지하는 행동이 타인에게 해악을 가한다고 믿는 데 근거한다는 점은 분명하지 않다. 이러한 규칙들이 실제로 그러한 정당화(justification)를 가질 수 있는지도 또한 명확하지 않다. 신적 명령으로서의 도덕성을 더 이상 신봉하지 않는 현대 사회에서도, 동성애(homosexuality)에 대한 일반적인 금지처럼 성적 행위에 대한 도덕적 규율이 부여하는 중요성은, 그것이 타인에게 미치는 해악에 대한 계산만으로 설명되지 않는다. 성적 기능과 감정은 모든 이에게 매우 중요하고 정서적으로 민감한 사안이기 때문에, 그 표현이 통상적 또는 수용된 양식에서 벗어날 경우, 그 행위는 고유한 ‘수치(pudor)’ 또는 내재적 중요성을 띠게 된다. 이러한 행위들은 그것이 (p. 175) 사회적 해악이라는 신념에서라기보다는, 단순히 ‘부자연스럽다(unnatural)’거나 그것 자체로 혐오스럽다(repugnant)는 이유로 혐오된다(abhorred). 그럼에도 불구하고, 이와 같은 강력한 사회적 금지(social vetoes)에 도덕성이라는 명칭을 부정하는 것은 부당할 것이다. 사실, 성적 도덕성(sexual morality)은 일반인들이 도덕(morality)이라고 생각하는 바의 가장 두드러진 측면일 수도 있다. 물론, 사회가 자기 도덕

을 이와 같은 비(非)공리주의적 방식으로 이해한다고 해서, 그 규칙들이 비판이나 비난으로부터 면책되는 것은 아니다. 그 규칙들이 무익하다고 판단되거나, 큰 고통의 대가로 유지되고 있다면, 그것은 정당하게 비판될 수 있다.

우리가 앞서 본 바와 같이, 법률 규칙들은 요구되거나 금지하는 행동이 도덕 규칙들과 일치할 수 있다. 그렇게 일치하는 경우, 해당 법률 규칙은 도덕 규칙만큼이나 중요한 것으로 여겨질 수 있다. 그러나 중요성(importance)은 모든 법률 규칙의 지위(status)에 본질적인 것은 아니며, 도덕 규칙에서는 본질적이다. 하나의 법률 규칙이 더 이상 유지할 필요가 없다고 널리 여겨지고, 폐지되어야 한다는 데 일반적인 합의가 존재하더라도, 그것은 실제로 폐지되기 전까지는 여전히 법률 규칙의 지위를 유지한다. 반면, 어떤 규칙이 더 이상 중요하지 않다고 여겨지고, 유지할 가치가 없다고 여겨진다면 하면서도 그것을 여전히 어떤 사회의 도덕의 일부로 간주하는 것은 터무니없는 일일 것이다. 과거에는 도덕 규칙의 지위를 가졌던 오래된 관습(customs)이나 전통(traditions)이 지금은 단지 관성적으로 유지되고 있는 경우가 있을 수 있지만, 그것들에 부여되던 중요성이 사라짐에 따라, 그것들의 도덕성으로서의 지위도 함께 사라진 것이다.

(ii) 숙고적 변경으로부터의 면책(Immunity from deliberate change). 법체계(legal system)의 특징 중 하나는, 새로운 법률 규칙들(legal rules)을 숙고적인 제정(deliberate enactment)을 통해 도입할 수 있으며, 기존의 규칙들을 변경하거나 폐지할 수 있다는 점이다. 물론 일부 법률은 최고 입법기관의 입법권(legislative competence)을 제한하는 성문헌법(written constitution)에 의해 변경으로부터 보호될 수도 있다. 이와 대조적으로, 도덕 규칙들(moral rules)이나 도덕 원칙들(moral principles)은 이러한 방식으로 생성되거나 변경되거나 제거될 수 없다. 여기서 ‘~할 수 없다(cannot)’는 주장은, 인간이 기후를 변경할 수 없다는 식의 어떤 가능성 있는 사실 상황을 부정하는 것이 아니다. 오히려 이 주장은 다음과 같은 사실들을 지적한다. 우리는 ‘1960년 1월 1일부터 어떤 행위를 하는 것이 범죄행위가 된다’ 혹은 ‘1960년 1월 1일부터 어떤 행위가 더 이상

불법이 아니다'와 같은 문장을 말하는 것이 전혀 어색하지 않으며, 실제로 제정되거나 폐지된 법률들을 근거로 이러한 진술들을 정당화할 수 있다. 그러나 '내일부터 (p. 176) 어떤 행위는 더 이상 비도덕적(immoral)이 아니다' 또는 '지난 1월 1일부터 어떤 행위는 도덕적으로 그른 것이 되었다'는 식의 진술은, 그것이 숙고적인 제정을 근거로 삼으려는 경우에는, 무의미하다고는 하지 않더라도 놀라운 역설(paradox)처럼 들린다. 왜냐하면, 도덕성(morality)이 개인의 삶에서 수행하는 역할과 양립할 수 없기 때문이다. 즉, 도덕 규칙, 원칙, 또는 기준(standards)이 법률과 같이 숙고적인 행위(deliberate act)를 통해 생성되거나 변경될 수 있는 것들로 간주되어서는 안 된다는 것이다. 행위 기준들(standards of conduct)은 인간의 명령(human fiat)만으로 도덕적 지위(moral status)를 부여받거나 박탈당할 수 없다. 반면, 제정(enactment)과 폐지(repeal)라는 개념이 일상적으로 사용되는 것만 보더라도, 법률의 경우는 그렇지 않다는 점을 보여준다.

도덕 철학(moral philosophy)의 많은 부분은 이러한 도덕성의 특징을 설명하고, 도덕이란 것이 인간의 숙고적인 선택이 아니라, '거기에 존재하는(something "there")' 것으로 인식되어야 한다는 통찰을 명확히 하는 데 할애된다. 그러나 이러한 설명과는 별도로, 이 사실 자체는 도덕 규칙들만의 고유성은 아니다. 따라서 이 도덕성의 특징은 매우 중요하긴 하지만, 그것만으로 도덕성을 다른 모든 형태의 사회 규범(social norms)으로부터 구분하기에는 불충분하다. 왜냐하면, 이 점에 있어서는—다른 점들과는 달리—모든 사회적 전통(social tradition)도 도덕과 유사하기 때문이다. 전통 또한 인간의 명령(fiat)이나 숙고적 제정으로 도입되거나 폐지될 수 없다. 예컨대, 한 영국 신설 사립학교의 교장이 다음 학기부터 '상급생은 특정한 복장을 착용하는 것이 전통이 될 것이다'라고 선언했다는(사실 여부가 불확실한) 일화가 희극적 효과를 가지는 이유는, 전통(tradition)이라는 개념이 숙고적 제정(deliberate enactment)이나 선택(choice)이라는 개념과 논리적으로 양립 불가능하다는 데 있다. 규칙들은 자생적으로 형성되고 실천되며, 실천이 중단되고 쇠퇴함에 따라 전통의 지위를 획득하거나

상실한다. 이러한 느리고 비의도적인 과정을 통해 형성되지 않은 규칙은 전통의 지위를 획득하거나 상실할 수 없다.

도덕성과 전통이, 법률처럼 입법적 제정(legislative enactment)을 통해 직접적으로 변경될 수 없다는 사실은, 그것들이 다른 형태의 변화로부터의 면책(immunity)이라는 의미로 오해되어서는 안 된다. 실제로, 도덕 규칙이나 전통은 숙고적 선택이나 제정을 통해 폐지되거나 변경될 수는 없지만, 어떤 법률의 제정 또는 폐지가 특정 도덕 기준이나 전통의 변화 또는 쇠퇴의 원인이 되는 경우는 종종 있다. 예컨대, 가이 포크스(Guy Fawkes) 기념일에 행해지던 전통적 실천이 (p. 177) 법에 의해 금지되고, 위반 시 처벌(punishment)을 받게 되면, 그 실천은 중단되고 전통도 사라질 수 있다. 반대로, 법률이 특정 계층에 병역 의무를 부과하게 되면, 그들 사이에서 새로운 전통이 형성될 수 있으며, 이는 그 법률보다 더 오래 지속될 수도 있다. 또한, 법률 제정은 정직(honesty)과 인간성(humanity)에 대한 기준(standards)을 설정하여 현재의 도덕성을 변화시키고 향상시킬 수도 있다. 반대로, 법이 어떤 도덕적으로 의무적(morally obligatory)이라고 여겨지는 실천들을 억압하게 되면, 시간이 지나면서 그러한 행위에 대한 중요성 인식이 약화되어 그것의 도덕성 지위조차 상실될 수 있다. 하지만, 그러한 경우에도 법은 종종 뿌리 깊은 도덕성에 패배하며, 도덕 규칙은 여전히 강력한 힘을 유지하면서, 자신이 명령하는 행위를 금지하는 법률과 나란히 계속 존재한다.

이와 같은 도덕성과 전통의 변화 양상은, 법률의 제정이나 폐지에 의해 발생하는 입법적 변화(legislative change)와는 구별되어야 한다. 왜냐하면, 제정된 법령(enacted statute)에 의해 법적 지위(legal status)를 획득하거나 상실하는 것은, 법령이 도덕성이나 전통에 미치는 결과적 효과와 달리, 우연적 인과적 변화(contingent causal change)가 아니기 때문이다. 이 차이는 다음과 같은 단순한 사실에서 분명히 드러난다. 즉, 어떤 명확하고 유효하며 법적으로 정당한 법률 제정이 실제로 도덕성에 변화를 초래할지를 우리는 항상 의심할 수 있다. 그러나 그러한 법률 제정이 실제로 법률을 변경했는지 여부에 대해서는 유사한 의심이 제기될 수 없다.

도덕성(morality)이나 전통(tradition)의 개념이 숙고적 제정에 의한 변경과

양립할 수 없다는 점은, 어떤 법률이 헌법(constitution)의 제한 조항에 의해 입법적 변경으로부터 보호받는 경우에 부여되는 면책(immunity)과는 구별되어야 한다. 이러한 법률상의 면책은, 어떤 규칙이 ‘법률’이라는 지위를 가지는데에 필수적인 요소가 아니며, 헌법 개정을 통해 폐지될 수도 있다. 그러나 도덕성이나 전통이 유사한 방식으로 변경될 수 없다는 점은, 공동체나 시대에 따라 달라지는 것이 아니라, 바로 이 용어들이 가진 의미 속에 포함되어 있다. 도덕성의 전체 개념에 반하는 것은, 법률 제정이 법을 만들고 변경하듯, ‘도덕 입법기관(moral legislature)’이 도덕을 만들고 변경할 수 있다는 생각이다. 우리가 국제법(international law)을 다룰 때, 우리는 입법기관이 단지 존재하지 않는다는 사실상(de facto)의 결여를, 그것이 체계의 결함으로 여겨질 수는 있겠지만, 여기서 (p. 178) 강조한 바와 같이 도덕 규칙이나 규준이 입법에 의해 생성되거나 폐지될 수 있다는 사고방식 속에 내재된 근본적인 모순과는 분명히 구별해야 할 것이다.

- (iii) 도덕적 위반의 자발적 성격(Voluntary character of moral offences). 도덕(morals)은 오직 ‘내적(internal)’인 것에만, 법(law)은 ‘외적(external)’행위에만 관련된다는 오래된 관념은, 앞서 논의한 두 가지 특징을 오해한 부분이 일부 포함되어 있다. 그러나 이 관념은 주로 도덕적 책임(moral responsibility)과 도덕적 비난(moral blame)의 두드러진 특징들을 지칭하는 방식으로 다루어진다. 어떤 사람의 행위가 외부적 기준(ab extra)에 따라 도덕 규칙이나 도덕 원칙(moral rules or principles)에 반하는 것으로 평가되더라도, 그가 가능한 모든 주의를 기울였음에도 불구하고 그것이 비의도적(unintentional)이었음을 입증할 수 있다면, 그는 도덕적 책임으로부터 면책(excused)되며, 이러한 상황에서 그를 비난하는 것은 도덕적으로 부당한 것으로 간주된다. 도덕적 비난은, 그가 자신이 할 수 있는 모든 것을 다 했기 때문에, 배제되는 것이다. 발전된 법체계에서는 이와 유사한 점이 일정 부분 존재한다. 형사책임(criminal responsibility)의 일반적 요건으로 고의성(mens rea)이 요구되며, 이는 부주의 없이, 알지 못한 채로, 또는 신체적·정신적 능력 부족으로 인해 법률 규칙을

준수하지 못한 자를 면책하기 위한 장치이다. 특히 중대한 범죄에 대해 중대한 처벌(punishment)이 부과되는 경우, 이러한 고려가 없다면 해당 법체계는 심각한 도덕적 비판에 직면할 것이다.

그럼에도 불구하고, 모든 법체계에서 이러한 면책 사유의 인정은 다양한 방식으로 제한된다. 심리적 사실(psychological facts)에 대한 증명 곤란이나 그 주장 자체의 불확실성으로 인해, 법체계는 개별 행위자의 실제 정신 상태나 능력을 조사하는 것을 거부하고, 대신 ‘객관적 기준(objective tests)’을 사용하는 경향이 있다. 이 기준에 따르면, 범죄 혐의를 받는 자는 정상적이거나 ‘합리적인(reasonable)’ 사람이라면 가졌을 것으로 여겨지는 통제력(control)이나 주의력(precaution 능력)을 갖춘 것으로 간주된다. 또한 어떤 법체계는 ‘인지적(cognitive)’ 장애와 구분되는 ‘의지적(volitional)’ 장애를 고려 대상에서 제외할 수도 있다. 그렇게 되면, 면책의 범위는 의도(intent)의 부재나 지식(knowledge)의 결함에 국한된다. 나아가, 특정 범주의 범죄에 대해서는 법체계가 엄격책임(strict liability)을 부과하여, 고의성(mens rea) 요건 자체를 폐지할 수도 있다. 이 경우, 피고인이 최소한 정상적인 근육통제(muscular control) 능력을 가지고 있는지만 요구된다.

따라서 법적 책임(legal responsibility)은, 피고인이 자신이 위반한 법률을 지킬 수 없었음을 입증했다고 하더라도, (p. 179) 반드시 면제되는 것은 아니다. 반면, 도덕 영역에서 ‘나는 어쩔 수 없었다(I could not help it)’는 항상 정당한 면책 사유(excuse)가 되며, 도덕적 의무(moral obligation)는, 이러한 의미에서 ‘해야 한다(ought)’는 ‘할 수 있다(can)’를 함의하지 않는다면 전혀 다른 성격을 띠게 될 것이다. 그러나 ‘나는 어쩔 수 없었다’는 단지 하나의 면책 사유일 뿐이며, 그것이 정당화(justification)는 아니라는 점을 분명히 하는 것이 중요하다. 앞서 언급했듯, 도덕이 외적 행위를 요구하지 않는다고 보는 주장은 바로 이 두 개념—면책과 정당화—을 혼동하는 데 기초하고 있다. 만약 선한 의도(good intentions)가 도덕 규칙이 금지하는 행위를 정당화할 수 있다면, 모든 주의를 기울였음에도 불구하고 우발적으로 타인을 죽인 사람의 행위는 비난의 여지가 없을 것이다. 우리는 그런 행위를, 현재 자위행위(self-defence)로서 타인을 살

해하는 행위를 대하는 방식처럼 보게 될 것이다. 후자(자위행위)는, 그러한 상황에서서는 살인이 일반적인 금지의 예외임에도 불구하고, 체계가 그것을 역제의 대상으로 삼지 않거나 오히려 장려하기도 하는 행위 유형으로 간주되므로, 정당화된(justified) 것이다. 반면, 어떤 사람이 비의도적으로 도덕 규칙을 위반했을 때 면책되는(excused) 것은, 그 행위가 법률의 정책상 허용되거나 환영받는 행위 유형이기 때문이 아니라, 그 특정 행위자의 정신적 조건을 조사해보았을 때 그가 해당 법률 요구사항에 부합할 수 있는 정상적인 능력을 결여하고 있었기 때문이다. 그러므로 도덕의 ‘내적 성격(internality)’이라는 측면은, 도덕이 외적 행위를 통제하지 않는다는 뜻이 아니라, 도덕적 책임이 성립하려면 개인이 자신의 행위에 대해 일정한 통제력을 가지고 있어야 한다는 점을 뜻할 뿐이다. 도덕의 영역에서도 ‘그는 그른 일을 하지 않았다’는 진술과 ‘그는 자신이 한 일을 어쩔 수 없이 했다’는 진술 사이에는 분명한 차이가 존재한다.

- (iv) 도덕적 압력의 형태(The form of moral pressure). 도덕성(morality)을 특징짓는 또 하나의 구별 기준은, 그것을 지지하고 강화하는 데 사용되는 도덕적 압력(moral pressure)의 고유한 형태이다. 이 특징은 앞에서 논의한 도덕적 책임의 내적 성격과 밀접히 연관되며, 도덕이 ‘내적인 것’에 관련된다는 막연한 인식을 강화하는 데 중요한 역할을 해왔다. 이와 같은 해석을 유발한 사실관계는 다음과 같다. 만약 어떤 사람이 행위 규칙(rule of conduct)을 위반하려 할 때마다, 오로지(only) 신체적 처벌(physical punishment)이나 불쾌한 결과에 대한 위협만이 그를 제지하기 위한 논증에서 사용된다면, 그러한 규칙은 (p. 180) 해당 사회의 도덕(morality)의 일부로 간주될 수 없을 것이다. 다만, 그것이 법률(law)의 일부로 간주되는 데에는 아무런 문제가 없다. 실제로 법적 압력(legal pressure)의 전형적 형태는 바로 이러한 위협(threats)으로 구성된다고 말할 수 있다. 반면, 도덕에서 전형적인 압력 형태는 그러한 위협이 아니라, 해당 규칙이 그 자체로 중요한 것이라는 점에 대한 존중(respect for the rules)에 호소하는 방식이다. 이러한 존중은, 발화 대상자들이 이미 공유하고 있다고 전제된다. 그러므로 도덕적 압력은 일반적으로, 두려움(fear)

이나 이해관계(interest)에 대한 호소나 물리적 위협이 아니라, 고려 중인 행위의 도덕적 성격(moral character)과 도덕성의 요구(moral demands)를 환기시키는 방식으로 작동한다. 예컨대, ‘그건 거짓말이야’, ‘그건 너의 약속을 어기는 거야’와 같은 식이다. 물론 그 배경에는 도덕적 처벌의 ‘내적 유사물(internal analogues)’로서 수치심(shame)이나 죄책감(guilt)에 대한 두려움이 존재한다. 도덕적 항의는 이러한 감정들을 일깨울 수 있을 것이라 전제되며, 사람들은 자신의 양심(conscience)에 의해 ‘처벌’ 받을 수 있다. 물론, 이러한 고유한 도덕적 호소는 때때로 물리적 처벌에 대한 위협이나 일반적인 개인적 이해에 대한 호소와 함께 나타나기도 한다. 도덕 규범에서 벗어난 행위는, 상대적으로 비공식적인 경멸 표현에서부터 사회적 관계 단절이나 추방(ostracism)에 이르기까지 다양한 형태의 사회적 반응을 야기한다. 그러나 도덕 규칙이 무엇을 요구하는지를 강조하는 환기(reminders), 양심에 대한 호소(appeals to conscience), 죄책감과 후회(remorse)의 작용에 의존하는 방식은, 사회적 도덕성(social morality)을 지지하기 위한 압력의 가장 두드러지고 대표적인 형태이다. 도덕 규칙과 도덕 기준(moral standards)을 지지하기 위해 이러한 방식이 사용된다는 점은, 그것들이 유지되는 것이 무엇보다도 명백하게 중요하다는 점을 사회가 수용하고 있음을 반영한다. 이러한 방식으로 지지되지 않는 기준은 도덕적 의무(moral obligation)로서 사회적·개인적 삶에서 고유한 지위를 점할 수 없다.

3. 도덕 이상(Moral Ideals)과 사회적 비판(Social Criticism)

도덕적 의무(moral obligation)와 책무(duty)는 사회적 도덕성(social morality)의 기반(bedrock)을 이루지만, 그것이 도덕성의 전부는 아니다. 다른 형태들을 살펴보기에 앞서, 우리는 먼저 도덕적 의무에 대한 우리가 제시한 성격 규정 방식에 제기될 수 있는 한 가지 반론을 검토하고자 한다. 앞 절에서 우리가 도덕적 의무를 다른 형태의 사회적 기준(standards)이나 규칙들(rules)과 구별하기 위해 사용한 네 가지 기준—중요성(importance), 의도적 변경으로부터의 면책

(immunity from deliberate change), 도덕적 위반의 자발성(voluntary character of moral offences), 도덕적 압력의 고유한 형태(special form of moral pressure)—은 어떤 의미에서 형식적(formal) (p. 181) 기준이다. 이 기준들은 어떤 규칙이나 기준이 도덕적인 것으로 간주되기 위해 필연적으로 포함해야 할 내용(content), 또는 사회생활에서 반드시 수행해야 할 목적(purpose)에 직접적으로 언급하지 않는다. 우리는 물론 모든 도덕 규범(moral codes)에서 사람이나 사물에 대한 폭력 사용의 금지, 진실성(truthfulness), 공정한 거래(fair dealing), 약속에 대한 존중(respect for promises)이라는 요구가 어떤 형태로든 나타난다는 점을 강조해 왔다. 이러한 내용들은 인간 본성과 물리적 세계의 성격에 관한 몇 가지 자명한 사실(truisms)만을 전제한다면, 인간이 서로 가까워서 지속적으로 살아가기 위해 필수적인 것임을 쉽게 알 수 있다. 그러므로 이러한 내용들을 담고 있는 규칙들이 도덕적 중요성과 지위(moral status)를 부여받지 않는 사회가 존재한다면 그것이야말로 비정상적일 것이다. 이러한 규칙들이 요구하는(demand) 개인적 이익의 희생(sacrifice of personal interest)은 우리와 같은 세계에서 타인과 함께 살아가기 위해 치러야 할 대가이며, 이 규칙들이 제공하는(afford) 보호(protection)는 우리와 같은 존재들이 타인과의 공동생활을 할 만한 것으로 만들어주는 최소한의 조건이라 할 수 있다. 우리가 다음 장에서 논증하듯이, 이러한 단순한 사실들은 자연법(Natural Law)의 학설들 속에 내포된 부인할 수 없는 핵심 진리(core of indisputable truth)를 형성한다.

많은 도덕철학자들은 우리가 제시한 네 가지 기준에 더하여, 도덕성의 정의에 도덕성과 인간의 필요(human needs), 이해관계(interests) 사이의 이처럼 명백한 연관성을 또 하나의 기준으로 포함시키고자 할 것이다. 이들은 다음과 같이 주장할 수 있다. 어떤 규칙도 인간의 이해관계라는 기준에서 이성적 비판(rational criticism)을 통과할 수 있고, 그러한 공동체 안에서 그것이 이해관계를 증진시키는 것으로 입증될 수 있을 때에만 도덕의 일부로 인정되어야 한다는 것이다. 여기서 그 증진은 어떤 공정성(fairness)이나 평등성(equality)을 지닐 수도 있다. 더 나아가, 어떤 사람들은 그 규칙이 요구하는 자제(forbearances)나 행위(actions)의 혜택이 특정 사회의 경계를 넘어, 그러한 규칙을 존중할 의지와 능력을 지닌 모든 사람에게 확장되지 않는다면, 그것은 도덕적 원칙이나 규칙으

로 인정되어서는 안 된다고 주장할 수 있다. 하지만 우리는 의도적으로 도덕성에 대한 보다 넓은 관점을 취하였다. 사회의 실제 실천 속에서 위 네 가지 특징을 보여주는 모든 사회 규칙들과 기준들을 도덕성에 포함시키기 위해서이다. 이들 가운데 일부는 위와 같은 추가 기준으로도 비판을 견디고 살아남을 수 있겠지만, 다른 일부는 비이성적(irrational), 무지한(unenlightened), 심지어 야만적인(barbarous) 것으로 평가되어 비판받을 수도 있다. 우리가 이러한 입장을 택한 이유는 단지 (p. 182) ‘도덕(moral)’이라는 단어가 일상에서 이보다 넓은 의미로 사용된다는 언어적 사용의 무게 때문만은 아니다. 만약 위 기준을 만족하지 못하는 규칙들을 도덕의 범주에서 제외한다면, 우리는 동일한 방식으로 사회 구성원들의 삶 속에서 기능하고 있는 사회 구조의 구성 요소들을 비현실적인 방식으로 나누어야 하기 때문이다. 실제로 타인에게 해악(harm)을 가하지 않는 행위를 금지하는 도덕적 규정들도, 해악을 가하는 행위를 금지하는 규정들과 동일한 본능적 존중(instinctive respect)을 받으며, 함께 성격(character)에 대한 사회적 평가(social estimates)의 요소로 작용하고, 그와 함께 개인이 살아가야 하며 실제로 살아가고 있다고 여겨지는 삶의 전형적인 모습에 포함된다.

그러나 도덕성이 특정 사회 집단의 실제 실천 속에서 인정받는 의무(obligations)와 책무(duties) 이상의 많은 것을 포함한다는 점은 사실이며 동시에 중요하다. 의무와 책무는 도덕성의 토대일 뿐이며, 사회적 도덕성이라 할지라도 그것만으로 도덕성을 설명할 수 없다. 도덕성에는 특정 사회의 공유된 도덕성(socially accepted morality)을 넘어서는 형태들이 존재한다. 여기서 두 가지 추가적인 측면이 주목되어야 한다. 첫째, 특정 사회의 도덕성 내부에서도, 의무와 책무의 구조 및 그것들을 규정하는 비교적 명확한 규칙들 외에, 일정한 도덕적 이상(ideals)이 병존한다. 이러한 이상은 책무처럼 당연한 것으로 간주되지 않고, 성취로서 찬양의 대상이 된다. 영웅(hero)과 성인(saint)은 의무를 초과하여(more) 더 많은 것을 수행한 이들의 전형적 유형이다. 그들이 행한 것은 의무나 책무처럼 요구될 수 있는 것이 아니며, 그것을 하지 않았다고 해서 그른(wrong) 것으로 간주되거나 비난(blame)의 대상이 되지 않는다. 성인이나 영웅보다는 덜 극적인 수준에서, 일상생활에서 용기(bravery), 자선(charity), 자비(benevolence), 인내(patience), 정절(chastity)과 같은 도덕적 미덕(moral

virtues)을 나타냄으로써 사회로부터 칭찬받는 사람들이 있다. 이처럼 사회적으로 승인된 이상과 미덕은, 기본적으로 강제력을 지닌 사회적 의무 및 책무와 비교적 명확한 연결성을 갖는다. 많은 도덕적 미덕들은, 의무가 요구하는 범위를 넘어 타인의 이익에 대한 배려나 사적 이익의 희생을 자발적으로 확장해나가는 능력과 성향(disposition)으로 이루어진 성격 특성들이다. 자비(benevolence)와 자선(charity)은 이러한 유형의 대표적 예이다. 또 다른 도덕적 미덕들—예컨대 절제(temperance), 인내(patience), 용기(bravery), 양심성(conscientiousness)—은 (p. 183) 일정한 의미에서 보조적인(ancillary) 미덕들로 간주될 수 있다. 이는 특별한 유혹이나 위험 상황 속에서 의무에 대한 탁월한 헌신, 혹은 실질적인 도덕적 이상을 추구하는 과정에서 드러나는 성격 특성들이다.

도덕성(morality)의 보다 심화된 차원은, 특정 사회 집단들 내에서 인정되는 의무들(obligations)과 이상들(ideals)의 한계를 넘어서, 사회 자체에 대한 도덕적 비판(moral criticism)에 사용되는 원칙들(principles) 및 이상들로 우리를 이끈다. 그러나 이 경우에도 도덕성의 원초적 사회적 형태(primordial social form of morality)와의 중요한 연관성은 여전히 유지된다. 우리가 자기 사회 혹은 다른 사회의 수용된 도덕성(accepted morality)을 검토할 때, 그 속에서 다수의 비판점을 발견하게 될 가능성은 항상 존재한다. 그것은 현재 이용 가능한 지식의 관점에서 보았을 때, 불필요하게 억압적이거나, 잔혹하거나, 미신적이거나, 계몽되지 않은 것으로 보일 수 있다. 그것은 인간의 자유(human liberty)를 억압할 수 있으며, 특히 종교의 논의나 실천, 혹은 다양한 삶의 형식에 대한 실험에 있어서 그러하다. 이러한 억압이 타인에게 실질적인 이익을 거의 제공하지 않음에도 불구하고 그러할 수 있다. 무엇보다도, 특정 사회의 도덕성은 해악(harm)으로부터의 보호를 오직 그 사회의 구성원에게만, 심지어는 특정 계층에만 제공하면서, 노예(slave)나 노예적 계층(helot class)은 주인의 자의적 의지에 전적으로 노출시킬 수 있다. 이러한 형태의 비판 속에는 (설령 그것이 거부되더라도) 그것이 ‘도덕적’ 비판으로서의 자격을 확실히 인정받을 수 있다는 점이 암묵적으로 전제되어 있다. 그리고 이 비판 속에는 다음의 두 가지 형식적 조건이 사회의 제도적 구조, 즉 수용된 도덕성을 포함한 사회적 배열(social arrangements)에 요구된다는 전제가 깔려 있다. 첫째는 이성성(rationality)이

고, 둘째는 보편성(*generality*)이다. 이러한 비판은, 첫째로, 사회의 제도가 반증 가능한 오류에 기반한 믿음 위에 놓여서는 안 된다는 점을 함의하며, 둘째로는 도덕성이 본질적으로 그 요구하는 행위(*actions*) 및 자제(*forbearances*)를 통해 제공하는 해악으로부터의 보호가, 그러한 제한을 스스로 수용하고 준수할 수 있는 모든 인간에게 최소한으로 확장되어야 한다는 점을 함의한다. 그러므로 자유(*liberty*), 우애(*fraternity*), 평등(*equality*), 행복 추구(*the pursuit of happiness*)와 같은 표어들 속에 구현된 사회에 대한 이러한 도덕적 비판은, 다음과 같은 점에서 도덕성을 갖는다. 즉 그것은 모든 실질적인 사회적 도덕성들 속에서(비록 불충분한 수준일지라도) 이미 인정받고 있는 어떤 가치나 가치들의 결합의 이름으로, 혹은 그것들을 정제하고 확장한 형태로, 이성성과 보편성의 두 요구에 부합하기 위해 사회의 개혁을 요구한다는 점에서 도덕성을 지닌다.

물론, 자유나 평등의 이름으로 수용된 도덕성이나 (p. 184) 다른 사회 제도들을 비판하는 것이 도덕적(*moral*) 비판으로서 인정받는다고 해서, 그것에 대한 거부나 다른 가치들의 이름으로 이루어진 경우 그것이 도덕적이지 않다는 결론이 자동적으로 도출되지는 않는다. 자유의 제한에 대한 비난은, 자유를 사회적 혹은 경제적 평등(*equality*)이나 안전(*security*)을 위해 희생하는 것이 오히려 정당화될 수 있다(*justified*)는 주장에 직면할 수 있다. 이러한 상이한 도덕적 가치들에 부여되는 무게(*weight*)나 강조의 차이는 종종 조정 불가능할 수 있다. 그것들은 서로 급진적으로 다른 이상적 사회 구상(*radically different ideal conceptions of society*)을 구성할 수 있으며, 서로 대립하는 정치 집단의 도덕적 기반이 될 수 있다. 민주주의(*democracy*)의 가장 중요한 정당성 정당화(*justification*) 중 하나는, 이러한 대안들 사이에서 실험과 수정 가능한 선택을 가능하게 한다는 데 있다.

끝으로, 특정 사회에서 일반적으로 인정되는 의무와 이상을 넘어서는 도덕성의 확장은 반드시 사회 비판(*social criticism*)의 형태를 취할 필요는 없다. 도덕성에는 개인적(*private*) 측면도 있다는 점을 기억하는 것이 중요하다. 이것은 어떤 개인이 이상들(*ideals*)을 인식하고 그것에 헌신하는 방식으로 드러나며, 그는 이 이상들을 다른 이들과 공유할 필요도, 타인 또는 사회 전체에 대한 비판 근거로 삼을 필요도 없다. 삶은 영웅적, 낭만적, 미적, 학문적 이상 또는 (덜 공

정적으로는) 육체적 고행(mortification of the flesh)에 대한 헌신에 의해 지배될 수도 있다. 이 경우에도, 우리가 그것을 도덕(morality)이라고 부를 수 있는 이유는, 개인들이 추구하는 가치들이 자기 사회의 도덕성 속에서 인정되는 가치들과 유사하다는 점 때문일 수 있다. 그러나 그 유사성은 내용(content)의 유사성이 아니라, 형식(form)과 기능(function)의 유사성이다. 왜냐하면 이러한 이상들은 개인의 삶 속에서, 도덕성이 사회 전체에서 수행하는 역할과 동일한 기능을 수행하기 때문이다. 이들은 궁극적으로 중요한 것으로 간주되어, 그 추구는 다른 이해관계나 욕망보다 우선하는 의무처럼 느껴지며, 비록 전환(conversion)은 가능하더라도 그러한 이상들이 의도적인 선택에 의해 채택·변경·폐기될 수 있다는 개념은 공허하다(chimerical). 그리고 이러한 이상에서 벗어나는 이탈(deviation)은 사회적 도덕성(social morality)이 기본적으로 호소하는 바로 그 양심(conscience), 죄책감(guilt), 후회(remorse)을 통해 ‘처벌(punished)’된다.

CHAPTER VIII 주석

157쪽. 정의(*Justice*)는 도덕성(*morality*)의 독립된 한 영역이다. 아리스토텔레스는 『니코마코스 윤리학(Nicomachean Ethics)』 제5권 1-3장에서, 정의는 인간들 사이의 균형(balance)이나 비례(proportion)를 유지하거나 회복하는 것에 특수하게 관련된 것으로 설명한다. 정의 개념에 대한 현대의 가장 뛰어난 설명은 시즈윅(Sidgwick)의 『윤리학의 방법(The Method of Ethics)』 제6장, 페를만(Perelman)의 『정의에 대하여(De la Justice)』(1945), 그리고 이를 따른 로스(Ross)의 『법과 정의(On Law and Justice)』 제12장에 있다. 역사적으로 흥미로운 논의는 델 베키오(Del Vecchio)의 『정의(Justice)』에 있으며, 이는 하트(Hart)가 『철학(Philosophy)』 제28호(1953)에서 서평했다.

161쪽. 법 적용에서의 정의. 이 정의의 측면만을 정의 전체로 환원하려는 유혹은, 홉스(Hobbes)가 『리바이어던(Leviathan)』 제30장에서 “어떠한 법도 부정의할 수 없다(no law can be unjust)”라고 말한 데 대한 설명일 수 있다. 오스틴(Austin)은 『법의 영역(The Province of Jurisprudence Determined)』 제6장 260쪽 각주에서 “‘정의롭다(just)’는 말은 상대적 의미를 가지며, 그것은 발화자가 비교 기준으로 가정하는 특정한 법률에 대한 관계에서 말해진다”고 보았다. 따라서 그에게 있어 법률은 그것이 실정 도덕(positive morality)이나 신의 법(law of God)에 의해 판단된다면 도덕적으로 부정의할 수 있다. 오스틴은 홉스가 단지 법이 법적으로(*legally*) 부정의할 수 없다고 말한 것이라 보았다.

162쪽. 정의와 평등(*Equality*). ‘인간은 원칙적으로 동등하게 다루어져야 한다’는 원칙의 지위와 정의 개념과의 관계에 대한 유익한 논의로는, 벤(Benn)과 피터스(Peters)의 『사회 원칙과 민주 국가(Social Principles and the Democratic State)』 제5장 ‘정의와 평등(Justice and Equality)’, 롤스(Rawls)의 “정의를 공정으로서(Justice as Fairness)”(*Philosophical Review*, 1958), 라파엘(Raphael)의 “평등과 형평(Equality and Equity)”(*Philosophy*, 제21권, 1946), 그리고 “정의와 자유(Justice and Liberty)”(*Proceedings of the Aristotelian Society*, 제51권, 1951-2)가 있다.

162쪽. 아리스토텔레스의 노예제. 『정치학(Politics)』 제1권 제2장 3-22절 참조. 그는 어떤 이들은 ‘자연적으로(by nature)’ 노예가 아니며, 그들에게 노예제는 정의롭지도 유익하지도 않다고 보았다.

163쪽. 정의와 보상(*compensation*). 이는 아리스토텔레스에 의해 분배적 정의(distributive justice)와 명확히 구별되며, 위 저서 제5권 제4장에서 논의된다. 그는 모든 정의 개념의 적용에서 유지되거나 회복되어야 할 ‘정의로운’ 비례가 있다는 통일 원칙을 강조하였다. 해설서로는 잭슨(H. Jackson)의 『니코마코스 윤리학 제5권』(1879)

참조.

164쪽. 사생활 침해에 대한 법적 보상. 사생활권(the right to privacy)을 법이 인정해야 하며, 보통법(common law)의 원칙들이 이를 요구한다는 논증은, 워런(Warren)과 브랜다이스(Brandeis)의 “사생활의 권리(The Right to Privacy)” (*Harvard Law Review*, 제4권, 1890)와 *Roberson v. Rochester Folding Box Co.* (1902, 171 NY 538) 사건에서의 그레이 판사(Gray J.)의 반대 의견에서 확인된다. 영국의 불법행위법(tort law)은 사생활 자체를 보호하지는 않지만, 미국에서는 이제 광범위하게 보호된다. 영국법에서는 *Tolley v. J. S. Fry and Sons Ltd.* (1931, AC 333) 참조.

166쪽. 개인 간 정의와 더 넓은 사회적 이익 간의 충돌. 불법행위법(tort)에서의 엄격책임(strict liability)과 대리책임(vicarious liability)에 대한 논의는 프로서(Prosser)의 『불법행위론(Torts)』 제10장 및 제11장, 프리드먼(Friedmann)의 『변화하는 사회 속의 법(Law in a Changing Society)』 제5장에서 다루어진다. 형사법에서 엄격책임의 정당화에 대해서는 글랜빌 윌리엄스(Glanville Williams)의 『형사법(The Criminal Law)』 제7장, 프리드먼 위 저서 제6장 참조.

166쪽. 정의와 ‘공공선(common good)’. 공공선 추구를 정의로운 행위 혹은 공동체의 모든 구성원의 이익에 대한 공정한 배려로 동일시하는 논의는, 벤과 피터스의 『사회 원칙과 민주 국가』 제13장에서 다루어진다. 이처럼 ‘공공선’을 정의와 동일시하는 입장은 보편적으로 수용되지는 않는다. 시즈윅의 『윤리학의 방법』 제3장 참조.

167쪽. 도덕적 의무(Moral Obligation). 사회적 도덕성(social morality) 내의 의무(obligations)와 책무(duties)를 도덕적 이상(moral ideals) 및 개인적 도덕성(personal morality)과 구분해야 한다는 논의는, 엄슨(Urmson)의 “성인과 영웅(Saints and Heroes)” (*Essays on Moral Philosophy*, 멜든(Melden) 편), 화이트리(Whiteley)의 “도덕성 정의하기(On Defining ‘Morality’)” (*Analysis*, 제20권, 1960), 스트로슨(Strawson)의 “사회 도덕성과 개인 이상(Social Morality and Individual Ideal)” (*Philosophy*, 1961), 브래들리(Bradley)의 『윤리학 연구(Ethical Studies)』 제5장 및 제6장에서 확인된다.

169쪽. 사회 집단의 도덕성. 오스틴(Austin)은 『법의 영역(The Province of Jurisprudence Determined)』에서 ‘실정 도덕(positive morality)’이라는 표현을 사용하여, 하나의 사회에서 실제로 관찰되는 도덕성을 ‘신의 법(the law of God)’과 구분하였다. 후자는 오스틴에게 있어 실정 도덕과 실정 법을 판단하는 궁극적인 기준이었다. 이는 사회적 도덕성과 그것을 넘어서 이를 비판하는 도덕 원칙들 사이의 중요한 구별을 형성한다. 오스틴의 실정 도덕은 실정법 외의 모든 사회 규칙을 포함하며, 예절, 게임, 클럽, 국제법 등도 포함된다. 이러한 광범위한 도덕 개념은 형식과 사회적 기능의

중요한 구분을 흐린다. 제10장 제4절 참조.

172쪽. 필수 규칙들(Essential Rules). 폭력 사용을 제한하고 재산(property)과 약속(promises)에 대한 존중을 요구하는 규칙들이 실정법과 사회적 도덕성 모두의 기저에 있는 자연법(Natural Law)의 ‘최소 내용(minimum content)’을 형성한다는 논의는 제9장 제2절 참조.

172-173쪽. 법과 외적 행위. 본문에서 비판된, 법은 외적 행위를 요구하지만 도덕은 그렇지 않다는 견해는, 칸트(Kant)의 법률적 법(juridical laws)과 윤리적 법(ethical laws) 사이의 구분에서 비롯되었다. 이에 대한 고전적 설명은 헤이스티(Hastie) 편 『칸트의 법철학(Kant's Philosophy of Law)』(1887) 서론 14쪽 및 20-24쪽 참조. 현대적 재진술은 칸토로비츠(Kantorowicz)의 『법의 정의(The Definition of Law)』 43-51쪽에 있으며, 이는 휴즈(Hughes)의 “법체계의 존재(The Existence of a Legal System)” (New York University Law Review, 제35권, 1960)에서 비판된다.

178쪽. 범의(mens rea)와 객관적 기준. 홈즈(Holmes)의 『보통법(The Common Law)』 제11장, 홀(Hall)의 『형법 원칙(Principles of Criminal Law)』 제5장 및 제6장, 하트(Hart)의 “법적 책임과 면책(Legal Responsibility and Excuses)” (Determinism and Freedom, 후크(Hook) 편) 참조.

179쪽. 정당화(Justification)와 면책(Excuse). 살인(homicide)에 관한 법 이론에서의 이 구분은 케니(Kenny)의 『형법 개요(Outlines of Criminal Law)』(24판) 109-116쪽 참조. 일반 도덕 이론에서의 중요성은 오스틴(Austin)의 “면책을 위한 변론(A Plea for Excuses)” (Proceedings of the Aristotelian Society, 제57권, 1956-57), 하트의 “처벌의 원칙에 대한 서설(Prolegomenon to the Principles of Punishment)” (PAS, 제60권, 1959-60) 12쪽에서 논의됨. 유사한 구별은 벤담(Bentham)의 『법 일반론(Of Laws in General)』 121-122쪽의 ‘면제(exemption)’와 ‘면책(exculpation)’ 참조.

181쪽. 도덕성, 인간의 필요, 이해관계. 도덕 규칙(moral rule)을 도덕적인 것으로 부를 수 있는 기준은 그것이 당사자들의 이해관계에 대한 이성적이고 공정한 고려(reasoned and impartial consideration)의 산물이라는 입장에 대해서는 벤과 피터스의 『사회 원칙과 민주 국가』 제2장 참조. 대조적으로 데블린(Devlin)의 『도덕의 집행(The Enforcement of Morals)』(1959) 참조.

CHAPTER VIII 제3판 주석

157-160쪽. 정의의 원칙들(Principles of Justice). 하트(Hart)에게서 중요한 영향을 받은 존 롤스(John Rawls)는 정의(Justice)의 주제를 『정의론(A Theory of Justice)』(개정판,

하버드대학출판부, 1999) 제1장에서, 특히 6-10쪽에서 다룬다. 정의의 원칙들, 특히 분배적 성격(distributive character)에 주목한 유용한 개관으로는 데이비드 밀러(David Miller)의 『사회정의(Social Justice)』(옥스퍼드대학출판부, 1976) 제1장이 있다.

159-160쪽. ‘동일한 사건을 동일하게 대우하라(*Treat like cases alike*)’. 하트가 이를 일종의 정의로 간주한 것은 논쟁의 대상이 되어 왔다. 이 논의는 데이비드 라이언스(David Lyons)의 “형식적 정의에 대하여(*On Formal Justice*)” (*Cornell Law Review*, 제 58권, 1972, 833쪽), 매튜 크레이머(Matthew Kramer)의 “지속성으로서의 정의(*Justice as Constancy*)” (*Law and Philosophy*, 제16권, 1997, 561쪽), 존 가드너(John Gardner)의 『신념의 도약으로서의 법(*Law as a Leap of Faith*)』 제10장 “정의의 덕성과 법의 성격”에서 다루어진다. 드워킨(Dworkin)은 ‘동일한 사건을 동일하게 다룬다’는 원칙을 단순한 일관성(consistency)이 아니라 ‘통합성(integrity)’이라는 이상(ideal)과 연결시킨다. 그는 “통합성은 공동체의 공적 기준들(public standards)이, 가능한 한, 하나의 일관되고 통합된 정의(Justice)와 공정성(Fairness)의 체계를 표현하고 있음이 제도적으로 구현되고 또한 그렇게 보일 것을 요구한다”고 말한다 (*Law's Empire*, 219쪽). 이에 대한 회의적 입장은 드니즈 레움(Denise Réaume)의 “통합성은 덕성인가? 드워킨의 법적 의무 이론(*Is Integrity a Virtue? Dworkin's Theory of Legal Obligation*)” (*University of Toronto Law Journal*, 제39권, 1989, 380쪽), 조셉 라즈(Joseph Raz)의 『공적 영역에서의 윤리(*Ethics in the Public Domain*)』 319-325쪽을 참조하라.

161-164쪽. 분배적 정의(*Distributive Justice*)와 보상적 정의(*Compensatory Justice*). 정의의 ‘형태들(forms)’에 대한 전통적 분류와 그들 사이의 관계는 명확하지 않다. 특히 분배적 정의와 교정적 정의(corrective justice)에 관한 논의는 줄스 콜먼(Jules Coleman)의 『위험과 잘못(*Risks and Wrongs*)』(개정판, 옥스퍼드대학출판부, 1992), 스티븐 페리(Stephen Perry)의 “교정적 정의와 분배적 정의 사이의 관계에 대하여(*On the Relationship between Corrective and Distributive Justice*)” (제러미 호더(Jeremy Horder) 편, 『옥스퍼드 법철학 논문집』 제4집, 2000), 존 피니스(John Finnis)의 『자연법과 자연권(*Natural Law and Natural Rights*)』 173-184쪽, 존 가드너의 “불법행위법은 무엇을 위한 것인가? 제1부: 교정적 정의의 위치” (*Law and Philosophy*, 제30권, 2011, 1쪽)를 참조하라.

166-167쪽. 정의와 다른 가치들. 존 롤스는 『정의론』(개정판) 3-4쪽에서 정의는 사회 제도(social institutions)의 제1덕성(first virtue)이라 주장한다. 이 견해는 존 가드너의 『신념의 도약으로서의 법』 제10장 “정의의 덕성과 법의 성격”, 제러미 월드론(Jeremy Waldron)의 “정의의 우선성(*The Primacy of Justice*)” (*Legal Theory*, 제9권,

2003, 269쪽)에서 다루어진다.

169-170쪽. 관행적 도덕성(*Conventional Morality*). 하트는 ‘실정 도덕(positive morality)’과 ‘비판적 도덕성(critical morality)’을 구별한다. 실정적 혹은 관습적(customary), 또는 관행적 도덕성(conventional morality)은 특정 사회 집단에 의해 실제로 수용되고 있는 도덕성이다. 반면, 비판적 도덕성은 타당하고 정당화 가능한 도덕성, 즉 그 사회가 수용해야 마땅한(*ought to accept*) 도덕성이다. 이는 하트의 『법, 자유, 도덕(Law, Liberty, and Morality)』(스텐퍼드대학출판부, 1963) 17-24쪽에서 설명된다. 드워킨은, 사회적으로 수용된 모든 행위에 대한 태도들이 도덕성으로 간주될 수는 없으며, 일부는 단지 혐오(hatreds), 공포(phobias) 등에 불과하다고 주장한다. 이는 『권리를 진지하게 다루기(Taking Rights Seriously)』 248-255쪽에서 논의된다. W. J. 왈루초우(W. J. Waluchow)는, 단순한 관행이 아닌 공동체의 제도들에 의해 전제되는 실정적 ‘공동체 헌법 도덕성(community constitutional morality)’이 존재한다고 주장한다. 이는 그의 『판례법적 사법심사 이론(A Common Law Theory of Judicial Review: The Living Tree)』(케임브리지대학출판부, 2007)에서 전개된다.

183-184쪽. 사회에 대한 도덕적 비판(*Moral Criticism of Society*). 관련 논의는 패트릭 데블린(Patrick Devlin)의 『도덕의 집행(The Enforcement of Morals)』(옥스퍼드대학출판부, 1965), 하트의 『법, 자유, 도덕』, 드워킨의 『권리를 진지하게 다루기』 제10장, 로버트 P. 조지(Robert P. George)의 『도덕적 인간 만들기(Making Men Moral): 시민적 자유와 공적 도덕성(Civil Liberties and Public Morality)』(옥스퍼드대학출판부, 1993) 제2장을 참조하라.

IX. 법과 도덕 (Laws and Morals)

1. 자연법과 법실증주의 (Natural Law and Legal Positivism)

법과 도덕 사이에는 다양한 유형의 관계가 존재하며, 그 중 어느 하나를 그들 사이의 관계로 특정하여 연구 대상으로 삼는 것은 유익하지 않다. 대신, 법과 도덕이 관련되어 있다고 주장하거나 부인할 때 의미될 수 있는 다양한 사태들을 구분하는 것이 중요하다. 때로는 거의 누구도 부인한 적 없는 일종의 연결성을 주장하는 경우도 있으며, 이러한 논박의 여지 없는 사실이 보다 의심스러운 연결성의 징표로 잘못 수용되거나, 심지어 그것과 혼동되기도 한다. 예컨대, 언제 어디서나 법의 발전이 특정 사회 집단의 관행적 도덕(moral convention)과 이상(ideal), 그리고 당시 통용되는 도덕을 초월한 개인들의 계몽된 도덕적 비판(enlightened moral criticism)에 의해 심대한 영향을 받아왔다는 점은 진지하게 반박될 수 없다. 그러나 이러한 사실을 부당하게 일반화하여 다음과 같은 주장을 정당화하는 것으로 오용할 수 있다. 즉, 법체계는 일정한 형태의 도덕 혹은 정의(justice)에 반드시 부합해야 하며, 또는 그것에 대한 복종(obedience)이 도덕적 의무라는 널리 퍼진 확신 위에 반드시 기초해야 한다는 것이다. 물론 이 주장은 어떤 의미에서는 타당할 수 있으나, 그렇다고 해서 특정 법체계 내에서 사용되는 법적 유효성(legal validity)의 기준이 반드시 명시적으로든 암묵적으로든 도덕 혹은 정의에 대한 언급을 포함해야 한다는 결론이 도출되는 것은 아니다.

이 외에도 법과 도덕의 관계에 관한 문제는 매우 다양하게 제기될 수 있다. 본 장에서는 그중 두 가지 문제에 대해서만 논의하되, 이들 모두가 여러 다른 문제들과의 연관성을 수반할 것이다. 첫 번째는 전통적으로 ‘자연법 대 법실증주의’(Natural Law vs. Legal Positivism)의 대립으로 기술되어온 문제로, 이 두 용어는 이제 법과 도덕에 관한 다양한 명제들을 포괄하는 명칭이 되었다. 여기서 우리는 ‘법실증주의’(Legal Positivism)를 다음과 같은 단순한 주장의 의미로 이해할 것이다. 즉, (p. 186) 법이 특정한 도덕의 요구를 재현하거나 충족해야 한다는 것은 어떠한 의미에서도 필연적 진리로 간주될 수 없으며, 단지 사실적으로 그러한 경우가 종종 있었다는 것이다. 그러나 이 견해를 수용한 이들이

도덕의 본질에 관해 침묵했거나 서로 매우 상이한 견해를 보였다는 점에서, 법실증주의가 거부되어온 두 가지 매우 상이한 양태를 검토할 필요가 있다. 그 하나는 고전적 자연법 이론에서 가장 명확히 표현되는데, 이 이론은 인간 이성¹⁾에 의해 발견될 수 있는 일정한 인간 행위의 원칙들이 존재하며, 인간이 만든 법이 유효하기 위해서는 반드시 이에 부합해야 한다고 본다. 다른 하나는 보다 비합리주의적인 도덕관에 입각하여, 법적 유효성과 도덕적 가치 사이의 관계를 다른 방식으로 설명한다. 우리는 본 절과 다음 절에서 첫 번째 관점을 다룰 것이다.

플라톤으로부터 현대에 이르기까지, 인간이 어떻게 행동해야 하는지를 인간 이성(human reason)에 의해 발견할 수 있다는 주장과 그 부정을 둘러싼 방대한 문헌 속에서, 논쟁 당사자들은 서로에게 “이걸 못 본다면 눈이 먼 것이다”라고 말하고, 이에 대해 “당신은 꿈을 꿔요”라는 답을 듣는 경우가 잦다. 이는, 올바른 행위의 진정한 원칙이 이성적으로 발견 가능하다는 주장이 별개의 교의(doctrine)로 제시된 것이 아니라, 원래는 자연(nature)의 일반적 개념, 즉 무생물과 생명체 모두를 아우르는 하나의 관점의 일부로 제시되었기 때문이다. 이 자연에 대한 관점은 현대의 세속적 사고의 틀을 이루는 자연 개념과 여러 면에서 상충된다. 이로 인해 자연법 이론은 비판자들에게는 현대적 사고가 극복한 오래된 혼란의 산물로 보이지만, 지지자들에게는 오히려 그러한 비판자들이 피상적인 사소성만을 고집하면서 심층적 진리를 외면한다고 비친다.

예컨대, 많은 현대 비판자들은 인간 이성이 올바른 행위의 법칙을 발견할 수 있다는 주장이 ‘법’(law)이라는 단어의 단순한 중의성에 근거하고 있다고 본다. 그리고 이 중의성이 폭로됨으로써 자연법 이론은 결정적인 타격을 받았다고 여긴다. 존 스튜어트 밀(John Stuart Mill)은 몽테스키외(Montesquieu)를 이와 같은 방식으로 다루었다. 몽테스키외는 『법의 정신』(Esprit des Lois)의 첫 장에서, 왜 별(star)과 같은 무생물이나 동물은 ‘자연의 법칙’을 따르는데, 인간은 이를 따르지 않고 죄에 빠지는지를 순진하게 묻는다. 밀은 이것이 (p. 187) 자연의 규칙성 또는 경향성을 진술하는 법칙과 인간에게 일정한 방식으로 행동할 것을 요구하는 규범적 법칙을 혼동한 전형적인 사례라고 보았다. 전자는 관찰과 추론을 통해 발견되는 것으로서 ‘기술적 법칙’(descriptive laws)이라 부를 수

있으며, 과학자의 임무는 바로 이를 밝히는 것이다. 반면 후자는 사실에 대한 진술이 아니라 인간이 특정한 방식으로 행동해야 한다는 ‘명령’(prescriptions)이므로, 동일한 방식으로 확립될 수 없다. 따라서 몽테스키외의 질문에 대한 대답은 간단하다. 규범적 법칙은 위반될 수 있으면서도 여전히 법칙으로 남는다. 이는 단지 인간이 그들에게 주어진 지시를 따르지 않았다는 의미일 뿐이다. 그러나 자연과학이 발견한 법칙에 대해서는 위반 가능성 자체가 무의미하다. 만일 별들이 과학 법칙이 기술하는 규칙성과 다르게 움직인다면, 이는 법칙이 위반된 것이 아니라, 그러한 법칙은 ‘법칙’이라는 명칭을 잃고 새롭게 정식화되어야 한다. 이러한 ‘법’의 의미 차이에 대응하여, ‘~해야 한다’(must), ‘~할 의무가 있다’(bound to), ‘~하여야 한다’(ought), ‘~하는 것이 마땅하다’(should) 등의 연관된 어휘도 체계적인 의미 차이를 보인다. 따라서 이 관점에 따르면, 자연법에 대한 믿음은 단순한 오류로 환원된다. 즉, 법이라는 단어가 지닐 수 있는 매우 상이한 의미들을 식별하지 못한 데서 비롯된 오류라는 것이다. 마치 ‘너는 군복무에 반드시 응해야 한다’(You are bound to report for military service)와 ‘바람이 북쪽으로 불면 반드시 추워진다’(It is bound to freeze if the wind goes round to the north)에서 ‘bound to’의 의미 차이를 식별하지 못한 것과 같다.

자연법을 가장 강하게 공격한 벤담(Bentham)과 밀(Mill) 같은 비판자들은, 이러한 상이한 ‘법’의 의미를 혼동하는 오류가 우주의 신적 통치자(Divine Governor of the Universe)에 의해 자연의 규칙성이 명령되거나 제정되었다는 믿음의 잔재에서 기인한다고 보았다. 이러한 신정주의적(theocratic) 관점에서, 만유인력의 법칙과 십계명(God’s law for Man)의 차이는 단지 상대적인 것이며, 블랙스톤(Blackstone)의 표현처럼, 인간만이 이성과 자유의지를 부여받아 신의 명령을 인식하고 위반할 수 있다는 점이 유일한 차이였다. 그러나 자연법 이론은 언제나 신적 통치자나 입법자(Lawgiver)에 대한 신앙과 연관된 것은 아니며, 설령 그런 경우가 있었다 하더라도 그 이론의 핵심 교의들은 그러한 신앙에 논리적으로 의존하지 않는다. 자연법(Natural Law)이라는 용어에 포함된 ‘자연’(natural)의 관련 의미, (p. 188) 그리고 규범적 법과 기술적 법 사이의 명백하고도 중요한 차이를 축소하려는 이론의 전체적 태도는, 이 목적에 있어서는 세속적인 고대 그리스 사유에서 비롯되었다. 실제로 자연법 이론이 반복적으로

재확인되어 온 이유는, 그것이 신적 권위도 인간의 권위도 아닌 별개의 근거를 통해 도덕과 법을 설명하려 하기 때문이며, 그 형이상학적 언어와 오늘날에는 수용되기 어려운 전제들에도 불구하고 도덕과 법을 이해함에 있어 중요한 기초적 진리들을 담고 있기 때문이다. 본 장에서는 이들 진리를 형이상학적 맥락에서 분리하여 보다 단순한 용어로 다시 서술하고자 한다.

현대의 세속적 사고에서, 무생물과 생명체, 동물과 인간으로 구성된 세계는 반복적으로 발생하는 유형의 사건과 변화가 일정한 규칙적 연결성(regularity)을 보여주는 장면으로 이해된다. 이 중 일부는 인간이 발견하고 ‘자연법칙’(laws of nature)으로 정식화하였다. 현대적 관점에서 자연을 이해한다는 것은 바로 이러한 규칙성에 대한 지식을 어떤 영역에 적용하는 것이다. 위대한 과학 이론의 구조는 관찰 가능한 사실이나 변화, 사건을 단순하게 반영하는 것이 아니다. 오히려 상당 부분은 관찰 가능한 사실과 직접적 대응관계를 갖지 않는 추상적인 수학적 공식들로 구성된다. 그러나 이들 이론은 그러한 추상적 공식으로부터 일반화를 도출할 수 있게 하며, 이는 다시 관찰 가능한 사건을 통해 확인되거나 반박될 수 있다. 과학 이론이 자연에 대한 이해를 촉진할 수 있다는 주장은 궁극적으로는 그것이 미래에 어떤 일이 일어날지를 예측할 수 있는 능력, 곧 규칙적 발생에 대한 일반화에 근거하고 있다. 만유인력 법칙과 열역학 제2법칙은, 그러한 규칙적 현상에 대한 정보를 제공한다는 점에서, 현대 사유에서는 단순한 수학적 구성물을 넘어선 ‘자연법칙’으로 간주된다.

자연법 이론은, 관찰 가능한 세계를 단지 규칙성의 장으로 보지 않고, 이에 대한 지식 또한 그러한 규칙성의 인식에만 그치지 않는 오래된 자연 개념의 일부이다. 이 고전적 관점에서는, 인간, 동물, 무생물을 막론하고 명명 가능한 모든 존재자는 단지 자기 존재를 유지하려는 경향을 가질 뿐만 아니라, (p. 189) 각자에게 고유하게 적합한 목적(end)이나 최적 상태(optimum state)를 향해 나아가는 것으로 간주된다.

이는 사물들이 스스로 실현하는 탁월성의 단계들을 포함하고 있다는 목적론적 자연 개념(teleological conception of nature)이다. 주어진 종류의 사물이 그 고유한 목적(end) 또는 본래적 목적(proper end)을 향해 나아가는 과정은 규칙적이며, 해당 사물의 특유한 변화, 작용 또는 발달 양식을 일반화한 명제로

기술될 수 있다. 이 점에서 목적론적 자연관은 현대적 사고와 일정 부분 겹친다. 그러나 차이점은, 목적론적 자연관에서는 사물에 정기적으로 일어나는 사건들을 단순히 규칙적으로 발생하는 것이라고 여기지 않으며, 그것들이 실제로 규칙적으로 발생하는지 여부, 그것들이 마땅히 발생해야 하는지 여부, 그리고 그것들이 발생하는 것이 좋은 것인지 여부는 별개의 질문으로 간주되지 않는다는 점이다. 반대로, (예외적으로 ‘우연’(chance)에 기인한 기형적 사례를 제외하면) 일반적으로 발생하는 일들은, 그것이 해당 사물의 적절한 목적 또는 목표를 향한 하나의 단계로 드러나는 방식으로, 설명될 수 있고 또한 그것이 좋은 것 또는 마땅히 일어나야 할 것으로 평가될 수 있다. 따라서 어떤 사물의 발달 법칙은 그것이 마땅히 어떻게 작용하거나 변화해야 하는지를, 그리고 그것이 실제로 어떻게 작용하거나 변화하는지를 동시에 보여주어야 한다.

이와 같은 자연에 대한 사유 방식은 추상적으로 진술될 경우 낯설게 느껴질 수 있다. 그러나 생명체에 대해 우리가 오늘날에도 사용하는 표현 방식들을 떠올려 보면, 이러한 목적론적 관점이 여전히 그들의 발달을 설명하는 통상적 서술 방식 속에 반영되어 있음을 알 수 있다. 예컨대 도토리 경우, 참나무로 성장하는 것은 단지 도토리들이 보통 성취하는 현상이 아니라, 그들의 부패(이 역시 규칙적이지만)와는 달리 ‘성숙’의 최적 상태(optimum state)로 간주된다. 이러한 최종 상태의 관점에서, 도종의 발달 단계들은 설명되고 또한 ‘좋은’ 혹은 ‘나쁜’ 것으로 평가된다. 또한 도토리의 여러 부위와 구조적 변화의 ‘기능’(function)도 이 관점에서 규정된다. 예를 들어, 도토리가 ‘충분한’ 또는 ‘적절한’ 발달을 이루려면 수분이 필요하고, 잎의 정상적인 성장은 이러한 수분을 흡수하는 데 필요하며, 따라서 잎의 ‘기능’은 이를 공급하는 것이다. 우리는 이 성장을 “자연스럽게 발생해야 하는 것”(what ought naturally to occur)이라고 생각하고 말한다. 무생물의 작용이나 운동에 대해서는, 이러한 식의 설명 방식이 설득력을 잃는다. 다만 그것들이 인간의 목적을 위해 설계된 인공물(artefact)일 경우는 예외다. 돌이 떨어지면서 적절한 (p. 190) ‘목적’(end)을 실현하거나, ‘본래의 자리’(proper place)로 돌아간다고 보는 관점은, 오늘날에는 다소 우스꽝스럽게 여겨진다.

사실, 목적론적 자연관을 이해하는 데 있어 어려움 중 하나는, 그것이 ‘정

기적으로 발생하는 것에 대한 진술'과 '마땅히 발생해야 하는 것에 대한 진술' 사이의 차이를 최소화하듯, 현대 사유에서 매우 중요한 또 다른 차이도 흐릿하게 만든다는 점이다. 즉, 목적을 스스로 자각하고 이를 실현하고자 노력하는 인간과 그렇지 않은 생명체 또는 무생물 간의 차이를 희미하게 만든다. 목적론적 자연관에서, 인간은 다른 사물들과 마찬가지로 일정한 고유의 최적 상태(optimum state) 또는 목적(end)을 향해 나아가는 존재로 간주되며, 그가 다른 존재들과 달리 이 과정을 자각적으로 수행할 수 있다는 사실은 인간과 자연의 나머지 존재자들 사이에 본질적인 차이를 구성하지 않는다. 이러한 인간 고유의 목적 또는 선(good)은, 다른 생명체들과 마찬가지로 생물학적 성숙과 신체적 능력의 발달이라는 조건을 일부 포함하지만, 사고(thought)와 행위(conduct)를 통해 드러나는 정신과 품성의 발달 및 탁월성을 인간 고유의 요소로 포함한다. 인간은 다른 사물들과 달리, 이성과 성찰을 통해 이러한 정신적·도덕적 탁월성을 실현한다는 것이 무엇을 의미하는지 발견하고, 그것을 욕망할 수 있다. 그러나 이 목적론적 관점에 따르면, 이러한 최적 상태는 인간이 욕망하기 때문에 인간의 선 또는 목적이 되는 것이 아니라, 그것이 이미 자연적인 인간의 목적이기 때문에 인간은 그것을 욕망하는 것이다.

이러한 목적론적 관점의 많은 요소는 여전히 인간에 대한 우리의 사고와 언어 속에 잔존하고 있다. 우리는 어떤 것을 인간의 욕구(needs)라고 지칭하며, 그것을 충족시키는 것이 좋다(good)고 말하고, 인간에게 행해지거나 인간에 의해(by) 경험된 특정 행위나 상태를 해악(harm) 또는 손상(injury)이라고 말한다. 물론, 어떤 사람들은 죽기를 원해 음식이나 휴식을 거부할 수도 있다. 그러나 우리는 음식 섭취나 휴식을 단순히 인간이 정기적으로 하는 일이나 우연히 욕망하는 것으로 여기지 않는다. 음식과 휴식은 인간의 욕구이며, 설령 어떤 이들이 필요한 시점에 그것을 거부하더라도, 우리는 모든 인간이 먹고 자는 것이 자연스럽다고 할 뿐 아니라, 때때로 반드시 먹고 쉬어야 하며, 이러한 행위는 자연적으로 좋은 것이라고도 말한다. 이처럼 인간 행위에 대한 평가적 판단에서 '자연적으로'(naturally)라는 표현이 갖는 힘은, 그것이 단지 관행(convention)이나 인간이 정한 규범(human prescriptions)에 기초한 판단(예: "모자를 벗는 것이 예의이다")과 구별되기 때문이다. 전자는 (p. 191) 사고나 성찰을 통해

그 내용을 발견할 수 없으며, 또한 이는 단지 어떤 개인이 특정 시점에 우연히 가지고 있을 수도 있고 아닐 수도 있는 목적을 달성하기 위한 필요 조건을 지시하는 판단과도 다르다. 유사한 관점은 우리는 신체 기관의 기능(function)에 대한 개념과, 단순한 인과적 속성(causal properties) 간의 구분에서도 찾아볼 수 있다. 우리는 심장의 기능이 혈액을 순환시키는 것이라고 말하지만, 암세포의 기능이 죽음을 초래하는 것이라고는 말하지 않는다.

이러한 투박한 예시들은 인간의 행위에 대한 일상적 사고 속에 여전히 살아 있는 목적론적 요소들을 설명하기 위한 것으로, 인간이 다른 동물과 공유하는 생물학적 사실의 낮은 층위에서 가져온 것이다. 이 사고와 표현의 방식이 성립할 수 있는 것은 전적으로 명백한 어떤 전제를 내포하기 때문이다. 그것은 바로 인간 활동의 본래 목적이 생존(survival)이라는 암묵적 전제이며, 이는 대다수의 인간이 대부분의 시간 동안 존재를 지속하기를 원한다는 단순한 우연적 사실(contingent fact)에 기초하고 있다. 우리가 ‘자연적으로 좋은 행위’라고 말하는 행위들은 생존에 필요한 것들이며, ‘인간의 욕구’(human need), ‘해악’(harm), 그리고 신체 기관이나 변화의 ‘기능’(function)이라는 개념들 역시 동일한 단순한 사실 위에 성립한다. 물론 여기서 멈춘다면, 우리는 매우 약화된 형태의 자연법(Natural Law)만을 갖게 된다. 고전적 자연법론자들은 생존(perseverare in esse suo)을 인간의 목적 또는 선에 대한 훨씬 더 복잡하고 논쟁적인 개념 구조 속에서 가장 낮은 층위로만 간주하였다. 아리스토텔레스는 인간 지성의 무욕적 계발(disinterested cultivation of the human intellect)을, 아퀴나스는 신에 대한 인식(knowledge of God)을 인간 목적에 포함시켰으며, 이들 모두는 도전받을 수 있는 가치들을 제시하였다. 그러나 홉스(Hobbes)와 흄(Hume)을 비롯한 다른 사상가들은 목표 수준을 낮추었다. 그들은 생존이라는 겸손한 목적 속에 자연법의 용어를 실증적으로 설명해주는 중심적이고 반박할 수 없는 요소가 존재한다고 보았다. “인간 본성은 개인들 간의 결합(association) 없이는 결코 존속할 수 없으며, 그러한 결합은 공평(equity)과 정의(justice)의 법칙들이 존중받지 않는다면 결코 성립할 수 없다.”²⁹

이 단순한 사고는 실제로 법과 도덕의 성격 모두에 깊은 관련이 있으며,

²⁹Hume, *Treatise of Human Nature*, m. ii, ‘Of Justice and Injustice’.

(p. 192) 인간의 목적 또는 선을 특정한 삶의 방식(specific way of life)으로 상정하는 일반 목적론적 관점 속에서 나타나는 보다 논쟁적인 요소들로부터 분리해낼 수 있다. 더 나아가, 우리는 생존에 관해 언급하면서 그것을 선형적으로 고정된 것이며, 인간이 그것을 욕망하는 이유가 그것이 본래적 목적이기 때문이라는 관념을 현대의 인식에 비해 지나치게 형이상학적이라고 보고 폐기할 수 있다. 대신, 생존이 인간에게 일반적으로 욕망되는 것은 단지 우연적 사실에 불과하며, 인간의 목적 또는 선이라는 표현은 단지 그것이 인간이 욕망하는 것이기 때문이라는 의미로만 이해할 수도 있다. 그럼에도 불구하고, 우리가 생존을 상식적(common-sense) 방식으로 이해하더라도, 그것은 인간 행위와 그것에 대한 우리의 사고 속에서 여전히 특수한 지위를 가진다. 이는 고전적 자연법 이론에서 생존에 부여된 중심성과 필연성과 유사한 위상을 갖는다. 대다수의 인간이 극심한 고통을 감수하면서도 살아가기를 원하는 것뿐 아니라, 이러한 경향은 우리가 세계와 타인을 설명하는 사고 및 언어의 구조 전반에 반영되어 있다. 우리가 삶에 대한 일반적인 욕망을 제거한다면, ‘위험’과 ‘안전’, ‘해악’과 ‘이익’, ‘욕구’와 ‘기능’, ‘질병’과 ‘치유’ 같은 개념을 온전히 유지할 수 없을 것이다. 이러한 개념들은 모두 생존이라는 수용된 목적에 비추어 대상을 동시에 기술하고 평가하는 방식이기 때문이다.

그러나 생존(survival)을 하나의 목표로 수용하는 것이 필요하다는 점을 보여주는 논의들은 이보다 단순하고 철학적이지 않은 형태로도 제시될 수 있다. 이러한 논의들은 법과 도덕을 둘러싼 논의와 더욱 직접적으로 관련된 방식에서 유의미하다. 우리는 생존을 논의의 전제로서 수용할 수밖에 없다. 왜냐하면 우리가 관심을 두는 것은 자살 동호회(suicide club)의 방식이 아니라, 지속적인 공동 존재를 위한 사회적 장치(social arrangements)이기 때문이다. 우리는 이러한 사회적 장치들 가운데 어떤 것들이 이성(reason)에 의해 발견 가능한 자연법(natural law)으로 유의미하게 간주될 수 있는지를, 그리고 그것이 인간 법(human law)과 도덕(morality)과 어떤 관계를 맺는지를 알고자 한다. 인간이 어떻게 함께 살아가야 하는지에 관한 이 문제, 혹은 그 어떤 문제를 제기하더라도, 우리는 일반적으로 인간이 살기를 원한다는 전제를 설정해야 한다. 이 지점부터 논증은 단순하다. 인간의 본성과 인간이 살아가는 세계에 관한 몇 가지 매우

자명한 일반화들—실로 상식적 진리(truisms)—을 숙고해보면, (p. 193) 이러한 조건들이 유지되는 한, 어떤 사회조직이 존속 가능하려면 반드시 포함해야 하는 일정한 행위 규칙들이 존재함을 알 수 있다. 실제로 이러한 규칙들은 법과 관행적 도덕(conventional morality)이 사회적 통제의 상이한 형식으로 구분되기에 이를 정도로 발전한 모든 사회들에서 공통된 요소를 구성한다. 물론 그러한 사회들의 법과 도덕에는 특정 사회에 고유한 요소들과 임의적이거나 단순한 선택 사항처럼 보이는 것들도 다수 존재한다. 하지만 인간 존재, 자연적 환경, 그리고 그 목표에 관한 기본적인 진리들에 근거를 두고 보편적으로 인정되는 행위의 원칙들은, 보다 거창하고 논쟁적인 자연법 이론들과 구별되는 의미에서 자연법의 최소 내용(minimum content of Natural Law)으로 간주될 수 있다. 다음 절에서는 이러한 소박하지만 중요한 최소 내용을 뒷받침하는 인간 본성의 핵심적 특징들을 다섯 가지 상식적 진술의 형식으로 고찰할 것이다.

2. 자연법의 최소 내용 (The Minimum Content of Natural Law)

이제 우리가 제시할 단순한 상식적 진술들과 그것이 법과 도덕과 맺는 연관성을 고려할 때, 각 경우에 언급되는 사실들이 생존을 목표로 전제할 경우, 법과 도덕이 특정한 내용을 포함해야 하는 이유(reason)를 제공한다는 점에 주목하는 것이 중요하다. 이 논증의 일반적인 형태는 다음과 같이 단순하다. 즉, 그러한 내용을 포함하지 않는 한, 법과 도덕은 인간이 서로 연대(association)하는 최소한의 목적—즉 생존—을 실현하는 데 기여할 수 없다는 것이다. 만약 이러한 내용이 결여되어 있다면, 현재의 인간 존재 조건 하에서 인간은 자발적으로 어떤 규칙도 따를 이유가 없으며, 규칙을 자발적으로 따르고 유지하는 것이 자신에게 이익이 된다고 판단하는 사람들로부터 최소한의 협력이 제공되지 않는다면, 자발적으로 따르지 않는 다른 사람들을 강제할 수단은 존재하지 않게 된다. 이 접근법에서는 자연적 사실(natural facts)과 법적·도덕적 규칙의 내용 간의 관계가 이성적(rational)으로 매개되어 있다는 점을 강조하는 것이 중요하다. 왜냐하면, 자연적 사실과 법·도덕 규범 사이에는 이와는 전혀 다른 형태의 연결관계를 탐구하는 것도 가능하며 또한 중요하기 때문이다. 예컨대, 아직

초기 단계에 있는 심리학(psychology)과 사회학(sociology) 등의 과학은 다음과 같은 사실을 이미 발견했거나 앞으로 발견할 수 있을 것이다. 예컨대, 특정한 신체적·심리적·경제적 조건이 충족되지 않으면, 즉 어린아이가 (p. 194) 가정 내에서 특정 방식으로 양육되지 않으면, 어떠한 법체계나 도덕규범 체계도 수립될 수 없다는 것, 또는 특정한 유형의 법률만이 성공적으로 기능할 수 있다는 것 등이다. 이러한 자연적 조건들과 규범 체계들 간의 연결은 이유(reason)에 의해 매개되지 않는다. 왜냐하면 그것들은 특정 규칙의 존재를 그것을 따르는 사람들의 자각적 목표(conscious aims)나 목적(purpose)에 연결시키지 않기 때문이다. 예컨대, 유아기에 특정한 방식으로 양육되는 것이 어떤 인구집단이 도덕적 또는 법적 규범을 발전시키거나 유지하는 데 필요조건이거나 심지어 원인(cause)이 될 수는 있겠지만, 그것이 그렇게 하는 이유(reason)는 아니다. 물론 이러한 인과적 연결(causal connections)은 목적이나 의식적인 목표에 기반한 연결과 충돌하지 않는다. 오히려 이 인과적 설명들은 후자의 연결보다 더 중요하거나 근본적인 것으로 간주될 수도 있다. 왜냐하면 그것들은 인간이 자연법이 출발점으로 삼는 그러한 자각적 목적들을 가지게 된 이유를 실제로 설명해줄 수 있기 때문이다. 이러한 종류의 인과 설명은 상식적 진술(truisms)에 의존하지 않으며, 의식적인 목적이나 의도를 매개로 하지 않는다. 그것들은 일반화와 이론, 관찰 및 가능하다면 실험에 기초한 사회학과 심리학 같은 과학의 과업이다. 그러므로 이 연결들은 아래에 제시될 상식적 진술들과 특정한 법적·도덕적 규칙의 내용을 연결하는 방식과는 전혀 다른 유형의 연결이다.

- (i) 인간의 취약성 (Human vulnerability) 법과 도덕의 공통된 요구사항들은 대부분 적극적 봉사가 아니라 자제(forbearance)의 형태로 나타나며, 이는 대개 부정적 명령, 즉 금지(prohibition)로 표현된다. 사회생활에 있어 가장 중요한 것은 타인에게 신체적 위해를 가하거나 살해하는 데에 폭력을 사용하는 것을 제한하는 규칙들이다. 이러한 규칙들의 기본적 성격은 다음과 같은 질문을 통해 드러난다. 만약 이런 규칙이 없다면, 우리 같은 존재들이 다른 종류의 어떤 규칙이라도 가질 이유가 있을까? 이 수사적 질문의 힘은 인간이 때때로 타인을 신체적으로 공격하는 경향이 있으며,

일반적으로는 타인의 공격에 취약하다는 사실에 기반한다. 이는 상식적 진술(truism)이지만, 필연적 진리(necessary truth)는 아니다. 상황은 달라질 수도 있고, 언젠가는 달라질 수도 있다. 어떤 동물 종들은 외골격(exoskeleton)이나 딱딱한 등껍질(carapace)과 같은 신체 구조를 지니고 있어, 동종의 다른 개체의 공격에 사실상 면역이거나, 공격 수단이 전혀 없는 경우도 있다. 만약 인간이 (p. 195) 서로에게 신체적으로 취약하지 않게 된다면, 법과 도덕의 가장 대표적인 규정 가운데 하나인 살인하지 말라(Thou shalt not kill)는 조항의 명백한 정당성도 사라질 것이다.

- (ii) 대략적 평등 (Approximate equality) 인간은 신체적 힘, 민첩성, 그리고 더욱이 지적 능력(intellectual capacity)에서 서로 다르다. 그럼에도 불구하고, 인간 법제와 도덕의 다양한 형태를 이해함에 있어 결정적으로 중요한 사실은, 어떤 개인도 타인들을 장기간에 걸쳐 협력 없이 지배하거나 제압할 수 있을 정도로 압도적으로 강하지 않다는 점이다. 가장 강한 사람조차도 때때로 잠을 자야 하며, 수면 중에는 일시적으로 그의 우월성을 상실한다. 이와 같은 대략적 평등(approximate equality)의 사실은, 상호 자제(mutual forbearance)와 절충(compromise)의 체계가 필요하다는 점—법적·도덕적 의무의 기반이 되는 점—을 무엇보다 명확히 보여준다. 이러한 자제를 요구하는 규칙들과 함께 살아가는 사회생활은 때로는 불편하고 성가시기도 하지만, 이와 같은 대략적으로 평등한 존재들에게 있어 그것은 제한 없는 공격 상태에서의 삶보다는 덜 악랄하고, 덜 야만적이며, 덜 짧다. 물론 이와 양립하는 또 하나의 상식적 진술은, 이러한 자제 체계가 수립되면 언제나 이를 악용하려는 자들이 존재한다는 것이다. 즉, 그들은 동시에 이 체계의 보호 아래 살면서도 그 제약을 깨뜨리려 한다. 실제로 이는, 뒤에서 설명하겠지만, 단순한 도덕적 통제로부터 조직화된 법적 통제로 이행하는 것이 필연적인 이유가 되는 자연적 사실 가운데 하나이다. 다시 말해, 사태는 다르게 전개될 수도 있었을 것이다. 인간이 대략적으로 평등한 대신, 어떤 사람들은 현존 평균 수준보다 훨씬 강하거나, 휴식을 거의 취하지 않아도 되는 존재일 수도 있었고, 또는

대부분의 사람들이 평균보다 훨씬 열등했을 수도 있다. 이러한 예외적 존재들에게는, 타인과 상호 자제하거나 타협하는 것보다 공격을 통해 더 많은 것을 얻을 가능성이 컸을 것이다. 그러나 우리는 거인들이 소인들 사이에서 사는 환상적인 장면을 상상할 필요도 없다. 왜냐하면 대략적 평등의 결정적 중요성은 국제 사회의 사실들—국가 간의 힘과 취약성의 극단적 불균형—에서 오히려 더 잘 드러나기 때문이다. 후술하겠지만, 국제법(international law)의 구성 단위들 사이의 이러한 불평등은, 그것이 국내법(municipal law)과 매우 다른 성격을 갖게 만든 요인 중 하나이며, 국제법이 조직화된 강제 체계(coercive system)로 기능할 수 있는 범위를 제한해왔다. (p. 196)

(iii) 제한된 이타성 (Limited altruism) 인간은 서로를 말살하려는 욕망에 지배당한 악마가 아니며, 단지 생존이라는 소박한 목적만을 가정하더라도, 법과 도덕의 기본 규칙들이 필수적이라는 점을 입증하는 것은, 인간이 본질적으로 이기적이며 타인의 생존과 복지에 대해 무관심하다는 잘못된 견해와 동일시되어서는 안 된다. 그러나 인간이 악마가 아니라면, 동시에 천사도 아니다. 인간이 이 두 극단 사이의 중간자라는 사실은 상호 자제 체계가 필요하며 가능하다는 점을 보여준다. 타인에게 해를 끼칠 유혹조차 느끼지 않는 천사들 사이에서는, 자제를 요구하는 규칙이 필요하지 않을 것이다. 반면에, 자기 희생을 개의치 않고 파괴를 일삼는 악마들 사이에서는 그러한 규칙이 아예 성립할 수 없다. 실제 세계에서 인간의 이타성은 범위가 제한적이고 지속적이지 않으며, 공격적 성향은 충분히 자주 발현되어 통제되지 않으면 사회생활을 파괴할 수 있다.

(iv) 제한된 자원 (Limited resources) 인간은 음식, 의복, 거처를 필요로 하며, 이들은 무한히 풍부하게 존재하지 않고, 자연으로부터 경작하거나 획득하거나 인간의 노동으로 만들어져야 한다는 사실은 단지 우연적인(contingent) 사실일 뿐이다. 그러나 이 사실들만으로도, 어떤 최소 형태의 재산 제도(property institution)는 필수적이며(비록 그것이 반드시 개인 재산일 필요는 없더라도), 이를 존중할 것을 요구하는 고유한 규칙

유형이 필요하다. 가장 단순한 재산 개념은 다음과 같은 규칙에서 찾아볼 수 있다. 즉, ‘소유자’(owner)가 아닌 자들의 토지 출입 또는 사용, 혹은 물질적 사물의 취득 및 사용을 배제하는 규칙이다. 작물이 자라기 위해서는 토지가 무차별적 출입으로부터 보호되어야 하고, 식량은 수확 또는 포획과 소비 사이의 기간 동안 타인에 의해 빼앗기지 않아야 한다. 언제 어디서든, 인간의 삶은 이러한 최소한의 자제 행위에 의존한다. 물론 이 점 또한 상황이 달랐을 수도 있다. 인간 유기체가 식물처럼 대기 중에서 음식물을 추출할 수 있었거나, 인간이 필요로 하는 것이 경작 없이 무한히 자라나는 방식으로 구성되어 있었다면 말이다.

지금까지 논의한 규칙들은 정태적 규칙(static rules)이다. 즉, 그것들이 부과하는 의무 및 그 의무의 귀속은 개인에 의해 변형될 수 없는 의미에서 그러하다. 그러나 최소 규모 집단을 제외한 모든 집단은, 충분한 자원을 확보하기 위해 노동의 분업(division of labour)을 발전시켜야 하며, 이는 개별 구성원이 의무를 생성하거나 그 귀속을 변경할 수 있도록 하는 (p. 197) 동태적 규칙(dynamic rules)을 필요로 한다. 그 예로는 생산물을 이전, 교환, 또는 판매할 수 있게 하는 규칙들이 있다. 이러한 거래들은, 재산의 가장 단순한 형태를 정의하는 초기 권리와 의무의 귀속을 변경할 수 있는 능력을 전제하기 때문이다. 동일하게 불가피한 노동 분업과 지속적인 협력의 필요성은, 약속이 의무의 근원(source of obligation)으로 인정되도록 하는 다른 유형의 동태적 규칙들을 필수적인 것으로 만든다. 이러한 장치를 통해, 개인은 말(구두든 문서든)을 통해 자신을 일정한 방식으로 행동할 의무를 지닌 존재로 만들 수 있으며, 그 의무 불이행 시 비난이나 처벌의 대상이 될 수 있다. 이타성이 무제한이 아니라면, 그러한 자기구속적 행위(self-binding act)를 제도적으로 보장하는 절차가 요구된다. 이는 타인의 미래 행위에 대한 최소한의 신뢰를 가능케 하고, 협력에 필수적인 예측 가능성(predictability)을 확보하기 위한 것이다. 이는 특히 교환되거나 공동으로 기획되는 것이 상호 서비스이거나, 재화(goods)가 동시에 또는 즉각적으로 제공되지 않는 경우에 가장 필요하다.

(v) 제한된 이해력과 의지력 (Limited understanding and strength of will) 인격

(persons), 재산(property), 약속(promises)을 존중하는 규칙들이 사회생활에서 필요하다는 사실은 단순하며, 그 상호적 이익도 명백하다. 대부분의 사람들은 이를 인식할 수 있으며, 이러한 규칙에 순응(compliance)하는 데 요구되는 단기적 이익의 희생을 감수할 수 있다. 실제로 사람들은 다양한 동기에 따라 복종할 수 있다. 어떤 이는 그 희생이 장기적으로 얻는 이익에 비해 타당하다는 신중한 계산(prudential calculation)에서, 또 어떤 이는 타인의 복지에 대한 무관심하지 않은 관심(disinterested interest)에서, 또 어떤 이는 해당 규칙 자체가 존중할 가치가 있다고 보고, 그것에 헌신하는 데서 이상(ideals)을 찾기 때문이다. 그러나 이러한 복종의 동기를 작동하게 하는 장기적 이익에 대한 이해나, 의지의 권총강도 또는 선함(strength or goodness of will)은 모든 사람에게 동등하게 분포되어 있지 않다. 누구나 때때로 자신의 즉각적 이익을 우선하려는 유혹을 받으며, 이를 탐지하고 처벌하기 위한 특수한 조직이 없다면, 많은 사람들이 그 유혹에 굴복하게 될 것이다. 물론 상호 자제의 이점이 워낙 명백하기 때문에, (p. 198) 강제적 체계(coercive system) 내에서 자발적으로 협력하려는 사람들의 수와 그 힘은, 일반적으로 범법자들의 가능한 조합보다 클 것이다. 그럼에도 불구하고, 아주 소규모의 밀접하게 조직된 사회를 제외하고는, 억제 체계(system of restraints)에 대한 복종은, 그 의무(obligations)에 복종하지 않으면서 그 이점만을 얻고자 하는 자들을 강제할 조직이 없다면, 어리석은 일이 될 것이다. 따라서 ‘제재’(sanctions)는 통상적인 복종의 동기로 요구되는 것이 아니라, 자발적으로 복종하려는 자들이 복종하지 않으려는 자들에게 희생되지 않도록 보장하는 장치(guarantee)로서 요구된다. 이러한 장치 없이 복종한다는 것은 도태될 위험을 감수하는 일이다. 이와 같은 항구적인 위험이 존재하는 조건에서, 이성이 요구하는 것은 강제적 체계 내에서의 자발적 협력(voluntary co-operation in a coercive system)이다.

이 지점에서 주목해야 할 것은, 인간 사이의 대략적 평등(approximate equality)이라는 동일한 자연적 사실이, 조직화된 제재가 효과를 발휘하는 데 결정적

으로 중요하다. 만약 어떤 이들이 다른 이들보다 훨씬 더 강력하여 타인의 자제에 의존하지 않아도 된다면, 범법자들의 힘이 법과 질서를 지지하는 이들의 힘을 능가할 수 있다. 이러한 불평등이 존재할 경우, 제재의 사용은 성공할 수 없으며, 오히려 그것이 억제하려는 위험만큼이나 큰 위험을 초래할 수 있다. 이러한 조건에서는, 사회생활이 소수 범법자에 대해 간헐적으로 힘을 사용하는 상호 자제 체계에 기반하기보다는, 약자들이 가능한 최상의 조건 하에서 강자에게 굴복하고, 그들의 ‘보호’ 하에 살아가는 체계만이 유일하게 존속 가능하다. 이러한 체계는 자원의 희소성(scarcity of resources)으로 인해 다수의 상호 충돌하는 권력 중심들이 생기게 하며, 각 중심은 자신만의 ‘강자’(strong man)를 중심으로 결집하게 된다. 이들은 때때로 상호 간 전쟁을 벌일 수도 있지만, 패배라는 자연적 제재(natural sanction)의 위험이 결코 무시할 수 없는 것이기에 불안정한 평화를 유지할 수도 있다. ‘권력자들’(powers)이 직접 전투를 벌이기를 꺼리는 쟁점들에 대해서는, 일종의 규칙들이 수용될 수도 있다. 다시 말해, 우리는 소인국과 거인의 환상적 비유를 상상할 필요 없이, 대략적 평등의 단순한 작동 논리(logistics)와 그것이 법에 있어 갖는 중요성을 이해할 수 있다. 국가들 간의 힘의 격차가 극심했던 국제 사회(international scene)는 그 예시로 충분하다. 수 세기 동안 국가 간의 이러한 불균형은 조직화된 제재의 작동을 불가능하게 만들었고, 법은 ‘중대 사안’(vital issues)에 영향을 미치지 않는 영역에만 한정되었다. (p. 199) 향후 원자무기(atomic weapons)가 모든 국가에 의해 사용 가능해질 경우, 이러한 불균형이 어느 정도 시정되고, 국제 통제가 국내 형사법(municipal criminal law)에 더 가까운 형태로 진화하게 될지 여부는 아직 확정되지 않았다.

우리가 지금까지 논의한 이러한 단순한 진부하게 참인 진술들(truisms)은, 자연법(Natural Law) 이론 속의 핵심적인 이성적 직관을 드러낼 뿐 아니라, 법과 도덕을 이해하는 데 본질적으로 중요하며, 왜 법과 도덕의 기본 형태를 특정한 내용이나 사회적 필요에 대한 언급 없이 순전히 형식적 정의로만 설명하는 것이 부적절했는지를 설명해 준다. 아마도 이러한 관점이 법이론(jurisprudence)에 주는 가장 큰 공헌은, 법의 성격에 대한 논의를 자주 흐리게 해왔던 몇몇 오해를 불러일으키는 이분법(dichotomies)들로부터 벗어날 수 있는 여지를 제공한다는

점이다. 예컨대, 전통적인 질문인 “모든 법체계는 제재를 반드시 포함해야 하는가?”라는 문제는, 자연법의 이 단순한 판본이 제공하는 관점에서 새롭고 보다 명료한 방식으로 제기될 수 있다. 우리는 더 이상 다음의 두 가지 부적절한 대안 사이에서 선택을 강요받지 않아도 된다: 하나는, 법(law)이나 법체계(legal system)라는 단어의 ‘정의’에 비추어 제재가 요구된다고 주장하는 입장이고, 다른 하나는, 대부분의 법체계가 실제로 제재를 포함하고 있다는 것이 단지 ‘사실’(just a fact)에 불과하다고 주장하는 입장이다. 이 두 입장은 모두 만족스럽지 않다. 중앙집중적 제재가 없는 체계에 대해 ‘법’이라는 용어를 사용하는 것을 금지하는 확립된 원칙은 존재하지 않으며, 제재를 포함하지 않는 체계를 ‘국제법’(international law)이라 부르는 데에도 타당한 이유(비록 강제성은 없지만)가 있다. 그러나 반대로, 인간 존재의 조건에 부합하는 최소한의 목적들을 수행하려는 국내 체계(municipal system)의 경우에는, 그 안에서 제재가 반드시 차지해야 할 위치를 구분해야 한다. 자연적 사실들과 목적들이, 국내 체계 안에서 제재를 가능하고 필수적인 것으로 만든다는 점을 고려하면, 우리는 이것이 하나의 자연적 필연성(natural necessity)이라고 말할 수 있다; 그리고 이와 같은 표현은, 인격(persons), 재산(property), 약속(promises)에 대한 최소한의 보호 형태가 국내법의 필수 구성 요소로 기능한다는 점을 전달하는 데도 필요하다. 우리는 바로 이러한 방식으로 “법은 어떤 내용도 가질 수 있다”(law may have any content)는 실증주의 테제에 응답해야 한다. 왜냐하면 법뿐 아니라 많은 다른 사회 제도들을 적절히 서술하기 위해서는, 정의(definitions)나 일반적 사실 진술(statements of fact) 외에도 제3의 진술 범주가 필요하기 때문이다. (p. 200) 즉, 그 진리 여부가 인간 존재와 그들이 살아가는 세계가 특정한 핵심적 특징을 유지하는 한에서 조건적으로 성립하는 진술들이 필요하다는 것이다.

3. 법적 유효성과 도덕적 가치

상호 자제(mutual forbearance)의 체계가 제공하는 보호와 이익은, 법과 도덕의 기초를 이루면서도, 각기 다른 사회에서 매우 상이한 범위의 사람들에게 확장될 수 있다. 일정한 제한을 기꺼이 수용하는 한 어떤 인간 집단에게도 이러한

기본적 보호를 부정하는 것은, 모든 현대 국가가 최소한 언어적으로는 존중을 표하는 도덕과 정의의 원칙에 반하는 일이라는 점은 사실이다. 오늘날 널리 공언되는 도덕적 관점은, 적어도 이러한 근본적인 영역에서만은 인간은 동등하게 대우받을 자격이 있으며, 차별적 대우는 단순히 타인의 이익을 근거로 정당화될 수 없다는 관념을 바탕으로 깔고 있다.

그러나 한편으로는, 어떤 사회의 법이나 통용되는 도덕이 그들의 범위 내에 있는 모든 사람에게 이러한 최소한의 보호와 이익을 제공해야 할 필요는 없으며, 실제로 종종 그러지 않았다. 노예제 사회에서 지배 집단은 노예를 단순한 사용의 대상이 아니라 인간이라는 사실 자체를 인식하지 못하게 될 수 있으며, 동시에 서로 간의 권리와 이해관계에는 매우 민감한 도덕의식을 유지할 수도 있다. 『허클베리 핀(Huckleberry Finn)』에서, 증기선의 보일러가 폭발해 다친 사람이 있는지를 묻는 말에 허크는 “아뇨, 그냥 감동이 한 명이 죽었어요(No'm: killed a nigger)”라고 답한다. 이때 앤트 셸리가 “그래도 다행이네, 가끔은 사람도 다치거든(Well it's lucky because sometimes people do get hurt)”이라고 덧붙이는 장면은, 실제로 인간 사회에서 오래도록 지배적이었던 하나의 도덕 체계를 응축해서 보여준다. 그러한 도덕 체계가 지배하는 사회에서, 허크가 뼈저리게 경험했듯이, 노예에 대해 지배 집단 구성원들 사이에서 자연스럽게 작동하는 상호 관심을 연장 적용하려는 시도는 중대한 도덕적 위반으로 간주되며, 그에 상응하는 도덕적 죄책(moral guilt)의 결과를 초래한다. 나치 독일과 남아프리카 공화국의 사례는, 그 시간이 우리에게 불편할 정도로 가깝다는 점에서 유사한 교훈을 제공한다.

물론 어떤 사회의 법은 때로는 통용되는 도덕보다 앞서기도 했지만, 일반적으로 법은 도덕을 뒤따르며, 노예 살인조차도 공적 자원의 낭비이거나, 노예를 소유한 주인의 재산에 대한 침해로만 간주되기도 한다. 심지어 노예제가 공식적으로 인정되지 않는 사회에서도, 인종, 피부색, (p. 201) 또는 신조 등의 이유로 차별이 존재할 수 있으며, 이러한 차별은 모든 인간이 타인으로부터 최소한의 보호를 받을 자격이 있다는 점을 법체계나 사회적 도덕이 인정하지 않게 만든다.

이러한 인간사의 고통스러운 사실들은, 어떤 사회가 존속 가능하려면 반드시 일부 구성원에게는 상호 자제의 체계를 제공해야 하지만, 그것이 반드시

모든 이에게 제공되어야 할 필요는 없다는 점을 명확히 보여준다. 앞서 제재(sanction)의 필요성과 가능성에 대해 논의하면서 강조한 바와 같이, 어떤 규칙 체계가 강제력(force)에 의해 시행되려면, 일정 수의 사람들이 그것을 자발적으로 수용해야 한다. 이러한 자발적 협력은 곧 권위(authority)를 형성하며, 이는 법과 정부의 강제력을 정초하는 기반이다. 하지만 이렇게 형성된 강제력은 두 가지 주요한 방식으로 사용될 수 있다. 첫째, 그 강제력은 규칙으로부터 보호를 받으면서도 이기적으로 그것을 위반하는 범법자(malefactors)에 대해서만 행사될 수 있다. 둘째, 그 강제력은 일정한 수의 피지배 집단(subject group)을 억압하고 그들을 영구적인 열등한 지위에 고정시키는 데 사용될 수도 있다. 이때 피지배 집단의 규모는 지배 집단(master group)의 연대력(solidarity), 규율(discipline), 그리고 강제 수단의 가용성에 따라 크거나 작을 수 있으며, 피지배 집단의 무력함이나 조직화 능력 부족은 그 억압을 더욱 가능하게 만든다. 이러한 억압을 받는 자들에게는, 그 체계가 그들의 충성을 요구할 만한 어떠한 것도 제공하지 않으며, 오직 두려움의 대상일 뿐이다. 그들은 법체계의 수혜자(beneficiaries)가 아니라 피해자(victims)이다.

이 책의 앞선 장들에서 우리는 법체계의 존재는 하나의 사회적 현상(social phenomenon)이라는 점을 강조했으며, 그것이 항상 두 가지 측면을 지닌다는 점에 주의를 기울여야 한다고 말했다. 하나는 규칙의 자발적 수용(voluntary acceptance of rules)에 내재된 태도와 행위이고, 다른 하나는 단순한 복종(obedience)이나 묵인(acquiescence)에 따른 보다 단순한 형태의 태도와 행위이다.

따라서 법을 갖춘 사회는, 그 규칙들을 단지 불복종할 경우 공무원에게서 어떤 처벌이 닥칠지를 예측하게 해주는 신뢰할 만한 지표로만 여기는 것이 아니라, 행위의 기준으로 수용된 규범(accepted standards of behaviour)으로, 즉 내적 관점(internal point of view)에서 바라보는 사람들을 포함한다. 그러나 동시에 그러한 사회는, 범법자(malefactors)이거나 단순히 그 체계의 무력한 희생자인 사람들처럼, 이러한 법적 규범들이 오직 물리적 강제력 또는 그 위협을 통해 부과되어야만 하는 이들도 포함한다. 이들은 그러한 규칙들을 가능한 처벌의 원천으로만 인식한다. 이 두 부류 사이의 균형은 (p. 202) 다양한 요소들에 의해 결정된다. 만약 그 체계가 공정하고, 순응(compliance)을 요구하는 모든 이들의

중대한 이해관계(vital interests)를 진정성 있게 고려한다면, 그것은 대부분의 사람들에게 대부분의 시간 동안 충성을 얻고 유지할 수 있으며, 결과적으로 안정적인 체계가 될 수 있다. 반대로, 법 체계가 지배 집단의 이익에만 복무하는 협소하고 배타적인 것이라면, 그 체계는 점점 더 억압적이며 불안정해질 것이고, 잠재된 격변의 위협 아래 놓이게 될 것이다. 이 두 극단 사이에는 다양한 법에 대한 태도 조합들이 존재하며, 종종 하나의 개인 내부에도 이러한 이중성이 공존한다.

이 측면에 대한 성찰은 다음과 같은 경각심을 주는 사실을 드러낸다. 즉, 의무 규칙(primary rules of obligation)만으로 구성된 단순한 형태의 사회에서, 중앙 조직화된 입법부, 법원, 공무원, 그리고 제재(sanctions)를 갖춘 법적 체계로 이행하는 과정은, 실질적인 이익을 수반하지만 일정한 대가도 따른다는 점이다. 그 이익은 변화에의 적응력, 확실성, 효율성이라는 점에서 막대하지만, 그 대가는 다음과 같은 위험이다. 즉, 중앙 집권적 권력이, 더 이상 그들의 지지를 필요로 하지 않는 다수의 사람들을 억압하는 데 사용될 수 있다는 것이다. 이런 방식의 억압은, 1차 규칙들로만 이루어진 단순한 체계에서는 일어나기 어렵다. 이러한 위험이 과거에 실현되었고 앞으로도 그러할 수 있기 때문에, 자연법(Natural Law)의 최소 내용(minimum content)으로 제시된 수준을 넘어서서 법이 도덕에 반드시 부합해야 한다(must conform)는 주장은 매우 신중하게 검토되어야 한다. 이러한 주장들 중 다수는, 법과 도덕의 연결이 필연적(necessary)이라고 말할 때 그것이 어떤 의미인지 명확히 제시하지 않으며, 혹은 그 내용을 분석해 보면, 그것이 진실하고 중요하긴 하지만, 그것을 법과 도덕 사이의 필연적 연결로 표현하는 것은 오히려 혼란을 초래한다. 우리는 이 장을 마무리하면서, 그러한 주장 형태의 여섯 가지를 검토할 것이다.

- (i) 권력과 권위 (Power and authority) 법 체계는 단순히 인간이 인간을 지배하는 힘에 근거할 수 없고 또한 그래서는 안 되므로, 반드시 도덕적 의무감(moral obligation)이나 법체계의 도덕적 가치에 대한 확신(conviction)에 근거해야 한다는 주장이 자주 제기된다. 우리는 이 책의 앞선 장들에서, 단순히 위협에 의해 뒷받침되는 명령(orders backed by threats)과

복종의 습관(habits of obedience)만으로는 법체계의 기초와 법적 유효성(legal validity)이라는 개념을 설명하기에 불충분하다는 점을 강조하였다. 우리는 (p. 203) 제6장에서 논증한 바와 같이, 이러한 개념들을 이해하려면 수용된 승인 규칙(accepted rule of recognition)의 개념이 반드시 필요하며, 본 장에서 본 것처럼, 강제력의 존재 조건은 적어도 일부 사람들이 자발적으로 그 체계에 협력하고, 그 규칙들을 수용(acceptance)하는 것이다. 이 의미에서, 법의 강제력은 그것의 수용된 권위(accepted authority)를 전제로 한다는 것은 사실이다. 그러나 ‘단지 권력에 기반한 법’과 ‘도덕적으로 구속력을 가지는 것으로 받아들여진 법’이라는 이분법(dichotomy)은 포괄적인 구분이 아니다. 매우 많은 수의 사람들이, 그들이 도덕적으로 구속력을 가진다고 생각하지 않는 법에 의해 강제될 수 있으며, 자발적으로 법 체계를 수용하는 이들조차도 반드시 스스로를 도덕적으로 구속받는 존재라고 인식해야 하는 것은 아니다. 물론 그들이 그렇게 인식할 때 가장 안정적인 체계가 될 것이다. 사실, 사람들이 그 체계에 대한 충성(allegiance)을 보이는 이유는 다음과 같이 다양할 수 있다. 장기적 이익에 대한 계산, 타인에 대한 무관심하지 않은 관심(disinterested interest), 반성 없는 전통적 태도, 혹은 단지 타인들이 그렇게 하기에 그에 따르려는 욕망 등이다. 법체계의 권위를 수용하는 이들이 양심을 살펴본 끝에, 도덕적으로는 이를 받아들여서는 안 된다고 판단하면서도, 다양한 이유로 여전히 수용을 지속할 수도 있는 것이다.

이러한 상식적인 사실들이 종종 모호해지는 이유는, 사람들이 법적 의무(legal obligation)와 도덕적 의무(moral obligation)를 동일한 어휘로 표현하기 때문이다. 법체계의 권위를 수용하는 이들은 법을 내적 관점(internal point of view)에서 바라보며, 법이 요구하는 바를 다음과 같은 규범적 언어로 표현한다. 이 규범적 언어는 법과 도덕 모두에서 공유되는 것이다.: “나는/너는 ~~해야 한다(I/You ought)”, “나는/그는 ~~해야만 한다(I/he must)”, “나는/그들은 의무를 지닌다(I/they have an obligation).” 그러나 그들은 이러한 표현을 통해, 법이 요구하는 바를 실천하는 것이 도덕적으로 정당하다는 도덕적 판단에 전념하고

있는 것은 아니다. 물론 아무런 부가 설명이 없다면, 어떤 사람이 자신 또는 타인의 법적 의무를 이렇게 표현할 경우, 그것을 이행하는 데 반대할 도덕적 또는 기타 이유가 없다고 생각한다는 추정(presumption)이 가능할 것이다. 그러나 이로부터, 어떤 사항이 법적으로 유효한 의무(legally obligatory)로 인정되기 위해서는 반드시 도덕적으로도 의무적(morally obligatory)으로 수용되어야 한다는 결론이 도출되는 것은 아니다. 우리가 말한 이 추정은, 어떤 사람이 법적 의무를 인정하거나 언급하는 것이, 만약 그가 그것을 이행해서는 안 된다고 여기는 확고한 도덕적 혹은 다른 이유를 가지고 있다면 무의미할 것이라는 점에 기초한 것이다.

- (ii) 도덕이 법에 미치는 영향 (The influence of morality on law) 모든 현대 국가의 법은 (p. 204) 수많은 지점에서, 통용되는 사회적 도덕(social morality)과 보다 보편적인 도덕적 이상(moral ideals)의 영향을 보여준다. 이러한 영향은 입법을 통해 갑작스럽고 공공연하게 법 안으로 들어오기도 하고, 사법절차를 통해 조용히 점진적으로 스며들기도 한다. 어떤 체계들, 예컨대 미국의 경우에는, 법적 유효성(legal validity)의 궁극적 기준에 정의(justice)나 실질적 도덕 가치(substantive moral values)가 명시적으로 포함되어 있다. 반면 영국과 같은 체계에서는, 최고 입법기관의 입법권에 공식적인 제한이 없음에도 불구하고, 그 입법은 정의나 도덕에 대한 신중한 부합(conformity)을 결코 덜 요구하지 않는다. 법이 도덕을 반영하는 추가적인 방식들은 무수히 많으며, 아직 충분히 연구되지 않았다. 예컨대, 어떤 법률 조항은 단지 법적 외피(legal shell)에 불과하고, 그 조항의 명문 자체가 도덕적 원칙의 도움을 통해 내용을 보완할 것을 요구하기도 한다. 집행 가능한 계약(enforceable contracts)의 범위는 도덕성과 공정성(fairness)의 개념에 따라 제한될 수 있으며, 민사 및 형사상 불법행위에 대한 책임(liability)은 지배적인 도덕적 책임관(moral responsibility)의 관념에 따라 조정되기도 한다. 어떤 실증주의자(positivist)도 이러한 사실들—즉, 법체계의 안정성(stability)은 이와 같은 도덕과의 대응 유형에 부분적으로 의존한다는 사실—을 부인할 수는 없다. 만약 이것이 법과

도덕 사이의 필연적 연결(necessary connection)을 의미하는 것이라면, 그 존재는 인정되어야 한다.

- (iii) 해석 (Interpretation) 법은 구체적 사안에 적용되기 위해서는 해석이 요구되며, 사법 절차(judicial processes)의 본질을 흐리는 신화를 현실적 연구로 제거하면, 법의 개방적 직조(open texture)가 창의적 활동의 광대한 영역을 남긴다는 점이 분명해진다. 이러한 창의적 활동은 일부에서 입법적(legislative)이라 불리기도 한다. 선례(precedent)나 성문법(statute)을 해석함에 있어, 판사들은 맹목적이고 자의적인 선택이나, 사전에 고정된 의미를 갖는 규칙들로부터의 ‘기계적 연역’(mechanical deduction) 사이에만 갇혀 있는 것이 아니다. 종종 그들의 선택은 해석 대상 규칙의 목적이 합리적일 것이라는 가정에 의해 이끌린다. 즉, 해당 규칙들은 부정의를 야기하거나 정착된 도덕 원칙(settled moral principles)을 침해하도록 설계된 것이 아니라는 전제이다. 특히 고도의 헌법적 중요성(high constitutional import)이 있는 사안에서의 사법적 판단(judicial decision)은, 하나의 도덕 원칙의 단순한 적용이 아니라, 상이한 도덕적 가치들 사이의 선택을 수반하는 경우가 많다. 법의 의미가 불확실한 상황에서, 도덕이 항상 명확한 해답을 제공한다고 믿는 것은 어리석은 일이다. 이 지점에서 판사들은 다시금 자의적이지도, 기계적이지도 않은 선택을 할 수 있으며, 바로 여기에서 종종 (p. 205) 판사 고유의 미덕(judicial virtues)이 드러난다. 이러한 미덕들이 법적 판단에 적합한 이유는, 이와 같은 활동을 단순히 ‘입법’이라 부르기를 주저하게 만드는 이유이기도 하다. 이러한 미덕에는 다음이 포함된다: 대안들을 고찰함에 있어의 공정성과 중립성(impartiality and neutrality), 영향을 받게 될 모든 이들의 이익에 대한 고려, 그리고 수용 가능한 일반 원칙을 근거 있는 결정의 기반으로 삼고자 하는 노력이다. 물론 항상 다양한 원칙들이 존재 가능하기 때문에, 어떤 결정이 유일하게 옳다는 것을 증명(demonstrate)할 수는 없지만, 그것은 정보에 기초한 공정한 선택의 이성적 산물(reasoned product)로서 수용될 수 있다. 이 모든 과정에서 우리는 경쟁하는 이해관계들 간의

정의 실현을 위한 ‘저울질’(weighing)과 ‘균형 조정’(balancing)의 과정을 보게 된다.

이러한 요소들은, 결정을 수용 가능하게 만드는 데 있어 도덕적(moral)이라 불릴 수 있으며, 그것들의 중요성은 거의 누구도 부인하지 않을 것이다. 대부분의 법체계에서 해석을 지배하는 느슨하고 변화 가능한 전통 혹은 해석 규범(canon of interpretation) 역시 이러한 요소들을 대체로 모호하게나마 포함하고 있다. 그러나 이러한 사실들이 법과 도덕 사이의 필연적 연결(necessary connection)을 입증하는 증거로 제시될 경우, 우리는 다음 사실을 기억해야 한다. 즉, 동일한 원칙들이 지켜지는 경우만큼이나 위반되는 경우에도 거의 동일하게 ‘존중’되어 왔다는 점이다. 오스틴(Austin) 이후 오늘날에 이르기까지, 이러한 요소들이 판단을 이끌어야 한다(should)고 주장해 온 이들은, 법관의 법형성(judicial law-making)이 종종 사회적 가치에 대해 맹목적이거나, ‘자동적’이거나, 이성적 근거가 부족하다는 점을 지적한 비판자들이었다.

(iv) 법에 대한 비판 (The criticism of law) 때로 법과 도덕 사이의 필연적 연결이 존재한다는 주장은, 단지 “좋은(good) 법체계는 정의와 도덕의 요구에 일정한 지점에서 부합(conform)해야 한다”는 주장에 불과하기도 하다. 앞 단락에서 언급한 바와 같은 지점들에서 말이다. 일부 사람들은 이것을 자명한 상식(truism)으로 간주할지도 모르지만, 그것은 동어반복(tautology)은 아니다. 실제로 법에 대한 비판 과정에서는, 어떤 도덕적 기준이 적절한지, 그리고 어떤 지점에서의 부합이 요구되는지를 둘러싸고 의견 차이가 있을 수 있다. 즉, 법이 부합해야 할 도덕(morality)이란 해당 집단 내에서 수용된 통념적 도덕인가? 설령 그것이 미신에 기초하거나, 노예나 피지배 계층에게 이익과 보호를 부여하지 않는 경우일지라도? 아니면, 도덕이란 사실에 대한 이성적 믿음에 기초하고, 모든 인간이 동등한 고려와 존중을 받을 자격이 있다고 인정하는 의미에서 계몽된(enlightened) 기준인가?

(p. 206) ‘법체계는 그 적용 대상인 모든 인간을 일정한 기본적 보호와 자유의 수혜자로 대우해야 한다’는 주장은, 오늘날 법 비판에서 자명하고도 중요한

이상(ideal)으로 일반적으로 받아들여지고 있다. 실제 실천이 이를 따르지 않더라도, 이 이상에 대한 형식적 동의(lip service)는 통상적으로 제공된다. 심지어 모든 인간이 동등한 고려의 권리를 갖는다는 견해를 수용하지 않는 도덕 이론은, 철학적으로 내적 모순, 독단성, 혹은 비이성성을 내포하고 있음이 논증될 수도 있다. 만약 그렇다면, 이러한 권리를 인정하는 계몽된 도덕(enlightened morality)은 진정한 도덕(true morality)으로서 특별한 정당성(credentials)을 가지며, 단지 가능한 여러 도덕 중 하나가 아니다. 이러한 주장은 여기서 검토할 수 없지만, 비록 이들이 받아들여지더라도, 그 사실은 다음의 사실을 바꾸거나 흐리게 해서는 안 된다. 즉, 기본 규칙(primary rules)과 2차 규칙(secondary rules)의 구조를 특징으로 하는 국내 법체계(municipal legal systems)는, 이러한 정의의 원칙들을 무시하면서도 오랫동안 지속되어 왔다는 점이다. 부정의한 규칙(iniquitous rules)을 ‘법’으로 인정하지 않음으로써 무엇을 얻게 되는지에 대한 논의는, 이후에서 다룬다.

- (v) 법다움과 정의의 원칙들 (Principles of legality and justice) 도덕성과 정의에 일정한 지점에서 부합하는(conform) 좋은 법체계와 그렇지 않은 법체계 사이의 구분은, 인간 행위가 일반 규칙에 의해 공공연히 공표되고 사법적으로 적용되는 방식으로 통제되는 한, 정의의 최소한이 필연적으로 실현된다는 이유에서, 오류를 포함한 구분이라고 말할 수도 있다. 실제로 우리는 이미 정의(justice)의 개념을 분석하면서³⁰, 그 가장 단순한 형태인 ‘법의 적용에서의 정의’(justice in the application of the law)가 단지 “서로 다른 많은 사람들에게 적용되어야 할 것이 동일한 일반 규칙(general rule)”이라는 생각을 편견, 이해관계, 또는 변덕에 휘둘리지 않고 진지하게 받아들이는 것에 지나지 않음을 지적한 바 있다. 이러한 공정성(impartiality)은, 영어 및 미국 법률가들이 ‘자연적 정의’(Natural Justice)의 원칙들로 알고 있는 절차적 기준(procedural standards)이 보장하고자 하는 바로 그 요소이다. 따라서 가장 혐오스러운 법률조차도 정당하게 적용될 수 있으며, 일반 법규칙을 적용한다는 그 자체의 최소한의 관념

³⁰p. 160 above.

속에는 적어도 정의의 씨앗(germ of justice)이 존재한다고 할 수 있다.

이러한 정의의 최소 형태, 곧 ‘자연적’(natural)이라 불릴 수 있는 양상들은, 실제로 (p. 207) 어떤 형태의 사회 통제가 작동하려면 어떤 조건들이 전제되어야 하는지를 살펴볼 때 드러난다. 이는 게임의 규칙이든 법이든, 기본적으로는 일반적인 행위 기준(general standards of conduct)을 사람들의 특정 집단에 전달하고, 그 집단이 추가적인 공식 지시 없이 그것을 이해하고 준수(conformity)할 것을 기대하는 방식의 통제이다. 이러한 유형의 사회 통제가 기능하기 위해서는, 규칙은 다음의 조건을 충족해야 한다: 이해 가능해야 하며(intelligible), 대부분의 사람들이 준수할 수 있어야 하고, 일반적으로는 소급 적용(retrospective)이 되어서는 안 된다. 예외적으로만 가능하다. 이 말은, 규칙 위반으로 처벌받는 사람들은 대부분 그것을 준수할 능력과 기회를 가지고 있었다는 것을 의미한다. 명백히 이러한 규칙에 의한 통제의 특징들은, 법률가들이 법다움의 원칙(principles of legality)이라 부르는 정의의 요구사항들과 밀접히 관련되어 있다. 실제로 어떤 실증주의 비판자는, 이러한 규칙에 의한 통제의 양상들 속에서 법과 도덕 사이의 필연적 연결(necessary connection)의 의미를 찾았고, 그것을 ‘법의 내적 도덕성’(the inner morality of law)이라 불려야 한다고 제안하기도 했다. 다시 말해, 만약 이것이 법과 도덕의 필연적 연결이라는 것이 의미하는 바라면, 우리는 그것을 수용할 수도 있다. 그러나 유감스럽게도, 그것은 극심한 부정의(iniquity)와도 양립할 수 있다.

(vi) 법적 유효성(legal validity)과 법에 대한 저항 그들의 일반적 관점을 다소 조심성 없이 제시했다고 하더라도, 실증주의자로 분류되는 법이론가들 중 소수가 아닌 이들이 앞의 다섯 항목에서 논의한 법과 도덕 사이의 연결 양태들을 부정하고자 했던 것은 아니다. 그렇다면, 법실증주의의 유명한 구호들이 지향했던 바는 무엇인가? 예컨대, “법의 존재는 한 가지 문제고, 그 가치 여부는 또 다른 문제다.”³¹; “국가의 법은 이상이 아니라 실제로 존재하는 것이다 … 그것은 되어야 할 것이 아니라, 있는 그대로

³¹Austin, The Province of Jurisprudence Defined, Lecture V, pp. 184–5.

의 것이다.”³²; “법규범(legal norms)은 어떠한 내용(content)도 가질 수 있다.”³³

이러한 사상가들이 주로 옹호하고자 했던 것은, 도덕적으로 부정의하더라도 적법한 형식으로 제정되었고, 의미가 명확하며, 해당 법체계의 모든 인정된 유효성(validity) 기준을 충족하는 특정 법률의 존재가 제기하는 이론적 및 도덕적 문제들을 명료하고 정직하게 서술하려는 시도였다. 그들의 입장은, 이러한 법률에 대해 고찰할 때, 이론가든 그 법률을 적용하거나 준수해야 하는 공무원 또는 시민이든 간에, (p. 208) 그것을 ‘법’ 또는 ‘유효한 법’이라는 명칭으로 부르지 말라는 초대에는 혼란만을 야기할 것이라는 것이었다. 그들은, 이 문제에 직면할 때, 더 단순하고 더 솔직한 방법들이 있으며, 그것이 관련된 모든 지적·도덕적 고려사항들을 더 명확히 조명해 줄 것이라고 생각했다. 즉 우리는 “이것은 법이다. 그러나 그것은 너무나 부정의하여 적용하거나 복종할 수 없다”라고 말해야 한다는 것이다.

이에 반대되는 입장은, 혁명이나 대규모 정치적 격변 이후에, 법원이 이전 체제하에서 공무원이나 민간인이 법 형식을 통해 저지른 도덕적 불의에 대해 어떤 태도를 취할지를 고찰해야 할 때, 매력적으로 보이기도 한다. 이들의 처벌은 사회적으로 바람직하게 느껴질 수 있으나, 그것을 달성하기 위해서는, 과거 체제 하에서 허용되거나 심지어 요구되었던 행위를 소급적으로 범죄화하는 입법이 필요하며, 이는 실현이 어렵거나, 스스로 도덕적으로 혐오스럽거나, 실행 불가능할 수도 있다. 이러한 상황에서, 법적 어휘 속에 잠재된 도덕적 함의들을 활용하는 것이 자연스럽게 보일 수도 있다. 특히 *ius*, *recht*, *diritto*, *droit*와 같은 단어들은 자연법(Natural Law)의 이론으로 충만한 용어들이므로 더욱 그러하다. 이 경우, 부정의를 명령하거나 허용했던 법률들은, 비록 그것들이 제정된 법체계가 입법권에 대한 어떠한 제한도 인정하지 않았더라도, 유효(valid)하거나 법의 성격(quality of law)을 갖는 것으로 인정되어서는 안 된다(recognized)는 주장을 하게 되는 유혹에 빠지기 쉽다. 이러한 형태로, 제 2차 세계대전 이후 독일에서는 나치 정권의 부정의와 그 패배로 인해 남겨진

³²Gray, *The Nature and Sources of the Law*, s. 213.

³³Kelsen, *General Theory of Law and State*, p. 113.

첨예한 사회 문제들에 대응하기 위해 자연법 논증들이 부활했다. 이기적 목적을 위해 괴물 같은 법령에 따른 범죄로 타인을 투옥시킨 밀고자들은 처벌받아야 하는가? 그러한 법령들이 자연법을 위반했기 때문에 무효(void)이며, 그로 인해 그 법령을 위반한 것에 따른 투옥은 실질적으로 불법(unlawful)이었고, 그것을 야기한 행위는 그 자체로 범죄였다고 하여, 전후 독일 법정에서 그들을 유죄로 판단할 수 있었는가?³⁴ 이처럼 (p. 209) “도덕적으로 부정의한 규칙은 법이 될 수 없다”는 견해를 받아들이는 입장과 거부하는 입장 사이의 논쟁은 표면상 간단해 보이지만, 그 일반적 성격에 대한 이해는 종종 불분명하다. 여기서 문제되는 것은, 도덕적으로 부정의한 규칙을 적용하거나, 복종하거나, 타인이 그것을 항변하는 것을 허용하지 않겠다는 도덕적 결정을 표현하는 대안적 방식들 간의 차이이다. 그러나 이 문제는 단순히 언어적 표현에 관한 문제로 제시될 수는 없다. 논쟁의 양측 누구도, 단순히 “당신 말이 맞습니다. 당신이 주장한 바는 영어(또는 독일어)에서 그 종류의 주장을 표현하는 올바른 방식입니다”라는 답변에 만족하지 않을 것이다. 따라서 실증주의자는 다음과 같이 주장할 수도 있다. 즉, 영어 사용 관행에 비추어 보아, “어떤 법규칙이 너무나 부정의하여 복종할 수 없다”고 주장하는 데에는 모순이 없으며, “그 규칙에 복종할 수 없다”는 명제가 “그 규칙은 유효한 법규칙이 아니다”는 결론으로 이어지는 것은 아니라고 주장할 수 있다. 그러나 그 반대편에 선 이들은 이 주장으로 인해 논쟁이 종결되었다고 보지는 않을 것이다.

명백히, 우리는 이 문제를 언어 사용의 적절성(propriety)에 관한 것으로만 본다면, 그것을 충분히 다룰 수 없다. 진정으로 문제가 되는 것은, 사회생활에서 일반적으로 효과적으로 작동하는 하나의 규칙 체계에 속한 규칙들을 분류하는 방식으로서의 넓은 개념과 좁은 개념, 즉 경쟁하는 두 규범 개념들 중 어느 것이 이론적 탐구나 도덕적 숙고—혹은 그 둘 모두—를 더 잘 보조하는지에 따라 선택되어야 한다는 점이다.

³⁴See the judgment of 27 July 1949, Oberlandesgericht Bamberg, 5 Süddeutsche Juristen-Zeitung, 207: discussed at length in H. L. A. Hart, ‘Legal Positivism and the Separation of Law and Morals’, in 71. Harvard L. Rev. (1958), 598, and in L. Fuller, ‘Positivism and Fidelity to Law’, *ibid.*, p. 630. But note corrected account of this judgment below, pp. 303–4.

이 두 경쟁 개념 중에서 더 넓은 개념은 좁은 개념을 포함한다. 더 넓은 개념을 채택할 경우, 우리는 이론적 탐구에서 다음과 같은 방식을 취하게 된다: 일차적(primary) 및 이차적(secondary) 규칙의 체계가 제시하는 형식적 기준에 따라 유효(valid) 한 모든 규칙들을—비록 그 일부가 특정 사회의 도덕성이나 우리가 진정한 도덕성 또는 계몽된 도덕성이라 여기는 것에 어긋나더라도—‘법’(law)으로 묶어 함께 고찰하게 된다. 반면, 좁은 개념을 채택하면 그러한 도덕적으로 불의한 규칙들은 ‘법’의 범주에서 제외된다. 그러나 이처럼 좁은 개념을 채택하는 것은, 법을 사회적 현상으로 연구하는 이론적·과학적 탐구에 있어서 아무런 이익도 가져다주지 않는 듯하다. 왜냐하면 이는 비록 법의 복잡한 특징들을 모두 갖추었더라도, 특정 규칙들을 법에서 배제하게 되기 때문이다. 이러한 규칙들을 다른 학문 분야로 넘기자는 제안에서 비롯될 수 있는 것은 오직 혼란뿐이며, 실제로 그 어떤 역사적 연구나 법학의 다른 분과도 이러한 시도를 유익하다고 판단하지 않았다. 반면 넓은 개념의 법 개념을 채택하면, (p. 210) 우리는 도덕적으로 불의한 법이 지니는 특수한 성격들과 사회가 그것에 보이는 반응까지 포함하여 포괄적으로 연구할 수 있다. 따라서 좁은 개념을 사용할 경우, 일차·이차 규칙 체계에서 구현되는 사회통제의 특정 방식이 어떻게 발전하고 어떤 가능성을 지니는지를 이해하려는 우리의 노력은 혼란스럽게 분열될 수밖에 없다. 그것의 사용에 대한 연구는 필연적으로 그것의 오용(misuse)에 대한 연구를 포함해야 하기 때문이다.

그렇다면 좁은 개념이 도덕적 숙고에 있어 가지는 실천적 유익성은 무엇인가? 도덕적으로 부정의한 요구에 직면했을 때, ‘이것은 어떤 의미에서도 법이 아니다’라고 판단하는 것이 ‘이것은 법이지만 너무 부정의하여 복종하거나 적용할 수 없다’라고 판단하는 것보다 나은가? 이 판단은 사람들을 더 명료하게 만들거나, 도덕이 요구할 때 더 쉽게 불복종하도록 만들 것인가? 혹은 나치 정권이 남긴 문제들을 더 나은 방식으로 처리하게 할 것인가? 물론 사상은 영향력을 가진다. 그러나 도덕적으로 부정의하지만 유효(valid) 한 법이 존재할 수 없다는 좁은 법적 유효성(validity) 개념을 사람들에게 교육하고 훈련시키는 노력이, 조직화된 권력의 위협에 직면하여 악에 저항하는 의지를 강화시키거나, 복종이 요구될 때 도덕적으로 어떤 문제가 제기되는지를 더 명확하게 인식하게

만들 것이라 보기는 어렵다. 인간이 일부의 협조를 통해 타인을 지배할 수 있는 한, 그들은 법의 형식(form)을 그 수단 중 하나로 사용할 것이다. 사악한 자들은 사악한 규칙을 제정하고, 다른 자들은 그것을 집행할 것이다. 이러한 권력의 공식적 남용에 맞서 사람들을 명확하게 인식하게 만들기 위해 무엇보다 필요한 것은, 어떤 규칙이 법적으로 유효하다고 인증(certification)되었다는 사실이 복종의 문제를 최종적으로 해결하는 것은 아니라는 점을 인식하는 것이다. 그리고 공식적 체계가 아무리 위엄이나 권위를 띠더라도, 그 요구는 결국 도덕적 심판(moral scrutiny)에 복종되어야 한다는 점을 자각하는 것이다. 이러한 감각—곧 공식적 체계 밖에 어떤 기준이 존재하며, 개인은 최종적으로 그것에 의거해 복종의 문제를 해결해야 한다는 인식—은 법규칙이 부정의할 수 있다(may be iniquitous)는 사고에 익숙한 사람들 사이에서 훨씬 더 생생히 유지될 가능성이 크다. 반면, 어떤 부정의한 것도 결코 법의 지위를 가질 수 없다고 생각하는 사람들 사이에서는 그렇지 않다.

그러나 우리가 ‘이것은 법이지만 부정의하다’라고 사고하고 표현할 수 있게 해주는 법의 넓은 개념을 선호해야 할 더 강력한 이유는 따로 있다. (p. 211) 그것은 부정의한 규칙에 대해 법적 인정을 거부함으로써, 그것이 초래하는 도덕적 문제들의 다양성과 복잡성을 지나치게 단순화할 위험이 있기 때문이다. 벤담(Bentham)과 오스틴(Austin)과 같은 고전 이론가들은 ‘법이란 무엇인가’와 ‘법은 어떻게 되어야 하는가’ 사이의 구분을 강조했는데, 이는 사람들이 이 구분을 유지하지 않으면, 사회에 어떤 대가가 따르든 무시한 채 법이 유효하지 않다고 성급히 판단하고 복종하지 않으려 할 수 있기 때문이었다. 이러한 무정부 상태의 위험은 그들이 과대평가했을 수도 있으나, 또 다른 형태의 과도한 단순화도 있다. 만약 우리가 관점을 좁혀 ‘악한 규칙에 복종(obey)해야 하는 사람’만을 고려한다면, 그가 그것이 ‘법’이라는 유효한 규칙인지 아닌지를 어떻게 인식하든, 도덕적 부정의를 인식하고 도덕이 요구하는 대로 행동한다면 그것은 무관하다고 판단할 수도 있다. 그러나 ‘복종’이라는 도덕적 문제(“내가 이 부정의한 일을 해야 하는가?”) 외에도, 소크라테스가 던진 문제—“불복종에 대한 처벌을 감수해야 하는가, 아니면 탈출해야 하는가?”—가 있으며, 또한 전후 독일 법원이 마주했던 질문—“당시 시행 중이던 부정의한 규칙들이 허용한 악행을 저지른

자들을 우리는 처벌해야 하는가?”—도 존재한다. 이러한 질문들은 서로 매우 다른 도덕적·정의적 문제들을 제기하며, 각각 독립적으로 고려되어야 한다. 그 어떤 목적을 위해서도 부정의한 법률을 유효하다고 인정하지 않겠다(refuse to recognize)는 일회적 선언으로 해결될 수 없다. 이것은 복잡하고 미묘한 도덕적 문제들에 대해 지나치게 거친 접근 방식이다.

법의 유효성(validity)을 그 도덕성(morality)으로부터 구별할 수 있도록 해주는 법 개념은, 이처럼 서로 다른 문제들의 복잡성과 다양성을 인식할 수 있게 한다. 반면, 부정의한 규칙은 결코 법적으로 유효할 수 없다고 주장하는 좁은 법 개념은, 오히려 이러한 문제들을 가리는 역할을 할 수도 있다. 독일의 밀고자들이 이기적인 동기에서 괴물 같은 법 아래에서 타인을 처벌받게 한 것이 도덕적으로 잘못된 일임은 분명하지만, 동시에 도덕은 국가가 오직, 그 당시 법이 금한 악행을 저지른 사람만을 처벌해야 한다고 요구할 수도 있다. 이것이 바로 ‘법 없이는 형벌도 없다’(nulla poena sine lege)라는 원칙이다. 만약 이 원칙을 희생하지 않고서는 더 큰 악을 피할 수 없다면, 그 희생이 정당화되는 조건들이 명확히 규정되어야 한다. 소급 처벌의 사례가, 마치 당시 이미 불법이었던 행위에 대한 처벌인 것처럼 보이게 해서는 안 된다. (p. 212) 실증주의적 간명한 입장이, 즉 ‘도덕적으로 부정의한 규칙들도 여전히 법일 수 있다’는 주장이 가지는 최소한의 의미는 바로 이것이다. 그것은 극단적 상황에서 악 중의 선택(choice between evils)이 불가피할 때, 그 선택을 덮거나 위장하지 않는다는 점이다.

CHAPTER IX 주석

185쪽. 자연법(Natural Law). 고전적·스콜라철학적·근대적 자연법 개념과 ‘실증주의(positivism)’라는 표현의 다의성에 대한 방대한 주석 문헌이 존재하는 탓에, 자연법(Natural Law)이 법실증주의(Legal Positivism)와 대립할 때 정확히 어떤 쟁점이 걸려 있는지를 파악하기 어려울 때가 많다. 본문에서는 그 중 하나의 쟁점을 식별하려는 시도를 한다. 그러나 이 주제를 논의함에 있어 이차 문헌만을 읽는다면 얻을 수 있는 것은 극히 제한적이다. 자연법의 1차 문헌들에 나타난 어휘와 철학적 전제들을 직접적으로 이해하는 것이 필수적이다. 다음은 쉽게 접근 가능한 최소한의 자료들이다: 아리스토텔레스(Aristotle), 『자연학(Physics)』 제2권 제8장 (Ross 역, Oxford); 아퀴나스(Aquinas), 『신학대전(Summa Theologica)』 제1-2부, 문제 90-97 (D’Entrèves, 『아퀴나스: 선별된 정치적 저작』(Aquinas: Selected Political Writings), Oxford, 1948에 번역 수록); 그로티우스(Grotius), 『전쟁과 평화의 법(On the Law of War and Peace)』, 서론(Prolegomena) (The Classics of International Law, 제3권, Oxford, 1925 수록 번역본); 블랙스톤(Blackstone), 『주석(Commentaries)』, 서론 제2절.

185쪽. 법실증주의(Legal Positivism). 현대 영미권 문헌에서 ‘실증주의(positivism)’라는 표현은 다음과 같은 하나 혹은 그 이상의 주장을 가리키는 데 사용된다: (1) 법은 인간에 의해 부과된 명령(command)이다; (2) 법과 도덕, 또는 존재하는 법(law as it is)과 마땅히 그래야 할 법(law as it ought to be) 사이에는 필연적 연결이 없다; (3) 법 개념의 의미를 분석하거나 연구하는 것은 역사적 탐구, 사회학적 탐구, 도덕·사회적 목적·기능에 따른 비판적 평가와는 구별되는 (그러나 적대적인 것이 아닌) 중요한 연구 분야이다; (4) 법체계는 ‘폐쇄된 논리 체계(closed logical system)’이며, 올바른 판결은 오직 미리 정해진 법규로부터 논리적 방법만으로 도출될 수 있다; (5) 도덕판단은 사실 명제(statements of fact)처럼 합리적 논변, 증거, 또는 입증을 통해 정립될 수 없다 (윤리적 비인지주의, non-cognitivism in ethics). 벤담(Bentham)과 오스틴(Austin)은 (1), (2), (3)의 견해를 지지했으나 (4), (5)는 지지하지 않았다. 켈젠(Kelsen)은 (2), (3), (5)를 수용했으나 (1), (4)는 수용하지 않았다. 주장 (4)는 흔히 ‘분석법학자(analytical jurists)’에게 귀속되곤 하지만, 이는 타당한 근거 없이 이루어진 것이다. 대륙 유럽 문헌에서는 ‘실증주의(positivism)’라는 표현이 흔히 이성에 의해서만 발견 가능한 인간 행위의 어떤 원칙이나 규칙의 존재를 전면적으로 부정하는 입장을 가리키는 데 사용된다. ‘실증주의’ 개념의 다의성에 대한 아고(Ago)의 유익한 논의는 *American Journal of International Law* 제51권(1957) 참조.

186쪽. 밀(Mill)의 자연법 비판. 『자연(Nature), 종교의 효용성, 유신론』에 수록된

“자연(Nature)” 에세이 참조.

187쪽. 블랙스톤과 벤담의 자연법에 대한 견해. 블랙스톤, 위 인용(loc. cit.); 벤담, 『주석에 대한 논평(Comment on the Commentaries)』 제1-6절.

193쪽. 자연법의 최소한의 내용. 자연법의 이 경험주의적 버전은 홉스(Hobbes), 『리바이어던(Leviathan)』 제14·15장과 흄(Hume), 『인성론(Treatise of Human Nature)』 제3권 제2부, 특히 제2절 및 제4-7절에 근거한다.

200쪽. 『허클베리 핀(Huckleberry Finn)』. 마크 트웨인(Mark Twain)의 이 소설은 사회적 도덕이 개인의 공감(sympathy)이나 인도주의(humanitarianism)에 반할 경우 발생하는 도덕적 딜레마에 대한 심오한 탐구다. 모든 도덕성을 인도주의와 동일시하는 경향에 대한 귀중한 반론이 된다.

200쪽. 노예제(Slavery). 아리스토텔레스에게 있어 노예는 ‘살아있는 도구’였다. (정치학(Politics) 제1권 제2-4장).

203쪽. 도덕성이 법에 미치는 영향. 법의 발전(development)이 도덕성에 의해 어떻게 영향을 받아왔는지를 다룬 유익한 연구들로는 에임스(Ames), “법과 도덕(Law and Morals)”, *Harvard Law Review* 제22권(1908); 파운드(Pound), 『법과 도덕(Law and Morals)』(1926); 굿하트(Goodhart), 『영국법과 도덕법(English Law and the Moral Law)』(1953) 등이 있다. 오스틴은 이와 같은 사실적 혹은 인과적 연관을 충분히 인식하고 있었다. 『법의 영역(The Province of Jurisprudence Determined)』 제5강, 162쪽 참조.

204쪽. 해석(Interpretation). 법 해석에서 도덕적 고려가 차지하는 위치에 대해서는 라몽(Lamont), 『가치판단(The Value Judgment)』 296-301쪽; 웨슬러(Wechsler), “헌법 해석의 중립 원칙을 향하여”, *Harvard Law Review* 제73권, 960쪽; 하트(Hart), 앞서 인용한 *HLR* 제71권, 606-615쪽 및 풀러(Fuller)의 비판, 동일호 661쪽 끝 부분(*ad fin.*) 참조. 오스틴의 ‘경쟁하는 유추(competing analogies)’ 사이에서 판사가 선택할 수 있는 여지를 인정된 부분과, 공리성의 기준에 그 판결이 부합하지 않는다는 비판은 『강의(The Lectures)』 제37·38강 참조.

205쪽. 법에 대한 비판과 모든 인간의 평등한 고려에 대한 권리. 이러한 권리가 단지 다양한 도덕성 중 하나에 속하는 것이 아니라 진정한 도덕성의 정의적 특징(*defining feature*)이라는 견해는 벤(Benn)과 피터스(Peters), 『사회 원칙과 민주국가(Social Principles and the Democratic State)』 제2·5장, 그리고 바이어(Baier), 『도덕적 관점(The Moral Point of View)』 제8장을 참조.

206쪽. 법다움과 정의의 원칙(*Principles of legality and justice*). 법다움 원칙에 대해서는 홀(Hall), 『형법의 원칙(Principles of Criminal Law)』 제1장을, ‘법의 내재적

도덕성(the internal morality of law)’에 대해서는 풀러(Fuller), *Harvard Law Review* 제 71권(1958), 644-648쪽 참조.

208쪽. 전후 독일에서의 자연법 이론의 부활. G. 라트브루흐(Radbruch)의 후기 견해, 하트(Hart), 그리고 이에 대한 풀러(Fuller)의 응답에 대한 논의는 모두 *HLR* 제71권(1958) 참조. 이 논의는 1949년 7월 바이에른주 고등법원(Oberlandsgericht Bamberg)의 판결을 중심으로 진행되었는데, 이 사건은 1934년 나치 법률 위반 혐의로 남편을 신고한 아내가 남편의 자유를 불법적으로 박탈한 혐의로 유죄 판결을 받은 사건이다. 이 사건에 대한 설명은 *HLR* 제64권(1951) 1005쪽에 기술된 것으로, 해당 법원이 1934년 법률을 무효로 판단했다는 전제에 따라 이루어진다. 그러나 이 설명의 정확성은 파페(Pappe)의 비판(“나치 시대의 사법판단의 유효성에 대하여”, *Modern Law Review* 제23권(1960))에 의해 최근에 도전받았다. 파페 박사의 비판은 정당하며, 하트가 논한 사례는 엄밀히 말하면 가상의 것으로 간주되어야 한다. 파페 박사에 따르면(위 저서, 263쪽), 실제 사건에서 항소법원은 법률이 자연법(Natural Law)을 위반한 경우 무효가 될 수 있다는 이론적 가능성을 받아들이면서도, 쟁점이 된 나치 법률이 이를 위반했다고 보지는 않았다. 피고는 정보를 제공할 의무(duty)가 없음에도, 순전히 사적 동기에서 그렇게 했으며, 그러한 행위가 ‘모든 양심 있는 인간의 건전한 양식과 정의감에 반하는 것임을 인식했음이 분명하다’는 이유로 불법적인 자유 박탈(unlawful deprivation of liberty) 혐의로 유죄 판결을 받았다. 파페 박사가 유사 사건에 대한 독일 연방대법원의 판결을 세밀하게 분석한 내용(268쪽 끝 부분)도 반드시 참고할 필요가 있다.

CHAPTER IX 제3판 주석

185-6쪽. 실증주의(Positivism)와 ‘분리 명제(separability thesis)’. 하트는 “법이 도덕의 특정 요구를 재현하거나 충족시키는 것이 필연적 진리인 것은 결코 아니다”라고 말한다. (홈즈 강연에서는 “법과 도덕 사이에는 필연적 연결이 없다”고 말한다: H. L. A. Hart, “Positivism and the Separation of Law and Morals” (1957) *Harvard Law Review* 제71권 593쪽, 601쪽 주석 25 참조.) 이 분리 명제(separability thesis)는 혼란스러운 개념인데, 그 이유 중 하나는 하트 자신이 법과 정의 사이의 규칙적 연관성(159-60쪽 주석 참조)과 최소한의 내용 명제(minimum content thesis)(193쪽 주석 참조)를 통해 두 가지 ‘필연적 연결’을 옹호하는 것처럼 보이기 때문이다. 이 난제를 정리하려는 다양한 시도로는 다음이 있다: John Gardner, 「Legal Positivism: 5½ Myths」, *Law as a Leap of Faith* 제2장; Matthew H. Kramer, 「On The Separability of Law and Morality」 (2004) *Canadian Journal of Law and Jurisprudence* 제17권 315쪽; James Morauta, 「Three

Separation Theses」(2004) *Law and Philosophy* 제23권 111쪽; Leslie Green, 「Positivism and the Inseparability of Law and Morals」(2008) *New York University Law Review* 제83권 1035쪽.

185-93쪽. 고전적 자연법 이론(*Classical theories of natural law*). 하트가 묘사한 견해의 후손 격이나 신토미즘적(*neothomist*) 성향이 가미된 입장으로는 John Finnis의 『Natural Law and Natural Rights』, Mark C. Murphy의 『Natural Law in Jurisprudence and Politics』(Cambridge University Press, 2006)이 있다. Nigel Simmonds의 『Law as a Moral Idea』(Oxford University Press, 2007)와 비교할 것. 자연법과 실증주의의 관계에 대해서는 John Finnis, 「The Truth in Legal Positivism」, 『Philosophy of Law』 제7장 참조. 자연법적 도덕 이론, 법 해석 이론, 자연법 법철학 이론 간의 (결여된) 관계에 대해서는 Philip Soper, 「Some Confusions about Natural Law」(1992) *Michigan Law Review* 제90권 2393쪽.

193-200쪽. ‘최소한의 내용’ 명제(*The ‘minimum content’ thesis*). 인간의 본성과 우리가 살아가는 세계를 고려할 때, 보편적으로 가치 있는 것들에 관한 최소한의 내용(*minimum content*)을 다루지 않는 규칙 체계는 어떤 경우에도 유효한 법체계(*legal system*)가 될 수 없다. 하트의 목록을 수정한 사례로는 Neil MacCormick, 『H. L. A. Hart』 92-99쪽, John Finnis, 『Natural Law and Natural Rights』 제4장 참조. 법의 필수적 내용에 대한 다른 접근은 Joseph Raz, 『Practical Reason and Norms』 162-170쪽 참조.

203쪽. 법과 도덕의 공유 어휘(*The shared vocabulary of law and morality*). ‘의무(*obligation*)’, ‘권리(*right*)’, ‘자유(*liberty*)’ 등의 개념이 법과 도덕에서 공통적으로 사용되는 이유에 대한 다른 설명은 Joseph Raz, 『The Authority of Law』 제8장 참조. 이에 대한 하트의 응답은 『Essays on Bentham』 153-161쪽에 실려 있다.

203-4쪽. 도덕의 법 내포(*The incorporation of morality in law*). 이 부분, 그리고 더 강조되는 후기(*Postscript*)에서 하트는 다음과 같이 말한다: “일부 법체계에서는 … 법적 유효성(*legal validity*)의 궁극적 기준이 정의 원칙이나 실질적 도덕 가치(*substantive moral values*)를 명시적으로 내포하고 있다.” 하트는 이를 ‘연성 실증주의(*soft positivism*)’라 부르지만, 현재는 일반적으로 ‘내포 명제(*incorporation thesis*)’ 또는 ‘포괄적 법실증주의(*inclusive legal positivism*)’라 불린다. 관련 문헌은 기술적으로 복잡할 수 있다. 훌륭한 개관으로는 K. E. Himma, 「Inclusive Legal Positivism」, Jules Coleman & Scott Shapiro 편, 『The Oxford Handbook of Jurisprudence and Philosophy of Law』 수록. 하트의 입장에 대한 비판은 Joseph Raz, 『The Authority of Law』 제3장, 『Between Authority and Interpretation』 제7장 참조. 포괄적 실증주의를 발전시킨 논

이론은 다음이 있다: Jules Coleman, 「Negative and Positive Positivism」 (1982) *Journal of Legal Studies* 제11권 139쪽; 『The Practice of Principle: In Defence of a Pragmatist Approach to Legal Theory』(Oxford University Press, 2001) 제8장; W. J. Waluchow, 『Inclusive Legal Positivism』(Oxford University Press, 1994). 드워킨(Dworkin)은 하트의 접근(Philip Soper와 David Lyons가 채택한 방식)을 『Taking Rights Seriously』 345-350쪽에서 비판하며, Coleman의 입장은 「Thirty Years On」 (2002) *Harvard Law Review* 제115권 1655쪽에서 비판한다.

206-7쪽. 법다움과 정의의 원칙(*Principles of legality and justice*). 론 풀러(Lon L. Fuller)의 논의가 영향력 있다: 『법의 도덕성(The Morality of Law)』(개정판, Yale University Press, 1969) 46-91쪽; 하트의 서평 「Lon L. Fuller, 'The Morality of Law」」는 『Essays in Jurisprudence and Philosophy』 제16장에 수록. 하트와 풀러 간 논쟁의 중요성에 대해서는 Peter Cane 편, 『The Hart-Fuller Debate: 50 Years On』(Hart Publishing, 2010) 수록 논문들 참조. 법치(rule of law)와 법의 본성 사이의 관계에 대해서는 Raz, 『The Authority of Law』 제11장 참조. 드워킨은 「Hart's Postscript and the Character of Political Philosophy」 (2004) *Oxford Journal of Legal Studies* 제24권 1, 23-37쪽에서 '법다움(legality)'이라는 가치에 기초하여 자신의 이론을 재구성한다.

207-12쪽. 법적 유효성과 법 저항(*Legal validity and resistance to law*). 정의를 확보하려는 최소한의 시도조차 하지 않는 법은 유효하지 않다(*invalid*)는 라드브루흐(Gustav Radbruch)의 논제를 현대적으로 계승한 사례로는 Robert Alexy, 『The Argument from Injustice: A Reply to Legal Positivism』(Bonnie L. Paulson & Stanley L. Paulson 번역, Oxford University Press, 2002). 법이 우리의 복종(obedience)을 요구할 수 있는 도덕적 정당성에 대해서는 다음 문헌 참조: Joseph Raz, 『The Authority of Law』 제12-15장; A. J. Simmons, 『Moral Principles and Political Obligations』(Princeton University Press, 1979); Leslie Green, 『The Authority of the State』; W. A. Edmundson, 『Three Anarchical Fallacies: An Essay on Political Authority』(Cambridge University Press, 1998).

208-12쪽. '광의의 법 개념(*broad concept of law*)'을 옹호하기. 하트는 실증주의적 법 개념이 "도덕적 숙고(moral deliberation)를 촉진하고 명확하게 할 수 있다"고 주장한다 (209쪽). 하트는 이 주장을 자신의 분석의 타당성(validity)을 증명하기 위한 필수 요소로 보지는 않으며, 부차적 고려이거나, 광의의 법 개념이 정치적으로 위험하다고 비판하는 사람들에 대한 응답으로 간주한다. 문헌에서는 법 개념(*the concept of law*)이 도덕적으로 바람직한 결과를 위해 조정되어야 한다는 주장과 법의 내용(*the content of the law*)이 도덕적으로 좋은 결과를 위해 조정되어야 한다는 주장 사이에 모호함이

존재한다 (예: 판사의 직무를 오직 근원적 자료(*source-based materials*) 적용에 한정하려는 시도 등). 비교 자료: Neil MacCormick, 「도덕주의적 법 비판, 비도덕주의적 법 옹호(A Moralistic Case for A-Moralistic Law)」 (1985) *Valparaiso Law Review* 제20권 1쪽; Thomas Campbell, 『윤리적 실증주의의 법이론(The Legal Theory of Ethical Positivism)』 (Dartmouth, 1996); Jeremy Waldron, 「규범적(또는 윤리적) 실증주의」, Jules Coleman 편, 『Hart's Postscript』; Liam Murphy, 「법 개념에 대한 정치적 물음」, 동일 저서 수록.

X. 국제법(INTERNATIONAL LAW)

1. 의심의 근원(SOURCES OF DOUBT)

본서에서 중요한 위치를 부여한 일차 규칙(primary rules)과 이차 규칙(secondary rules)의 결합이라는 개념은, 법이론 내 양극단 사이의 중용(median)으로 간주될 수 있다. 법이론은 종종 법을 이해하는 열쇠를 단순한 '명령과 그에 따른 위협(order backed by threats)'이라는 개념에서 찾으려 하거나, 반대로 도덕성(morality)이라는 복잡한 개념에서 찾으려 해왔다. 법은 이 두 개념 모두와 분명 여러 유사점과 연관성을 지니고 있지만, 우리가 살펴보았듯이, 이러한 연관성을 과장함으로써 법을 다른 사회통제 수단들과 구별하는 고유한 특성들을 가리는 위험이 항상 존재해 왔다. 우리가 중심적 개념으로 채택한 이 규칙의 결합 개념은, 법과 강제력(coercion), 도덕성 간의 복합적 관계를 있는 그대로 파악할 수 있게 해주며, 이러한 관계들이 과연 어떤 의미에서, 그리고 어떤 조건에서 필연적인 것인지 다시 숙고할 수 있도록 해주는 장점을 지닌다.

일차 규칙과 이차 규칙의 결합 개념이 이러한 장점을 지닌다는 점, 그리고 이 규칙 구조의 존재를 '법체계(legal system)'라는 표현이 적용될 수 있는 충분조건(sufficient condition)으로 다루는 것이 통상적인 용례(usage)와 부합한다는 점에도 불구하고, 우리는 '법(law)'이라는 단어가 반드시 이러한 개념으로 정의되어야 한다고 주장하지는 않았다. 우리는 '법(law)'이나 '법적(legal)'이라는 단어의 사용을 이 방식으로 식별하거나 규율해야 한다고 주장하지 않기에, 본서는 이 표현들의 사용을 위한 규칙(rule)이나 규칙들의 체계를 제시하려는 정의(definition)가 아니라, '법'이라는 개념(concept)에 대한 해명(elucidation)을 목표로 한다. 이러한 목적에 따라, 우리는 앞 장에서 독일의 판례들이 제기한 주장을 고찰하였다. 해당 판례들은, 비록 일정한 일차 및 이차 규칙 체계에 속해 있음에도 불구하고, 그 규칙들이 도덕적으로 부당하다는 이유로 '유효한(valid)' 법이라는 명칭을 부여받지 말아야 한다고 주장하였다. 우리는 궁극적으로 이 주장을 기각하였다. 그러나 그 이유는 그러한 규칙들이 그 체계에 속한다면 반드시 '법'으로 불려야 한다는 관점과 충돌하기 때문도 아니었고, 통례적 용

법과 상충하기 때문도 아니었다. (p. 214) 오히려 우리는, 도덕적으로 부당한 규칙들을 배제함으로써 유효한 법의 범위를 인위적으로 좁히려는 시도가 이론적 탐구나 도덕적 숙고의 진전에 기여하지 못한다고 비판하였다. 이러한 목적을 위해서는, 도덕적으로 부당하더라도 규칙을 법으로 간주할 수 있도록 해주는 보다 넓은 개념이 통례적 사용과도 부합하며, 검토 결과 충분히 적절하다는 것이 입증되었다.

국제법(international law)은 이와 반대의 경우를 제시한다. 지난 150년 동안의 용례에 따르면 국제법을 '법'이라 부르는 데 큰 무리는 없으나, 국제 입법기관(international legislature), 강제적 관할권을 지닌 법원(courts with compulsory jurisdiction), 중앙 조직화된 제재 기관(centrally organized sanctions)이 부재하다는 점은 법이론가들로 하여금 의문을 품게 하였다. 이러한 제도적 결핍은 국가간의 규칙들이, 개인 사회에서 발견되는 단순한 일차 의무 규칙(primary rules of obligation)의 형태와 유사하게 되며, 이는 우리가 발전된 법체제와 대비시키는 사회 구조의 원형이다. 우리가 이후에 보여줄 바와 같이, 국제법은 입법기관과 법원을 구성하는 이차 규칙들(change와 adjudication의 규칙)뿐 아니라, 법의 '근원(sources)'을 명시하고 그 규칙들을 식별할 수 있는 일반 기준을 제공하는 승인 규칙(rule of recognition)까지도 결여하고 있다는 주장이 가능하다. 이러한 차이점들은 매우 두드러지며, "국제법은 정말로 법인가?"라는 질문을 무시할 수 없게 만든다. 그러나 이 경우에도 우리는, 다수의 이들이 품는 의심을 단순히 기존 용례를 환기시켜 해소하려 하지도 않을 것이며, 일차 및 이차 규칙의 결합이 '법체제'라는 표현의 타당한 사용을 위한 필요충분조건(necessary and sufficient condition)이라는 전제 위에서 의심을 확인하지도 않을 것이다. 우리는 오히려, 그 의심들이 지닌 구체적 성격을 면밀히 탐구하고, 앞서의 독일 판례처럼, '국제법(international law)'이라는 보다 넓은 통례적 사용이 어떤 실천적(practical) 또는 이론적(theoretical) 목적을 방해하는지 여부를 질문할 것이다.

비록 국제법의 성격에 관한 이 문제를 단 하나의 장에서만 다루겠지만, 일부 저자들은 이보다도 더 간단히 다루자는 제안을 해왔다. 이들에게는 "국제법은 정말로 법인가?"라는 질문이 단지 사소한 언어의 의미 문제에 불과한 것인데, 이를 사물의 본질에 관한 (p. 215) 진지한 질문으로 오해한 결과라고 여겨진

다. 국제법과 국내법(municipal law)을 구분하는 사실(facts)들은 명확하고 널리 알려져 있으므로, 해결해야 할 유일한 문제는 우리가 기존의 언어 관행을 유지할 것인지, 아니면 이를 벗어날 것인지 여부라는 것이다. 그리고 이는 각 개인이 스스로 결정할 문제로 간주된다. 그러나 이러한 '간단한 해결책(short way)'은 지나치게 간단하다. 확실히, 법이론가들이 '법(law)'이라는 단어를 국제법에까지 확장하여 적용하기를 주저해 온 이유들 가운데는, 매우 단순하거나 심지어 터무니없는 관점—서로 매우 다른 것들에 동일한 용어를 적용하는 것을 정당화하는 것이 무엇인지에 대한—도 일부 작용하였다. 일반적인 분류어(classifying terms)의 확장은 다양한 원리에 따라 이루어질 수 있음에도, 법이론에서는 이러한 원리들이 자주 간과되어 왔다. 그럼에도 불구하고, 국제법에 대한 의심의 근원들은 단순히 단어 사용에 대한 오해에 그치지 않으며, 훨씬 더 심층적이고 흥미로운 문제들에 뿌리를 두고 있다. 더불어, '기존 관행을 유지할 것인가 아니면 이를 벗어날 것인가?'라는 선택지는 유일한 대안이 아니다. 그 외에도, 기존의 용법을 실질적으로 이끌어온 원리들(principles)을 명시하고, 이를 비판적으로 검토하는 선택지도 존재한다.

이러한 '간단한 해결책'은 우리가 고유명사(proper name)에 대해 논의하고 있을 경우에는 적절했을지도 모른다. 누군가 '런던(London)'이라는 지명이 정말(really) 런던인가를 묻는다면, 우리는 단지 그 명명 관행(convention)을 상기시키고, 그가 이를 따르거나 자기 입맛에 맞는 다른 이름을 선택하게 두는 수밖에 없다. 이 경우에 '런던이라는 이름이 어떤 원리에 따라 붙여졌는가, 그 원리가 정당한가'를 묻는 것은 부조리할 것이다. 이는 고유명사의 할당이 단지(only) 임의적(ad hoc) 관행에 의존하기 때문이다. 반면, 어떤 진지한 학문 분야에서 일반 명사(general terms)의 확장은 반드시 일정한 원리나 근거(rationale)를 전제로 하며, 그것이 즉각적으로 명확하지 않을 수는 있어도 존재하지 않는 법은 없다. 현재와 같은 경우에 “우리는 그것을 법이라고 부르고 있지만, 그것이 정말 법인가?”라고 의문을 제기하는 사람들은, 명확하지는 않지만, 실질적으로는 그 원리를 명확히 하고 그 정당성을 검토할 것을 요구하고 있는 것이다.

우리는 국제법의 법적 성격에 대한 의심의 주요한 근원 두 가지를 살펴보고, 그와 관련하여 법이론가들이 이를 해결하기 위해 취해온 논변들을 고찰할 것이

다. (p. 216) 이 두 형태의 의심은 모두 국제법을 국내법과 비교하면서 생겨나며, 국내법은 '법이 무엇인지'에 대한 명료한 기준 사례로 간주된다. 첫 번째 의심은, 법이란 본질적으로 위협에 의해 뒷받침되는 명령이라는 관념(conception)에 깊이 뿌리를 두고 있으며, 국제법의 규칙들(rules)의 성격을 국내법의 그것과 대조시킨다. 두 번째 형태의 의심은, 국가(state)는 본질적으로 법적 의무(legal obligation)의 수범자(subject)가 될 수 없다는 모호한 신념에서 기원하며, 국제법의 수범자들(subjects)의 성격을 국내법의 그것과 대조시킨다.

2. 의무와 제재(OBLIGATIONS AND SANCTIONS)

우리가 여기서 고찰할 의문들은 국제법 교과서의 서문에서 흔히 “국제법이 어떻게 구속력을(binding) 가질 수 있는가?”라는 질문의 형태로 제기된다. 하지만 이와 같은 방식의 질문에는 다소 혼란스러운 측면이 있다. 우리는 본격적인 논의에 앞서, 그보다 더 근본적인 선결문제를 다루어야 하며, 그에 대한 답변은 결코 자명하지 않다. 그 선결문제란 다음과 같다. 전체적인 법체계에 대해 그것이 “구속력을 가진다(binding)”고 말할 때, 과연 무슨 의미인가? 어떤 특정한 법체계의 규칙이 특정한 사람에게 구속력을 가진다고 말하는 진술은, 법률가들에게는 익숙하며 그 의미도 비교적 명확하다. 이 진술은 다음과 같이 바꿔 말할 수 있다. 즉, 해당 규칙은 유효한(valid) 규칙이며, 그에 따라 해당 인물은 어떤 의무(obligation) 또는 책무(duty)를 지닌다. 이와 별개로, 더 일반적인 형태의 진술이 사용되는 상황들도 존재한다. 우리는 특정한 개인에게 어떤 법체계가 적용되는지에 대해 의문을 품을 수 있다. 이러한 의문은 '국제공법'이나 '법률의 충돌(conflict of laws)'의 맥락에서 발생한다. 전자의 경우, 우리는 어떤 특정한 거래에 대해 프랑스법 또는 영국법이 어떤 사람에게 구속력을 가지는지 물을 수 있으며, 후자의 경우에는 예를 들어 적국에 점령된 벨기에(Belgium)의 주민들이 망명정부가 주장하는 벨기에법에 따라야 하는지, 아니면 점령 세력이 발령한 포고령에 따라야 하는지를 물을 수 있다. 그러나 이 두 경우 모두, 해당 질문은 어떤 법체계(국내법 또는 국제법) 내부에서(within) 제기되는 법적 질문이며, 해당 법체계의 규칙이나 원칙을 참조하여 해결된다. 이러한 질문들은 규칙의

일반적 성격을 문제 삼는 것이 아니라, 특정한 사람이나 상황에 (p. 217) 규칙이 적용(applicability)되는 범위를 묻는 것이다. 이에 비해, “국제법은 구속력을 가지는가(Is international law binding)?” 또는 “국제법은 어떻게 구속력을 가질 수 있는가?”, “무엇이 국제법을 구속력 있게 만드는가?”라는 질문은 전혀 다른 차원의 문제를 제기한다. 그것은 규칙의 적용범위가 아니라, 국제법 일반의 법적 지위(legal status) 자체에 대한 의문을 표현한다. 보다 솔직하게 표현하자면, 그 질문은 다음과 같다. “이러한 규칙들이 과연 의미 있고 진실되게 ‘의무(obligation)’를 발생시킨다고 말할 수 있는가?” 국제법에 대한 이러한 회의의 한 근원은, 국제법 체계에 중앙 조직화된 제재기관(centrally organized sanctions)이 부재하다는 사실이다. 이는 국제법이 법적 의무의 전형(paradigm of legal obligation)으로 간주되는 국내법과 비교되어 비판을 받는 지점이다. 여기에서 논증은 간단하게 전개된다. 즉, 만약 이러한 이유로 인해 국제법의 규칙들이 ‘구속력이 없다’면, 그것들을 ‘법(law)’이라고 진지하게 분류하는 것은 정당화될 수 없다는 것이다. 일반 언어 사용(conventional speech)이 아무리 관대하다 해도, 이 정도의 차이는 무시할 수 없다. 결국, 법의 본질에 대한 모든 이론적 사유는, 법이 존재한다는 사실이 일정한 행위를 의무화(obligatory) 한다는 전제에서 출발한다.

우리는 이 논증을 고찰하면서, 국제법 체계에 관한 모든 사실관계에서 회의론자에게 유리한 가정을 받아들일 것이다. 즉, 국제연맹(League of Nations)의 규약(Covenant) 제16조나 유엔 헌장(United Nations Charter) 제7장을 통해, 국제법에 국내법의 제재와 동일한 기능을 하는 어떤 제도가 도입된 바는 없다고 간주한다. 한국전쟁(Korean War)이나 수에즈 사태(Suez incident)로부터 어떤 교훈을 끌어낼 수 있다 해도, 실질적인 법 집행 수단은 유엔 안전보장이사회의 거부권(veto)으로 인해 마비될 가능성이 높고, 따라서 그것들은 문서상에만 존재한다고 할 수 있다.

국제법에 조직화된 제재가 없다는 이유로 그것이 구속력을 가지지 않는다고 주장하는 것은, 법이란 본질적으로 위협에 의해 뒷받침되는 명령(order backed by threats)이라는 이론 속에서 ‘의무(obligation)’를 분석한 방식에 암묵적으로 동의하는 것이다. 이 이론은, 앞서 논의한 바와 같이, ‘의무가 있다(having an

obligation)’ 혹은 ‘구속된다(being bound)’는 것을 “불복종 시 위협된 제재나 처벌을 당할 가능성이 있다”는 의미로 동일시한다. 그러나 우리는 이미 논증했듯, 이러한 동일시는 법적 사유와 담론 전체에서 (p. 218) ‘의무(obligation)’와 ‘책무(duty)’ 개념이 수행하는 역할을 왜곡한다. 실제로는, 제재가 효과적으로 조직되어 있는 국내법에서도, 우리는 제3장에서 제시한 다양한 이유들에 따라, 다음 두 가지를 엄격히 구분해야 한다: “나는 (또는 너는) 불복종할 경우 제재를 당할 가능성이 있다”는 외적 예측 진술(external predictive statement)과 “나는 (또는 너는) 그렇게 행동해야 할 의무가 있다”는 내적 규범 진술(internal normative statement)은 전혀 다른 것이다. 이 두 번째 진술은 특정한 사람의 상황을, 행위지침으로 받아들여진 규칙의 관점에서 평가한다. 물론 모든 규칙이 의무나 책무를 발생시키는 것은 아니다. 그러나 일반적으로 그러한 규칙들은 사적 이익의 일정한 희생을 요구하며, 준수를 위한 강력한 기대(compliance pressure)와 이탈에 대한 지속적인 비판을 동반한다. 그렇지만 우리가 이러한 예측적 분석과, 그것의 전제가 되는 ‘법이란 위협에 의한 명령’이라는 개념으로부터 자유로워진다면, 조직화된 제재가 존재해야만 규범적 의미의 의무가 성립한다는 식의 제한은 정당화될 수 없다.

하지만 보다 설득력 있는 형태의 논증도 고려해보아야 한다. 이는 의무(obligation)를 위협된 제재의 가능성으로 정의하지는 않지만, 다음과 같은 점을 지적한다. 우리가 앞서 강조했듯, 국내법 체계에는 다음과 같은 조항들이 정당하게 필수적(necessary)이라 불린다. 예컨대, 자유로운 폭력 행사 금지를 명하는 일차 의무 규칙(primary rules of obligation)과, 이러한 규칙들을 위반했을 때 공식적 제재(official use of force)가 가능하도록 규정하는 규칙들이 그러하다. 그렇다면, 이러한 규칙들과 그것들을 뒷받침하는 제재가 국내법에서 필수적이라면, 국제법에서도 마찬가지로 필수적이지 않은가? 이러한 주장은, ‘binding’이나 ‘obligation’이라는 단어의 의미로부터 직접 도출되지 않더라도, 여전히 설득력을 가질 수 있다.

이 논증에 대한 답변은 인간 존재와 그 환경에 대한 기본적 진실, 즉 국내법의 지속적인 심리적·물리적 배경으로 구성된 조건들 속에 있다. 개인들이 살아가는 사회에서는, 신체적 힘과 취약성에서 대체로 평등하며, 물리적 제재는

필요할 뿐 아니라 가능하다. 이는 자발적으로 법의 구속에 따르려는 자들이, 그러한 제재가 없다면 법을 무시하면서 타인의 준수로부터 이익만 얻으려는 악의적 행위자들(malefactors)의 희생양이 되지 않기 위해 필요하다. 개인들이 서로 가까이 살아가는 환경에서는, (p. 219) 공개적인 공격뿐 아니라 교묘한 방식의 피해까지도 발생할 가능성이 크고, 탈출의 여지도 상당하므로, 간단한 사회 형태를 제외하고는 단순한 자연적 억제 요소(natural deterrents)만으로는, 법을 지키기에는 너무 악하거나, 어리석거나, 약한 자들을 통제하기에 부족하다. 그러나 동시에, 일정한 평등성과 자발적 협력의 이점으로 인해, 악의적 행위자들의 연합이 법 유지에 협력하는 이들의 연합보다 더 강력해질 가능성은 적다. 이러한 조건은 국내법의 배경을 이루며, 이 환경에서는 악의적 행위자들에 대한 제재가 비교적 적은 위협으로 실현 가능하며, 제재의 위협은 자연적 억제 요소를 보완한다. 그러나 이러한 단순한 상식들이 개인들에 대해서는 성립하더라도, 국가(states)에는 성립하지 않는다. 즉, 국제법의 사실적 배경은 국내법과 매우 다르므로, 제재가 국제법에 필수적인 것도 아니고, 실현 가능하고 안전한 수단도 아니다.

국가 간의 침략은 개인 간의 침략과 매우 다르다. 국가 간 폭력의 사용은 공개적(public)이어야 하며, 국제 경찰력(international police force)이 존재하지 않는 상황에서도, 그 행위가 단순히 침략자와 피해자 사이의 문제로 남을 가능성은 거의 없다. 전쟁을 시작한다는 것은, 가장 강한 국가에게조차도, 예측할 수 없는 결과를 감수해야 하는 모험이다. 더구나 국가 간에는 힘의 불균형이 존재하기 때문에, 국제 질서 유지에 협력하는 국가들의 결합된 힘이 침략을 유혹받는 국가들보다 우세하다고 보장할 수도 없다. 따라서 제재의 조직과 사용은 막대한 위험을 수반할 수 있고, 그 위험은 자연적 억제 요소에 큰 도움이 되지 않을 수 있다. 이러한 상이한 사실적 배경 속에서, 국제법은 국내법과는 다른 형태로 발전해왔다. 현대 국가의 국민 사이에서는, 범죄에 대한 조직화된 억제와 처벌이 없으면, 폭력과 절도가 일상적으로 벌어질 것이다. 그러나 국가 간의 경우에는, 참혹한 전쟁 사이에 오랜 평화의 시기가 존재해왔다. 이러한 평화는 (p. 220) 전쟁의 위험성과 이해득실, 그리고 국가 간 상호 의존성에 비추어 볼 때 오직 합리적으로 기대될 수 있는 것이며, 그러한 평화 상태는 중앙기관의

집행 조항이 없는 규칙들에 의해 규율되는 것이 타당하다. 그럼에도 불구하고, 이러한 규칙들은 의무적인 것(obligatory)으로 여겨지며, 준수에 대한 일반적 압력이 존재한다. 권리 주장(claims)과 승인(admissions)은 이들 규칙에 근거하고, 규칙의 위반은 보상(compensation) 요구뿐 아니라 보복조치(reprisals)와 대응조치(counter-measures)를 정당화한다고 여겨진다. 규칙이 무시될 때에도, 그러한 위반은 '구속력이 없었기 때문'이라는 식으로 표현되지 않는다. 오히려 위반 사실 자체를 은폐하려는 시도가 나타난다. 물론 이러한 규칙들이 국가들이 전쟁을 감수할 의지가 없는 사안에 대해서만 효과를 가진다고 말할 수도 있다. 이는 국제법 체계의 중요성과 인류에 대한 그 가치에 부정적인 함의를 줄 수도 있다. 그러나 그럼에도 불구하고 그러한 규칙들이 일정 수준의 효과성을 발휘하고 있다는 점은, 다음과 같은 주장의 오류를 보여준다. 즉, 국내법에서 조직화된 제재가 필요하다는 사실로부터, 매우 다른 사실적 환경을 가진 국제법에 제재가 없으면 그것은 의무를 부과하지 않으며, 구속력도 없고, 법이라 불릴 가치도 없다는 결론이 도출될 수 있다는 주장은, 단순한 논리적 추론으로 성립될 수 없다.

3. 의무와 국가의 주권(OBLIGATION AND THE SOVEREIGNTY OF STATES)

영국(Great Britain), 벨기에(Belgium), 그리스(Greece), 소련(Soviet Russia) 등은 국제법상 권리와 의무(rights and obligations)를 가지며, 따라서 국제법의 수범자(subjects)에 속한다. 이들은 일반인이 독립국가(independent state)로 간주하고, 법률가는 '주권국가(sovereign state)'로 승인(recognize)할 국가들의 예시일 뿐이다. 국제법이 의무(obligatory)의 성격을 가진다는 점에 대해 끊임 없이 제기되는 혼란의 주요 원천 중 하나는, 주권적(state is sovereign)인 국가가 국제법에 의해 '구속받는다(bound)'거나 의무(obligation)를 가진다는 사실을 받아들이거나 설명하는 데서 느껴지는 어려움이다. 이러한 형태의 회의론은, 국제법이 제재(sanction)를 결여하고 있기 때문에 구속력이 없다고 보는 주장보다, 어떤 의미에서는 더 극단적이다. 왜냐하면 후자의 경우에는 언젠가 국

제법에 제재 체계가 도입되면 문제는 해결될 수 있지만, 현재의 주장은 다음과 같은 근본적 모순(radical inconsistency)에 기반하고 있기 때문이다. 즉, 국가가 동시에 '주권적'이면서도 '법의 수범자(subject to law)'가 될 수 있다는 개념 자체에 모순이 있다는 것이다.

이러한 비판을 검토하기 위해서는, 주권(sovereignty) 개념을 면밀히 분석해야 하며, (p. 221) 이 개념은 국가 내부의(within) 입법부나 특정 요소나 인물에 적용되는 것이 아니라, 국가(state) 그 자체에 적용된다. 주권적(sov​er​eign)이라는 단어가 법이론(jurisprudence) 속에서 등장할 때마다, 그것은 종종 법 위에 존재하며, 그 말이 곧 법이 되는 인물—즉, 하위자(inferior) 또는 수범자(subject)에 대해 군림하는 인물—이라는 관념과 연결되곤 한다. 이 책의 초반 장들에서 보았듯이, 이와 같은 매혹적인 관념은 국내법(municipal law)의 구조를 이해하는데 있어 매우 나쁜 안내자이며, 국제법 이론에 있어서도 더욱 큰 혼란의 원인이 되어왔다. 물론 국가를 그러한 방식으로—마치 일종의 '초인(Superman)'으로—상상하는 것이 가능하긴(possible) 하다. 즉, 본질적으로 법을 초월한 존재이면서, 자국민에게는 법의 근원이 되는 존재로 여기는 것이다. 16세기 이후 “국가란 곧 나다(L'état c'est moi)”라는 상징적 동일시는 이와 같은 사유를 부추겼으며, 이는 정치이론과 법이론 모두에 의심스러운 영향을 미쳐왔다. 그러나 국제법을 이해하기 위해서는 이러한 연상을 벗어나는 것이 중요하다. '국가(a state)'라는 표현은, 그 자체로 본질적으로 혹은 '자연상(naturally)' 법의 외부에 있는 인물이나 사물을 지칭하는 명칭이 아니다. 오히려 두 가지 사실을 지칭하는 방식일 뿐이다. 첫째, 일정한 영토에 거주하는 인구가 입법부, 법원, 그리고 일차 규칙(primary rules)이라는 고유한 구조를 갖춘 법체계(legal system)가 마련한 질서 있는 정부(government) 하에 존재한다는 사실, 둘째, 그 정부가 일정한 정도의 독립성(independence)을—비록 모호하게 정의되었더라도—향유한다는 사실이다.

물론 '국가(state)'라는 단어 자체에도 상당한 모호성(vagueness)이 내포되어 있지만, 위에서 언급한 설명은 그 핵심 의미를 드러내기에 충분하다. 예를 들어, 영국이나 브라질, 미국이나 이탈리아와 같은 국가는—임의적 예시로 보더라도—그 영토 밖의 어떤 권위나 인물로부터도 법적·사실적 통제를 거의 받지 않으며,

국제법상 '주권국가(sovvereign state)'로 분류된다. 반면, 연방(federal union)에 속한 개별 주(state)—예컨대 미국의 주(state)—는 다양한 방식으로 연방정부와 연방헌법의 권위와 통제에 종속된다(subject to). 그러나 이들 연방국조차도 잉글랜드의 카운티(county)와 같은 단위에 비하면 상당한 독립성을 유지하고 있으며, 후자의 경우에는 '국가(state)'라는 용어 자체가 전혀 사용되지 않는다. 카운티는 해당 지역에 대해 일정한 입법 기능을 수행하는 지방의회를 가질 수 있지만, 그 권한은 의회의 권한에 철저히 종속되며, (p. 222) 일부 사소한 경우를 제외하면, 그 지역은 국가의 다른 지역과 동일한 법률과 정부에 따라 규율된다.

이러한 극단적 사례들 사이에는, 질서 있는 정부를 보유한 영토 단위(territorial units) 사이에 존재하는 다양한 유형과 정도의 종속성과 독립성의 스펙트럼이 존재한다. 식민지(colonies), 보호령(protectorates), 속령(suzerainties), 신탁통치지역(trust territories), 연합(confederations) 등은 이 관점에서 볼 때 흥미로운 분류 문제를 제기한다. 대부분의 경우, 하나의 단위가 다른 단위에 종속되어 있다는 사실은 법적 형식으로 표현된다. 즉, 종속 단위의 영토에서 '법'으로 작용하는 규칙은, 적어도 일부 사안에 있어서는, 결국 다른 단위에서 이루어진 입법 행위(law-making operations)에 따라 결정된다.

어떤 경우에는 종속된 영토의 법체계(legal system)가 그 종속성을 전혀 반영하지 않을 수도 있다. 이러한 경우는 두 가지 유형으로 나타날 수 있다. 하나는 해당 영토가 형식상 독립되어 있지만, 실질적으로는 외부로부터 꼭두각시(puppet)를 통해 통치되고 있는 경우이며, 다른 하나는 해당 영토가 내정(internal affairs)에 대해서는 실질적인 자치권(autonomy)을 보유하고 있으나, 외교(external affairs)에 대해서는 다른 국가에 의존하고 있으며, 그 외교적 종속성이 자국의 국내법(domestic law)상 표현될 필요가 없는 경우이다. 이처럼 하나의 영토 단위가 다른 단위에 대해 갖는 종속성은 독립성이 제한되는 유일한 방식이 아니다. 그 제한 요인은 다른 영토 단위의 권력이나 권위가 아니라, 상호 독립적인 여러 단위들에 영향을 미치는 국제적 권위(international authority)일 수도 있다. 다양한 형태의 국제 권위를 상상할 수 있으며, 그에 상응하여 국가의 독립성(independence)에 대한 다양한 제약이 가능하다. 그 예시는 다음과 같다: 모든 국가의 내정과 외교를 규율할 법적 한계 없는 권한

(legally unlimited powers)을 가진, 영국 의회(British Parliament)를 모델로 한 세계 입법기관(world legislature); 특정한 사안에 대해서만 법적 관할권(legal competence)을 가지거나, 구성 단위의 특정 권리를 보장하는 한도에서만 권한이 제한되는, 미국 의회(Congress)를 모델로 한 연방 입법기관(federal legislature); 일반적으로 수용된 규칙들(rules generally accepted)만이 법적 통제로 작용하는 체제; 마지막으로, 계약적 또는 자기부과적(self-imposed)인 형태만이 유일하게 인정되는 의무(obligation)의 체제—즉, 국가의 독립성은 오직 자국의 행위에 의해서만 법적으로 제한되는 체제.

이러한 가능성의 범위를 고찰하는 것은 유익하다. 왜냐하면 단지 다양한 유형과 (p. 223) 정도의 종속성과 독립성이 존재할 수 있음을 인식하는 것만으로도, 다음과 같은 주장에 대한 반론의 단초를 제공하기 때문이다. 즉, 국가들이 주권적(sov​er​eign)이므로 국제법의 수범자(subject)가 “될 수 없다(cannot)”거나, “오직 특정한 형태의 국제법에 의해서만 구속“될 수 있다(can)”는 주장 말이다. 여기서 ‘주권적’이라는 단어는 단지 ‘독립적(independent)’이라는 의미일 뿐이며, 그것 역시 부정적 개념(negative in force)이다. 즉, 주권국가란 어떤 유형의 통제(control)도 받지 않는(not) 국가이고, 주권이란 자율적으로 행동할 수 있는 영역을 의미한다. 우리가 앞서 본 것처럼, ‘국가(state)’라는 단어 자체의 의미에는 일정 정도의 자율성(autonomy)이 내포되어 있다. 그러나 이 자율성이 반드시 무제한“이어야 한다(must)”거나, 오직 특정 유형의 의무(obligation)에 의해서만 제한“될 수 있다(can)”는 주장은, 기껏해야 ‘국가는 그 외의 모든 제약으로부터 자유로워야 한다’는 당위적 요구(ought)의 진술이며, 최악의 경우에는 어떠한 근거도 없이 반복되는 독단적 신념(dogma)에 불과하다. 실제로 국가들 사이에 어떤 형태의 국제 권위가 존재한다면, 그만큼 국가의 주권은 제한되며, 그 제한의 범위는 해당 규칙들(rules)이 허용하는 한도에 따른 것이다. 따라서 어떤 국가가 주권적(sov​er​eign)인지, 그리고 그 주권의 범위가 얼마인지를 알기 위해서는, 먼저 해당 규칙들이 무엇인지를 알아야 한다. 이는 마치 한 영국인 또는 미국인이 자유로운지, 그리고 그의 자유의 범위가 어느 정도인지를 파악하기 위해서는, 영국법 또는 미국법이 무엇인지를 먼저 알아야 하는 것과 같다. 국제법의 규칙들은 실제로 여러 측면에서 모호(vague)하고 서

로 충돌(conflicting)하기 때문에, 국가에게 남겨진 독립성의 영역에 관한 의문은 국내법 하에서 시민의 자유 범위에 관한 의문보다 훨씬 크다. 그럼에도 불구하고, 이러한 어려움은 다음과 같은 선험적(a priori) 논증을 정당화하지는 않는다. 즉, 국제법의 일반적 성격은—국제법 자체를 참조하지도 않은 채—국가가 본래 절대적 주권(absolute sovereignty)을 가진다고 가정함으로써 도출될 수 있다는 주장은 오류다.

여기서 주목할 점은, '주권(sovereignty)'이라는 개념을 비판 없이 사용하는 태도가, 국내법 이론과 국제법 이론 모두에 유사한 혼란을 퍼뜨려 왔으며, 양자 모두에 유사한 수정이 필요하다는 점이다. 이 개념의 영향 아래 우리는 다음과 같이 믿게 된다: 모든 국내법 체계에는 법적 제한을 받지 않는 주권 입법자(legally unlimited sovereign legislator)가 반드시 존재해야 한다(must); 마찬가지로, 국제법은 국가는 오직 스스로에 의해서만 법적으로 제한될 수 있는 존재이므로 반드시 특정한 성격을 가져야 한다(must)는 믿음도 같은 영향의 산물이다. 양 경우 모두, '법적으로 무제한적인 주권자'의 존재가 필연적이라고 믿는 것은, 실제 규칙을 검토해보기도 전에 선입적으로 판단(prejudging)하는 (p. 224) 것이다. 국내법의 경우 물어야 할 질문은 다음과 같다. “이 체계에서 인정되는 최고 입법권(supreme legislative authority)의 범위는 무엇인가?” 국제법의 경우에는 이렇게 묻는 것이 적절하다. “규칙들이 국가에 허용하는 최대 자율성(maximum area of autonomy)의 범위는 무엇인가?”

따라서 현재의 비판에 대한 가장 간단한 대답은, 그 비판이 질문이 제기되어야 할 순서를 전도(inverts the order)시켰다는 것이다. 국가들이 어떤 주권(sovereignty)을 가지는지는, 국제법의 형태가 무엇인지 그리고 그것이 단지 공허한 형식(empty forms)인지 여부를 알기 전에는 알 수 없다. 많은 법이론 논쟁들이 바로 이 원칙이 무시되었기 때문에 혼란스러웠으며, 이 원칙의 관점에서 다음과 같은 국제법 이론들을 검토하는 것은 유익하다. 즉, 이른바 '의지주의(voluntarist)' 또는 '자기제한(auto-limitation)' 이론들이다. 이러한 이론들은, 국가의 (절대적) 주권과 국제법의 구속력 있는 규칙(binding rules)의 존재를 조화시키기 위해, 모든 국제적 의무(obligation)는 약속(promise)에서 발생하는 의무와 같이 자기부과적(self-imposed)이라고 간주하였다. 사실상 이러한 이론

들은 국제법 내에서, 정치학의 사회계약론(social contract theories)과 대응하는 위치를 점한다. 사회계약론은 다음과 같은 사실을 설명하고자 했다. 즉, 개인은 ‘자연적으로’ 자유롭게 독립적인 존재임에도 불구하고, 어떻게 국내법에 의해 구속될 수 있는가를 설명하기 위해, 법에 복종할 의무는 개인들끼리, 혹은 경우에 따라 그들의 통치자와 계약(contract)을 맺음으로써 발생한다고 보았다. 우리는 여기서 이러한 사회계약론을 문자 그대로 받아들였을 때 제기되는 잘 알려진 반론들이나, 비유로서 유익한 통찰을 줄 수 있는 가능성에 대해서는 논의하지 않을 것이다. 대신, 우리는 이 이론의 역사로부터 다음 장에서 의지주의 국제법 이론들에 대한 세 가지 반론(threesome argument)을 도출할 것이다.

첫째, 이러한 이론들은 국가들이 오직 자기부과적(self-imposed) 의무(obligations)에 의해서만 구속 “될 수 있다(can)”는 사실이 어떻게 알려졌는지, 또는 왜 그러한 국가 주권(sovereignty)에 대한 견해가 국제법의 실제 성격에 대한 어떠한 검토도 없이 사전에 수용되어야 하는지(accepted)를 전혀 설명하지 못한다. 그 주장을 뒷받침하는 근거가 반복적으로 되풀이되어 왔다는 사실 외에 과연 더 있는가? 둘째, 주권 때문에 국가는 오직 자신이 스스로 부과한 규칙에 의해서만 수범자(subject)가 되거나 구속될 수 있다(can)는 주장을 입증하려는 논증에는 일종의 모순이 있다. ‘자기제한(auto-limitation)’ 이론의 극단적 형태들에서는 국가의 합의나 조약 체결이 단지 미래 행동에 대한 선언(statement)으로 간주되고, 이를 이행하지 않아도 어떠한 의무 위반(breach of obligation)으로도 간주되지 않는다. (p. 225) 이는 사실과 크게 어긋나지만, 적어도 일관성(consistency)은 있다. 즉, 국가의 절대적 주권(absolute sovereignty)은 어떠한 종류의 의무(obligation)와도 양립할 수 없다는 단순한 이론으로, 의회(Parliament)와 마찬가지로 국가는 스스로를 구속할 수 없다(bind itself)는 것이다. 그러나 보다 온건한 입장은, 국가는 약속(promise), 합의(agreement), 또는 조약(treaty)을 통해 자기 자신에게 의무를 부과할 수 있다고 주장한다. 하지만 이는, 국가는 오직 자기가 스스로 부과한 규칙에만 수범자(subject)가 된다는 이론과는 양립할 수 없다. 왜냐하면, 말로 하든 문서로 하든, 특정한 상황에서 그것이 약속, 합의, 조약으로 기능하여 의무를 발생시키고 타인이 그로부터 권리(right)를 주장할 수 있으려면, 이미 다음과 같은 규칙들(rules)이 존재해야 한다. 즉,

국가는 적절한 방식으로 어떤 행위를 하겠다고 서약한 경우, 그것을 실행해야 할 의무를 가진다는 규칙이 존재해야 한다는 것이다. 이러한 규칙들은 자기부과적 의무(self-imposed obligation)라는 개념 자체에 선행하는 것으로, 이 규칙들 자체가 자기부과적 의무로부터 그들의(their) 의무적 지위(obligatory status)를 도출할 수는 없다.

물론 하나의 특정 행위(action)에 대해, 해당 국가가 그것을 이행할 의무가 있다는 점은 이론적으로 약속에서 도출될 수 있다. 하지만 그것은 다음의 조건 하에서만 가능하다. 즉, '약속 등은 의무를 발생시킨다'는 규칙(rule)이 해당 국가에 대해, 그 국가의 어떤 약속과는 무관하게, 독립적으로 적용되는 경우에 한한다. 어떤 사회든, 그것이 개인(individuals)으로 이루어졌든 국가(states)로 이루어졌든, 약속, 합의, 조약 등의 언명이 의무를 발생시킬 수 있으려면, 다음과 같은 규칙이 일반적으로, 비록 반드시 보편적으로는 아니더라도, 인정되어야 한다(acknowledged). 즉, 이러한 자기구속 행위(self-binding operations)를 규율하는 규칙들과 그것에 대한 절차를 명시하는 규칙이 존재해야 한다. 이러한 규칙이 인정되는 곳에서는, 해당 절차를 의식적으로 사용하는 개인 또는 국가는, 자신이 원하든 원하지 않든, 그 절차에 의해 구속된다(is bound). 따라서 이러한 가장 자발적인(voluntary) 형태의 사회적 의무(social obligation)조차도, 그 당사자의 선택과 무관하게 구속력을 가지는 규칙들을 포함하고 있으며, 이는 국가의 경우에, 주권이 그러한 모든 규칙으로부터의 자유를 요구한다는 가정과 양립할 수 없다.

셋째로, 사실(facts)이 존재한다. 우리는 다음 두 주장을 구분해야 한다. (1) 앞서 비판된 선험적(a priori) 주장—즉, 국가는 오직 자기부과적 의무에 의해서만 구속될 수 있다(can)는 주장, 그리고 (2) “국가가 다른 방식으로 구속될 수도 있었겠지만, 현행 국제법 규칙들 하에서는 그러한 다른 형태의 의무는 존재하지 않는다”는 경험적 주장. 물론 국제법 체계가 (p. 226) 완전히 이러한 합의(consensual)적 형태를 띠는 경우도 가능하다. 이 견해에 대한 긍정과 부정은 학자들의 저술, 판사들의 의견, 심지어 국제 재판소의 판단이나 국가의 선언 등에서도 모두 발견된다. 이 견해가 타당한지 여부는, 국가들의 실제 실천(actual practice)을 냉정하게 조사해 보아야만 판단할 수 있다. 확실히 현대 국제법은

상당 부분이 조약법(treaty law)이며, 국가의 사전 동의 없이도 구속력이 있는 것으로 보이는 규칙들이 실제로는 명시적이든 암묵적이든 동의(consent)에 기초하고 있다는 점을 입증하기 위한 복잡한 시도가 있어왔다. 이러한 동의는 '암묵적(tacit)'으로 주어졌거나, '추론(inferred)'된 것으로 해석되기도 한다. 이들 중 일부는 허구(fiction)가 아닐 수도 있지만, 적어도 일부 시도들은, 우리가 이미 살펴보았던 '암묵적 명령(tacit command)'이라는 개념—국내법에서 유사하게 허구적으로 단순화된 개념—과 마찬가지로, 국제법에서의 다양한 의무 형태를 하나로 환원하려는 시도로서 의심을 불러일으킨다.

이러한 '국제적 의무는 전적으로 당사자의 동의(consent)로부터 발생한다'는 주장을 면밀히 검토하는 것은 여기서 다룰 수 없지만, 이 이론에 대한 두 가지 명확하고 중요한 예외(exception)는 반드시 언급되어야 한다. 첫째는, 신생국가(new state)의 경우이다. 예컨대 1932년의 이라크(Iraq), 1948년의 이스라엘(Israel)처럼 새로운 독립 국가가 등장할 때, 그 국가는 조약에 구속력을 부여하는 규칙들을 포함하여, 국제법의 일반적 의무(general obligations of international law)에 구속된다(is bound)는 점에 대해, 의심이 제기된 적은 없다. 이 경우에, 신생국의 국제적 의무가 '암묵적(tacit)' 또는 '추론된(inferred)' 동의(consent)에 근거한다는 주장은 극히 빈약해 보인다. 둘째는, 국가가 영토를 획득하거나 다른 방식으로 변화하여, 그동안 준수하거나 위반할 기회조차 없었던 규칙들 하에 처음으로 의무를 지게 되는 경우이다. 예컨대, 기존에 바다에 접근할 수 없던 국가가 해양 영토를 획득한다면, 이는 해당 국가가 영해(territorial waters) 및 공해(high seas)에 관한 모든 국제법 규칙의 수범자(subject)가 되기에 충분한 조건이다. 이 외에도, 주로 다자조약(multilateral treaties)이나 일반조약(general treaties)이 비당사국(non-parties)에 미치는 효과와 관련하여 논쟁적인 사례들이 더 있지만, 위의 두 가지 중요한 예외만으로도 다음과 같은 의심은 정당화된다. 즉, '모든 국제법상의 의무는 자기부과적이다'라는 일반이론은, 지나치게 추상적 독단(dogma)에 영감을 받았고, 사실(facts)에 대한 존중은 부족한 것이다.

4. 국제법과 도덕(INTERNATIONAL LAW AND MORALITY)

(p. 227) 제5장에서 우리는 오직 일차적 의무 규칙(primary rules of obligation)으로만 구성된 단순한 형태의 사회 구조를 고찰하였다. 그리고 이러한 구조는 가장 작고 결속력 있는 고립 사회를 제외하고는 심각한 결함들을 지니고 있다는 점을 확인했다. 이와 같은 체계는 정태적(static)일 수밖에 없으며, 그 규칙들은 성장과 쇠퇴라는 느린 과정을 통해서만 변할 수 있다. 규칙의 식별(identification)은 불확실하며, 규칙 위반 사실의 확인(ascertainment)과 위반자에 대한 사회적 압력의 적용은 우연적이고 시간 소모가 크며 비효율적이다. 우리는 국내법(municipal law)의 고유한 이차 규칙(secondary rules)—즉, 승인(recognition), 변경(change), 판정(adjudication)의 규칙들—을 이러한 결함들에 대응하는 서로 구별되면서도 관련된 수단(remedies)으로 이해하는 것이 유익함을 보았다. 형식상으로 보면, 국제법은 이러한 일차 규칙 체계와 유사하지만, 그 내용은 종종 매우 복잡하며 원시 사회의 규칙들과는 전혀 다르고, 그 개념·방법·기법의 상당 부분은 현대 국내법과 동일하다. 많은 법학자들은 이러한 형식상의 차이를 설명하기 위해 국제법을 '도덕(morality)'으로 분류하는 것이 최선이라고 생각해왔다. 그러나 이러한 방식으로 차이를 표기하는 것은 혼란을 불러올 수 있음이 분명하다.

국가 간 관계를 규율하는 규칙들이 오직 도덕 규칙일 뿐이라는 주장에는 종종 다음과 같은 오래된 독단적 주장(dogmatism)이 깔려 있다. 즉, 위협에 의해 뒷받침되는 명령(order)으로 환원되지 않는 사회 구조는 오직 '도덕성(morality)'의 한 형태일 수밖에 없다는 것이다. 물론 '도덕(morality)'이라는 단어를 이와 같이 포괄적으로 사용할 수도 있다. 그렇게 되면, 그 속에는 게임의 규칙, 클럽 규칙, 예절 규칙, 헌법이나 국제법의 기본 조항들, 그리고 일반적으로 도덕 규칙(moral rules)이라고 간주되는 잔혹, 부정직, 거짓말 등에 대한 금지와 같은 원칙들이 모두 함께 포함된다. 그러나 이러한 분류 방식에 대한 반론은 다음과 같다. 즉, 이처럼 '도덕'이라는 이름 아래 함께 묶인 것들 사이에는 형식과 사회적 기능 모두에 있어 중대한 차이가 존재하며, 이러한 조잡한 분류는 어떠한 실천적 목적이나 이론적 목적에도 봉사하지 못한다. 오히려 이렇게

인위적으로 확장된 도덕 범주 안에서는, 이 분류로 인해 흐려진 기존의 구분들을 다시 설정해야만 할 것이다.

(p. 228) 국제법의 특정 사안의 경우, 그것의 규칙들을 '도덕'으로 분류하는 것에 저항해야 할 이유는 여러 가지가 있다. 첫 번째는 다음과 같다. 국가들은 종종 서로의 비도덕적 행위(immoral conduct)를 비난하거나, 자신 또는 타국이 국제적 도덕 기준에 부합했다고 자찬하기도 한다. 물론 국제법을 준수하는 것이 국가가 발휘할 수 있는 미덕(virtues) 중 하나(one)임은 분명하나, 그렇다고 해서 국제법이 곧 도덕(morality)이라는 뜻은 아니다. 실제로, 국가의 행위를 도덕적 관점에서 평가하는 것과, 국제법 규칙 하에서 권리(right)와 의무(obligation)를 주장하거나 요구하거나 인정(acknowledge)하는 것 사이에는 명백한 차이가 있다. 제9장에서 우리는 사회적 도덕성(social morality)의 정의적 특징으로 간주될 수 있는 몇 가지 요소들을 제시한 바 있다. 그 중 하나는, 도덕 규칙이 주로 양심에의 호소(appeal to conscience)를 통해 지지된다는 것이다. 여기서의 압박은 두려움에의 호소나 보복 또는 보상의 요구가 아니라, 당사자에게 도덕 원칙을 상기시킴으로써 그가 죄책감이나 수치심에 의해 규칙을 존중하고 보상하도록 유도하는 데 있다.

그러나 국제법 하에서의 청구(claim)는 이러한 방식으로 표현되지 않는다. 물론 국내법과 마찬가지로, 그것은 도덕적 호소와 결합될 수는 있다. 그러나 국가들이 국제법 해석 문제로 서로에게 제시하는 종종 기술적인 논증들에서는, 선례(precedents), 조약(treaties), 법학 저술(juristic writings)에 대한 참조가 중심을 이룬다. 도덕적 옳고 그름이나 선악에 대한 언급은 종종 전혀 등장하지 않는다. 예를 들어, “베이징 정부가 포모사(Formosa, 대만)에서 국민당(Nationalist) 세력을 추방할 국제법상의 권리를 가지고 있는가 또는 없는가”라는 주장은, “그것이 공정(fair)하거나 정의롭거나 도덕적으로 선한 행위인가?”라는 질문과는 전혀 다르며, 그 주장들은 전혀 다른 방식의 논증에 의해 뒷받침된다. 물론 국가 간 관계에서도, 명백한 법도 명백한 도덕도 아닌 중간지대(halfway houses)가 존재한다. 이는 사적 생활에서 인정되는 예의나 예절과 유사한 기준들과 대응된다. 그러한 사례의 대표는 국제 관례(international comity)의 영역이며, 외교 사절이 개인적 용도로 수입하는 물품에 대해 관세 면제를 받는 특권

(privilege) 같은 것이 이에 해당한다.

보다 중요한 구별 근거는 다음과 같다. 국제법의 규칙은 국내법의 그것처럼 (p. 229) 종종 도덕적으로 전혀 무관심할 수 있다. 특정 규칙이 존재하는 이유는, 그것이 도덕적으로 중요한 것이기 때문이 아니라, 단지 관련 주제를 둘러싼 명확하고 고정된 규칙이 필요하거나 편리하기 때문일 수 있다. 해당 규칙은 수많은 가능한 대안들 중 하나일 뿐이며, 다른 규칙이라도 마찬가지로 잘 작동했을 것이다. 따라서 국내법과 국제법의 법규칙들은 흔히 매우 구체적인 세부 사항(specific detail)을 포함하고 있으며, 도덕 규칙에서는 이해될 수 없는 임의적 구분(arbitrary distinctions)을 도입한다. 물론 사회적 도덕성의 내용에 대해 독단적(dogmatic)이어서는 안 된다. 제9장에서 살펴보았듯이, 하나의 사회 집단의 도덕성은 현대 지식의 기준에서 보면 불합리하거나 미신적(superstitious)으로 보일 수 있는 금지 규정들을 포함할 수도 있다. 예컨대, 우리의 믿음과 전혀 다른 일반 신념을 지닌 사람들이, 도로의 좌측이 아닌 우측 운전이 도덕적(moral) 중요성을 부여하거나, 두 명의 증인이 있는 약속은 어겼을 때 죄책감을 느끼지만, 한 명의 증인만 있었을 경우에는 그렇지 않다고 여길 수도 있다. 이러한 낮은 형태의 도덕성이 가능하긴 하지만, 도덕이 다음과 같은 규칙을 논리적으로 포함할 수는 없다. 즉, 그 규칙이 따르는 이들에 의해 대안보다 더 낫다고 여겨지지 않으며, 내재적 중요성도 없다고 여겨지는 경우이다. 그러나 법은 도덕적으로 중요한 요소들을 포함함에도 불구하고, 바로 그와 같은 규칙들—즉, 내재적 중요성이 없고 대안과의 비교우위가 없으며, 형식성과 임의성(formality and arbitrariness)을 지닌 규칙들—을 포함할 수 있으며, 실제로 포함하고 있다. 이러한 규칙들은 도덕 규칙의 일부로는 이해되기 가장 어려운 것들이지만, 법에서는 자연스럽게 쉽게 이해될 수 있는 요소들이다. 왜냐하면 법의 전형적인 기능 중 하나는, 도덕과 달리, 확실성과 예측가능성(certainty and predictability)을 극대화하고, 청구(claim)의 입증이나 판단을 용이하게 하기 위해 형식성과 세부사항을 도입하는 것이기 때문이다. 형식과 세부사항에 대한 과도한 집착은, 법이 ‘형식주의(formalism)’ 또는 ‘법률주의(legalism)’라는 비판을 받게 하였지만, 이러한 비판들은 법의 고유한 특성(distinctive qualities)이 과장되어 나타난 결과일 뿐임을 기억하는 것이 중요하다.

우리가 유효(valid)하게 성립된 유언장(will)에 필요한 증인의 수를 도덕(morality) 규범이 아닌 국내법 체계(municipal legal system)에서 기대하듯이, 교전 중인 선박이 중립항에서 급유 또는 수리를 위해 체류할 수 있는 날짜 수, (p. 230) 영해(territorial waters)의 폭, 그리고 그 측정 방식 등과 같은 사안들은 도덕이 아니라 국제법에서 제공해주기를 기대하는 것도 이와 같은 이유에서이다. 이 모든 사항은 법규칙(legal rules)이 정하는 것이 필요하고 바람직한 사항이다. 그러나 이러한 규칙들이 여러 형태 중 하나를 임의적으로 택할 수 있다는 점, 또는 그것들이 특정 목적을 달성하기 위한 여러 수단 중 하나로서만 중요하다는 인식이 유지되는 한, 이 규칙들은 개인적 혹은 사회적 삶에서 도덕성(morality)의 특성을 갖는 규칙들과는 여전히 구별된다. 물론 국제법의 모든 규칙들이 이러한 형식적(formal), 자의적(arbitrary), 혹은 도덕적으로 중립적인 성격을 지니는 것은 아니다. 여기서의 핵심은, 법규칙은 이러한 성격을 가질 수 있지만(can), 도덕규칙은 그럴 수 없다는(cannot) 점이다.

국제법과 우리가 자연스럽게 도덕(morality)이라 여기는 것 사이의 성격 차이는 다른 측면에서도 드러난다. 어떤 실천을 요구하거나 금지하는 법이 결과적으로 한 집단의 도덕성에 변화를 초래할 수는 있지만, 도덕규칙을 제정하거나 폐지하는 입법자(legislature)의 개념 자체는, 제7장에서 살펴본 바와 같이, 부조리한 것이다. 입법자는 어떤 새로운 규칙을 입법 명령(fiat)으로 도입했다고 해서 그것에 도덕규칙의 지위를 부여할 수는 없다. 이는 마치 입법자가 동일한 방식으로 하나의 규칙에 전통(tradition)의 지위를 부여할 수 없는 것과 같다. 물론 두 경우의 불가능성에 대한 이유는 다를 수 있다. 따라서 도덕은 단순히 입법기관을 가지지 않거나(does not have) 우연히 가지지 않는 것이 아니라, 인간의 입법적 명령(fiat)에 의한 변화를 용납하지 않는다는 점에서 도덕 개념 자체에 위배된다. 그 이유는, 우리가 도덕을 입법행위든 그 밖의 행위든 간에 인간 행위(human actions)를 평가하는 최종 기준(ultimate standard)으로 간주하기 때문이다. 이에 비해 국제법은 명확히 대조된다. 국제법의 본질이나 기능에는 그 규칙들이 입법적 변경에 종속될 수 있다는 개념과 모순되는 어떠한 요소도 없다. 입법기관의 부재는 단순히 결함일 뿐이며, 많은 이들은 언젠가 그것이 보완될 수 있는 결함으로 간주한다.

끝으로, 국제법 이론에는 제9장에서 비판한 논증과 유사한 병렬 구조가 있다. 즉, 개별 국내법 규칙들이 도덕과 충돌할 수는 있지만, 그럼에도 불구하고 전체 체계(system)로서의 국내법은 일반적으로 확산된 도덕적 의무(moral obligation) 인식 위에 기반을 두고 있으며, 단지 특별한 예외적 상황에서만 그 의무가 무시될 수 있다는 주장이다. 국제법의 '기초(foundations)'에 관한 논의에서도, (p. 231) 결국 국제법의 규칙들은 그것을 준수해야 할 도덕적 의무가 있다고 하는 국가들의 확신(conviction)에 의존해야 한다(must)는 주장이 종종 제기되어 왔다. 그러나 이 주장이 단순히, 국가들이 인식하는 의무(obligations)가 공적으로 조직된 제재에 의해 강제되지 않는다는 점 이상을 의미한다면, 이를 받아들여야 할 이유는 없어 보인다. 물론 국제법이 요구하는 어떤 행위가 도덕적으로 의무적이라고 국가가 인식하고 그 이유로 행동하는 상황을 상정할 수는 있다. 예컨대, 하나의 국가는 조약(treaty)의 신뢰가 심각하게 훼손되면 인류에게 해악이 초래된다는 점을 고려하여, 또는 자신이 과거에 그 부담을 지우지 않고 혜택을 입은 규범체계(code)의 부담을 이번에는 공정하게 감당해야 한다는 인식에 따라, 불리한 조약상의 의무를 계속 이행할 수도 있다. 이처럼 도덕적 확신에 관한 동기나 사고, 감정이 누구의 것인지—즉 그 주체가 누구로 간주되어야 하는지—라는 문제는 이 자리에서 더 논의하지 않아도 된다.

그러나 그러한 도덕적 의무감(sense of moral obligation)이 존재할 수도 있다 (may)는 점을 인정하더라도, 그것이 국제법의 존재 조건으로서 반드시 존재해야 한다(must)는 주장을 정당화할 이유는 찾기 어렵다. 실제로 국제 실천에서는, 특정 규칙들이 일정한 희생을 감수하면서도 일관되게 존중되며, 그 규칙들을 근거로 하여 권리 청구가 공식적으로 제기되며, 규칙 위반자는 심각한 비판에 직면하고 보상 또는 보복 청구의 정당한 대상이 된다는 사실을 확인할 수 있다. 이는 국가들 사이에 의무를 부과하는 규칙(rules imposing obligations)이 존재한다는 주장을 뒷받침하기에 충분한 요소들이다. 어떤 사회에서든 '구속력 있는(binding)' 규칙이 존재함을 입증하는 것은 단지 사람들이 그것을 그러한 것으로 사유(thought of)하고, 말하며(spoken of), 그러한 방식으로 기능(function)하게끔 한다는 사실에 있다. 그 이상으로 무엇이 '기초(foundations)'로서 요구되는가? 그리고 만약 더 많은 것이 요구된다면, 왜 그것은 반드시 도덕적

의무(moral obligation)이어야만 하는가? 물론 국가들 사이의 관계에서 규칙이 존재하거나 기능하기 위해서는, 대다수의 국가들이 그 규칙을 수용(acceptance)하고 자발적으로 협력해야 한다는 점은 사실이다. 또한, 규칙을 위반하거나 위반 위협을 가하는 자에게 가해지는 압박은 종종 상대적으로 미약하고, 대체로 분산되어 있으며 조직화되어 있지 않다는 것도 사실이다. 그러나 이는 개인의 경우도 마찬가지다. 개인들도 훨씬 더 강제적인 국내법 체계를 자발적으로 수용한다. 그리고 그러한 체계를 자발적으로 지지하는 동기는 매우 다양할 수 있다. 어떤 형태의 (p. 232) 법질서도 일반적으로 그것을 따르는 것이 도덕적으로 의무라는 인식이 널리 퍼져 있을 때 가장 건강할 수는 있다. 그러나 법에의 복종(adherence)이 반드시 그러한 인식에서 비롯되는 것은 아니다. 그것은 장기적인 이익 계산, 전통 유지의 의지, 타인에 대한 사심 없는 관심 등으로부터 비롯될 수 있다. 이러한 동기들 중 어느 것도, 개인 간이든 국가 간이든, 법의 존재 조건으로 필수적인(necessary) 요소라고 식별해야 할 합당한 이유는 없다.

5. 형식 및 내용의 유사성(Analogies of Form and Content)

순진한 시각에서 볼 때, 입법기관, 강제 관할권을 지닌 법원, 공식적으로 조직된 제재수단이 결여된 국제법의 형식적 구조는 국내법(municipal law)과는 매우 다르게 보인다. 이는, 우리가 이미 언급한 바와 같이, 내용은 전혀 다르지만 형식 면에서는 일종의 일차적 또는 관습법(customary law) 체제와 유사하다. 그러나 일부 이론가들은 국제법이 '법(law)'이라는 명칭을 가질 자격을 회의론자들 앞에서 방어하려는 지나친 열망 속에서, 이러한 형식적 차이를 축소하려는 유혹에 빠졌고, 국내법의 바람직한 형식적 요소들과 국제법 사이에서 찾을 수 있는 유사성을 과장하게 되었다. 예컨대, 전쟁이 조약(treaty)으로 종결되어 패전국이 영토를 양도하거나, 의무(obligations)를 수락하거나, 일정한 제한된 형태의 독립을 받아들이는 경우, 이는 본질적으로 입법적 행위(legislative act)이며, 왜냐하면 입법과 마찬가지로 이는 법적 변화를 강제하는 것이기 때문이라고 주장되어 왔다. 그러나 이제는 거의 누구도 이와 같은 유비에 감명을 받지 않으며, 그것이 국제법이 국내법과 동등하게 '법'이라 불릴 자격을 지닌다는

점을 입증하는 데 도움이 된다고 생각하지 않는다. 그 이유는, 국내법과 국제법 사이의 두드러진 차이점 중 하나는 전자가 보통 폭력에 의해 강제된 합의의 유효성(validity)을 승인(recognition)하지 않는 반면, 후자는 이를 승인한다는 데 있다.

보다 타당한 유비들이 국제법이 ‘법’이라는 명칭을 가질 자격이 있다고 보는 이들에 의해 강조되어 왔다. 국제사법재판소(International Court)와 그 전신인 국제연맹의 국제사법재판소(Permanent Court of International Justice)의 판결이 거의 모든 경우에 당사자들에 의해 성실히 이행되었다는 점은 종종 강조되어 왔는데, 이는 국내법 법원과 달리 어떤 국가도 자발적 동의 없이 이들 국제재판소에 회부될 수 없다는 사실을 상쇄할 수 있다는 암묵적 전제 하에 이루어진 것이다. 또한, (p. 233) 국내법에서의 제재(sanction)로서 법적으로 규율되고 공식적으로 집행되는 물리력의 사용과, 국제법상 권리가 다른 국가에 의해 침해되었다고 주장하는 국가가 전쟁이나 강제적 보복에 호소하는 ‘탈중앙화된 제재(decentralized sanctions)’ 사이의 유사성도 지적되어 왔다. 물론 일정한 유사성이 존재하는 것은 명백하다. 그러나 그 의미는, 국내법 법원이 ‘자력구제(self-help)’의 권리성과 위법성을 조사할 강제 관할권(compulsory jurisdiction)을 지니고 있으며, 위법한 자력구제는 처벌될 수 있다는 사실과, 국제법 법원은 이에 상응하는 권한을 가지지 못한다는 점을 감안할 때 신중히 평가되어야 한다.

이러한 의심스러운 유비들 중 일부는 유엔 헌장(United Nations Charter) 하에서 국가들이 수락한 의무(obligations)들로 인해 상당히 강화되었다고 볼 수도 있다. 그러나 이 유비들의 타당성을 평가할 때, 그 힘은 유엔 헌장의 법집행 조항들이 문서상으로는 훌륭하나, 거부권(veto)과 강대국들 사이의 이념적 분열 및 동맹관계로 인해 실제로는 마비되어 있다는 점을 간과한다면 그 평가는 아무런 의미가 없다. 이와 관련하여, 국내법의 법집행 조항 역시 총파업과 같은 사태로 인해 마비될 수도 있다(might)는 반론이 제기되기도 하지만, 이는 그다지 설득력 있지 않다. 왜냐하면 우리가 국내법과 국제법을 비교할 때 초점을 두는 것은 실제로 존재하는 사태들이며, 이 점에서 사실(fact)은 명백히 다르기 때문이다.

그럼에도 불구하고, 국제법과 국내법 사이에 제기된 한 가지 형식적 유사성

은 여기서 검토해볼 가치가 있다. 켈젠(Hans Kelsen)과 많은 현대 이론가들은 국제법도 국내법처럼 ‘기초규범(basic norm)’, 혹은 우리가 ‘승인규칙(rule of recognition)’이라 부르는 것을 지니고 있으며, 다른 규칙들의 유효성(validity)이 그에 따라 평가되고, 그 규칙들로 하여금 하나의 통일된 체계(system)를 구성하게 한다고 주장한다. 이에 반대되는 견해는 이러한 구조적 유비가 거짓이라고 본다. 국제법은 단순히 하나의 체계(system)가 아니라 상호 분리된 의무규칙(primary rules of obligation)들의 집합(set)에 불과하다는 것이다. 국제법은 전통적인 국제법 용어로는 일종의 관습규칙(customary rules)의 집합이며, 조약에 구속력을 부여하는 규칙도 이들 중 하나일 뿐이다. 국제법의 ‘기초규범’을 공식화하려는 시도가 매우 큰 어려움에 직면해 있다는 것은 잘 알려져 있다. 이 자리를 차지하기 위한 후보 중에는 pacta sunt servanda(약속은 지켜져야 한다)는 원칙이 있었다. 그러나 이 원칙은 국제법상 모든 의무가 (p. 234) 약속(pacta)에서 발생하는 것이 아니라는 점에서, 그리고 이 용어의 의미를 아무리 확장하여 해석하더라도 결국은 모순된다는 이유로 대부분의 이론가들에 의해 폐기되었다.

그 결과로 보다 생소한 명제, 즉 ‘국가는 그들이 관습적으로 해온 방식대로 행동해야 한다’는 소위 규칙이 제안되기에 이르렀다. 이러한 국제법상의 기초 규범에 대한 상이한 정의들의 장단점에 대해 논의하기보다는, 우리는 그러한 요소가 반드시 있어야 한다는 전제(assumption) 자체를 문제삼을 것이다. 여기서 우리가 던질 첫 번째이자 마지막 질문은 다음과 같다: 왜 우리는 이와 같은 선험적(a priori) 전제를 도입하여 국제법의 실제적 성격에 대해 판단을 미리 결정해야 하는가? 왜냐하면 어떤 사회가 구성원들에게 의무(obligation)를 부과하는 규칙들을 ‘구속력 있는(binding)’ 것으로 수용하고 따르면서도, 그것들이 더 근본적인 규칙에 의해 통일되거나 유효성을 부여받는 것이 아니라 단순한 개별 규칙들의 집합(set)으로 간주되는 경우는 충분히 상정할 수 있으며, 실제로 과거에도 그랬을 가능성이 있기 때문이다. 규칙들이 존재한다고 해서 반드시 근본 규칙(basic rule)이 존재해야 하는 것은 아니다. 대부분의 현대 사회에는 예절(etiquette)의 규칙들이 존재하지만, 우리는 그것이 의무를 부과한다고 보지 않음에도 불구하고 그러한 규칙들이 ‘존재한다’고 말할 수 있다. 그러나 우리는

그러한 예절규칙 각각의 유효성을 그로부터 도출할 수 있는 기초규칙을 찾거나 찾을 필요도 없다. 이러한 규칙들은 하나의 체계를 이루지 않고 단지 집합(set)에 불과하다. 물론 예절보다 훨씬 더 중요한 사안이 관련된 경우에는 이와 같은 형태의 사회적 통제가 지니는 불편함은 매우 클 수 있으며, 이에 대해서는 이미 제5장에서 설명한 바 있다. 그러나 만약 규칙들이 실제로 행위의 기준(standards of conduct)으로서 수용되고, 의무규칙의 고유한 사회적 압력(social pressure) 양식들에 의해 지지된다면, 그러한 규칙들은 비록 국내법에서와 같이 시스템 내부의 궁극적 규칙에 비추어 개별 규칙의 유효성을 입증할 수 있는 방식이 존재하지 않더라도, 구속력 있는 규칙(binding rules)이라고 간주하기에 충분하다.

물론, 하나의 체계(system)가 아니라 단순한 집합(set)으로 구성된 규칙들에 대해서도 여러 가지 질문을 제기할 수 있다. 예컨대, 우리는 해당 규칙들의 역사적 기원에 대해, 혹은 그 규칙들의 성장을 촉진시킨 인과적 요인(causal influences)에 대해 물을 수 있다. 또한, 그 규칙들이 그에 따라 살아가는 사람들에게 어떤 가치를 지니는지, 그리고 그들이 스스로를 도덕적으로 따를 의무(obligation)가 있다고 여기는지, (p. 235) 아니면 다른 동기에 따라 따르는지에 대해 질문할 수 있다. 그러나 단순한 규칙의 집합에 대해서는, 근본 규범(basic norm) 또는 승인규칙(rule of recognition)과 같은 이차적 규칙(secondary rule)에 의해 풍부하게 구성된 하나의 체계—예컨대 국내법(municipal law)—의 규칙들에 대해 우리가 제기할 수 있는 한 종류의 질문을 던질 수 없다. 즉, 단순한 규칙집합의 경우에는 다음과 같은 질문을 던질 수 없다: ‘이 각각의 규칙들은 체계 내의 어떤 궁극적 조항으로부터 그 유효성(validity) 또는 “구속력(binding force)”을 도출하는가?’ 왜냐하면 그러한 조항이 존재하지 않으며, 존재할 필요도 없기 때문이다. 따라서, 기초규칙 또는 승인규칙이 의무규칙(rules of obligation) 또는 구속력 있는 규칙(binding rules)의 존재에 대한 일반적인 필요조건이라고 간주하는 것은 오류이다. 그것은 필수적인 것이 아니라 사치재(luxury)로서, 고도화된 사회(social systems)에서 발견되는 특성이다. 그러한 사회에서는 구성원들이 단순히 개별 규칙을 하나씩 받아들이는 데 그치지 않고, 일반적인 유효성 기준(general criteria of validity)에 따라 구분된 일반적

규칙유형의 수용(acceptance)을 선행적으로 약속한다. 반면, 단순한 형태의 사회에서는 어떤 규칙이 규칙으로서 수용될지를 ‘기다려 보고’ 판단해야 한다. 그러나 승인규칙(rule of recognition)이 존재하는 체계에서는, 어떤 규칙이 실제로 제정되기 전에도 다음과 같이 말할 수 있다: “그 규칙이 승인규칙의 요건에 부합(conform)한다면(if), 유효(valid)할 것이다(will).”

같은 요점을 다른 형식으로도 제시할 수 있다. 만약 단순한 개별 규칙들의 집합에 승인규칙과 같은 것이 추가된다면, 그것은 단지 체계성과 규칙 식별의 용이성이라는 이점을 제공할 뿐만 아니라, 처음으로 새로운 형식의 진술(statement)을 가능하게 만든다. 그것은 바로 규칙의 유효성(validity)에 대한 내적 진술(internal statements)이다. 이제 우리는 새로운 의미에서 다음과 같이 물을 수 있다: ‘이 규칙을 구속력 있게 만드는 체계의 조항은 무엇인가?’ 또는 켈젠(Kelsen)의 용어로 표현하자면, ‘체계 내에서 이 규칙의 유효성의 이유(reason)는 무엇인가?’ 이 새로운 질문들에 대한 대답은 승인규칙(rule of recognition)에 의해 제공된다. 그러나 단순한 구조에서는, 규칙의 유효성은 그보다 더 근본적인 어떤 규칙에 대한 참조를 통해 입증될 수 없다는 점을 인정하더라도, 이것이 규칙들 또는 그것들의 구속력(binding force)이나 유효성(validity)에 관해 어떤 설명되지 않은 의문이 남는다는 것을 의미하지는 않는다. 즉, 단순한 사회 구조에서 규칙들이 왜 구속력을 지니는가에 대한 어떤 미스터리가 존재하며, 그것이 기초규칙(basic rule)을 찾기만 하면 해결될 수 있으리라는 식의 주장은 사실이 아니다. 더 고도화된 체계의 기초규칙처럼, 단순한 구조의 규칙들 역시 수용(acceptance)되고 그러한 기능을 수행한다면, 그것은 곧 구속력(binding)을 지닌 것이다. 그러나 이러한 사회 구조의 다양한 형태에 관한 단순한 진실들은, 이러한 바람직한 요소들(체계성이나 통일성)이 (p. 236) 실제로 존재하지 않는 상황에서 이를 억지로 찾으려는 완고한 시도로 인해 쉽게 가려질 수 있다.

실제로, 가장 단순한 사회 구조에서 기초규칙을 인위적으로 만들어내려는 노력은 어딘가 우스꽝스럽다. 그것은 마치 우리가 옷을 입지 않은 원시인을 보면서, 실제로는 현대식 복장을 어떤 보이지 않는 형태로 입고 있어야만 한다(must)고 주장하는 것과 같다. 불행히도, 여기에는 지속적인 혼동의 가능성도 존재한다. 우리는, (개인 혹은 국가들로 구성된) 특정 사회가 어떤 행위 기준

(standards of conduct)을 의무적 규칙(obligatory rules)으로서 준수하고 있다는 단순한 사실을, 기초규칙으로 잘못 간주하게 될 수도 있다. 실제로 국제법에서 제안된 기이한 기초규범이 그러한 예인데, 그 내용은 다음과 같다: ‘국가는 관습적으로 해온 방식대로 행동해야 한다.’ 그러나 이 명제는 결국, 특정 규칙을 수용(acceptance)한 자는 그 규칙들이 준수되어야 한다는 규칙 또한 수용해야 한다는 말을 반복하는 것에 지나지 않는다. 이것은 단지, 국가들이 어떤 규칙들을 구속력 있는 것으로 수용한다는 사실을 무익하게 반복한 것일 뿐이다.

다시 말해, 우리가 국제법에 어떤 근본 규칙(a basic rule)이 반드시 포함되어야 한다(must)는 전제에서 벗어난다면, 직면해야 할 문제는 사실의 문제(factual question)이다. 즉, 국가들 사이의 관계에서 실제로 작동하는 규칙들의 성격은 어떤가? 물론, 관찰되는 현상에 대한 해석은 다를 수 있다. 그러나 여기서 제출되는 주장은 다음과 같다: 국제법의 규칙들은 그 유효성에 대한 일반적인 기준을 제공하는 기초규칙을 가지고 있지 않으며, 실제로 작동하는 규칙들은 체계(system)를 이루는 것이 아니라, 조약(treaty)에 구속력을 부여하는 규칙들을 포함한 단순한 집합(set)일 뿐이다. 물론 많은 중요한 사안들에서 국가 간의 관계는 다자간 조약(multilateral treaties)에 의해 규율되며, 때로는 이러한 조약이 비당사국(non-party states)에게도 구속력을 미친다고 주장되기도 한다. 만약 이 주장이 일반적으로 승인된다면, 그러한 조약은 실제로 입법적 제정(legislative enactments)이 될 것이고, 국제법은 그 규칙들에 대해 명확한 유효성 기준을 갖게 될 것이다. 이 경우 하나의 승인규칙(rule of recognition)을 공식화할 수 있게 되며, 그것은 단순히 “국가들이 어떤 규칙을 준수하고 있다”는 사실을 반복하는 것이 아닌, 체계의 실제적 특징(actual feature)을 나타내는 것이 될 것이다. 아마도 국제법은 현재, 이러한 제도들—즉 국제법의 구조를 국내법(municipal law) 체계에 더 가까이 이끄는—의 수용을 향해 과도기적 단계(stage of transition)에 있는지도 모른다. 만약, (p. 230) 그리고 이 과도기가 완료될 때, 지금으로서는 빈약하고 기만적으로 보일 수도 있는 형식상의 유비(analogy of form)들은 실질을 갖게 될 것이며, 국제법의 법적 ‘성질(quality)’에 대한 회의론자의 마지막 의혹도 사라지게 될 것이다. 그러나 그 단계에 이르기 전까지, 유사성은 분명히 형식(form)이 아닌 기능(function)과 내용(content)에 속한다.

기능적 유사성은 국제법이 도덕(morality)과 어떻게 구별되는지를 성찰할 때 가장 명확히 드러나며, 그 중 일부는 앞 절에서 검토한 바 있다. 내용상의 유사성은 국내법과 국제법 모두에 공통되는 원칙(principles), 개념(concepts), 방법(methods)의 범위에 있다. 이것이 법률가의 기술이 양자의 영역을 자유롭게 넘나들 수 있게 만드는 이유이다. '국제법(international law)'이라는 표현을 처음 고안한 벤담(Jeremy Bentham)은 단지 그것이 '국내법과 충분히 유사하다(sufficiently analogous)'는 이유만으로 그 표현을 정당화하였다³⁵. 여기에 우리는 아마 두 가지 논평을 덧붙일 수 있을 것이다. 첫째, 그 유사성은 형식(form)이 아니라 내용(content)의 유사성이라는 점이다. 둘째, 내용상의 유사성에서, 국제법만큼 국내법과 밀접한 사회규칙은 없다는 점이다.

³⁵Principles of Morals and Legislation, XVII. 25, n. 1.

CHAPTER X 주석

Page 214. ‘국제법은 정말 법인가?’ — 이것이 단지 사실문제로 오인된 언어적 질문에 불과하다는 견해는 Glanville Williams, 앞서 인용, 22 *BYBIL* (1945)을 참조하라.

Page 215. 의문에 대한 근원들(*Sources of doubt*). — 건설적인 일반적 개관으로는 A. H. Campbell, ‘International Law and the Student of Jurisprudence’ in 35 *Grotius Society Proceedings* (1950); Gihl, ‘The Legal Character and Sources of International Law’ in *Scandinavian Studies in Law* (1957)을 참조하라.

Page 216. ‘국제법은 어떻게 구속력을 가지는가?’ — 이 질문(때로는 국제법의 구속력(binding force)에 관한 문제로 언급됨)은 Fischer Williams, *Chapters on Current International Law*, pp. 11–27; Brierly, *The Law of Nations*, 제5판 (1955), 제2장; *The Basis of Obligation in International Law* (1958), 제1장을 참조하라. 또한 Fitzmaurice, ‘The Foundations of the Authority of International Law and the Problem of Enforcement’ in 19 *MLR* (1956)을 참조하라. 이들 저자들은 규칙 체계가 구속력 있는(binding) 것이라는 주장 또는 그렇지 않다는 주장 자체의 의미를 명시적으로 논의하지는 않는다.

Page 217. 국제법에서의 제재(*Sanctions*). — 국제연맹 규약(*League of Nations Covenant*) 제16조 하에서의 상황은 Fischer Williams, ‘Sanctions under the Covenant’ in 17 *BYBIL* (1936)을 참조하라. 유엔 헌장 제7장 하에서의 제재에 관해서는 Kelsen, ‘Sanctions in International Law under the Charter of U.N.’, 31 *Iowa LR* (1946), 그리고 Tucker, ‘The Interpretation of War under present International Law’, 4 *The International Law Quarterly* (1951)을 참조하라. 한국전쟁에 대해서는 Stone, *Legal Controls of International Conflict* (1954), 제9장, 담론 14(Discourse 14)를 참조하라. ‘평화를 위한 단결(유엔총회 결의)’이 유엔이 ‘마비되었다(paralyzed)’는 주장을 반박하는 것이라는 해석도 가능하다.

Page 220. 국제법이 의무적(*obligatory*)이라고 생각되고 말해지는 방식. — Jessup, *A Modern Law of Nations*, 제1장, 그리고 ‘The Reality of International Law’, 118 *Foreign Affairs* (1940)을 참조하라.

Page 220. 국가의 주권(*The Sovereignty of States*). — ‘주권은 단지 국제 영역 중 국가의 개별 행위에 맡겨진 부분에 부여된 이름일 뿐이다’라는 견해에 대한 명료한 설명은 Fischer Williams, 앞서 인용, pp. 10–11, 285–99, *Aspects of Modern International Law*, pp. 24–26, 그리고 Van Kleffens, ‘Sovereignty and International Law’, *Recueil des Cours* (1953), I, pp. 82–83을 참조하라.

Page 221. 국가 개념(*The State*). — ‘국가(state)’의 개념과 종속국(dependent states)

의 유형에 대해서는 Brierly, *The Law of Nations*, 제4장을 참조하라.

Page 224. 의지주의(voluntarist) 및 자기제한(auto-limitation) 이론들. — 주요 저자들은 Jellinek, *Die Rechtliche Natur der Staatsverträge*; Triepel, 'Les Rapports entre le droit interne et le droit internationale', *Recueil des Cours* (1923)이 있다. 극단적인 견해는 Zorn, *Grundzüge des Völkerrechts*에 나타나며, 이에 대한 비판적 논의는 Gihl, 앞서 인용, *Scandinavian Studies in Law* (1957); Starke, *An Introduction to International Law*, 제1장; Fischer Williams, *Chapters on Current International Law*, pp. 11-16을 참조하라.

Page 224. 의무(obligation)와 동의(consent). — 한 국가가 국제법의 어떤 규칙에도 그 사전 동의(명시적이든 묵시적이든) 없이는 구속되지 않는다는 견해는 영국 법원에서 표현되었으며(R. v. Keyn 1876, 2 Ex. Div. 63, 'The Franconia' 사건), 국제사법재판소(PCIJ)에서도 제기되었다. 이에 관해서는 *The Lotus*, PCIJ Series A, No. 10을 참조하라.

Page 226. 신생국 및 해양영역을 획득한 국가들. — 이에 대해서는 Kelsen, *Principles of International Law*, pp. 312-13을 참조하라.

Page 226. 비당사국(non-parties)에 대한 일반 국제조약의 효력. — 이에 대해서는 Kelsen, 앞서 인용, pp. 345 ff.; Starke, 앞서 인용, 제1장; Brierly, 앞서 인용, 제7장, pp. 251-2를 참조하라.

Page 227. '도덕성(morality)'이라는 용어의 포괄적 사용. — 이에 대해서는 Austin, *The Province* 제5강(Lecture V), pp. 125-9, 141-2에서 '실정적 도덕(positive morality)'에 관한 논의를 참조하라.

Page 230. 국제법을 준수할 도덕적 의무(moral obligation). — 이것이 국제법의 '기초'라고 보는 견해는 Lauterpacht, Brierly의 *The Basis of Obligation in International Law* 서문(xviii), 그리고 Brierly, 같은 책 제1장을 참조하라.

Page 232. 강제에 의해 체결된 조약을 입법으로 간주하는 문제. — 이에 대해서는 Scott, 'The Legal Nature of International Law', *American Journal of International Law* (1907), pp. 837, 862-4를 참조하라. 일반 조약을 '국제 입법(international legislation)'이라고 부르는 통상적 표현에 대한 비판은 Jennings, 'The Progressive Development of International Law and its Codification', *24 BYBIL* (1947), p. 303에서 확인할 수 있다.

Page 233. 비집중적 제재(decentralized sanctions). — 이에 대해서는 Kelsen, 앞서 인용, p. 20; Tucker, 앞서 인용, *4 International Law Quarterly* (1951)을 참조하라.

Page 233. 국제법의 근본 규범(basic norm). — 이를 *pacta sunt servanda*로 공식화한 논의는 Anzilotti, *Corso di diritto internazionale* (1923), p. 40을 참조하라. 이를 '국가는 관습적으로 해온 대로 행동해야 한다'는 식으로 대체하려는 논의는 Kelsen, *General*

Theory, p. 369, 그리고 *Principles of International Law*, p. 418을 참조하라. 이에 대한 중요한 비판적 논의는 Gihl, *International Legislation* (1937) 및 *Scandinavian Studies in Law* (1957), pp. 62 ff.에 있다. 국제법에 기초규범이 없다는 해석을 보다 폭넓게 전개한 논의로는 Ago, 'Positive Law and International Law', *51 American Journal of International Law* (1957), *Scienza giuridica e diritto internazionale* (1958)을 참조하라. Gihl은 국제사법재판소 규정 제38조에도 불구하고 국제법은 공식적인 법적 근원을 갖지 않는다고 결론짓는다. 국제법에 대해 하나의 '초기 가설(initial hypothesis)'을 제시하려는 시도로서, 본문에서 지적된 것과 유사한 비판에 노출될 수 있는 견해는 Lauterpacht, *The Future of Law in the International Community*, pp. 420-3을 참조하라.

Page 237. 국제법과 국내법 간의 내용상의 유사성(*analogy of content*). — 이에 대해서는 Campbell, 앞서 인용, *35 Grotius Society Proceedings* (1950), p. 121 *ad fin.*, 그리고 조약(treaties), 영토취득(acquisition of territory), 시효(prescriptions), 임대(leases), 위임(mandates), 용익권(servitudes) 등에 관한 규칙들을 논의한 Lauterpacht, *Private Law Sources and Analogies of International Law* (1927)을 참조하라.

CHAPTER X 제3판 주석

Pages 220-226. 주권국가와 국제법(*Sovereign states and international law*) 국제법의 제약과 주권(sovrenignty)의 양립 가능성에 관해서는 Timothy Endicott, 「The Logic of Freedom and Power」, Samantha Besson 및 John Tasioulas 편, *The Philosophy of International Law* (Oxford University Press, 2010)을 참조하라. 국가의 주권(state sovereignty)과 법의 지배(rule of law) 간의 관계에 대해서는 Jeremy Waldron, 「The Rule of International Law」, (2006) *Harvard Journal of Law and Public Policy* 제30권, 15쪽을 참조하라. 초국가적 권위(transnational authority)의 다양한 등장 형태에 비추어 주권 개념을 재해석하려는 시도에 대해서는 Neil MacCormick, *Questioning Sovereignty*를 참조하라. 현대 세계에서 '주권국가'의 사실상의 권력(de facto power)에 대한 회의적 견해는 Saskia Sassen, *Losing Control? Sovereignty in an Age of Globalization* (Columbia University Press, 1996)을 참조하라.

Pages 227-232. 국제법과 도덕성(*International law and morality*) 국제 영역에서 정의의 원칙들(principles of justice)의 적용에 대한 매우 영향력 있는 논의는 John Rawls, *The Law of Peoples* (Harvard University Press, 1999)을 참조하라. 또한 Allen Buchanan, *Justice, Legitimacy, and Self-Determination: Moral Foundations for International Law* (Oxford University Press, 2003)을 참조하라. 국가들이 국제법에 실제로(*compliance*), 그리

고 마땅히(*ought to*) 자국의 국익(*national self-interest*)을 증진시키기 위해서만 순응해야 한다는 ‘현실주의(*realist*)’ 관점에 대해서는 Jack L. Goldsmith 및 Eric A. Posner, *The Limits of International Law* (Oxford University Press, 2005)를 참조하라.

Pages 232–237. 형식 및 내용상의 유사성(*Analogies of form and content*) Hart가 저술 하던 시기에 비해 오늘날의 국제법은 더욱 체계화되었다는 제안에 대해서는 Samantha Besson 및 John Tasioulas가 편집한 *The Philosophy of International Law* 서문의 ‘Introduction’과 그에 인용된 자료들을 참조하라. 또한 Allen Buchanan 및 David Golove, 「Philosophy of International Law」 in Jules L. Coleman 및 Scott Shapiro 편, *The Oxford Handbook of Jurisprudence and Philosophy of Law*를 참조하라.

후기(POSTSCRIPT)

서론(INTRODUCTORY)

이 책이 처음 출판된 지 32년이 지났다. 그 사이 법이론(jurisprudence)과 철학은 훨씬 더 가까워졌으며, 법이론(legal theory)이라는 주제는 이 나라와 미국 모두에서 크게 발전하였다. 이 책이 그러한 발전을 자극하는 데에, 적어도 일부 역할을 했기를 바란다. 비록 학계의 법학자들과 철학자들 사이에서는 이 책의 주요 명제들에 대한 비판자들이 그에 동의하는 이들만큼이나 많았을지라도 말이다. 어쨌든, 나는 이 책을 원래는 영국의 학부생 독자들을 염두에 두고 썼지만, 이 책은 훨씬 더 널리 유통되었고, 영어권 세계뿐 아니라 여러 번역서가 출간된 나라들에서 방대한 부차적 문헌과 비평적 논의를 낳았다. 이러한 비평적 문헌의 상당수는 법학 및 철학 저널에 실린 논문들이지만, 그 외에도 이 책의 다양한 명제들을 비판의 대상으로 삼거나 자신의 법이론을 전개하는 출발점으로 삼은 중요한 단행본들이 출판되었다.

나는 내 비판자들 가운데 특히 고(故) 론 풀러(Lon Fuller) 교수¹와 R. M. 드워킨 교수²에게 약간의 반격을 가하긴 했지만, 지금까지는 그 누구에게도 포괄적이고 일반적인 답변을 하지 않았다. 나는 비판자들 사이에서도 서로 간의 견해차가 나와의 견해차만큼 크다는 점에서, 매우 유익한 지속적 논쟁을 지켜보고 배우는 쪽을 선호했다. 하지만 이번 후기에서는 드워킨이 그의 대표적 논문 모음집 *Taking Rights Seriously* (1977)와 *A Matter of Principle* (1985), 그리고

¹그의 *The Morality of Law* (1964)에 대한 나의 서평을 보라, *Harvard Law Review* 제78권 (1965) 1281면. 이 글은 *Essays in Jurisprudence and Philosophy* (1983)에도 재수록됨, 343면. [주: 대괄호로 표시된 각주는 편집자들이 추가한 것임.]

²나의 다음 글을 참조하라: “Law in the Perspective of Philosophy: 1776–1976”, *New York University Law Review* 제51권 (1976) 538면; “American Jurisprudence through English Eyes: The Nightmare and the Noble Dream”, *Georgia Law Review* 제11권 (1977) 969면; “Between Utility and Rights”, *Columbia Law Review* 제79권 (1979) 828면. 이들 모두 *Essays in Jurisprudence and Philosophy*에 재수록되어 있다. 또한, “Legal Duty and Obligation”, *Essays on Bentham* (1982)의 제6장, 그리고 R. Gavison 편, *Issues in Contemporary Legal Philosophy* (1987) 수록 “Comment” (35면)를 참조하라.

저서 *Law's Empire* (1986)³에서 제기한 광범위한 비판에 대해 응답하고자 한다. 나는 이 후기에서 주로 드워킨의 비판에 초점을 맞추는데, 그 이유는 그가 이 책의 거의 모든 핵심 명제가 근본적으로 잘못되었다고 주장할 뿐 아니라, 이 책에 암묵적으로 내재된 법이론의 개념 자체와 법이론이 수행해야 할 역할 전체를 문제 삼기 때문이다. 드워킨의 반론은 수년 동안 대체로 일관된 틀을 유지해 왔지만, 그 중 일부는 내용상 변화가 있었고 사용된 용어도 달라졌다. 그의 초기 논문에서 두드러졌던 일부 비판은 후속 저작들에서는 더 이상 등장하지 않지만, 명시적으로 철회된 것도 아니다. 이러한 초기 비판들은 널리 퍼져 강력한 영향력을 발휘해왔기에, 나는 그의 후속 비판들과 함께 이에 대해서도 응답할 필요가 있다고 판단하였다. 이 후기의 첫 번째이자 더 긴 부분은 드워킨의 논변들에 대한 응답에 해당하며, 두 번째 부분에서는 다른 여러 비판자들이 제기한 주장들—즉 내가 내 명제들을 전개함에 있어 불명료하거나 부정확할 뿐 아니라, 실제로는 모순되거나 비일관적인 점들이 있다는 주장들—을 다룬다.⁴ 이 점에 대해서 나는, 생각보다 많은 사례에서 비판자들이 옳았음을 인정하지 않을 수 없으며, 이 후기를 통해 그러한 불명료함을 명확히 하고, 모순되거나 부정합한 부분은 원래 서술을 수정할 기회를 삼고자 한다.

1. 법이론의 본성(THE NATURE OF LEGAL THEORY)

이 책에서의 나의 목표는 법(law)이란 무엇인가에 대한 이론을 제시하는 것이었으며, 그것은 일반적(general)이면서 기술적(descriptive)인 것이다. 그것이 일반적(general)이라는 것은 특정한 법체계나 법문화에 국한되지 않고, 규칙(rule)에 의해 지배되는(그 점에서 '규범적(normative)'인) 복합적 사회·정치 제도로서의 법(law)을 설명하고 명료화하려는 시도라는 의미이다. 이 (p. 240) 제도는 다양한 문화와 시대에 따라 다채로운 변형을 보이지만, 동일한 일반적 형태와 구조를 띠어 왔으며, 이에 대해 명료화를 요구하는 오해들과 신화들이 뒤섞여왔다. 이러한 명료화 작업의 출발점은, 본서 3쪽에서 내가 “어느 정도 교양 있는 사람”이라면 누구나 공통적으로 알고 있을, 근대적 국내법제도(modern

³이하에서는 각각 TRS, AMP, LE로 인용함.

⁴[하트는 본 절에서 언급된 두 개 절 중 두 번째를 완성하지 못함. 편집자 주 참조.]

municipal legal system)의 두드러진 특징들에 대한 보편적 지식을 전제로 한다. 이러한 설명은 기술적(descriptive)이다. 즉, 도덕적으로 중립적이며 어떤 정당화 목적도 지니지 않는다. 다시 말해, 이 이론은 내가 일반적으로 기술한 법의 형태나 구조를 도덕적 또는 그 밖의 근거에 따라 정당화하거나 찬성하려 하지 않는다. 하지만 나는 그러한 법의 구조를 명확하게 이해하는 것이, 법(the law)에 대한 유익한 도덕적 비판을 수행하는 데에 선행 조건이 된다고 본다.

이러한 기술적 작업을 수행하기 위해 나는 다음과 같은 여러 개념들을 반복적으로 사용한다. 의무를 부과하는 규칙(duty-imposing rules), 권한을 부여하는 규칙(power-conferring rules), 승인규칙(rule of recognition), 변경규칙(rule of change), 규칙의 수용(acceptance of rules), 내적 관점과 외적 관점(internal and external points of view), 내적 진술과 외적 진술(internal and external statements), 법적 유효성(legal validity) 등이 그것이다. 이 개념들은 다양한 법적 제도와 법적 실천을 분석하는 데 있어 주목해야 할 요소들에 주의를 집중시키며, 그러한 제도와 실천에 대한 성찰로부터 촉발된 법의 일반적 성격에 관한 여러 질문들에 대해 설명할 수 있도록 돕는다. 이러한 질문들은 다음과 같다. 규칙이란 무엇인가? 규칙은 단순한 습관(habit)이나 행위의 규칙성(regularity)과 어떻게 다른가? 법적 규칙에는 본질적으로 서로 다른 유형들이 존재하는가? 규칙들은 어떤 방식으로 상호 관련될 수 있는가? 규칙들이 하나의 체계를 구성한다는 것은 무엇인가? 법적 규칙과 그 권위는 위협(threat)이나 도덕적 요구(moral requirements)와 어떤 관계를 가지는가?⁵

이와 같은 방식으로 기술적이고 일반적인 법이론을 구성하려는 작업은, 드워킨이 이해하는 법이론(그는 종종 이를 ‘법철학(jurisprudence)’이라 부른다)—즉 평가적이고 정당화적인 성격을 지니며, 대개 이론가 자신의 법문화, 드워킨의 경우에는 영미법(Anglo-American law)에 초점을 맞춘 이론—과는⁶ 근본적으로 다른 과제이다. 드워킨에 따르면, 이러한 법이론의 중심 과제는 ‘해석적(interpretive)’이라고 불리며,⁷ 이는 일부분 평가적이기도 하다. 왜냐하면

⁵H. L. A. Hart, “Comment”, 위의 Gavison 편, 주석 2, 35면.

⁶LE 102면.

⁷LE 제3장.

이는 법체계의 정착된 실천과 법(the law)과 가장 잘 부합하고 조화를 이루는 원칙들(principles)을 식별하고, 동시에 그것들에 대한 최선의 도덕적 정당화(moral justification)를 제공하려는 시도를 포함하기 때문이다. 즉, 법을 ‘최상의 모습으로 보여주는(showing the law in its best light)’ 것이다.⁸ 드워킨에게 있어서 이렇게 식별된 원칙들은 단지 법에 대한 이론의 일부일 뿐만 아니라, 법(the law) 자체에 암묵적으로 포함되어 있는 구성 요소이기도 하다. 그래서 그는 “법철학(Jurisprudence)은 판결의 일반 이론이며, 법적 결정(law)을 내리기 위한 침묵의 서곡”이라고 말한다.⁹ 그의 초기 저작에서는 이러한 원칙들이 단순히 “가장 건전한 법이론(the soundest theory of law)”으로 불렸지만,¹⁰ 그의 후기 저작 Law's Empire에서는 이러한 원칙들과 그로부터 도출되는 개별 법명제들(propositions of law)이 ‘해석적 의미에서의 법(law in an interpretive sense)’이라고 묘사된다. 이 해석이 적용되어야 하는 법의 정착된 실천 또는 전형(paradigms)은 드워킨에 의해 ‘전(前)해석적(preinterpretive)’이라 불리며,¹¹ 이론가는 그러한 전해석적 자료를 식별하는 데 있어 아무런 어려움도 없으며, 이 점에 대해 별도의 이론적 과제를 수행할 필요도 없다고 여겨진다. 이러한 자료들은 특정한 법체계에서 법률가들 간의 일반적 합의(general consensus)에 의해 정착된 것이기 때문이다.¹²

그렇다면 왜 나의 작업과 드워킨(Dworkin)의 법이론(legal theory) 구상처럼 서로 다른 과제들 사이에 중대한 충돌이 있어야 하며, 실제로 존재할 수 있는지 명확하지 않다. 드워킨의 많은 작업, Law's Empire를 포함하여, 법(law, ‘과거의 정치적 결정들’)¹³이 어떻게 강제를 정당화하는지를 설명하려는 세 가지 서로 다른 설명방식의 비교 우위에 대한 정교한 논의로 이루어져 있으며, 그는 이 세 가지 법이론을 각각 ‘관행주의(conventionalism)’, ‘법적 실용주의(legal

⁸LE 90면.

⁹LE 90면.

¹⁰TRS 66면.

¹¹LE 65-66면.

¹²그러나 드워킨은 그러한 해석 전 단계의 법(preinterpretive law)을 식별하는 일 자체가 해석을 수반할 수 있다고 경고한다. LE 66면 참조.

¹³LE 93면.

pragmatism)', '통합성으로서의 법(law as integrity)'이라 명명한다.¹⁴ 드워킨이 이 세 가지 유형의 이론들에 관하여 서술한 모든 내용은, 평가적이고 정당화지향적인 법철학(jurisprudence)에 대한 기여로서 매우 흥미롭고 중요한 것이며, 내가 관심을 갖는 쟁점은 그가 제시한 이러한 해석적 구상들에 대해 논박하려는 것이 아니다.¹⁵ 단지 내가 이 책에서 제시한 바와 같은 실증주의적(positivist) 법이론이, 그러한 해석적 이론으로 재구성될 수 있다고 그가 주장하는 한에서만 예외이다. 이러한 주장은 나의 견해로는 잘못된 것이며, 내가 그러한 해석적 버전에 반대하는 이유들을 아래에 제시한다.

하지만 드워킨은 그의 저작들에서 일반적이고 기술적인 법이론을 그릇된 것이거나, 기껏해야 단순히 무용한 것으로 간주하는 듯하다. 그는 “유용한 법이론(theories of law)은 역사적으로 전개되는 실천의 특정 국면을 해석하는 이론이다”¹⁶라고 말하며, 또한 앞서 “기술(description)과 평가(evaluation)를 단순히 구분하는 기획은 법이론을 무기력하게 만들었다”¹⁷고 쓰기도 했다.

나는 드워킨이 기술적 법이론 혹은 그가 자주 사용하는 표현대로 '법철학(jurisprudence)'을 거부하는 구체적 이유들을 정확히 따라가기 어렵다. 그의 중심적인 반대는, 법이론은 법에 대한 내적 관점(internal perspective), 즉 하나의 법체계 안에서 활동하는 내부자 혹은 참여자(participant)의 관점을 고려해야 하며, 참여자의 관점이 아닌 외부 관찰자(observer)의 관점에서 접근하는 기술적 이론으로는 이러한 내적 관점을 제대로 설명할 수 없다는 것이다.¹⁸ 그러나 실제로는, 나의 책이 보여주듯이, 기술적 법철학이라는 기획은 외부자적 관찰자가 수범자(subject)들이 법을 내적으로 어떻게 바라보는지를 기술하는 것을 전혀

¹⁴LE 94면.

¹⁵그러나 일부 비평가들, 예컨대 Michael Moore는 “The Interpretive Turn in Modern Theory: A Turn for the Worse?”, Stanford Law Review 제41권 (1989) 871면에서 947-948면, 드워킨의 의미에서 법실천이 해석적이라는 점에는 동의하면서도, 법이론은 해석적일 수 없다고 주장한다.

¹⁶LE 102면. 또한, “법에 대한 일반이론은 우리에게 우리 자신의 사법 실천에 대한 일반 해석이다”라는 진술도 참조. LE 410면.

¹⁷AMP 148면. 또한, “‘법이론은 사회적 실천에 대한 중립적인 기술로 간주되어서는 안 된다’”는 진술도 비교하라. Ronald Dworkin, “A Reply by Ronald Dworkin”, Marshall Cohen 편, Ronald Dworkin and Contemporary Jurisprudence (1983), 이하 RDCJ로 인용, 247-254면.

¹⁸[LE 13-14면 참조.]

배제하지 않는다. 나는 이 책에서 상당한 분량을 할애하여, 수범자들이 법을 자신의 행위를 인도하는 지침이자 비판의 기준으로 수용(acceptance)함으로써 그들의 내적 관점을 드러낸다고 설명하였다. 물론, 기술적 법이론가는 이와 같은 방식으로 법을 수용하지는 않지만, 그러한 수용 자체를 기술할 수 있고 또 그래야 하며, 나는 실제로 그것을 본서에서 시도하였다. 물론 이를 위해 기술적 법이론가는 내적 관점이 무엇인지 이해(understand)해야 하며, 그러한 제한된 의미에서 내부자의 입장에 자신을 놓을 수 있어야 한다. 그러나 이는 법을 수용하거나 내부자의 관점에 동의(endorse)하거나, 그 관점을 공유하거나, 기술적 관점을 포기하는 것을 의미하지 않는다.

드워킨은 기술적 법철학에 대한 비판에서, 외부 관찰자가 참여자의 내적 관점을 기술적으로 고려하는 명백한 가능성을 배제하는 듯하다. 그는 앞서 말했듯이, 법철학을 '재판(adjudication)의 일반 이론'으로 규정하고 있으며, 이는 곧 법철학 혹은 법이론 자체를 사법적 참여자들의 내적 관점에서 바라본 법체계의 일부로 간주하는 것이다. 그러나 기술적 법이론가는 수범자의 내적 관점을 이해하고 기술할 수 있으며, 그것을 채택하거나 공유하지 않고도 이를 수행할 수 있다. 만약 (니일 매클릭(Neil MacCormick)¹⁹과 많은 비판자들이 주장하듯이) 수범자의 내적 관점이란, 법의 요구사항에 복종해야 할 도덕적 이유들(moral reasons)이나 강제의 사용을 정당화하는 도덕적 정당화(moral justification)도 필연적으로 포함한다고 하더라도, 그것은 도덕적으로 중립적인 기술적 법철학이 기록해야 할 사항일 뿐, 수용하거나 동의해야 할 대상이 아니다.

그러나 내가 주장하는 바, 즉 드워킨이 말하는 '해석적' 문제들이 법철학과 법이론의 유일한 적절한 대상이 아니며, 일반적이고 기술적인 법철학도 중요한 자리를 차지한다는 점에 대하여, 드워킨은 결국 이를 인정하였다. 그는 '법철학은 재판의 일반 이론'이라는 자신의 서술 역시 수정될 필요가 있음을 설명하였으며, 그것은 이제 "오직" 의미의 문제(question of sense)에 관한 법철학에만 해당된다"고 말한다.²⁰ 이는, 오직 해석적이고 평가적인 이론만이 적절한

¹⁹[Legal Reasoning and Legal Theory (1978), 63-64면 및 139-140면 참조.]

²⁰R. M. Dworkin, "Legal Theory and the Problem of Sense", R. Gavison 편, Issues in Contemporary Legal Philosophy: The Influence of H. L. A. Hart (1987), 19면.

법이론이라는 지나치고, 드워킨 자신이 표현하듯 “제국주의적(imperialist)”인 주장으로 보였던 입장을 수정한 중요한 발전이자 환영할 만한 교정이다.

하지만 나는 그가 그 제국주의적 주장 철회를 동반하여 덧붙인 다음의 주 의적 발언이 내포하는 의미에 대해 여전히 크게 혼란을 느낀다. 그는 “그러나 하트의 이론과 같은 일반 이론들이 주로 논의해온 쟁점들에서, ‘의미의 문제’가 얼마나 광범위하게 작동하는지를 강조할 필요가 있다”고 썼다.²¹ 이 경고의 관련성은 명확하지 않다. 내가 논의한 쟁점들(위 p. 240 참조)은, 예컨대 법이 강제적 위협과 어떤 관계를 가지며, 또 도덕적 요구사항과는 어떤 관계를 갖는가 등의 질문들을 포함한다. 드워킨의 경고의 요지는, 이러한 문제들을 논의함에 있어 기술적 법이론가라도 결국에는 법명제(propositions of law)의 의미에 대한 문제—그리고 이는 해석적이며 부분적으로 평가적인 법이론만이 만족스럽게 대답할 수 있는 문제—를 직면하게 된다는 것이다. 만일 그것이 사실이라면, 특정한 법명제의 의미를 결정하기 위해, 기술적 법이론가도 해석적이고 평가적인 질문—“정착된 법에 가장 잘 부합하며 그것을 가장 잘 정당화하는 원칙들로부터 이 명제가 도출되려면, 이 명제에는 어떤 의미가 부여되어야 하는가?”—을 제기하고 응답해야만 할 것이다. 그러나 내가 언급한 문제들에 대한 해답을 구하려는 일반적이고 기술적인 법이론가가, 다양한 법체계에서 법명제의 의미를 결정해야 한다는 것이 사실이라 해도, 그 의미 결정이 반드시 드워킨의 해석적·평가적 질문을 통해 이루어져야 한다(must)는 이유는 없다. 나아가, 일반적·기술적 법이론가가 다루어야 할 모든 법체계의 판사들과 법률가들이 실제로 이러한 해석적·평가적 방식으로 의미의 문제를 해결하고 있다고 하더라도, 이는 기술적 법이론가가 사실로서 기록해야 할 사항일 뿐, 그러한 사실에 기초하여 자신의 일반 기술적 결론들을 도출하면 되는 것이다. 물론 이러한 결론들이 그러한 해석적 사례들에 기초한다고 해서, 그것들 자체가 해석적이고 평가적인 것이거나, 기술자의 과제가 기술(description)에서 해석과 평가로 전이된 것이라고 여겨서는 안 된다. 설명(description)은, 그 대상이 평가(evaluation)일지라도 여전히 설명일 수 있다.

²¹앞 인용과 동일.

2. 법실증주의의 본성

(i) 의미론적 이론으로서의 실증주의(Positivism as a Semantic Theory)

나의 저서는 드워킨(Dworkin)에 의해 현대 법실증주의(modern legal positivism)의 대표작으로 간주되며, 이 이론은 벤담(Bentham)과 오스틴(Austin)의 초기 버전과는 구별된다. 그 차이는 주로 그들이 제시한 명령 이론(imperative theories)과, 모든 법(law)이 법적으로 무제한인 입법자 혹은 입법기관이라는 주체로부터 나온다는 관념을 거부한다는 데 있다. 드워킨은 내가 제시한 법실증주의 버전에서 다수의 서로 관련된 오류들을 지적한다. 그 중 가장 근본적인 오류는 다음과 같은 관점이다. 즉, 법적 권리와 법적 의무를 설명하는 법명제(propositions of law)의 진리성(truth)은 오직 개별적 신념이나 사회적 태도에 관한 사실들을 포함하는 명백한 역사적 사실(historical fact)에만 의존한다는 것이다.²² 법명제의 진리성이 의존하는 사실들은 드워킨이 ‘법의 근거들(grounds of law)’이라 부르는 것들이며,²³ 드워킨에 따르면 실증주의자는 이 ‘근거들’이, 판사들과 법률가들이 공유하는 언어적 규칙(linguistic rules)에 의해 고정되어 있다고 잘못 간주한다. 이러한 규칙은 ‘law’라는 단어가 특정 체계의 당해 법(the law)이 무엇인지 진술할 때뿐 아니라, ‘법’(law) 일반이 무엇인지를 진술할 때 사용되는 방식과 의미를 지배한다고 한다.²⁴ 실증주의자의 이러한 관점에 따르면, 법에 관한 모든 논쟁은 그러한 역사적 사실이 존재하느냐의 문제에 국한되며, 무엇이 법의 ‘근거’인지를 둘러싼 이론적 논쟁은 존재할 수 없다.

드워킨은 법실증주의에 대한 비판에서 상당한 분량을 할애하여, 법의 근거가 무엇인지에 대한 이론적 논쟁이 실증주의자의 주장과는 달리, 영미법 실천(Anglo-American legal practices)의 두드러진 특징임을 보여준다. 그는 법의 근거가 판사들과 법률가들이 공유하는 언어적 규칙에 의해 논쟁의 여지 없이 고정되어 있다는 견해에 반대하며, 그 근거는 본질적으로 논쟁적이며, 단지 역사적 사실뿐 아니라 논쟁적인 도덕 판단(moral judgments) 및 가치 판단(value

²² LE 6면 이하.

²³ LE 4면.

²⁴ LE 31면 이하.

judgments)도 빈번히 포함된다고 주장한다.

드워킨은 왜 실증주의자들이 이러한 근본적으로 잘못된 관점을 취하게 되었는지에 대해 매우 상이한 두 가지 설명을 제시한다. 첫 번째 설명에 따르면, 실증주의자들은 다음과 같이 믿는다. 즉, 만약 법의 근거가 규칙에 의해 분명하게 정해지지 않고 논쟁적인 문제로 남아 이론적 불일치를 허용하게 된다면, 'law'라는 단어는 사람마다 서로 다른 의미를 갖게(mean) 될 것이며, 그 단어를 사용하는 이들은 서로 다른 것을 이야기하게 되어 의사소통이 이루어지지 않게 된다는 것이다. 드워킨은 이러한 신념이 실증주의자에게 귀속된다면 그것은 전적으로 잘못된 것이라고 보고, 실증주의자가 이를 근거로 법의 논쟁적 근거에 반대한다고 주장하는 논증을 '의미론의 독침(sting of semantics)'²⁵이라 부르며, 이는 'law'라는 단어의 의미에 관한 이론에 의존하는 것이기 때문이라고 본다. 그래서 그는 Law's Empire에서 이 '의미론의 독침'을 제거하려 한다.

드워킨은 Law's Empire의 제1장에서 나를 오스틴(Austin)과 함께 의미론적 이론가(semantic theorist)로 분류하면서, 내가 'law'라는 단어의 의미에서 출발하여 명백한 사실에 기반한 실증주의 이론(plain-fact positivist theory)을 도출하고 있으며, 의미적 침의 문제를 겪고 있다고 한다. 그러나 나의 저서나 그 밖의 저술들 어디에도, 나의 이론이 그러한 설명에 근거한다는 주장을 뒷받침하는 내용은 없다. 예컨대, 내가 제시한 “성숙한 국내 법체제는 법원이 적용해야 할 법을 식별하는 기준(criteria)을 명시하는 승인규칙(rule of recognition)을 포함한다”는 이론은 틀릴 수는 있지만, 그 이론을 내가 모든 법체계에 승인규칙이 존재해야 한다는 주장을 'law'라는 단어의 의미로부터 끌어낸 것이거나, 또는 법의 근거를 식별하는 기준이 명확하게 고정되어 있지 않다면 'law'는 사람마다 서로 다른 의미를 지니게(mean) 될 것이라는 더욱 잘못된 생각에 기초한 것은 아니다.

실제로 이 마지막 논증은 개념의 의미(meaning of a concept)와 그 개념의 적용 기준(criteria for application)을 혼동한 것이다. 나는 이와는 정반대로, 이 책 160쪽에서 정의(justice)의 개념을 설명하면서, 동일한 의미를 갖는 개념일 지라도 그 적용 기준은 다양할 수 있으며 논쟁적일 수도 있음을 명시적으로

²⁵LE 45면.

지적하였다. 나는 이 점을 명확히 하기 위해, 드워킨의 후기 작업에서 중요하게 작용하는 개념과 개념에 대한 다양한 개념화들(conceptions) 사이의 구분을 실질적으로 동일한 방식으로 도입하였다.²⁶

마지막으로, 드워킨은 실증주의자가 자신의 법이론은 의미론적 이론이 아니라, 법이라는 복합적 사회현상의 특수한 특징들에 대한 기술적 설명(descriptive account)이라고 주장하는 것 자체가, 의미론적 이론과의 대비를 이루는 것처럼 보이지만 사실은 공허하고 오도적인 것이라고 강하게 주장한다. 그의 논변은 다음과 같다.²⁷ 즉, 법이라는 사회현상의 고유한 특징 중 하나는 법률가들이 법 명제의 진위(truth)를 논의하고, 이를 그러한 명제의 의미를 근거로 설명한다는 것이다. 따라서 이러한 기술적 법이론은 결국 의미론적 이론이 될 수밖에 없다는 것이다.²⁸ 그러나 이 논변은 'law'라는 단어의 의미와 법명제(propositions of law)의 의미를 혼동하는 것으로 보인다. 드워킨에 따르면, 의미론적 법이론이란 'law'라는 단어의 의미 자체가 법이 특정한 기준에 따라야 한다는 것을 의미한다고 보는 이론이다. 그러나 법명제란 일반적으로 '법(law)이 무엇인가'를 진술하는 것이 아니라, 당해 법(the law)이 무엇인지, 즉 특정 법체계 내에서 무엇을 허용하고 요구하거나 권한을 부여하는지를 진술하는 명제들이다. 따라서 설령 이러한 법명제들의 의미가 정의나 진리조건에 의해 결정된다고 해도, 그것이 곧 'law'라는 단어의 의미 자체가 법을 특정한 기준에 의존하게 만든다는 결론으로 이어지지는 않는다. 그러한 결론이 가능하려면, 법체계의 승인규칙(rule of recognition)에 의해 제공되는 기준들과, 그러한 규칙 자체의 필요성이 'law'라는 단어의 의미로부터 도출되어야 한다. 그러나 나의 작업에는 그러한 주장을 뒷받침하는 흔적이 전혀 없다.²⁹

드워킨이 나의 법실증주의를 잘못 묘사하는 또 하나의 측면은 다음과 같다. 그는 나의 승인규칙 이론이, 법을 식별하기 위한 기준이 오직 역사적 사실

²⁶이 구분에 대해서는 John Rawls, *A Theory of Justice* (1971), 5-6, 10면 참조. [Rawls는 정의의 개념(concept of justice)과 정의의 개념들(conceptions of justice)을 구분하면서 “나는 H. L. A. Hart의 *The Concept of Law*... 155-159면을 따른다”고 명시함. *A Theory of Justice* 5면 각주 1 참조.]

²⁷LE 418-419면, 주석 29.

²⁸LE 31-33면 참조.

²⁹본서 209면 참조. 이곳에서 나는 그러한 교리를 명시적으로 거부하고 있다.

(historical facts)만으로 구성되어야 한다고 요구하는 것으로 보고, 이를 '명백한 사실 실증주의(plain-fact positivism)'의 예시로 간주한다.³⁰ 그러나 내가 승인 규칙이 제공하는 기준에 대한 주요 예시로 제시한 것들이, 법이 법제도에 의해 채택되고 제정되는 방식만을 다루고 법의 내용은 다루지 않는, 드워킨이 '계보(pedigree)'라 부르는 것이라는 점은 사실이다.³¹ 그럼에도 불구하고 나는 이 책(72쪽)과 「실증주의와 법과 도덕의 분리(Positivism and the Separation of Law and Morals)」라는 이전의 논문 모두에서, 미국과 같은 일부 법체계에서는 법적 유효성(legal validity)의 궁극적 기준이 계보뿐 아니라 정의의 원칙들(principles of justice)이나 실질적 도덕 가치(substantive moral values)를 명시적으로 포함할 수도 있으며, 이는 헌법적 제약의 내용을 형성할 수 있다고 명시적으로 언급하였다.³² 드워킨이 Law's Empire에서 나에게 '명백한 사실 실증주의'를 귀속시키는 것은 이러한 나의 이론의 측면을 무시한 것이다. 따라서 그가 나에게 귀속시키는 '의미론적 버전의 명백한 사실 실증주의'는 분명히 나의 이론이 아니며, 나의 이론은 어떤 형태로든 명백한 사실 실증주의가 아니다.

(ii) 해석적 이론으로서의 실증주의(Positivism as an Interpretive Theory)

드워킨(Dworkin)의 두 번째 명백한 사실 실증주의(plain-fact positivism) 설명은, 그것을 의미론적 이론(semantic theory)이나 언어적 고려에 기초한 것으로 다루지 않고, 그가 '관행주의'(conventionalism)라 부르는 드워킨식 해석 이론(Dworkinian interpretive theory)의 한 형태로 재구성하고자 시도한다. 이 이론에 따르면(드워킨은 궁극적으로 이 이론을 결함 있는 것으로 기각하지만), 실증주의자는 해석 이론가(interpretive theorist)의 입장에서 당해 법(the law)을 가장 좋게 보이도록 구성하고자 하며, 이에 따라 법의 기준(criteria of law)은 명백한 사실들(plain facts)로 구성된다고 제시된다. 이러한 기준은 의미론적

³⁰[이 표현은 하트 자신의 것이며, LE에는 등장하지 않음.]

³¹TRS 17면.

³²Harvard Law Review 제71권 (1958) 598면. Essays on Jurisprudence and Philosophy에도 재수록. 특히 54-55면 참조.

버전처럼 법의 어휘에 의해 고정되는 것이 아니라, 판사들과 법률가들 사이에 공유된 신념(conviction)에 의해 논쟁 없이 고정된다고 본다. 이 관점은 법이 수범자(subject)들에게 매우 중요한 어떤 것을 보장한다는 점을 보여줌으로써 법을 유리하게 조명한다. 즉, 법적 강제(legal coercion)의 시점이 모두가 접근 가능한 명백한 사실에 의존하도록 함으로써, 강제가 사용되기 전 모든 사람이 공정한 경고를 받을 수 있도록 한다는 점이다. 드워킨은 이를 ‘보호된 기대의 이상’(the ideal of protected expectations)³³이라 부르지만, 그의 판단으로는 이러한 장점이 여러 결함을 상쇄할 만큼 충분하지 않다.

그러나 이러한 해석적 관행주의 이론으로서의 실증주의 설명은 나의 법이론의 그럴듯한 버전 또는 재구성으로 간주될 수 없다. 이는 두 가지 이유 때문이다. 첫째, 내가 이미 명시한 바와 같이, 나의 이론은 ‘명백한 사실 실증주의’가 아니다. 왜냐하면 나의 이론은 법의 기준들 가운데에 ‘명백한’ 사실들뿐 아니라 가치들(values)도 포함하기 때문이다. 둘째이자 보다 중요한 이유는, 드워킨의 모든 형태의 해석 이론은 법과 법적 실천의 목적(point or purpose)이 강제를 정당화하는 데 있다고 전제하지만,³⁴ 나는 법이 그러한 목적을 갖는다고 본 적이 없으며 지금도 그렇지 않다. 다른 형태의 실증주의들과 마찬가지로, 나의 이론은 법과 법적 실천의 목적을 밝히고자 하는 주장을 전혀 하지 않으며, 따라서 법의 목적이 강제(coercion)의 정당화(justification)라고 보는 드워킨의 견해(나는 이에 결코 동의하지 않는다)를 뒷받침하는 내용은 나의 이론 어디에도 없다. 실제로 나는 법이 수행하는 보다 구체적인 목적을 찾으려는 시도는 무의미하다고 본다. 법은 인간 행위에 대한 지침(guides)을 제공하고, 그러한 행위에 대한 비판의 준거(standards)를 제공하는 것을 넘어서 어떤 목적을 가진다고 보기는 어렵기 때문이다. 물론, 이러한 목적은 일반적 목표를 가진 다른 규칙(rule)이나 원칙(principle)들과 법을 구별하는 데에는 도움이 되지 않는다. 법의 고유한 특징은, 승인(recognition)·변경(change)·집행(enforcement)이라는 이차적 규칙들(secondary rules)을 통해 기준들을 식별하고, 그것들을 변경하고 집행할 수 있는 수단을 제공하며, 다른 기준들에 대한 우선권(priority)을

³³LE 117면.

³⁴[LE 93면.]

일반적으로 주장한다는 점에 있다. 따라서 설령 내가 명백한 사실 실증주의의 한 형태인 관행주의(conventionalism)에 전적으로 의존한다고 가정하더라도, 그리고 그것이 법적 강제에 대한 사전 통지를 일반적으로 가능케 함으로써 기대를 보호한다 하더라도, 이로부터 내가 이것을 단지 법이 가지는 도덕적 장점(moral merit) 중 하나로 본다는 것 이상은 도출되지 않는다. 즉, 내가 법의 전체적 목적이 그것이라고 본다는 결론에는 도달할 수 없다. 법적 강제는 대부분 수범자(subject)들의 행위를 인도하는 법의 기본 기능이 실패한 경우에 발생하는 것이다. 그러므로 법적 강제는 물론 중요하긴 하지만, 부차적 기능(secondary function)이다. 그러한 강제를 정당화하는 것은 법 일반의 목적이 될 수 없다.

드워킨이 나의 법이론을 ‘관행주의적 해석 이론’(conventionalist interpretive theory)으로 재구성하면서, “법적 강제는 그것이 관행적 이해(conventional understandings)에 부합할 때에만 정당화된다”³⁵고 주장하는 이유는 이 책의 제5장 제3절에 있는 나의 법의 요소들(Elements of Law)에 대한 설명에 근거한다. 나는 이 부분에서 승인, 변경, 재판의 이차적 규칙들(secondary rules of recognition, change, and adjudication)을, 오직 의무의 일차적 규칙들(primary rules of obligation)만으로 구성된 가상의 단순한 체계가 가진 결함에 대한 처방(remedies)으로 제시하였다. 그 결함들이란 규칙의 동일성에 대한 불확실성(uncertainty), 규칙의 정태성(static quality), 그리고 규칙이 분산된 사회적 압력(diffuse social pressure)에 의해서만 집행될 때 발생하는 시간 낭비적 비효율성(inefficiency)이다. 그러나 이러한 이차적 규칙들을 그와 같은 결함들에 대한 처방으로 제시하면서도, 나는 법적 강제가 이러한 규칙들에 부합할 때에만 정당화된다(justified)는 주장을 어디에서도 한 바 없다. 더 나아가, 그러한 정당화 제공이 법 일반의 목적이라는 주장은 더더욱 하지 않았다. 사실, 내가 이차적 규칙들을 논의하면서 강제(coercion)에 대해 언급한 유일한 문맥은, 규칙의 집행을 법원에 의해 조직된 제재가 아니라 분산된 사회적 압력에 맡길 경우 발생하는 시간 낭비적 비효율성(inefficiency)에 (p. 250) 대한 것이다. 그러나 비효율성에 대한 처방(remedy)은 결코 정당화(justification)가 아니다.

물론, 의무의 일차적 규칙 체계에 승인 규칙(rule of recognition)이라는 이

³⁵LE 429면 주석 3.

차적 규칙을 추가하면, 개인들이 강제의 시점을 사전에 식별할 수 있게 해줌으로써 강제 사용을 일정한 의미에서 정당화하는 데 기여할 수는 있다. 즉, 강제 사용에 대한 하나의 도덕적 반대 사유를 제거해 주기 때문이다. 그러나 승인 규칙이 가져오는 법의 요구사항들에 대한 사전의 명확성과 인식은 강제(coercion)가 문제 되는 경우에만 중요한 것이 아니다. 그것은 유언이나 계약 같은 법적 권한의 합리적 행사에도 필수적이며, 사적 또는 공적 생활의 합리적 계획 수립에도 마찬가지로 결정적이다. 따라서 승인 규칙이 기여하는 법적 강제의 정당화는, 그것이 승인 규칙의 일반적인 목적이라고 볼 수 없으며, 더구나 법 전체의 일반적 목적이라고 간주될 수는 없다. 나의 이론 어디에서도 그렇게 볼 수 있는 내용은 없다.

(iii) 연성 실증주의(Soft Positivism)

드워킨(Dworkin)은 나에게 ‘명백한 사실 실증주의’(plain-fact positivism) 이론을 귀속시키면서, 나의 이론이 승인 규칙(rule of recognition)의 존재와 권위가 법원(courts)에 의한 수용(acceptance)이라는 사실(fact)에 의존해야 한다고 요구한다는 점에서는 옳게 이해했지만, 그 승인 규칙이 제공하는 법적 유효성(validity)의 기준(criteria)은 오직 드워킨이 ‘계보적’(pedigree) 사항이라 부르는 특정한 종류의 명백한 사실들, 즉 법이 창출되거나 채택되는 방식 및 형식에 관한 사실로만 구성되어야 한다고 요구한다는 점에서는 오해하고 있다. 이러한 해석은 이중으로 잘못되었다. 첫째, 그것은 내가 명시적으로 승인한 바 있는 내용을 무시한다. 즉, 승인 규칙은 법적 유효성의 기준으로서 도덕적 원칙(moral principles) 또는 실질적 가치(substantive values)와의 정합성(conformity)을 포함할 수 있다는 것이다. 따라서 나의 이론은 드워킨이 말하는 ‘명백한 사실 실증주의’가 아니라, 소위 ‘연성 실증주의’(soft positivism)에 해당한다. 둘째, 나의 저서 어디에도 승인 규칙이 제공하는 명백한 사실의 기준이 오직 계보(pedigree)에 관한 사항으로만 구성되어야 한다는 암시는 없다. 오히려 그러한 기준들은, 종교의 설립을 금지하거나 참정권의 제한을 방지하는 미국 헌법 수정조항 제 16조나 제 19조처럼, 입법 내용에 대한 실질적 제약(substantive constraints)일

수도 있다.

그러나 이러한 답변은 드워킨의 가장 근본적인 비판에 대한 대응은 되지 않는다. (p. 251) 왜냐하면 드워킨은 연성 실증주의의 어떤 형태를 채택한 다른 이론가들에 대해서도 중요한 비판을 제기한 바 있으며,³⁶ 그것이 타당하다면 나의 이론에도 적용되어 여기에서 응답을 요하기 때문이다.

드워킨의 가장 근본적인 비판은 다음과 같다. 즉, 도덕적 혹은 가치 판단과의 정합성(conformity)이라는 논쟁적인 쟁점들에 법의 식별이 의존할 수 있다고 허용하는 연성 실증주의는, 법을 본질적으로는 수범자(subject)의 행위에 대한 신뢰할 수 있는 공적 기준(public standards)을 제공하는 것으로 묘사하는 일반적인 실증주의의 ‘도식’(picture)과 깊은 모순을 이룬다는 것이다. 이러한 공적 기준들은, 실증주의적 설명에 따르면, 논쟁적 도덕 논변에 의존하지 않고 명백한 사실로서 확정 가능해야 한다³⁷. 드워킨은, 연성 실증주의와 나의 이론의 나머지 부분 사이의 이러한 모순을 입증하기 위해, 내가 승인 규칙(rule of recognition)을 가상의 전(前)법적 체계(pre-legal regime), 즉 관습-유형(custom-type)의 일차 규칙(primary rules of obligation)이 가진 결함들 중 특히 불확실성(uncertainty)을 치유하는 수단으로 설명한 점을 인용할 것이다. 그러나 이러한 비판은, 실증주의자가 법적 기준 집합에 대해 반드시 부여해야 한다고 여겨지는 확실성의 정도를 과장하고 있을 뿐만 아니라, 법적 유효성의 기준에 특정 도덕 원칙이나 가치들과의 정합성을 포함시킬 경우 생겨날 불확실성의 정도 역시 과장하고 있다. 물론, 승인 규칙의 중요한 기능 중 하나는 당해 법(the law)이 얼마나 확실하게 인지될 수 있는지를 향상시키는 것이다. 만약 승인 규칙이 도입하는 검증 기준들이 모든 사례에서 논쟁적 쟁점을 야기한다면, 이 기능은 실패할 것이다. 그러나 어떤 대가를 치르더라도 모든 불확실성을 제거하는 것이 승인 규칙의 목표라고 나는 한 번도 주장한 바 없다. 이 점은, 승인 규칙 자체와 그것을 참조하여 식별되는 개별 법 규칙들이 논의 가능한 주변부(penumbra)의 불확실성을 지닐 수 있다고 내가 명시적으로 언급한 이 책의 진술에서 분명히

³⁶E. P. Soper와 J. L. Coleman에 대한 드워킨의 응답을 RDCJ 247면 이하, 252면 이하에서 볼 수 있음.

³⁷RDCJ 248면.

드러난다³⁸. 또한 내가 전개한 일반적 논증은 다음과 같다. 설령 법률이 그 의미에 대한 모든 가능한 질문을 사전에 결정할 수 있도록 제정될 수 있다 하더라도, 그러한 법률을 채택하는 것은 법이 지향해야 할 다른 목적들과 충돌하는 경우가 많다는 것이다³⁹. 많은 법 규칙들에서는 일정한 불확실성의 여지(margin of uncertainty)를 (p. 252) 허용하고, 실제로는 환영해야 할 것이다. 그래야만 예측할 수 없었던 사안이 구성되었을 때, 사안에서 문제가 되는 쟁점들을 식별하고 이에 대해 합리적으로 판결할 수 있는 법원의 정보 기반 결정이 가능하기 때문이다. 오직 승인 규칙의 확실성 제공 기능을 지상 명령적이며 절대적인 것으로 간주할 때에만, 도덕 원칙이나 가치들과의 정합성을 포함하고 있는 연성 실증주의를 이론 내부적으로 모순된 것으로 평가할 수 있을 것이다. 여기에서 제기되는 근본적인 질문은 다음과 같다. 법 체계가 수범자의 행위에 대한 일반적으로 신뢰할 수 있고 사전에 식별 가능한 안내 지침(guides to conduct)을 제공하는 분산된 관습-유형 규칙들의 체계로부터 유의미한 진전을 이루기 위해, 어느 정도의 불확실성을 수용할 수 있는가?

드워킨의 나의 연성 실증주의 버전에 대한 두 번째 비판은, 법의 결정성(determinacy)과 완결성(completeness)에 관한 더 복잡한 문제를 제기한다. 내가 이 책에서 주장한 바에 따르면, 승인 규칙이 제공하는 기준들에 의해 일반적으로 식별되는 법 규칙과 법 원칙들은 종종 내가 ‘개방적 직조’(open texture)라 부르는 특성을 지닌다. 즉, 어떤 특정 규칙이 특정 사안에 적용되는지의 여부가 문제될 경우, 법은 그에 대해 어느 쪽의 답도 결정해주지 못하고, 그리하여 부분적으로 결정 불가능한 것으로 드러난다. 이러한 사례들은 단순히 ‘어려운 사례들’(hard cases)만이 아니다. 즉, 정보가 풍부하고 합리적인 법률가들 사이에서 어떤 해답이 법적으로 정당한가에 대해 의견이 갈릴 수 있는 의미에서의 논쟁적인 경우를 넘어서, 그러한 경우에서 법 자체가 불완전하다(incomplete)는 것이다. 다시 말해, 해당 사안에서 문제되는 질문들에 대해 어떠한(no) 답도 제공하지 못한다. 그러한 사례들은 법적으로 규율되지 않는 영역이며, 이에 대한 결정을 내리기 위해서는 법원이 내가 ‘재량’(discretion)이라 부르는 제한된

³⁸본서 123면, 147-154면 참조.

³⁹[본서 128면 참조.]

입법 기능(law-making function)을 행사해야 한다. 드워킨은 법이 이와 같은 방식으로 불완전하며, 그러한 입법적 재량의 행사를 통해 그 공백(gaps)을 메우는 것을 허용한다는 생각을 거부한다. 그는 이 견해가 다음과 같은 잘못된 추론에 기초한다고 본다. 즉, 법적 권리나 법적 의무의 존재를 주장하는 법 명제(proposition of law)가 논쟁적이며, 따라서 합리적이고 정보가 풍부한 사람들이 의견을 달리할 수 있다는 사실로부터, 법은 공백을 남기며 그러한 재량을 통해 채워져야 한다는 결론을 도출하는 것은 오류라는 것이다. 왜냐하면 어떤 법 명제가 논쟁적인 경우에도, 그것이 참인지 거짓인지에 관하여 여전히 존재하는 ‘사실’(facts of the matter)이 있을 수 있으며, 그 진위 여부를 입증할 수는 없더라도, 그것이 참이라는 논증을 거짓이라는 논증보다 더 설득력 있게 평가할 수 있기 때문이다. 그리고 그 반대도 마찬가지다. 이러한 ‘논쟁적 법’(controversial law)과 ‘불완전하거나 결정되지 않은 법’(incomplete or indeterminate law) 사이의 구분은 드워킨의 해석 이론에서 매우 중요한 문제이다. 왜냐하면 그의 이론에 따르면, 어떤 법 명제가 참이기 위해서는 다른 전제들과 함께 그것이 해당 법 체계의 제도적 역사에 가장 잘 들어맞는 원칙들(principles)로부터 도출되어야 하며, 동시에 그것들을 도덕적으로 가장 잘 정당화할 수 있어야 하기 때문이다. 결국 드워킨에게 있어서, 모든 법 명제의 진리는 그것이 무엇을 가장 잘 정당화하는지를 판단하는 도덕 판단(moral judgment)의 진리에 의존하며, 그에게 있어 도덕 판단은 본질적으로 논쟁적인 것이기 때문에, 모든 법 명제도 따라서 본질적으로 논쟁적이다.

드워킨(Dworkin)에게 있어, 그 적용이 논쟁적인 도덕 판단(moral judgment)을 수반하는 법적 유효성(legal validity)의 기준(criterion)이라는 개념은 이론적으로 아무런 어려움을 제기하지 않는다. 그의 관점에서 그것은 여전히 당해 법(the law)의 사전 존재를 확인하는 진정한 검증 수단(test)이 될 수 있다. 왜냐하면 그것이 논쟁적이라는 특성은, 그것이 참임을 가능케 하는 사실들(facts)—많은 경우 도덕적 사실(moral facts)—이 존재하는 것과 완전히 양립 가능하기 때문이다.

그러나 연성 실증주의(soft positivism)—즉 법적 유효성의 기준이 부분적으로 도덕적 시험(moral test)이 될 수 있음을 허용하는 이론—은 드워킨이 주장하듯,

앞서 251-252쪽에서 논의된 바와는 별개로, 두 번째 모순에도 연루되어 있다. 이 이론은 실증주의자들이 그리는 ‘법은 확실성(certainty)을 가지고 식별될 수 있다’는 도식(picture)과만 모순되는 것이 아니라, 법적 명제들(propositions of law)의 ‘객관적 지위’(objective standing)를 어떤 논쟁적인 철학 이론—특히 도덕 판단의 지위(status)에 관한 철학 이론—에도 의존하지 않게 하려는, 드워킨이 실증주의자들에게 귀속시키는 바람과도 모순된다⁴⁰. 도덕적 시험이 당해 법에 대한 시험이 되기 위해서는, 도덕 판단들이 참인 근거가 되는 객관적 도덕 사실들(objective moral facts)이 존재해야 한다. 그러나 이러한 사실들이 존재한다는 것은 논쟁적인 철학적 이론이다. 만약 그러한 사실들이 존재하지 않는다면, 도덕적 기준을 적용하라는 명령을 받은 판사는 이를 단지 법 체계가 부과하는 제약(constraints) 하에서, 자신이 최선이라고 판단하는 도덕적 이해(morality and its requirements)에 따라 새로운 법을 창출하는 입법적 재량(law-making discretion)의 행사 요청으로밖에 받아들일 수 없게 된다.

나는 여전히 법 이론이 도덕 판단의 일반적 지위에 관한 논쟁적인 철학 이론들에 대한 어떠한 입장도 채택하지 말아야 한다고 생각하며, 이 책에서도 그렇듯 (168쪽), 도덕 판단들이 드워킨이 말하는 ‘객관적 지위’(objective standing)를 갖는지에 대한 일반적 질문을 열린 채로 남겨두어야 한다고 본다. 왜냐하면, 이 철학적 질문에 대한 답변이 어떻든, 판사가 따라야 할 의무(duty)는 동일하기 때문이다. 즉, 자신이 판단해야 할 도덕적 쟁점들에 대해 가능한 최선의 도덕 판단을 내리는 것이다. 그리고 실제적인 목적에서는, 판사가 사건을 결정하면서 법을 만들고 있는(making) 것인지, 혹은 도덕적 기준을 통한 당해 법에 대한 검증을 통해 이미 존재하는 법(existing law)이 무엇인지를 자신의 도덕 판단에 따라 발견하고 있는 것인지는 중요하지 않다. 물론, 만약 법 이론이 도덕 판단의 객관적 지위를 열린 문제로 남겨두는 것이 타당하다고 본다면, 연성 실증주의는 단순히 ‘도덕 원칙들(moral principles)이나 가치들(values)이 법적 유효성의 기준 중 일부가 될 수 있다’는 이론으로 특징지을 수 없다. 왜냐하면, 만약 도덕 원칙들과 가치들이 객관적 지위를 가지는지는 열린 문제라면, 연성 실증주의적 조항들이 그러한 원칙들과의 정합성(conformity)을 당해 법에 대한 시험(test)

⁴⁰RDCJ 250면.

으로 포함한다고 할 경우, 그것이 실제로 법의 기준이 되는 효과를 가지는지, 아니면 단지 법원이 도덕에 따라 법을 창출하라(make)는 지시(directions)를 구성하는 것인지 역시 열린 문제로 남기게 되기 때문이다.

한 가지 주목할 점은, 특히 라즈(Raz)와 같은 일부 이론가들이 다음과 같은 입장을 견지한다는 것이다. 즉, 도덕 판단의 철학적 지위가 어떠한 간에, 법이 법원의 법 결정(law determination)에 있어 도덕적 기준들(moral standards)의 적용을 요구할 경우, 이는 곧 법원이 도덕에 따라 최선의 도덕 판단을 사용하여 새로운 법을 창출하라는 재량의 부여를 의미하며, 그렇게 한다고 해서 도덕이 이미-존재하는 법(pre-existing law)으로 전환되는 것은 아니라는 것이다⁴¹.

3. 규칙의 본성(The Nature of Rules)

(i) 규칙에 대한 실천 이론(The Practice Theory of Rules)

이 책의 여러 지점에서 나는 법의 내적 진술(internal statements)과 외적 진술(external statements) 사이의 구분, 그리고 법의 내적 측면(internal aspects)과 외적 측면(external aspects) 사이의 구분에 주의를 기울였다.

이러한 구분과 그 중요성을 설명하기 위해 나는 (56-7쪽) 성문법과 관습-유형(custom-type) 규칙(custom-type rules)을 모두 포함하는 고도로 복잡한 법 체계의 사례가 아니라, 보다 단순한 사례—그러나 동일한 내·외적 구분이 적용되는—즉, 어떤 사회 집단(크든 작든)의 관습-유형(custom-type) 규칙을 먼저 고찰하였다. 나는 이를 '사회 규칙(social rules)'이라 부른다. 내가 제시한 이러한 설명은 '규칙에 대한 실천 이론(practice theory)'으로 알려지게 되었는데, 이는 특정 집단의 사회 규칙을 일련의 사회적 실천(social practice)으로 구성된 것으로 간주하며, 그 실천은 다음 두 가지 요소를 포함한다. (1) 집단의 대다수 구성원이 지속적으로 따르는 행위 양식(patterns of conduct), 그리고 (2) 그러한 행위 양식에 대해 구성원들이 가지는 독특한 규범적 태도(normative attitude)를 포함한다. 나는 이러한 태도를 '수용(acceptance)'이라 불렀다. 이는 개인이

⁴¹J. Raz, "Dworkin: A New Link in the Chain", California Law Review 제74권 (1986) 1103면, 1110면 및 1115-1116면.

해당 행위 양식을 자신의 향후 행동에 대한 지침으로 삼고, 그 양식을 기준으로 삼아 비판하거나 정당한 요구 또는 다양한 형태의 준수 압력(conformity pressure)을 행사하려는 지속적 성향(standing disposition)을 의미한다. 사회 규칙에 대한 외적 관점(external point of view)은 그 실천을 관찰하는 외부자의 시각이며, 내적 관점(internal point of view)은 해당 규칙을 행위 지침 및 비판 기준으로 받아들이는 참여자의 시각이다.

내가 제시한 사회 규칙에 대한 실천 이론은 드워킨(Dworkin)에 의해 광범위하게 비판을 받았으며, 앞서 언급했듯, 그는 이와 유사하면서도 실제로는 여러 측면에서 매우 상이한 구분을 제안한다. 그는 한편으로는 사회학자가 공동체의 사회 규칙을 외재적으로 기술하는 관점과, 다른 한편으로는 그러한 규칙을 자신의 행위나 타인의 행위에 대한 평가와 비판의 근거로 삼는 참여자의 내적 관점을 구분한다⁴². 드워킨이 내가 제시한 사회 규칙 이론을 비판하면서 제기한 몇몇 지적은 확실히 타당하며, 법에 대한 이해에 있어 중요한 시사점을 갖는다. 아래에서 나는 이제 수정이 필요하다고 판단하는 내 원래 설명의 주요 측면들을 서술한다.

- (i) 드워킨이 주장했듯이, 나의 설명은 한 집단의 관행적 규칙(conventional rules)에서 나타나는 관행(convention)에 대한 합의(consensus)와, 동시적 행위(concurrent practices)에서 나타나는 독립된 신념(conviction)에 대한 합의 사이의 중요한 차이를 간과한 점에서 결함이 있다. 만일 어떤 규칙에 대해 그 집단의 일반적 준수(conformity)가 해당 규칙을 수용(acceptance)하는 구성원 개개인의 이유(reasons) 중 하나가 된다면, 해당 규칙은 관행적 사회 실천(conventional social practices)이라 할 수 있다. 반면에, 어떤 특정한 방식으로 행동하고자 하는 동일하지만 독립적인 이유들을 구성원들이 각각 가지고 있고 실제로 그러한 이유에 따라 일반적으로 행동한다면, 이는 단순히 동시적 행위(concurrent practices)일 뿐, 관행은 아니다. 예컨대, 한 집단이 공유하는 도덕성은 관행이 아니라 이러한 독립적 이유들의 공존으로 이루어진다.

⁴²[LE 13-14면 참조.]

(ii) 드워킨이 또한 정확히 지적했듯이, 나의 사회 규칙 설명은 위에서 설명한 의미에서의 관행적 규칙들에만 적용 가능하다. 이는 내가 제시한 관행 이론의 적용 범위를 상당히 축소시키며, 나는 이제 그것을 도덕(morality)—개인적 도덕이든 사회적 도덕이든—의 타당한 설명으로 보지 않는다. 그러나 이 이론은 여전히 관행적 사회 규칙(conventional social rules)에 대한 충실한 설명으로 남는다. 이에는 일반적인 사회 관습(그 법적 효력이 승인(recognition)될 수도 있고 되지 않을 수도 있는 것들)뿐 아니라, 몇몇 중요한 법 규칙들도 포함된다. 예를 들어, 승인 규칙(rule of recognition)은 사실상 판례상의 관습적 규칙의 한 형태이며, 이는 오직 법원을 중심으로 한 법 식별(law-identifying) 및 법 적용(law-applying) 행위에서 수용되고(accepted) 실천될(practised) 때에만 존재할 수 있다. 반면 제정된 법 규칙(enacted legal rules)은, 승인 규칙에 의해 제공되는 기준(criteria)에 따라 유효(valid)한 법 규칙으로 식별될 수는 있지만, 실제로 시행되기 전에는 아무런 실천이 존재하지 않아도, 제정되는 순간부터 법 규칙으로 존재할 수 있다. 따라서 이러한 제정법 규칙에 대해서는 실천 이론이 적용되지 않는다.

드워킨(Dworkin)의 실천 이론(practice theory of rules)에 대한 핵심 비판은, 이 이론이 사회 규칙(social rule)을 그것이 따르는 사회적 실천(social practice)에 의해 구성된 것으로 잘못 간주하고, 따라서 그러한 규칙이 존재한다는 진술을 단순히 그 규칙의 존재 조건으로 제시된 실천-조건들이 충족되었다는 외적 사회학적 사실에 관한 진술로 취급한다는 것이다⁴³. 그러나 드워킨에 따르면, 이러한 설명은 심지어 가장 단순한 관행적 규칙(conventional rule)이 가지는 규범적 성격(normative character)조차도 설명할 수 없다. 왜냐하면 이러한 규칙들은 의무(duties)와 행위에 대한 이유(reasons for action)를 확립하며, 실제로 이 규칙들이 인용될 때(일반적으로 비판이나 행위 요구의 근거로 인용된다) 그러한 역할을 수행하기 때문이다. 이처럼 이유를 제공하고 의무를 설정하는 기능은 규칙이 지니는 독특한 규범적 성격이며, 따라서 그러한 규칙의 존재는

⁴³[TRS 48-58면 참조.]

단순히 사실적 상태(factual state of affairs)—즉, 실천 이론에 따르면 사회 규칙의 존재를 구성하는 것으로 여겨지는 실천과 태도—에 귀속될 수 없다. 드워킨에 따르면, 이러한 독특한 특성을 지닌 규범적 규칙(normative rule)은 오직 ‘특정한 규범적 상태(normative state of affairs)’가 존재할 경우에만 존재할 수 있다⁴⁴. 나는 이 표현이 무엇을 의미하는지 다소 모호하다고 느낀다. 그는 예시로 든 ‘교회 출석자 규칙’(남성은 교회에서 모자를 벗어야 한다)⁴⁵에 대한 논의를 통해, 드워킨이 규범적 상태란 규칙이 요구하는 행위를 수행할 정당한 도덕적 근거(good moral grounds) 또는 정당화(justification)가 존재하는 상태를 의미하는 것으로 보인다. 드워킨은, 단순히 교회 참석자들이 교회에서 정기적으로 모자를 벗는 실천은 규칙 자체를 구성하지는 않지만, 모자를 쓰는 것이 불쾌감을 유발하거나 특정한 기대를 형성함으로써 해당 규칙을 정당화하는 데 기여할 수 있다고 주장한다. 그러나 만약 드워킨이 규범적 규칙에 대한 주장(assertion)을 정당화하기 위해 요구되는 규범적 상태를 이런 식으로 이해한다면, 그의 사회 규칙의 존재 조건에 대한 설명은 지나치게 강한 것으로 보인다. 이는 규칙을 의무 부여 혹은 행위 이유 제공의 근거로 삼는 참여자들이 단지 해당 규칙을 따르는 데 있어 도덕적으로 정당한 이유가 있다고 믿는 것뿐만 아니라, 실제로 그러한 정당한 이유가 존재해야 한다고 요구하는 셈이기 때문이다. 하지만 어떤 사회가 그 구성원에 의해 수용되는 규칙들을 가지고 있더라도, 그 규칙들이 도덕적으로 부당한 경우는 분명히 존재한다. 예컨대, 특정 인종이 공공시설(공원이나 해수욕장 등)을 이용하는 것을 금지하는 규칙은 그러한 예시이다. 더 나아가, 사회 규칙의 존재를 위한 조건으로서 단지 참여자들이 그러한 규칙을 따를 도덕적 정당한 이유가 존재한다고 믿는 것(believe)만을 요구하더라도, 그것조차도 사회 규칙의 존재 조건으로는 지나치게 강한 요구이다. 왜냐하면 일부 규칙은 전통에 대한 존중, 다른 사람들과 동일시하려는 욕구, 혹은 사회가 개인에게 유리한 방향을 가장 잘 안다고 믿는 신념 등 다양한 이유에서 수용되기도 하기 때문이다. 이러한 태도들은 해당 규칙이 도덕적으로 문제가 있다는 자각과 동시에 병존할 수도 있다. 물론 어떤 관행적 규칙은 실제로 도덕적으로

⁴⁴TRS 51면.

⁴⁵[TRS 50-58면; 본서 124-125면 참조.]

정당하고, 그렇게 믿어지기도 할 수 있다. 그러나 어떤 사람들이 특정 관행적 규칙을 자신의 행위 지침이나 비판 기준으로 수용한 이유를 묻는다면, 나는 이 책의 203쪽과 232쪽에서 언급된 바와 같이 여러 가능한 답변들 가운데 '규칙에 대한 도덕적 정당화에 대한 신념'을 유일하게 가능한 또는 충분한 해답으로 간주할 이유를 찾을 수 없다.

마지막으로, 드워킨은 심지어 관행적 규칙에만 한정하여 보더라도, 규칙에 대한 실천 이론은 결국 폐기되어야 한다고 주장한다. 그 이유는, 관행적 규칙의 적용 범위(scope)가 논쟁의 대상이 될 수 있고 실제로 이견이 존재하기 때문이다⁴⁶. 그는 어떤 규칙들은 정기적인 실천과 수용에 의해 구성된다는 점을 부정하지는 않지만, 그렇게 구성되는 규칙들은 상대적으로 중요하지 않은 사례들—예컨대 일부 게임의 규칙—에 불과하다고 주장한다. 그러나 이 책에서는, 당해 법(the law)을 적용하고 집행하는 법원의 행위에 대한 지침으로 법원이 일관되게 이를 수용하는 실천을 통해 구성된, 법체계의 기본 승인 규칙(rule of recognition)과 같은 중요하고도 거의 논란의 여지가 없는 규칙조차 실천 규칙으로 취급하고 있다. 이에 대해 드워킨은, 어려운 사건(hard cases)에서는 특정 주제에 관한 법이 무엇인지에 대해 판사들 사이에 이론적 분쟁이 자주 발생하며, 이로 인해 '논란 없음' 또는 '일반적 수용'이라는 외양은 환상에 불과하다고 주장한다. 물론 그러한 분쟁이 빈번하게 발생하고 또 중요하다는 점은 부정할 수 없다. 그러나 이러한 사실을 승인 규칙에 대한 실천 이론 적용가능성에 대한 반론으로 사용하는 것은 승인 규칙의 기능을 오해한 데 기초하고 있다. 즉, 승인 규칙은 어떤 사건에서 발생하는 모든 법적 쟁점을 단순히 그 규칙이 제공하는 기준(criteria)이나 시험(test)을 통해 해결할 수 있도록 완전한 법적 결과를 결정하는 기능을 수행하는 것이 아니다. 오히려 승인 규칙의 기능은, 현대 법체계에서 타당한 법적 판단이 충족해야 하는 일반 조건을 설정하는 데 있다. 이 규칙은 드워킨이 '연혁(pedigree)에 관한 사항들'이라 부르는, 법의 내용이 아니라 법이 생성되거나 채택된 방식 및 형식에 관한 기준을 제공함으로써 이러한 기능을 수행한다. 그러나 앞서 250쪽에서 언급했듯, 승인 규칙은 그러한 연혁 기준(pedigree matters)뿐 아니라, 법의 내용 자체가 특정 실질적 도덕 가치나 원칙에

⁴⁶[TRS 58면.]

부합하는지 여부에 관한 기준도 제공할 수 있다. 물론, 개별 사건에서 그러한 기준이 충족되었는지에 관하여 판사들 사이에 의견 차이가 존재할 수 있으며, 승인 규칙에 포함된 도덕적 기준은 그러한 분쟁을 해소하지 못할 수도 있다. 그러나 판사들은 특정 사건에서 그 기준이 무엇을 요구하는지에 관해서는 의견이 다르더라도, 해당 기준이 법원의 확립된 실천에 따라 법의 기준으로서 관련성을 갖는 것에 대해서는 일치할 수 있다. 이와 같은 방식으로 승인 규칙을 바라본다면, 실천 이론은 그 규칙에 대해 완전히 적용 가능하다.

(ii) 규칙(rules)과 원칙(principles)

오랫동안 드워킨(Dworkin)이 이 책에 대해 제기한 가장 널리 알려진 비판은, 이 책이 법(law)을 오직 ‘전부 아니면 무(無)’(all-or-nothing)식의 규칙들로만 구성된 것으로 오해하고 있으며, 법적 추론과 재판(adjudication)에서 중요한 역할을 수행하는, 전혀 다른 유형의 법적 기준인 법적 원칙(legal principles)을 간과하고 있다는 것이다. 이러한 결함을 지적한 일부 비평가들은, 그것이 비교적 고립된 결점이며 단지 법체계의 구성 요소로서 법적 규칙과 함께 법적 원칙을 포함시키는 방식으로 간단히 수정할 수 있는 것으로 이해하였다. 그리고 그들은 내가 책의 주요 논제를 포기하거나 심각하게 수정하지 않고도 그것을 수용할 수 있다고 여겼다. 그러나 이 비판을 처음 제기한 드워킨은, 법적 원칙을 나의 법 이론에 포함시키려면 그 중심 교의들을 포기하는 대가를 치러야 한다고 주장해 왔다. 그의 주장에 따르면, 만약 내가 법이 부분적으로 원칙들로 구성되어 있다고 인정한다면, 나는 법체계의 법(the law)이 법원이 수용하는 승인 규칙(rule of recognition)이 제공하는 기준(criteria)에 의해 식별된다고 한 나의 주장을 유지할 수 없게 되며, 또한 명시적인 기준의 법이 결정을 지시하지 못하는 경우 법원이 실제로 비어 있는 간극(interstitial)을 채우는 입법권 혹은 재량(law-making power or discretion)을 행사한다는 주장, 그리고 법과 도덕 사이에는 중요한 필연적 혹은 개념적 연결이 존재하지 않는다는 주장 또한 일관되게 유지할 수 없게 된다. 이 세 가지 주장은 단지 나의 법 이론의 핵심일 뿐 아니라, 현대 법실증주의(modern legal positivism)의 핵심을 구성하는 것으로

간주되어 왔으며, 따라서 이를 포기하는 것은 중대한 사안이다.

나는 이 응답의 본 절에서, 내가 법적 원칙을 무시하였다는 비판의 다양한 측면을 검토하고, 그 비판 중 유효(valid)한 것으로 보이는 부분이 있더라도 그것이 나의 전체 이론에 심각한 결과를 초래하지 않고 수용될 수 있음을 보이고자 한다. 그러나 나는 분명히 인정하건대, 이 책에서 재판(adjudication)과 법적 추론(legal reasoning), 특히 비평가들이 말하는 법적 원칙에 근거한 논증에 대해 거의 언급하지 않았다는 점은 결함이다. 나는 이제, 이 책에서 원칙들이 단지 지나가는 언급에 그친 것은 명백한 약점이라고 동의한다.

그러나 정확히 내가 무시했다고 비판받는 것이 무엇인가? 법적 원칙이란 무엇이며, 그것은 법적 규칙과 어떻게 다른가? 법학자들에 의해 사용될 때, '원칙(principles)'이라는 표현은 이론적·실천적 고려사항의 방대한 범위를 포함하는 경우가 많으며, 그 중 일부만이 드워킨이 제기하고자 한 문제와 관련된다. 설령 '원칙'이라는 표현이 사건 결정에 있어서 법원의 행위를 포함하는 행위 기준(standards of conduct)으로 한정된다 하더라도, 규칙과 그러한 원칙을 구분하는 방식은 여러 가지가 있을 수 있다. 그러나 나를 원칙을 무시했다고 비판한 모든 이들은 최소한 두 가지 특징이 규칙과 원칙을 구별하는 데 핵심적이라는 데 동의할 것이다. 첫째 특징은 정도(degree)의 문제로, 원칙은 규칙에 비해 상대적으로 넓고 일반적이며 불특정한 기준이다. 즉, 여러 개의 개별적 규칙들이 단일한 원칙의 예시나 실현으로 나타날 수 있다는 점에서 그러하다. 둘째 특징은, 원칙이 어느 정도 명시적으로 목적(purpose), 목표(goal), 권리(entitlement), 또는 가치(value)와 연결되며, 어떤 관점에서는 그것이 유지되어야 하거나 따를 만한 것으로 간주된다는 점이다. 이로 인해 원칙은 해당 규칙들을 설명하거나 그 근거를 제시하는 역할을 할 뿐 아니라, 규칙들을 정당화(justification)하는데 일정 부분 기여하는 것으로 간주된다.

이러한 비교적 논쟁의 여지가 없는 두 가지 특성—범위의 넓음과 어떤 관점에서의 바람직성—외에도, 원칙과 규칙을 구별하는 제3의 특징이 있다. 나는 그것이 정도의 문제라고 보는 반면, 드워킨은 그것이 결정적인 요소라고 본다. 드워킨에 따르면, 규칙은 그것을 적용하는 이의 추론에서 '전부 아니면 무'(all-or-nothing)의 방식으로 기능한다. 즉, 규칙이 유효(valid)하며 특정 사안에

적용 가능하다면, 그것은 필연적으로(necessitates) 법적 결과를 결정짓는다는 것이다⁴⁷. 그는 법적 규칙의 사례로, 고속도로에서 시속 60마일의 제한 속도를 정하는 규칙이나, 유언의 작성·증명·효력과 관련하여 유언장이 두 명의 증인의 서명이 없으면 유효하지 않다는 식의 법률 규정들을 들고 있다. 드워킨에 따르면, 법적 원칙은 이러한 전부 아니면 무식 규칙과 다르다. 왜냐하면 원칙은 적용될 때 필연적으로 결론을 도출하지 않으며, 단지 결정에 대한 방향 제시, 긍정적 요소, 혹은 재판부가 고려해야 할 일방적 이유(reason)를 제공할 뿐이고, 이는 다른 이유에 의해 무시될 수 있다. 나는 이러한 원칙의 특징을 간단히 ‘비결정적 성격(non-conclusive character)’이라 부르겠다. 드워킨이 제시한 이러한 비결정적 원칙의 예시에는 다음과 같은 것이 있다: ‘법원은 소비자 및 공익이 공정하게 대우받았는지 여부를 면밀히 검토하여 자동차 구매 계약을 살펴야 한다’⁴⁸, ‘자신의 잘못으로부터 이익을 얻어서는 안 된다’⁴⁹, 그리고 미국 연방 헌법 제1·5·14차 수정조항들에 규정된, 연방 의회 및 주 입법의 권한에 대한 가장 중요한 헌법적 제한들도 이러한 비결정적 원칙으로 작동한다고 그는 본다⁵⁰. 드워킨에 따르면, 법적 원칙은 규칙과 달리 유효성(validity)이 아니라 무게(중요도, weight)의 차원을 가진다⁵¹. 따라서 어떤 원칙이 더 큰 무게를 지닌 다른 원칙과 충돌할 경우, 전자는 무효화되거나 결정에서 배제될 수 있으나, 여전히 그 자체로는 온전히 존속하며, 다른 사안에서는 더 낮은 무게의 원칙과 경쟁하여 승리할 수 있다. 반면, 규칙은 유효하거나 무효하거나 둘 중 하나일 뿐이며, 무게의 차원을 가지지 않는다. 그래서 초기에 제시된 규칙들이 상호 충돌할 경우, 드워킨에 따르면 둘 중 오직 하나만 유효할 수 있고, 패한 규칙은 그 경쟁 규칙과 일치하도록 다시 공식화되어야 하며, 따라서 해당 사건에는 적용 불가능하게 된다⁵².

⁴⁷[TRS 24면.]

⁴⁸TRS 24면. 다음 판례에서 인용함: Henningsen v. Bloomfield Motors, Inc., 32 NJ 358, 161 A.2d 69 (1960), 387면, 85면.

⁴⁹TRS 25-26면.

⁵⁰[드워킨은 TRS 27면에서 수정헌법 제1조가 규칙(rule)인지 원칙(principle)인지 논의함.]

⁵¹[TRS 26면.]

⁵²TRS 24-27면.

나는 법적 원칙(legal principles)과 법적 규칙(legal rules) 사이에 이토록 날카로운 대조를 설정해야 할 이유를 인정하지 않으며, 또한 유효한(valid) 규칙이 특정 사안에 적용 가능하다면 반드시, 원칙과는 달리, 그 사건의 결과를 항상 결정해야 한다는 견해도 받아들이지 않는다. 유효한 규칙이 그 적용 가능한 경우들에 대하여 결과를 결정하는 것은, 단지 그와 동시에 동일 사건에 적용되는 더 중요하다고 판단되는 다른 규칙이 없는 경우에만 그러해야 한다는 점에서, 충분히 법체계가 인정할 수 있는 사항이다. 따라서 특정 사건에서 더 중요한 규칙과의 경쟁에서 패한 규칙도, 원칙과 마찬가지로, 다른 사건에서는 그것이 더 중요하다고 판단되는 경우 결과를 결정하는 데 사용될 수 있다⁵³.

드워킨(Dworkin)에 따르면, 법(law)은 전부 아니면 무(all-or-nothing)식의 규칙들과 비결정적(non-conclusive) 원칙들 모두를 포함한다. 그는 이 둘 사이의 차이가 정도의 문제라고는 보지 않는다. 그러나 나는 드워킨의 입장이 일관적(coherent)이라고 보지 않는다. 그의 초기 예시들 자체가, 규칙이 원칙과 충돌할 수 있으며, 어떤 경우에는 원칙이 규칙과의 경쟁에서 승리하기도 하고 패배하기도 한다는 점을 암시한다. 그가 인용한 사례 중에는 Riggs 대 Palmer 사건⁵⁴이 포함되는데, 이 사건에서는 '자신의 불법행위로부터 이익을 얻어서는 안 된다'는 원칙이, 유언의 효력에 관한 명확한 법정 규정에도 불구하고, 살인자가 자신의 희생자의 유언에 따라 상속받는 것을 배제하는 근거로 작용하였다. 이는 규칙과 원칙의 경쟁에서 원칙이 승리한 사례이지만, 그러한 경쟁 자체가 발생한다는 사실은 규칙들이 전부 아니면 무의 성격만을 가지는 것은 아님을 분명히 보여준다. 왜냐하면 규칙은 자신보다 더 큰 무게(weight)를 가진 원칙과의 충돌 속에서 밀려날 수 있기 때문이다. 설령 우리가 이러한 사례를 드워킨이 제안한 대로 규칙과 원칙 간의 충돌이 아니라, 해당 규칙을 설명하고 정당화하는 원칙과 다른 원칙 사이의 충돌로 설명한다 하더라도, 전부 아니면 무의 규칙과 비결정적 원칙 간의 날카로운 대비는 사라진다. 왜냐하면 이러한

⁵³이 점은 Raz와 Waluchow가 강조한 중요한 사안으로, 나는 이에 충분한 주의를 기울이지 못했다. J. Raz, "Legal Principles and the Limits of the Law", Yale Law Journal 제81권 (1972) 823면, 832-834면; W. J. Waluchow, "Herculean Positivism", Oxford Journal of Legal Studies 제5권 (1985) 187면, 189-192면 참조.

⁵⁴115 N.Y. 506, 22 N.E. 188 (1889); TRS 23면; LE 15면 이하 참조.

관점에서 보면, 특정 규칙이 그 문언상 적용되는 사안에서 결과를 결정하지 못하는 것은, 그것을 정당화하는 원칙이 다른 원칙에 의해 무게에서 밀렸기 때문이라는 설명이 가능하기 때문이다. 마찬가지로, 드워킨이 제안한 또 다른 해석처럼, 원칙이 명확하게 형성된 어떤 법적 규칙에 대한 새로운 해석의 이유(reason)를 제공한다고 본다면, 역시 마찬가지로의 결론이 따른다⁵⁵.

이처럼 전부 아니면 무의 규칙과 비결정적 원칙이 공존한다는 주장에서 발생하는 비일관성은, 그 구분이 정도의 문제라고 인정한다면 해소될 수 있다. 실제로 법적 결과를 결정하는 데 있어서, 적용 조건이 충족되면 (다른 보다 중요한 규칙과의 충돌이 있는 일부 사례를 제외하고는) 대부분의 경우 결과를 결정할 수 있는, 거의 결정적인(near-conclusive) 규칙들과, 반면 그저 어떤 방향을 가리키기만 하고 자주 결과를 결정하지는 못하는 비결정적 원칙들 간에는 합리적인 대비가 가능하다.

나는 이러한 비결정적 원칙들로부터의 논증이 재판(adjudication)과 법적 추론(legal reasoning)의 중요한 요소라고 확신하며, 이에 상응하는 적절한 개념어가 마련되어야 한다고 생각한다. 이 점을 보여주고 구체적인 예시를 들어 그 중요성과 기능을 밝힌 점에서 드워킨은 확실히 공로가 있다. 나는 이 원칙들이 가지는 비결정적 효력을 강조하지 않은 점이 나의 중대한 실수였다는 점을 인정한다. 그러나 나는 ‘규칙(rule)’이라는 단어를 사용할 때, 법체계가 오직 ‘전부 아니면 무(all-or-nothing)’ 방식의 규칙 또는 거의 결정적인 규칙들만을 포함한다고 주장하려던 의도는 전혀 없었다. 나는 이 책의 130-3쪽에서 (다소 부적절한 표현이긴 하지만) ‘가변적 법적 기준(variable legal standards)’이라 불리는 개념에 주목하였으며, 이러한 기준이 상충하는 요소들을 고려하고 비교형량하는 방식으로 기능한다는 점을 지적하였다. 또한 133-4쪽에서는 어떤 행위 영역들이 ‘상당한 주의(due care)’와 같은 가변적 기준보다는, 드문 예외를 제외하고 항상 동일한 특정 행위를 요구하거나 금지하는 거의 결정적인 규칙들에 의해 규율되는 것이 더 적합한지에 대한 이유를 설명하고자 하였다. 그래서 우리는 살인(murder)과 절도(theft)에 대한 금지 규칙을 갖고 있는 것이며, 단지 인간 생명(human life)과 재산(property)에 대한 적절한 존중을 요구하는 원칙

⁵⁵[드워킨의 논의는 TRS 22-28면, LE 15-20면 참조.]

만으로는 충분하지 않은 것이다.

4. 원칙과 승인 규칙(Rule of Recognition)

형식적 기원(Pedigree)과 해석(Interpretation)

드워킨(Dworkin)은 법적 원칙(legal principles)은 법원(courts)의 실천에서 드러나는 승인 규칙(rule of recognition)이 제공하는 기준에 의해 식별될 수 없으며, 법적 원칙들이 법(law)의 필수 구성 요소인 이상, 승인 규칙에 관한 이론은 폐기되어야 한다고 주장해왔다. 그의 견해에 따르면, 법적 원칙은 오직 구성적 해석(constructive interpretation)을 통해서만 식별될 수 있는데, 이 해석은 특정 법체계의 확립된 법(settled law)의 제도적 역사 전체와 가장 잘 부합하고 이를 가장 잘 정당화하는 유일한 일련의 원칙들로 구성된다. 물론 영국이든 미국이든 어떤 법원도 당해 법(the law)을 식별하는 기준으로서 이러한 체계 전반적이고 총체적인 기준을 명시적으로 채택한 적은 없다. 드워킨 자신도 실제 인간 판사, 즉 그의 신화적 이상 판사인 '헤라클레스(Hercules)'와 구별되는 현실의 판사라면 누구든 자국의 모든 법을 단번에 해석해 구성해내는 일은 불가능하다는 점을 인정한다. 그럼에도 불구하고 그는 법원들이 제한된 방식으로 '헤라클레스를 모방하려 한다'고 보는 것이 가장 설명력이 높다고 본다. 그는 이러한 관점으로 법원의 판결을 바라보는 것이 '숨겨진 구조(the hidden structure)'를 드러내는데 도움이 된다고 주장한다⁵⁶.

영국의 법률가들에게 익숙한 예 중 가장 유명한 것은 Donoghue 대 Stevenson 사건⁵⁷에서 애킨 경(Lord Atkin)이 이전까지 명시적으로 공식화되지 않았던 '이웃 원칙(neighbour principle)'을, 다양한 상황에서 주의의무(duty of care)를 정립해 온 개별 규칙들을 뒷받침하는 기반 원칙으로 구성적 해석을 통해 식별한 것이다.

나는 이와 같은 제한된 구성적 해석의 사례들에서, 판사들이 헤라클레스의 총체적 접근을 모방하려 했다고 이해하는 것이 설득력 있다고는 보지 않는다.

⁵⁶LE 265면.

⁵⁷[1932] A.C. 562.

그러나 여기서 내가 제기하는 비판의 핵심은, 드워킨이 구성적 해석에 집착함으로써 다수의 법적 원칙들이 정착된 법의 해석으로 기능하는 그 내용이 아니라, 그가 ‘형식적 기원(pedigree)’이라 부르는 바와 같이 승인된 권위 있는 출처(authoritative source)에 의해 창출되거나 채택된 방식에 의해 법적 지위를 획득한다는 사실을 간과하게 되었다는 점이다. 이러한 해석 중심적 집착은 결국 드워킨에게 두 가지 오류를 야기했다. 첫째, 법적 원칙은 형식적 기원에 따라 식별될 수 없다는 믿음. 둘째, 승인 규칙은 오직 형식적 기원 기준(pedigree criteria)만을 제공할 수 있다는 믿음이다. 이 두 믿음은 모두 잘못이다. 첫째는, 원칙의 비결정적(non-conclusive) 성격이나 그 밖의 특성들 중 어느 것도 형식적 기원에 의한 식별을 배제하지 않기 때문에 잘못되었다. 실제로 성문 헌법(written constitution)이나 헌법 개정(constitutional amendment), 혹은 일반 법률(statute)조항이, 원칙의 특징인 비결정적 방식으로 작동하도록 의도되었음을 받아들일 수 있다. 이는 어떤 사안에서는 더 강력한 이유(reasons)를 제시하는 다른 규칙이나 원칙이 존재할 경우, 해당 조항이 제공하는 결정 이유가 이를 압도당할 수 있다는 의미이다. 드워킨 자신도 미국 수정헌법 제1조(First Amendment)—연방 의회는 표현의 자유(freedom of speech)를 침해해서는 안 된다는 조항—가 바로 이러한 방식으로 해석되어야 한다고 본다⁵⁸. 또한, ‘자신의 불법행위로부터 이익을 얻어서는 안 된다(no man may profit from his own wrongdoing)’는 것과 같은 일부 공통법(Common Law)의 기본 원칙들은, 여러 사건들에서 법원이 일관되게 그 원칙들을 결정의 이유로 소환해온 역사로부터, 형식적 기원에 의한 식별(pedigree test)을 통해 법으로 식별된다. 이는 그 원칙이 어떤 경우에는 반대 방향으로 작용하는 더 강력한 이유들에 의해 배제될 수 있음에도 불구하고, 고려되어야 할 결정 사유로 작용해왔음을 보여준다. 이처럼 형식적 기원 기준에 의해 식별되는 법적 원칙들의 존재 앞에서, 원칙을 법의 일부로 포함하는 것이 승인 규칙 이론의 포기를 수반한다는 일반 논변은 성립될 수 없다. 오히려 내가 아래에서 보여줄 바와 같이, 원칙을 법에 포함시키는 것은 승인 규칙 이론의 수용을 필요로 하며, 그것과 양립 가능할 뿐 아니라 오히려 그것에 의해 뒷받침된다. 만일 적어도 일부 법적 원칙들이 승인 규칙이 제공하는

⁵⁸[TRS 27면 참조.]

형식적 기원 기준에 따라 법으로 ‘포착’되거나 식별될 수 있다는 점이 인정된다면—이는 반드시 인정되어야 한다—드워킨의 비판은 보다 겸손한 주장으로 축소되어야 한다. 즉, 너무 많거나, 지나치게 일시적이거나, 자주 변경되며, 형식적 기원과 같은 기준으로 식별될 수 있는 속성이 없고, 오직 특정 법체계의 제도적 역사와 실천들에 가장 잘 부합하고 그것을 가장 잘 정당화하는 일관된 원칙 체계에 속하는가 여부라는 기준에 의해서만 법적 원칙으로 식별될 수 있는 많은 원칙들이 존재한다는 주장이다. 겉보기에 이러한 해석주의적 기준은 승인 규칙이 제공하는 기준의 대안이 아닌 듯하지만, 일부 비평가들이 주장한 바와 같이,⁵⁹ 그것은 단지 그 내용(content)에 따라 원칙을 식별하는 복합적인 ‘연성 실증주의(soft-positivist)’ 형태의 승인 규칙에 불과하다. 물론 그러한 해석적 기준이 승인 규칙의 일부로 포함된다면, 드워킨이 본문 251쪽 이하에서 논의한 바와 같이, 법 식별에서 실증주의자가 바라는 정도의 유효성(validity)이나 확실성(certainty)을 확보하지는 못할 것이다. 그럼에도 불구하고, 해석 기준이 법-승인의 관행적 패턴(conventional pattern of law-recognition)의 일부임을 보여주는 것은 그것이 가지는 법적 지위(legal status)를 이론적으로 설명하는데 있어 여전히 유의미하다. 따라서 드워킨이 주장한 바와 같은, 원칙을 법의 일부로 수용하는 것과 승인 규칙 이론 사이에 존재한다고 한 불일치는 결코 존재하지 않는다.

최근 두 단락의 논증만으로도, 드워킨(Dworkin)의 주장과 달리, 원칙들(principles)을 법(law)의 일부로 수용하는 것이 승인 규칙(rule of recognition) 이론과 양립 가능하다는 점은 분명히 드러난다. 이는 비록 드워킨이 주장하듯 해석 기준(interpretive test)이 그러한 원칙들을 식별하기 위한 유일하게 적절한 기준이라고 하더라도 그러하다. 그러나 실제로는 이보다 더 강한 결론이 도출될 수 있다. 즉, 법적 원칙들(legal principles)이 그러한 기준에 의해 식별되기 위해서는 승인 규칙이 반드시 필요하다는 것이다. 왜냐하면 드워킨의 해석 기준에 따라 밝혀질 법적 원칙의 식별 출발점은, 해당 원칙이 부합하며 정당

⁵⁹예: E. P. Soper, “Legal Theory and the Obligation of a Judge”, RDCJ 3면, 16면; J. Coleman, “Negative and Positive Positivism”, RDCJ 28면; D. Lyons, “Principles, Positivism and Legal Theory”, Yale Law Journal 제87권 (1977) 415면.

화에 기여하는 어떤 특정한 확립된 법(settled law)의 영역이기 때문이다. 따라서 그러한 기준을 사용하는 것은 곧 확립된 법의 식별을 전제로 하며, 이러한 식별이 가능하려면 법의 근원을 구성하는 자료(source of law)들과 이들 간의 상하관계(superiority and subordination relationships)를 명시하는 승인 규칙이 필요하다. Law's Empire에서 사용된 용어를 따르자면, 잠재적이거나 암시적(implicit)인 법적 원칙들을 식별하기 위한 해석적 과제의 출발점이 되는 법적 규칙과 실천들은 '전(前)해석적 법(preinterpretive law)'을 구성하며, 드워킨이 이에 대해 언급한 내용의 상당 부분은, 그것을 식별하기 위해서는 본서에서 기술된 바와 같은 법의 권위 있는 근원을 식별하는 승인 규칙과 유사한 무언가가 필요하다는 견해를 뒷받침하는 것으로 보인다. 이 점에서 나와 드워킨의 입장 간 핵심 차이는 다음과 같다. 나는 법의 근원을 식별하는 기준에 대해 판사들 간에 일반적인 합의가 존재하는 이유를, 그러한 기준을 제공하는 규칙들(rules)의 공유된 수용(acceptance) 때문이라고 본다. 반면 드워킨은 이를 '규칙'이라고 부르지 않고, 동일한 해석 공동체(interpretive community) 구성원들이 공유하는 '합의(consensus)'⁶⁰, '전형(paradigms)'⁶¹, '가정(assumptions)'⁶²이라는 용어로 설명하길 선호한다. 물론 드워킨이 명확히 설명하듯, 독립적 확신들의 합의(consensus of independent convictions)—그 구성원 각각이 동일한 판단에 도달하는 데 있어 타인의 판단을 이유로 고려하지 않는 경우—와, 구성원들의 판단이 상호적으로 의존하는 관행의 합의(consensus of convention)는 중요한 차이를 가진다. 분명히, 본서에서 승인 규칙은 후자의 관행적 형태의 사법적 합의에 기초한 것으로 다뤄진다. 특히 영미법에서 이것은 명확하다. 영국의 판사가 의회 입법을(또는 미국 판사가 헌법을) 다른 법의 근원(source of law)들보다 우위에 있는 법의 근원으로 다루는 이유 중에는, 동료 판사들과 과거 판사들 역시 그렇게 해왔다는 사실이 포함된다. 실제로 드워킨 자신도 입법 우위 원칙(doctrine of legislative supremacy)을 법적 역사(legal history)의 날것의 사실(brute fact)로 묘사하며, 이는 판사의 개인적 신념이 수행할 수 있는 역할을

⁶⁰[LE 65-66면, 91-92면.]

⁶¹[LE 72-73면.]

⁶²[LE 47, 67면.]

제한한다고 말한 바 있다⁶³. 그는 또한 ‘해석적 태도(interpretive attitude)는 동일한 해석 공동체의 구성원들이 “무엇이 실천의 일부로 간주되는가”에 관한 최소한 유사한 가정을 공유하지 않으면 유지될 수 없다’고 진술한다⁶⁴. 따라서 나는 결론적으로, 드워킨이 말하는 ‘가정(assumptions)’, ‘합의(consensus)’, ‘전형(paradigms)’과 규칙(rules) 사이에 어떤 차이가 남아있다고 하더라도, 법의 근원을 판사가 식별하는 방식에 대한 그의 설명은 실질적으로 나의 설명과 동일하다고 본다.

그러나 나와 드워킨의 견해 사이에는 여전히 상당한 이론적 차이가 존재한다. 드워킨은 내가 그의 해석 기준을 법적 원칙들을 위한 승인 규칙의 특정한 형태—즉, 해당 법체계의 판사들에 의해 수용되는 관행적 규칙(conventional rule)—으로 다른 것을 분명히 거부할 것이다. 이는 그가 보기에, ‘법을 도덕적으로 가장 좋은 빛으로 제시하려는 구성적 해석(constructive interpretation)의 과업’을 왜곡하고 폄훼하는 것으로 여겨질 것이기 때문이다. 드워킨은 이러한 해석 방식을 단순히 특정 법체계에서 판사들과 법률가들이 수용하는 관행적 규칙에 의해 요구되는 법 인식의 방식으로 보지 않는다. 오히려 그는 그것을 법을 넘어서서 다양한 사회사상과 사회적 실천에서 나타나는 중심적 특징이며, 문학비평에서의 해석이나 심지어 자연과학에서의 해석과도 깊은 연관성을 지닌다고 제시한다⁶⁵. 그러나 설령 이 해석 기준이 단순히 관행적 규칙이 요구하는 법 인식의 방식이 아니라 다른 학문 영역에서 이해되는 해석들과 유사성과 연결성을 가진다고 하더라도, 만약 드워킨의 총체적 해석 기준(holistic interpretive criterion)이 실제로 법적 원칙들을 식별하는 데 사용되는 어떤 법체계가 존재한다면, 그 법체계에서 해당 기준은 관행적 승인 규칙에 의해 제공되는 것일 수 있음은 분명하다. 하지만 현실의 어떤 법체계도 그러한 전면적 총체적 기준을 실제로 사용하지는 않는다. 단지 영국법이나 미국법과 같은 체계들에서는 Donoghue 대 Stevenson 사건과 같은 사안에서 구성적 해석을 보다 제한적으로 수행하며, 잠재된 법적 원칙들을 식별하는 정도에 그친다. 그러므로 우리가

⁶³[LE 401면.]

⁶⁴LE 67면.

⁶⁵LE 53면.

검토해야 할 유일한 질문은, 이러한 제한된 구성적 해석이 관행적 승인 규칙이 제공하는 기준의 적용으로 이해되어야 하는가, 혹은 다른 방식으로 이해되어야 하는가이며, 만약 그렇다면 그것들이 가지는 법적 지위는 무엇인가 하는 것이다.

5. 법과 도덕 (LAW AND MORALITY)

(i) 권리와 의무 (Rights and Duties)

이 책에서 나는, 법(law)과 도덕(morality) 사이에는 다양한 우연적 연관성들이 존재할 수 있지만, 그 내용 사이에는 개념적으로 필연적인 연결은 존재하지 않는다고 주장한다. 따라서 도덕적으로 부당한 조항들 역시 유효한(valid) 법규(rule) 또는 원칙(principle)으로 성립할 수 있다. 이러한 법과 도덕의 분리를 나타내는 한 측면은, 도덕적 정당성이나 구속력 없이도 법적 권리(legal rights)와 법적 의무(legal duties)가 존재할 수 있다는 점이다. 드워킨(Dworkin)은 이러한 견해를 거부하고, 법적 권리와 의무의 존재를 주장하기 위해서는 적어도 일차적으로는 도덕적 이유들(moral grounds)이 있어야 한다는 견해를 지지한다. 그는 ‘법적 권리는 도덕적 권리의 한 종류로 이해되어야 한다’는 생각을 자신의 법이론에서 ‘결정적(crucial)’⁶⁶ 요소로 간주하며, 이에 반대하는 실증주의적(positivist) 이론은 ‘법적 본질주의(legal essentialism)라는 특이한 세계’에 속한다고 말한다. 이 세계에서는 우리가 분석 이전(pre-analytically)부터 도덕적 근거 없이도 법적 권리와 의무가 존재할 수 있다는 사실을 단순히 ‘주는 대로’ 아는 것으로 되어 있다⁶⁷. 그러나 나는 드워킨의 일반 해석이론의 장점이 무엇이든 간에, 법적 권리와 의무가 도덕적 정당성이나 구속력 없이도 존재할 수 있다는 이론에 대한 그의 비판은 오류라고 본다. 그 이유는 다음과 같다. 법적 권리와 의무는, 각각 개인의 자유를 보호하거나 제한하며, 수범자(subject)에게 법의 강제 수단(coercive machinery)을 행사할 수 있는 권한을 부여하거나 부인하는 법체계의 핵심 작용 지점을 구성한다. 따라서 해당 법률들이 도덕적으로 선하든 악하든, 정의롭든 불의하든 간에, 법적 권리와 의무는 인간에게 지대한 중요성을 가지는

⁶⁶RDCJ 260면.

⁶⁷RDCJ 259면.

법의 작동에서 중심적 지점들이며, 이는 법의 도덕적 정당성과는 무관하게 중요하다. 그러므로, 법적 권리와 의무의 명제(proposition)가 현실 세계에서 의미를 가지기 위해 반드시 도덕적 근거가 있어야 한다는 주장은 사실이 아니다.

(ii) 법의 식별 (The Identification of the Law)

이 책에서 전개된 법이론과 드워킨의 이론 사이의 법과 도덕의 연관성에 대한 가장 근본적인 차이는 법의 식별 방식에 있다. 내 이론에 따르면, 법의 존재와 내용은 그 사회적 근원들(social sources of the law)—예: 입법, 판결, 사회 관습 등—에 대한 참조를 통해 식별될 수 있으며, 그 법 자체가 도덕적 기준을 법 식별 기준으로 통합하지 않은 이상, 도덕에 대한 참조는 필요하지 않다. 반면 드워킨의 해석이론에서는, 어떤 주제에 관한 법이 무엇인지 진술하는 모든 법적 명제(proposition of law)는 반드시 도덕적 판단을 수반한다. 왜냐하면 그의 전체론적(holistic) 해석이론에 따르면, 어떤 법적 명제가 참이기 위해서는, 다른 전제들과 함께, 사회적 근원을 통해 식별된 확립된 법(settled law) 전체에 가장 잘 부합하고, 그것을 도덕적으로 가장 잘 정당화하는 원칙들의 집합으로부터 도출되어야 하기 때문이다. 이러한 전체론적 해석이론은 따라서 이중적 기능을 수행한다. 즉, 법을 식별하고 동시에 그것을 도덕적으로 정당화한다.

이것이 바로 Law's Empire에서 드워킨이 ‘해석적(interpretive)’ 법과 ‘전(前)해석적(preinterpretive)’ 법 사이의 구분을 도입하기 이전의, 요약된 그의 이론이다. 실증주의자(positivist)의 이론—즉, 법의 존재와 내용은 도덕과 무관하게 식별될 수 있다는 주장—에 대한 대안으로서 드워킨의 원래 이론은 다음과 같은 비판에 취약했다. 즉, 사회적 근원을 통해 식별된 법이 도덕적으로 부당할 경우, 그것을 가장 잘 ‘정당화’하는 원칙들은 단지 그 부당한 법에 부합하는 원칙들 가운데 가장 덜 부당한 원칙일 수밖에 없다. 그러나 이러한 ‘덜 부당한’ 원칙들은 어떤 정당화력을 갖지 못하며, 법으로 간주될 수 있는 것에 대해 도덕적 한계나 제약을 제공할 수 없다. 그리고 그것들은 아무리 부당한 법체계라도 반드시 부합하므로, 그것들에 따라 법을 식별한다는 이론은 도덕에 대한 어떤 참조 없이도 법을 식별할 수 있다는 실증주의 이론과 구별되지 않는다. 드워킨

이 ‘배경 도덕성(background morality)’⁶⁸이라 부른 기준에 비추어 도덕적으로 타당한 원칙들—즉 단지 법에 부합하는 원칙들 중에서 가장 타당한 것이 아닌 원칙들—은 실제로 법으로 간주될 수 있는 것에 도덕적 한계나 제약을 부여할 수 있다. 나는 이 명제에 대해 어떤 반대도 하지 않는다. 그러나 그것은 법이 도덕에 대한 참조 없이도 식별될 수 있다는 나의 주장과 완전히 양립 가능하다.

드워킨(Dworkin)은 후기 이론에서 ‘해석적(interpretive) 법’과 ‘전(前)해석적(preinterpretive) 법’ 사이의 구분을 도입하면서, 도덕적으로 우리가 수용할 수 있는 어떤 해석도 불가능할 정도로 악한 법체계가 존재할 수 있음을 인정한다. 이러한 경우, 그는 설명하듯이, ‘내부 회의주의(internal scepticism)’⁶⁹에 의지하여 해당 체계를 법(law)으로 간주하는 것을 거부할 수 있다고 말한다. 그러나 이러한 상황을 기술할 수 있는 우리의 언어 자원은 매우 유연하기 때문에, 반드시 그러한 결론에 도달해야만 하는 것은 아니다. 대신, 아무리 악한 법체계라도 전(前)해석적 의미에서 법이라고 말할 수 있다⁷⁰. 따라서, 우리는 심지어 가장 악명 높은 나치(Nazi) 법률조차도 법이 아니라고 단정할 필요는 없다. 왜냐하면 그 법들은 도덕적으로 부당한 내용을 가졌다는 점만이 다를 뿐, 도덕적으로 수용 가능한 체제의 법률들과 법의 형식적 특성(예: 법 형성 절차, 재판 및 집행 절차 등)을 공유하고 있기 때문이다. 많은 문맥에서, 그리고 다양한 목적을 위해, 우리는 그 도덕적 차이를 무시하고 연성 실증주의자(soft positivist)처럼 그 악한 체계들 역시 법이라고 말할 이유가 충분할 수 있다. 이에 대해 드워킨은 다만 부가적으로 그의 일반적 해석주의적 입장을 드러내며, 그러한 악한 체계들은 오직 전(前)해석적 의미에서만 법이라고 덧붙일 것이다.

나는 이러한 언어적 유연성에 대한 호소와 해석적/전(前)해석적 법 사이의 구분의 도입은 실증주의자의 입장을 약화시키기보다는 오히려 그것을 인정하는 것으로 본다. 왜냐하면 이는 실질적으로 ‘기술적 법이론(descriptive jurisprudence)’에서 법은 도덕에 대한 참조 없이도 식별될 수 있으나, ‘정당화적 해석법이론(justificatory interpretive jurisprudence)’에서는 당해 법(the law)

⁶⁸[TRS 112, 128면, TRS 93면 참조.]

⁶⁹LE 78–79면.

⁷⁰[LE 103면.]

의 식별이 항상 그 확립된 법(settled law)을 가장 잘 정당화하는 도덕적 판단을 수반해야 한다는 메시지를 전달하는 것 이상이 아니기 때문이다. 물론 이 메시지는 실증주의자가 자신의 기술적 작업을 포기해야 할 이유를 제공하지 않으며, 애초에 그러한 목적도 아니다. 그러나 이 메시지조차도 한 가지 점에서 수정되어야 한다. 왜냐하면 법이 너무나 악하여 '내부 회의주의'가 필요한 경우, 법에 대한 해석은 도덕적 판단을 수반하지 않게 되며, 드워킨이 이해하는 바의 해석 자체가 포기되어야 하기 때문이다⁷¹.

드워킨의 해석이론에 대한 또 하나의 중요한 수정은 그의 법적 권리에 대한 설명과 관련이 있다. 초기의 전체론적 해석이론에서, 법의 식별과 그 정당화는 모두 특정 법체계의 모든 확립된 법을 가장 잘 부합시키고 정당화하는 하나의 고유한 원칙 집합으로부터 도출되는 것으로 간주되었다. 따라서 이러한 원칙들은 앞서 언급한 바와 같이 이중 기능을 가진다. 그러나 어떤 법체계의 확립된 법이 너무나 악하여 전반적인 정당화 해석이 불가능한 경우에는, 이 두 기능이 분리될 수 있으며, 그 결과 도덕적 참조 없이도 식별되는 법의 원칙들만이 남게 된다. 하지만 그러한 법은 드워킨이 주장하는 바와 같이 일차적으로 도덕적 구속력(prima-facie moral force) 가지는 법적 권리를 창출할 수 없다. 그럼에도 드워킨은 이후에, 법체계 전체가 매우 사악하여 도덕적 또는 정당화 가능한 해석이 불가능한 경우에도, 특정한 상황에서는 개인이 적어도 일차적으로 도덕적 구속력을 지닌 권리를 가진다고 말할 수 있는 경우가 존재할 수 있음을 인정하였다⁷². 예컨대 그러한 경우는, 해당 체계가 계약의 형성과 집행에 관한 법률 등과 같이, 법체계의 일반적 사악함에 영향을 받지 않는 법을 포함하고 있으며, 개인이 자신의 삶을 계획하거나 재산을 처분하는 데 있어 그 법률에 의존한 경우에 해당한다. 이러한 상황을 반영하기 위해 드워킨은, (p. 272) 일차적으로 도덕적 구속력을 지닌 법적 권리와 의무는 일반 해석이론으로부터 도출되어야 한다는 자신의 원래 입장을 수정하고, 자신의 일반 이론과는 무관하게, 이러한 상황들에서 개인에게 일정한 도덕적 구속력을 지닌 법적 권리를 부여하는 '특별한 이유들(special reasons)'이 존재한다고 인정하였다.

⁷¹[LE 105면.]

⁷²[LE 105-106면.]

6. 사법적 재량(Judicial Discretion)⁷³

이 책에서 제시하는 법이론과 드워킨(Dworkin)의 이론 간 가장 직접적이고 날카로운 충돌은, 어떤 법체계에서도 법적으로 규율되지 않은 사안들이 항상 존재하며, 특정 쟁점에 대해 어느 쪽의 결론도 법(law)에 의해 요구되지 않는 경우가 발생한다는 나의 주장에 기반한다. 따라서 법(law)은 부분적으로는 불완전하거나 결정 불가능하며(indeterminate), 법적으로 비규율된 사안에서는 판사가 결정을 내려야 한다. 이때 벤담(Bentham)이 한때 주장한 것처럼 사법권을 부인하거나 기존 법이 규율하지 않는 쟁점을 입법부에 회부하지 않는 한, 판사는 기존에 존재하던 확립된 법을 단순히 적용하는 것이 아니라 재량(discretion)을 행사하여 당해 사건(the case)을 위한 새로운 법을 창출(make)해야 한다. 따라서 이러한 법적으로 미규율된 사안들에서 판사는 확립된 법을 적용하는 동시에 새로운 법을 창출하게 된다. 확립된 법은 그에게 법창출 권한을 부여함과 동시에 그것을 제한하는 역할을 한다.

이처럼 법(the law)이 부분적으로 불완전하거나 결정 불가능하며, 판사는 제한된 범위 내에서 법 창출적 재량(law-creating discretion)을 행사하여 그 틈(gap)을 메운다는 구상은, 드워킨에 의해 왜곡된 묘사로 간주되어 거부된다. 드워킨은, 불완전한 것은 법(law)이 아니라 오히려 실증주의자의 그것에 대한 묘사라고 주장하며, 자신이 제시한 ‘해석적(interpretive)’ 설명에서 이를 밝히고자 한다. 그에 따르면, 사회적 근거(social sources)를 통해 식별되는 명시적(explicit) 확립법 외에도, 그것에 가장 잘 부합하거나 일관되며(cohere) 도덕적으로 정당화할 수 있는 원칙들 역시 함의된(implicit) 법적 원칙으로 간주되어 법(the law)에 포함된다. 이러한 해석적 관점에서는 법(the law)이 결코 불완전하거나 결정 불가능하지 않으며, 따라서 판사는 결정을 내리기 위해 법 바깥으로 나가(law-creating power를 행사하여) 새로운 법을 만드는 상황에 처하지 않는다. 그러므로, 사회적 근거들이 어떤 법적 쟁점에 대해 결정을 내려주지 못하는 이른바 ‘난해한 사건(hard cases)’에서는 법원은 그러한 도덕적 차원(moral dimensions)을 포함한 함의적 원칙들에 호소해야 한다.

⁷³[본 절의 도입 문단의 대체 버전은 미주(endnote)에 수록됨.]

내가 주장하는 바, 기존 법이 부분적으로 규율하지 못한 사안들을 해결하기 위해 판사에게 부여된 법 창출 권한(law-creating powers)은 입법자의 권한과는 다르다는 점이 중요하다. 판사의 권한은 입법자가 자유롭게 행사할 수 있는 것과는 달리 그의 선택을 좁히는(narrowing his choice) 많은 제약들에 종속될 뿐만 아니라, 판사의 권한은 특정 사건의 분쟁을 해결하는 데에만 제한적으로 사용되므로 대규모 개혁이나 새로운 법전의 도입과 같은 권한은 행사할 수 없다. 이러한 의미에서, 판사의 권한은 간극적(interstitial)이며 실체적 제약(substantive constraints)을 많이 받는다. 그럼에도 불구하고, 기존 법이 어느 쪽 결론도 지시하지 못하는 지점이 존재하며, 이러한 경우에 판사는 법 창출 권한을 행사하지 않으면 안 된다. 그러나 그는 이를 자의적으로 행사해서는 안 된다. 즉, 그는 항상 자신의 결정에 대해 정당화할 수 있는 일반적 이유들(general reasons)을 가져야 하며, 자신의 신념과 가치에 따라 결정하는 양심적 입법자(conscientious legislator)처럼 행동해야 한다. 이 조건들을 충족할 경우, 그는 법(law)에 의해 지시되지 않고, 유사한 난해한 사건들에서 다른 판사들이 따를 수 있는 것과는 다른 기준(standards)이나 이유들(reasons)을 따를 권한이 있다.

법원이 이렇게 부분적으로만 규율된 사건들을 해결하기 위해 제한된 재량권을 행사한다는 나의 설명에 대해, 드워킨은 세 가지 주요 비판을 제기한다. 첫째, 이는 '난해한 사건(hard cases)'에서 법원이 실제로 수행하는 것과 사법적 절차(judicial process)를 잘못 기술한 설명이라는 것이다⁷⁴. 이를 보여주기 위해 드워킨은 판사와 변호사들이 판사의 임무를 설명할 때 사용하는 언어와, 사법적 결정의 현상학(phenomenology)에 주목한다. 사건을 심리하는 판사와 유리한 결정을 유도하고자 하는 변호사들은, 심지어 새롭고 난해한 사건에서도, 판사가 '법을 만든다(make law)'는 식의 표현을 거의 사용하지 않는다. 심지어 가장 어려운 사건에서도, 판사는 실증주의자가 주장하듯이 다음과 같은 전혀 다른 두 단계를 구분하여 인식하는 태도를 거의 보이지 않는다. (1) 판사가 먼저 기존 법이 어느 쪽의 결정을 지시하지 못한다고 판단하는 단계, 그리고 (2) 그 다음 기존 법에서 벗어나 자신의 판단에 따라 당사자들을 위해 사후적으로(ex

⁷⁴[TRS 81면; LE 37-39면 비교.]

post facto), 처음부터(de novo) 새로운 법을 만드는 단계. 대신, 변호사들은 마치 판사가 항상 기존의 법을 발견하고(enforce) 집행하는 임무를 가진 것처럼 말하며, 판사 역시 법(law)이 모든 사안에 대한 해답을 이미 내포하고 있는, 즉 틈이 없는(gapless) 권리체계로 구성되어 있다고 말하는 경향이 있다.

물론, 사법 절차에 내재된 익숙한 수사(rhetoric)는 발전된 법체계에는 법적으로 규율되지 않은 사안이 없다는 인상을 준다. 그러나 우리는 이러한 언어를 어디까지 심각하게 받아들여야 할 것인가? 유럽의 오랜 전통과 권력분립 이론은 입법자(Legislator)와 판사(Judge)의 구분을 극적으로 강조하며, 판사는 기존 법이 명확할 때 그러하듯이 언제나 자신이 만들거나 수정하지 않은 법의 대변자(mouthpiece)에 불과하다고 주장한다. 하지만, 판사와 변호사들이 법정을 운영하며 사용하는 의례적 언어(ritual language)와, 사법 절차에 대해 보다 성찰적인 일반 진술들은 구분되어야 한다. 미국의 올리버 웬델 홈스(Oliver Wendell Holmes)와 카도조(Cardozo), 영국의 맥밀런 경(Lord Macmillan), 래드클리프 경(Lord Radcliffe), 리드 경(Lord Reid)과 같은 저명한 판사들, 그리고 수많은 학계 및 실무계 법률가들은, 법이 완전히 규율하지 못한 사건들이 존재하며, 이때 판사는 간극적(interstitial)이지만 피할 수 없는 법 창출적 임무를 수행해야 하며, 법(law)에 의하면 많은 사건들이 어느 쪽으로든 결정될 수 있다는 점을 강하게 주장해 왔다.

하나의 핵심적 고려사항은, 판사가 때때로 법을 창출하면서 동시에 적용한다는 주장에 대한 저항을 설명해 줄 뿐만 아니라, 사법적 법창출(judicial law-making)과 입법기관의 법창출 간의 주요한 차이를 밝히는 데 도움을 준다. 그것은 다음과 같은 점에 있다. 즉, 법원이 법적으로 규율되지 않은 사건을 판결할 때, 비록 그것이 새로운 법(new law)이라고(is) 하더라도, 그들이 만드는 새 법이 기존 법에서 이미 기반을 두고 있는 원칙들(principles)이나 그 기초가 되는 이유들(reasons)과 조화를 이루도록 하기 위해, 판례법의 방식인 유추(analogy)를 통해 진행하는 경향을 중요시한다는 것이다. 실제로, 특정한 성문법(statutes)이나 판례(precedents)가 불확실하거나(indeterminate), 명시적 법(explicit law)이 침묵하고 있을 경우, 판사들은 단지 법전을 덮고 무제한의 입법권을 행사하는 것이 아니다. 종종 판사는, 그러한 판결에서, 기존 법의 상당 부분이 구현하거나

증진한다고 이해될 수 있는 어떤 일반 원칙이나 목표(purpose)를 인용하며, 그것이 당해 난해한 사건(hard case)에 대해 명확한 해답을 제시한다고 본다. 이는 드워킨(Dworkin)의 판결이론(adjudication theory)에서 매우 두드러지게 나타나는 구성적 해석(constructive interpretation)의 핵심(nucleus)이다. 그러나 이러한 절차는 법 창출의 순간을 유예(defers)할 뿐, 제거(eliminate)하지는 못한다. 왜냐하면 어떤 난해한 사건에서도 서로 경쟁하는 유추(competing analogies)를 뒷받침하는 서로 다른 원칙들이 제시될 수 있으며, 판사는 그러한 원칙들 중에서 선택해야 하기 때문이다. 이때 그는, 이미 법에 의해 자신에게 우선순위가 정해진 기준이 부여되지 않은 상황에서, 양심적인 입법자(conscientious legislator)처럼 자신의 판단에 따라 최선이라고 여기는 기준을 의존하게 된다. 오직 모든 난해한 사건에서, 경쟁하는 하위 원칙들(lower-order principles) 사이의 상대적 무게나 우선순위를 배정해 주는 어떤 고차원 원칙의 독자적 집합(unique set of higher-order principles)이 기존 법 안에 항상 존재한다면, 그때에만 판사의 법 창출의 순간은 단순한 유예가 아닌 완전한 제거가 가능할 것이다.

드워킨이 제기하는 나의 사법 재량 설명에 대한 다른 비판들은, 그것이 기술적(descriptive)으로 잘못되었다기보다는, 비민주적이며 부정의하다(unjust)는 이유로 그것을 승인(endorse)한 점을 문제 삼는다⁷⁵. 판사들은 대개 선거를 통해 선출되지 않으며, 민주주의 사회에서는 오직 국민에 의해 선출된 대표자들만이 법 창출 권한을 가져야 한다는 주장이 제기된다. 이에 대한 반론은 여러 가지가 있다. 첫째, 법(the law)이 규율하지 못하는 분쟁들을 해결하기 위해 판사에게 법 창출 권한을 부여하는 것은, 이를 입법부에 회부하거나 다른 수단을 사용하는 데서 발생할 수 있는 불편함을 피하기 위해 지불해야 하는 불가피한 대가로 간주될 수 있으며, 만약 판사의 권한 행사가 제약을 받으며, 광범위한 법전이나 제도 개혁을 수립할 수 없고, 특정 사건에 의해 제기된 쟁점에만 한정되는 규칙(rule)만을 만들 수 있다면, 그 대가는 크지 않다고 볼 수 있다. 둘째, 행정부에 제한된 입법권을 위임하는 것은 현대 민주주의에서 익숙한 특징이며, 이러한 위임이 사법부에 이뤄진다고 해서 민주주의에 대한 더 큰 위협이 된다고 보긴 어렵다. 이 두 형태의 위임 모두에서, 선출된 입법기관은 보통 잔여적 통제권

⁷⁵[TRS 84-85면.]

(residual control)을 보유하며, 받아들일 수 없는 하위 법률(subordinate laws)을 폐지하거나 수정할 수 있다. 물론 미국과 같이 입법기관의 권한이 성문헌법(written constitution)에 의해 제한되고 법원이 광범위한 사법심사 권한(powers of review)을 가진 경우, 민주적으로 선출된 입법기관(democratically elected legislature)조차도 사법적 입법을 뒤집지 못하는 상황에 처할 수 있다. 이 경우, 궁극적인 민주적 통제는 헌법 개정이라는 번거로운 장치(cumbrous machinery)를 통해서만 확보될 수 있으며, 이는 정부에 대한 법적 제약을 인정함으로써 지불해야 하는 대가이다.

드워킨은 더 나아가 사법적 입법(judicial law-making)은 부정의하다고 주장하며, 그것이 소급적(ex post facto) 입법의 한 형태라는 점에서 비난받아야 한다고 말한다. 소급적 입법이 일반적으로 부정의하다고 간주되는 이유는, 행위자가 자신이 행위를 할 당시 당해 법(the law)의 알려진 상태에 따라 법적 결과가 결정될 것이라고 정당하게 기대하였던 기대(expectations)를 저버리기 때문이다. 그러나 이러한 반론은, 확립된 법이 분명히 존재하는 경우에 그러한 법을 뒤집거나 변경하는 사법적 판단에 대해서는 어느 정도 타당할 수 있겠지만, 애초에 법이 불완전하게 규율하고 있던 난해한 사건에서는 적용될 수 없다. 왜냐하면 그러한 경우에는 명확하고 확립된 법의 상태가 존재하지 않으므로, 정당한 기대를 형성할 수 없기 때문이다.

POSTSCRIPT 주석

Page 272. [이 절의 대체 시작문이 여기에 포함되어 있으며, 폐기되지 않음.]

드워킨(Dworkin)은 오랜 시간에 걸친 판결(adjudication)에 관한 저술 전반에서, 법원이 기존의 법에 의해 불완전하게 규율된 사안을 결정할 법 창출적 권한(law-creating power)을 가지는 재량(discretion)을 갖고 있다는 것을 부인하는 입장을 한결같이 견지해 왔다. 실제로 그는, 사소한 예외를 제외하면 그러한 사안은 존재하지 않으며, 모든 실질적인 법적 문제에는 항상 단 하나의 '정답(right answer)'이 존재한다고 주장하였다.

76

그러나 이러한 불변하는 듯한 입장에도 불구하고, 드워킨이 후기에 해석적 개념(interpretive ideas)을 자신의 법이론에 도입하고, 모든 법적 명제(propositions of law)가 그가 특수한 의미로 정의한 '해석적'이라는 주장에 따라, 이 입장은 실질적으로는 나의 입장과 매우 가까워졌다고 볼 수 있다. 이는 법원이 실제로 법 창출적 재량(law-creating discretion)을 갖고 있으며 자주 이를 행사한다는 점을 인정하게 된 것이기 때문이다. 라즈(Raz)는 이 점을 최초로 명확히 하였다⁷⁷. 해석 개념이 도입되기 이전에는, 드워킨의 재량 부정과 '정답' 존재에 대한 주장이 판사의 역할을 기존법을 식별하고 집행하는 것(*discern and enforce existing law*)으로 제한한 바, 나의 입장(법원이 법 창출적 재량을 행사함)과 날카롭게 충돌했다. 그러나 이러한 초기 구상은, 물론 나의 주장과 명확히 대립하지만, 더 이상 이 절에서 등장하지 않는다.

[섹션 6의 대체 시작문의 텍스트는 여기에서 끝난다.]

POSTSCRIPT 제3판 주석

이것은 아마도 Postscript를 주제로 단독 저서가 출간된 유일한 사례일 것이다:

⁷⁶[그의 글 'No Right Answer?' in P. M. S. Hacker and J. Raz (eds.), *Law, Morality and Society* (1977), pp. 58-84. 개정 후 재수록: 'Is There Really No Right Answer in Hard Cases?' AMP, 제5장 참조.]

⁷⁷[J. Raz, 'Dworkin: A New Link in the Chain', 74 *California Law Review*, 1103 (1986), pp. 1110, 1115-16 참조.]

Jules Coleman 역음, *Hart's Postscript*. 수록된 에세이들은 Postscript뿐만 아니라 하트의 법이론 전반을 이해하는 데 매우 유익하다. 또한, Ronald Dworkin, "Hart's Postscript and the Character of Political Philosophy" (*Oxford Journal of Legal Studies* 제 24권, 2004년, 1면)을 참조하라.